

LUIZ GUILHERME MARINONI
SÉRGIO CRUZ ARENHART

COMENTÁRIOS
AO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL VI

ARTIGOS 369 AO 380

LUIZ GUILHERME MARINONI

DIRETOR

SÉRGIO CRUZ ARENHART

DANIEL MITIDIERO

COORDENADORES

2ª edição revista e atualizada

THOMSON REUTERS

REVISTA DOS
TRIBUNAIS

2019 - 08 - 26

Comentários ao CPC - v. VI - Marinoni - Ed. 2018

EXPEDIENTE

Expediente

Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais **Juliana Mayumi Ono**

Editorial: Andréia Regina Schneider Nunes, Cristiane Gonzalez Basile de Faria, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo, Marcella Pâmela da Costa Silva e Thiago César Gonçalves de Souza

Analista Editorial: Karolina de Albuquerque Araújo

Assistente Editorial: Francisca Lucélia Carvalho de Sena

Produção Editorial

Coordenação

Iviê A. M. Loureiro Gomes

Líder Técnica de Qualidade Editorial: Maria Angélica Leite

Analista de Projetos: Larissa Gonçalves de Moura

Analistas de Operações Editoriais: Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Felipe Augusto da Costa Souza, Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos, Maria Eduarda Silva Rocha, Mayara Macioni Pinto, Patrícia Melhado Navarra, Rafaella Araujo Akiyama e Thaís Rodrigues Sampaio

Analistas de Qualidade Editorial: Carina Xavier e Daniela Medeiros Gonçalves Melo

Estagiários: Angélica Andrade, Miriam da Costa Leite, Nicolas Eugênio Almeida Bueno e Sthefany Moreira Barros

Capa: Chrisley Figueiredo

Adaptação da Capa: Linotec

Projeto Gráfico: Carla Lemos

Equipe de Conteúdo Digital

Coordenação

Marcello Antonio Mastrorosa Pedro

Analistas: Ana Paula Cavalcanti, Jonatan Souza, Luciano Guimarães e Rafael Ribeiro

Administrativo e Produção Gráfica

Coordenação

Mauricio Alves Monte

2019 - 08 - 26

Comentários ao CPC - v. VI - Marinoni - Ed. 2018

SOBRE OS AUTORES

Sobre os Autores

Luiz Guilherme Marinoni

Professor Titular de Direito Processual Civil – *com defesa de tese* – na UFPR. Pós-Doutorado na Universidade Estatal de Milão e na *Columbia University*. Tem dezessete livros publicados na América Latina e na Europa e mais de trinta livros publicados no Brasil. Diretor das Revistas *Iberoamericana de Derecho Procesal* e de Processo Comparado – ambas publicadas pela Ed. Revista dos Tribunais. Diretor do Instituto Iberoamericano de *Derecho Procesal*. Membro do Conselho da *International Association of Procedural Law*. Recebeu o Prêmio Jabuti em 2010 e foi indicado ao mesmo prêmio em diversas outras ocasiões. Ex-Procurador da República. Ex-Presidente da OAB-Paraná. Advogado e parecerista, com intensa atuação nos Tribunais e nas Cortes Supremas. Recebeu o Prêmio Jabuti em 2017.

Sérgio Cruz Arenhart

Pós-Doutorado pela Università degli Studi di Firenze. Doutor e Mestre em Direito pela Federal do Paraná – UFPR. Professor Associado de Direito Processual Civil nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná – UFPR. Publicou mais de 20 livros – um deles no exterior – e diversos artigos em revistas especializadas. Foi o mais jovem Juiz Federal do Brasil e atualmente é Procurador Regional da República na 4.^a Região, tendo ingressado no Ministério Público Federal mediante concurso nacional aprovado em 1.^o lugar. Recebeu o Prêmio Jabuti em 2017.

© desta edição [2018]

Apresentação

Desde a formação da ciência jurídica como a conhecemos, a prática do direito orientou-se pela doutrina formada em torno de textos dotados de autoridade – primeiro com a Glosa e logo em seguida com os Comentários. Esse hábito de argumentar invocando a *communis opinio doctorum* é particularmente tão arraigado na tradição luso-brasileira que a glosa de Accursio e opinião de Bartolus constituíam fonte subsidiária do direito nas Ordenações Afonsinas e Manuelinas, tendo inclusive mantido esse mesmo patamar nas Ordenações Filipinas – com a única diferença de que a glosa de Accursio e a opinião de Bartolus não poderiam ser contrárias à *communis opinio doctorum* para então figurarem como fonte do direito.

Nesse cenário, em que se refletem as mais fundas raízes da cultura jurídica brasileira, é natural que os Comentários tenham tido grande proeminência na conformação da prática do direito brasileiro. Especialmente no campo do processo civil, não só o Código de 1939 despertou a atenção para a redação de textos com intenção sistemática, mas também o Código de 1973 experimentou idêntico interesse.

Atenta à tradição – e ao mesmo tempo ciente de seu compromisso em renová-la à luz das necessidades atuais – a Editora Revista dos Tribunais/Thomson Reuters organizou não só duas coleções de Comentários ao Código de 1973 (a primeira organizada por Sérgio Bermudes e a segunda por Ovídio Baptista da Silva), mas igualmente se preocupou em convidar-nos para coordenar estes Comentários, os primeiros a constituírem uma coleção completa entregue à cultura jurídica nacional a respeito do Código de 2015. A fim de que o seu conteúdo pudesse espelhar os diferentes fios que se entrelaçam para dar sustentação ao processo civil brasileiro, a coleção é composta de autores do mais alto nível de formação acadêmica, atuantes em diferentes segmentos da prática jurídica e pertencentes a todos os quadrantes do nosso país.

Estes Comentários estão voltados a todos aqueles que trabalham diariamente com o Código de Processo Civil. É por essa razão que é uma grande alegria apresentar esta coleção de Comentários ao Código de Processo Civil de 2015, ao mesmo tempo em que agradecemos a confiança depositada pela Editora em nosso trabalho, pelos nossos coautores em nossa capacidade de levar adiante o projeto e pelo público interessado em torná-los seus instrumentos de trabalho. Enredar-se na tradição a fim de torná-la sempre viva e comprometida com a prática do direito é motivo de enorme felicidade para nós – ainda mais quando o seu objeto é o processo civil, ramo das leis mais rente à vida, sem o qual a tutela dos direitos não passa de uma mal-acabada impressão.

Luiz Guilherme Marinoni

Sérgio Cruz Arenhart

Daniel Mitidiero

SUMÁRIO

PARTE 1 - A técnica de cognição, a verdade e o conceito de prova

1. Primeiras considerações
2. As relações entre verdade e prova
3. A natureza das regras sobre prova
4. Objeto da prova
5. Fases do procedimento probatório
6. Prova direta, prova indireta, indícios e presunções
7. A prova na ação inibitória
8. A questão da impossib. do reexame da prova diante do REsp e RE
9. Negócios processuais em matéria de prova
10. A conduta processual dos sujeitos como meio de prova

PARTE 2 - Parte especial do CPC/15

LIVRO I - DO PROCESSO DE CONHEC. E DO CUMPRIM. DE SENTENÇA

TÍTULO I - Do Procedimento Comum [Art. 318 a 512]

[...]

CAPÍTULO XII - Das Provas [arts. 369 a 380]

Comentários ao CPC - v. VI - Marinoni - Ed. 2018

PARTE I

A TÉCNICA DA COGNIÇÃO A VERDADE E O CONCEITO DE PROVA. PARTE I

1. Primeiras considerações

O tema da prova é um dos mais difíceis na área do direito. Isso porque é matéria com nítidos e inseparáveis contornos multidisciplinares, envolve a necessária análise de aspectos não apenas jurídicos, mas também filosóficos, psicológicos e sociológicos, cada qual com seus diferentes métodos e particulares princípios.

Por isso, nenhum exame do tema – ainda que inserto em obra que pretenda apenas realizar comentários sobre as previsões contidas em diploma normativo – pode dispensar breve incursão sobre alguns conceitos básicos operacionais. Tais premissas são imprescindíveis não apenas para conferir ao leitor a ideia da ótica em que se pretende trabalhar o tema, como também para fixar alguns elementos, sem os quais não se poderá compreender adequadamente a extensão e a direção das teses sustentadas.

Assim, a primeira parte destes comentários destina-se à abordagem de algumas questões prévias ao exame dos dispositivos do Código de Processo Civil. São analisadas, inicialmente, as relações do sujeito que conhece com o objeto do conhecimento, tratando-se, basicamente, de algumas ponderações a respeito da verdade e da finalidade da prova. A seguir, tenta-se imprimir um conceito de prova que possa servir como parâmetro para o exame da matéria de direito positivado. Após, reservou-se um espaço para o exame de alguns elementos que encontram lugar ideal para tratamento não no corpo dos comentários aos artigos do Código, mas em posição inicial, extravagantes que são em relação à matéria típica da legislação processual. Fixados tais conceitos elementares – úteis a quem pretenda ter visão ampla do tema, com uma verticalização da compreensão –, passa-se ao exame específico dos dispositivos legais inseridos no Código de Processo Civil.

Estes comentários objetivam analisar problemas que repercutem no dia-a-dia do aplicador do direito. Assim, pouca atenção foi dada ao desenvolvimento histórico dos institutos abordados ou ainda às teorias que se formaram, na evolução da ciência jurídica, sobre cada um dos elementos estudados. O ponto central de preocupação foi, sempre, atender às necessidades dos operadores jurídicos, tentando, ao máximo, transitar pelos possíveis problemas que poderiam surgir na aplicação de cada regra jurídica. Sem dúvida alguma, muitas questões podem ter passado em branco – até porque a previsibilidade não é, de forma alguma, algo típico do fenômeno jurídico. Porém, considerados os conceitos apresentados na parte introdutória, talvez as questões inusitadas possam ser razoavelmente suplantadas.

2. As relações entre verdade e prova

2.1. A verdade como o pressuposto para a prova

A todo aquele que acudir a preocupação com o tema da prova no processo, virá à mente a questão da função da prova. Intuitivamente, vem de pronto a ideia de que pela prova se busca investigar a verdade dos fatos ocorridos, sobre os quais se aporá a regra jurídica abstrata, que deverá reger certa situação.

Semelhante preocupação, com efeito, é absolutamente normal para qualquer pessoa que se veja na incumbência de estudar o direito processual. Não há dúvida de que a função do fato (e,

portanto, da prova) no processo é absolutamente essencial, razão mesmo para que a investigação dos fatos, no processo de conhecimento, ocupe quase que a totalidade do procedimento e das regras que disciplinam o tema no Código de Processo Civil brasileiro.¹ Se é pressuposto para a aplicação do direito o conhecimento dos fatos,² e se, para o perfeito cumprimento dos escopos da Jurisdição é necessária a correta incidência do direito aos fatos ocorridos, tem-se como lógica a atenção redobrada que merece a análise fática no processo.

Não é por outra razão que um dos princípios mais fundamentais do processo civil é o da verdade substancial. No dizer de Mittermayer, a verdade é a concordância entre um fato ocorrido na realidade sensível e a ideia que fazemos dele.³ Esta visão, típica de uma filosofia vinculada ao paradigma do ser,⁴ embora tenha todos os seus pressupostos já superados pela filosofia moderna, ainda continua a guiar os estudos da maioria dos processualistas modernos. Estes ainda se preocupam em saber se o fato reconstruído no processo é o mesmo ocorrido no mundo físico, ou seja, se a ideia do fato que se obtém no processo guarda consonância com o fato ocorrido no passado (correspondência).

A descoberta da verdade, na perspectiva acima descrita, sempre exerceu um papel crucial para o processo e para sua ideologia. Na realidade, ela é tida como um dos objetivos, senão o principal, do processo. Através do processo (especialmente o de conhecimento), o juiz descobre a verdade sobre os fatos, aplicando, então, a estes fatos a norma apropriada. O chamado “juízo de subsunção” nada mais representa do que esta ideia: tomar o fato ocorrido no mundo físico e, a ele, aplicar a regra abstrata e hipotética prevista no ordenamento jurídico. A propósito, Liebman, ao conceituar o termo “julgar”, assevera que tal consiste em valorar determinado fato ocorrido no passado, valoração esta feita com base no direito vigente, determinando, como consequência, a norma concreta que regerá o caso.⁵

Esse esquema, como é evidente, põe a salvo a imparcialidade do juiz e, em particular, legitima um modelo de atuação de direito que supõe a separação entre a criação da norma e a sua imposição. Isso representou pedra fundamental para erigir-se toda a teoria jurídica dos séculos pretéritos, especialmente calcada na premissa de que a legitimação do Direito só pode advir da fonte primeira de suas regras: o legislativo, eleito pelo povo.

De fato, considerando que, sob essa perspectiva, ao Judiciário cumpre aplicar o direito objetivo aos casos concretos – aplicando, em síntese, a ideia de Kelsen, de que dado um certo fato deve ser a respectiva consequência –, parece ser de uma evidência solar constatar ser imprescindível a reconstrução de tais fatos, a fim de que a hipótese prevista na norma seja adequadamente aplicada.⁶ Cumpre lembrar Carnelutti, o qual, após declarar que o processo é um trabalho, assevera que “aquilo que é necessário saber, antes de mais nada, é que o trabalho é união do homo com a res, sendo que esta coisa vimos estar em torno de um homo: que o homo iudicans trabalhe sobre o homo iudicandus significa, no fundo, que deve unir-se com ele; somente através da união ele conseguirá saber como se passaram as coisas (come sono andate le cose) e como deveriam passar-se, a sua história e o seu valor; em uma palavra a sua verdade”.⁷ Eis a razão pela qual se tem a verdade material (ou substancial) como escopo básico da atividade jurisdicional. Como dizem Taruffo e Micheli, no processo a verdade não constitui um fim em si mesma, contudo insta buscá-la enquanto condição para que se dê qualidade à justiça ofertada pelo Estado.⁸

Ainda que hoje se considere superada essa forma de encarar o Direito, não há dúvida que o mito da verdade ainda representa importante fonte legitimadora para o processo.

Por isso, e diante desta necessidade de se saber como “sono andate le cose”, decorre o destaque que se dá ao processo de conhecimento. Ainda que com um valor essencial meramente simbólico,⁹ o conforto desse esquema de atuação permanece basilar para a sociedade.

Sob outro vértice, seria impensável o direito processual sem sua mais nobre função: um processo destinado à “descoberta” dos fatos sobre os quais o Estado é chamado a manifestar-se. É neste campo que o juiz conhece os fatos e aplica a eles a norma correspondente, seguindo o milenar brocardo “narra mihi factum, dabo tibi ius”. Daí todo o fundamento da atividade

probatória do juiz, bem assim de todo o procedimento – que se torna a sucessão de atos, previstos legalmente, a fim de legitimar a forma da busca da verdade na atividade investigatória do juiz.

2.2. Pressupostos do princípio da verdade substancial

A verdade, pois, sempre foi fator de legitimação para o direito processual. Ora, sob a suposição de que as decisões judiciais nada mais são do que a aplicação objetiva do direito positivo – em tese, derivado da vontade popular, já que emanado de representantes do povo – a fatos pretéritos rigorosamente reconstruídos, conclui-se que a atividade jurisdicional atende aos anseios populares, já que não haveria, sob esta perspectiva, nenhuma influência do arbítrio do juiz ou de outra força externa qualquer. Sob essa ótica, o juiz chega mesmo a ser concebido como algo anímico (quase uma máquina), cuja função é, tão somente, concretizar o direito abstrato para a situação específica.¹⁰ O raciocínio, de nítidos ares iluministas e liberais, e cristalizado na célebre ideia de Montesquieu de que o juiz não é mais que a “bouche de la loi” (a boca da lei), tinha definida função no período das Revoluções do Século XIX: visava a proteção do interesse da coletividade contra os abusos da aristocracia (que dominava o Judiciário e o Executivo da época).¹¹ A ideia era a de que, ficando o juiz cingido a verificar os fatos ocorridos, aplicando a eles um direito pré-estabelecido (fruto de elaboração pelo Legislativo, função do Estado que realmente representava os interesses da população) a atuação jurisdicional jamais poderia ser ilegítima, na medida em que o juiz não seria mais do que um executor das diretrizes do Legislativo.¹²

Ora, vista a jurisdição como a atividade do Estado responsável pela justa composição da lide, ou pela atuação da vontade concreta do direito, conclui-se facilmente que esse papel se liga a uma atividade secundária, que não se confunde com a criação do Direito.

Ligados à ideia de “busca da verdade material”, estão diversos dos mais importantes institutos do direito processual. O principal deles, sem dúvida, é a prova. Apenas a título exemplificativo, observe-se que Lent, ao conceituar prova, tonifica sua função de convencimento do juiz a respeito da verdade ou falsidade de uma afirmação.¹³

Outro instituto de grande relevância, que teve sua função intrinsecamente ligada à ideia de verdade é a coisa julgada. Até a Idade Média, partindo-se de uma lição de Ulpiano (D. 1.5.25) a natureza jurídica da coisa julgada era fundada na presunção da verdade sobre os fatos versados na sentença. A escolástica via na verdade o objetivo básico do processo; esta era a premissa menor do silogismo (fato) a ser aplicada à premissa maior (matéria de direito) a fim de chegar-se à conclusão (decisão).¹⁴

Realmente, seria difícil, sob essa perspectiva, legitimar as decisões judiciais se estas não tivessem como pressuposto a reconstrução dos fatos sobre os quais ela incide. Afinal, como fazer o povo crer que tais decisões são legítimas se – mesmo tendo como pressuposto de que a norma é legítima – a hipótese sobre a qual incide a norma não se configura no mundo real.

Aí está a raiz de toda a relevância, para a doutrina processual, da verdade substancial. Eis a função primordial do processo: conhecer (cognoscere); e esta é a matriz legitimante de toda a atividade jurisdicional.

Esta influência da descoberta da verdade substancial sobre o direito processual (o que se evidencia, ainda com maior força, no direito processual penal) já se nota nas primeiras manifestações deste ramo do direito.

Em Roma, como é notório, o iudex poderia abster-se de decidir a questão que lhe era posta bastando declarar, sob juramento, sibi non liquere.¹⁵ Vê-se aí, claramente, o culto à verdade, a ponto de se negar a prestação jurisdicional, sob argumento de que o juiz não logrará atingi-la no processo, ou, por outras palavras, porque os fatos não estavam suficientemente aclarados.¹⁶

Semelhante papel é hoje desempenhado pelo regime do ônus da prova em alguns sistemas. Sob a afirmativa de que aquele a quem incumbia a prova dos fatos alegados não cumpriu satisfatoriamente tal missão, o juiz pode abster-se de julgar o mérito da causa. Assim, por exemplo,

a disciplina dada ao tema na tutela dos direitos coletivos, como se infere de dispositivos do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor.¹⁷ Neste diploma, estabelece-se um regime todo particular para a coisa julgada que já vem sendo adotada em outras legislações, e mesmo em outras áreas do direito pátrio. Trata-se da assim chamada “coisa julgada secundum eventum litis”; caso a demanda seja julgada improcedente por insuficiência de provas, não incide sobre a declaração contida nesta sentença coisa julgada material, podendo a mesma ação ser promovida novamente (sob o mesmo fundamento) instruída com novas provas. Ora, a intenção desta disciplina é óbvia. Ao obstar a incidência de coisa julgada material quando o juiz entender por rejeitar a demanda por ausência de provas (caso em que, portanto, não haveria completa análise de mérito), autoriza-se o juiz a aplicar a velha cláusula romana do *non liquet*, podendo a parte, então, propor novamente a mesma ação. Novamente, vê-se a presença marcante da opção pela busca da verdade substancial.

O mesmo ocorre com a tendência da doutrina mais atual de permitir ao juiz uma posição ativa na colheita da prova. Busca-se ampliar os poderes do juiz na instrução da causa, sob a bandeira de que o processo é instrumento público e que deve buscar a verdade sobre os fatos investigados.¹⁸ Ao se permitir que o juiz possa determinar, de ofício, a produção de provas – suprimindo, pois, a atividade que competiria primariamente às partes – novamente pretende-se dar ênfase à busca da verdade substancial, trazida como verdadeiro dogma para o direito processual.

Tal visão, com efeito, é ainda mais salientada no direito processual penal. Lá, como é cediço, a posição ativa do juiz na produção da prova, aliada à possibilidade do reconhecimento de insuficiência de provas (art. 386, VI, do Código de Processo Penal) é tema pacificado na doutrina e na jurisprudência.¹⁹

2.3. Verdade substancial e verdade formal

Durante algum tempo, a doutrina processual tentou distinguir a forma pela qual o processo civil e o penal lidavam com o tema da verdade. Sustentava-se que o processo penal trabalharia com a verdade substancial, ao passo que o processo civil deveria satisfazer-se com a verdade formal. A distinção vem bem posta por Arruda Alvim, que leciona que a verdade formal, ao contrário da substancial, é aquela refletida no processo, e juridicamente apta a sustentar a decisão judicial.²⁰ Diversamente da noção de verdade substancial, aqui não há aquela necessidade de identificação absoluta do conceito extraído com a essência do objeto. O conceito de verdade formal identifica-se muito mais com uma “ficção” da verdade. Obedecidas as regras do ônus da prova e decorrida a fase instrutória da ação, cumpre ao juiz ter a reconstrução histórica promovida no processo como completa, considerando o resultado obtido como verdade – mesmo que saiba que tal produto está longe de representar a verdade sobre o caso em exame. Com efeito, as diversas regras existentes no Código de Processo Civil tendentes a disciplinar formalidades para a colheita das provas, as inúmeras presunções concebidas a priori pelo legislador e o sempre presente temor de que o objeto reconstruído no processo não se identifique plenamente com os acontecimentos verificados in concreto induzem a doutrina a buscar satisfazer-se com outra “categoria de verdade”, menos exigente que a verdade substancial.²¹

Parte-se da premissa de que o processo civil, por lidar com bens menos relevantes que o processo penal, pode contentar-se com menor grau de segurança, satisfazendo-se com um grau de certeza menor. Seguindo esta tendência, a doutrina do processo civil – ainda hoje muito em voga²² – passou a dar mais relevo à observância de certos requisitos legais da pesquisa probatória (através da qual a comprovação do fato era obtida), do que ao conteúdo do material de prova. Passou a interessar mais a forma que representava a verdade do fato do que se este produto final efetivamente representava a verdade. Mas ainda assim, reconhecia-se a possibilidade de obtenção de algo que representasse a verdade – apenas ressalvava-se que o processo civil não estava disposto a pagar o alto custo desta obtenção, bastando, portanto, algo que fosse considerado juridicamente verdadeiro. Era uma questão de relação custo-benefício: entre a necessidade de decidir rapidamente e decidir com segurança, a doutrina do processo civil optou pela preponderância da primeira.

Atualmente, a distinção entre verdade formal e substancial perdeu seu brilho. A doutrina

moderna do direito processual vem sistematicamente rechaçando esta diferenciação, corretamente considerando que os interesses objeto da relação jurídica processual penal não têm particularidade nenhuma que autorize a inferência de que se deve aplicar a estes método de reconstrução dos fatos diverso daquele adotado pelo processo civil. Realmente, se o processo penal lida com a liberdade do indivíduo, não se pode esquecer que o processo civil labora também com interesses fundamentais da pessoa humana – como a família, a capacidade jurídica do indivíduo e os direitos metaindividuais – pelo que totalmente despropositada a distinção da cognição entre as áreas.

Além disso, não se pode esquecer que a ideia de verdade formal foi duramente criticada pela pena severa de CHIOVENDA. Como acentuou o autor, “juridicamente a vontade da lei é aquilo que o juiz afirma ser a vontade da lei. Nem esta afirmação do juiz pode chamar-se uma verdade formal: frase que supõe um confronto entre o que o juiz afirma e o que poderia afirmar; o direito não admite esta confrontação, e nós ao buscar a essência de uma instituição jurídica devemos colocar-nos no ponto de vista do direito”.²³ Também Carnelutti ofereceu semelhante crítica à figura, qualificando-a como verdadeira metáfora.²⁴ Realmente, falar-se em verdade formal (especialmente em oposição à verdade substancial) implica reconhecer que a decisão judicial não é calcada na verdade, mas em uma não-verdade. Supõe-se que exista uma verdade mais perfeita (a verdade substancial) mas que, para a decisão no processo civil, deve o juiz contentar-se com aquela imperfeita e, portanto, não condizente com a verdade.²⁵

A ideia de verdade formal é, portanto, absolutamente inconsistente e, por esta mesma razão, foi (e tende a ser cada vez mais) paulatinamente perdendo seu prestígio no seio do processo civil. A doutrina mais moderna nenhuma referência mais faz a este conceito, que não apresenta qualquer utilidade prática, sendo mero argumento retórico a sustentar a posição cômoda do juiz de inércia na reconstrução dos fatos e a frequente dissonância do produto obtido no processo com a realidade fática.

2.4. Verdade e verossimilhança

Da análise já elaborada, pode-se observar que o trato da finalidade da prova e, portanto, da verdade, há de passar, necessariamente, por um estudo mais amplo e aprofundado do tema, que extrapola os limites do direito, lançando miradas sobre outras ciências.²⁶ Em outros termos, a questão da finalidade da prova deve orientar-se pelo estudo do mecanismo que regula o conhecimento humano dos fatos.

Embora toda a teoria processual esteja, conforme já visto, calcada na ideia e no ideal de verdade (como o único caminho que pode conduzir à justiça, na medida em que é o pressuposto para a aplicação da lei ao caso concreto) não se pode negar que a intenção de atingir, através do processo, a verdade real sobre determinado acontecimento não passa de mera utopia.

A essência da Verdade (como conceito absoluto) é intangível. Já o dissera Voltaire, ao afirmar que “les vérités historiques ne sont que des probabilités”.²⁷ Assim também percebeu Miguel Reale, ao estudar o problema, propondo o conceito de quase-verdade em substituição ao da verdade, visto que este último seria imprestável, porque inatingível.²⁸

Se assim é para as situações comuns, com maiores matizes isso ocorre no direito processual.

Deveras, a “reconstrução” de um fato ocorrido no passado sempre vem influenciada por aspectos subjetivos das pessoas que assistiram a ele, ou ainda do juiz, que há de valorar a evidência concreta.²⁹ Sempre há uma interpretação formulada sobre tal fato – ou sobre a prova direta dele derivada – que altera o seu real conteúdo, acrescentando-lhe um toque pessoal que distorce a realidade. Mais que isso, o julgador (ou o historiador, ou, enfim, quem quer que deva tentar reconstruir fatos do passado) jamais poderá excluir, terminantemente, a possibilidade de que as coisas possam ter-se passado de outra forma.

Acreditar que o juiz possa analisar, objetivamente, um fato, sem lhe acrescentar qualquer dose de subjetividade, é pura ingenuidade.³⁰ Esta análise, de per se, já envolve certa valoração do fato,

alterando-lhe a substância e inviabilizando o conhecimento do fato objetivo, tal como ocorreu.

Se essa circunstância já limita a apreensão da Verdade, é de se notar que no processo, isso é ainda mais complicado.

Como bem observou Giovanni Verde,³¹ no processo, as regras sobre prova não regulam apenas os meios de que o juiz pode servir-se para “descobrir a verdade”, mas também traçam limites à atividade probatória, tornando inadmissíveis certos meios de prova, resguardando outros interesses (como a intimidade, o silêncio etc.) ou ainda condicionando a eficácia do meio probatório à adoção de certas formalidades (como o uso do instrumento público). Diante desta proteção legal (de forte intensidade) a outros interesses, ou ainda, da submissão do mecanismo de “revelação da verdade” a certos requisitos, parece não ser difícil perceber que o compromisso que o direito tem com a verdade não é tão inexorável como aparenta ser.

Há, realmente, uma contradição neste aspecto, como bem demonstra Sergio Cotta.³² Quer-se um juiz que seja justo e apto a desvendar a essência verdadeira do fato ocorrido no passado, mas se reconhece que a falibilidade humana e o condicionamento desta descoberta às formas legais não o permitem. O juiz não é um ser divino, mas ainda assim tem, como objeto de sua pesquisa, a verdade objetiva – verdade esta que lhe é, assim como a todos os demais, inatingível. Exige-se, portanto, que o juiz seja um deus, capaz de desvendar a verdade velada pela controvérsia das partes – onde cada qual entende estar com a “verdadeira” verdade e, portanto, com a razão.

Todavia, e sem que se precise de maior esforço para atingir esta conclusão, esta obra é impossível, somente se prestando como argumento retórico para justificar a “justiça” da decisão tomada. O juiz é um ser humano como qualquer outro e sujeito, conseqüentemente, a avaliações subjetivas da realidade que o cerca. A figura mítica do juiz, como alguém capaz de descobrir a verdade sobre as coisas e, por isso mesmo, apto a fazer justiça, deve ser desmascarada. Esta fundamentação retórica de toda a doutrina processual não pode mais ter o papel de destaque que ocupa hoje. O juiz não é – mais do que qualquer outro – capaz de reconstruir fatos ocorridos no passado; o máximo que se lhe pode exigir é que a avaliação que há de fazer das provas carreadas aos autos sobre o fato a ser investigado não divirja da opinião comum média que se faria das mesmas provas e que a justificação que ele oferece para essa avaliação seja racional e razoável.

Aliás, a ideia de que o conhecimento se trava a partir da descoberta da realidade é, já, totalmente superada em filosofia. O chamado paradigma do objeto – típico da antiguidade – parte da premissa de que os objetos têm, todos, a sua essência, que é revelada ao sujeito cognoscente, a partir do conhecimento (o sujeito cognoscente nada mais faz do que descobrir aquela essência, preexistente no objeto).³³ Explica Celso Ludwig que, para essa ótica, “‘O ser é, o não-ser não é’. O ser é tido como o fundamento dos entes. O fundamento do mundo. O que não é ser, não é. É o nada. O ser não é pensado, compreendido como um fundamento distante e isolado do mundo. Ao contrário, o ser como fundamento significa que o mundo, os entes, as coisas (tà ónta), os úteis (tà prágmata) são vistos, porque iluminados por ele. Ser e mundo coincidem”.³⁴

Trata-se, claramente, da ideia de correspondência, no sentido de que a verdade só se verifica se houver uma precisa identidade entre a afirmação que se faz do fato e o fato efetivamente ocorrido.

Como se pode observar da história, esta perspectiva vigorou absoluta na filosofia até meados do século XVII. A partir de então, foi substituída por outro paradigma, moldado sob influência das novas ideias racionalistas e iluministas emergentes, denominado de paradigma do sujeito. A partir de então, a relevância está no sujeito cognoscente, e não mais no objeto do conhecimento. Penso, logo existo,³⁵ disse Descartes, sintetizando magnificamente o espírito deste modelo. Os objetos somente existem porque o sujeito pode conhecê-los. Desloca-se, portanto, o núcleo de interesse do objeto para o sujeito, ainda que permaneça a ideia da correspondência, ainda que deslocado o eixo do conhecimento.

Especificamente em relação ao tema da “verdade”, a falibilidade do paradigma do objeto, como noção útil para o direito processual, põe-se a nu por completo. O conceito de Verdade, por ser algo absoluto, somente pode ser atingido quando se tenha por certo de que determinada coisa se

passou de tal forma, excluindo-se, de pronto, qualquer outra possibilidade. E, como é óbvio, esta possibilidade extrapola os limites humanos. Como afirma Carnelutti, “exatamente porque a coisa é uma parte ela é e não é; pode ser comparada a uma medalha sobre cujo anverso está inscrito o seu ser e no verso o seu não ser. Mas para conhecer a verdade da coisa, ou digamos apenas da parte, é necessário conhecer tanto o verso quanto o anverso: uma rosa é uma rosa, ensinava a Francesco, porque não é alguma outra flor; isto quer dizer que para conhecer realmente a rosa, isto é para atingir à verdade, impõe-se conhecer não apenas aquilo que ela é mas também o que ela não é. Por isso a verdade de uma coisa não aparece até que nós possamos conhecer todas as outras coisas e assim não podemos conseguir que um conhecimento parcial. (...) Em suma, a verdade está no todo, não na parte; e o todo é demais para nós. (...) Assim a minha estrada, começada com atribuir ao processo a busca da verdade, conduziu à substituição da verdade pela certeza”.³⁶

De fato, é irresponsável o argumento trazido por Carnelutti. Mesmo as provas mais exatas não têm a aptidão para conduzir seguramente à verdade sobre o fato ocorrido. Apenas mostram elementos capazes de apontar, provavelmente, como o fato ocorreu; são um indicativo, mas que não necessariamente levam à caracterização absoluta do fato, tal como efetivamente ocorreu (ou, ao menos, não se pode dizer que existe segurança absoluta sobre esta conclusão).³⁷ Como disse Wach, “aller Beweis ist richtig verstanden nur Wahrscheinlichkeitsbeweis”.³⁸ E, especificamente sobre a prova mais difundida em nossos dias (a prova testemunhal), lembra Voltaire que “aquele que ouviu dizer a coisa de doze mil testemunhas oculares não tem mais que doze mil probabilidades, iguais a uma forte probabilidade, a qual não é igual à certeza”.³⁹

Tem-se, assim, ser impossível atingir-se a verdade sobre certo evento histórico. Pode-se ter uma elevada probabilidade sobre como o mesmo se passou, mas nunca a certeza da obtenção de verdade.

Se é assim para o conhecimento comum, a situação é exponencialmente mais complexa no campo do processo. Os dois polos do litígio acreditam, em regra, ter razão e suas versões sobre a realidade dos fatos são, comumente, antagônicas.⁴⁰ Sua contribuição para a busca da realidade dos fatos é, muitas vezes, parcial e tendenciosa. As provas geralmente apontam para inúmeras conclusões. E ainda assim, o magistrado é obrigado a elaborar alguma “realidade” para o ocorrido.

Como diz Calamandrei,⁴¹ mesmo para o juiz mais escrupuloso e atento vale o fatal limite de relatividade que é próprio da natureza humana: aquilo que se vê é apenas aquilo que parece ser visto. Não é Verdade, mas verossimilhança, isto é, aparência (que pode ser ilusão) de verdade. O mesmo processualista acrescenta, a propósito do real conceito de verdade, que quando se diz que um fato é verdadeiro, apenas se diz que a consciência de quem emite o juízo atingiu o grau máximo de verossimilhança que, segundo os meios limitados de cognição de que dispõe o sujeito, basta a dar-lhe certeza subjetiva de que tal fato ocorreu.⁴²

Para atingir o conceito de verossimilhança, Calamandrei vale-se da ideia de máxima da experiência. Partindo deste conceito, desenha o autor a noção de que “verossimilhança” é uma ideia que se atinge a partir daquilo que normalmente acontece.⁴³ É esta ilação lógica do usual que permite ao sujeito reconhecer como verossímil algo que, segundo critérios adotados pelo homem médio, prestar-se-iam para adquirir a certeza quanto a certo fato. Assim, “para julgar se um fato é verossímil ou inverossímil, recorramos, sem necessidade de uma direta pesquisa histórica sobre sua concreta verdade, a um critério de ordem geral já adquirido previamente mediante a observação do quod plerumque accidit: já que a experiência nos ensina que fatos daquela específica categoria ocorrem normalmente em circunstâncias similares àquelas que se encontram no caso concreto, decorre desta experiência que também o fato em questão se apresenta com a aparência de ser verdadeiro; e vice-versa conclui-se que algo é inverossímil, quando, mesmo podendo ser verdadeiro, parece porém em contraste com o critério sugerido pela normalidade”.⁴⁴ Por certo – e como também lembrado pelo processualista florentino – esta verossimilhança dependerá de critérios nitidamente subjetivos e variáveis, de acordo com o sujeito cognoscente. Assim o demonstra a verificação de que, a cada dia, fatos que até então eram tidos como inverídicos, passam a assumir – em função da evolução das ciências – ares de possíveis ou mesmo verossímeis.⁴⁵

Por isso mesmo, Sergio Cotta diz que a verdade integral resta sempre latente, o que aponta para a fragilidade da função judicante. A decisão judicial não revela a verdade dos fatos mas apenas impõe, como verdade, certos dados que a decisão toma por pressuposto (chamando-os de verdade, mesmo que ciente de que tais dados não necessariamente confundem-se com a verdade em essência).⁴⁶

Segundo o mesmo autor, há três razões para que a verdade obtida no processo não possa refletir a verdade substancial.⁴⁷ A primeira delas diz com a alienação da consciência do juiz à verdade temporalmente sintética do evento. A segunda é a solidão do juiz no estabelecimento definitivo da verdade. E, finalmente, a impotência final do juiz em restabelecer a “continuidade das pessoas”.

Realmente, o juiz não esteve presente à realização dos fatos; a análise do que ocorreu, portanto, há de passar tanto pela subjetividade das testemunhas que presenciaram o evento, quanto pela do juiz, distorcendo-se com isto duplamente os fatos. Não obstante esses limites, impõe-se ao magistrado “declarar” uma verdade sobre o ocorrido – isso, afinal, é pressuposto para a correta “aplicação” do direito – ainda que todos saibam que essa verdade é intangível e que a cooperação das partes normalmente é parcial e divergente.

Por todo o visto, conclui-se que o mito da verdade substancial tem servido apenas em desprestígio do processo, alongando-o em nome de uma reconstrução precisa dos fatos que é, em síntese, impossível. Por mais laborioso que tenha sido o trabalho e o empenho do juiz no processo, o resultado nunca será mais que um juízo de verossimilhança,⁴⁸ de aparência, que jamais se confunde com a essência da verdade sobre o fato.

Apesar de tudo isso, a doutrina dominante insiste em chamar o resultado obtido na reconstrução fática do processo como verdade, sendo certo que isso é essencial para se manter o mito da subsunção da norma jurídica e, conseqüentemente, da neutralidade do Direito. Ora, caso se admitisse que o juiz poderia aplicar a sanção da norma a um caso em que há ainda dúvida a respeito de ter ou não o fato ocorrido da maneira descrita pelo antecedente da norma, cairia por terra toda a teoria da norma – já que, mesmo não se verificando o antecedente (ou, ao menos, não se tendo certeza de que o mesmo ocorreria) incidiu o conseqüente. O resultado, à evidência, seria catastrófico, já que não mais se poderia legitimar a decisão judicial no ordenamento jurídico (ou na repartição dos poderes), mas apenas na força do Estado.

É certo que ao alterar a coluna de sustentação da teoria da legitimação da decisão judicial, excluindo-se de seu seio a ideia de que o juiz decide apenas baseado na verdade, torna-se necessário buscar esta fundamentação em outro campo. De toda sorte, permanecer cultuando a ilusão de que a decisão judicial está calcada na verdade dos fatos, gerando a falsa impressão de que o juiz se limita, no julgamento, a um simples silogismo, a um juízo de subsunção do fato à norma, é algo que não tem mais o menor cabimento, sendo mito que deve ser contestado. Este mito, de qualquer forma, já está em derrocada, e não é a manutenção da miragem da verdade substancial que conseguirá impedir o naufrágio destas ideias.

Deve-se, portanto, excluir do campo de alcance da atividade jurisdicional a possibilidade da verdade substancial. Jamais o juiz poderá chegar a este ideal. O máximo que permite a sua atividade é chegar a um resultado que se assemelhe à verdade, um conceito aproximativo, baseado muito mais na convicção do juiz de que ali é o ponto mais próximo da verdade que ele pode atingir, do que em algum critério objetivo.

Ainda assim, o conceito de verossimilhança, embora operacional, ainda parece insuficiente para apoiar todas as cogitações a respeito do direito probatório. Como visto, a verossimilhança apresenta-se como uma verdade aproximada, fundada naquilo que regularmente acontece (uma aparência de verdade).⁴⁹ Porém, aquilo que acontece “de ordinário” nem sempre pode ser considerado como o máximo grau de cognição possível diante de uma situação concreta. Embora a verossimilhança corresponda à ideia de normalidade de uma situação, é certo que nem sempre esse juízo de regularidade (quod plerumque accidit) pode ser confundido com o máximo de aproximação de um conceito ideal de verdade que a situação permite.⁵⁰

Poder-se-ia, por isso, justapor ao conceito de verossimilhança o de verdade factível ou de verdade conjectural. Este seria – sem nenhuma pretensão de definitividade ou de vinculação ao paradigma objetivo – o grau máximo de aproximação que se consegue obter diante de uma situação concreta. Permanece este sendo um juízo de aproximação, mas agora correspondente à mais ampla possibilidade possível. Enquanto a verossimilhança representaria a aproximação do conceito de verdade, a “verdade factível” seria a mais próxima representação da verdade que se consegue obter dentro de certas circunstâncias.

Nesse ponto, é necessário extremar esses dois conceitos de outros, que também traduzem certo grau de indeterminabilidade e de juízos cognitivos, e muitas vezes confundidos com os anteriormente expostos. De fato, a indeterminação dos conceitos empregados não pode redundar na imprestabilidade de sua diferenciação, especialmente porque traduzem realidades diversas e pretensões bastante distantes.

Excluído o conceito de verdade material (conceito absoluto), todos os demais conceitos que derivam deste são, meramente, aproximativos e relativos – já que importam uma relação entre o conceito absoluto (verdade substancial) e o outro que se pretende definir.⁵¹

Poder-se-ia dizer que a verdade possível e a verossimilhança implicam uma relação de ordem aproximativa, junto com a ideia de possibilidade e probabilidade, com o conceito ideal de verdade, como faz Calamandrei.⁵² Ainda assim, e como mesmo observado pelo próprio processualista italiano, a linha distintiva entre todos estes conceitos permaneceria imprecisa e tênue, especialmente porque não se pode comparar dois conceitos relativos que apontam para o mesmo conceito absoluto; cada juiz poderá avaliar, de forma diversa, a distância entre cada um destes conceitos e destas ideias.

É preciso, então, buscar algum referencial para a estipulação das diferenças entre tais conceitos, que possa ser objetivamente aferido pelo magistrado no curso do processo. Entra, assim, em cena a necessidade de recorrer-se a novos paradigmas da ciência do conhecimento, que possam auxiliar nesta definição de parâmetros.

2.5. A teoria de Habermas e a verdade

Excluída a possibilidade de obter a verdade substancial no processo, insta buscar um novo objetivo, capaz de se adequar às necessidades da ciência (aí incluído o processo) e às possibilidades da cognição humana. A moderna filosofia, sob a batuta de Jürgen Habermas, compreende que a verdade sobre um fato é um conceito dialético, construído com base na argumentação desenvolvida pelos sujeitos cognoscentes. A “verdade”, sob esse prisma, não se descobre, mas se constrói, através da argumentação.

Certamente não é este o lugar adequado para tratar da questão, de forma aprofundada; porém pela relevância das ideias para a compreensão dos conceitos que se pretende atingir, parece importante tentar um resumo breve, e mesmo superficial, da teoria deste filósofo. Seu pensamento constitui uma tentativa de superação dialética dos demais paradigmas, buscando centrar o ponto de apoio do estudo não mais no objeto ou no sujeito, mas no discurso. A razão não está mais no mundo (paradigma do ser) ou no sujeito individual (paradigma do sujeito), mas naquilo que os sujeitos produzem a partir de certos elementos comuns (linguagem).

O sujeito não é mais visto como conquistador do objeto, tal como ocorria no paradigma do sujeito. Agora, o sujeito deve interagir com os demais sujeitos, a fim de atingir um consenso sobre o que possa significar conhecer o objeto e dominar o objeto;⁵³ não é mais a subjetividade que importa, mas sim a intersubjetividade.

O diálogo (comunicação) passa a ter a preponderância no sistema. Há um retorno à velha ideia aristotélica da tópica e da retórica. A razão centra-se na comunicação e não mais na reflexão isolada de um só sujeito. Este “diálogo”, entretanto, é prévio, necessariamente anterior a qualquer forma de conhecimento. Trata-se da busca de um consenso que permita o conhecimento – e não um consenso a respeito do objeto examinado. É algo que ocorre no mundo ideal, como um a priori,

e não no mundo sensível. Este consenso importa a aceitação prévia dos critérios necessários para a realização de qualquer comunicação (interação). Como explica Habermas, “a razão comunicativa distingue-se da razão prática por não estar adstrita a nenhum ator singular nem a um macrossujeito sociopolítico. O que torna a razão comunicativa possível é o medium linguístico, através do qual as interações se interligam e as formas de vida se estruturam. Tal racionalidade está inscrita no *telos* linguísticos do entendimento, formando um ensemble de condições possibilitadoras e, ao mesmo tempo, limitadoras”.⁵⁴

Segundo Ludwig,⁵⁵ na teoria de Habermas “os sujeitos que se comunicam pela linguagem, apoiam-se necessariamente num consenso que ‘serve de pano de fundo para sua ação comunicativa’. O consenso torna-se manifesto através do reconhecimento recíproco, prévio, de pretensões de validade, pressupostas. São elas: pretensão de compreensibilidade da comunicação, pretensão de verdade do conteúdo, pretensão de correção (de justiça) do conteúdo normativo e pretensão de sinceridade e autenticidade relativas ao mundo subjetivo”. Obviamente, estas pretensões não têm em vista o mundo real, mas o pressupõem. Aplicam-se a momento anterior ao diálogo concreto, que só ocorre porque tais pretensões estão, inexoravelmente, supostas.

A propósito das pretensões de validade da comunicação, leciona Habermas que “o modo fundamental destas manifestações determina-se pelas pretensões de validade que implicitamente levam associadas: a verdade, a retitude, a adequação ou a inteligibilidade (ou correção no uso dos meios de expressão). A estes mesmos modos conduz também uma análise de enfoque semântico das formas de enunciados. As orações descritivas que, no sentido mais lato, servem à constatação de fatos que podem ser asseverados ou negados sob o aspecto da verdade de uma proposição; as orações normativas ou orações de dever que servem à justificação de ações, sob o aspecto da retitude (ou da ‘justiça’) da sua forma de atuar; as orações valorativas (os juízos de valor) que servem à valoração de algo, sob o aspecto da adequação dos standards de valor (ou sob o aspecto do ‘bom’), e as explicações de regras geradoras que servem à explicação de operações tais como falar, classificar, calcular, deduzir, julgar etc., sob o aspecto de inteligibilidade ou correção formal das expressões simbólicas”.⁵⁶

É evidente que, acaso os sujeitos envolvidos no diálogo concreto tivessem em mente que sua fala seria incompreendida pelo outro sujeito, não haveria razão para que ocorresse o diálogo. O mesmo se diga quanto às demais pretensões. Assim, estas pretensões devem ser presumidas em toda a situação de argumentação real. São, pois, momento anterior, que não ocorre de fato, mas que deve ser pressuposto, sob pena de inviabilizar a comunicação.

Ademais, estas pretensões visam à universalização da comunicação hipotética. De fato, atingindo estas pretensões um nível de validade geral, tem-se a universalidade da possibilidade da comunicação. Por outro lado, esta universalidade também é acompanhada da igualdade da comunicação. Estas pretensões impõem aos sujeitos uma igualdade invencível na situação de discurso.

Havendo consenso quanto a estas pretensões, a comunicação espontânea se estabelece. Quando, porém, qualquer destas pretensões é contestada (de modo geral), o consenso é perturbado e a comunicação entra em crise. Ausente a pretensão de compreensibilidade, a questão pode ser resolvida no próprio contexto da interação. Já quanto às pretensões de verdade e de justiça, a superação da contestação apenas pode ser atingida fora da situação, em novo tipo de diálogo – o discurso ou comunicação argumentativa. No discurso, todas as pretensões ficam suspensas, até que a assertiva seja confirmada ou refutada (em discurso teórico) ou até que a norma seja considerada legítima ou ilegítima (através de discurso prático).

Isto implica dizer que verdade e legitimidade não são conceitos absolutos, de validade plena e eterna. Ao contrário, resultam do consenso discursivo. Há deslocamento da formulação da verdade em relação às proposições fáticas e da legitimidade em relação às proposições normativas para a intersubjetividade. A verdade é algo necessariamente provisório, apenas prevalecendo enquanto se verificar o consenso.

Tal, com efeito, é a garantia da universalidade do procedimento. A verdade não mais é buscada

no conteúdo da assertiva, mas na forma pela qual ela é obtida (consenso). O conteúdo é evidentemente importante, mas nada tem que ver com a verdade – pois para esta apenas interessa a forma pela qual a afirmação é obtida. Esta noção de verdadeiro e de falso não se dá a partir das coisas, nem na razão individual, mas no procedimento.

Daí se extrai uma nova consequência: as afirmações (sobre fatos e também sobre regras) devem ser constantemente justificadas e legitimadas, a fim de verificar a manutenção do consenso. Aplicando esta teoria ao direito, leciona Miguel Reale que “segundo este pensador, última e mais alta expressão da Escola de Frankfurt, a razão comunicativa possibilitaria o medium linguístico através do qual as interações se entrelaçam e as formas de vida se estruturam, logrando-se atingir espontaneamente a necessária correlação entre validade e eficácia, essencial ao Direito, numa conexão descentralizada de condições. A revelação das normas jurídicas, enquanto regras obrigatórias, não resultaria de sua subordinação, deontologicamente, a mandamentos morais, ou, axiologicamente, a uma constelação de valores privilegiados, ou, ainda, empiricamente à efetividade de uma norma técnica. Tudo se resolveria, afinal, em função da razão comunicativa, a qual, se não é uma fonte de normas, permite que estas se formem livremente através da vida comunitária sem o ‘mal do normativismo’, que, a seu ver, corre o risco de perder contato com a realidade, e com a vantagem de manter-se aberta a instância do juízo crítico aferidor, sem cuja atuante permanência não haveria real democracia”.⁵⁷ ⁵⁸

Enfim, como bem observa Ludwig,⁵⁹ “a teoria comunicativa, em primeiro lugar, vê o homem desde já como social, dotado de linguagem, sendo esta seu atributo universal, e obrigado a satisfazer suas necessidades, por meio de uma ação, visando o consenso. Em segundo lugar, a ética discursiva é em princípio válida para todos os homens, isto é, as pretensões de validade são universalmente válidas. Não há fronteiras argumentativas. Por fim, Habermas defende a universalidade do princípio, posto que não se limita a expressar os ‘preconceitos dos europeus adultos, burgueses, brancos e do sexo masculino’”.

2.6. Verdade e procedimento

A ideia da interferência do procedimento na avaliação da verdade não é nova. Já o processo germânico antigo era particularizado pelo cuidado na obtenção dos fatos da causa – ainda que, naquele sistema, se privilegiasse a ideia de reconstrução da verdade.⁶⁰

É o procedimento que atribui à “reconstrução” dos fatos sua capacidade de gerar verdade. Já em Aristóteles se encontra a verdadeira semente desta ideia (não, obviamente, com a formulação dada pelo direito germânico antigo). Para ele, a busca do conhecimento verdadeiro apenas se daria pela via da dialética.⁶¹ O objeto do conhecimento deveria ser debatido pelos sujeitos – cada qual, presumivelmente, com parcela do conhecimento – logrando-se, assim, aperfeiçoar a verdade de cada qual sobre o objeto. A dialética aristotélica é, então, uma busca, uma tentativa de aproximação da verdade.⁶²

A filosofia moderna denomina de “ordem isonômica” a técnica probatória baseada na dialética e no debate sobre os argumentos de prova. Como ensina Alessandro Giuliani, “a possibilidade mesma da verdade prática depende de uma tal ordem, que realiza a cooperação involuntária entre os participantes de uma discussão jurídica, filosófica, política. Uma tal ordem, portanto: a) não é pré-constituída, como no caso de um sistema; b) não é espontânea no sentido de que se realiza automaticamente no conflito entre as partes. A procura da ordem isonômica deve, portanto, evitar, de um lado, a tentação da demonstração científica e, do outro lado, a degeneração da violência verbal. Sob este aspecto a dialética aristotélica pode ser considerada a lógica da ordem isonômica”.⁶³

Parte-se, dentro desta concepção, de três premissas essenciais⁶⁴ – que confrontam, em linhas gerais, com os princípios adotados pela ordem assimétrica, empregada em regras nos modelos processuais atuais. Inicialmente, rejeita-se a controvérsia erística como fenômeno útil para a solução da verdade prática; não é a polêmica, a luta (verbal ou física) ou o conflito que permite a descoberta ou a construção da verdade. De outra parte, é essencial que a dialética da ordem isonômica parta, necessariamente, da prévia isonomia entre os debatedores, aí incluídas as partes

e o juiz. Finalmente, desconsidera-se a influência da lógica matemática (pitagórica) na avaliação da verdade.

Partindo-se desta lógica, tem-se uma construção da verdade, legitimada pelo procedimento adotado, que deve ser o de uma argumentação em colaboração (não em conflitualidade).⁶⁵ As versões parciais apresentadas pelas partes somam-se ao papel ativo do juiz, em perfeito diálogo, na tentativa de construir (e não descobrir) uma verdade possível que guiará a aplicação da lei ao caso submetido ao Judiciário. Assume, então, relevante papel dentro desta ordem a noção e a extensão do contraditório. É este elemento a válvula reguladora que permitirá estabelecer o nível da argumentação dialética e, conseqüentemente, da legitimação da construção da verdade.

Dentro deste paradigma, todo o conhecimento se trava na relação inter-subjetiva. É a interferência entre os sujeitos que permite o conhecimento (ou mesmo, poder-se-ia dizer a elaboração) dos fatos.⁶⁶ Por isso, o processo deixa de ser instrumento para a reconstrução dos fatos (e futura aplicação da norma respectiva) para ser palco de argumentação. Vinga, novamente, a noção aristotélica da retórica e da tópica. A verdade é aquilo que o consenso do grupo diz que é, embasado este em posições de verossimilhança, de verdade factível e de diálogo argumentativo.

Não importa mais a essência do objeto do conhecimento (que é inatingível). Não preocupa mais a convergência da ideia obtida da coisa com sua verdadeira essência. Reformando a ideia de verdade formal, poder-se-ia dizer que o importante é obter a verdade “formal”, esclarecendo que o “formal” aqui significa o procedimento utilizado para se atingir o conceito – procedimento este que há de ser o consenso, atingido através do discurso habermasiano. Assim é que se chega ao conceito da dita “verdade factível”.

HABERMAS, analisando o tema, estabelece que “‘real’ é o que pode ser representado em proposições verdadeiras, ao passo que ‘verdadeiro’ pode ser explicado a partir da pretensão que é levantada por um em relação ao outro no momento em que assevera uma proposição. Com o sentido assertórico de sua afirmação, um falante levanta a pretensão, criticável, à validade da proposição proferida; e como ninguém dispõe diretamente de condições de validade que não sejam interpretadas, a ‘validade’ (Gültigkeit) tem de ser entendida epistemologicamente como ‘validade que se mostra para nós’ (Geltung). A justificada pretensão de verdade de um proponente deve ser defensável, através de argumentos, contra objeções de possíveis oponentes e, no final, deve poder contar com um acordo racional da comunidade de interpretação em geral”.⁶⁷ Fica, então, clara a ideia de diálogo, de argumentação e de persuasão, como componentes indissociáveis da verdade factível.

Se essa lógica vale para o conhecimento em geral, também sua aplicabilidade é necessária no campo processual. A doutrina processual precisa superar sua visão ontológica a respeito da verdade. Somente assim poderá ela aceitar reformas profundas nos axiomas processuais, a fim de garantir a efetividade do processo. É preciso convencer os processualistas de que a descoberta da verdade é um mito e de que o processo trabalha, de fato (e sempre trabalhou, embora veladamente) com a verossimilhança, a verdade possível e a argumentação.⁶⁸

Apenas com isto é que se logrará livrar o processo de certos vícios que atravancam seu desenvolvimento. As restrições, ainda hoje postas pela doutrina, em admitir a antecipação da tutela, adotada de forma explícita em nosso Código de Processo Civil, através de seus arts. 273 e 461, são grande prova desse preconceito. Grande parcela da doutrina ainda se mostra renitente em aceitar que o juiz possa antecipar o provimento final, sem que tenha percorrido todo o iter procedimental – já que, enquanto não encerrado o procedimento, não se poderia dizer que a verdade sobre os fatos foi obtida. Ora, tal visão míope somente cabe dentro desta posição ortodoxa mantida pela doutrina. Reconhecendo-se que a verdade não pode ser obtida, mas havendo alto grau de probabilidade de que os fatos tenham se passado de certa maneira, e diante da necessidade da antecipação da tutela (sob pena de perecimento do direito afirmado pelo requerente da medida) não há outra saída que não a concessão da antecipação, pena de inutilidade da prestação jurisdicional extemporânea.

Identicamente, a compreensão dessa faceta da prova – e desta função por ela desempenhada –

permite ampliar o campo de aplicação das tutelas preventivas. Costuma-se tratar, hodiernamente, da tutela inibitória, como uma tutela voltada para o futuro, que visa a evitar a ocorrência de um ilícito. Ora, tratando-se de medida judicial que tem por objetivo evitar a ocorrência de algo, é evidente que a prova que se exige para a concessão da medida não pode ser a mesma – ou ter a mesma intensidade – daquela imposta para as tutelas repressivas (voltadas para o passado). Apenas revendo o conceito e a função da prova é que se consegue dar suficiente suporte teórico para o estudo da tutela preventiva, autorizando que ela possa desenvolver-se de modo adequado, em toda sua potencialidade.⁶⁹

Questões como as acima ventiladas, porém, só se resolvem saindo do paradigma em que vive o direito processual atualmente.

Por outro lado, essa percepção permite concluir que, mesmo no âmbito aproximativo, é possível imaginar gradações no campo da verossimilhança. Se há um grau máximo de aparência (qualificado, aqui, como verdade factível), há também graus menos extremos, assimiláveis à noção de *fumus boni iuris* (probabilidade), por exemplo. Todos esses graus, porque contingentes a determinadas situações, legitimam decisões judiciais, sempre que presentes as circunstâncias que impediriam maior grau de verossimilhança.

Remete-se, por conta disso, à importância do procedimento para a determinação da qualidade da “verdade” obtida ou exigível. É diante da qualidade do contraditório disponível, da possibilidade de argumentação, e da justificação oferecida para certo convencimento, que se poderá aferir a legitimidade da decisão judicial.

2.7. A concepção de Michele Taruffo

Não obstante o amplo apoio doutrinário que embasa as ideias acima desenvolvidas, é crucial sublinhar que elas estão longe de serem aceitas de modo unânime.

A noção de uma verdade argumentativa, possível, e mesmo condicionada, encontra críticos severos, especialmente no campo do direito processual. Toma-se como parâmetro dessa orientação os escritos de Michele Taruffo,⁷⁰ não apenas por sua relevância para o estudo do processo civil, mas em particular diante da profundidade de seu exame e da polêmica levantada em razão dessa pesquisa.⁷¹

Segundo o autor, crescem, tanto no campo da filosofia como em outros espaços, as teorias que assumem uma postura cética quanto à possibilidade de se encontrar a verdade. A tendência à “verifobia”, como denomina Taruffo, baseando-se em trabalho de Alvin Goldman,⁷² pode ser extremamente prejudicial para o direito processual, especialmente em razão das nuances políticas, éticas e ideológicas que estão por trás dessa postura. Por isso – e porque não se deve confundir a “inexistência” da verdade com a dificuldade em sua reconstrução – insta recuperar a ligação do processo com a verdade objetiva, afastando as teorias que se assentam na ideia de verdade como produto da linguagem ou como resultado da certeza subjetiva.

Lastreando-se, basicamente, no pensamento de Susan Haack, Bernard Williams e Alvin Goldman, Taruffo assenta sua premissa de que é sim possível atingir-se a verdade, aceita como a correspondência entre o fato e a afirmação que se faz sobre ele. Para tanto, Taruffo estabelece os seguintes argumentos: a) faz sentido supor que o mundo externo exista; b) cada enunciado referente ao acontecimento do mundo real ou é verdadeiro ou é falso, em razão da sua efetiva ocorrência nesse mundo externo; c) esta verdade “objetiva” pode ser conhecida.⁷³

Diante disso, Taruffo não apenas conclui pela existência de uma verdade objetivamente considerada, mas ainda afirma que essa verdade possa ser obtida e demonstrada.⁷⁴ De outro lado, rechaça ele a ideia de que a verdade seja o produto do consenso, considerando que algum fato possa ser verdadeiro, ainda quando ninguém acredite em sua ocorrência.⁷⁵

Apesar de parecer que essas ideias são absolutamente incompatíveis com aquilo que aqui se defende, um exame mais aprofundado da obra de Taruffo demonstra que, por mais estranho que

pareça, as diferenças são mais de linguagem do que de concepções.

É que, embora Taruffo se refira a uma “verdade objetiva”, também ele reconhece que essa verdade, ou pelo menos o conhecimento dela, é condicionado a limitações culturais, técnicas e factuais. Afirma ele que *“anche senza condividere tesi ontologicamente realiste è possibile ipotizzare che vi sia una verità razionalmente conoscibile e dimostrabile. Si tratta della concezione epistemica della verità, risalente a Dewey ma riproposta più di recente da Michael Dummett, secondo la qual ella verità di un enunciato corrisponde alla sua warranted assertibility, ossia all’esistenza di valide giustificazioni per ritenere che un enunciato sia vero”*.⁷⁶

Ora, ao aludir a uma “verdade racionalmente cognoscível e demonstrável” e à necessidade de que se busque “justificações que mostrem que um enunciado é verdadeiro”, parece claro que Taruffo aponta para um conceito que está longe de ser objetivo, mas que é racionalizado e justificado. Por outras palavras, parece certo que, mesmo na concepção adotada pelo autor, a verdade não está no mundo externo, mas sim no sujeito que a obtém/cria.

Mais especificamente no campo processual – que aqui é o único que interessa – a diversidade de concepção parece mostrar-se claramente linguística. Afirma Taruffo que, no campo processual, embora se possa falar em verdade objetiva, ela é certamente relativa.⁷⁷ E é relativa exatamente em razão das limitações da cognição humana, condicionada que é à quantidade e à qualidade das informações de que se dispõe para a formação do conhecimento.⁷⁸

Ora, ainda que se pudesse almejar a obtenção de uma verdade objetiva e unívoca, não há dúvida de que aquilo que efetivamente se conseguirá, sempre, é um conhecimento dessa verdade ou, por outras palavras, uma impressão da verdade.

Assim, no processo ou fora dele, se apenas conseguimos obter impressões que nos parecem verdadeiras – e que são, como afirma Taruffo, condicionadas por vários elementos, seja atinentes às informações que obtemos, seja referentes ao âmbito cultural em que estamos inseridos, seja ainda alusivos a outros fatores – não há nenhum sentido em se prender ao conceito de verdade (objetiva ou substancial), já que esse não é um conceito operacional.

Ao fim e ao cabo, portanto, a conclusão de Taruffo não se distancia daquela aqui exposta. Ainda que ele fixe a premissa de que existe uma verdade externa e objetiva,⁷⁹ reconhece que, ao menos para o processo, a sua obtenção depende da cognição humana, que é naturalmente condicionada. Em última análise, então, tem-se que também aquilo que se pode obter no processo não é a dita “verdade objetiva”, mas apenas algo que talvez a ela se pareça, porque condicionada às limitações humanas.

Taruffo chega mesmo a fazer a distinção entre verdade e certeza – sendo aquela objetiva e esta subjetiva – mas parece preferir manter a conclusão de que a relação do processo seja com a primeira e não com a segunda.⁸⁰

Apesar disso, parece claro que sendo a cognição humana invariavelmente limitada por várias circunstâncias, trabalhar com um conceito único e objetivo de verdade é exigir demais, tanto do processo como das pessoas que se envolvem nele. Por isso, parece muito mais adequado empregar, como conceito operativo para o direito processual, a noção de verdade factível aqui defendida.

2.8. Verdade, pretensão de verdade e processo

Logicamente, afastar a possibilidade de se encontrar a verdade (objetiva, absoluta, externa) no processo não é o mesmo que negar qualquer importância para esse parâmetro de referência.

Embora, na ótica aqui sustentada, a noção de verdade absoluta seja intangível, parece certo que isso não significa abraçar alguma concepção radicalmente cética ou concluir pelo “império da falsidade no processo”. Ao contrário, a postura aqui assumida pretende apenas mostrar que a “desculpa da verdade”, ainda que sinceramente usada por muitos processualistas para defender certas concepções no processo civil nacional, parte de premissas manifestamente equivocadas e

absolutamente insustentáveis.

Assim, por exemplo, quando se pretende “relativizar a coisa julgada” sob o argumento de que “a ordem constitucional não tolera que se eternizem injustiças a pretexto de não eternizar litígios”⁸¹ – como se fosse possível afastar a coisa julgada porque a decisão não encontrou a verdade sobre os fatos da causa e, portanto, gera uma solução injusta para o litígio – parece evidente o recurso à ideia de “verdade absoluta”, como o soberano critério do processo. O argumento da necessidade de revisar sentenças quando a prova então obtida não reflete a “verdade dos fatos” ou de que instrumentos mais recentes de prova (técnica, em especial) devem sempre autorizar a revisão de julgados anteriores parece claramente refletir o pensamento que aqui se quer evitar.

Como afirma Laercio Becker, “a busca frenética da verdade não passa de um tapume de automatismo e suposta infalibilidade, a tentar fazer desnecessário qualquer prurido ético na decisão judicial”.⁸² Com efeito, ao se agarrar a um conceito claramente impossível e manifestamente inatingível para oferecer certa resposta a um problema ético judicial, a doutrina, na verdade, esconde o verdadeiro problema e, assim, abre ensejo a uma solução qualquer, em que restam suspensas todas as exigências de argumentação razoável.

Recorde-se que o mito da verdade já foi o discurso que legitimou a tortura⁸³ e as ordálias. Em algumas culturas mais recentes, o mesmo postulado autorizou a prática de magia e o recurso a oráculos no campo processual.⁸⁴ Na atualidade brasileira, não são raros os exemplos de decisões que atrelam suas conclusões à “verdade substancial”,⁸⁵ dando ainda maior força ao mito e maior eco a essa ilusão de ótica.

Em conta disso, ainda que a pretensão de verdade constitua uma das premissas do discurso jurídico – e, ademais, do discurso em geral – é certo que essa pretensão se impõe, mas nos seus próprios limites deontológicos, como já se viu anteriormente.⁸⁶ Ou seja, essa pretensão é uma das condições que legitima e justifica o diálogo, mas está longe de refletir o seu produto ou de pautar a confiança nas conclusões a que se chega.

Como se observou a partir das lições de Habermas antes sumariamente expostas, o discurso exige algumas condições prévias de viabilidade. Dentre estas, está a pretensão à veracidade e à sinceridade dos participantes. Porém, essa pretensão não se equipara a dizer que o discurso só existe se incidir sobre algum objeto verdadeiro ou algo do gênero. Isso só implica dizer que o discurso é tanto mais legitimado quanto mais se aproxima do pleno atendimento às suas pretensões.

Em consequência, tem-se que a pretensão a que o discurso se desenvolva tendo, dentre suas perspectivas, a intenção de que ele se aproxime da verdade e, portanto, exclua versões absurda de fatos, é bastante razoável. O que não se deve tolerar, porém, é transformar o mito da verdade no objetivo único ou principal do discurso processual, exigindo do processo algo que ele não pode dar.

Embora pareça desnecessário, vale recordar que o processo se orienta por vários valores distintos, sendo a “pretensão de verdade” apenas um dos pontos considerados na construção dos procedimentos disponíveis. Em virtude disso, é inequívoco que a importância de outros valores pode implicar limitações – e de fato implica – à investigação da verdade. Apenas como exemplo mais singelo, pense-se na coisa julgada. Sem dúvida, o interesse na preservação da segurança e da estabilidade da decisão judicial acaba por impor condicionantes à verdade (re)construída, o que evidencia a falta de um comprometimento absoluto do processo com a verdade.⁸⁷

Por isso, ainda que em outros campos, o valor “verdade” possa ser tomado de modo autônomo e isolado, o mesmo não ocorre no processo. Aqui, em virtude da concorrência de outros valores e de outros interesses, a “verdade possível” recebe contornos muito limitados.⁸⁸ Embora não se chegue ao extremo de compartilhar da visão que defende a absoluta irrelevância de qualquer âncora do direito e do processo em alguma verdade aproximativa,⁸⁹ é inquestionável que o processo não tem sequer condições de oferecer a verdade absoluta em seu trabalho de aferição

dos fatos.

Daí a importância – negada por Taruffo⁹⁰ – da noção de procedural justice, como elemento controlador da legitimidade do procedimento e da justiça da decisão.⁹¹ Inviabilizado o controle dessa atividade a partir da noção de “reconstrução da verdade dos fatos”, resta como forma de legitimação da atividade judicial a necessária observância do processo adequado, como já acentuado anteriormente.

É, enfim, a atenção à justificação da decisão judicial e ao procedimento que a antecede, que não de legitimar a atividade estatal.

2.9. A finalidade da prova

Partindo-se das premissas estabelecidas acima, é possível dizer que a prova não tem por objeto a reconstrução dos fatos, que servirão de supedâneo para a incidência da regra jurídica abstrata que deverá (em concretizando-se na sentença) reger o caso concreto.

Da pequena incursão feita sobre alguns avanços na teoria do conhecimento, pode-se extrair que a função da prova é prestar-se como peça de argumentação, no diálogo judicial, elemento de convencimento do Estado-Jurisdição sobre qual das partes deverá ser beneficiada com a proteção jurídica do órgão estatal.

A decisão judicial é legitimada pelo procedimento que a precede.⁹² São a forma e as garantias que permeiam o procedimento que permitem que a decisão daí emanada seja legítima e represente, ipso facto, a manifestação de um Estado de Direito. Essa legitimação se dá na proporção direta do grau de participação que se autoriza aos sujeitos envolvidos no conflito para a formação do convencimento judicial. Já que esta participação se dá, em linhas genéricas, por intermédio de alegações e de comprovações, a prova assume um papel de argumento retórico, elemento de argumentação, dirigido a convencer o magistrado de que a afirmação feita pela parte merece crédito.

Obviamente, tais noções partem do entendimento das ideias iniciais, vinculadas à teoria do agir comunicativo, propostos pela teoria habermasiana. Ou seja, para o sucesso dessa visão, exige-se que todos os sujeitos do processo estejam em situação de diálogo (podem comunicar-se, porque dominam os critérios da interação). A parte (por suposição, autora) faz uma proposição (por exemplo, na petição inicial), a cuja validade podem insurgir-se os demais sujeitos da comunicação (no caso, os sujeitos do processo); havendo esta impugnação à pretensão de validade da primeira proposição, surge a necessidade da argumentação sobre a proposição, o que se faz através de afirmações e provas. A prova, em direito processual, então, assume a condição de um meio retórico, não vedado por lei, e dirigido a, dentro dos parâmetros fixados pelo Direito e de critérios racionais, convencer o Estado-juiz da validade das proposições, objeto de impugnação, feitas no processo, permitindo a este a fundamentação válida das conclusões chegadas em matéria de fato.

a) Trata-se de um meio retórico, porque – antes de destinar-se à reconstrução de fatos (componente ideal inatingível) – destinam-se a estabelecer o diálogo, entre as partes e o Estado-juiz, necessário para a “fixação dos fatos controvertidos”.⁹³

Como bem lembra Chaïm Perelman,⁹⁴ as provas sempre se referem a alguma proposição ou, como prefere ele denominar, uma tese; ademais, é certo que esta proposição não pode ser fundamentada exclusivamente em um critério metafísico ou intuitivo, sendo necessário que se expresse por via de uma linguagem. Partindo-se desta premissa, “a escolha de uma linguagem ligada a uma teoria, e elemento indispensável para a descrição do real, é uma obra humana, na qual as estruturas formais se combinam com motivações culturais, tanto emotivas quanto práticas. Como uma linguagem não é nem necessária, nem arbitrária, seu emprego é consecutivo a uma argumentação, às vezes explícita, o mais das vezes implícita, quando seu uso parece tradicional”.⁹⁵

Porque a linguagem é necessária para a expressão de uma ideia ou de uma proposição, a retórica impõe-se como forma de estabelecer a comunicação entre os sujeitos do diálogo, para o

fim de lograr o objetivo inicialmente concebido para a proposição (e também para a prova): o convencimento. “Um raciocínio, tradicional na história da filosofia, faz qualquer conhecimento depender, em última instância, de uma evidência, intuitiva ou sensível: ou a proposição é objeto de uma evidência imediata ou resulta, por meio de certo número de elos intermediários, de outras proposições cuja evidência é imediata. Apenas a evidência forneceria a garantia suficiente às afirmações de uma ciência que se opusesse, de maneira igualmente tradicional, às opiniões, variadas e instáveis, que se entrecrocavam em controvérsias intermináveis e estéreis, que nenhuma prova reconhecida permite dirimir”.⁹⁶

b) Este meio deve enquadrar-se nas prescrições legais atinentes à matéria, ou, ao menos, não ser vedado por elas. Ainda que, em regra, a lei autorize a liberdade desses meios, é certo que as normas sobre prova representam “critérios prévios”, determinantes da possibilidade do “diálogo”; assim é que estas determinações de lei podem regular tanto o modo de formação da prova, como sua produção dentro do processo, como ainda podem condicionar a sua força probante no limite do convencimento do Estado-Jurisdição (prova legal).

c) Enfim, a função assumida por este meio é a de convencer o juiz da validade (ou verossimilhança) das proposições fáticas formuladas inicialmente (tanto como afirmações, pretensões e exceções) que tenham sido objeto de dúvida, autorizando a formação da fundamentação correta a respeito dessas questões.⁹⁷

Com efeito, a função da prova é permitir o embasamento concreto das proposições formuladas, de forma a convencer o juiz de sua validade, diante da impugnação desta por outro sujeito do diálogo. É por esta razão que, em princípio, somente os fatos (rectius as afirmações de fato) controvertidos é que são objeto de prova; as afirmações de fato sobre as quais não se levanta (por nenhum dos sujeitos do processo) qualquer dúvida, são incontroversas e, portanto, estão, de regra, fora da investigação processual (arts. 341 e 374 do Código de Processo Civil).

No processo, a prova dirige-se à argumentação exclusivamente relacionada às afirmações de fato, formuladas no interior da relação processual. Embora também no campo da atuação das normas, a argumentação funcione como parâmetro para a fixação do Direito, é certo que este não é o campo da prova.

Quanto ao convencimento do órgão jurisdicional, é certo que este se dará, ao menos em linha de princípio, por critérios de racionalidade, utilizando-se, como bem notou Calamandrei,⁹⁸ de raciocínio idêntico ao que sustenta as máximas da experiência. Haverá o juiz de considerar o que acontece na normalidade dos casos, como parâmetro para argumentação a respeito da formação de seu convencimento. Todavia, é necessário advertir, que este convencimento do Estado-juiz não é asséptico; o juiz, ao formar seu convencimento sobre o fato, não age como ser inerte e neutro, desprovido de qualquer “pré-conceito”, preconceitos ou vontade anterior.⁹⁹

O convencimento do órgão julgador – em face de sua peculiar situação frente aos demais sujeitos da argumentação e frente ao objeto do processo – merece especial atenção, já que toda a retórica do “diálogo judicial” se destina a ele. E, este juiz, assim como todo sujeito vivente, é influenciado por critérios políticos, sociais, econômicos, históricos etc.¹⁰⁰ Este convencimento (e, também, o conhecimento) envolve, sempre, uma relação de poder¹⁰¹ entre o sujeito-juiz, o objeto de conhecimento e os demais sujeitos envolvidos.

Destas afirmações ressurgem a importância de se colocar o juiz no centro do problema probatório. É ele o destinatário final da prova porque é ele, enquanto representante do Estado-Jurisdição, quem deve estar convencido da validade (ou não) das proposições formuladas. A argumentação probatória, portanto, deverá tomar em conta, também, as características próprias do Estado-juiz instituído, porque o seu convencimento há, necessariamente, de estar condicionado por inúmeras variáveis políticas, econômicas, sociais etc. Assim se explica o porquê, diante de dois processos idênticos, em que foram produzidas as mesmas alegações e as mesmas provas, dois juízes distintos podem chegar a duas conclusões completamente antagônicas: é que a prova não se presta à reconstrução da verdade – caso em que, as conclusões judiciais, como exercício de mero silogismo, deveriam ser, inexoravelmente, as mesmas – mas a apoiar a argumentação retórica das

partes (e também do magistrado) sobre a controvérsia exposta.

Enfim, também não se pode negar que a prova será condicionada, ainda, pelas componentes culturais, políticas, econômicas e sociais dos outros sujeitos do processo. É certo que em uma sociedade altamente organizada, com alto padrão cultural, econômico e social, se possa exigir, para a comprovação de fatos, meios probatórios mais elaborados e evoluídos. Ao contrário, em uma comunidade pobre, de baixo status cultural, social e político, prevalecem as provas simples, orais e, muitas vezes, mesmo informais. Também este componente há de entrar na avaliação judicial, diante do diálogo probatório travado no processo.

Daí a relevância em se relativizar as exigências probatórias e em se modular suas possibilidades, segundo as circunstâncias de cada situação. Daí também a importância da justificação judicial adequada a propósito da obtenção da prova e de sua adequada valoração. Somente assim se conseguirá um processo mais aderente à realidade e mais atento àquilo que efetivamente se pode esperar da prestação jurisdicional.

3. A natureza das regras sobre prova

Embora pareça tema de conteúdo estritamente acadêmico, é importante abordar o tema relativo à natureza das regras sobre prova. No direito comparado algumas legislações tratam da matéria da prova em diplomas de direito material (v.g., o direito italiano e o direito português), enquanto outras preferem discipliná-la juntamente com as questões processuais. Mesmo em nosso direito nota-se que, conquanto a matéria venha, em termos amplos, tratada pela legislação processual, existem inúmeros dispositivos que versam sobre o tema inseridos em códigos de direito material (como é o caso das regras constantes do Código Civil). É certo que esse critério topográfico pouca, ou nenhuma, importância tem para a definição da natureza jurídica das regras; entretanto, permitem apontar para a polêmica que se trava quanto a essa essência.

Sobretudo, importa salientar que essa discussão não apresenta apenas aspectos que interessam ao plano acadêmico ou meramente teórico. Ao contrário, a definição da natureza jurídica dessas regras permitirá aplicar-lhes o regime próprio, de direito material ou de direito processual, especialmente no que refere à aplicação da lei no tempo e no espaço. A distinção ainda espreia importância em alguns sistemas jurídicos – como o argentino –, onde as regras de direito processual são de competência provincial, enquanto as regras materiais são de alçada federal – questão que poderia ser transportada para o direito brasileiro em relação a algumas regras de procedimento – matéria sujeita a legislação estadual supletiva.

3.1. A natureza material das regras sobre prova

A ideia de que as regras sobre prova têm natureza de direito material certamente possui matriz mais antiga, especialmente ubicada nas origens sincréticas do direito processual. Entretanto, seu desenvolvimento após a fase autonomista do direito processual teve amplo espaço, mormente porque se observou que as provas podiam ter função não exclusivamente no processo, mas também extraprocessual, na medida em que permitiam a formalização das relações jurídicas, emprestando-lhes certo grau de estabilidade e, conseqüentemente, perenidade e paz no convívio social.

A exposição de motivos do Código Civil italiano, ao tratar do tema da prova, justificou tal opção, dizendo que as provas “vem aqui em consideração como meio e instrumento para fazer valer ou para defender geralmente os próprios direitos, e isto não apenas em juízo, mas também fora e antes deste, já que a evidência e a virtual segurança de obtê-las quando que seja o reconhecimento, é condição já por si só normalmente suficiente de respeito dos direitos mesmos, de tranquilidade no seu gozo e de segurança nas negociações que lhe dizem respeito” (Exposição de Motivos, n. 1.065).

Nessa mesma linha, Carnelutti salientou que o juiz “tem em regra necessidade de provas; mas as próprias partes também o podem ter. Nem todos os fatos jurídicos que elas têm de pesar se passam sob os seus olhos; e nem todos os atos jurídicos que terão de avaliar são por elas

praticados. Basta que o leitor pense na posição do herdeiro perante o testamento, ou na do proprietário perante o desaparecimento da sua coisa, devido possivelmente a perda ou a furto, ou a roubo de Tício ou de Caio”.¹⁰²

Nota-se dessas palavras a preocupação com a função extraprocessual da prova, como elemento certificador das relações jurídicas e, portanto, capaz de agir – também como prova –, por exemplo, em uma tentativa amigável de solução de conflito.

Todavia, mesmo dentro do processo, observa-se que as regras sobre prova têm por objetivo informar o magistrado sobre o suporte fático da demanda que dá lastro para a pretensão exposta em juízo. Assim, visam, em última análise, subsidiar o magistrado com aspectos que dizem respeito à aplicação do direito material – como elementos do julgamento da causa. Não se confundem, dessa forma, com regras meramente procedimentais ordinatórias, tendo por escopo a própria decisão do litígio, o que, novamente, apoia a ideia de que as regras sobre prova têm natureza material.

3.2. A natureza processual das regras sobre prova

A essa orientação opõe-se a quase unanimidade da doutrina. Segundo a maioria dos processualistas contemporâneos, as regras sobre prova são de natureza processual, já que apenas no processo têm a sua eficácia própria.

De acordo com Chiovenda, todas as normas que realmente tratam de matéria probatória (norme vere e proprie sulle prova) têm natureza processual.¹⁰³ E tais regras são, segundo ensina, aquelas estabelecidas pelo legislador por alguma “razão processual”.¹⁰⁴ Para Chiovenda, qualquer regra que efetivamente tenha alguma aplicação no processo tem natureza processual.

Também Liebman adere à tese de que as regras sobre prova têm natureza processual.¹⁰⁵ Segundo ele, todas as normas que tratam de prova (mesmo aquelas inseridas em legislação material) têm em vista regular a prova no processo; assim sói acontecer com a confissão, a prova testemunhal, a prova pericial, que somente podem ser produzidas no processo. Argumenta Liebman que, mesmo em relação à prova documental (pré-constituída), a eficácia da prova somente se mostrará com vigor no processo, já que somente aí o documento será confrontado e posto em choque com os demais meios de prova.¹⁰⁶

Além disso, lembra o autor que a tese de que as provas se prestam para assegurar a certeza jurídica sobre as relações jurídicas e sua fruição pacífica não passa de mera ilusão. Isso porque, como sustenta o genial processualista, “o direito não pode fazer outra coisa que instituir um órgão a quem confere o ofício de judicar com eficácia juridicamente vinculante e por isso sobretudo aquele de declarar (accertare) os fatos. Assim o problema da certeza dos fatos jurídicos se resolve inevitavelmente naquele da sua prova no processo e a esta e apenas a esta são dedicadas as normas legais sobre a prova”.¹⁰⁷

Essa corrente, como se conclui das observações feitas, compreende que as regras sobre prova têm natureza processual porque – ainda que as provas sejam usadas fora do processo, para fins particulares ou para a certificação das relações jurídicas – somente assumem real importância dentro do processo. As formalidades impostas pela lei para a formação da prova, os critérios estabelecidos para a sua valoração e, com maior intensidade ainda, as determinações legais sobre a propositura e a colheita da prova, dirigem-se todos para a figura do juiz e, assim, para o processo.

3.3. Uma visão eclética sobre a natureza das regras sobre prova

Ao lado dessas noções absolutas, há quem busque oferecer uma teoria conciliatória sobre a natureza das regras sobre prova. Surge, assim, a ideia de que tais normas podem ter natureza ambivalente, conforme a situação em que se aplicam.

Como explica Jaime Guasp, podem existir duas espécies de prova: a prova material e a prova

processual.¹⁰⁸ A primeira representa a “instituição que, no âmbito das relações jurídicas regidas pelo direito material, destina-se à justificação da existência de determinados acontecimentos da vida real”.¹⁰⁹ Segundo sua visão, a prova não tem destinatário específico, visando apenas a objetivamente dar crédito (justificar) ao dado referido na prova, sendo, por isso, regulada pelo direito material. Já a prova processual “dirige-se a produzir a convicção psicológica do juiz em um sentido determinado, com respeito a um dado ou conjunto de dados processuais. Neste caso já não há que falar de justificações objetivas, mas de comprovações pessoalmente dirigidas a um sujeito particularizado”.¹¹⁰ Nesse último sentido, conforme ensina GUASP, a prova pode utilizar-se dos mesmos meios probatórios da prova material, mas terá sempre uma finalidade distinta, porque dirigida a um sujeito específico.

Também Satta e Punzi¹¹¹ parecem aderir a essa ideia. Falam no aspecto estático e dinâmico da prova. O primeiro (estático) “é aquele de ente ou meio decisivo ou relevante para a certeza de um fato”.¹¹² Nesse aspecto, as regras sobre prova pertencem ao plano do direito material, que fixa, em abstrato, os meios de prova, os limites de certeza que cada prova pode comportar etc. No aspecto dinâmico, a prova se destina à verificação específica de um fato.¹¹³ Aqui a prova já não mais se relaciona, propriamente, com um fato, senão com uma afirmação de fato no processo. Na ótica dinâmica da prova, a relação que era abstrata, de certeza hipotética, passa a ser específica, travada entre dois sujeitos determinados: um que alega um fato e um que o reconhece.¹¹⁴ O fato alegado, então, torna-se certo por meio da representação que o primeiro sujeito consegue criar no segundo, o que faz através das provas.

Dessas ideias é possível extrair uma tentativa de aproximação das teorias anteriores, calcada na situação específica em que a prova é utilizada. Se destinada ao processo, as suas regras teriam natureza processual. Mas, quando dirigida apenas a regular condutas sociais em abstrato, seriam regidas por normas materiais. É clara, entretanto, a imprestabilidade dessas ideias no campo prático. Isso porque todas as provas, embora tenham eficácia social pré-processual, podem sempre vir a ser utilizadas no processo. E, se o forem, ter-se-á de alterar o regime que as rege do direito material para o direito processual. Ocorre, porém, que essa mudança de regime, após a formação da prova (a sua constituição) pode torná-la totalmente inútil, uma vez que existindo duas regras que tratem do mesmo tema (meio de prova, grau de certeza da prova, ônus da prova etc.), nada impede que cada uma delas veja o assunto de forma distinta.

Pense-se, por exemplo, em um meio de prova constituído segundo as leis locais materiais para a formalização de um certo negócio jurídico. Segundo tal lei material, esse é o meio de prova correto para demonstrar a existência do negócio jurídico. Caso surja algum conflito decorrente desse negócio, a transformação da regra de regência, da lei material para a lei processual, pode implicar a alteração do meio de prova adequado para a comprovação do negócio – pense-se também que isto pode acontecer porque o local do fato (que regia a aplicação da lei material) pode não ser o local da propositura da ação (em geral, nos termos do Código de Processo Civil, o domicílio do réu), e nada impede que este outro local tenha suas regras próprias (processuais) sobre o tema probatório. Ora, isso considerado sob o prisma da estabilidade e da certificação que se pretende ver na prova é simplesmente catastrófico, pois dela retira toda a sua utilidade prática.

3.4. Conclusão

Das visões parciais sucintamente expostas, pode-se notar a complexidade do tema e a dificuldade que a doutrina tem para enfrentar a questão. Os próprios critérios usados para a distinção – direito material ou direito processual – possuem fronteiras obscuras e definições imprecisas, especialmente quando considerados diante de situações limítrofes.

A dificuldade em traçar adequadamente os contornos de cada uma das esferas levou DENTI a propor o abandono dos parâmetros conceptualísticos de distinção e a tentar localizar outro critério.¹¹⁵ Realmente, como demonstrou DENTI, a tentativa de enquadrar as regras sobre prova em esquemas abstratos pré-determinados esbarra na dificuldade de elaborar uma adequada distinção entre eles e, o que é pior, não leva em conta as particularidades dos casos concretos.

A atitude aparentemente neutra, de estabelecer esquemas abstratos para tentar explicar a problemática, faz surgir situações inexplicáveis. Na verdade, não há como deixar de atender as exigências do caso concreto – que podem suceder-se de forma diversa, mesmo dentro de uma única relação processual –, o que obriga o juiz a reger-se ora por critérios de direito material ora por critérios de direito processual.¹¹⁶

A necessidade de considerar o caso concreto recebeu a adesão de Cappelletti, que advertiu que a tentativa de enquadrar as normas sobre prova como regras de direito material ou de direito processual fracassa quando se percebe que certas normas não se amoldam perfeitamente nem em uma nem em outra categoria.¹¹⁷ Isso revela – prossegue o processualista – que “não podemos remeter a solução dos problemas a premissas puramente abstratas e teóricas, que nada têm que ver com as exigências da realidade”, e que o exame casuístico deve preponderar sobre a ótica simplista e reducionista do esquema formal.¹¹⁸

Como escreve Cappelletti, com isso não se pretende dar ao juiz a possibilidade de uma decisão discricionária caso a caso, mas sim lhe confiar a elaboração de critérios de solução problema a problema. Esses critérios também podem ser sistematizados, mas não podem buscar a solução do problema em premissas abstratas, conceituais e formais – natureza processual ou natureza material – mas na consciência da função prática do direito e na necessidade de encontrar soluções correspondentes e adequadas a essa função.¹¹⁹

Os critérios abstratos, se têm função didática, não têm coerência com a racionalidade do caso concreto. Os padrões fixados – normas processuais e normas materiais – não guardam relação com a realidade, representando apenas divisões arbitrárias. Portanto, também aqui se corre na direção da ideia de que o direito não deve ser pensado em abstrato, como se fosse uma região árida e inatingível pela vitalidade do caso concreto.

4. Objeto da prova

Observando o que foi dito até aqui, um elemento deve ser destacado, qual seja a menção a que a prova não se destina a provar fatos, mas sim afirmações de fato. É, com efeito, a alegação, e não o fato, que pode corresponder ou não à realidade daquilo que se passou fora do processo. O fato não pode ser qualificado de verdadeiro ou falso, já que esse existe ou não existe. É a alegação do fato que, em determinado momento, pode assumir importância jurídico-processual e, assim, assumir relevância a demonstração da veracidade da alegação do fato.

Precisam ser alegados apenas os fatos principais, e não os fatos secundários, uma vez que existe a possibilidade de os últimos serem apreciados pelo juiz ainda que não tenham sido afirmados pela parte interessada.¹²⁰ Os fatos principais (também ditos essenciais ou diretos) são aqueles que devem ser afirmados na petição inicial e na contestação, destinando-se diretamente a demonstrar com quem está a razão. Como dito, a prova deve se situar no âmbito das afirmações de fato que suportam o *thema decidendum* ou, mais precisamente, no espaço criado pelos argumentos do autor, que embasam seu pedido, e pelos argumentos do réu, que conformam as defesas apresentadas para a rejeição do pedido (ou seja, somente no espaço das afirmações de fato controvertidas no processo).

Porém, podem existir outros fatos que não sejam capazes de demonstrar diretamente a verdade dessas afirmações de fato, embora sirvam indiretamente para convencer o juiz de que elas são verdadeiras. Trata-se dos fatos secundários (também ditos indiciários).

O fato secundário não precisa ser alegado – e assim não se submete ao chamado ônus da afirmação, ainda que isso não queira dizer, evidentemente, que o autor não possa alegá-lo. O que se quer esclarecer é que o fato secundário, ainda que não alegado, pode ser objeto de prova. Esse fato não precisa ser alegado porque se destina a demonstrar que a afirmação do fato principal (direto ou essencial) é verdadeira.

Por outro lado, somente alegações a respeito de fatos pertinentes e relevantes para o processo

constituem objeto de prova. Assim, pouco interessa para o processo a afirmação e, conseqüentemente, a prova de fatos não importantes à solução do litígio – por exemplo, nenhuma relevância existiria na afirmação, e conseqüente prova, quanto às circunstâncias em que a petição inicial foi elaborada, se estava chovendo naquele instante ou não, se a aceitação da causa foi ou não difícil etc. – já que não constituem esses elementos pontos (ou questões) sobre os quais é possível controverter no processo.

De outro lado, também o direito não depende de prova, já que é dever do magistrado conhecê-lo. Excetua-se dessa regra, ao menos aparentemente, a possibilidade de o juiz exigir a prova do direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário. Tal é o que prevê o art. 376, autorizando o magistrado a, em havendo necessidade de recorrer a essa espécie de direito, poder determinar a prova de seu teor e sua vigência à parte que o alega. A exceção, porém, é mais aparente do que real. Na verdade, muito embora o preceito fale em prova da alegação do direito, a verdade é que direito não se alega; direito se invoca, supondose, em virtude do brocardo *Iura novit curia*, que o juiz o conheça. O que se alega são fatos.¹²¹ E, a prova admitida no dispositivo, a rigor, não é a prova “do direito”, mas apenas a prova do teor e da vigência de determinada norma, o que obviamente é questão que não pode ser rigorosamente qualificada como prova do direito.

5. Fases do procedimento probatório

O procedimento probatório pode ser dividido em quatro fases, correspondentes a cada um dos momentos da prova no processo. São elas: o requerimento, a admissão, a produção e a valoração da prova. Em geral, essas fases são nitidamente separadas, permitindo sua fácil localização; eventualmente, porém, confundem-se em uma única ocasião, em virtude de alguma particularidade do processo.

O requerimento é fase inicial, em que se pleiteia ao órgão judiciário – que tem o poder de controle sobre a prova, permitindo ou não o recurso a certo meio de prova no processo – a produção de determinada prova, a fim de influir no convencimento do juiz. Essa fase, normalmente, será realizada no início do processo, incumbindo à parte requerer as provas que deseja produzir na petição inicial ou na resposta (arts. 319, VI, e 336). Outros momentos, todavia, são designados pela lei também para essa função, decorrentes de algum evento próprio, ocorrido no curso do processo. Assim, determina o art. 348 que o juiz permita ao autor especificar as provas que pretende produzir quando, embora o réu não tenha contestado o pedido inicial, não tenha também ocorrido o efeito material da revelia (art. 344). Da mesma forma, o requerimento de prova pode ser efetivado mesmo fora e antes do processo ser instaurado, por via de demanda autônoma (medida de produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383), tendente a evitar o desaparecimento da prova em função do tempo, de algum outro perigo que possa colocar em risco a prova a ser utilizada em outro processo ou ainda com o simples intuito de sua colheita antecipada.¹²² Também será admissível o requerimento da prova no processo, mas em momento ulterior ao ordinariamente conferido para tanto, quando for necessário comprovar “fato novo”, não existente quando o processo teve seu início (por exemplo, nos termos do que preveem os arts. 435, 493, parágrafo único, e 938, § 3.º).

Uma vez requerida a prova, cabe ao órgão jurisdicional examinar o cabimento e a conveniência em realizar-se tal prova. Esta é, então, a fase de admissão da prova. O juiz exerce aqui decisão a respeito da prova requerida, admitindo-a ou não, levando em conta a hipotética utilidade da prova no processo (a viabilidade de que a prova solicitada venha efetivamente a contribuir com o resultado do processo), bem como sua admissão pelo direito positivo. Para que o magistrado possa decidir adequadamente sobre a admissão ou não da prova solicitada, deve, obviamente, o requerimento ser específico – não se admitindo seja genérico e indeterminado –, mencionando o tipo de prova a ser produzido, sua determinação (qual o documento ou, ainda, por exemplo, que tipo de perícia se pretende) e sua finalidade (a que alegação de fato se destina).

Da mesma forma, a decisão que admite ou não a produção de certa prova deve ser fundamentada, esclarecendo de modo preciso as razões que levam o magistrado a sentir a sua necessidade, ou que determinam sua rejeição.

Admitida a prova, deverá ela ser produzida. Em geral, as provas são produzidas na audiência de instrução e julgamento (art. 358). Eventualmente, porém, essa produção pode se dar em outro momento e em outro lugar, como seria o caso de ser necessário ouvir pessoa enferma, que não possa se deslocar até a sede do juízo (art. 449, parágrafo único), ou de se garantir a prerrogativa dada a certas pessoas de serem ouvidas onde indicarem (art. 454). A prova documental também constitui exceção a esta regra. A parte que requer a produção de prova documental já deve juntar aos autos o documento a ser utilizado,¹²³ cuja admissibilidade somente ocorrerá em ocasião posterior, após o contraditório (art. 437), e com a decisão do magistrado, quando então será efetivamente tida por produzida.

Uma vez produzida a prova, será ela valorada pelo juiz. Em regra, essa valoração será feita na sentença ou na decisão concessiva de tutela provisória, quando o magistrado terá de formar seu convencimento.¹²⁴ No direito brasileiro, adota-se o princípio da persuasão racional do juiz, de modo que as provas não têm, em regra,¹²⁵ valor predeterminado, podendo o magistrado convencer-se livremente com qualquer das evidências presentes nos autos, desde que justifique os motivos pelos quais entende que certa prova gera convencimento, ou as razões para que certa prova se sobreponha a outra (art. 371).

Assim, em regra, o modelo brasileiro centra o controle da formação da convicção judicial sobre a motivação oferecida por ele a respeito das provas do processo. Daí a necessidade de que essa motivação seja completa, no sentido de apontar com precisão as razões que levaram o magistrado (ou o tribunal) a dar maior peso a esta ou àquela prova, refutando outra, em sentido contrário. Não bastará, por isso, que o juiz se limite a alinhar as provas que vão no sentido de sua conclusão, para que se tenha como fundamentada a sua decisão. Será sempre necessário que ele justifique o porquê de não ter dado valor aos outros meios de prova, que sustentariam a conclusão diversa. Trata-se de decorrência necessária do preceito contido no art. 489, § 1.º, IV, a impor que o juiz examine todos os argumentos que poderiam se contrapor à sua conclusão. Logicamente, não basta o juiz afastar tais argumentos, sendo também necessário que examine a prova que sustenta esses argumentos e justifique os motivos pelos quais não lhe dá crédito.

Por fim, é bom distinguir duas figuras, nem sempre separadas pela doutrina, mas de repercussão certa no processo. Não se pode confundir produção de prova com obtenção de prova. Prova “obtida” nem sempre é prova “produzida”. A prova “obtida” é aquela sobre a qual ainda não cabe juízo de admissibilidade. É o que acontece, por exemplo, com as provas “obtidas” por meio da chamada “produção antecipada de prova”; nela realiza-se a prova fora e antes do processo em que poderá ser utilizada. Com efeito, essa prova somente será “produzida” após “admitida” pelo juiz do processo em que se pretende sua utilização. Pode acontecer, por exemplo, que o resultado da prova obtida nesse processo “preparatório” (em que a prova foi obtida) seja inútil ou irrelevante para o convencimento do juiz (que deve apreciar a causa que a prova pretendia esclarecer). Não haverá, então, razão para a prova ser utilizada quando for discutida a causa, motivo pelo qual não se há de autorizar sua produção. Aí, então, ter-se-á uma prova obtida, mas cuja produção (no processo para o qual originariamente se destinava) não será autorizada. Também por essa razão, no procedimento de produção antecipada de prova, não se autoriza ao juiz pronunciar-se a respeito da ocorrência ou não do fato, ou ainda sobre as correspondentes consequências jurídicas (art. 382, § 2.º).

6. Prova direta, prova indireta, indícios e presunções

6.1. Fato direto (primário) e fato indireto (secundário)

Os fatos diretos são aqueles que devem ser afirmados na petição inicial e na contestação, destinando-se diretamente a demonstrar com quem está a razão. A prova deve se situar no âmbito das afirmações de fato que suportam o *thema decidendum* ou, mais precisamente, no espaço criado pelos argumentos do autor, que embasam seu pedido, e pelos argumentos do réu, que conformam as exceções apresentadas para a rejeição do pedido (ou seja, somente no espaço das afirmações de fato controvertidas no processo).

Porém, podem existir outros fatos que não sejam capazes de demonstrar diretamente a verdade dessas afirmações de fato, embora sirvam indiretamente para convencer o juiz de que elas são verdadeiras. Trata-se dos fatos indiciários ou secundários.

O fato indiciário não precisa ser alegado – e assim não se submete ao chamado ônus da afirmação,¹²⁶ ainda que isso não queira dizer, evidentemente, que o autor não possa ou deva alegá-los. O que se quer esclarecer é que o fato indiciário, ainda que não alegado, pode ser objeto de prova. Esse fato não precisa ser alegado porque se destina a demonstrar que a afirmação de fato (direto) é verdadeira.

6.2. Prova direta e prova indireta

A distinção entre prova direta e prova indireta foi feita inicialmente por Carnelutti, que afirmou que a diferença entre os dois tipos de prova está na coincidência ou na divergência do fato a provar (objeto da prova) e do fato percebido pelo juiz (objeto da percepção).¹²⁷

Nesse sentido, quando o juiz, por meio da prova, percebe o fato a provar, a prova é dita direta. Mas, quando o objeto da percepção não é o objeto da prova, mas sim outro fato, do qual o juiz pode deduzir o fato direto, a prova é indireta. Portanto, segundo Carnelutti, na prova indireta há uma separação entre o objeto da prova e o objeto da percepção judicial.¹²⁸

Parece, entretanto, ser necessário distinguir o fato a ser provado – que pode ser direto ou indireto –, o meio de prova destinado a elucidá-lo e a percepção judicial – que também pode ser direta ou indireta.

Ora, se é inegável que um fato pode ser indicativo de outro, é evidente a diferença entre o fato indireto e o fato direto. Acontece que a prova nem sempre permite uma percepção direta do fato, seja ele direto ou indireto. Em outros termos: ainda que o fato seja direto, em alguns casos o juiz somente pode percebê-lo indiretamente; assim, por meio de uma prova indireta.

A prova testemunhal e a prova pericial, ainda que tentem elucidar o fato principal, sempre constituirão as versões da testemunha e do perito, pelo que o juiz, diante delas, nunca terá percepção direta do fato, mas sim percepção por meio da prova testemunhal e da prova pericial. Nessa linha, tais provas, embora relacionadas ao fato direto, deveriam ser compreendidas como provas indiretas, exatamente porque o juiz, por meio delas, tem apenas uma percepção indireta do fato direto. Caberia catalogar como prova direta, nesse último sentido, apenas a inspeção judicial e o documento.

Entretanto, é importante tentar evidenciar o motivo para se classificar a prova em direta ou indireta?

Quando a classificação toma em consideração a natureza do fato – direto ou indireto – deseja-se sublinhar que, diante da prova direta, o juiz relaciona automaticamente a prova com o fato, enquanto que a prova indireta requer que o juiz estabeleça um raciocínio dedutivo, que deve ser explicitado racionalmente, a partir de regras de experiência que sejam suficientes para fazer crer que do fato indireto decorre o fato direto.¹²⁹

Afirma-se que se o juiz outorga credibilidade a um elemento de prova direta, qualquer raciocínio inferencial é demais, uma vez que, nesse caso, a inferência configura-se como uma tautologia que se move de uma proposição particular (que enuncia o elemento de prova) até outra proposição particular (que constitui a hipótese fática correspondente), sem a mediação de critérios gerais, em virtude da relação de identidade existente, no plano lógico-semântico, entre as duas proposições.¹³⁰

Esse entendimento, embora aluda à distinção entre a prova direta e a prova indireta, na realidade está preocupado com o raciocínio judicial diante das provas do fato direto e do fato indireto. Quando a prova recai sobre um fato direto, como por exemplo o testemunhal, o juiz deve se perguntar, em primeiro lugar, sobre a idoneidade da testemunha e do testemunho, para após

fazer a relação direta entre o depoimento e o fato. Entretanto, algo bem mais complexo, em termos de raciocínio judicial, ocorre quando se está frente a um fato indireto. Aí, também no caso de prova testemunhal, além da idoneidade da testemunha e do testemunho, e da relação entre o depoimento e o fato indireto, o juiz deve raciocinar para concluir se a prova do fato indireto permite a dedução do fato direto.¹³¹

Diante da diversidade evidente do raciocínio judicial nesses dois casos, a distinção entre a prova do fato direto e a prova do fato indireto possui bastante importância. Na realidade, o que realmente interessa, no tema que ora nos ocupa, é o raciocínio judicial, e não a forma como o juiz tem a percepção a respeito do fato (direta ou indireta).¹³² Nesse último caso, como dito, provas diretas seriam a inspeção judicial e o documento (esse último com ressalvas), e então não se faria qualquer distinção entre a prova do fato direto e a prova do fato indireto.

A única vantagem dessa última distinção seria a de separar a prova em que o juiz forma a sua convicção sem qualquer intermediação, daquelas em que a convicção judicial passa pela idoneidade da própria prova. Isso porque é inegável que o juiz deve aferir a credibilidade do depoimento testemunhal (por exemplo).

Como se vê, também há diferença, em termos de raciocínio judicial, entre a prova intermediada e a prova cujo contato do juiz é direto. É que na prova testemunhal, como já foi observado, não basta ao juiz relacionar o depoimento com o fato, mas é preciso aferir a credibilidade da própria prova testemunhal. Ou seja, antes de o juiz relacionar o depoimento e o fato, deve aferir a credibilidade da testemunha (se ela tem razões para mentir) e a credibilidade do próprio depoimento (se existem contradições internas ao depoimento, que revelem lapsos de memória ou má-fé etc.).

Que tudo isso respeita ao raciocínio judicial é inegável. Porém, a real diferença entre o contato direto e o contato intermediado é que a aferição dos requisitos relativos à credibilidade da prova testemunhal (por exemplo) é prévio à relação entre o resultado da prova e o fato.¹³³ Nessa perspectiva, dando o lugar de prévio ao raciocínio atinente à credibilidade da prova, a prova testemunhal do fato direto exige a mera relação entre o depoimento e o objeto da prova, quando então se torna exata a distinção entre a prova do fato direto e a prova do fato indireto.

6.3. Precisão dos conceitos de indício, prova indiciária, raciocínio presuntivo e presunção

O indício é um fato, que por essa razão é chamado de fato indiciário, e, assim, deve ser colocado no mesmo plano classificatório do fato direto. O indício não é prova, pois ainda que tenha o objetivo de demonstrar, de forma indireta (através de raciocínio judicial dedutivo), a afirmação do fato direto, antes deve ser elucidado por meio de prova. Se o indício pode servir para o juiz pensar, por meio de raciocínio dedutivo, sobre a afirmação do fato direto, não se pode esquecer que ele, para ser tomado em consideração para o juiz formar o seu convencimento, também deve ser objeto de prova.

Ou seja, para que o juiz possa formar a sua convicção a partir do indício, esse obviamente deve estar provado. Portanto, o indício não é prova, mas sim elemento para a formação do juízo acerca da afirmação do fato direto. Indício, assim, é o mesmo que fato indiciário. Como afirma Barbosa Moreira, “o que o indício tem em comum com um documento ou com o depoimento de uma testemunha é a circunstância de que todos são pontos de partida. Enquanto, porém, o documento ou o testemunho são unicamente pontos de partida, o indício, repita-se, já é, ao mesmo tempo, um ponto de chegada. Não ainda o ponto final; mas um ponto, sem dúvida, a que o juiz chega mediante o exame e a valoração do documento ou do depoimento da testemunha. O indício, para resumir, é ponto de partida em confronto com a presunção, e é ponto de chegada em confronto com a prova documental ou testemunhal. Tanto basta, a nosso ver, para que seja impróprio colocá-lo no mesmo nível destas”.¹³⁴

O que difere o indício da prova não é propriamente algum aspecto intrínseco a cada uma dessas figuras ou à sua estrutura própria. Isso porque, se há prova sobre o indício, a distinção deve ser procurada na afirmação a ser provada.¹³⁵

Deixe-se claro que a prova indiciária é uma prova do indício. O que é indireto, nessa perspectiva, é o indício em relação ao fato direto. Como o indício deve ser provado, é pouco mais do que óbvio que sobre ele recai uma prova, que pode ser dita “prova indiciária”. A sua particularidade, em relação à prova do fato direto, está apenas no seu fim, que é o de elucidar um fato indiciário. A prova indiciária não incide sobre fato da causa, mas sobre fato externo, que se liga a algum fato da causa por um raciocínio indutivo lógico. Por meio da prova indiciária são provados fatos indiciários (ou secundários), dos quais se pode deduzir o fato direto.¹³⁶

Mas, ainda cabe estabelecer o significado de presunção.¹³⁷ Como é óbvio, o indício – que é fato – não pode sequer ser aproximado do conceito de presunção. Não obstante, é comum imaginar que a presunção é uma espécie de prova. Se o fato indiciário é o ponto de onde o juiz parte para chegar ao fato direto, para tanto ele deve realizar um raciocínio dedutivo. Portanto, a presunção está muito mais perto do raciocínio judicial do que da prova, compreendida essa em sua acepção tradicional, de meio destinado a demonstrar a verdade de um fato. A presunção, é certo, apoia-se no indício e na prova indiciária, mas não existe sem o raciocínio judicial. Como esclarece Barbosa Moreira, é claro que essa presunção “não constitui, a rigor, meio de prova, ao menos no sentido que se dá a semelhante locução quando se afirma que é meio de prova, v.g., um documento ou o depoimento de uma testemunha. O processo mental que, a partir da afirmação do fato x, permite ao juiz concluir pela afirmação também do fato y, não se afigura assimilável à atitude da instrução, em que se visa a colher elementos para a formação do convencimento judicial. Quando o juiz passa da premissa à conclusão, por meio do raciocínio ‘se ocorreu x, deve ter ocorrido y’, nada de novo surge no plano material, concreto, sensível: a novidade emerge exclusivamente em nível intelectual, in mente iudicis. Seria de todo impróprio dizer que, nesse momento, se adquire mais uma prova: o que se adquire é um novo conhecimento, coisa bem diferente”.¹³⁸

Com efeito, o raciocínio judicial está longe de poder configurar meio de prova.¹³⁹ Mas, se o juiz raciocina a partir do fato indiciário para chegar a uma conclusão, que é a presunção, também é preciso distinguir raciocínio presuntivo e presunção. Se a presunção, como observa GUASP,¹⁴⁰ é o resultado do raciocínio e não o mecanismo que o admite, e nesse está incluído o raciocínio judicial, esse mecanismo somente pode ser a fonte da presunção, e não a presunção em si mesma.¹⁴¹

6.4. Sobre presunção e juízo

Estabelecido o conceito de presunção como o resultado do raciocínio formado a partir do indício e da prova indiciária, ainda resta demonstrar que a presunção não pode ser confundida com o juízo a respeito da procedência ou da improcedência do pedido.

A presunção é um elemento para a formação do juízo, uma vez que ao lado dela podem existir outras presunções ou mesmo provas de fatos diretos. Note-se, por exemplo, que pode haver a presunção de que um ato será praticado, mas a prova produzida indicar que esse ato não constitui ilícito, caso em que o juízo não será de procedência.

Ademais, nada impede que, em determinado caso concreto, sejam provados três fatos indiciários (por exemplo) e realizados três raciocínios presuntivos que apontem para três presunções. A dificuldade que pode ser posta diz respeito a se saber se aqui estamos frente a três presunções ou a uma presunção formada a partir de três fatos indiciários. Porém, essa questão pode ser facilmente resolvida a partir da constatação de que cada fato indiciário exige um raciocínio e, dessa forma, uma presunção. Ora, o fato indiciário somente pode ser levado em conta quando aponta para uma presunção. A existência de três presunções, que podem se somar, não dilui a existência de cada uma delas, mas dá origem a um novo juízo. Esse novo juízo se forma a partir de presunções que podem apontar em uma mesma direção, ou mesmo em direções opostas, como também de provas que recaem sobre fatos diretos.

Aliás, apenas para demonstrar a autonomia da presunção em relação ao juízo sobre o mérito, basta lembrar que uma presunção pode ser somada a outra para formar um juízo de procedência.

Como está claro, o juízo sobre o mérito, assim como a presunção, constitui uma conclusão, e nesse sentido, a conclusão a que o juiz chega após ter raciocinado. Por esse motivo, tanto o juízo

sobre o mérito quanto a presunção constituem “juízos”. A diferença é a de que, em relação ao juízo sobre o mérito, o raciocínio do juiz é muito mais abrangente do que o realizado para o estabelecimento da presunção.

6.5. Juízo sobre o mérito: “juízo final” e “juízo provisório”

Acontece que o juízo sobre o mérito pode se dar no final ou no curso do procedimento. No primeiro caso o juízo admite a plenitude da oportunidade de participação, enquanto que, no outro, ele é formado sem que tenha sido possível o aprofundamento do contraditório. Nessa perspectiva, é correto pensar em “juízo final” e “juízo provisório”.

O “juízo final” é a parte final do raciocínio do julgador, em que se chega a um resultado sobre a pretensão do autor. Fala-se em “juízo final” para distinguir o juízo a respeito da pretensão do autor e aquele formado em relação a um pedido de tutela antecipatória (quando é possível falar em “juízo provisório”). Nesse último caso, como é óbvio, também há juízo, mas não é correto pensar em “juízo final”.

A distinção entre “juízo final” e “juízo provisório”, ao deixar claro que há juízo em relação à tutela final e à tutela antecipatória, demonstra que qualquer um desses juízos pode se fundar em presunções e provas diretas, pouco importando as direções em que apontem. Ou seja, é impossível dizer que o juízo provisório somente pode considerar uma prova ou presunção que aponte em direção ao direito do autor, ou mesmo que esse juízo provisório, para permitir a concessão da tutela antecipatória, não pode ser formado com base em presunção ou prova que prevaleça sobre outra presunção.

Ademais, quando se tem clara a distinção entre esses juízos, fica fácil perceber que, em substância, não há diferença entre a tutela antecipatória e a tutela final,¹⁴² mas apenas entre os juízos que permitem a sua concessão. Ou seja, não há que se pensar que a tutela antecipatória, apenas por ser formada com base em um “juízo provisório”, que constitua uma tutela provisória.

6.6. Juízo sobre o mérito e “juízo instrumental”

Para a formação de um juízo sobre o mérito – que pode ser, conforme visto, um juízo final ou um juízo provisório – devem ser consideradas as provas sobre os fatos diretos e as presunções, além das normas de direito e das chamadas “regras de experiência”. Tomando em consideração, por enquanto, as provas e as presunções, não há como esquecer que essas, até o momento de serem valoradas para a elaboração do juízo sobre o mérito, exigem juízos antecedentes, embora com o fim último de permitir o julgamento do mérito.

Assim, por exemplo, são deferidas provas de fatos diretos e de fatos indiciários, quando obviamente existem decisões, e assim juízos, que têm a particularidade de decidir sobre a oportunidade e adequação da formação de elementos capazes de influir sobre o juízo acerca do mérito. Tais juízos antecedentes, diante da sua indissociável ligação com o juízo sobre o mérito, podem ser chamados de juízos instrumentais. Não porque constituam – eles mesmos – instrumentos para a concretização do juízo sobre o mérito, mas sim porque relacionados à formação de um elemento (a prova) voltado a influir sobre esse juízo (de mérito). Ou seja, embora o instrumento seja a prova, nada impede que se conclua que o juízo feito sobre a sua admissão e produção seja considerado um juízo instrumental.

Não obstante, a presunção, como já dito, também constitui o resultado de um raciocínio – e assim também um juízo – que parte de um indício e da sua prova. Como a presunção também parte de uma prova, ela também depende de um juízo instrumental, embora não constitua um juízo sobre o mérito, mas apenas mais um elemento para o juízo sobre o mérito.

Isso quer dizer que o juízo sobre a prova indiciária é instrumental em relação à presunção, mas que a presunção, por também se destinar à formação do juízo sobre o mérito, é marcada pelo mesmo signo da instrumentalidade. De modo que não é apenas o juízo sobre a admissibilidade e a produção da prova que são instrumentais, mas qualquer juízo que se preste à formação de um

elemento a ser considerado na elaboração do juízo sobre o mérito.

O desejo dessa distinção é evidenciar: i) que o juízo sobre o mérito tem a sua legitimidade dependente da idoneidade dos juízos que lhe antecederam; ii) que a presunção é um juízo e não uma prova; e iii) que a presunção não se confunde com o juízo sobre o mérito (provisório ou final), de modo que podem existir várias presunções e, até mesmo, presunções que apontem em sentidos contrários.

6.7. Normas de juízo e elementos sobre os quais o juízo de mérito incide

O juízo sobre o mérito, conforme demonstrado, é formado a partir de provas e presunções, ou melhor, sobre elementos que se destinam a demonstrar ao juiz um conhecimento que ele não possui, mas que importa para o julgamento sobre o mérito.

Acontece que tais elementos, que são aportes de um conhecimento que chega ao juiz em cada caso concreto, não podem ser confundidos com as chamadas normas de juízo, que são as normas de direito e as regras de experiência.

O juiz, a partir das provas e presunções, julga o mérito com base nas normas de direito e nas regras de experiência, conforme preceitua o art. 375: “O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”.¹⁴³

As regras de experiência não constituem algo que deva ser provado pelas partes, mas sim regras¹⁴⁴ que auxiliam o juiz a valorar a prova e as presunções e a julgar o mérito, situando-se, nessa perspectiva, mais perto das normas de direito do que dos fatos. Porém, com as normas de direito não se confundem, uma vez que constituem a condensação daquilo que é conhecido pelo chamado “homem comum”. Deixe-se claro, ainda que apenas sumariamente, que as regras de experiência são relativas ao conhecimento do juiz em sentido universal, inserido na experiência, e que assim não decorrem do caso concreto ou dos fatos.

As provas e as presunções constituem o material – nesse sentido o objeto – em que o juiz se apoia para julgar o mérito. De acordo com Stein, os meios probatórios e os indícios não têm qualquer parentesco entre si, embora se encontrem no tratamento da apreciação da prova. Segundo o jurista alemão, os meios de prova são declarações, testemunhos no sentido mais amplo, ou estado de coisas que o juiz tenha percebido no processo com o fim de prova, enquanto que “os indícios são fatos, isto é, acontecimentos ou circunstâncias, a partir dos quais, e por meio da experiência, pode-se concluir em outros fatos que estão fora do processo e constituem o objeto da prova”.¹⁴⁵

A ideia de Stein, ao que parece, padece de um pequeno vício, pois as regras de experiência não se projetam sobre indícios – ou fatos indiciários –, mas sim sobre as provas e as presunções. É que as presunções não se identificam com os indícios, mas são os resultados dos raciocínios que neles se baseiam.

As regras de experiência são imprescindíveis para o juiz valorar as presunções e as provas. Isso quer dizer que as regras de experiência incidem sobre objetos destinados a conferir conhecimento para o juiz solucionar o mérito. As presunções e as provas, assim, são elementos formados no caso concreto, enquanto que as regras de experiência permitem ao juiz extrair conclusões a partir delas.

É evidente que as regras de experiência não são provas, mas regras que servem para a compreensão ou valoração das provas e das presunções. Aliás, como o juízo sobre o mérito recai nas provas e nas presunções, e não nas provas e nos indícios, as regras de experiência não atuam apenas quando do julgamento do mérito, mas também quando da elaboração da presunção. Recorde-se que a presunção não se confunde com o juízo de mérito.

Lembre-se que Stein destaca a importância das regras de experiência diante dos indícios,

lembrando que, também aqui – e certamente com maior clareza que em outras áreas, apesar disso ser poucas vezes ressaltado – entra em jogo a experiência, estabelecendo a conexão entre o indício e o fato direto (relevante).¹⁴⁶

Não há dúvida sobre a importância da experiência para a definição de uma presunção, isto é, para a conclusão do raciocínio que parte da prova do fato x para chegar na evidência do fato y. Acontece que, quando do julgamento do mérito, podem existir várias presunções ou mesmo presunções em sentidos contrários. Nesse caso, as várias presunções devem ser valoradas conjuntamente, quando as regras de experiência também são imprescindíveis. Ou seja, as regras de experiência devem incidir sobre os indícios, na formação das presunções, e sobre as presunções, na formação do juízo sobre o mérito.

6.8. Presunção, regra de experiência e fato notório (breve distinção)

Frise-se que as regras de experiência não podem ser confundidas com os fatos notórios.¹⁴⁷ As regras de experiência dizem respeito às noções, generalizações e critérios que fazem parte do senso comum do homem médio e são retiradas da sua experiência de mundo. Por sua vez, o notório é um fato do conhecimento do homem médio – ou mesmo de um grupo restrito, quando o fato diz respeito somente a ele –, mas cuja forma de conhecimento nada tem a ver com senso comum e com o modo como o homem pensa a realidade que o cerca. Por exemplo: um acontecimento político que se tornou de conhecimento público constitui um fato notório, mas não uma regra de experiência.

Por outro lado, as regras de experiência são regras de juízo que se destinam a permitir ao juiz raciocinar sobre os fatos e as provas, enquanto o fato notório é simplesmente um fato – essencial ou secundário – que importa para o autor demonstrar o seu direito. Por isso mesmo, as regras de experiência não se submetem ao ônus da alegação, uma vez que não constituem fatos específicos, como os fatos notórios. Esses últimos, ainda que não precisem ser provados, devem ser afirmados pelo autor, pois constituem fatos que importam para o seu sucesso no processo. Ou seja, o juiz não procura, no fato notório, uma regra de juízo, já que tal fato constitui o objeto sobre o qual o seu raciocínio incide, embora seja excluído do thema probandum.

Por sua vez, a presunção, como já dito, constitui a conclusão do raciocínio judicial (dito presuntivo) que parte do fato indiciário e da sua prova (indiciária). Para o juiz formar a presunção, deduzindo o fato probandum a partir do fato indiciário, raciocina com base nas regras de experiência. Portanto, é bastante clara a distinção entre a presunção e a regra de experiência, pois a última é uma regra que serve para se chegar à primeira (na conclusão ou na presunção).

6.9. Presunções

De natureza controvertida e de função questionada pela doutrina (especialmente a do processo penal), as presunções formam importante capítulo no sistema probatório. Sejam as designadas pelo legislador, sejam as encontradas pelo raciocínio do juiz no caso concreto, é certo que a ideia de presunção liga-se diretamente ao tema da prova, embora pareça dissociar-se da noção que, tradicionalmente, dele é extraída. Contudo, não é difícil imaginar situações em que o juiz não terá elementos capazes de representar nenhum dos fatos componentes do suporte fático que legitimaria a pretensão, mas apenas elementos que em torno deles gravitam, suficientes apenas para induzi-lo (ou por vezes o legislador) a convencer-se de que os fatos diretos (objeto da causa de pedir) efetivamente ocorreram.

A noção de presunção parte da ideia de que o conhecimento de certo fato pode ser induzido pela verificação de um outro, ao qual, normalmente, o primeiro está associado.¹⁴⁸ Ou seja, partindo-se da convicção da ocorrência de determinado fato, pode-se, por dedução lógica, inferir a existência de outro, pois comumente um decorre do outro, ou ambos devem acontecer simultaneamente. Com base nessa raiz (que, conforme será visto adiante, nem sempre está na origem de todas as presunções) é que se admite a dedução de um fato pela prova de outro.

A partir daí, desse conceito elementar, cria-se uma rica doutrina a respeito dessa “prova

crítica”, capaz de facilitar – em situações particulares – os mecanismos de prova de que se serve a parte para trazer sua pretensão a juízo. É importante notar que as presunções assumem papel relevante nesse campo, prestando-se, por vezes, como uma espécie de “redução do módulo de prova”,¹⁴⁹ aplicando técnica de diminuição das exigências legais e judiciais sobre a solidez das provas que seriam necessárias para aceitar um fato como verossímil. Em outras palavras: verificando o legislador ou o juiz que a prova de certo fato é muito difícil ou especialmente sacrificante, poderá servir-se da ideia de presunção para montar um raciocínio capaz de conduzi-lo à conclusão da sua ocorrência, pela verificação do contexto em que normalmente ele incidiria. Como se vê, esse poderoso instrumento é importante aliado do processo para a prova de fatos de difícil verificação – como os fatos futuros, no caso da ação inibitória.

Conforme a inferência do fato probando por meio do fato provado se dê pelo juiz ou pelo legislador, fala-se em presunções judiciais e presunções legais. Essa última categoria comporta, ainda, uma subdivisão, estabelecida entre as presunções relativas (*iuris tantum*) e absolutas (*iuris et de iure*). Costuma-se dizer que as primeiras, e não as presunções absolutas, admitem prova em contrário. Porém, como notou Barbosa Moreira, essa distinção não é precisa, pois o que interessa não é exatamente a possibilidade de prova em contrário, mas sim a relevância da demonstração de que o fato presumido pelo legislador não ocorreu na situação específica.¹⁵⁰

a) Presunções judiciais

Cabe então fixar a atenção na primeira espécie das presunções referidas: as presunções judiciais, também chamadas, por alguns, de presunções simples ou ainda de *praesumptiones hominis*. Tem-se aqui a dedução da ocorrência de um fato pela verificação (prova) de outro, através de raciocínio executado exclusivamente pelo juiz – sem qualquer interferência *a priori* do legislador. Na lição de Proto Pisani, adquirido o conhecimento de um fato secundário por meio de fontes materiais de prova (ou sendo o fato incontroverso em razão de não contestação ou sendo ele “notório”), e elaborado um raciocínio judicial dirigido a dele deduzir o fato principal ignorado, há presunção judicial.¹⁵¹

O conhecimento do fato probando resulta de uma inferência lógica, formulada pelo magistrado a quem é submetida a causa, a partir do conhecimento de outro fato – que se prova nos autos –, ao qual, normalmente, a ocorrência do fato ignorado está ligada. Há, assim, um fato “secundário” (externo à causa de pedir, não pertencente ao material fático da demanda) provado, e, diante da sua ocorrência, extrai-se a conseqüente existência (ou inexistência) do fato “primário” (pertencente à causa de pedir), em que se tinha, efetivamente, interesse. Esse juízo é possível diante de um critério racional indutivo de normalidade ou de probabilidade lógica da coexistência de ambos os fatos. Ou seja, tem-se, no cerne da figura, uma ideia de silogismo: ocorrendo o fato A, sempre deve ocorrer o fato B; verificada a ocorrência do fato A, então também ocorreu o fato B.¹⁵² Ou, com maior precisão, na explicação de Comoglio, Ferri e Taruffo: “existe um fato F, conhecido pelo juiz, que pode ser tido como premissa de uma inferência I, fundada sob um critério C (solidamente constituído por máximas da experiência), a qual permite se atribuir um grau G de correção à asserção pela qual o fato a provar FP é verdadeiro ou falso”.¹⁵³

Como fica claro da análise dos esquemas apresentados, a adequação ou não da inferência lógica está calcada na maior ou menor precisão das premissas utilizadas para subsidiar a conclusão, ou seja, no grau de “certeza” que se tem da efetiva ocorrência do fato secundário e no grau de vinculação que existe entre a verificação desse e a conseqüente e necessária existência do fato primário (ou, utilizando o esquema de Comoglio, Ferri e Taruffo, na consistência do critério C e, por via lógica, do grau G). De modo que o grau de credibilidade da presunção judicial repousa na convicção da procedência da ilação formulada.¹⁵⁴

Dessa necessidade de um juízo intermediário entre a prova do fato ocorrido e a conclusão da existência de outro fato, a doutrina pergunta se as presunções têm natureza probatória. Ora, como demonstrado no capítulo anterior, as presunções constituem o resultado do raciocínio judicial que parte do indício (do fato indiciário) e de sua prova (indiciária), o que quer dizer que a presunção é um juízo (embora não o juízo sobre o mérito), e não uma prova ou um fato.

Em vista disso, algumas peculiaridades relativas às presunções judiciais merecem particular atenção. Inicialmente, conforme pondera Guasp, em virtude da natureza de processo mental lógico que conforma as presunções, não se cogita de aplicar-lhes as regras normais sobre lugar, tempo e forma para a sua produção.¹⁵⁵

Além disso, como já observado, para o exame do cabimento ou não da prova (documental, testemunhal etc.) do indício (do fato secundário), o juiz não poderá se basear na presença dessa alegação de fato dentre os argumentos da petição inicial ou da resposta do réu, ou mesmo na ausência de controvérsia específica sobre esse fato (não impugnação específica). Como visto, porque o fato secundário é fato externo à demanda, é certo que tais situações sempre podem apresentar-se (sendo mesmo da essência do instituto que ocorram), razão pela qual não podem constituir-se em óbice à produção de tal prova.

De outra parte, poderá o juiz indeferir a produção da prova do indício (do qual se pretende obter a presunção) se verificar que, ainda que se tenha esse fato como provado, o fato primário não lhe segue como consequência.¹⁵⁶ Lembre-se que a idoneidade da ponte mental hipotética para a certeza do fato que se pretende efetivamente ter como provado é elemento imprescindível para a garantia do raciocínio. Porém, não é preciso que o fato probando seja a única consequência do fato indiciário para a procedência da demanda, uma vez que, como se verá no final desse item, as presunções podem ser somadas.

Ademais, também pode o juiz indeferir a produção da prova do indício quando o meio que a parte pretender utilizar for inadequado (por exemplo, quando se exija, para a prova do indício, certo meio específico, como o documental, e a parte pretenda comprová-lo por outra via). Nesse caso, o silogismo de inferência será inadequado porque há vício na prova do fato-origem (secundário) do raciocínio.

Finalmente, releve ponderar que o valor da presunção assenta-se na sua capacidade de satisfazer os seus aspectos intensivo e extensivo.¹⁵⁷ O critério extensivo pergunta se a presunção é apta para demonstrar a totalidade do fato probando (isto é, do fato principal, que se pretende provar). Para o critério intensivo importa saber se do fato indiciário pode decorrer outro fato que não o que se pretende provar. Sucede, então, que a demonstração, pela parte contrária, de que o indício não cobre a totalidade do fato probando, ou ainda de que do fato secundário podem advir outros fatos que não apenas o fato principal, é elemento suficiente para abalar a credibilidade da presunção formada –¹⁵⁸ e quanto mais forte se torna essa demonstração, menos razoável se apresenta a presunção.

Prosseguindo nesse raciocínio, é possível concluir, embora em outra direção, que as presunções podem somar-se – quando convergem para a mesma conclusão – para formar o juízo sobre o mérito. As presunções não se confundem com os indícios, uma vez que as primeiras devem ser valoradas para a formação do juízo de mérito, ao passo que o indício e a prova indiciária devem ser valorados para a elaboração da presunção.

Quando uma presunção pode colaborar para demonstrar o fato direto, ela evidentemente pode ser somada a outra presunção para formar um juízo de procedência, embora seja necessário deixar claro que, para a elaboração desse juízo de procedência, não é imprescindível somar várias presunções. Uma única presunção, dependendo do caso concreto, pode ser suficiente para formar a convicção do juiz a respeito da procedência do pedido. Entretanto, ao existir apenas uma presunção, essa deve ser capaz de formar um juízo de procedência que possa ser plenamente justificável. Em outros termos, é possível dizer que, tratando-se de apenas uma presunção, o juiz deve valorá-la com extremo rigor.¹⁵⁹

No raciocínio presuntivo, como já explicado, o juiz parte de um indício e da prova indiciária para chegar ao fato probando, enquanto que a formação do juízo de mérito depende da valoração da prova do fato direto e da presunção formada a partir da prova do indício. O juiz, ao raciocinar sobre a presunção ou ao raciocinar sobre o mérito, baseia-se nas regras de experiência, que são imprescindíveis não apenas para a verificação da presunção a partir do indício, mas também para a análise do mérito com base na própria presunção.

Frise-se que a presunção judicial não exige que a regra de experiência faça concluir, de modo preciso e absoluto, que do fato indiciário decorra o fato probando. Isso, aliás, diante da possibilidade de soma ou contradição entre as presunções judiciais, é bastante evidente. Contudo, nada pode impedir, em casos excepcionais, que o juiz forme um juízo de procedência a partir de presunções que apontem apenas para uma “verossimilhança preponderante”.

b) Presunções legais relativas

Os princípios elementares acima estudados não recebem alteração substancial quando se passa do estudo das presunções judiciais para o das presunções legais. A variação essencial que se verifica está em que a formação do silogismo racional indutivo não é feita pelo juiz da causa, mas sim pelo legislador.

A presunção relativa parte de premissa semelhante a que autoriza a presunção judicial.¹⁶⁰ Escreve Barbosa Moreira: “Numa e noutra, estabelece-se entre dois fatos certa relação que permite, verificado o primeiro, afirmar (ao menos como provável) a ocorrência do segundo, pelo simples motivo de andarem normalmente juntos (...) A diferença capital reside em que, numa hipótese, se deixa ao órgão judicial o estabelecimento da correlação entre os dois fatos, o conhecido e o desconhecido, ao passo que, na outra, é o próprio legislador quem dá como pressuposta a correlação, excluindo, em certa medida, a valoração do juiz. Em certa medida, reitera-se: pois resta a possibilidade de que venham aos autos elementos capazes de demonstrar que, naquele caso concreto, não existe o nexo, tendo-se passado as coisas de modo diverso do costumeiro; e ao órgão judicial, naturalmente, competirá valorar a prova colhida, a fim de verificar se ela tem ou não suficiente força persuasiva para afastar a presunção”.¹⁶¹

Mas, na presunção relativa, ainda que o legislador tenha se fundado em um tipo de raciocínio semelhante ao que o juiz desenvolve para chegar em uma presunção judicial, o certo é que essa última é consequência lógica, enquanto que a primeira é consequência jurídica. Portanto, se a presunção judicial é um mecanismo de convencimento do juiz, a presunção relativa nada mais é do que a imposição de um dever de dividir o ônus da prova de determinado modo.¹⁶²

Como diz o art. 373, caput, do CPC, ao autor incumbe a prova do fato constitutivo e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.¹⁶³ Isso significa que o ônus da prova é normalmente distribuído consoante a posição da parte no processo. Porém, quando sobre determinado fato incide uma presunção legal relativa, a parte a quem essa presunção prejudica fica com o ônus de provar o contrário (do estabelecido na presunção), pouco importando a sua posição no processo. Essa “distribuição” do ônus da prova não é mais feita com base em um critério processual, mas sim a partir de uma situação que caracteriza determinado sujeito perante o direito material.¹⁶⁴ Nesse sentido, é possível compreender que as presunções relativas representam “uma das técnicas adotadas pelo legislador para qualificar como impeditiva, e não constitutiva, a relevância de um fato no âmbito da específica hipótese (fatispecie) legal abstrata”.¹⁶⁵

Como se vê, a presunção legal, nessa perspectiva, assume a função de alterar o critério para a distribuição do ônus da prova, demonstrando que o direito material não pode ser ignorado nessa área. Fala-se em critério de distribuição e não em inversão do ônus da prova, pois, como acentua Barbosa Moreira, não se trata propriamente de inversão do ônus da prova, já que pode ocorrer que a imputação do onus probandi, decorrente da presunção, coincida perfeitamente com a regra de distribuição “normal” do ônus da prova.¹⁶⁶

Ademais, conforme advertiu Carnelutti, a presunção relativa apenas opera uma atenuação, uma facilitação da prova: a parte que teria de provar um fato, cuja prova é difícil ou complexa, precisa, por determinação de lei, comprovar apenas outro fato (de prova mais simples e fácil), ao qual o primeiro se liga. Mas, o onus probandi – ao menos em relação ao fato indiciário –, obviamente permanece sendo da parte a quem a presunção beneficia.¹⁶⁷ Nessa linha, porque a presunção relativa não opera a exoneração do ônus da prova, mas sim a sua facilitação, também não seria correto pensar em inversão do ônus da prova. Novamente, pode-se delinear aqui uma tendência, fixada pelo legislador, de facilitar a prova. Aceita-se a prefixação de determinados

critérios pelo direito material, sob o pressuposto de que outra orientação poderia frustrar a tutela jurisdicional acaso necessária.

Assim, e para que seja possível contribuir com maior precisão, parece adequado simplesmente afirmar que a presunção relativa considera um fato provado, mas abre oportunidade para que ele seja provado em contrário pela parte que – na perspectiva da regra geral do art. 373 do CPC – não teria o ônus da prova, com a advertência de que a presunção relativa não se limita a simplesmente distribuir o ônus da prova, mas sim a fixar as consequências jurídicas da ausência de prova contrária ao fato presumido.¹⁶⁸ Melhor explicando: no caso de presunção relativa, a ausência de prova não conduz apenas a um resultado desfavorável ao onerado, mas sim a uma determinada consequência jurídica pré-estabelecida pela regra que fixou a própria presunção relativa.

c) Presunções legais absolutas

Resta analisar, ainda, a chamada presunção absoluta – também conhecida como presunção *iuris et de iure*. A figura liga-se diretamente ao direito material, não guardando referência direta com o direito processual. Aqui, a probabilidade de que um fato seja indício de outro, conduz o legislador a transformar o fato indiciário do fato principal no próprio fato principal, agregando diretamente a ele a produção do efeito jurídico e relegando o fato principal ao nível de motivo ou de ratio.¹⁶⁹

Na verdade, o raciocínio presuntivo, na hipótese da presunção absoluta, fica apenas como suposto – como mera explicação da existência da figura –, sendo totalmente irrelevante para as situações concretas em que será aplicada. Uma vez fixada a hipótese normativa abstrata, a presunção desvincula-se completamente do raciocínio que a autoriza, incidindo no caso concreto independentemente de qualquer valoração lógica ulterior. Ou seja, a presunção desprende-se totalmente da razão da sua existência, e a lógica que subsidiou a sua previsão deixa de ter qualquer relevância em juízo.¹⁷⁰

Daí se explica a razão pela qual, em face das presunções absolutas, toda prova em contrário ao silogismo é irrelevante. É que a avaliação fática, nesse caso, não importa para o juiz, pois as conclusões hipotéticas lançadas na lei são a ele vinculativas. Diante de uma presunção absoluta, todo tipo de prova se torna inútil. Tanto a que pretenda reforçar a conclusão, quanto a que deseje demonstrar que a presunção parte de um silogismo falso.¹⁷¹ Toda espécie de contraprova ou de prova concorrente é irrelevante, na medida em que o suporte fático do silogismo, embora tenha sido importante para a sua fixação como hipótese normativa, deixou de ter qualquer significado para o caso concreto.

Por isso, tem-se como brilhante a distinção elaborada por Barbosa Moreira entre a presunção relativa e a absoluta: “naquela [na presunção relativa], o que se dispensa é apenas a prova de certo fato; nesta [na presunção absoluta], dispensa-se o próprio fato, em si mesmo”.¹⁷² Aqui, realmente, a ligação lógica entre os fatos (indício e fato principal) é despicienda e irrelevante. Para a validade da presunção imposta pela lei, nenhuma outra indagação é permitida ao juiz, nem a de questionar as premissas em que se embasa a presunção, nem mesmo a de verificar se, no caso concreto, permanece válida a suposição do legislador.¹⁷³

Essa negativa de valoração pelo juiz decorre da simples constatação de que, na presunção absoluta, altera-se, em última análise, o próprio suporte normativo que rege a situação. Ou seja, a presunção absoluta não importa em uma forma de “redistribuição” do ônus da prova, mas em uma influência na própria regra de direito material, que passa a incorporar em sua hipótese descritiva os novos elementos contidos na norma que estabelece a presunção absoluta.¹⁷⁴ Essa é a razão pela qual não se admite, diante das presunções absolutas, a prova em contrário, nem mesmo se considera viável que o juiz afaste essa presunção diante da completa ilogicidade do silogismo. Isso tudo pouco importa, já que a própria regra de direito material vem conformada pela presunção, de onde resulta que, mesmo diante da comprovação fática em contrário, essa é a situação qualificada pelo direito material.

Aqui, como resulta evidente dos aspectos já examinados, a presunção desvincula-se

completamente do tema da prova, para incidir no campo do direito material. E certo, assim, que essa previsão somente pode decorrer de alguma disposição normativa. Porém, se a presunção absoluta jamais admite prova em contrário, obviamente é possível questionar a sua constitucionalidade no caso de a norma derivada da regra abstrata, em conjugação com a presunção legal absoluta, violar a Constituição Federal.¹⁷⁵

6.10. Conflito entre presunções

É preciso perceber, ainda, que a lógica não exclui a possibilidade de conflitos entre presunções. Essa situação ocorre quando cada uma das partes tem uma presunção em seu favor.

Sendo uma das presunções legal absoluta e a outra não, há de prevalecer a primeira sobre a segunda. Isso porque a presunção absoluta não admite prova em contrário, não aceitando seu afastamento pela convicção do juiz de que ela é imprecisa ou ilógica.

Se o conflito se estabelece entre uma presunção legal relativa e uma presunção judicial, a solução do problema caminhará pela avaliação excludente de uma das duas presunções. Ou o juiz entenderá que a presunção judicial constitui prova contrária à determinação contida na presunção legal relativa, afastando essa, ou concluirá que a presunção judicial não é elemento forte o suficiente para afastar a presunção relativa.

Caso o conflito se estabeleça entre presunções da mesma espécie (absoluta com absoluta, relativa com relativa ou judicial com judicial), não haverá outra saída senão buscar a sua solução nas circunstâncias do caso concreto. Nesse caso, o juiz deverá, motivadamente, acolher uma das presunções, afastando a outra. Somente o juiz, no caso concreto, diante dos elementos fáticos e jurídicos que circundam a controvérsia posta à sua solução, poderá verificar qual das presunções merecerá prevalecer.¹⁷⁶

Note-se que, quando se pensa em conflito entre presunções, torna-se fácil evidenciar que as presunções são elementos destinados à formação do juízo de mérito e, assim, não se confundem os indícios.

7. A prova na ação inibitória

7.1. A necessidade de alteração de paradigma para se compreender a prova em face da ação inibitória

A ação inibitória tem por fim impedir a prática, a repetição ou a continuação do ilícito. Trata-se, assim, de uma ação voltada para o futuro, que se dissocia, nesse sentido, da ação ressarcitória, que objetiva verificar se o réu deve responder pelo dano produzido e, então, impor a sanção ressarcitória.¹⁷⁷

O processo civil, na sua gênese, foi concebido para atender o passado ou, mais precisamente, para remediar a violação praticada. Essa ideia tem íntima relação com a concepção liberal clássica de jurisdição. Tal concepção, fortemente marcada pelos valores do Estado liberal, reflete a tendência de privilegiar as liberdades individuais em detrimento dos poderes de intervenção estatal.¹⁷⁸ Temendo-se a interferência do Estado na esfera jurídica dos particulares, não se dava ao juiz a possibilidade de agir antes de o particular ter violado a lei. Ou seja, qualquer ingerência judicial nas relações privadas, sem que houvesse sido violado um direito (e, portanto, sem que houvesse “motivo”), constituiria um atentado contra as liberdades individuais. Não é por outro motivo que a doutrina italiana mais antiga (embora já dos anos 50 do século passado) chegou a dizer que a tutela inibitória antecedente a qualquer ilícito seria “la più preoccupante, como è di tutte le prevenzioni che possono eccessivamente limitare l’umana autonomia”.¹⁷⁹

Não é possível esquecer que tal concepção de jurisdição é subordinada à prevalência funcional da noção de direito subjetivo privado. Nessa época, diante de uma visão privatista do processo, não havia separação entre direito processual e direito material. Portanto, a jurisdição, que somente podia entrar em ação após a violação da lei, não poderia servir para outra coisa senão

garantir a reintegração do direito subjetivo violado, e assim atuar apenas dirigida para o passado.¹⁸⁰

Contudo, com o passar do tempo, modificadas as funções do Estado – que deixou de ser visto como um “inimigo” – e evidenciada a autonomia do direito processual em relação ao direito material, a necessidade de estruturação de técnicas capazes de evitar a violação dos direitos passou a ser vista como uma consequência lógica do próprio dever de proteção estatal contra a agressão dos direitos.

É importante frisar que esses direitos também se revestiram de forma diversa daquela que era própria ao Estado liberal clássico, assumindo natureza frequentemente não-patrimonial ou, muitas vezes, incompatível com a tutela ressarcitória. Além disso, como a função preventiva estatal migrou da esfera administrativa para a jurisdicional, na medida em que se passou a dar ao juiz um poder que antes era apenas do administrador, solidificou-se a noção de que todos têm direito de exigir do judiciário uma tutela capaz de impedir a violação dos direitos.

A própria Constituição Federal de 1988, no seu art. 5.o, XXXV, deixou claro que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário.¹⁸¹ Antes, porém, a própria prática forense (ao admitir o uso anômalo da ação cautelar inominada) e a melhor doutrina estavam cientes da necessidade de tutela jurisdicional preventiva. Como advertiu Ada Pellegrini Grinover, a atividade judicial, diante da tutela preventiva, ocorre “a priori, com o objetivo de evitar o dano que deriva da ameaça de lesão a um direito, antes que esta se consume. Foi justamente salientado que, na tutela preventiva, o interesse de agir não decorre do prejuízo, mas do perigo de prejuízo jurídico: em outras palavras, da ameaça de lesão ou, mais precisamente, frente a sinais inequívocos de sua incidência”.¹⁸² Elogiando essa forma de tutela, completou a processualista: “A superioridade da tutela preventiva foi recentemente assinalada, frente à inviabilidade frequente da modalidade tradicional de tutela que consiste na aplicação de sanções, quer sob a forma primária de restituição ao estado anterior, quer sob as formas secundárias da reparação ou do ressarcimento. E a gravidade do problema, afirmou-se, aumenta de intensidade quando se passa das relações jurídicas de caráter patrimonial àquelas categorias em que se reconhece ao homem uma situação de vantagem insuscetível de traduzir-se em termos econômicos: os direitos da personalidade”.¹⁸³

Porém, não obstante a óbvia importância da tutela preventiva, a preocupação da doutrina com a tutela inibitória – não apenas brasileira, mas também estrangeira – é recente, especialmente quando se considera a grande atenção que os processualistas sempre dispensaram à tutela repressiva.¹⁸⁴ Em razão disso, é natural que os vários institutos do direito processual ainda não tenham se adaptado a essa nova modalidade de tutela, o que é particularmente grave quando se pensa no tema da prova.

Basta lembrar que a doutrina construiu a teoria da prova a partir da premissa de que o processo de conhecimento deve permitir a reconstrução dos fatos passados. Contudo, isso não pode ser alcançado pelo processo, nem pode ser, obviamente, o intento da prova na ação inibitória, pela simples razão de que ninguém pode supor que um fato futuro pode ser diretamente provado.

A questão apresenta contornos ainda mais intrincados quando se constata a mudança radical que essa percepção impõe ao processo. Suponha-se a situação de alguém que tema a violação do seu direito à honra e, assim, proponha ação inibitória e requeira tutela antecipada inibitória, que reste concedida para proibir a ré de divulgar determinada notícia. E ainda que, atendida a ordem judicial, a ré apresente contestação afirmando que jamais cogitou de veicular tal notícia. Seria possível dizer que houve, nesse caso, reconhecimento da procedência do pedido? Como saber se a ré não divulgou a notícia em função da efetividade da tutela antecipada ou porque jamais pretendia divulgar a notícia?

Como se vê, o tema da prova, diante da ação inibitória, requer uma reflexão muito especial e atenta, que deve caminhar na linha do que dissemos até agora nesses Comentários, exigindo uma completa revisão da função que se costuma atribuir à prova.¹⁸⁵

7.2. A ação inibitória, o dano e a culpa

Desde logo, é possível dizer que, em razão da própria finalidade da ação inibitória, não há sentido em exigir a demonstração de dano. Aliás, não é porque o ato contrário ao direito (o ilícito) já foi praticado, que se exigirá a demonstração de dano. Isso pelo simples motivo de que ato contrário ao direito e dano não se confundem. O dano é consequência eventual do ilícito, e não necessária. A confusão entre um e outro deriva do fato de que, em uma perspectiva meramente cronológica, o ato contrário ao direito e o dano muitas vezes surgem no mesmo instante.¹⁸⁶ Pontes De Miranda já atinava para essa situação, deixando claro que “pode haver delito, ou melhor, ato ilícito, sem dano, e, pois, sem que se possa reclamar a reparação”.¹⁸⁷

Embora normalmente o ilícito se exteriorize pelo dano gerado, é certo que a identificação entre uma figura e outra é descabida. Para o cabimento da ação inibitória, além de não ser necessária a prática do dano (como é óbvio), não é sequer preciso a sua probabilidade. Basta a probabilidade de ato contrário ao direito, ou melhor, basta o temor da prática de um ilícito. Nesse sentido, adequadamente explica Aldo Frignani¹⁸⁸: “A ação inibitória é caracterizada pela presença de três condições: uma positiva – perigo de prejuízo futuro – e duas negativas – desnecessidade do dano e da culpa (...). Inicialmente a ação inibitória era ligada ao ‘dano’ – aí também compreendidas as ‘moléstias’ que impedem a fruição real – e a inibitória servia para evitá-lo. (...) Apenas mais tarde se reconheceu que a tutela inibitória serve para prevenir o ato ilícito como fonte produtiva de dano. Hoje se reconhece a exigência de prevenção também contra a simples violação de uma norma que tutela um ‘interesse’ – prejuízo a um interesse tutelado (...)”.¹⁸⁹ Realmente, o perigo, próprio à ação inibitória, não se liga ao dano, mas apenas ao ato contrário ao direito. Ou melhor, o que se teme é a probabilidade de ato contrário ao direito.

Por outro lado, como o dano não importa para a ação inibitória, não é preciso demonstrar, por consequência lógica, a culpa.¹⁹⁰ Lembre-se que a culpa é elemento definidor da responsabilidade pelo dano. De modo que ela só aparece como necessária na ação ressarcitória, e isso quando o dever de ressarcir não dispensa a sua presença, como acontece nas hipóteses de responsabilidade objetiva.

Se a ação inibitória se dirige ao futuro – e assim dispensa o dano –, não há como pensar em culpa. Ou melhor, se a culpa é critério para a imputação ressarcitória,¹⁹¹ não há dúvida que a ação inibitória a dispensa.

Mesmo que se pudesse admitir que essa ação exige a probabilidade de dano (e não de ato contrário ao direito), não haveria como pensar em culpa, pois não há como valorar subjetivamente um comportamento futuro.¹⁹² Note-se, aliás, que se a ação tem o objetivo de evitar o ilícito, não há razão para investigar a culpa daquele que ameaça praticá-lo. Com efeito, pouco importa se há culpa na ameaça da prática de ilícito. Esteja de má-fé ou não o agente, o direito de evitá-lo é inegável.¹⁹³

Como esclarece Pontes De Miranda, “a pretensão e a ação de abstenção não são pretensão e ação ex delicto. Nem a culpa lhe é pressuposto necessário. Se a culpa existe, é plus. Só se exige o ser contrário a direito o ato que se teme, ou cuja continuação se tem por fito evitar”.¹⁹⁴ Vale dizer: esse plus é importante apenas na medida em que se pretenda, ao lado da tutela inibitória, a indenização por alguma lesão sofrida. Fora daí, é totalmente irrelevante a indagação sobre culpa.

Conclui-se, portanto, que na ação inibitória não há espaço para a alegação – e, conseqüentemente, para a prova – do dano e da culpa. O thema decidendum fica restrito à questão da futura ocorrência de um ilícito, e assim pode ser decomposto em dois elementos: i) a ameaça da prática de ato e ii) a sua ilicitude.

7.3. A ameaça e a ilicitude

Embora sejam dois os elementos da cognição judicial na ação inibitória (ameaça e ilicitude), a noção da licitude ou não de certa conduta é juízo de valor, que depende, via de regra, da mera comparação do ato afirmado com o ordenamento jurídico. Vale dizer, o conceito de ilicitude se

extraí da comparação da conduta (ainda que hipotética) com as regras existentes no ordenamento jurídico –, as quais qualificam as condutas como lícitas ou ilícitas.¹⁹⁵ Por essa razão, a afirmação de ilicitude da conduta, normalmente, não dependerá de prova, reduzindo-se, no mais das vezes, à análise de uma questão de direito – que obviamente não depende de prova.¹⁹⁶

Além disso, importa lembrar que a grande maioria dos direitos que exigem tutela inibitória (embora essa possa ser conferida a quaisquer tipos de direitos), a exemplo dos direitos da personalidade, do meio ambiente, da saúde pública etc., são direitos absolutos – no sentido de potestativos, que independem de qualquer colaboração de vontade de outra pessoa –, irrenunciáveis e intransmissíveis.¹⁹⁷ Ademais, são direitos inatos à pessoa humana, ou seja, direitos pertencentes a toda pessoa humana, independentemente de outra condição.¹⁹⁸

Daí resulta a constatação de que esses direitos são insuscetíveis de oposição. Ninguém jamais poderá negar a sua existência, ou melhor: não dependem de prova, até porque essa prova seria a singela comprovação da existência da pessoa física que pretende a tutela jurisdicional – o que é pressuposto para a própria existência da relação jurídica processual.

Mas, em relação ao outro requisito exigido para a tutela inibitória, a questão não é tão simples assim, pois a ameaça é questão de fato. Se a ação inibitória exige a prova da ameaça de lesão, é correto indagar sobre o grau de convicção que essa prova deve gerar para a concessão da tutela inibitória (final ou antecipada).

De um lado, a excessiva tolerância com o requisito da ameaça acarretará a expansão desmesurada da tutela inibitória, que passará a servir como paliativo para a falta de eficácia social das leis,¹⁹⁹ conduzindo à sua desfiguração. De outro, a necessidade de uma demonstração irretorquível da ameaça poderá levar à exigência de “prova impossível”, frustrando todas as suas expectativas.

Assim, antes de mais nada, é adequado verificar como a doutrina tem tratado da questão da prova da ameaça em face das tradicionais, e há muito conhecidas, ações de mandado de segurança e de interdito proibitório.

7.4. A questão da prova da ameaça diante do mandado de segurança e do interdito proibitório

Como se percebe, a questão da prova da ameaça não é nova.²⁰⁰ A doutrina e os tribunais, diante do mandado de segurança, são unânicos em exigir, para a prova da ameaça de lesão (a direito líquido e certo), elementos objetivos que indiquem a efetiva possibilidade de infração ao direito. Segundo Caio Tácito, “o mandado de segurança preventivo tem, como pressuposto necessário, a existência de ameaça a direito líquido e certo, que importe justo receio de que este venha ter intensidade bastante para gerar o elemento subjetivo (justo receio), um e outro sintomáticos da ilegalidade ou abuso de poder virtual ou potencial. Não é suficiente o temor ou receio de que a autoridade exorbite de seus poderes. Para que esse receio se torne justo, é mister que a autoridade tenha manifestado objetivamente, por meio de atos preparatórios ou de indícios razoáveis, a tendência de praticar atos ou omitir-se a fazê-los, de tal forma que, a consumir-se este propósito, a lesão do direito se torne efetiva. Assim como na violência consumada, a que o juiz atende reparando o direito, também na ameaça ou expectativa de violência, ter-se-á sempre um dado objetivo que se caracteriza no ato ou omissão da autoridade”.²⁰¹ Celso Agrícola Barbi chega a criticar a expressão “justo receio”, utilizada pela Lei 1.533/1951, afirmando que esse conceito é puramente subjetivo, não podendo ser avaliado pelo Judiciário. O que importa, no seu entender, é o elemento objetivo desse receio, que seria a ameaça. Diz ele: “A nosso ver, sem descumprir a lei, pode-se introduzir um critério objetivo na apreciação da ameaça; teremos então que o ‘receio’ deve ser considerado ‘justo’ quando a ‘ameaça’ de lesão revestir-se de ‘determinadas características’. E estas são justamente as constantes da citada Declaração do Congresso Internacional [ver nota de rodapé acima], isto é, a ‘ameaça’ deve ser ‘objetiva e atual’. Entendemos que a ‘ameaça’ será ‘objetiva’ quando ‘real’, traduzida por fatos e atos, e não por meras suposições; e será ‘atual’ se existir no momento, não bastando que tenha existido em outros tempos e haja desaparecido”. Diante dessa fundamentação, conclui o saudoso processualista mineiro: “A

‘ameaça’ que tiver essas duas características, segundo o prudente arbítrio do juiz, será então capaz de produzir o ‘justo receio’, a que se refere a lei. Na falta de algum daqueles requisitos, a ameaça será inábil para causar a modalidade de receio que a legislação exige para justificar o ingresso em juízo”.²⁰²

Essa mesma conclusão vem sendo afirmada pelos tribunais.²⁰³ Analisando-a, observou Alfredo Buzaid que “o mandado de segurança preventivo tem por escopo obstar a que se consume uma ameaça real, consistente em ato ou omissão ilegal ou de abuso de poder, qualquer que seja a autoridade; a ameaça há de ser individuada e pôr em risco direito líquido e certo de determinada pessoa. Por isso não se presta o mandado de segurança à obtenção de sentença preventiva genérica, aplicável a todos os casos futuros da mesma espécie”.²⁰⁴

Perante o interdito proibitório as soluções são as mesmas. Pontes De Miranda, em comentários ao art. 932 do Código de Processo Civil/1973 (art. 567 do CPC/2015), afirma que, para o autor ter “receio”, deve “ter conhecimento de fatos ou circunstâncias que lhe façam suspeitar de que o réu o vai molestar na posse. Quem receia tem de encobrir-se (re-celare), porque teme”. E, em adição a essa advertência introdutória, salienta que “justo receio é o receio que se não reduz a simples suspeita, a simples temor subjetivo. É preciso que exista alguma fundamentação dele. Quem receia, sem razão para recear, receia injustamente”.²⁰⁵

Na mesma direção, sublinha Adroaldo Furtado Fabrício que “o justo receio, de um lado, é o temor justificado, no sentido de estar embasado em fatos exteriores, em dados objetivos. Nesse enfoque, não basta como requisito para obtenção do mandado proibitório o receio infundado, estritamente subjetivo – ainda que existente. Por tibieza de temperamento ou até por deformação psíquica pode alguém tomar como ameaça à posse o que não passa de maus modos de um vizinho incivil. O receio pode existir, mas é infundado, porque não se ancora em fatos objetivos caracterizadores de uma verdadeira ameaça. Não importa essa observação em endosso à tese segundo a qual a ameaça apenas verbal não basta, por não estar no ‘domínio concreto dos fatos’: palavras também são fatos, e possivelmente mais minazes do que outros quaisquer. O que importa é a seriedade da ameaça, sua credibilidade, sua aptidão para infundir num espírito normal o estado de receio”.²⁰⁶

Essa mesma ideia vem orientando os tribunais. Decidiu o Tribunal de Justiça da Bahia, por exemplo, que não se deve “confundir simples receio com justo receio. Aquele se confunde com mera preocupação ou apreensão; este, por sua vez, decorre de circunstâncias anteriores, graves, autorizadoras de justificado temor de moléstia à posse, calçado em dados objetivos, devidamente comprovados, extrapolando o campo estritamente subjetivo”.²⁰⁷

Como se vê, a tendência da doutrina e dos tribunais é exigir – tanto para o mandado de segurança preventivo, como para o interdito proibitório – a caracterização da ameaça com base em dados objetivos. Em suma: o entendimento é de que o autor deve demonstrar, a partir de fatos, a ocorrência de efetiva ameaça de lesão a direito, não bastando o simples temor subjetivo.

7.5. A prova da ameaça no direito estrangeiro

Frignani,²⁰⁸ ao tratar da injunction – própria ao direito anglo-saxão – e ressaltar a importância da sua função preventiva (de evitar a prática do ilícito), faz expressa referência à lição de De Funiak, que se aproxima bastante do que é dito pela doutrina brasileira em relação à ameaça no mandado de segurança e no interdito proibitório. Com efeito, para justificar o acesso à equity e, mais do que isso, para viabilizar a concessão da injunction antes da prática de qualquer ilícito (e não apenas para evitar a sua repetição ou continuação), De Funiak diz que deve haver uma “reasonable probability” de violação, quando a intenção deve ter sido claramente manifestada, não sendo suficiente a mera possibilidade de violação (When there is reasonable probability of injury, when the intention to do the wrong has clearly been manifested, equity at once interferes. However, mere idle words or mere possibility of injury do not suffice ...).²⁰⁹

Adverte Frignani que a injunction concedida com base nesse pressuposto é chamada de quia timet, de acordo com uma expressão latina encontrada nos formulários dos antigos writs. Essa

expressão, de origem latina, está nos writs pela razão de que, na Inglaterra, a língua jurídica foi, por muitos séculos, a latina.²¹⁰ Mas, o que importa é que a tomada de empréstimo dessa expressão, por fazer parte da essência preventiva dos writs, possui alta carga simbólica, sendo fundamental para significar a função preventiva dessa manifestação das injunctions.

Analisando o texto de De Funiak, afirma Frignani que nas palavras do jurista americano “estão contidos in nuce os pressupostos essenciais para a concessão da injunction a título preventivo: é necessário, realmente, que exista uma razoável probabilidade (reasonable probability) de que o ilícito venha a existir, e não basta, ao contrário, uma simples possibilidade (mere possibility). Naturalmente, segundo uma abordagem que no mundo da common law se mostra peculiar, caberá ao juiz avaliar caso a caso a razoabilidade do ‘temor’ que um ilícito venha a ser cometido, já que não existem nem na lei escrita (statutes) nem na common law, normas de onde se possa retirar, em via geral e apriorística, uma definição da reasonable probability.”²¹¹

Como se vê, a tutela preventiva, também na common law, é subordinada a uma intenção clara de violação, ou a uma “reasonable probability”, que pode ser equiparada à ideia que ressaí de “justo receio” no Brasil.

Por outro lado, a solução de deixar a critério do juiz a análise da presença da reasonableness parece ser a única viável, pois seria impossível ao legislador pensar em todos os casos de “razoável probabilidade” (ou “justo receio”), ou mesmo em um esquema lógico e abstrato capaz de apreender, na inteireza, essa contingência.²¹² Não é por outra razão que esse também foi o caminho tomado pelo nosso sistema jurídico.

É certo que essa opção, embora possibilite a adequada apreciação da casuística concreta, abre espaço para arbitrariedades e inseguranças. Entretanto, e apesar desse risco, não há melhor alternativa para o problema. É necessário e imperioso, diante da infinidade de situações materiais que podem se apresentar, e do inevitável descompasso entre a legislação e a realidade, confiar na figura do juiz, pois a ele foi dada a missão de fazer atuar o direito com justiça.²¹³

Na Itália não foi encontrada melhor saída. Contudo, Frignani ressalta a dificuldade da prova nos casos em que a ação inibitória é utilizada antes da prática ou do início do ilícito, vale dizer, quando a ação inibitória tem o objetivo de evitar o ilícito, ainda que nenhum ato da mesma natureza tenha sido praticado ou iniciado (ou seja, quando a inibitória não objetiva apenas impedir a repetição ou a continuação do ilícito). Sobre a prova nessa modalidade de ação inibitória, diz Frignani: “Problema um pouco mais delicado é a possibilidade de invocar a inibitória quando a atividade ilícita ainda não ocorreu; quando, pois, a conduta não se aperfeiçoou, mas foram postos em ação apenas preparativos para o ilícito futuro. A nosso ver, a peculiaridade dessa hipótese, em relação às outras [relativas à repetição ou a continuação do ilícito], consiste no fato de que aqui a prova do perigo da prática do ilícito é mais difícil, já que é extremamente árduo dar uma valoração ex ante da idoneidade dos meios empregados nos preparativos da perpetração do ilícito. Todavia, uma vez que se tenha como certa tal idoneidade e univocidade, não há dúvida de que o juiz possa conceder uma ordem inibitória”.²¹⁴

Vale trazer à colação, por último, a manifestação da doutrina francesa a respeito das ações preventivas. René Morel, dissertando sobre o interesse de agir para a propositura dessas ações, salienta a necessidade de que haja uma ameaça suficientemente séria (“menace suffisamment sérieuse”).²¹⁵ Lembra, nesse sentido, julgado da Corte de Cassação Francesa (acórdão de 23 de junho de 1890 – D. 90.1.289, S. 93.1.519), em que se decidiu que é viável a ação preventiva desde que presente a contestação ao direito, manifestada por atos ou fatos que constituam uma turbacão (“trouble”) material ou jurídica.²¹⁶ De acordo com Morel, para que a ameaça possa ser reputada suficientemente séria, não bastam afirmações pouco precisas e consistentes daquele que contesta a existência do direito.²¹⁷

7.6. Reconstrução crítica da prova da ameaça

7.6.1. A importância da compreensão do mecanismo da presunção para a aferição da ameaça

Diante de tudo isso, cabe uma análise crítica sobre a prova capaz de evidenciar a ameaça de lesão. Deixe-se claro, antes de mais nada, que o perigo de lesão não pode ser confundido com o perigo de que em algum dia possa ocorrer a violação. É imprescindível que haja uma situação específica a ameaçar o direito. Frignani, ao afirmar que não basta o perigo genérico, recorda – como argumento – que na previsão normativa das medidas cautelares ele é sempre qualificado, mesmo que de maneira variada. “Lembre-se do pericolo di danno na denunzia di nuova opera; o pericolo di danno grave e prossimo na denunzia di danno temuto; e enfim o perigo de um pregiudizio imminente e irreparabile no provimento de urgência”.²¹⁸

Como se viu, a tendência da doutrina e dos tribunais, no Brasil e no exterior, é exigir a ocorrência de dados objetivos e concretos capazes de demonstrar a ocorrência do justo receio de lesão. Não basta, em outras palavras, o mero temor subjetivo de futura violação. É necessário que o temor se apoie em elementos concretos, exteriores, capazes de avalizar o receio.

A questão da prova merece tratamento diversificado, conforme a ação inibitória objetive impedir a continuação ou a repetição do ilícito, ou evitar a sua prática (e não apenas sua repetição ou continuação). Note-se que, no caso em que um ilícito já foi praticado ou iniciou, a prova pode recair sobre algo que, estando no passado, pode evidenciar, com grande grau de aproximação, que o ilícito provavelmente se repetirá ou continuará, o que é suficiente para demonstrar a ameaça.²¹⁹

Mas, mesmo que um ilícito já tenha sido praticado ou iniciado, o que se teme é o fato futuro, embora isso fique muito mais claro na hipótese de ação inibitória “pura” – que visa impedir a prática de um ilícito ainda que ato nenhum de igual natureza tenha sido praticado.

Se é assim, todo e qualquer fato que diga respeito ao fato futuro somente poderá ser um fato indiciário ou indicativo de que a violação ocorrerá. Isso quer dizer que, para se resolver a questão da prova na ação inibitória, é imprescindível conhecer o tema das presunções (visto no último capítulo), além de, obviamente, aceitar que a prova não tem por objetivo apenas o passado.

Quando se teme a repetição do ilícito, a prova de que já foi praticado ato de igual porte é prova de um fato indiciário que, por meio de raciocínio presuntivo, permite a formação de uma conclusão – ou de uma presunção – de que provavelmente o ilícito será repetido. Tratando-se de ação dirigida a impedir a continuação do ilícito, a prova de que o ilícito, ou uma atividade ilícita, já iniciou, também é prova de indício que, apenas através do raciocínio, pode permitir que o juiz chegue a uma presunção e ao juízo de procedência.

Na modalidade de ação inibitória que mais preocupa – que não tem o objetivo de apenas impedir a repetição ou a continuação do ilícito –, a conclusão de que não resta outra alternativa a não ser demonstrar um fato indiciário é ainda mais óbvia. Nesse caso, como já foi dito, não é possível ao menos indicar ilícito de igual natureza ao temido. Somente é possível demonstrar fato de natureza completamente diversa, que ainda não constitui ilícito, mas apenas sinal de que o ilícito provavelmente ocorrerá. Assim, por exemplo, temendo-se a divulgação de uma notícia lesiva à personalidade, constituirá relevante indício, capaz de formar presunção e juízo de procedência, a divulgação de propaganda, por parte de determinada empresa de comunicação, de que a notícia será divulgada.²²⁰

Ora, a prova de quem alega temer a prática de ilícito somente pode recair em fatos que indiquem a sua probabilidade. Não obstante, quando a doutrina fala em ato ilícito (no caso em que se teme a sua repetição ou a sua continuação) e ato preparatório como suficientes à prova da ameaça, ainda está com a atenção voltada para o passado. Imagina, em outros termos, que a prova dos fatos passados é a prova da ameaça e, nesse sentido, que a prova dos fatos passados é a prova dos fatos diretos – e não a prova de fatos indiciários capazes de formar um juízo de probabilidade sobre algo que está no futuro. A dificuldade de ver tais fatos como indícios deriva de preconceitos infundados em relação à prova por presunção e à existência de um juízo que apenas possa se basear em convicção de verossimilhança.

De qualquer forma, é inevitável concluir que se a prova recai em um indício, e o juiz, a partir dele, raciocina com base na experiência e no senso comum para elaborar uma presunção sobre a

ocorrência de um fato futuro, o juízo sobre o mérito, na ação inibitória, não se submete aos mesmos rigores dos juízos “tradicionais”.

Apanhadas as razões e a extensão do equívoco, torna-se fácil a sua dissolução. Basta aceitar a obviedade de que aquilo que deve ser demonstrado, na ação inibitória, é a afirmação de que um fato futuro provavelmente ocorrerá, e não a afirmação de que um fato aconteceu. Os fatos passados se destinam apenas a demonstrar a afirmação de que o réu provavelmente praticará o ato contrário ao direito. Ou seja, o que se alega, e por isso deve ser demonstrado, é a probabilidade da prática do ato, ainda que essa demonstração se dê por meio de raciocínio presuntivo, isto é, a partir da prova do indício – que é fato passado.

Note-se que, se o fato passado fosse um fato direto, o juiz não precisaria relacioná-lo com o fato temido. Aliás, ver o fato passado como fato direto implica em admitir que o autor deve necessariamente alegá-lo na petição inicial, visto que apenas os fatos indiciários podem ser provados independentemente de alegação. Nesse sentido, se faltasse ao autor a alegação de um ato preparatório, a prova não poderia ser produzida. O absurdo dessa conclusão está em impor a aceitação de que um ato, indicativo da prática de um ilícito futuro, pode ser descartado pelo juiz pela razão de não ter sido afirmado na petição inicial. Ora, um ato dessa espécie, em essência indicativo, possui indisfarçável natureza indiciária, pelo simples motivo de que é um fato que gravita ao redor do fato essencial, servindo apenas para demonstrá-lo.

Por outro lado, é errôneo pensar que, ao se tomar como alvo o fato futuro, por ser somente viável chegar à verossimilhança, existiria uma convicção judicial incompatível com a definição do mérito. É certo que, em toda ação de conhecimento, o juiz deve buscar a convicção da verdade sobre o mérito (o que é diferente do que simplesmente correr atrás da verdade). Porém, na ação inibitória a prova tem características particulares. Nesse caso, por ser a ação voltada para o futuro, o direito apenas pode ser demonstrado a partir de prova indiciária e a convicção apenas pode chegar em um resultado de verossimilhança. Portanto, o uso da prova indiciária e o juízo de verossimilhança ou probabilidade da prática do ato são justificados pelo direito material que necessita de prevenção e pela norma constitucional que outorga o direito de ir a juízo para evitar a violação.

Assim, permitimo-nos, nesse momento, formular a conclusão de que a prova da ameaça é a prova da probabilidade da prática do ato temido. Isso não significa deixar de lado a necessidade da prova dos chamados elementos objetivos, mas apenas a constatação de que tais elementos nada mais do que indícios, sobre os quais obviamente deve recair a prova (indiciária), mas com a finalidade de demonstrar ou provar a probabilidade da prática do ato contrário ao direito.

Vale dizer: a convicção do juiz, na ação inibitória, somente pode ser a convicção sobre a probabilidade da prática do ato temido. Nesse sentido, há uma redução da convicção necessária para a formação do juízo de procedência (redução da exigência de prova) – quando consideradas as hipóteses “normais”.

7.6.2. A formação da convicção nas diferentes espécies de ações inibitórias

Evidenciada a importância da prova por presunção em face da ameaça de ato futuro, cabe distinguir a forma como ela atua diante de cada uma das três espécies de ação inibitória.

Quando se teme a repetição ou a continuação do ilícito, o fato indiciário é o ilícito já praticado ou iniciado. Se o autor não pode fazer o juiz chegar à probabilidade da repetição ou da continuação a não ser demonstrando a violação passada, é claro que isso é suficiente para formar a convicção do juiz. Nesse caso, a dúvida que pode persistir não pode ser paga pelo autor, pois quem viola um direito mostra, por meio do seu comportamento, que, além de não respeitar o direito do demandado, tem um interesse muito provável em repetir ou continuar o ilícito.

Quando nenhum ilícito foi praticado ou iniciado, a prova resta mais difícil. Nessa situação, a prova da ameaça diz respeito a atos preparatórios, ou a fatos objetivos que, sem constituírem atos da mesma natureza que o temido, podem indicá-lo como provável.

Como é evidente, como também ocorre em relação às outras duas ações inibitórias, não há como fazer outra prova que não a prova por presunção simples. Tal prova, diante da ação inibitória, é a única possível. Sem ela, e a possibilidade da redução das exigências de prova, não há como pensar em tutela inibitória. Mas, essa prova, no caso em que ilícito algum foi praticado ou iniciado, pode ter maior dificuldade para trazer ao juiz uma convicção necessária à concessão da tutela. Assim, o juiz deverá considerar as dificuldades probatórias peculiares a essa situação, visualizando a prova no contexto do caso concreto, e assim formar a sua convicção a partir não só das provas, mas também das dificuldades para a sua produção e das próprias circunstâncias do caso conflitivo.

Além disso, não se deve imaginar que todas as ações inibitórias “puras” (que não visam apenas a impedir a repetição ou a continuação do ilícito) são iguais. A dificuldade probatória varia conforme a situação de direito material objeto da ação. Como determinadas circunstâncias específicas apontam para uma maior dificuldade de prova, essas não podem deixar de ser levadas em conta pelo juiz.

7.6.3. A impossibilidade de produção de prova da ameaça

Não é incomum que a ameaça de lesão (conquanto existente) careça de qualquer demonstração material ou prova objetiva. Não são raras as hipóteses de ameaça velada (por telefone, por exemplo) de difamação, e muito menos raros os casos em que sequer se dá ciência da ofensa que se fará divulgar. Também são frequentes os casos em que a vítima tem ciência da ameaça de ofensa por mero boato ou por informações de terceiros.²²¹ Em tais situações, como compatibilizar a necessidade de tutela inibitória com as exigências tradicionais de comprovação da objetividade da ameaça?

O caminho abre-se em duas direções. Ou se mantém indene a exigência da prova da ameaça, correndo-se o risco de inviabilizar a proteção inibitória ao direito, ou se dispensa a prova, tornando-se a ação praticamente isenta de necessidade probatória.

A primeira solução gera o risco de a tutela inibitória não ser alcançável. Nesse caso, não logrando o autor produzir, previamente à lesão, prova da ameaça, não teria como obter a tutela jurisdicional. Porém, mantém segura a necessidade mínima para a intervenção judicial, que é a ameaça de lesão.

A outra alternativa traz a vantagem de permitir a criação de procedimento incomparavelmente rápido. Considerando o direito incontestável e a total desnecessidade de prova, permitir-se-ia a tutela de forma bastante célere. Entretanto, o seu defeito está na possibilidade de autorizar que uma pessoa sem razão possa obter tutela inibitória e, com isso, trazer prejuízo a alguém que jamais tenha pensado em violar o direito.

Se é fácil concluir que ambas as soluções são parcialmente insatisfatórias, o certo é que não se pode fugir a uma delas para equacionar o problema – ao menos enquanto não houver legislação específica sobre o tema, que possa evitar os problemas apontados.

Talvez a solução para compatibilizar as necessidades e ultrapassar os percalços referidos (ao menos em sua maioria) esteja na correta utilização do mecanismo da tutela antecipatória, imprescindível para a efetividade da ação inibitória. Realmente, conforme acima sublinhado, haverá hipóteses em que a prova da ameaça dependerá de inevitável dilação probatória, que pode inviabilizar a tutela inibitória. Recorde-se o caso em que se tem ciência da ameaça de lesão por meio de boatos ou por meio de advertência oral de terceiros. A prova dessa ameaça dependerá da instalação de audiência, na qual se colherá a prova para a demonstração do requisito. Tal providência, porém, pode ser suficiente para inviabilizar a tutela inibitória, dado o espaço de tempo necessário para a sua realização.

Nessas situações, a tutela antecipatória tem grande importância, e a prova mais uma vez assume posição de destaque. No caso de tutela antecipatória, como é óbvio, não é sequer preciso pensar na possibilidade de se abrir exceção à convicção de verdade. Isso porque o juiz somente

precisa chegar a essa convicção ao final do processo. Quando a tutela é concedida no curso do processo de conhecimento, e assim antes de se dar às partes a devida oportunidade de participação, a cognição é sumária, e, dessa forma, a convicção somente pode ser de verossimilhança. Ou melhor, diante da tutela antecipatória, a própria lei processual impõe a convicção de verossimilhança, enquanto que, para a concessão da tutela final, o juiz, em regra, deve ter convicção de verdade.

Para que o juiz possa conceder a tutela final com base em convicção de verossimilhança, deve justificar essa necessidade a partir do direito material e das circunstâncias do caso concreto. O mesmo não ocorre em relação à tutela inibitória antecipada, pois aí, como dito, a própria lei processual impõe a convicção de verossimilhança como bastante. Por isso, para a concessão da tutela inibitória antecipada não se pode exigir da prova mais do que a demonstração da aparência da verdade das afirmações de ameaça e ilicitude.

Note-se, porém, que assim como a convicção de verdade, própria ao juízo final, pode ser reduzida em face de determinadas circunstâncias, a convicção de verossimilhança, relativa ao juízo provisório (à tutela antecipatória), também pode ser reduzida em razão de específicas situações de direito material.

Se a convicção de verdade, característica do juízo final, pode ceder diante de certos casos concretos (conforme vimos nos capítulos anteriores), maior razão existe para se admitir a redução das exigências de convicção judicial no curso do processo. Ou melhor: quando da decisão sobre a tutela antecipatória, o módulo da prova (ainda que já reduzido pela própria lei processual) também pode variar para atender a dificuldade de prova em face de uma certa situação de direito material, quando deverão ser considerados o grau de credibilidade das alegações – obviamente que em uma perspectiva objetiva – e o valor do direito que se pretende tutelar.

Na verdade, o juiz, seja para conceder a tutela final, seja para conceder a tutela antecipatória, deve satisfazer-se com a “prova possível da alegação” e, com base nela, analisar o caso concreto que lhe foi submetido, pois de outra maneira certamente inviabilizará que o Estado se desincumba do seu dever de dar proteção aos direitos. Não se pense, apressadamente, que essa posição configura tautologia, afirmando-se que o juiz somente pode julgar com base na prova que as partes produziram. Ora, obviamente não se quer dizer que “prova possível” é a prova que pôde ser produzida, ou mesmo que o juiz não pode se negar a julgar – pois isso é evidente –, mas sim que o juiz deve sempre analisar o pleito de tutela jurisdicional à luz da dificuldade de prova e das circunstâncias do caso concreto.

Como já foi dito, a prova não pode ser encarada como um mecanismo de reconstrução da verdade dos fatos. Ao contrário, deve ser vista como um elemento retórico, destinado a convencer o magistrado das versões das partes, desvinculando-se completamente dos fatos pretéritos. A prova deve ser compreendida como um elemento de argumentação capaz de permitir a “construção dialética” da realidade, libertando-se de qualquer preconceito ôntico que possa intrinsecamente carregar. Nessa perspectiva é que se pode – e se deve – admitir a “redução das exigências de prova”, que, aqui, não deixa de ser mais do que uma modificação do âmbito do diálogo argumentativo.

A necessidade de a prova ser tratada de acordo com a diferença das situações concretas já abriu oportunidade para a aceitação de que, em determinadas circunstâncias, deve-se considerar a mera afirmação da parte,²²² como também para se pensar em balance of conveniences²²³ e em necessidade da ponderação dos interesses em conflito. Adverte Ovídio,²²⁴ ainda, que se fala, pensando-se na avaliação da procedência das alegações feitas pela parte,²²⁵ em “credibilidade das alegações”, em lealdade, correção moral e conduta social dos litigantes (Mario-Enrico Dini, *I provvedimenti d'urgenza*, v. 1, p. 258), em “pessoa honrada e digna de crédito” (Gerhard Walter, *Libre apreciación de la prueba*, p. 253) e, até mesmo, de aferição da “normalidade ou anormalidade circunstancial do evento sobre o qual se discute”.²²⁶

Nessa mesma linha de raciocínio, Fritz Baur admitiu que o juiz, ao analisar o cabimento da tutela cautelar, deveria adotar um princípio de proporcionalidade, levando em conta a gravidade

da interferência da tutela na esfera jurídica do requerido, no sentido de que, quanto mais grave fosse essa interferência, mais severas deveriam ser “as exigências a impor a quem cabe tornar críveis as alegações”, para mais tarde concluir que, ao lado da verificação da gravidade da interferência da tutela, deveria ser posta a necessidade de consideração da sua urgência. Eis a fundamentação do processualista alemão: “À semelhança do que ocorre com a polícia, que tem por dever o de assegurar, em sua primeira intervenção, as condições externas da ordem para a convivência humana, nesse nosso setor trata-se de conservar em condições de funcionar as comunidades jurídicas e uniões de pessoas ou de garantir provisoriamente aos seus membros um grau mínimo de participação e de direitos de participação. As providências que aqui entram em cogitação são tão diferentes quanto a sua oportunidade e seu conteúdo que se torna difícil assentar princípios gerais para solucionar a questão, que nos interessa, do exame da situação de direito material. Se a necessária ‘intervenção’ se mostra particularmente premente, o tribunal muitas vezes se servirá do princípio, conhecido no direito de polícia, de que, ‘antes de tudo, há de se cuidar do perturbador’. Àquele que, por sua ação ou omissão, perturba a ordem dentro da comunidade ou união de pessoas, têm de serem impostos limites, sem que, desde logo, seja possível averiguar se cometeu a perturbação ‘com razão’. Em outros casos, menos prementes no tempo, ao diverso, será adequado um exato exame revisivo da situação jurídica, diferenciado segundo a gravidade da intervenção. Com outras palavras, não se deverá ter em vista apenas a gravidade da interferência – como se fizera antes –, mas ainda a sua urgência”.²²⁷

Não cabe sustentar – e nem se pretende – a procedência de todos esses critérios. O que se deseja, apenas, é demonstrar a necessidade de a prova ser pensada de acordo com as diversidades dos casos concretos, levando em conta as dificuldades que cada um deles pode trazer à prova, gerando, muitas vezes, a impossibilidade de sua produção (ou uma “prova impossível”).

Como a efetividade da tutela inibitória requer, muitas vezes, a sua antecipação e, nesses casos, dada a urgência para a concessão da tutela jurisdicional, a produção da prova pode ser extremamente difícil, não resta outra saída ao juiz a não ser considerar: i) a urgência; ii) a dificuldade de se provar sumariamente a ameaça, especialmente em face da situação de direito material; iii) a credibilidade das alegações, diante das circunstâncias do caso e do comportamento das partes envolvidas; iv) o valor do bem material a ser protegido; e v) a interferência que a tutela ocasionará sobre a esfera jurídica do demandado. Desconsiderar esses critérios, e insistir no exame da prova como se não importasse o caso a que deve servir, talvez seja uma opção cômoda, mas certamente não proporcionará ao processo a possibilidade de realizar a justiça.

A lógica é bastante simples: não se pode exigir do titular do direito à tutela jurisdicional algo que torne impossível o seu exercício. Em outros termos: sempre que a dificuldade da produção da prova – obviamente considerada a situação específica – for capaz de inviabilizar a obtenção da tutela jurisdicional, o juiz deve levar em conta tal dificuldade e as circunstâncias do caso concreto.

Note-se, para finalizar, que são duas as técnicas que servem para explicar o juízo sobre a ameaça: a técnica da presunção judicial e a técnica da redução das exigências de prova. Como já foi explicado, a presunção judicial é formada a partir do indício (que é o elemento objetivo, tão requisitado pela doutrina), mas é o ponto final do raciocínio judicial presuntivo, elaborado a partir da experiência ou do senso comum do julgador e, portanto, da compreensão das circunstâncias do caso concreto. Enquanto isso, a técnica da redução das exigências de prova, sem constituir consequência imediata da natureza do fato que se pretende evidenciar, resulta da percepção de que a dificuldade da prova tem relação com as diferentes situações de direito substancial, e que, se o processo deve tutelar os direitos, não pode deixar de levar isso em conta. Outro raciocínio equivale a exigir uma prova impossível ou, pior ainda, impor o sacrifício do direito à tutela jurisdicional e do próprio direito material que se busca proteger.

8. A questão da impossibilidade do reexame da prova diante dos recursos especial e extraordinário

8.1. Aferição dos critérios jurídicos para a utilização da prova e para a formação da convicção judicial

Quando se pensa no tema da prova, não se pode deixar de abordar o problema das restrições eventualmente concebidas pela jurisprudência para a análise de elementos instrutórios em determinados momentos do processo. Nesse sentido, importa lembrar a questão da impossibilidade do reexame da prova por ocasião dos recursos especial e extraordinário.

Nessa linha, cabe lembrar a importância da prova para a formação da convicção judicial e, diante disso, do valor da imediatidade entre o juiz e a sua produção para uma prestação jurisdicional de maior qualidade. A imediatidade é privilégio do juiz de primeiro grau, embora isso não constitua obstáculo para a reapreciação dos julgados pelos tribunais mediante recurso de apelação, pois esses podem reexaminar a prova para formar a sua própria convicção sobre os fatos. Os tribunais, ainda que destituídos do benefício da imediatidade, estão autorizados a rejulgar a matéria de fato.

Os recursos especial e extraordinário, entretanto, não viabilizam novo exame da causa, nos moldes do recurso de apelação. Tais recursos têm âmbito restrito, permitindo apenas o reexame da solução que pode ter afrontado a lei federal (recurso especial – art. 105, III, CF) ou a Constituição Federal (recurso extraordinário – art. 102, III, CF).

Bem por isso, dizem as Súmulas 279 do STF e 7 do STJ²²⁸ que os referidos recursos não permitem o reexame de prova. Ocorre que a doutrina e os tribunais têm tido dificuldades em precisar esse conceito.

O conceito de reexame de prova deve ser atrelado ao de convicção, pois o que não se deseja permitir, quando se fala em impossibilidade de reexame de prova, é a formação de nova convicção sobre os fatos.²²⁹ Não se quer, em outras palavras, que os recursos extraordinário e especial viabilizem um juízo que resulte da análise dos fatos a partir das provas.

Acontece que esse juízo não se confunde com aquele que diz respeito à valoração dos critérios jurídicos respeitantes à utilização da prova e à formação da convicção. É preciso distinguir reexame de prova de aferição: i) da licitude da prova; ii) da qualidade da prova necessária para a validade do ato jurídico ou; iii) para o uso de certo procedimento; iv) do objeto da convicção; v) da convicção suficiente diante da lei processual e; vi) do direito material; vii) do ônus da prova; viii) da idoneidade das regras de experiência e das presunções; ix) além de outras questões que antecedem a imediata relação entre o conjunto das provas e os fatos, por dizerem respeito ao valor abstrato de cada uma das provas, e dos critérios que guiaram os raciocínios presuntivo, probatório e decisório.

Note-se que o que se veda, mediante a proibição do reexame de provas, é a possibilidade de analisar se o tribunal recorrido apreciou, adequadamente, a prova para formar a sua convicção sobre os fatos. Assim, por exemplo, é proibido voltar a analisar as provas que convenceram o tribunal de origem sobre a presença de culpa.

8.2. Prova, motivação e qualificação jurídica dos fatos

Como é óbvio, o problema do reexame da prova não possui relação com a falta de motivação e com a qualificação jurídica dos fatos.

A ausência de motivação constitui, por si só, violação do Código de Processo Civil e da Constituição Federal, pouco importando o conteúdo da decisão que deixou de ser motivada. Uma decisão que, além de não motivada, violou critério jurídico ao estabelecer uma presunção – por exemplo –, é, antes de tudo, violadora do dever de motivar. A motivação, por ser necessária à aferição do uso adequado da prova, configura razão suficiente para a impugnação da decisão.

Por outro lado, a qualificação jurídica do fato é posterior ao exame da relação entre a prova e o fato e, assim, parte da premissa de que o fato está provado. Por isso, como é pouco mais do que evidente, nada tem a ver com a valoração da prova e com a perfeição da formação da convicção sobre a matéria de fato.²³⁰ A qualificação jurídica de um ato, ou de uma manifestação de vontade, acontece quando a discussão recai, somente, na sua qualidade jurídica. Se a controvérsia diz

respeito à qualificação de uma manifestação de vontade por instrumento público, é claro que sequer chega perto de reexame de prova, pois aí não importa nem mesmo saber sobre a utilização da prova ou a respeito da formação da convicção sobre o fato, mas somente sobre a sua qualificação jurídica, vale dizer, se essa manifestação constitui reversão de doação, doação condicional ou doação mortis causa – por exemplo.²³¹

8.3. Prova essencial à validade do ato jurídico

De acordo com o art. 406 do CPC, quando a lei exigir, como sendo da substância do ato, o instrumento público, nenhuma outra prova pode suprir-lhe a falta. Embora esse artigo fale de prova, o instrumento público, aí exigido, é dito da “substância do ato”. Na verdade, trata-se do chamado documento substancial que não se presta a provar, mas, sim, a constituir o direito.

Diante disso, se uma decisão dispensa o instrumento público diante de ato cuja existência dele depende, há evidente violação de lei federal, apta a ser corrigida mediante recurso especial. A alegação recursal de inexistência desse documento não enseja simples reexame de prova, mas sim a análise da existência do próprio ato.

8.4. Uso de prova incompatível com determinado procedimento

Como é sabido, o mandado de segurança não admite o uso de prova diferente da documental. Assim, caso se afirme, em sede de recurso especial, que uma decisão admitiu o uso de prova diversa da documental no mandado de segurança, há inquestionável alegação de violação de lei federal, sendo equivocado pensar em pretensão de simples reexame de prova.

Nesse caso, existe apenas aferição do valor da prova que fundou o julgamento do recorrido, e não reexame da prova para a verificação da procedência da convicção fática.²³²

8.5. Discussão sobre a qualidade da prova necessária ao uso do procedimento

O procedimento monitorio requer a chamada prova escrita. O CPC alude apenas à “prova escrita sem eficácia de título executivo” (art. 700), sem dar qualquer outro indicativo desse conceito, deixando de esclarecer o que seria a prova escrita ou de apontar as provas que mereceriam o qualificativo de “escrita”.

Em razão disso, é claramente possível a discussão sobre se a prova oferecida pelo autor da ação monitoria, realmente, constitui “prova escrita”. Aqui não importa, como é evidente, definir tal conceito, mas, apenas, evidenciar que ele pode ser discutido no caso concreto.

Nessa discussão não entra a questão de saber se o juiz se convenceu adequadamente sobre os fatos, mas, sim, a de se o juiz poderia ter julgado com base em determinada prova – afirmada não merecedora do qualificativo de “escrita”.²³³ Nesse sentido, o que se coloca no recurso especial diz respeito à natureza da prova sobre a qual a decisão se apoiou. O enfrentamento da natureza da prova utilizada em concreto não pode ser confundido com a análise da convicção fática que, a partir dela, se formou.

8.6. Convicção de probabilidade

O art. 300 do CPC fala em convicção de probabilidade, conceito sobre o qual há sérias dúvidas na doutrina e nos tribunais, especialmente, porque se pretende tratar desse conceito apenas em uma perspectiva processual, esquecendo-se da obviedade de que toda convicção incide sobre um objeto, o qual, nesse caso, pertence ao plano do direito material.

Portanto, pouco importa concluir que não se pode analisar, mediante recurso especial, a idoneidade da convicção de probabilidade, pois ninguém discute que a convicção fática não pode ser reavaliada.

O que realmente importa é saber se os critérios jurídicos de formação da convicção de probabilidade foram utilizados de maneira adequada quando é imprescindível cogitar a respeito

do objeto material da tutela antecipada satisfativa.

Isso significa que a análise da convicção de probabilidade requer, como antecedente lógico, a descoberta dos diferentes pressupostos das várias tutelas antecipatórias – ditas tutelas de urgência quando vistas, somente, em perspectiva processual. Tais tutelas têm diferentes pressupostos conforme sejam: inibitória, de remoção do ilícito, de ressarcimento na forma específica e do adimplemento na forma específica – por exemplo.²³⁴ Melhor explicando: a compreensão do conceito de convicção de probabilidade depende da natureza da tutela antecipatória requerida, pois essa convicção, como acontece também com a convicção de verdade, não pode ser compreendida fora do caso concreto.

A tutela antecipatória pode ser preventiva ou repressiva e, nesse último caso, ter por objeto um ato contrário ao direito, um dano, um inadimplemento total ou um cumprimento imperfeito da obrigação. Não é preciso dizer que os pressupostos de cada uma dessas tutelas são completamente distintos.

Quando se alega, no recurso especial, que o tribunal recorrido deixou de, devidamente, analisar os pressupostos da tutela antecipatória não se cogita acerca de inadequada formação da convicção fática, mas, sim, de indevida consideração do direito material. Lembre-se que a tutela antecipatória pode ter como pressuposto (por exemplo): i) a probabilidade de vir a ser praticado ato contrário ao direito (tutela antecipatória inibitória); ii) a probabilidade de vir a acontecer dano (tutela antecipatória inibitória); iii) a probabilidade de ter ocorrido ato contrário ao direito (tutela antecipatória de remoção do ilícito) além do; iv) fundado receio de dano que deve se juntar à probabilidade de ter ocorrido inadimplemento total ou cumprimento imperfeito (tutela antecipatória do adimplemento na forma específica).²³⁵

Assim, se o Ministério Público requer, em ação civil pública, a apreensão liminar de produtos, ilicitamente, expostos à venda, e a decisão recorrida deixa de conceder a tutela antecipatória sob a alegação de inexistência de probabilidade de dano, há evidente violação do direito material, pois pressuposto dessa tutela antecipatória é a probabilidade de a exposição à venda constituir ilícito – ato contrário ao direito – e não a probabilidade de vir a ocorrer dano.²³⁶

8.7. Desconsideração da convicção suficiente

Pior do que isso é a desconsideração da convicção suficiente para a concessão da tutela antecipatória. O art. 300 do CPC, como dito, afirma, expressamente, que para a concessão dessa tutela basta a convicção de probabilidade.

Não obstante, são frequentes as decisões que não admitem a antecipação da tutela sob o argumento de inexistência de convicção de aparência sem qualquer alusão e justificativa acerca das razões que levaram a tal conclusão. Quando isso ocorre, pode inexistir apenas uma ilegítima despreocupação em relação ao objeto da convicção, mas, muitas vezes, a exigência de uma convicção que está além da probabilidade, chegando perto a de verdade – necessária apenas para a procedência do pedido.

Acontece que o juiz, diante de requerimento de tutela provisória satisfativa, não está autorizado a exigir uma convicção mais aprofundada do que a estabelecida no art. 300. O respeito à convicção fixada como suficiente pelo legislador é uma garantia do jurisdicionado, que tem direito a obter a antecipação da tutela, no caso em que demonstra perigo, quando há “aparência preponderante”, isto é, quando o seu direito é mais “provável” que o do réu.

É claro que há ilegalidade quando o juiz, expressamente, afirma que é necessário a convicção de verdade, pois há aí flagrante violação do ditado legislativo, que lhe obriga a contentar-se com a probabilidade. Mas, na generalidade dos casos de desconsideração da convicção de probabilidade, o juiz supõe que essa convicção não está presente. Isso porque desconhece o significado dessa modalidade de convicção, especialmente porque está acostumado a raciocinar a partir da convicção de verdade.

A convicção de aparência se expressa mediante a ideia de verossimilhança preponderante. Isso quer dizer que, no caso de perigo, o juiz deve analisar se o direito do autor é mais provável que o do réu; isto é, se a preponderância pende para o lado da parte autora. Em caso positivo, apenas poderá deixar de conceder a tutela na hipótese em que a sua concessão puder acarretar risco de prejuízo irreversível ao direito que, no caso concreto, tiver valor maior do que aquele que o autor pretende ver imediatamente tutelado. Se o juiz deixar de conceder a tutela, mas dessa forma não raciocinar e motivar, a sua decisão terá violado o art. 300 do CPC.

Perceba-se que a aferição de tal violação não requer o reexame das provas e, portanto, é cabível em sede de recurso especial. Não há como confundir reexame de prova para a formação da convicção com descon sideração da suficiência da “verossimilhança preponderante”. No entanto, alguém menos avisado poderia argumentar que, para a constatação da verossimilhança preponderante, é preciso examinar as provas. Contudo, aqui se está tratando da hipótese em que o juiz nega, ou não compreende, que a “verossimilhança preponderante” é suficiente – violando o art. 300 – e não se concluindo que é possível reexaminar se as provas produzidas fizeram surgir convicção de probabilidade.

8.8. Redução das exigências de prova e direito material

De lado à hipótese em que a convicção de probabilidade é estabelecida na lei, existem situações de direito material que permitem ao juiz reduzir as exigências de prova, obviamente que justificando.

Isso acontece quando a situação específica de direito material, para ser bem tratada, naturalmente, requer a redução das exigências de prova. Nessas situações, o direito material não se compatibiliza com a convicção de verdade; a dificuldade de o autor provar o seu direito torna racional a admissão de uma convicção que não seja da mesma intensidade daquela, usualmente, exigida para a procedência do pedido.

Assim, por exemplo, nos casos de lesões pré-natais, em que não é possível exigir do autor a prova capaz de levar à convicção de verdade de que um acidente automobilístico foi o responsável pelo dano à saúde do recém-nascido. Do mesmo modo, na hipótese em que não se pode provar, de maneira a formar convicção de verdade, que a atividade da empresa ré é diretamente responsável pelo dano ambiental.

Agora não importa saber se a redução do módulo de prova é justificável nessas situações. O que interessa, nesse momento, é evidenciar que o juiz, ao reduzir o módulo da prova – evidentemente justificando –, pode violar a norma que impõe ao autor o ônus da prova. Na mesma perspectiva, quando a situação concreta permitir a conclusão de que não se pode solicitar algo mais do autor, a decisão violará a regra do ônus da prova ao deixar de reduzir as exigências de prova.

Por isso, o recurso especial pode tratar da questão da redução do módulo de prova, sem que se possa pensar que o seu enfrentamento possa significar reexame de prova. No recurso especial é possível discutir a questão de se a decisão poderia, ou não, ter reduzido a convicção usualmente necessária para a procedência do pedido.

8.9. Inversão do ônus da prova e seus requisitos

O art. 6.º, VIII, do CDC admite a modificação do ônus da prova em duas situações: i) no caso de verossimilhança da alegação e; ii) na hipótese de hipossuficiência. O CPC, em seu art. 373, § 1º, permite ao juiz modificar o ônus da prova de acordo com a maior dificuldade, ou maior facilidade na obtenção da prova.²³⁷

A análise a respeito do significado desses conteúdos, e sua aplicação por decisão específica, obviamente, transborda os limites do reexame de prova. Trata-se de clara discussão de direito, que deve ser controlada por meio do recurso especial.

Não se diga, como já fez o STJ, que “o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova na

origem, por não se tratar de hipossuficiência, mas, também, pela impossibilidade de se aferir da razoabilidade da verossimilhança das alegações do consumidor, conceito de índole fático-probatório, atrai a censura da Súmula 7 do STJ, impedindo o conhecimento do especial, manejado sob o fundamento de maltrato ao art. 6.º, VIII do CDC”.²³⁸ Lembre-se que os critérios da hipossuficiência e da verossimilhança da alegação são autônomos, o que significa que, para a inversão do ônus da prova, ambos, não precisam estar presentes. O juiz, para decidir sobre a hipossuficiência, deve considerar apenas a dificuldade de produção de prova. Portanto, a decisão a respeito de hipossuficiência não pode impedir o especial sob o argumento de impossibilidade de reexame de prova. Além disso, não há como confundir exame de prova para a formação da convicção de verossimilhança com redução das exigências de prova para a procedência do pedido ou para a inversão do ônus da prova na sentença.

Decidir sobre a modificação do ônus da prova requer a consideração do direito material e das circunstâncias do caso concreto, ao passo que a formação da convicção, nada mais é do que a análise da prova e dos demais argumentos. Inverter o ônus da prova não está sequer perto de formar a convicção com base nas provas. Assim, o recurso especial pode afirmar que a decisão que tratou do ônus da prova violou a lei, o que, evidentemente, não requer o reexame das provas.²³⁹

8.10. Determinação da credibilidade da prova

O juiz, antes de valorar as provas, deve estar certo de que a prova é idônea para formar o seu convencimento. Prova idônea, nesse sentido, é a que passou pelo teste de credibilidade. Para o juiz decidir sobre a credibilidade de uma prova, deve enfrentar certos critérios, precisamente determinadas regras de experiência. São as regras de experiência que devem guiar a aferição da credibilidade da prova.

Quando essa aferição for explícita, seja em razão de contradita da testemunha, seja em virtude de alguma circunstância a ter exigido, o juiz deve precisar a solidez da regra de experiência utilizada, justificando a sua aplicação no caso concreto. No caso em que tal aferição não tiver sido explicitada – e não houver violação ao dever de motivação –, ainda assim será possível dizer que a prova, diante de sua evidente inidoneidade, não poderia ter sido valorada para formar a convicção judicial.

Em qualquer uma dessas hipóteses, não há como negar a possibilidade de discutir eventual violação do direito à prova em razão de incorreta aferição da sua credibilidade. Não ocorrerá, nessas situações, reexame de prova, mas, sim, a verificação de se a prova poderia ter sido valorada.

Analisar se uma prova poderia provar não é o mesmo que examinar a convicção que a decisão recorrida formou a partir das provas valoradas. Em tais circunstâncias, o recurso ficará limitado à análise de uma regra de experiência, ou seja, de uma regra de juízo, pois a análise da credibilidade da prova não poderá ser feita quando, para se determinar a sua própria credibilidade, houver a necessidade de reexame de provas, como pode ocorrer diante da contradita.

8.11. Regras de experiência e presunções judiciais

Por outro lado, não é possível esquecer o papel das regras de experiência na formação das presunções. As presunções são formadas a partir dos indícios, ou melhor, das provas indiciárias, mas, sempre, com base em regras de experiência – comuns ou técnicas.

Nos recursos especial e extraordinário, certamente, não é possível reexaminar a prova indiciária e a convicção respeitante ao fato indiciário – também dito indício. Contudo, para chegar à presunção, o juiz raciocina ancorado em regras de experiência. É possível que o juiz aplique regra de experiência comum já totalmente desacreditada por outra regra de experiência comum ou que confronte com regra de experiência técnica; ou ainda que considere regra de experiência técnica sabidamente não mais aceita pela comunidade científica. Nessas situações, quando o uso da regra de experiência, por parte do juiz, não exigiu a produção de prova, nada pode impedir o questionamento da sua utilização. Note-se que, nessa hipótese, a regra de experiência não foi

pensada com base em prova nenhuma, mas apenas permitiu ao juiz raciocinar, a partir de uma prova indiciária e de um indício, para fixar a presunção. Aí não há qualquer discussão sobre a prova indiciária, mas apenas impugnação da idoneidade da regra de experiência e, por mera consequência, da presunção. Mas a discussão da presunção, em tal perspectiva, obviamente, não requer o reexame de prova. Perceba-se que não há nem mesmo reexame da presunção enquanto elemento de formação da convicção, mas somente indagação a respeito da regra de experiência que conduziu o raciocínio judicial até a presunção.

Nessa linha, o recurso especial – ou extraordinário – pode discutir se a adoção de uma regra de experiência violou a lei ou a Constituição Federal.²⁴⁰

8.12. Começo de prova escrita

De acordo com o art. 444 do CPC, “nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova”. A alusão a “começo” de prova traz, implicitamente, a ideia de que a sua apresentação não é capaz de liberar o autor do ônus da prova. Isso, aliás, também decorre claramente da circunstância de que a sua utilização é elemento que confere ao autor a oportunidade do uso da prova testemunhal, e isso quando emanou da parte contrária. Nesse sentido, tal prova somente pode ser entendida como aquela que, apesar de não suficiente para o cumprimento do ônus da prova, autoriza que a tentativa de convencimento judicial também seja feita por intermédio da prova testemunhal. Não é sem razão, portanto, que o Código Civil italiano, ao tratar desse conceito, alude a uma prova che faccia apparire verosimile il fatto allegato (art. 2.724, 1).

Pois bem. Caso a decisão recorrida enfrente a questão do conceito de prova por escrito, admitindo-a ou não, o recurso especial pode ser admitido para a sua discussão. Note-se, porém, que o mesmo não ocorre quando não se discutiu o conceito de prova por escrito, mas essa foi valorada, juntamente, com a prova testemunhal.²⁴¹

8.13. Fatos que apenas podem ser demonstrados mediante as provas documental e pericial

Segundo o art. 443, II, do CPC, o juiz deve indeferir a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. No primeiro grupo (documento) está incluída a hipótese do art. 406 do CPC. No segundo, estão os fatos que exigem prova pericial. No caso em que um fato não pode ser demonstrado por meio de documento ou de testemunha, mas, somente mediante análise técnica, a prova pericial não pode ser dispensada.

Porém, o que importa, como é intuitivo, é sublinhar que a decisão que analisou se um fato apenas poderia ser objeto de prova documental ou pericial pode ser objeto de recurso especial. Nesse caso, evidentemente, não há necessidade de reexame de prova ou de reelaboração da convicção, mas, apenas, a verificação de se a decisão, ao exigir prova documental ou pericial, não violou o CPC.

8.14. Valor da prova pericial

Diz o art. 479 do CPC que “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. Lembre-se, contudo, que quando a prova pericial não for suficiente para esclarecer o fato, o juiz deve pedir esclarecimentos (art. 477, §§ 2.º e 3.º) e, se for necessário, determinar o que se chama de “segunda perícia” para corrigir a primeira (art. 480).

Como a prova pericial é uma prova técnica e, assim, mais “objetiva” do que a testemunhal, o seu poder de convencimento também é mais forte. Portanto, a liberdade de o juiz formar a sua convicção com base em outras provas, quando produzida a prova pericial, está condicionada à explicação da razão pela qual a perícia não foi suficiente para esclarecer os fatos ou os motivos pelos quais os esclarecimentos solicitados ao perito, assim como a “segunda perícia”, não puderam

suprir as suas imperfeições.

Embora a necessidade de motivação seja algo que deva acompanhar toda e qualquer decisão, a sua ausência, na situação em que o resultado da perícia é desconsiderado, implica negação dos direitos à motivação e à prova e em violação ao art. 375 – que, ao dizer que o juiz não está adstrito à prova pericial, implicitamente, afirma que a decisão pode deixar o resultado dessa prova de lado somente em hipóteses excepcionais.

8.15. A questão da coerência lógica da decisão

O chamado critério da coerência lógica possui muita importância para o controle da motivação da decisão. Para esse critério, importam os elementos lógicos da decisão, especialmente, os relacionados a não-contradição e à coerência inferencial.²⁴²

Não é possível que uma decisão aceite um mesmo fato como verdadeiro e falso, confira determinada qualidade – de verdadeiro ou de falso – a fatos que são contrários ou contraditórios, ou empregue regras de inferência incompatíveis. Quando um mesmo fato é considerado em um momento verdadeiro e, em outro, falso, ou quando fatos inconciliáveis são admitidos como verdadeiros ou falsos; a decisão, certamente, padece de vício de ausência de lógica. O mesmo ocorre quando a decisão emprega, em um mesmo contexto, regras de experiência excludentes.

Nessas situações, o controle da decisão pode ser feito não apenas em grau de apelação, pois a aceitação da ausência de coerência lógica não exige reelaboração da convicção ou simples reexame da prova, mas, apenas, a análise dos elementos narrativos componentes da decisão.

8.16. A congruência da decisão

A coerência lógica é interna à decisão, defluindo da adequação da motivação, ao passo que, muitas vezes, a decisão deixa de se relacionar de modo pertinente com a prova, seja por não considerar um fato provado, seja por admitir um fato não provado. Nesse caso há o que se chama de ausência de congruência entre a decisão e os fatos provados.²⁴³

Em tais hipóteses, também não há pretensão de formação de nova convicção sobre as provas. Existe apenas afirmação de que a decisão deixou de tomar em conta uma prova – ou um fato provado – ou considerou um fato não provado. Tanto a decisão que ignora uma prova²⁴⁴ – ou um fato provado –, quanto a que admite um fato que não foi provado, são completamente estranhas ao material probatório e, por consequência, violadoras do Código de Processo Civil e da Constituição Federal.²⁴⁵

8.17. Erro na compreensão da prova em abstrato

A prova, equivocadamente, compreendida ou conceituada em abstrato não se confunde com a prova que, por ter sido mal valorada, conduziu a uma convicção distorcida. Quando se diz que houve erro na compreensão da prova em abstrato, não se afirma que a sua valoração foi mal feita e, assim, não se deseja uma reelaboração da convicção judicial.

Note-se que a valoração da prova implica na relação entre a prova – abstratamente considerada de forma perfeita – e o fato, ao passo que a compreensão da prova, em abstrato, supõe o conhecimento do conteúdo e do significado da prova enquanto instrumento para a demonstração de um fato.

Havendo erro na compreensão do conteúdo e do significado da prova, dizendo a decisão, por exemplo, que o documento afirma algo que não está dito nas próprias palavras nele contidas, há admissão de uma prova inexistente nos autos.

8.18. Prova ilícita

Soa óbvio que a afirmação de prova ilícita não requer o reexame da prova, pois está longe de propor apenas a formação de uma nova convicção. Pretende-se, nesse caso, a análise de se a prova

constitui instrumento lícito para servir à demonstração dos fatos.

Diante do art. 5.º, LVI, da CF, a dizer que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”, as decisões que enfrentam a questão da licitude das provas podem ser levadas ao STF por meio de recurso extraordinário.

Tanto a decisão que admitiu a prova sem conceituá-la como ilícita, quanto a que admitiu a prova ilícita mediante a aplicação da regra da proporcionalidade, como ainda a que não admitiu a prova por considerá-la ilícita, podem ser objeto de recurso extraordinário ao STF.

8.19. Decisão acerca de fatos que não dependem de prova

O art. 374 do CPC diz que “não dependem de prova os fatos: I – notórios; II – afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III – admitidos no processo como incontroversos; IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade”. O autor está dispensado de provar esses fatos e, por consequência, o juiz não necessita formar convicção sobre eles enquanto fatos individuais, devendo os considerar provados quando da valoração do conjunto probatório, isto é, das demais provas e argumentos de convicção.

A notoriedade é uma qualidade do fato que é conhecido no momento e no lugar em que a decisão é proferida. Quando for necessário produzir prova sobre a notoriedade – nunca sobre o fato em si, pois o art. 374, I, afirma que o fato, admitido como notório, não precisa ser provado –, obviamente, não há como pensar em rediscutir a convicção a respeito da notoriedade. Porém, mesmo que a definição de notoriedade não tenha exigido prova, mas seja fundada na convicção do juiz – devidamente motivada –, tal questão não pode ser levada ao STJ, pois implicaria renovação da formação da convicção sobre a notoriedade do fato.

Isso significa que o recurso especial apenas pode discutir a notoriedade no caso em que a decisão considerou um fato olhando para outro; isto é, considerou um fato no lugar do outro para concluir a respeito da notoriedade. Perceba-se que, nesse caso, embora possa não ter sido necessária a produção de prova sobre a notoriedade, não houve simples compreensão de uma prova em abstrato ou mera qualificação jurídica de um fato reputado existente, mas, sim, a definição da natureza ou dos contornos do próprio fato afirmado como notório. A notoriedade, em outras palavras, é uma qualidade que diz sobre a natureza de um fato, e não sobre a sua expressão jurídica, como quando se discute a respeito de uma manifestação de vontade.

É sabido que a confissão gera a dispensa de prova e a presunção de veracidade – quase que absoluta – sobre o fato confessado. A dispensa de prova não elimina a possibilidade da convicção se formar em sentido contrário ao da confissão. Não há racionalidade em aceitar um fato – ainda que confessado – que é logicamente inexplicável por intermédio das regras de experiência ou que colide frontalmente com outros fatos também aceitos como verdadeiros.

De qualquer forma, a questão dos efeitos da confissão pode ser posta no recurso especial. O STF já decidiu, há muito tempo, que tal questão não tem o veto da Súmula 279, pois não exige o reexame de prova.²⁴⁶ Porém, a situação não é tão simples, uma vez que requer a distinção entre a decisão que negou efeito à confissão, que a ela deu efeito pleno, desconsiderando os outros argumentos de prova, e a decisão que valorou a confissão como um dos elementos integrantes da formação da convicção.

Todas essas decisões podem ser objeto de recurso especial, embora devam ser devidamente compreendidas. A decisão que nega efeito à confissão, assim como a que lhe confere eficácia plena, trata do efeito da prova em abstrato, e não da prova como elemento gerador da convicção. Porém, em relação à decisão que atribuiu efeito à confissão, valorando-a juntamente com os demais elementos probatórios, é preciso mais cuidado. Se o vencido afirmou que a confissão tem eficácia plena, e assim não pode ser enfraquecida pelos demais argumentos de prova, o recurso especial pode ser admitido para que seja decidido a respeito do valor abstrato da confissão. Entretanto, se nunca se cogitou da eficácia plena da confissão, não cabe pretender reelaborar a convicção formada a partir dela, sob pena de o STJ incidir em reexame de prova.

De acordo com o art. 341 do CPC, o réu deve “manifestar-se precisamente sobre as alegações de fatos constantes da petição inicial”, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo: I – se não for admissível a seu respeito a confissão; II – se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público que a lei considerar da substância do ato; III – se estiverem em contradição com a defesa em seu conjunto.

Diante disso, se a decisão, para presumir – ou não – um fato como verdadeiro, trata da admissibilidade da confissão em relação a ele ou da necessidade de a petição inicial estar acompanhada de instrumento público, o recurso especial pode enfrentar uma questão ou outra, alegando violação dos arts. 341, I ou II e 374, III.

Por outro lado, o art. 341, III, evidencia que, para que um fato possa ser considerado não contestado, não é suficiente apenas a não contestação, sendo preciso verificar se outras alegações, contidas na contestação ou mesmo na reconvenção, não significam, mesmo que implicitamente, a sua negação. Se o réu deixa de contestar um fato de forma específica, o efeito da não contestação – ou seja, a admissão do fato como verdadeiro – somente se produzirá caso as demais alegações da defesa não forem tomadas como negação do fato que não foi contestado de maneira individualizada.²⁴⁷

Por isso, para que um fato não contestado possa ser presumido verdadeiro, é necessário analisar a defesa globalmente; verificando se é possível concluir, a partir do conjunto das alegações do réu, que o fato que não foi contestado de forma específica foi aceito como verdadeiro.

Isso quer dizer que, para que o juiz possa admitir um fato que não foi contestado, deve justificar que a defesa, em seu aspecto global, supriu a não contestação específica. Se isso não foi feito, e a não contestação foi alegada, a decisão que considerou o fato não contestado não só deixou de ser fundamentada, como violou os arts. 341, III e 374, III, do CPC.

Em último lugar, diz o art. 374, no seu inciso IV, que os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência, ou de veracidade, não dependem de prova. Nesse caso, a prova ou a análise fática não têm qualquer importância, pois o juiz é vinculado pelas conclusões hipotéticas da lei. Diante dessa modalidade de presunção – dita absoluta – a prova é inútil, pouco importando a sua intenção, ainda que voltada a demonstrar que a presunção parte de um silogismo falso.²⁴⁸ Nessa situação, toda prova ou contraprova é destituída de relevância, uma vez que o suporte fático do silogismo, embora tenha sido importante para a sua fixação como hipótese normativa, não possui qualquer significado no caso concreto.

Deixe-se claro que, caracterizado o fato do qual decorre a presunção absoluta, não há como pretender fazer prova que diga respeito à idoneidade da relação entre esse fato e a presunção. É que tal relação, como dito, é fixada por lei com caráter absoluto. De modo que a decisão que, a partir de um fato incontroverso, discute sobre a existência de uma presunção absoluta, trata, obviamente, de questão de direito, estando longe de poder encontrar obstáculo na impossibilidade de reexame de prova.

8.20. Recurso especial e admissão de revisão de condenações em valores irrisórios ou exagerados

O STJ tem admitido a revisão dos valores das condenações relativas a danos morais e honorários de advogado, sublinhando que, em tais casos, não incide a Súmula 7.

No que diz respeito aos danos morais, o STJ já advertiu, em julgado relatado pelo Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, que a Corte “tem exercido controle sobre os valores fixados pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, para minimizar a discrepância de decisões proferidas pelos diversos tribunais do país, e também nos casos em que o quantum indenizatório se mostra manifestamente irrisório ou exagerado, distanciando-se das finalidades da lei. Na fixação do valor indenizatório, não se está a reexaminar provas ou fatos, mas apenas valorando as circunstâncias fixadas nas instâncias ordinárias, procedimento esse que não encontra vedação no Enunciado 7 da súmula/STJ”.²⁴⁹

Outro julgado da 4.^a Turma, também relatado pelo Ministro Sálvio, assentou: “o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, desde que o quantum contrarie a lei ou o bom senso, mostrando-se manifestamente exagerado, ou irrisório, distanciando-se das finalidades da lei. Na espécie, levando em consideração a situação econômico-social das partes, a atividade ilícita exercida pelo réu segundo recorrente, de ganho fácil, o abalo físico, psíquico e social sofrido pelo autor, o elevado grau da agressão, a ausência de motivo e a natureza punitiva e inibidora que a indenização, no caso, deve ter, mostrou-se insuficiente o valor fixado pelo Tribunal de origem a título de danos morais, a reclamar majoração”. ²⁵⁰

Em 2003, a 2.^a Turma, relatora a Ministra Eliana Calmon, confirmou essa orientação: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de admitir a revisão das circunstâncias fáticas, contornando a vedação da Súmula 07/STJ, quando for irrisória ou absurda a quantificação do dano moral”. ²⁵¹

Quanto aos honorários de advogado, a 4.^a Turma, relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, concluiu ser “possível conhecer de recurso especial para rever a estipulação de honorários advocatícios em valor irrisório”. ²⁵² Em abril de 2004, a 2.^a Turma, em julgado de que foi relator o Ministro João Otávio de Noronha, frisou que esse passou a ser o entendimento da Corte: “O STJ tem conhecido de recurso especial quando se trata de rever a fixação de verba honorária em valores considerados irrisórios ou excessivos, situações em que a decisão recorrida se afasta do juízo de equidade preconizado na lei processual. A redução dos honorários advocatícios de 10% para, aproximadamente, 1% do valor da condenação, determinada pela Corte Regional com base no frágil e insólito argumento de que, nas ações de desapropriação indireta ‘o maior trabalho fica a cargo da perícia’, traduz inequívoca desqualificação dos árduos trabalhos desenvolvidos pelo profissional de direito. A fixação da verba honorária há de ser feita baseada em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do trabalho profissional. Recurso especial conhecido e provido”. ²⁵³

9. Negócios processuais em matéria de prova

9.1. Liberdade e processo civil

A presença do Estado em áreas que podem e devem contar com a participação exclusiva dos privados e a excessiva proteção do Estado sobre determinadas situações, a interferir sobre a liberdade dos particulares que se relacionam com o bem tutelado e, em alguns casos, na liberdade da própria pessoa tutelada, trouxe graves problemas à sociedade e ao próprio Estado. A intromissão demasiada do Estado sobre a esfera dos negócios tipicamente privados, ao negligenciar as regras do mercado, não poderia levar a outras consequências que não o fracasso econômico e o enriquecimento dos seus administradores à custa da sociedade. Além disso, a visão do empresário como um “inimigo”, típica a alguns setores da vida pública, inclusive da magistratura, fez com que sobre ele recaíssem exigências legais, administrativas e judiciais desproporcionais, a impedir a sua inserção e desenvolvimento no mercado. Por fim, a excessiva tutela estatal do cidadão, ao privá-lo de responsabilidade, naturalmente dificulta o seu amadurecimento, impedindo-o de ver na concorrência, no trabalho e no mérito o verdadeiro sinal do desenvolvimento.

Porém, se a economia e a vida em sociedade reclamam o redimensionamento do Estado e uma menor interferência sobre os negócios e a vida das pessoas, o que está em jogo é a liberdade. Sucede que a liberdade, além de não poder ser sufocada por regras e posturas que ignorem a importância da participação do particular na economia, para frutificar depende de pressupostos que exigem providências de ordem normativa e mesmo jurisdicionais.

O Código de Processo Civil brasileiro (2015) revela grande preocupação com a segurança jurídica, requisito sem o qual a liberdade não tem condições de se realizar. Ressalta a relevância da estabilidade e da coerência do direito, apontando para a importância da previsibilidade das decisões judiciais ²⁵⁴ e, deste modo, para a necessidade de os juízes respeitarem precedentes. ²⁵⁵

Como é óbvio, ninguém pode investir na produção, gerando trabalho, sem ter previsibilidade acerca das consequências do seu trabalho. Na verdade, como disse MacCormick, a previsibilidade das decisões constitui *valor moral imprescindível* para o homem, *de forma livre e autônoma*, poder se desenvolver e, portanto, estar num Estado de Direito,²⁵⁶ ou seja, num Estado que assegure a estabilidade e a previsibilidade do direito. Aliás, é nesse sentido que MacCormick fala em “ética do legalismo”.²⁵⁷

Além de frisar a importância do respeito aos precedentes para a proteção da segurança jurídica,²⁵⁸ o Código de Processo Civil brasileiro instituiu a coisa julgada sobre questão.²⁵⁹ Não há dúvida que a oportunidade de poder rediscutir o que já foi decidido, especialmente a possibilidade de rediscutir o que já se decidiu tão somente por se estar diante de um adversário com outro rosto,²⁶⁰ é um grande achado para quem é avesso à generalidade do direito e gosta de apostar na sorte de um novo caso.²⁶¹

Os precedentes obrigatórios e a coisa julgada sobre questão têm grande importância para demonstrar como o processo civil pode colaborar para a promoção da liberdade. Garantir a segurança jurídica é indispensável para que o homem possa livremente se autodeterminar em suas escolhas e, assim, para que a sua vida e negócios possam se desenvolver. Isto também é fundamental para que a economia possa frutificar, sendo este aspecto conhecido há muito tempo, ou desde que Max Weber relacionou a racionalidade formal do direito ao desenvolvimento econômico.²⁶²

Alude-se a outra feição da liberdade – muito menos relevante – quando se tem em conta a prevalência da vontade das partes *no processo*. É certo que a liberdade também é importante dentro do processo, já que em algumas situações a vontade dos litigantes pode colaborar para o fluir tempestivo e racional da marcha processual. Ocorre que o processo não pode esconder os valores do Estado – impressos na Constituição –, na medida em que cabe ao juiz, ao atuar e ao decidir, não apenas revelá-los, mas fazê-los realidade.

Significa, em outras palavras, que não há qualquer contradição entre processo preocupado com a liberdade e processo preocupado com os objetivos do Estado, ou mesmo qualquer problema em preservar valores do Estado em detrimento da vontade das partes. O processo contemporâneo deve dar vazão à vontade dos litigantes, desde que com isso não sejam prejudicados os valores que o Estado não pode deixar de atuar.

Na realidade, tudo seria muito simples se não fosse a tola e falsa ideia de tentar equiparar, em algumas situações específicas, fins do Estado com fins de um Estado autoritário e distante da democracia.²⁶³ Nestes casos, deixando-se a honestidade intelectual de lado, investe-se na retórica para confundir autoridade do Estado - reflexo de qualquer Estado de Direito - com autoritário, arbitrário e não democrático. Trata-se de uso descuidado da argumentação em detrimento da racionalidade do discurso, que gera prejuízos ao diálogo e à compreensão dos temas jurídicos.

9.2. Convenção processual, liberdade e fins do processo

A simples admissão de convenção processual é sinal de que o Estado deve contar com a colaboração das partes para a otimização do processo.²⁶⁴ No entanto, o registro da possibilidade de convenção processual está longe de significar que as partes passaram a ter poder para delinear o “modo de ser” do processo em seu exclusivo proveito.²⁶⁵

Engana-se quem imagina que o processo civil, *por também servir* à resolução de conflitos, pode se comportar de acordo com o interesse das partes envolvidas no conflito a ser solucionado. Isso não pode ser assim basicamente pelo fato de que o processo não se destina a atender episodicamente aos litigantes, como se estes fossem usuários de um sistema privado.²⁶⁶

O processo não pode se preocupar apenas com a resolução dos litígios nem muito menos se pautar no exclusivo interesse das partes. O Juiz tem compromisso com o desenvolvimento do direito e responsabilidade perante a sociedade.²⁶⁷ Portanto, o que impede a proeminência da vontade dos litigantes no processo não é o fato deste ser patrocinado pelo Estado, mas a

circunstância de que o Estado, mediante o processo, dever se desincumbir de grave responsabilidade, que obviamente está muito além do interesse das partes.²⁶⁸

Não fosse isso, há de se observar que o próprio modelo legal do processo tem inafastável compromisso com os direitos fundamentais. Assim, por exemplo, a coisa julgada sobre questão responde ao dever que o legislador possui de tutelar normativamente a segurança jurídica.

É absurdo supor que a liberdade no processo possa se sobrepor aos fins do processo, inclusive à tutela da segurança jurídica, indispensável à promoção da própria liberdade. Assim, a convenção processual sobre prova certamente não pode inibir a realização dos fins do Estado - inclusive a tutela da liberdade - revelados nas normas constitucionais e nos direitos fundamentais.²⁶⁹

9.3. A tendência à admissão dos negócios processuais

O Código de Processo Civil, alinhando-se a uma tendência desenvolvida, sobretudo, no direito francês, a partir da década de oitenta do século passado, abraçou, francamente, a contratualização do processo. Deve-se entender por essa expressão todos os acordos realizados na pendência de um processo judicial que disciplinam o modo como o magistrado deverá conduzir a tramitação da causa visando à prestação da tutela jurisdicional.²⁷⁰ Na base dessa ideia está a conclusão de que o fato de o processo ter natureza muito distante da contratual, e de a atividade jurisdicional assentar raízes em pressupostos muito diversos da convenção das partes não implica supor que sejam inadmissíveis acordos em relação a certos atos processuais ou a toda tramitação do processo.

Substancialmente, a experiência não é nova no ordenamento nacional. Conhece-se há muito diversas situações em que a vontade das partes pode disciplinar a organização do processo, impondo determinado rumo para o desenvolvimento do processo e para a prática dos atos processuais.

É evidente que esses pactos nada têm a ver com eventuais atos de disposição que interferem sobre o direito material. Figuras como a transação, a renúncia, o reconhecimento jurídico do pedido, obviamente, estão ligadas de forma direta ao poder de dispor do direito material e, portanto, ligam-se antes ao plano substancial que ao plano processual.

Quando se fala em contratos processuais, porém, pensa-se na derrogação de normas que tratam do desenvolvimento do processo judicial por meio da vontade das partes. Ou seja, pensa-se em impor determinada tramitação ao juiz da causa em atenção à vontade das partes. E nesse ponto há vários exemplos que podem ser invocados. Existem no Novo Código várias normas processuais que se enquadram nessa categoria, evidenciando a subordinação do desenvolvimento do processo às vontades das partes. Essas figuras, aliás, sequer são novas, possuindo correspondentes no CPC de 1973, de modo a demonstrar a familiaridade do direito brasileiro com esses acordos há tempos.

Sem dúvida, o caso mais emblemático é o da admissibilidade da cláusula de eleição de foro (art. 63), que derroga as regras de competência territorial ou fixadas em razão do valor no direito brasileiro. Ou seja, em que pese a especificação de regras fixando determinada competência territorial para o exame de determinadas causas, as partes podem, simplesmente, de comum acordo, eleger outro foro para a solução de sua controvérsia – acordo esse que se impõe ao magistrado, que não pode desconsiderá-lo. Situação muito semelhante tem-se no caso de prorrogação de competência diante da não arguição de incompetência relativa. Também aqui a jurisdição está limitada à atuação das partes que acaba lhe impondo determinada competência, independentemente do que prevejam as regras específicas sobre a questão.

Seguem na mesma linha as convenções sobre a suspensão do processo – que pode ocorrer, dentro de certos limites, por livre arbítrio das partes (art. 313, inciso II).

No campo da prova, sobressai como hipótese de acordo processual a possibilidade de as partes pactuarem a respeito do ônus da prova: a chamada convenção sobre o ônus da prova (art. 373, § 3.º). Por esse instrumento podem as partes criar regra para o comportamento no que tange à instrução do feito, e para o julgamento da causa em caso de inesclarecibilidade, impondo ao juiz,

que está em dúvida a respeito das alegações de fato, que presume ocorridos os fatos de determinada forma em prejuízo daquela parte que tinha o ônus da prova e não o desempenhou adequadamente.

Mais sutil que esses exemplos é aquele ligado à configuração da confissão no direito nacional. Muito se discute a respeito da natureza dessa figura. A questão será tratada de modo mais aprofundado oportunamente,²⁷¹ mas a orientação mais adequada é aquela que vê nessa figura uma dupla natureza. Em relação ao juiz, ela representa simples meio de prova, sujeita ao crivo da persuasão racional do magistrado. Na relação entre as partes, porém, a confissão opera verdadeiro ato de disposição por meio do qual uma das partes dispensa a outra de produzir prova a respeito de alegação de fato, vedando, ainda, a produção de prova pelo confitente que afaste a conclusão decorrente da confissão (art. 374, II).²⁷²

Enfim, a lei processual brasileira conhece, há muito tempo, hipóteses de acordos processuais por meio dos quais as partes impõem à jurisdição, dentro de certos limites, determinado ato ou solução processual.

O novo Código, porém, ampliou consideravelmente essas situações, autorizando as partes, praticamente, a dispor de todo procedimento previsto em lei. De fato, prevê o art. 190, que, sempre que a causa admitir autocomposição, podem as partes, desde que sejam capazes, estabelecer convenções sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. O juiz só pode recusar validade a esses acordos em caso de nulidade, de inserção abusiva em contrato de adesão ou quando verificar que uma das partes está em manifesta situação de vulnerabilidade (art. 190, parágrafo único).²⁷³

De outra parte, e aí independentemente da natureza disponível ou não do direito objeto do processo, podem as partes, conjuntamente com o juiz, estipular alterações no procedimento, fixando, por exemplo, calendário para a prática dos atos (art. 191).²⁷⁴ Seguindo a mesma orientação, diz o art. 357, § 2.º que as partes, no saneamento do processo, podem apresentar ao magistrado, para homologação, acordo sobre a delimitação das questões controvertidas. Em sendo homologado, tanto as partes, como o juiz, ficam vinculados a essas questões.

Outro exemplo claro desses acordos processuais pode ser encontrado no art. 471, que prevê que as partes podem, de comum acordo, sendo capazes e tratando-se de causa que admita autocomposição, realizar acordo sobre a escolha o perito judicial, caso em que a prova, assim produzida, terá a mesma eficácia que aquela realizada por perito escolhido pelo magistrado.

Enfim, vê-se que o Código ampliou extraordinariamente os poderes de disposição das partes sobre os atos do processo. Especialmente, diante de direitos disponíveis e de sujeitos capazes, é admissível uma radical alteração da feição do processo, o que certamente repercute na forma de agir, e de decidir, do magistrado.

9.4. Requisitos para a validade e eficácia dos acordos processuais

Já da leitura dos dispositivos acima indicados, vê-se que a permissão para que as partes disponham sobre as regras processuais não é absoluta.

Em certos casos, esse poder de disposição dependerá da capacidade plena das partes e da disponibilidade do objeto litigioso do processo. Assim, ocorre para a incidência do acordo processual decorrente da confissão. Como já dito, ela não é admissível em relação a direitos que não admitam autocomposição, nem pode ser realizada por sujeito incapaz. Do mesmo modo, essa é a exigência posta no art. 471, que trata da perícia convencional, por meio da qual as partes podem escolher o perito judicial, “impondo-o” ao magistrado.²⁷⁵

Quem examina, porém, as hipóteses em que é admissível a convenção sobre ônus da prova,²⁷⁶ nota que aí os requisitos não são idênticos. Em primeiro lugar, o Código prevê a nulidade da distribuição convencional do ônus da prova em dois casos: quando o direito objeto dessa convenção for indisponível, ou quando tornar excessivamente difícil o desempenho do ônus por

uma das partes. Embora a ideia de indisponibilidade possa ser reconduzida à incapacidade dos sujeitos, é certo que a situação da onerosidade excessiva constitui situação nova, não prevista nos preceitos anteriormente citados.

Por outro lado, os pressupostos para a modificação convencional da competência relativa são muito mais brandos. Basta que a cláusula que elege determinado foro não seja abusiva e que conste de instrumento escrito que aluda, especificamente, a determinado negócio jurídico, para que seja considerada válida (art. 63). Claro que a necessidade de que a cláusula de eleição de foro esteja prevista em contrato escrito impõe também a observância dos requisitos gerais do negócio jurídico, aí incluída a capacidade dos contraentes. Porém, não se exige a disponibilidade do direito. E, caso se pense na prorrogação da competência por não arguição da incompetência relativa, aí então sequer a incapacidade da parte – que estará representada em juízo, como exige a lei – ou a forma específica são exigidas. Bastará a conduta omissiva do advogado da parte, que não aponte, no prazo oportuno, o defeito (art. 65).

Para a aplicação da regra geral do art. 190 – que praticamente permite que qualquer ônus, poder, dever ou faculdade processual seja objeto de modificação convencional entre as partes – tem-se exigências mais severas. Como já dito, cabe ao juiz controlar a validade desses acordos, negando-lhes eficácia sempre que forem nulos – por qualquer razão –, quando abusivos ou envolverem parte em manifesta situação de vulnerabilidade.

Enfim, para as alterações processuais envolvendo as partes e o juiz, ou seja, para a fixação do calendário processual (art. 191), o controle judicial é concomitante à elaboração do acordo. Daí por que as exigências são ainda mais severas – visto que não exigem que as partes sejam capazes, nem que o objeto do processo seja disponível. O magistrado terá sempre o dever de rejeitar o acordo quando entender que ele é prejudicial ao processo, às suas finalidades ou mesmo ao equilíbrio das partes.

Em síntese, pode-se notar que não há absoluta homogeneidade nas exigências para os contratos processuais. Porém, parece ser possível estabelecer algumas linhas gerais que governam a validade de todos os acordos processuais.

Primeiramente, parece necessário fazer uma distinção fundamental: a convenção das partes pode envolver, exclusivamente, os seus próprios interesses no processo, ou podem abranger também a atividade jurisdicional. Pode-se imaginar, de um lado, acordo que afete, preponderantemente, os interesses das partes (por exemplo, quando se imagina a situação das partes que alterem, a seu critério, os seus prazos para a prática de atos do processo ou ainda aquela em que distribuem consensualmente a responsabilidade pelas despesas da condução do processo de modo diverso daquele indicado no Código). De outro lado, pode-se pensar em acordo que afete a atividade jurisdicional (por exemplo, a escolha, pelas partes, do perito judicial ou ainda a que limita a atividade do juiz na investigação das questões de fato envolvidas no processo).

Parece razoável concluir que, à medida que aumentam os deveres da jurisdição, diminui o espaço de convenção oferecido às partes.²⁷⁷ Particularmente, quando essas convenções não contam com a participação ou a anuência da jurisdição, sua imposição ao Judiciário deve revestir-se de maiores cautelas, como se verá a seguir.

9.4.1. Acordos que disciplinam apenas interesses das partes no processo

Na hipótese de convenção que só trata de interesses preponderantemente das partes, sem dispor sobre a atividade jurisdicional propriamente dita, a validade desses acordos deve sujeitar-se, em primeiro lugar, aos requisitos comuns exigidos para qualquer negócio jurídico.

Como esses acordos comprometem posições jurídicas das partes, mas não afetam diretamente a atividade do Estado; a princípio, deverão ser tratados como qualquer acordo entre as partes, exigindo agentes capazes, objeto lícito e forma prevista ou não proibida por lei. Desse modo, só poderão ser realizados se o direito for disponível (ou se os seus efeitos, objeto do processo, sejam disponíveis) e se os sujeitos envolvidos forem capazes – ou, pelo menos, se o sujeito que se obriga,

e pode ser prejudicado pelo acordo, for capaz.

Note-se que, ao contrário do que supostamente sugere a lei brasileira, pouco importa se o beneficiário desse acordo é incapaz ou não. Se ele é favorecido pelo acordo, não haveria razão para negar-se ao pacto validade. O que não poderia ocorrer é a permissão para o incapaz “dispor” de suas faculdades processuais – isso porque, nessa hipótese, o prejudicado poderia ser o incapaz, surgindo aí razão para se negar validade ao acordo.

Por outro lado, na análise da capacidade, deve-se inserir também a avaliação de eventuais limitações à disponibilidade de certos interesses. Assim, a pessoa casada está sujeita a certas restrições para a prática de atos processuais, que devem estender-se também para a disposição de atos do processo.

O preenchimento dos requisitos tradicionais dos atos jurídicos, todavia, pode não ser suficiente para a validade do negócio processual. É preciso observar que o processo possui objetivos próprios, perseguidos com base em direitos fundamentais, de modo que permitir acordos processuais indistintamente pode, paradoxalmente, implicar perda de liberdade para as próprias partes nele envolvidas. Isso quer dizer que o acordo sobre posições processuais não pode ser realizado à custa de renúncias a direitos fundamentais processuais em atenção apenas à vontade das partes.²⁷⁸

Assim, sempre que um desses acordos – mesmo que implique apenas restrição aos interesses das partes – violar um direito fundamental, eles devem ser desconsiderados. É o que ocorre, por exemplo, quando o acordo firmado entre as partes afrontar o direito ao contraditório ou direito à isonomia.

Aliás, as referências postas, em vários preceitos à vedação de acordos que tornem excessivamente difícil a atuação de uma das partes, ou que se imponham sobre parte manifestamente vulnerável; são evidentes reflexos da incidência dessas garantias fundamentais sobre o processo e, em consequência, sobre os acordos porventura aqui celebrados.

Do mesmo modo, os acordos entre as partes podem, eventualmente, afetar a garantia da duração razoável do processo. Imagine-se um acordo que preveja a ampliação demasiada de prazos processuais. Também aqui, poderá o magistrado intervir no acordo para negar-lhe eficácia, ainda que as consequências do pacto só digam respeito às posições jurídicas das partes. Isso porque, rigorosamente, o juiz tem competência para velar para razoável duração do processo (arts. 5.º, LXXVIII, CF/1988, e 4.º).

9.4.2. Acordos que afetam a atividade jurisdicional

Bem diverso deve ser o regime de eventuais acordos que afetem a própria atividade jurisdicional. E isso não apenas porque aí se envolve o próprio poder estatal, mas, também, porque a atividade jurisdicional não tem por única função a solução da controvérsia das partes. Os outros interesses que governam a atividade jurisdicional devem também ser pensados aqui, eventualmente merecendo esses outros valores prevalecer sobre o objetivo de oferecer às partes aquilo que elas desejam.

Entre esses acordos, que afetam a atividade jurisdicional, podem-se pensar naqueles que afetam a distribuição da competência entre os vários órgãos judiciais; e naqueles que se referem ao desenvolvimento do processo ou à forma de decisão do litígio. Em qualquer dos casos, a sujeição da atividade jurisdicional a acordos só é admissível nos limites da Constituição e da lei.

a) Acordos que afetam a distribuição da competência

As limitações que afetam a competência jurisdicional têm tratamento mais simples, já que aqui não se restringe a atuação do Estado, nem se limitam os deveres do magistrado para a condução ou para o julgamento do processo. Tais acordos apenas distribuem, de forma diversa, a atribuição para examinar as controvérsias nos casos em que a própria escolha legislativa tinha por finalidade atender preponderantemente aos interesses das partes.

Por essa razão, esses acordos não suscitam maior interesse. Embora afetem a atividade estatal, estão na disponibilidade das partes, exceto quando se verificar que, a rigor, não foi a vontade livre das partes que afastou a incidência do comando legal que atribuía a competência a determinado órgão. Assim, por exemplo, em contratos de adesão, não há propriamente a manifestação da vontade do contratante, que, simplesmente, adere às cláusulas previamente fixadas pelo outro sujeito. Por isso aí não se admite a disposição. Entretanto, se as partes optam voluntária, e conscientemente, por outro órgão jurisdicional para a solução de sua controvérsia – nos limites daquilo que lhes é facultado – então, a princípio, essa vontade deve prevalecer.

Note-se, porém, que essa disposição só será admitida em se tratando de regra posta à disposição das partes. Ou seja, é preciso que o próprio legislador tenha facultado às partes escolher outro foro para processar sua demanda. Do contrário, estar-se-á ultrapassando os limites legais e infringindo norma cogente.

b) Acordos que limitam os poderes jurisdicionais na condução e na decisão da causa

Quando o acordo afeta a própria atividade jurisdicional de direção e de julgamento da causa, o tema assume gravidade maior.

E não bastará, para que se aceite a possibilidade desses acordos, que se permita que o magistrado deles participe. Ora, o processo não pertence a um juiz determinado e, além disso, segundo as regras tradicionais, seria muito improvável conceber que o acordo feito por um magistrado seja oponível a outro (ou outros) que dele não participaram. Imagine-se um acordo, estabelecendo o calendário para a prática de atos processuais, celebrado nos termos do art. 191. O que deve suceder na hipótese de o juiz, que celebrou esse pacto, vier a se aposentar, a se remover, a se licenciar ou a ser promovido? Poderá o acordo ser obrigatório também ao seu sucessor, que jamais firmou qualquer convenção, ou anuiu a ela? Mais grave: firmado o acordo, com a anuência do juiz, pode o tribunal, em grau de recurso, entender que esse pacto vulnera normas impositivas, que prejudicou alguma das partes, ou ainda que é nulo por qualquer razão?

Eis a primeira grande dificuldade na aceitação desses acordos processuais que afetam a atuação do juiz no processo. O fato de não haver um único juiz vinculado ao processo, mas toda uma estrutura de órgãos por onde aquele feito poderá passar, torna muito mais complexo aceitar que, mesmo com a participação do magistrado no acordo, ele possa ser vinculante para o Judiciário. Aliás, sublinhe-se que o art. 191, ao prever que o calendário, convencionalmente celebrado entre o juiz e as partes, “vincula as partes e o juiz” (art. 191, § 1.º), não resolve o grave problema de estabelecer até onde há essa vinculação.

Por outro lado, mais complexo ainda é compreender a extensão que se deve dar aos acordos celebrados pelas partes (sem a participação do órgão jurisdicional) e que possam afetar as atribuições da jurisdição. Tome-se o exemplo da “perícia convencional”, em que, segundo a literalidade do art. 471, as partes teriam a prerrogativa de escolher o perito do juiz. É possível admitir, sobretudo, em face da multiplicidade de valores e de funções a que atende a jurisdição, que o juiz seja compelido, pela simples vontade das partes, a formar a sua convicção com base na análise de um expert que ele não conhece e em quem não confia?

Ou ainda, na forma do art. 190, seria possível que – mesmo diante de partes capazes e de um processo que discuta direito disponível – essas partes convencionassem a respeito dos seus deveres processuais,²⁷⁹ especialmente, exonerando-se de deveres de boa-fé processual previstos nos arts. 5.º e 77. Poderiam, por exemplo, liberar-se mutuamente do dever de expor em juízo os fatos conforme a verdade ou de cumprir com exatidão as decisões judiciais?

Ao que parece, a única solução possível nesses casos é aplicar aqui a mesma lógica que há muito tempo preside outros acordos semelhantes, a exemplo da confissão. Como se disse, a confissão deve ser vista com uma natureza dúplice. Na relação entre as partes, esse ato de disposição é vinculante, no sentido de dispensar a parte contrária de produzir prova sobre o fato e de sujeitar o confitente ao fato confessado, vedando-lhe o requerimento de provas em sentido contrário. Porém, na relação com o juiz, a confissão é, simplesmente, mais um meio de prova,

sujeito ao seu convencimento motivado.

O mesmo deve ocorrer em relação a qualquer outro acordo processual que *comprometa* a atividade jurisdicional de conduzir e de julgar o processo. Ainda que esse acordo possa vincular as partes do processo – podendo, eventualmente, uma parte exigir que a outra cumpra seus termos ou responda pelos prejuízos decorrentes – certamente, esse pacto não pode ser oponível ao juiz, sob pena de usurpação de regra de competência constitucional e legalmente conferida.²⁸⁰ Independentemente de o processo tratar de direitos disponíveis ou não, de as partes serem capazes e esclarecidas ou não; esses acordos não podem afetar o dever da jurisdição de prestar tutela aos direitos – o que, obviamente, não se confunde com a mera tarefa de resolver conflitos entre as partes.

Assim, esses acordos, desde que válidos, devem representar um parâmetro para a atividade jurisdicional. Mas não podem operar efeitos vinculantes para a jurisdição, especialmente, quando dificultem ou impeçam o cumprimento dos fins do Estado e da prestação da tutela dos direitos.

Em verdade, esses acordos apenas poderão ter algum grau de vinculatividade para o Poder Judiciário quando *incrementarem os objetivos da jurisdição*. Nesses casos, porque esses acordos estão alinhados aos objetivos *públicos* da jurisdição, é possível concluir que eles devem ser oponíveis também ao Estado-Juiz, exatamente porque as partes, no exercício de seu papel colaborativo, acabam aprimorando a atividade jurisdicional.

9.5. Considerações críticas

A tendência do processo à sua privatização, evidenciada, dentre outras figuras, pela ampliação da possibilidade de acordos processuais, é comum em países nos quais o processo civil está atrelado a litígios privados: França, Itália, Alemanha e outros países que desenvolvem, de modo separado, a análise da Justiça Civil, da Justiça Administrativa e da Justiça Tributária, por exemplo, tendem a ligar a atividade da Justiça Civil à solução do litígio das partes, e a função da Justiça “Pública” à atuação do Direito.

Porém, olhando-a de modo mais distante, é fácil perceber que a jurisdição tem funções muito mais amplas, que não podem ser resumidas à solução da controvérsia das partes. Por isso se mostra preocupante essa virada do processo em direção a centrar suas preocupações na resolução do litígio e, particularmente, no interesse das partes envolvidas.²⁸¹

A primeira leitura dos dispositivos do Novo CPC que tratam de negócios processuais parece indicar uma tentativa de trazer para o processo a ideologia e as linhas mestras da arbitragem, como se verá a seguir. Isso, porém, não apenas contrasta com o próprio papel do Estado, com a função epistêmica do processo e com a sua função de dar tutela aos direitos, como ainda traz para dentro do ambiente público as limitações e as insuficiências desses instrumentos privados de solução de controvérsias.

Essa privatização do processo civil, simplesmente, desconsidera todos os outros compromissos da jurisdição com seus mais elevados fins. Ao eleger a tutela do interesse das partes como primordial, o Código menospreza todos os outros valores que conformam o Estado e a atividade jurisdicional. Recorde-se que o processo civil brasileiro tem premissas muito diferentes, por exemplo, do processo civil estadunidense (pautado em grande parte pelo adversary system), em que se valorizam, extraordinariamente, a iniciativa e a condução da parte em favor da autonomia da vontade.

Comumente, afirma-se a favor dos acordos processuais que eles são decorrência natural da própria disponibilidade do direito material. Se as partes podem dar fim a um processo, desistindo da demanda, ou pleitear a qualquer tempo a sua suspensão, em favor de uma solução consensual da controvérsia, então que sentido haveria em se negar a elas o poder de ditar o andamento do processo e a forma de solução do litígio em juízo? Embora o argumento seduza em um primeiro momento, é necessário perceber que as concessões dadas pelo Estado em favor da vontade dos litigantes não podem ser tomadas como uma permissão geral, para que elas ditem aquilo que o

Estado deve ou não fazer de modo mais amplo. Se há espaço para que as partes optem por soluções consensuais e se, eventualmente, é admitido que as partes disponham de alguns momentos do processo, daí não decorre a conclusão de que, então, todo ato de disposição está e deve ser admitido. Essas limitações à atuação oficial do Estado devem ser vistas como parte da política pública de melhor atingir os próprios objetivos do Estado, e não como uma solução natural ao sistema de composição dos litígios.

Em conta disso, é preciso tomar com cautela a tendência à contratualização do processo civil, a fim de que esse não se converta em mero instrumento privado de solução de litígios. Lembre-se de que mesmo países tradicionalmente ligados ao adversarial system, em que se exaltam os poderes de disposição processual das partes, diante das injustiças que esse sistema é capaz de produzir, optaram por outorgar maiores poderes de condução do processo ao juiz (case management).²⁸² O ideal, portanto, é que se possa prestigiar a autonomia das partes sem negar ao processo sua função de tutela dos direitos na dimensão da Constituição.

9.6. Convenção sobre a prova e convicção judicial

A convenção sobre prova tem sentido quando as partes têm em consideração fatos cujo esclarecimento pode interessar a ambas. Assim, em face de um contrato, as partes podem convencionar que os eventuais litígios que daí surgirem devem ser solucionados mediante a produção de determinada modalidade de prova pericial.

O acordo de que os fatos devem ser investigados com base em certa espécie de prova não permite que uma das partes a recuse posteriormente, eis que estas livremente acordaram a sua utilização para o esclarecimento do litígio. Mediante tal acordo, as partes estão a colaborar para a adequada formação da convicção judicial.

Algo diverso ocorreria, porém, se as partes convencionassem que os fatos só poderiam ser verificados a partir de uma específica prova pericial. Neste caso, o juiz não estaria obrigado em face do acordo processual, na medida em que a formação da sua convicção não pode ser limitada pelas partes.²⁸³

Delimitar a prova que pode ser utilizada no processo ou restringir a prova que o juiz pode valorar para formar a sua convicção significa não apenas acordar sobre a prova que deve ser produzida, mas também negociar tomando em conta a convicção do juiz.²⁸⁴

Isto quer dizer que as partes podem convencionar sobre a prova quando não limitam a formação da convicção judicial, mas, ao contrário, estabelecem a importância de determinado meio de prova para que o juiz possa decidir com convicção.

9.7. Convenção em benefício da formação da convicção

As partes podem predefinir prova que reputam essencial para o esclarecimento dos fatos diante de eventual discordância. Essa convenção, além de não restringir a formação da convicção do juiz, fixa a importância de determinada prova para o devido esclarecimento da situação litigiosa, colaborando para a formação da convicção judicial e para a prestação da adequada tutela jurisdicional. O acordo, portanto, é claramente pautado na ideia de que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito *justa e efetiva*” (art. 6.º, CPC).

Esse acordo não impede que alguma das partes solicite a produção de *outra* prova, que a princípio será produzida ao lado daquela estabelecida na convenção. Não obstante, nenhuma das partes pode negar o acordo e, nesses termos, se opor à realização da prova.

Como é evidente, quando houver ocorrido circunstância nova ou que não poderia ser considerada à época do acordo, capaz de evidenciar que a prova não é idônea ou necessária para a demonstração dos fatos, qualquer das partes poderá demonstrar que, apesar do acordo, a prova não mais se mostra idônea ou útil e, desta forma, não deve ser produzida.

Por outro lado, o juiz obviamente poderá indeferir a produção da prova ao constatar que os fatos que por ela seriam evidenciados não importam para a solução do litígio ou sequer são controversos. Porém, quando os fatos importam para a solução de litígio, o juiz não poderá negar a produção da prova sob o argumento de que outra é mais adequada.

Mas também é válido o acordo em que as partes definem a impossibilidade de determinada prova, desde que garantida a adequada formação da convicção judicial. Considere-se, por exemplo, convenção que estabelece a proibição de prova obtida por meio de testemunha que sabe dos fatos apenas “por ouvir falar”. Nesta situação, fala-se no direito estadunidense em prova testemunhal por “*hearsay*”. David Taylor e Sara Cliffe, ao abordarem hipótese de convenção processual que proíbe a produção da prova testemunhal por “*hearsay*”, advertem que a convenção não pode prevalecer quando aquele que presenciou os fatos não tem condições de depor.²⁸⁵ Isso poderia acontecer, por exemplo, quando a pessoa que teve contato direto com os fatos já faleceu ou está impossibilitada de depor em virtude de enfermidade que não lhe permite adequadamente expressar sua vontade.

Note-se que a proibição da prova, neste caso, a princípio é admitida. Isto porque se parte do pressuposto de que, como a testemunha por “*hearsay*” não tem a mesma credibilidade da testemunha que presenciou diretamente os fatos, a convenção processual estaria a colaborar para a adequada formação da convicção do juiz.²⁸⁶

De qualquer modo, apesar da proibição da prova, em tal hipótese jamais se admitirá prejuízo à convicção do juiz, na medida em que, como antes dito, sempre será possível a investigação dos fatos por testemunhas que “ouviram falar” quando a testemunha presencial não tiver condições de depor.

Esse exemplo é importante exatamente porque demonstra que a convenção processual deve ser admitida quando objetiva aprimorar ou qualificar a convicção judicial, mas deve ser desconsiderada quando restringe a sua formação.

9.8. Convenção sobre prova e regra de exclusão

A recusa em produzir prova, em certas situações, é tutelada. Assim, por exemplo, a parte não é obrigada a depor sobre fatos “a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo” (art. 388, II, CPC), e a parte e o terceiro não são obrigados a exhibir o documento ou a coisa quando a “sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo” (art. 404, IV, CPC) ou ainda quando “subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição” (art. 404, V, CPC). A recusa não é tutelada apenas para proteger terceiros. A parte não é obrigada, por exemplo, a exhibir coisa ou documento “concernente a negócios da própria vida da família” ou que possam redundar em sua própria desonra (art. 404, I e III, CPC).

As regras que excluem o dever de produzir prova, ainda que baseadas em motivos legítimos, limitam a formação da convicção do juiz, assemelhando-se neste aspecto com a convenção processual sobre prova. Assim, seria possível pensar na possibilidade de as partes convencionarem, por exemplo, a impossibilidade de produção de prova capaz de revelar dados ou técnicas que não podem ser conhecidos pelo público. Como o acordo processual não pode criar regras de exclusão, dir-se-ia que as partes estão pautadas na cláusula geral (art. 404, V, CPC), referida acima, que dá ao juiz poder de aferir “motivos graves” que podem justificar a “recusa da exibição” de coisa ou documento e, assim, de dados ou tecnologias.

Sucede que, se as partes convencionam com base em uma cláusula geral de exclusão, obviamente não há como retirar do juiz o poder de, diante dos fatos e das particularidades do caso concreto, decidir se estão presentes “motivos graves” capazes de justificar a recusa da exibição. Em outras palavras, como as partes não podem criar ou alterar regras de prova ou mesmo se colocar no lugar do juiz, não há como admitir convenção processual destinada a excluir o dever de exhibir coisa ou documento.

Perceba-se que, ainda que fosse possível contratar a possibilidade de recusa de exibição de documento para uma hipótese particular, isto implicaria na difusão de regulamentos diferenciados para situações que devem ser tratadas da mesma forma. Para que isso não ocorra, é preciso a formação de precedentes que esclareçam o significado do pressuposto (“motivos graves”) que abre oportunidade para a recusa da produção da prova.

9.9. Poderes do juiz e convenção sobre a prova

Alguém poderia imaginar que a validade da convenção que limita a produção de prova tem relação direta com os poderes instrutórios do juiz. Assim, as partes poderiam livremente acordar que um litígio deve ser resolvido a partir da produção de determinada prova apenas quando o juiz não tem poder para determinar prova de ofício. Em caso contrário, entendendo-se que o juiz pode determinar a produção de prova sem requerimento da parte, o acordo sobre a prova estaria a impedir o juiz de exercer o seu poder instrutório. Como a convicção não estaria limitada à prova produzida em virtude da vontade das partes, o acordo também restringiria o poder do juiz.

Esta simplista relação entre convenção processual e poder instrutório pouco ajuda no tratamento do tema da convenção sobre prova. Bem vistas as coisas, tal relação guarda uma falsa e enganosa contraposição entre liberdade e poder instrutório. O obstáculo para convencionar sobre prova não deriva da intensidade do poder do juiz, mas do seu dever de prestar tutela jurisdicional com convicção.

Significa dizer que, mesmos nos sistemas em que o juiz não pode determinar prova de ofício, a convenção processual não pode restringir as provas para a solução de um litígio. Nessa situação, caso qualquer das partes possa demonstrar ao juiz que outra prova, distinta da predeterminada, é importante para o esclarecimento dos fatos litigiosos, o juiz não terá outra alternativa a não ser desconsiderar o acordo processual.

9.10. Convenção sobre prova e imprescindibilidade da devida convicção para a realização do direito fundamental à tutela jurisdicional e para o cumprimento do dever de o juiz prestá-la devidamente

Mas alguém poderia perguntar o motivo pelo qual não haveria legitimidade numa decisão baseada em prova não suficiente à aferição aprofundada dos fatos. O argumento seria o de que, se as partes podem acordar sobre o bem objeto do litígio, não haveria motivo para impedi-las de abrir mão de algumas modalidades de prova.²⁸⁷

Quando as partes convencionam sobre o uso exclusivo de determinada prova, como é evidente, não se pensa em decisão do litígio a partir de provas incapazes de permitir o adequado conhecimento dos fatos. Assim, para se admitir que as partes podem convencionar sobre a prova a despeito da convicção judicial, seria necessário entender que no acordo há uma *livre opção pelo risco* de a prova não se mostrar suficiente para a adequada formação da convicção do juiz.

Em outras palavras, não importaria saber se o litígio foi decidido com base nas provas capazes de permitir a formação do convencimento do julgador. A vontade das partes seria suficiente para legitimar a decisão, ainda que esta eventualmente estivesse fundada em convicção incapaz de traduzir como os fatos se passaram.

Ocorre que as coisas não podem ser assim. Ao menos quando se tem consciência de que todos têm direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e que a coisa julgada, quando vista como óbice à rediscussão de um litígio, é incondicionalmente ligada ao dever de o julgador buscar se convencer acerca da verdade para prestar a *devida* tutela jurisdicional.

O direito fundamental à tutela jurisdicional²⁸⁸ não pode se desligar do direito à utilização das técnicas processuais idôneas ao alcance da tutela prometida pelo direito material, assim como do direito à produção da prova capaz de permitir a elucidação das alegações de fato.²⁸⁹ De modo que o direito fundamental à tutela jurisdicional guarda em si o direito à prova, não obstante seja certamente possível categorizar este direito como um direito fundamental autônomo.

Isto quer dizer, precisamente, que o direito fundamental à tutela jurisdicional é violado em qualquer caso em que a parte não pode produzir prova capaz de permitir a demonstração de fatos. Assim, a restrição da prova em acordo processual não tem qualquer legitimidade quando uma das partes demonstra ao juiz que outra prova é necessária para a verificação dos fatos. Manter intacto o acordo processual, numa situação como esta, implica em entender que a parte abriu mão do seu direito fundamental à tutela jurisdicional no momento em que celebrou a convenção.

Contudo, o direito fundamental à tutela efetiva não é apenas um direito que tem como corolário o direito à prova, mas é um verdadeiro direito à prestação jurisdicional fundada em adequada convicção acerca da verdade. Entenda-se essa última como a convicção que o juiz deve buscar formar a respeito da relação entre as alegações de fato e a verdade.

É certo que o juiz, *em casos excepcionais*, pode decidir com base em *convicção de probabilidade*. Isso acontece quando há legitimidade na redução das exigências de convicção para a admissão dos fatos, como acontece, por exemplo, no caso de lesões pré-natais.²⁹⁰ Quando os fatos podem ser esclarecidos, no entanto, o juiz tem que formar *convicção de verdade* – ou seja, deve procurar se convencer da verdade a partir das provas idôneas à demonstração dos fatos – para prestar a *devida* tutela jurisdicional.

Nesta linha, o acordo processual que restringe provas nega o direito fundamental à tutela jurisdicional pautada em convicção de verdade, que também pode ser designado de direito fundamental à decisão justa.²⁹¹

Como é evidente, o dever do juiz não se limita à prestação formal de resposta jurisdicional. Incumbe-lhe prestar tutela jurisdicional tempestiva, efetiva e justa. Justa não apenas porque de acordo com os direitos fundamentais *materiais*, mas também no sentido de estar em conformidade com o que é possível averiguar sobre os fatos alegados. Quando em pauta a adequação da lei aos direitos fundamentais, é preciso que a decisão se funde em critérios objetivadores da identificação do conteúdo do direito fundamental, amparando-se em argumentação racional capaz de convencer.²⁹² No caso em que se discute como os fatos se passaram, a decisão tem que estar assentada em convicção lastreada nas provas disponíveis para a averiguação da verdade sobre os fatos.²⁹³

Não se deve confundir direito ao processo justo com direito à decisão racional e justa.²⁹⁴ A legitimação da jurisdição não depende apenas da observância dos direitos fundamentais *processuais* nem pode ser alcançada apenas pelo procedimento em contraditório. Note-se que o procedimento pode ser legítimo à luz das garantias processuais e, ainda assim, produzir decisão descompromissada com a substância das normas constitucionais.²⁹⁵ A legitimidade da jurisdição, além de depender da legitimidade do procedimento, requer a legitimidade da decisão, inclusive a sua conformidade com a convicção de verdade.²⁹⁶

Assim, e independentemente de o juiz poder determinar prova de ofício, o acordo processual sobre prova não tem validade quando prejudica a formação da convicção de verdade, pressuposto para a realização do direito fundamental à tutela jurisdicional e ao cumprimento do dever do julgador prestá-la devidamente.²⁹⁷

9.11. Convenção limitadora da prova e arbitragem

Sabe-se que em caso de litígio sobre direitos disponíveis as partes têm plena liberdade para atribuir a sua solução a um privado. Assim, seria possível supor que a convenção que livremente predetermina a exclusiva produção de determinada prova vincula o árbitro.

Nessa situação, o que implicaria a legitimidade da convenção processual seria o fato de as partes estarem diante do árbitro, em vez de na presença do juiz. Porém, há algum tempo restou estabelecido na legislação brasileira que “A sentença arbitral produz, entre as partes, e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo” (art. 31, Lei 9.307/96 - Lei da Arbitragem).

Se a sentença arbitral produz os mesmos efeitos da sentença do juiz, inclusive estabilidade semelhante à coisa julgada material, não há como admitir que a parte, ao se dirigir ao árbitro, possa ter um direito à resolução do conflito que seja desqualificado, ou melhor, um direito a uma decisão que não se paute em convicção de verdade. A decisão arbitral não teria legitimidade caso não fosse formada a partir do exaurimento das provas idôneas ao esclarecimento dos fatos que dão composição ao litígio.²⁹⁸

Tanto as partes têm direito fundamental a uma decisão arbitral pautada em convicção de verdade, quanto o árbitro tem dever de formar convicção, com base nas provas capazes de elucidar os fatos, para resolver o litígio que lhe foi submetido.²⁹⁹

Portanto, caso uma das partes faça ver ao árbitro a necessidade de produção de prova diversa da predeterminada no acordo, esse simplesmente deverá ser desconsiderado, deferindo-se a produção da prova solicitada. Ao negar a prova com base na convenção, o árbitro violará o direito fundamental à tutela jurisdicional. Se a arbitragem é equivalente jurisdicional, o árbitro obviamente não pode decidir em desatenção aos direitos fundamentais à tutela jurisdicional. Portanto, negada a prova sob a alegação de que a convenção a proíbe, há de se admitir ação de nulidade de sentença arbitral.³⁰⁰

No entanto, isso não significa que a convenção sobre prova não seja importante na arbitragem. A verdadeira vantagem da convenção sobre prova, tanto na jurisdição quanto na arbitragem, é a delimitação da prova que se entende imprescindível para a elucidação dos fatos do litígio.³⁰¹ Como é óbvio, não se deseja uma decisão pautada em probabilidade ou em convicção inadequada acerca dos fatos.

Nenhuma das partes, no Judiciário ou na arbitragem, pode recusar a produção da prova convencionada para o esclarecimento dos fatos, não obstante possam requerer a produção de outras provas. Do mesmo modo, nem o juiz nem o árbitro podem negar a produção da prova eleita pelas partes, a menos, é claro, que esta recaia sobre fato não pertinente ou irrelevante para a solução do conflito, ou mesmo incontroverso.

9.12. Os terceiros e a sociedade como destinatários da prova

Entretanto, as informações sobre os fatos e as provas que os esclarecem não são apenas do interesse das partes ou importantes unicamente para a prestação da tutela jurisdicional ou para a resolução do conflito de interesses.

Os terceiros não participantes do processo, têm interesse na prova emprestada e, especialmente, na coisa julgada sobre questão, que igualmente depende da possibilidade de produção de prova. Não há como sustentar que uma convenção não pode excluir prova em virtude do eventual interesse de terceiro na sua utilização em outro processo, mas o terceiro pode invocar a coisa julgada sobre questão - formada em processo de que não participou - em seu benefício.

Se a coisa julgada sobre questão não se forma quando as partes estão obstaculizadas de requerer a produção de prova, é claro que a convenção que a restringe elimina a coisa julgada não só em benefício de terceiro, contrariando os propósitos de proteção do valor constitucional da segurança jurídica, imprescindível para a promoção da liberdade e para o desenvolvimento da vida social.

Ademais, a sociedade espera orientação do Judiciário para poder ter previsibilidade em relação às suas decisões futuras. Essa orientação, como se sabe, frutifica por meio dos precedentes das Cortes Supremas. Sucede que a formação de precedente, nos casos dependentes do esclarecimento de fatos, exige a produção de prova. Como não é difícil perceber, a restrição das provas, em convenção processual, pode não só inviabilizar a instituição de precedente, mas também constituir estratégia para evitar a sua formação.

9.13. Convenção sobre prova e coisa julgada sobre questão

A contradição entre decisões é tanto maior quanto mais se pode rediscutir o que já foi decidido, o que significa que o afastamento da coisa julgada da questão necessária ao julgamento do litígio simplesmente legitimou dogmaticamente um sentimento avesso à generalidade do direito, próprio à cultura patrimonialista do “homem cordial”, que sempre se valeu do “jeito” para obter tratamento particular e arbitrário diante da administração pública e do Judiciário.³⁰²

Como é evidente, não há como admitir convenção processual que inviabilize a coisa julgada sobre questão. Não apenas porque esta forma de coisa julgada, inclusive no direito brasileiro, pode ser invocada por terceiro,³⁰³ mas também porque a segurança jurídica não pode ser negligenciada pelo simples fato de as partes estarem de acordo em não admitir a produção de prova necessária à investigação aprofundada de fatos imprescindíveis à devida solução da questão de que depende o julgamento do litígio.

A coisa julgada sobre questão, instituída no art. 503 do Código de Processo Civil brasileiro de 2015, tem nítido parentesco com o *collateral estoppel*. No direito estadunidense entende-se que, se o autor foi vencido apesar de ter tido ampla e justa oportunidade para litigar, não se confere vantagem aos litigantes e ao sistema judicial ao se permitir a relitigação da questão.³⁰⁴ Por isso, proíbe-se a relitigação da questão que foi discutida e decidida.³⁰⁵ Porém, quando determinado procedimento restringe a produção da prova,³⁰⁶ impedindo a devida discussão da questão, afirma-se, com base no § 28 do *Restatement (Second) of Judgments*, que a parte não teve “*full and fair opportunity*” para discutir a questão,³⁰⁷ negando-se eficácia preclusiva à decisão da questão.³⁰⁸

A configuração do *collateral estoppel* requer que as alegações que dão origem à questão tenham sido negadas (*put in issue*) e que as partes tenham tido adequada oportunidade para discuti-la.³⁰⁹ A mesma ideia está presente no art. 503 do Código brasileiro, que expressamente afasta a configuração da coisa julgada sobre questão quando há “restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial” (art. 503, § 2.º, CPC).

O objetivo claro, tanto do § 28 do *Restatement (Second) of Judgments*, quanto do art. 503, § 2.º, do Código brasileiro, é evitar a proibição da relitigação da questão quando a parte sequer pôde discuti-la. Mas, exatamente porque a parte sempre poderia contestar a proibição de relitigação sob a alegação de que teria outra prova para produzir, rejeita-se o argumento de que outra prova – que deixou de ser produzida – poderia ser mais convincente.³¹⁰

Não se pense que, quando as partes abrem mão da produção da prova por meio de acordo, não há motivo para excluir a coisa julgada sobre a questão. A coisa julgada exige a possibilidade da discussão da questão e, assim, é incompatível com a restrição probatória. Aliás, o art. 503, § 1.º, II, do Código brasileiro exclui a configuração de coisa julgada sobre questão em caso de revelia.

No direito estadunidense, a generalidade da doutrina³¹¹ não admite a incidência do *collateral estoppel* nos casos de “*default judgments*” (julgamentos em caso de revelia, embora as Cortes estaduais³¹² já tenham admitido *collateral estoppel* em tais situações.³¹³ Para justificar a inexistência de *collateral estoppel* em caso de “*default judgment*”, alega-se que o *collateral estoppel*, neste caso, não serviria para evitar contradição entre decisões, já que os efeitos da revelia excluem os fatos do *thema probandum* e da convicção judicial, não existindo juízo e, portanto, possibilidade de incoerência entre decisões. Entretanto, o verdadeiro fundamento para a rejeição do *collateral estoppel* é o de que a parte que escolhe não contestar, apesar de estar ciente das consequências da sua omissão no processo, dificilmente pode prever as suas consequências futuras, ou seja, os efeitos panprocessuais da revelia, a impedir a relitigação da questão em processos futuros.³¹⁴

A convenção processual, além de excluir a possibilidade de discussão da questão e, assim, impossibilitar a convicção judicial que deve estar à base de uma decisão que, além de produzir coisa julgada, afeta o resultado de outras ações, dificilmente permite prever que a decisão de questão poderá interferir sobre *eventual* processo futuro. Bem por isso, ciente dos benefícios e também dos prejuízos que a coisa julgada sobre questão pode acarretar, o Código brasileiro expressamente excluiu a coisa julgada em qualquer caso em que há restrição à produção de prova (art. 503, § 2.º, CPC), *não importando se esta restrição é legal ou convencional*.

Portanto, independentemente do ângulo por meio do qual se analisa o problema, não há como admitir coisa julgada sobre questão quando há acordo que limita a formação da convicção. Diante disso, cabe perguntar se a vontade das partes – ou seja, a convenção processual - pode impedir a formação da coisa julgada. Lembre-se de que a restrição da coisa julgada ao pedido e, por consequência, a ação declaratória incidental, estimuladas pelos teóricos que favoreceram o surgimento da ZPO de 1877,³¹⁵ pautaram-se na ideia de liberdade própria ao final do século XVIII e à primeira metade do século XIX.³¹⁶ Porém, se não há dúvida de que os conceitos que estiveram por detrás da ZPO e influenciaram o art. 34 do *Codice di Procedura Civile* foram influenciados pela ideia de que a vontade dos litigantes deveria presidir o campo de operação da coisa julgada, nos dias atuais não há como ver na autonomia da vontade fundamento para excluir a coisa julgada da questão.

Afinal, a coisa julgada é um elemento de direito público, indispensável à proteção da segurança jurídica e da coerência do direito. É interessante que Chiovenda, ao tratar da ação declaratória incidental, não enfrentou adequadamente a questão de se a coisa julgada pode ficar na dependência da vontade do jurisdicionado. Ao se deparar com a observação de Cameo, de que a coisa julgada sobre questão não pode depender da vontade das partes, limitou-se a responder: “esta observação *seria exata apenas se fosse verdade* que a coisa julgada é um fenômeno necessariamente ligado à ‘questão’, que se forme onde quer que há uma questão e não se forme se não há uma questão”.³¹⁷ Chiovenda fugiu da discussão sob a afirmação de que, se não há coisa julgada sobre decisão incidente, não há motivo para perguntar se a coisa julgada estaria sendo subordinada a pedido. Contudo, importa grifar que Chiovenda reconheceu que a ponderação de Cameo, no sentido de que a coisa julgada não pode depender da vontade dos litigantes, seria exata somente se admitido que a coisa julgada pode recair sobre a questão.³¹⁸

A coisa julgada sobre questão importa para o Estado e para a sociedade, sendo imprescindível para a tutela da segurança jurídica e da coerência do direito. O Código brasileiro de 2015, ao instituir a coisa julgada sobre questão e abandonar a desacreditada ação declaratória incidental, optou pela tutela da segurança jurídica em detrimento da ultrapassada suposição de que a liberdade poderia ser violada se a coisa julgada se formasse independentemente de pedido.

De modo que a coisa julgada sobre questão obviamente não pode ser deixada de lado em virtude de convenção entre as partes. Diante da invalidade da convenção, qualquer das partes pode requerer a produção da prova a princípio vedada. Também o juiz, ao verificar a necessidade de outra prova, pode determiná-la de ofício.

9.14. A importância da devida informação sobre os fatos para o desenvolvimento do direito e para a garantia da sua unidade

A resolução de conflitos está longe de ser a única função da jurisdição. Cabe ao Judiciário, entre outras relevantes funções, atribuir sentido ao direito e desenvolvê-lo de acordo com a evolução da sociedade.³¹⁹

Uma das consequências do desenvolvimento da teoria da interpretação é a aceitação da indeterminabilidade, menor ou maior, dos resultados extraíveis dos textos legais.³²⁰ Ademais, o juiz, ao interpretar a lei, muitas vezes deve ter em consideração as normas que instituem direitos fundamentais, as quais, em razão da sua textura aberta, exigem valorações atentas a fatos e valores sociais.³²¹

A dissociação entre texto e norma, a técnica das cláusulas abertas e o impacto do constitucionalismo deram à decisão judicial um significado bem distinto daquele imaginado por quem supunha que a missão do juiz era declarar a norma contida na lei. A decisão judicial, não só pela circunstância de que resulta de uma atividade interpretativa que contém valorações e decisões de conteúdos externos ao texto da lei, mas também em virtude das regras legais que convidam o juiz à sua concretização segundo as circunstâncias do caso e da imprescindibilidade de a lei ser conformada aos ditados da Constituição, certamente agrega sentido ou substância à ordem legislativa. Essa última, portanto, não é suficiente para orientar a sociedade ou para

sozinha espelhar o direito que conduz a vida social.³²²

Contudo, se todos os juízes têm poder para interpretar a lei, as Cortes Supremas têm a função de definir o sentido do direito, atribuindo-lhe unidade.³²³ Isto ocorre por meio de precedentes, ou melhor, mediante decisões que, revelando fundamentação hábil (*ratio decidendi*) a definir a questão jurídica, não podem deixar de ser observadas pelos demais juízes - ao menos num Estado de Direito.³²⁴ Realmente, como diz MacCormick, fidelidade ao Estado de Direito requer que se evite qualquer variação frívola no padrão decisório de um juiz ou corte para outro.³²⁵

Não obstante a definição do sentido do direito ocorra apenas nas Cortes Supremas, é imprescindível prévio debate e o amadurecimento da discussão perante os tribunais ordinários, de modo que o processo tem grave responsabilidade pela definição do direito capaz de responder de forma adequada às necessidades sociais. Para que o Judiciário possa atribuir sentido ao direito e desenvolvê-lo, informações adequadas sobre os fatos são imprescindíveis,³²⁶ daí importando não só a função do *amicus curiae*,³²⁷ como também a ideia de que a prova não importa apenas para a resolução do caso concreto, mas também para a fixação do precedente e, portanto, para a atribuição à sociedade do direito que deve orientá-la.

O resultado de ação ressarcitória em que se alega que a composição de um produto agrícola causou prejuízos à saúde tem grande interesse social. Num caso como este, o acordo que restringe a prova, ao impedir a adequada verificação dos efeitos do produto, pode retirar do Judiciário a possibilidade de definir a questão da responsabilidade pela sua comercialização.

Ainda que a Corte Suprema não possa valorar a prova, questão de direito relacionada à responsabilidade civil, ao abrir oportunidade para a intervenção da Corte, exige que o seu raciocínio decisório parta do pressuposto de que a composição do produto traz prejuízos à saúde, conforme evidenciado mediante a prova. Assim, embora a Corte trate apenas da questão de direito, a sua decisão poderá definir que há responsabilidade pela comercialização do produto agrícola. Lembre-se de que a Corte Suprema, ao firmar o precedente, julga o caso e não apenas decide a questão de direito em abstrato.

O exemplo demonstra claramente que a vontade das partes, ao excluir a produção de prova, pode impedir o Judiciário de definir o direito que deve orientar a sociedade e regular os casos conflitivos, prejudicando-se a segurança jurídica e, assim, a liberdade e a igualdade.

9.15. Convenção sobre prova, segurança jurídica, liberdade e igualdade

Se a convenção que restringe a prova pode impedir a formação de precedente e, por conta disso, não pode ser admitida, também ela deve ser vedada quando a vontade das partes puder impedir que o processo responda aos seus fins, entre eles o de tutelar a segurança jurídica.³²⁸

Quando se tem claro que os precedentes das Cortes Supremas, responsáveis por definir as questões de direito infraconstitucional e constitucional, devem ser observados por todos os juízes do país, investe-se contra a variação de decisões para casos similares em nome da segurança jurídica.

A previsibilidade pressupõe univocidade de qualificação das situações jurídicas.³²⁹ Se essa qualificação depende das decisões judiciais - que, em princípio, podem ser várias -, a previsibilidade está nas mãos das Cortes Supremas, cuja função é atribuir sentido ao Direito e garantir a sua unidade. Porém, se a previsibilidade pressupõe univocidade, ela igualmente depende da efetividade do sistema jurídico enquanto capacidade de garanti-la.³³⁰ Trata-se de constatar que um ordenamento incapaz de permitir previsões e qualificações jurídicas unívocas, e de gerar, assim, um sentido de segurança nos cidadãos, não merece sequer a qualificação de jurídico.³³¹ Daí a razão pela qual os precedentes obrigatórios constituem uma simples, mas inafastável, consequência da função outorgada às Cortes Supremas.

A coisa julgada sobre questão também tutela a segurança jurídica.³³² É certo que o Estado tem o dever de tutelar mediante normas a segurança jurídica, e assim revestir as decisões sobre os

litígios de coisa julgada. Contudo, alguém poderia dizer que, não obstante tal dever, a coisa julgada não precisa necessariamente recair sobre as decisões incidentes. Isso estaria correto se essas decisões não tivessem importância e significado para os litigantes, assim como para a sociedade e para o Estado. Porém, a estabilidade das decisões *sobre questão* é muito importante para os litigantes, assim como para a harmonia da vida social e para o desenvolvimento econômico do país. Além disso, a previsibilidade do que pode ocorrer diante de uma eventual e futura ação, em que a questão já decidida possa voltar a aparecer, é indispensável para que o homem saiba como deve conduzir a sua vida e os seus negócios sem ser perturbado e prejudicado, inclusive pelo Estado em suas várias formas, mesmo enquanto juiz.

A segurança jurídica é indispensável para a promoção da liberdade. Sem segurança jurídica o homem não tem liberdade para predeterminar suas escolhas, o que impede o seu desenvolvimento e o dos seus negócios, prejudicando a própria economia. A previsibilidade sempre foi indispensável à vida dotada de racionalidade e também para o desenvolvimento do capitalismo.³³³ Portanto, a variação das decisões judiciais, ao significar falta de critérios para o empresário definir suas estratégias de ação e de investimento,³³⁴ certamente conspira contra a economia.³³⁵

Mas a tutela da segurança jurídica também é imprescindível para a promoção da igualdade. Nada viola tanto a igualdade quanto dar, a quem teve o seu direito violado ou sofre iminente ameaça de tê-lo, uma decisão desconforme com o padrão já definido pelo Judiciário em casos similares. Após a Corte Suprema ter firmado precedente, não há como admitir, por parte de qualquer juiz ou tribunal, uma decisão que apresente razões divergentes. É inconcebível não perceber que uma decisão desse porte faz pouco caso não só do Estado de Direito e do Judiciário, mas também da igualdade, representando lamentável arbitrariedade ou ingenuidade inescusável.³³⁶ A igualdade perante as decisões judiciais é fruto do dever de o Estado dar a todos que estão em uma mesma situação a solução que a Corte Suprema racionalmente delineou, mediante as melhores razões possíveis. Afinal, todos os homens em condições iguais merecem a melhor solução que o Estado pode conceber para lhes garantir uma vida justa. É neste sentido que se diz que o valor constitucional tutelado pelo sistema de precedentes é a igualdade, realizada empiricamente mediante a vinculação dos tribunais e juízes ao “direito” delineado pela Corte Suprema, dependente da evolução da vida social, aberto ao dinamismo de um sistema voltado à atuação de princípios fundamentais munidos de inesgotável carga axiológica e atento à devida percepção das diferenças.³³⁷

Mas é ainda mais clara a violação da igualdade diante das questões *discutidas, decididas e não cobertas pela coisa julgada*. Se a negação do precedente firmado em caso em que figuram partes *diversas* é grave, muito pior é admitir que aquele que *já discutiu* a questão possa negar a decisão que a seu respeito foi proferida, como se o fato de estar litigando com o mesmo adversário em um segundo processo ou simplesmente com outro adversário outorgasse alguma racionalidade para o Judiciário decidir várias vezes a *mesma* questão.³³⁸

Tudo isto significa que as convenções processuais que restringem prova, exatamente porque podem inviabilizar a coisa julgada sobre questão e a formação de precedentes, negam um dos principais fins do processo, o de tutelar a segurança jurídica. Desse modo, e por consequência, as convenções limitadoras de prova também impedem que o processo realize os seus objetivos de promoção da liberdade e da igualdade.

10. A conduta processual dos sujeitos como meio de prova

10.1. A importância do comportamento dos sujeitos para o processo

A conduta processual dos sujeitos processuais e, particularmente, das partes é, inquestionavelmente, relevante para o desenvolvimento do processo. A legislação processual atual é pródiga em exigir certa conduta dos sujeitos que interferem na relação processual, seja exigindo que eles colaborem para a justa e efetiva decisão de mérito em tempo razoável (art. 4º), seja impondo-lhes que ajam sempre de boa-fé (art. 5º). Impõe-se, ademais, inúmeros deveres a esses

sujeitos (art. 77), o que permite concluir que o comportamento que *todos os sujeitos processuais* desempenham pode ser sim relevante para diversas consequências ao longo do processo.

Particularmente, no que respeita à prova, esse comportamento pode repercutir, sem dúvida, tanto no delineamento das afirmações de fato que deverão ser provadas, como na sua própria demonstração.

Assim ocorre, por exemplo, com a revelia. A inércia da parte em apresentar-se no processo e oferecer contestação implica, na ótica do legislador, a suposição de que as afirmações de fato deduzidas pelo autor devem ser presumidas verdadeiras, não carecendo de ser demonstradas (art. 344 do CPC). Do mesmo modo, atos jurídicos celebrados pelas partes, previamente ao processo, podem repercutir na distribuição do ônus da prova (art. 373, § 3.º, do CPC) ou mesmo na dispensa de prova sobre certo fato (diante da confissão, cf. art. 374, II, do CPC). Na mesma linha, a não apresentação de documento que esteja em posse da parte pode repercutir em seu desfavor, fazendo o juiz supor que o fato que seria demonstrado com esse documento deve ser interpretado contrariamente à parte negligente (art. 400 do CPC).

Necessário, porém, é cogitar sobre se somente em tais casos, e diante de regra legal expressa, é que a conduta das partes pode ser relevante para a formação da convicção do juiz. Por outras palavras, importa examinar se, mesmo ao lado dos casos expressamente arrolados pela lei, poderá o juiz extrair argumentos de prova da conduta das partes.³³⁹

10.2. A valoração legal da conduta processual dos sujeitos

Como se vê dos exemplos que acabam de ser dados, a legislação processual é repleta de presunções tomadas a partir da conduta das partes no curso da demanda. Em vários momentos, a experiência ditou ao legislador conclusões que podem ser extraídas a partir daquilo que o sujeito processual – às vezes, representado por seu advogado – faz ou deixa de fazer no processo.

Tal é o que ocorre, por exemplo, como já mencionado, com a presunção decorrente da revelia. Supõe-se que, se o réu não teve interesse em deduzir contestação no feito, é porque não tinha o que impugnar em relação aos fatos apresentados pelo autor. Em conta disso, deve-se supor como verdadeiros aqueles fatos, dispensando-se o autor de demonstrá-los em juízo. A presunção de veracidade associada à revelia, é bom frisar, não é universal ou necessária em todos os ordenamentos;³⁴⁰ no direito brasileiro, sua incorporação vem exatamente como sedimentação da suposição acima feita, no sentido de que aquele que não se defende, provavelmente, não tem argumentos para contrapor as afirmações de fato feitas pelo autor, razão pela qual estes devem ser tidos por verdadeiros. Vale dizer: o comportamento processual do réu, que de certo modo demonstra não ter alegações a contrapor ao fundamento da demanda, é tomada pelo legislador como argumento de prova, no sentido da veracidade das afirmações feitas pelo autor.

De modo idêntico – mesmo porque esse instituto é simples desdobramento da revelia – ocorre com a admissão (art. 341 do CPC). Cumpre ao réu em sua contestação, como cedo, impugnar todos os fatos alegados pelo autor na sua petição inicial, presumindo-se (salvo algumas exceções) verdadeiros os fatos não impugnados. Se a não impugnação de *todos* os fatos faz supor que sejam eles verdadeiros, seria mais do que natural considerar que a não impugnação de *um fato específico da causa de pedir* na contestação implica sua aceitação também como ocorrido.

A confissão ficta é ainda outro exemplo de presunção aplicada em razão da conduta processual da parte. Determina o Código que, intimada a parte a depor e não comparecendo, ou se recusando a depor, ou ainda empregando evasivas, é de se equiparar essa conduta à da confissão efetiva. De fato, supõe o legislador que essa sua omissão ou tais manobras empregadas pela parte podem significar que tem ela alguma coisa a esconder, de modo que essa sua conduta não pode vir em seu proveito. Assim, diante dessa omissão de colaboração da parte, há ela de arcar com os prejuízos decorrentes.

Na mesma linha se tem a presunção incidente sobre o descumprimento de dever de exibição de documento ou coisa (art. 400 do CPC).³⁴¹ Tendo a parte se recusado a exhibir a coisa que poderia

servir de prova no processo, é de se presumir que sua apresentação redundaria em prova contra ela. Daí ser lógica a presunção exposta no texto legal.

Também no Código Civil se vê exemplos dessa presunção incidente em matéria de prova. O art. 232 daquele Código, por exemplo, preceitua que “a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame”. O comando, extraído da experiência jurisprudencial, assenta-se exatamente na mesma premissa dos casos anteriores. Se a parte deixa de se submeter à prova ordenada pelo juiz, recusando-se *injustificadamente* a sujeitar-se à perícia determinada, é provável que a realização da prova viesse em seu prejuízo, razão pela qual é razoável concluir-se que essa negativa implique prova contra a parte. Daí a razão pela qual, segundo o art. 213 do mesmo Código, afirma que a recusa de alguém em submeter-se a exame médico não pode beneficiar o sujeito recalcitrante.

Enfim, vê-se que, em vários momentos a lei faz incidir efeitos probantes da conduta processual da parte ou, em termos mais gerais, de sujeitos do processo. Mais do que isso, pode-se perceber que, em certos casos, também a conduta processual da parte praticada por *seu representante legal* (advogado) é tomada para efeitos instrutórios, tal como ocorre com a revelia ou a admissão.

Seria, porém, viável extrair argumentos de prova da conduta da parte fora dos casos previstos em lei?

10.3. A conduta dos sujeitos processuais como prova atípica

A questão acima proposta exige, para sua resposta, a percepção de um dado simples: a conduta processual das partes é um fato jurídico. Aquilo que o sujeito processual faz – pessoalmente ou por seu advogado – ou deixa de fazer no processo é juridicamente relevante e interfere no andamento do feito. Dessa conduta, portanto, resultam efeitos processuais de várias ordens, de modo que é claro que essa atividade pode e deve ser considerada como jurídica.³⁴² Assim sendo, como fato jurídico que opera consequências relevantes para o processo, parece natural que esse comportamento dos sujeitos seja considerado pelo juiz no momento da decisão da controvérsia.

Isso porque, em primeiro lugar, é sabido que o sistema brasileiro admite expressamente o uso da prova atípica (art. 369, do CPC), de modo que não são só os meios expressamente regulados pelo Código que servem para a formação da convicção do juiz. Assim, qualquer elemento que possa forrar o magistrado com argumentos de prova – ainda que não expressamente regulados pela lei – pode ser, sem dúvida, empregada no processo.

A conduta processual dos sujeitos *não é propriamente uma prova atípica*, já que, como visto, há diversas situações em que a própria lei regra as consequências de certo comportamento processual. Muitos desses casos, é verdade, decorrem de raciocínio antes consolidado pela jurisprudência, o que acabou redundando na previsão legal dessa prática. A presunção legal estabelecida no art. 232do CC, em relação à recusa de submissão à prova pericial, por exemplo, decorre de anterior interpretação jurisprudencial formada antes da existência da norma.³⁴³ De todo modo, porém, é certo que o seu emprego generalizado pode sim ser visto como prova atípica, diante da falta de previsão legal expressa e geral a respeito desse uso.

A par disso, em um sistema como o brasileiro, que se pauta pelo princípio da convicção racional do juiz, parece certo que não é necessária previsão em lei para que o juiz seja autorizado a extrair argumentos de prova da conduta das partes e de terceiros que interferem na relação processual.³⁴⁴ Se, nos termos desse princípio, cumpre ao juiz apreciar a prova dos autos, indicando as razões de seu convencimento (art. 371 do CPC), nada impede que o magistrado considere o comportamento dos sujeitos processuais, desde que justifique adequadamente as razões que o levaram a extrair dessa conduta algum argumento de prova.

Assim, não deve dúvida da possibilidade do emprego da conduta dos sujeitos do processo como argumento de prova. Em outros países, aliás, essa aceitação é expressa na legislação, tal como ocorre com o art. 116 do Código de Processo Civil italiano (que permite ao magistrado extrair argumentos de prova “*dal contegno delle parti stesse nel processo*”). De modo menos amplo,

também prevê o Código de Processo Civil francês que as partes devem colaborar nos atos de instrução, podendo o juiz extrair todas as consequências decorrentes de alguma abstenção ou recusa nesse auxílio (art. 11). Embora a lei brasileira não tenha sido tão explícita e geral, parece clara a viabilidade do emprego desse mecanismo instrutório.

Desse modo, por exemplo, seria bastante razoável concluir que, demonstrada a destruição de autos ou de certo documento por ato voluntário de uma das partes, isso se ligaria à presença ali de prova em benefício do adversário. Tal conduta, portanto, certamente poderia implicar argumentos de prova contra a parte que assim agiu.³⁴⁵

Também seria razoável supor que, em determinados casos, o emprego de medidas protelatórias no processo fosse interpretado como prova contra a parte, ainda que não haja previsão legal a esse respeito.

No campo das demandas preventivas, outrossim, a formação da convicção judicial por meio da avaliação da conduta pretérita da parte é medida viável, especialmente diante da impossibilidade de se conseguir prova melhor para a decisão da questão.³⁴⁶ Nesse caso, aliás, a possibilidade de empregar a conduta da parte como prova vai além dos outros casos, já que se empregará a conduta dos sujeitos *antes do ajuizamento da demanda* como critério para influenciar a convicção do magistrado.

De toda sorte, é evidente que a conduta dos agentes processuais pode ser relevante para a formação do convencimento do juiz. Tais comportamentos (comissivos e omissivos) podem perfeitamente servir de base para a justificação da decisão judicial.

Posto isso, é de se questionar qual o regime a ser atribuído a essa prova. Parece que o raciocínio que mais se harmoniza com as peculiaridades dessa conduta é aquele próprio da prova indiciária. Isso porque o comportamento de algum sujeito processual sempre demandará certa intermediação de um raciocínio, que possa ligá-lo à existência ou à inexistência de certo fato relevante para o processo. Essa circunstância é muito própria da prova indiciária,³⁴⁷ de modo que há muita identidade entre aquilo que se faz na prova indiciária e o que é necessário fazer no emprego da conduta processual como prova.

A conduta processual das partes, então, pode permitir ao magistrado, por meio de raciocínio adequado, concluir pela existência ou não de fatos relevantes para o processo. Trata-se, então, de clara hipótese de presunção judicial, cujo valor dependerá da qualidade do indício e do raciocínio realizado pelo juiz.

Por isso, assume particular relevo a justificação dada pelo magistrado para o emprego desse elemento de prova. Como essa avaliação constitui prova atípica, não há prévio raciocínio do legislador capaz de gizar a conduta do juiz. Por isso, é fundamental que o juiz explique de maneira adequada quais as circunstâncias da conduta da parte que formaram a sua convicção e qual o raciocínio por ele empreendido para deduzir a existência de argumentos de prova.

Ademais, o comportamento do sujeito processual pode servir como argumento de prova tanto diante de algum fato isolado (ou ato processual específico), como em razão da sua conduta processual ao longo de todo o procedimento.³⁴⁸ Nesse passo, é possível cogitar se os argumentos de prova (em razão da conduta processual do agente) só podem derivar de *seu próprio comportamento*, ou se também podem derivar da conduta processual influenciada pelo advogado que eventualmente representa o sujeito. Como leciona Righi, “nessa perspectiva, como bem assinala Giorgetta Somogyia, a atividade da parte mostra-se ‘indissolúvelmente conexa à do próprio defensor’. Em outras palavras, o comportamento da parte é analisado sob ângulo do ‘modo de conduzir a causa’ – tarefa que cabe ao advogado”.³⁴⁹ De fato, praticamente todos os atos processuais praticados pelos sujeitos – e, em especial, pelas partes – são realizados por intermédio de seus advogados. Como seus representantes legais, agem eles no interesse e como mandatários de seus clientes. Logo, ainda quando a conduta não tenha sido “pessoalmente” praticada pela parte (ou pelo terceiro), é de se supor que o comportamento reflete o desejo da pessoa representada, de sorte que, mesmo assim, pode prestar-se para comprovar certo fato relevante para o processo.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Estranhamente, porém, embora a relevância do tema da prova (e dos fatos) no processo de conhecimento, observa-se nítido desdém da doutrina em tratar desta matéria. Prefere-se outorgar mais tempo ao debate de questões de direito, do que a questões de fato. A propósito, William Twining lembra das palavras de certo político, em um debate, que dizia que “certa vez foi sugerido que 90 por cento dos advogados gastam 90 por cento do seu tempo lidando com fatos e que isto deveria ser refletido nos seus treinamentos. Se 81 por cento do tempo dos advogados é gasto em uma coisa, daí decorre que 81 por cento da educação jurídica deveria ser devotada a isto. Existem alguns cursos isolados sobre descoberta dos fatos (fact-finding) e congêneres, mas nenhum instituto tem tido um programa completo em que a principal ênfase seja em fatos. Eu proponho que nós centremos nosso currículo neste princípio e que nós chamemos nosso grau um Bacharel de Fatos” (William Twining, *Rethinking evidence – exploratory essays*. Evanston: Northwestern University Press, 1994, p. 12). Conquanto certamente exagerada a estatística, é fato inquestionável que o tempo do operador do direito é gasto mais com a análise de fatos do que, propriamente, com a discussão de questões de direito. No entanto, dificilmente se observa uma grande preocupação com a caracterização dos fatos ou com o estudo detido dos princípios que regem sua exposição no processo (sobre as causas desse menosprezo, veja-se William Twining, *Rethinking evidence – exploratory essays*, ob. cit., p. 13 e ss.).

2

Como observa Chiovenda, “toda norma encerrada na lei representa uma vontade geral, abstrata, hipotética, condicionada à verificação de determinados fatos, que, em regra, podem multiplicar-se indefinidamente. Toda vez que se verifica o fato ou grupo de fatos previstos pela norma, forma-se uma vontade concreta da lei, ao tempo em que da vontade geral e abstrata nasce uma vontade particular que tende a atuar no caso determinado” (Giuseppe Chiovenda, *Instituições de direito processual civil*, vol. 1, trad. Paolo Capitanio, Campinas: Bookseller, 1998, p. 18). É assim que surge, na ótica deste jurista, a sua célebre definição de jurisdição, como tendo por escopo a atuação da vontade concreta da lei. V. tb., sobre a questão, Enrico Tullio Liebman, *Manuale di diritto processuale civile*, principi. 5. ed., Milano: Giuffrè, 1992, p. 318.

3

C.J.A. Mittermaier, *Tratado da prova em matéria criminal*. 2. ed., Rio de Janeiro: Eduardo & Henrique Laemmert Ed., 1879, p. 78.

4

Posição esta consagrada na visão de Aristóteles, com sua clássica noção de que “dizer daquilo que é, que é, e daquilo que não é, que não é, é verdadeiro; dizer daquilo que não é, que é, e daquilo que é, que não é, é falso” (apud Newton C. A. da Costa, “Conjectura e quase-verdade” in *Direito Política Filosofia Poesia: estudos em homenagem ao Professor Miguel Reale*, em seu octogésimo aniversário, coord. Celso Lafer e Tércio Sampaio Ferraz Jr. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 78).

5

Enrico Tullio Liebman, Manual de direito processual civil, tomo I, trad. de Cândido R. Dinamarco, Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 4.

6

Assim, aliás, acentua Carnelutti, ao ponderar que “noi sappiamo che il primo compito per giudicare è quello di ricostruire il fatto; non potrebbe il giudice procedere al confronto del fatto con la fattispecie prima di averlo ricostruito” (Diritto e processo, Napoli: Morano, 1958, p. 94). Da mesma forma, v. Carlo Furno, Contributo alla teoria della prova legale, Padova: CEDAM, 1940, p. 11.

7

Francesco Carnelutti, Op. cit., p. 124.

8

Gian Antonio Micheli; Michele Taruffo, “A prova” in Revista de Processo, n. 16, São Paulo: Ed. RT, out/dez 1979, p. 168

9

V. Oscar Chase, Law, culture, and ritual – disputing systems in cross-cultural context. New York: New York University Press, 2005, passim.

10

Significativas são, neste campo, as palavras de Chiovenda, que bem demonstram o espírito de sua época. Tratando da matéria e analisando a questão da interpretação do direito, dizia o mestre que “quando se fala de interpretação admite-se na lei um pensamento que o juiz nada mais faz do que aplicar”; e, logo a seguir, conclui que “a interpretação é obra da doutrina, não do juiz: e se a interpretação deve considerar-se como fonte do direito, é evidente que o juiz não faz mais que formulá-la” (Giuseppe Chiovenda, Principios de derecho procesal civil, vol. I, trad. de José Casais y Santalo, Madrid: Reus, 1922, p. 90-91). Também neste sentido manifesta-se Merryman que, ao analisar o juiz do direito continental europeu, salienta que “surge assim uma imagem do processo judicial como uma atividade bastante rotineira. O juiz converte-se em uma espécie de empregado especializado. Apresenta-se-lhe uma situação de fato para a qual se encontrará à mão uma resposta legislativa em todos os casos, exceto os extraordinários. Sua função consiste simplesmente em encontrar a disposição legislativa correta, compará-la com a situação legislativa correta, compará-la com a situação de fato e consagrar a solução que produz a união de forma mais ou menos automática. (...)”

A imagem clara do juiz é a do operador de uma máquina desenhada e construída pelos legisladores. Sua função é meramente mecânica. (...) O juiz do direito civil não é um herói cultural nem uma figura paternal, como o que é frequentemente entre nós. Sua imagem é a de um empregado público que desempenha funções importantes mas que resultam essencialmente pouco criativas” (John Henry Merryman, La tradición jurídica romano-canónica, trad. de Eduardo L. Suárez, México: Fondo de Cultura

11

V. a propósito, John Henry Merryman, *La tradición jurídica romano-canónica*, ob. cit., p. 41-42.

12

Como bem lembra Merryman, “o temor de um ‘gouvernement des juges’ pendia sobre as reformas francesas pós-revolucionárias e matizava o processo de codificação. O dogma na separação completa dos poderes, com todo o poder de legislação concentrado em uma legislatura representativa, era um procedimento para assegurar que se negasse ao poder judiciário a faculdade legislativa. A experiência dos tribunais pré-revolucionários havia feito com que os franceses temessem o poder legislativo dos juízes disfarçados de interpretação das leis. Para tanto, alguns autores sustentaram que deveria negar-se aos juízes mesmo a faculdade de interpretar a legislação” (John Henry Merryman, *La tradición jurídica romano-canónica*, ob. cit., p. 64).

13

Friedrich Lent, *Diritto processuale civile tedesco*, Napoli: Morano, 1962, p. 197. Neste mesmo sentido, Carnelutti, op. cit., p. 124-125.

14

Moacyr Amaral Santos, *Primeiras linhas de direito processual civil*, 3. vol., São Paulo: Saraiva, 1990, p. 46.

15

V. a respeito, Aloísio Surgik, *Lineamentos do processo civil romano*, Curitiba: Livro é Cultura, 1990, p.71; Vittorio. *Procedimiento civil romano – ejercicio y defensa de los derechos*. Trad. Santiago Sentís Melendo e Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: EJEA, 1954, p. 252-253.

16

Como bem pondera Carnelutti a respeito, o não julgamento por falta de provas, embora figura usual até hoje, representa, à toda evidência, um sinal de falha do sistema de tutela dos direitos. Como afirma o genial processualista, “entende-se até que o juiz possa ter esta tentação; entende-se, ao contrário, menos que, no campo do processo penal o legislador lhe autorize a ceder à tentação. A assim chamada absolvição por insuficiência de provas, com efeito, não é que uma rejeição de escolher; e portanto denuncia, como disse várias vezes, o insucesso da administração da justiça. Entre o sim e o não, o juiz, quando absolve por insuficiência de provas, confessa a sua incapacidade de superar a dúvida e deixa o acusado na condição em que se encontrava antes do processo: acusado por toda a vida” (Francesco Carnelutti, “Verità, dubbio, certezza” in *Rivista di diritto processuale*, vol. XX (II Série), Padova: CEDAM, 1965, p. 7).

17

Lei 8.078/1990, especialmente art. 103.

A propósito, acentua José Roberto dos Santos Bedaque, citando Francisco Campos, que “A direção do processo deve caber ao juiz; a este não compete apenas o papel de zelar pela observância formal das regras processuais por parte dos litigantes, mas também o de intervir no processo de maneira que este atinja, pelos meios adequados, o objetivo de investigação dos fatos e descoberta da verdade” (Poderes instrutórios do juiz, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 1994, p. 59). No mesmo sentido, e dentre outros, é a posição de José Carlos Barbosa Moreira (“Os poderes do juiz” in O processo civil contemporâneo, Curitiba: Juruá, 1994); José Rodríguez Urraca (“Las facultades probatorias del juez en el código procesal civil modelo para Iberoamérica” in Un ‘codice tipo’ di procedura civile per l’America Latina. Org. Sandro Schipani e Romano Vaccarella, Padova: CEDAM, 1990); Giovanni Verde (“Poteri del giudice e poteri delle parti” in Un ‘codice tipo’ di procedura civile per l’America Latina. Org. Sandro Schipani e Romano Vaccarella. Padova: CEDAM, 1990).

Apenas exemplificando esta visão, cabe mencionar o acórdão da 6.^a Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Recurso Especial 13.375-RJ, tendo como relator o Min. Vicente Cernicchiaro (j. 12.11.91), asseverou que “o processo penal é complexo de relações jurídicas que tem por objeto a aplicação da lei penal. Não há partes, pedido ou lide, nos termos empregados no processo civil. Juridicamente, acusação e defesa conjugam esforços, decorrência do contraditório e defesa ampla, para esclarecimento da verdade real. Ninguém pode ser condenado sem o devido processo legal. O assistente também é interessado na averiguação da verdade substancial”.

José Manoel Arruda Alvim, “Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil” in Revista de processo, n. 1, São Paulo: Ed. RT, jan/mar. 1976, p. 99.

Como bem observava Carnelutti, “o que aqui ao contrário me força constatar é como esta disciplina jurídica do processo de busca dos fatos controversos, alterando a sua construção puramente lógica, não consinta a rigor mais que se considere a busca da verdade no caso singular como o escopo ou melhor como o resultado do processo mesmo. Pode ser, como já observei, que isto ocorra precisamente por um intento de maior economia e segurança da busca na média dos casos; mas este intento, ainda que possa ser logrado com os meios indicados, não tolhe que, considerado diante do caso específico, o sistema dos limites à busca judicial reaja profundamente ao próprio resultado da busca. O conceito desta reação vem compediado comumente na antítese significativa da verdade material à verdade formal ou jurídica; o resultado da busca juridicamente limitada ou disciplinada não é mais a verdade material, ou, como se diria com um eficaz truismo, a verdade verdadeira, mas uma verdade convencional, que se batiza por verdade formal, enquanto com ela se conduz uma pesquisa regulada nas formas, ou por verdade jurídica, enquanto ela é buscada mediante leis jurídicas, não apenas mediante leis lógicas, e somente por efeito destas leis jurídicas substitui-se à verdade material” (Francesco Carnelutti, La prova civile, 2. ed., Roma: Ateneo, 1947, p. 29).

Veja-se, a propósito, a obra elementar para qualquer estudante da área, de Cândido Dinamarco, Ada P. Grinover e Antonio Carlos Araújo Cintra, Teoria geral do processo, 20. ed., São Paulo: Malheiros, 2004. Neste livro, com efeito, lê-se que “no campo do processo civil, embora o juiz hoje não mais se limite a assistir inerte à produção das provas, pois em princípio pode e deve assumir a iniciativa destas (CPC, arts. 130, 341 etc.), na maioria dos casos (direitos disponíveis) pode satisfazer-se com a verdade formal, limitando-se a acolher o que as partes levam ao processo e eventualmente rejeitando a demanda ou a defesa por falta de elementos probatórios”. E prosseguem os autores, lecionando que “no processo penal, porém, o fenômeno é inverso: só excepcionalmente o juiz penal se curva à verdade formal, quando não disponha de meios para assegurar a verdade real (CPP, art. 386, inc. VI)” (Ob. cit., p. 65).

Giuseppe Chiovenda, Principípios de derecho procesal civil, vol. I, ob. cit., p. 96.

Como bem ponderava o mestre, “na substância é realmente oportuno observar como a verdade não possa ser que uma, onde a verdade formal ou jurídica ou coincide com a verdade material, e não é que verdade, ou diverge desta, e não é que uma não verdade, de forma que, tirante a metáfora, o processo de busca sujeito a normas jurídicas, que lhe constroem e lhe deformam a pureza lógica, não pode ser sinceramente considerado como um meio de conhecimento da verdade dos fatos, mas sim como uma fixação ou determinação dos próprios fatos, que pode coincidir ou não coincidir com a verdade destes e permanece, seja como for, independente deste” (Francesco Carnelutti, La prova civile, ob. cit., p. 29-30).

Como se pode inferir da lição de Villey, a verdade é um conceito absoluto; ou é ou não é. Uma verdade parcial, imperfeita ou meramente formal, por simples questão de lógica, não pode ser verdade, já que este conceito (absoluto) apenas será atingido na base da verdade substancial (Michel Villey, *Réflexions sur la philosophie et le droit, les carnets*. Paris: PUF, 1995, p. 1).

Neste sentido, acentua Michele Taruffo que “o jurista não consegue mais estabelecer que coisa seja a verdade dos fatos no processo, e a que coisa servem as provas, sem defrontar-se com escolhas filosóficas e epistemológicas de ordem mais geral. A expressão ‘verdade material’, e as outras expressões sinônimas, transformam-se em etiquetas privadas de significado se não se ligam ao problema geral da verdade. Deste ponto de vista, o problema da verdade dos fatos no processo não é mais que uma variante específica deste problema mais geral” (Michele Taruffo, *La prova dei fatti giuridici, nozioni generali*, Milano: Giuffrè, 1992, p. 5).

Voltaire (AROUET, François-Marie). “Vérités historiques & histoire: certitude de l’histoire”. Dictionnaire philosophique. Ed. Beuchot. p. 432-433.

Miguel Reale, *Verdade e conjectura*. Nova Fronteira, 1983. Desta obra, extrai-se a lição de que “se a verdade, numa síntese talvez insuficiente, não é senão a expressão rigorosa do real, ou, por outras palavras, algo de logicamente redutível a uma correlação precisa entre ‘pensamento e realidade’, tomando este segundo termo em seu mais amplo significado, e não apenas como ‘realidade fatual’, forçoso é reconhecer que a adequação entre o mundo dos conceitos e o da realidade, mesmo nos domínios das ciências consideradas exatas, deixa-nos claros ou vazios que o homem não pode deixar de pensar. No fundo é esta a distinção kantiana essencial entre ‘conhecer segundo conceitos’ e ‘pensar segundo ideias’, isto é, acrescento eu com certa elasticidade, ‘pensar segundo conjecturas’. De mais a mais, discutem até hoje os filósofos e cientistas no que tange à definição de verdade, e os conceitos que se digladiam não são mais do que conjecturas, o que demonstra que a conjectura habita no âmago da verdade, por mais que nossa vaidade de homo sapiens pretenda sustentar o contrário” (Ob. cit., p. 17-18). E prossegue o genial jusfilósofo, afirmando que “não há nessa atitude, porém, nenhum laivo de ceticismo ou de relativismo, pois quem conjectura, quando a verdade não se lhe impõe precisamente ao espírito, quer lançar uma ponte sobre a dúvida que separa uma verdade da outra, para usarmos uma imagem feliz de Augusto Comte. É que o pensamento, tanto como a natureza, tem horror ao vácuo, ao não-explicado ou compreendido. Vaihinger, afirmando que toda verdade se reduz a uma ‘ficção’, a um como se (als ob) que o nosso espírito admite para compreender e dominar uma série de situações problemáticas, atendendo, assim, a exigências biológicas, e, mais amplamente, existenciais. A teoria da verdade reduzir-se-ia, desse modo, a uma teoria das ficções conscientes e úteis, em função dos esquemas ideais com que o homem encapsula o real e o ordena segundo os seus próprios fins vitais, constituindo, ao mesmo tempo, uma lógica naturalista e operacional” (Ob. cit., p. 18).

Conforme atenta observação de Gadamer, “a interpretação não é um ato posterior e oportunamente complementar à compreensão, porém, compreender é sempre interpretar, e, por conseguinte, a interpretação é a forma explícita da compreensão” (Hans-Georg Gadamer, *Verdade e método – traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica*, 2. ed., trad. Flávio Paulo Meurer, Petrópolis: Vozes, 1998, p. 459).

Neste sentido é a conclusão de Rui Portanova (*Motivações ideológicas da sentença*, 2. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1994) que expõe três ordens de motivação para a sentença judicial: probatória, pessoal e ideológica. Sobre as motivações pessoais, leciona o jurista que “as contradições, os exageros ou as omissões das testemunhas podem embasar com alguma objetividade o convencimento judicial: fora disso, os motivos pessoais do juiz para considerar um fato, uma prova ou um direito como relevantes para o provimento ou não da demanda são pouco perscrutáveis. São motivações pessoais: interferências (psicológicas, sociais, culturais) personalidade, preparação jurídica, valores, sentimento de justiça, percepção da função, ideologia, estresse, remorsos, intelectualização” (Ob. cit., p. 16).

“De resto, se a noção de prova devesse ser colocada coerentemente em relação com o escopo de consentir ao juiz de obter um pleno convencimento da real existência (ou inexistência) dos fatos controvertidos,

nenhum dos meios probatórios disciplinados pelo código poderia enquadrar-se plenamente na noção. A formação do convencimento judicial é, de fato, condicionada não apenas pelas regras que lhe impõem valorar de um certo modo as resultantes instrutórias, mas também por aquelas que fazem ter como inadmissíveis determinadas fontes de conhecimento (por exemplo, a ciência privada, o testemunho etc.) ou mesmo que impõem o respeito de determinadas modalidades de assunção, de tal forma que as provas formadas sem o respeito de tais limites ou modalidades devem compreender-se ilegítimas ou como consequência, segundo a opinião mais usual, ineficaz” (Giovanni Verde, “Prova (diritto processuale civile)” in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVII, Milano: Giuffrè, 1988, p. 590).

32

Sérgio Cotta, “Quidquid latet apparebit: Le problème de la vérité du jugement” in *Archives de philosophie du droit*, tome 39, Paris: Dalloz, 1995, p. 219-228.

33

A propósito, veja-se a excelente obra de Michel Villey, denominada *La formation de la pensée juridique moderne* (4. ed., Paris, 1975).

34

Celso Luiz Ludwig, *A alternatividade jurídica na perspectiva da libertação: uma leitura a partir da filosofia de Enrique Dussel*. Dissertação de mestrado apresentada no Curso de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 27 de outubro de 1993, p. 10.

35

René Descartes, *Discours de la méthode*. Paris: GF-Flammarion, 1992, p. 55.

36

Francesco Carnelutti, “Verità, dubbio, certezza”, ob. cit., p. 4-5. Nota-se, aí, claramente, a mudança de paradigma operada por Carnelutti; abandonando o paradigma do objeto, finca-se ele no paradigma do sujeito, centrando-se na busca da certeza, um conceito nitidamente subjetivo e pertencente ao sujeito cognoscente.

37

Lembre-se, a propósito, o exemplo da prova técnica de DNA, para a avaliação de paternidade. Mesmo com toda a sofisticação tecnológica do método, e todo o avanço científico, o exame é capaz de gerar uma segurança de 99,9%. Ou seja, ainda que ínfima, sempre haverá a possibilidade de que o exame esteja errado. E, se há esta possibilidade, então não se pode dizer que as conclusões deste teste reflitam a verdade, a qual, como conceito absoluto, não admite variações.

38

“Todas as provas, em verdade, não são que provas de verossimilhança” apud Piero Calamandrei, “Verità e

39

Voltaire, *Ob. loc. cit.*

40

“A querela entre os advogados e a verdade é tão antiga quanto a que existe entre o diabo e a água benta. E, entre as facécias costumeiras que circulam sobre a mentira profissional dos advogados, ouve-se fazer seriamente esta espécie de raciocínio: – Em todo processo há dois advogados, um que diz branco e outro que diz preto. Verdadeiros, os dois não podem ser, já que sustentam teses contrárias; logo, um deles sustenta a mentira. Isso autorizaria considerar que cinquenta por cento dos advogados são uns mentirosos; mas, como o mesmo advogado que tem razão numa causa não tem em outra, isso quer dizer que não há um só que não esteja disposto a sustentar no momento oportuno causas infundadas, ou seja, ora um ora outro, todos são mentirosos.

Esse raciocínio ignora que a verdade tem três dimensões e que ela poderá mostrar-se diferente a quem a observar de diferentes ângulos visuais.

No processo, os dois advogados, embora sustentando teses opostas, podem estar, e quase sempre estão, de boa-fé, pois cada um representa a verdade como a vê, colocando-se no lugar do seu cliente” (Piero Calamandrei, *Eles, os juízes, vistos por um advogado*, trad. Eduardo Brandão, São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 121). E, arrematando seu pensamento, o mesmo processualista florentino traz a seguinte imagem: “Ponham dois pintores diante de uma mesma paisagem, um ao lado do outro, cada um com seu cavalete, e voltem uma hora depois para ver o que cada um traçou em sua tela. Verão duas paisagens absolutamente diferentes, a ponto de parecer impossível que o modelo tenha sido o mesmo.

Dir-se-ia, nesse caso, que um dos dois traiu a verdade?” (*Ob. cit.*, p. 125). Realmente, é impossível fugir à “subjetivação” da realidade, razão pela qual jamais se poderá dizer, com absoluta segurança, que a “reconstrução” operada dos fatos efetivamente condiz com a realidade verificada.

41

Piero Calamandrei, “*Verità e verossimiglianza nel processo civile*”, *ob. cit.*, p. 165-166.

42

Idem, p. 164.

43

Tratamento semelhante da matéria é oferecido por Gadamer. Como expõe este autor, “o conceito de evidência pertence à tradição retórica. O eikos, o verossimile, o verossímil, o evidente, formam uma série que pode defender sua própria justificação, face à verdade e à certeza do que está demonstrado e sabido. Gostaria de recordar nesse ponto o significado especial que já reconhecemos ao *sensus communis*. Junto a isso, poderia perceber-se aqui o efeito de uma certa ressonância místico-pietista da *illuminatio*, iluminação, sobre a evidência (uma ressonância que se ouvia também no *sensus communis*, por exemplo,

em Oetinger). (...). O evidente é sempre algo dito: uma proposta, um plano, uma suposição, um argumento etc. Com isso está sempre dada a ideia de que o evidente não está demonstrado nem é absolutamente certo, mas se faz valer a si mesmo como algo preferencial, dentro do âmbito possível e do provável. Inclusive podemos admitir sem dificuldade que um argumento tem algo de evidente, quando o que pretendemos com ele é apreciar um contra-argumento” (Hans-Georg Gadamer, *Verdade e método*, 2. ed., Petrópolis: Vozes, 1998, p. 701).

44

Piero Calamandrei, “Verità e verossimiglianza nel processo civile”, ob. cit., p. 169-170.

45

“Mas mesmo porque os limites entre possibilidade e impossibilidade, ou entre verossimilhança e inverossimilhança, são sempre variáveis, segundo o nível de cultura do judicante, como é demonstrado pelo progresso da ciência que de dia em dia faz entrar no domínio da possibilidade ou da verossimilhança aquilo que até ontem a experiência vulgar considerava impossível e absurdo” (Piero Calamandrei, “Verità e verossimiglianza nel processo civile”, ob. cit., p. 170).

46

“Mas o enigma permanece: quidquid latet non apparuit. Esta latência da verdade integral mostra a impotência final do juiz a corresponder plenamente ao sentido fenomenológico do julgamento: a restauração da continuidade das pessoas. Esta impotência é insuperável, por sua razão ontológica; o veredicto do juiz não é a verdade, mas pro veritate habetur, como o ensina uma sabedoria que se assemelha à resignação. Certamente, esta verdade imperfeita, seguida pela restituição do bem ilegalmente adquirido, pelo ressarcimento do ilícito sofrido, ou pela pena infligida ao culpado, pode, certamente, satisfazer ao ofendido, mas não suprimir aquilo que foi feito: factum infectum fieri nequit. Os fatos permanecem, suspensos em uma espécie de intemporalidade objetiva, de onde a memória pode a todo momento recuperar para um presente continuamente renovável, a menos que o esquecimento o apague” (Op. cit., p. 225). Também aqui vê-se o equívoco de acreditar que o fato fica, objetivamente considerado, guardado na memória; em verdade, o que fica na memória é uma versão dos fatos, já trabalhada pela interpretação do sujeito.

47

Sergio Cotta, Op. cit., p. 225.

48

Assim também é a lição de Calamandrei, que salienta que “pode dar-se que assim o judicante, após ter feito tudo aquilo que lhe era possível para encontrar a verdade, consiga com o sentimento por-se em paz com sua consciência; mas isto não tolhe que a conclusão do juiz, mesmo se ele com o seu ao de fé consiga senti-la como tranquilizante certeza, permaneça, quando seja racionalmente valorado, apenas um juízo mais ou menos aproximativo. Assim é fácil concluir que a margem de aproximação varia de caso a caso, segundo os meios de prova de que o juiz pode servir-se para chegar à decisão ...” (Op. cit., p. 166).

Como afirma Taruffo, “non vi è nessuna coincidenza o corrispondenza tra verosimiglianza o verità. Un fatto che si considera verosimile nel senso appena indicato può benissimo non essersi verificato, per qualunque ragione: ciò significa che l’enunciato che riguarda quel fato può apparire verosimile ma è falso, in quanto la realtà di ciò che è accaduto non corrisponde a ciò che l’enunciato narra” (Michele Taruffo, *La semplice verità*, ob. cit., p. 89).

Lapidar, aqui, é a lição de Calamandrei sobre a questão. Como leciona o inolvidável jurista florentino, “ainda mais árduo é estabelecer uma precisa diferença, que seja praticamente utilizável em sede judiciária, entre as noções de possibilidade, verossimilhança, probabilidade. Não é esta a sede para pesquisar, através da etimologia e do uso dos bons autores, as nuances (sfumature) de significado que distinguem propriamente estas três expressões, muitas vezes usadas na linguagem comum como sinônimas. Possível é aquilo que pode ser verdadeiro; verossímil é aquilo que tem aparência de ser verdadeiro. Provável seria, etimologicamente, aquilo que se pode provar como verdadeiro; (...): e não faltam nos registros dos léxicos o uso da palavra provável como sinônimo de verossímil” (Piero Calamandrei, “Verità e verosimiglianza nel processo civile”, ob. cit., p. 170).

“Se se toma como termo de referência a declaração da verdade, pode-se dizer que estas três qualificações (possível, verossímil, provável) constituem, nesta ordem, uma gradual aproximação, uma progressiva acentuação em direção ao reconhecimento daquilo que é verdadeiro. Quem diz que um fato é verossímil, é mais próximo a reconhecê-lo verdadeiro de quem se limita a dizer que é possível; e quem diz que é provável, é ainda mais adiante de quem diz que é verossímil, porque vai além da aparência, e começa a admitir que existem argumentos para fazer compreender que à aparência corresponde a verdade. Mas se trata de delineações psicológicas, que cada judicante entende ao seu modo” (Piero Calamandrei, “Verità e verosimiglianza nel processo civile”, ob. cit., p. 170-171, grifo nosso).

Celso Luiz Ludwig, Op. cit., p. 55.

Jürgen Habermas, *Direito e democracia, entre facticidade e validade*, vol. I, trad. Flávio Beno Siebeneichler, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 20.

Celso Luiz Ludwig, Op. cit., p. 56.

56

Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa, tomo I, Madrid: Taurus, 1988, p. 64-65.

57

Miguel Reale, Fontes e modelos do direito. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 17.

59

Celso Luiz Ludwig, Op. cit., p. 63.

60

“O procedimento germânico conserva o caráter do processo primitivo, nascido historicamente como meio de pacificação social, encaminhado a dirimir as contendas, mais que a decidi-las, fazendo depender sua solução, não do convencimento do juiz, mas pelo regular, do resultado de fórmulas solenes, nas quais o povo descobre a expressão de um ato superior e imparcial de divindade. Tudo isso dá ao processo e à prova um aspecto sumamente formal”. (Giuseppe Chiovenda, Principios de derecho procesal civil, vol. I, ob. cit., p. 1).

61

Michel Villey, Philosophie du droit, II. Les moyens du droit. 2. ed., Paris: Dalloz, 1984, p. 49.

62

Michel Villey, Philosophie du droit, ob. cit., p. 48.

63

Alessandro Giuliani, “Prova (filosofia del diritto)” in Enciclopedia del diritto, vol. XXXVII, Milano: Giuffrè, 1988, p. 523.

64

Sobre todas estas premissas, v. Alessandro Giuliani, “Prova (filosofia del diritto)”, ob. cit., p. 523. A análise destas premissas é feita com vistas ao passado, e aos sistemas legais antigos; todavia, parece certa a sua aplicação também na atualidade.

65

Sobre a ideia de cooperação processual, v., entre outros, Mirjan R. Damaska, The faces of justice and state authority. New Haven: Yale University Press, 1986, passim; Daniel F. Mitidiero, Colaboração no processo civil. 2. ed., São Paulo: RT, 2011, passim.

Neste passo, interessante é a ponderação de Gadamer, comparando a verdade ao processo de um jogo. Como leciona ele, “a melhor maneira de determinar o que significa a verdade será, também aqui, recorrer ao conceito de jogo: o modo como se desenvolve o peso das coisas que nos vêm ao encontro na compreensão é, por sua vez, um processo linguístico, por assim dizer, um jogo de palavras que circunscrevem o que queremos dizer. São também jogos linguísticos os que nos permitem chegar à compreensão do mundo na qualidade de aprendizes – e quando deixaremos acaso de o ser? Por isso vale a pena recordar aqui as nossas constatações sobre a essência do jogo, segundo as quais o comportamento do jogador não deve ser entendido como um comportamento da subjetividade, já que é, antes, o próprio jogo o que joga, na medida em que inclui em si os jogadores e se converte desse modo em verdadeiro subjectum do movimento lúdico” (Hans-Georg Gadamer, *Verdade e método*, ob. cit., p. 707-708). Da passagem transcrita, observa-se nitidamente a compreensão do autor de que os sujeitos que se inter-relacionam no processo do conhecimento não permanecem externos a este conhecimento mas, ao contrário, acabam interferindo nele e fazendo parte da própria essência da cognição.

Jürgen Habermas, *Direito e democracia, entre facticidade e validade*, ob. cit., p. 31.

Ovídio Baptista da Silva, há muito tempo, já reclamava a necessidade desse avanço no campo processual, dizendo que “o princípio da verossimilhança domina literalmente a ação judicial. É com base nele que o juiz profere a decisão de recebimento da petição inicial, dando curso à ação civil, assim como igualmente baseado em critério de simples verossimilhança emite todas as decisões interlocutórias e, eventualmente – nos raros casos em que nosso direito o permite – profere sentenças liminares, provendo provisoriamente sobre o *meritum causae*, como nos interditos possessórios” (*Curso de processo civil*, vol. I, 4. ed., São Paulo: Ed. RT, 1998, p. 71).

A respeito desta questão, v., de forma mais detida, Sérgio Cruz Arenhart, *Perfis da tutela inibitória coletiva*. São Paulo: Ed. RT, 2003, p. 234 e ss.

Michele Taruffo, *La semplice verità – il giudice e la costruzione dei fatti*. passim.

V. Bruno Cavallone, “In difesa della veriphobia (considerazioni amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo)”. *Rivista di diritto processuale*. Padova: CEDAM, n. 1, jan-fev./2010 e, depois, Michele Taruffo, “Contro la veriphobia. Osservazioni sparse in risposta a Bruno Cavallone”. *Rivista di diritto processuale*. Padova: CEDAM, n. 5, set.-out./2010, p. 955 e ss.

73

Idem, ibidem, p. 78.

74

Diz Taruffo que “risulta chiaro infatti che, malgrado difficoltà teoriche e varietà di orientamenti, la verità – per dirla con Lynch – è oggettiva, è buona, è un oggetto degno di indagine ed è degna di essere coltivata per se stessa” (ob. cit., p. 79).

75

Idem, ibidem, p. 76. No mesmo sentido, v. Richard Bailey, “Overcoming veriphobia – learning to love truth again”. British Journal of Educational Studies. Oxford: Blackwell Publishers, vol. 49, n. 2, jun./2001, p. 164.

76

Idem, ibidem, p. 79.

77

“Nel contesto del processo è appropriato parlare di verità relativa e oggettiva. La verità dell’accertamento dei fatti è relativa – nel senso che è relativa la conoscenza di essa – perché si fonda sulle prove che giustificano il convincimento del giudice e rappresentano la base conoscitiva sulla quale trova giustificazione il convincimento che un certo enunciato corrisponda alla realtà dei fatti della causa” (ob. cit., p. 83).

78

Idem, ibidem, p. 82.

79

Algo com que não discordo, embora acredite que essa premissa é absolutamente inútil para a operacionalidade do sistema processual.

80

Michele Taruffo, Ob. cit., p. 85/88.

81

Cândido Rangel Dinamarco, “Relativizar a coisa julgada”. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial, n. 55/56, jan/dez 2001, p. 75.

82

Laercio Augusto Becker, “Sobre a incerteza e o conteúdo ético do processo civil”. Qual é o jogo do processo? Porto Alegre: Fabris, 2012, p. 314.

83

Laercio Augusto Becker. Ob. cit., p. 296.

84

V., a propósito, Oscar Chase, Law, culture, and ritual. New York: New York University Press, 2005, p. 15-29.

85

Comumente se fala, por exemplo, na inexistência de nulidade processual, se do ato não há prejuízo para a descoberta da “verdade substancial” (STJ, 2ª Turma. REsp 1.272.217/BA. Rel. Min. Eliana Calmon. DJe 16.04.13; STJ, 5ª Turma. HC 166.172/SP. Rel. Min. Gilson Dipp. DJe 01.08.12; STJ, 2ª Turma. AgRg nos EDcl no REsp 890.641/RJ. Rel. Min. Humberto Martins. DJe 23.04.12). Também é corrente atrelar-se a ideia da busca da verdade real aos poderes instrutórios do juiz (STJ, 5ª Turma. AgRg no Ag 1.154.432/MG. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. DJe 14.11.12) ou ainda ao grau de convencimento judicial (STJ, 4ª Turma. AgRg no Ag 1.403.694/MG. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJe 22.08.11; STJ, 2ª Turma. REsp 1.264.313/Rs. Rel. Min. Humberto Martins. DJe 14.10.11).

86

V. itens 5 e 6, acima.

87

Como aponta Bruno Cavallone, em crítica dirigida à obra antes examinada de Michele Taruffo, “in termini processuali, quella qualifica avrà un senso soltanto nei limiti in cui esista qualche rimedio, sia pure straordinario, ancora concretamente e utilmente esperibile contro di essa: altrimenti, per quanto possa dispiacere ai veriphiles (si dirà così?), res iudicata facit de albo nigrum” (Bruno Cavallone, “In difesa della veriphobia (considerazioni amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo)”, Rivista di diritto processuale. Padova: CEDAM, jan-fev/2010, n. 1, p. 10).

88

Chaim Perelman, Lógica jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 166-167.

89

A exemplo do que sugere um extraordinário trabalho de Anna Pintore (Il diritto senza verità. Torino: Giappichelli, 1996).

90

Michele Taruffo, *La semplice verità*, ob. cit., p. 99-107.

91

Assim tb., v. Bruno Cavallone, Ob. cit., p. 11-12.

92

V. a respeito, Luiz Guilherme Marinoni, *Novas linhas de processo civil*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 156/157; Cândido Rangel Dinamarco, *A instrumentalidade do processo*, 5. ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 140 e ss.

93

Francesco Carnelutti, *La prova civile*, ob. cit., p. 30.

94

Chaïm Perelman, *Retóricas*, trad. Maria Ermantina Galvão G. Pereira, São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 164.

95

Chaïm Perelman, *Retóricas*, ob. cit., p. 164-165.

96

Chaïm Perelman, *Retóricas*, ob. cit., p. 154.

97

De modo semelhante, v., entre outros, Loïc Cadiet, Jacques Normand, Soraya Amrani Mekki. *Théorie générale du procès*. Paris: PUF, 2010, p. 843-844.

98

Piero Calamandrei, “*Verità e verossimiglianza nel processo civile*”, ob. cit., p. 169-170.

99

Na lição de Gadamer, “assim, é certo que não existe compreensão que seja livre de todo preconceito, por mais que a vontade do nosso conhecimento tenha de estar sempre dirigida, no sentido de escapar ao conjunto dos nossos preconceitos. No conjunto a nossa investigação evidencia-se que, para garantir a verdade, não basta o gênero de certeza, que o uso dos métodos científicos proporciona. Isso vale especialmente para as ciências do espírito, mas não significa, de modo algum, uma diminuição de sua

cientificidade, mas, antes, a legitimação da pretensão de um significado humano especial, que elas vêm reivindicando desde antigamente. O fato de que, em seu conhecimento, opere também o ser próprio daquele que conhece, designa certamente o limite do ‘método’, mas não o da ciência. O que a ferramenta do ‘método’ não alcança tem de ser conseguido e pode realmente sê-lo através de uma disciplina do perguntar e do investigar, que garante a verdade” (Hans-Georg Gadamer, *Verdade e método*, ob. cit., p. 709).

100

Como pondera Michel Foucault, “de fato, as condições políticas, econômicas de existência não são um véu ou um obstáculo para o sujeito de conhecimento mas aquilo através do que se formam os sujeitos de conhecimento e, por conseguinte, as relações de verdade. Só pode haver certos tipos de sujeito de conhecimento, certas ordens de verdade, certos domínios de saber a partir de condições políticas que são o solo em que se formam o sujeito, os domínios de saber e as relações com a verdade” (*A verdade e as formas jurídicas*, trad. Roberto Cabral de Melo Machado e Eduardo Jardim Morais, Rio de Janeiro: Nau, 1996, p. 27).

101

Michel Foucault, *A verdade e as formas jurídicas*, ob. cit., p. 24.

102

Francesco Carnelutti, *Teoria geral do direito*. Trad. Antônio Carlos Ferreira. São Paulo: Lejus, 1999. § 178, p. 521. Em outra passagem, o mesmo autor escreveu: “posto que não só no processo como também fora dele devem ser valorados juridicamente os fatos, as provas não servem somente para o processo; em geral, a atividade jurídica, e não só a atividade judicial, se desenvolve por meio de provas. Por isso, assim como o estudo das provas não é próprio unicamente da ciência do direito processual, assim a disciplina dela não se encontra no Código de Processo Civil, mas no Código Civil (arts. 2.697 e ss.)” (Francesco Carnelutti, *Instituições do processo civil*. Trad. Adrián Sotero de Witt Batista. Campinas: Servanda, 1999. v 1, p. 307-308, n. 163). É bom salientar, no entanto, que Carnelutti, em obras anteriores, sempre sustentou a natureza processual das regras sobre prova (*La prova civile cit.*, apêndice I, p. 249-250).

103

Giuseppe Chiovenda, *La natura processuale delle norme sulla prova e l’efficacia della legge processuale nel tempo*. *Saggi di diritto processuale civile*. Milano: Giuffrè, 1993. v. 1, p. 242-243.

104

Idem, p. 243. Tal “razão processual”, na ótica de Chiovenda, é explicada da seguinte forma: “se o legislador põe uma nova norma probatória porque, inspirando-se nas condições modificadas da civilização, da sociedade, da moral pública, considera-a conforme ao escopo de assegurar um melhor resultado à lide, seja do ponto de vista da bondade intrínseca das decisões, seja da simplicidade e da presteza do procedimento; são estas razões processuais de reforma, e a norma que a estas é devida, seja que estenda seja que limite os meios de prova, encontrará aplicação em cada processo futuro, em qualquer tempo em que tenha ocorrido o fato que deva provar-se” (idem, *ibidem*).

105

Enrico Tullio Liebman, Manuale di diritto processuale civile – Principi cit., p. 322-325; V. também, do mesmo autor, Questioni vecchie e nuove in tema di qualificazione delle norme sulle prova. Rivista di Diritto Processuale, v. 24, Padova, Cedam, 1969. p. 353 e ss.

106

Enrico Tullio Liebman, Manuale di diritto processuale civile – Principi cit., p. 323.

107

Enrico Tullio Liebman, Idem, p. 324.

108

Jaime Guasp, Op. cit., t I, p. 301.

109

Idem, ibidem.

110

Idem, ibidem.

111

Salvatore Satta; Carmine Punzi, Op. cit., p. 219. É importante sublinhar, todavia, que logo adiante, nesta mesma obra, os autores defendem abertamente a ideia de que as regras sobre prova têm natureza exclusivamente material (idem, p. 314).

112

Salvatore Satta; Carmine Punzi, Idem, p. 219.

113

Idem, ibidem.

114

Idem, p. 220.

115

Vittorio Denti, La natura giuridica delle norme sulle prove civile. Rivista di Diritto Processuale, v. 24, Padova, Cedam, 1969. p. 8 e ss. – especialmente –, p. 35.

116

“É então perfeitamente inútil seguir, como sombras da caverna platônica, os conceitos abstratos de norma processual e de norma substancial (...) Não existirá então nenhum motivo de escândalo se uma norma probatória for considerada pelo mesmo juiz, ora de natureza processual ora de natureza substancial, segundo se trate de resolver um conflito de leis interno ou internacional, ou então um conflito temporal, ou de fazer retroagir os efeitos de uma decisão de ilegitimidade constitucional, ou ainda de individualizar o aporte e a aplicabilidade de um preceito da Constituição. Escândalo seria o caso oposto, em que os juízes opusessem às exigências de justiça do caso concreto a rigidez da fórmula abstrata, dotada de coerência apenas com determinadas premissas teóricas em torno da estrutura e da função das normas” (Vittorio Denti, Idem, p. 34-35).

117

Mauro Cappelletti, La “natura” delle norme sulle prove. Rivista di Diritto Processuale Civile, v. 24, Padova, Cedam, 1969. p. 92 e ss.

118

Idem, p. 98.

119

Idem, ibidem.

120

Cf. Salvatore Patti, Prove – Disposizioni generali, p. 10.

121

Ver Luis Cezar Ramos Pereira, A prova do direito estrangeiro e sua aplicabilidade. Revista de Processo 39/276.

122

Flávio Yarshell, Antecipação da prova sem o requisito da urgência e direito autônomo à prova, *passim*; Daniel Neves, Ações probatórias autônomas, *passim*.

123

Salvo quando o documento estiver em posse de terceiro, caso em que deverá ser pedida sua exibição, ou ainda quando estiver arquivado em repartição pública, caso em que será requisitado aos autos.

124

Sobre a valoração da prova, Michele Taruffo, *La prova nel processo civile*, passim; Massimo Nobili, *Il principio del libero convincimento del giudice*, passim; Jordi Nieva Fenoll, *La valoración de la prueba*, passim; Jordi Ferrer Beltrán, *La valoración racional de la prueba*, passim.

125

Existem exceções, concedidas ao sistema da prova legal (em que o valor da prova é vinculante para o juiz), como os casos previstos nos arts. 392 ou 406.

126

Ver Bruno Cavallone, *I poteri di iniziativa istruttoria del giudice civile*. Milano: Giuffrè, 1968. p. 2; Deltan Martinazzo Dallagnol, *As lógicas das provas no processo*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, passim.

127

Francesco Carnelutti, *La prova civile*. Milano: Giuffrè, 1992. p. 54 e ss.

128

“La prova indiretta presenta il distacco dell’oggetto della prova dall’oggetto della percezione: il fatto sottoposto alla percezione del giudice non serve se non di mezzo alla conoscenza di lui” (Francesco Carnelutti, *La prova civile*, cit., 1992, p. 56).

129

O fato indireto serve para permitir que o juiz, a partir da sua prova (indiciária), raciocine para estabelecer uma presunção. O fato indireto permite que o juiz forme uma presunção sobre o fato direto.

130

Cf. Juan Igartua Salaverría (*La motivación de las sentencias, imperativo constitucional*, p. 172), lembrando passagem de Lombardo (*La prova giudiziale...*, p. 496-497).

131

O testemunho serve para demonstrar os fatos diretos ou os fatos indiretos (ou indiciários), quando então pode ser visto como prova indireta (por requerer intermediação), enquanto que os fatos indiretos apontam para o fato direto, mas sem prescindirem do raciocínio presuntivo e da presunção.

132

Em termos, Michele Taruffo, *La prova dei fatti giuridici, nozioni generali* cit., p. 427.

133

“Es equivocado o induce al equívoco sostener que ‘en el mismo testimonio – tradicionalmente considerado como la más sólida prueba en el proceso – el paso de la premisa probatoria (Ticio dice que p) a la proposición a probar (es p) acontece sobre la base de un complejo juego de inferencias sobre la sinceridad del testigo, sobre la calidad de sus percepciones y sobre su memoria’. No, todas esas cuestiones no afectan al paso que va de la prueba al hecho objeto de la misma; son previas, conciernen a la fiabilidad de la prueba en cuanto tal. Volviendo al ejemplo anterior (‘Zutano vio bien que Fulano disparó contra Mengano’), el juez, antes de trazar el puente lógico entre la prueba y el hecho, tendrá que establecer si Zutano vio lo que dice (o miente) y si vio bien (o percibió mal). Y a partir de ahí vendrá, si procede, el automatismo que relaciona la prueba con el hecho (Juan Igartua Salaverría, Op. cit., p. 172-173).

134

José Carlos Barbosa Moreira, *As presunções e a prova*. In: José Carlos Barbosa Moreira, *Temas de direito processual civil. Primeira série*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 59. Em sentido contrário, v. Jaime Guasp, *Derecho procesal civil*. 4. ed. Madrid: Civitas, 1998. t. I, p. 383.

135

Cf. Jaime Guasp, Op. cit., p. 382.

136

Adolf Schönke, *Derecho procesal civil*. Barcelona: Bosch, 1950. p. 198. V., también, Hugo Alsina, *Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial*. 2. ed. Buenos Aires: Ediar, 1961. t. III, p. 683.

137

Ver C. B. Marcheis, *Probabilità e prova: considerazioni sulla struttura del giudizio di fatto*. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 1.119.

138

José Carlos Barbosa Moreira, *As presunções e a prova* cit., p. 57.

139

Vale ponderar, todavia, que em se considerando como meio de prova um argumento, destinado ao convencimento do magistrado sobre a atendibilidade ou não da pretensão inicialmente exposta, não haverá dificuldade em considerar as presunções – como argumentos que são – também como meio de prova.

140

Cf. Jaime Guasp, Op. cit., p. 382.

141

Francesco Carnelutti, *La prova civile*, 1947, p. 235.

142

É por isso, aliás, que não é exato estabelecer uma oposição entre a tutela antecipatória e a sentença, mas sim entre a tutela antecipatória e a tutela final. A sentença é apenas o mecanismo processual hábil à prestação da tutela final. Para maior aprofundamento, ver Luiz Guilherme Marinoni, *A antecipação da tutela*. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.

143

Ver, para maior aprofundamento do tema, os comentários ao art. 375, adiante.

144

Que em alguns poderão exigir demonstração científica.

145

Friedrich Stein, *El conocimiento privado del juez*. Trad. Andrés de la Oliva Santos. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 1990. p. 30-31.

146

Não apenas a experiência da causalidade – como alguns processualistas penais têm afirmado –, mas sim a experiência em todos os âmbitos da vida (Cf. *Idem*, p. 33).

147

Sobre a noção de fato notório, ver adiante os comentários ao art. 374; sobre as regras de experiência, ver os comentários ao art. 375.

148

A lei civil italiana, neste passo, assim define a ideia de presunção: “Art. 2.727. As presunções são as conseqüências que a lei ou o juiz extrai de um fato conhecido para remontar a um fato ignorado” (“le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”).

149

A respeito, v. Gerhard Walter, *Op. cit.*, p. 229 e ss. (com ampla análise do tema em relação às presunções e perfilhamento de inúmeros exemplos, ligados ao direito alemão).

150

“(…) Se costuma fixar a diferença conceptual entre as duas últimas figuras: serão relativas ou absolutas as presunções legais conforme admitam ou não, respectivamente, prova em contrário; ou, em termos porventura mais rigorosos do ponto de vista técnico, conforme seja ou não relevante, para a solução do litígio submetido à apreciação do juiz, a demonstração de que na realidade não ocorreu o fato legalmente presumido: com efeito, quando se diz que, na presunção absoluta, é inadmissível a ‘prova em contrário’, o que no fundo se quer afirmar é que nada adiantaria ministrar tal prova, pois, a despeito dela, o órgão judicial continuaria adstrito a pôr, como fundamento fáctico de sua decisão, aquilo que a lei presume. Nessa perspectiva, olhado mais de perto o fenômeno, a inadmissibilidade da ‘prova em contrário’ aparece como simples corolário de sua irrelevância, explicando-se pela razão óbvia de que no processo não se deve tolerar atividade inútil” (José Carlos Barbosa Moreira, *As presunções e a prova cit.*, p. 55).

151

Andrea Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile cit.*, p. 484.

152

Como se pode observar, as presunções normalmente constituem argumento de prova insuficiente para, por si só, sustentar uma conclusão absoluta. Por isso mesmo, como se verá adiante, o juiz deve ser prudente ao trabalhar com elas, embora isso não retire a possibilidade de julgamentos fundados exclusivamente em presunções.

153

Luigi Paolo Comoglio; Corrado Ferri; Michele Taruffo, *Op. cit.*, p. 652.

154

Afirma o art. 1.253 do Código Civil espanhol que “para que as presunções não estabelecidas pela lei sejam apreciáveis como meio de prova, é indispensável que entre o fato demonstrado e aquele que se trate de deduzir exista um enlace preciso e direto”. Aliás, Paula Baptista já dizia que as presunções judiciais são “as que o homem tira daquilo que ordinariamente acontece. Podem ser violentas, graves e leves, segundo é necessária, natural, ou assaz falível a ligação do fato sabido com o que se procura saber” (Francisco de Paula Baptista, *Teoria e prática do processo civil e comercial*. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 103). V. tb., para o direito anglo-americano, Fleming James Jr.; Geoffrey C. Hazard Jr.; John Leubsdorf, *Civil Procedure*. 4. ed. Boston: Little, Brown and Company, 1992. p. 346 e ss.

155

Jaime Guasp, *Op. cit.*, p. 384.

156

Seja porque do fato provado (indício) podem, segundo as máximas da experiência, resultar inúmeros outros fatos (e não apenas aquele que se pretende ter como conclusão lógica, o que retiraria qualquer credibilidade da presunção), seja porque o fato provado não é capaz de gerar a elaboração mental

indutiva pretendida.

157

A denominação é oriunda do direito americano (V. Fleming James Jr. ; Geoffrey C. Hazard Jr.; John Leubsdorf, Civil Procedure cit., p. 349).

158

Idem, ibidem.

159

“Il requisito che ha creato forse più problemi interpretativi è quello della concordanza delle presunzioni semplici. In un’accezione più ristretta e rigorosa, diretta a porre un limite a discrezionalità del giudice in materia di prova presuntiva, si è affermato che la concordanza di più presunzioni è sempre indispensabile. Di conseguenza, non basterebbe una sola presunzione semplice a fornire la prova del fatto, poichè sempre occorrerebbero più presunzioni concordanti. In un’accezione meno rigida, e più orientata a far perno sul discrezionale convincimento del giudice, si ritiene invece che la presenza di più presunzioni concordanti non sia indispensabile, e quindi che la prova del fatto possa derivare anche da una sola presunzione semplice, purché essa sia abbastanza grave e precisa” (Luigi Paolo Comoglio; Corrado Ferri, e Michele Taruffo, Op. cit., p. 553).

160

José Carlos Barbosa Moreira, As presunções e a prova cit., p. 59.

161

Idem, p. 60.

162

Ver Salvatore Patti, Prove – Disposizioni generali, commentario del Codice Civile (a cura di A. Scialoja e G. Branca). Bologna/Roma: Zanichelli – Il foro italiano, 1987. p. 103; Luigi Paolo Comoglio, Corrado Ferri; Michele Taruffo. Op. cit., p. 628; Andrea Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile cit., p. 488.

163

Veja-se, mais adiante, os comentários ao art. 373, onde se tratará do tema do ônus da prova.

164

“Em geral, como bem se sabe, o ônus da prova é distribuído precisamente em função dessa posição; quer dizer, o critério básico repousa na circunstância de ser autor ou réu, no processo, o sujeito considerado: de acordo com as regras tradicionais, se autor, caber-lhe-á provar o fato constitutivo do (suposto) direito; se réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. A presunção legal, porém, faz abstração dessa

circunstância que, nas restantes hipóteses, é decisiva: a pessoa a quem a presunção desfavorece suporta o ônus de provar o contrário independentemente de sua posição processual, nada importando o fato de ser autor ou réu” (José Carlos Barbosa Moreira, *As presunções e a prova cit.*, p. 60).

165

Andrea Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile cit.*, p. 483; Sérgio Cruz Arenhart, “Ônus da prova e sua modificação no processo civil brasileiro”. *Revista Jurídica*, Porto Alegre, n. 343, 2006.

166

José Carlos Barbosa Moreira, *As presunções e a prova cit.*, p. 61.

167

“O que pode, dentro de certos limites, atenuar este erro é a reflexão de que, enquanto permite proporcionar a demonstração mediante uma presunção legal, a lei facilita a demonstração mesma e assim alivia o peso de quem deve proporcioná-la, mas é uma confusão que se deve evitar a que se produz entre exoneração da prova (inversão do ônus) e facilitação da prova; esta segunda não suprime o ônus, mas se limita a fazer mais fácil a prova, a qual, sem embargo, continua estando a cargo da mesma parte; praticamente, a facilidade poderá ser tal que equivalha à exoneração, mas logicamente as duas posições devem seguir sendo distintas” (Francesco Carnelutti, *Sistema de derecho procesal civil*. Trad. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo e Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: Uteha, 1944. t. II, p. 547).

168

Salvatore Patti, *Prove – Disposizioni generali, commentario del Codice Civile* (a cura di A. Scialoja e G. Branca) *cit.*, p. 105.

169

Cf. Andrea Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile cit.*, p. 482.

170

Por isso mesmo, com muita precisão, acentua Barbosa Moreira que os critérios que determinaram a previsão normativa da presunção absoluta “dizem respeito a uma opção do legislador e, portanto, se inscrevem no plano da política legislativa. Sua relevância é, por assim dizer, pré-jurídica. Uma vez editada a norma, a respectiva eficácia manifesta-se com autonomia em relação aos motivos de conveniência ou de oportunidade que porventura a tenham inspirado; nem fica obscurecida essa verdade pelo papel que eventualmente possa desempenhar a *ratio legis* em matéria de interpretação” (José Carlos Barbosa Moreira, *As presunções e a prova cit.*, p. 62).

171

Eduardo J. Couture, *Fundamentos del derecho procesal civil cit.*, p. 227.

Costuma-se, neste passo, fazer uma distinção entre a presunção absoluta e a ficção. Segundo Mattiolo, “tanto as presunções juris como as ficções legais são criações do legislador e ambas pressupõem a existência de um fato que certamente não existe; mas, na presunção, o fato pressuposto é provável ou pelo menos duvidoso; ao contrário, com a ficção, o legislador, em consideração de especiais razões de conveniência, pressupõe a existência de um fato que certamente não existe” (Luis Mattiolo, Tratado de derecho judicial civil. Trad. Eduardo Ovejero. Madrid: Reus, 1934. v. 3, p. 330-331). Assim, haveria ficção quando o legislador, arbitrariamente e sem qualquer respaldo nas situações normais cotidianas (*quod plerumque accidit*), impõe o reconhecimento de certa situação como ocorrente, diante de uma premissa pré-estabelecida. Ao contrário, na presunção absoluta essa determinação (também arbitrária) tem respaldo lógico na verificação das situações normais e decorre de uma efetiva possibilidade de que o fato presumido realmente decorra do indício estipulado. A distinção, todavia, embora possa ter alguma relevância didática, não tem muita razão de ser em termos práticos.

Como diz Canelutti, “se alguém se detém um pouco a pensar neste mecanismo, dá-se conta de que, quando a lei age assim, faz o mesmo que faria se atribuisse sem mais o efeito jurídico, em lugar de ao fato a provar, ao fato que serve legalmente para prová-lo; se, por exemplo, a liberação do devedor é a consequência jurídica do pagamento, e se a voluntária restituição do documento engendra a presunção legal de pagamento, é o mesmo que reconhecer que esta restituição produz a liberação” (Francesco Canelutti, Sistema de derecho procesal civil, t. II, cit., p. 539).

Pense-se, por exemplo, em uma regra que pretendesse instituir um tributo com alíquotas diferenciadas em função da capacidade contributiva de cada pessoa. E que o critério para aferir essa diferente capacidade fosse fixado em razão da região do país habitada pelo sujeito passivo tributário. Trata-se, sem dúvida, de uma presunção legal absoluta (mais precisamente de uma ficção legal), a qual, por simples critério de lógica, ou mesmo diante de prova em contrário no processo, não pode ser afastada. Entretanto, pode o juiz afastá-la ao verificar a ausência de razoabilidade no *discrímen*, o que importaria na conclusão de que a presunção padece de vício de inconstitucionalidade por lesão ao princípio da isonomia.

Em sentido semelhante, v. Francisco Augusto das Neves E Castro,; Francisco Cavalcanti Pontes De Miranda, *Theoria das provas e sua applicação aos actos civis cit.*, p. 466. Os autores advertem, contudo, que “parecem-nos dignos de adoptar-se os subsidios, que n’esta parte nos fornecem os nossos antigos praxistas e jurisconsultos, os quaes diziam, que a presumpção especial prevere á geral, e entre as especiais, preferem as violentas ás que não o são. *Praesumptioque una cedit pluribus, et specialis generali prevalet, et eam tollit*. Em quanto á collisão de presumpções simples tem unicamente lugar o prudente arbitrio do julgador” (*Theoria das provas e sua applicação aos actos civis cit.*, p. 46-47 – texto conforme a grafia

original).

177

Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela inibitória*, 3. ed., cit.; Sérgio Cruz Arenhart, *Perfis da tutela inibitória coletiva*, São Paulo: Ed. RT, 2003; Id. *A tutela inibitória da vida privada*. São Paulo: Ed. RT, 2000.

178

Cristina Rapisarda, *Profili della tutela civile inibitoria*. Padova: Cedam, 1987. p. 16.

179

Lodovico Barassi, *La teoria generale delle obbligazioni*. Milano: Giuffrè, 1964. p. 428.

180

Como diz Rapisarda, “l’identificazione dell’azione con il diritto sostanziale sottostante implicava, cioè, la perfetta coincidência tra il sorgere del direito de ação ed il verificarsi del momento patológico della violazione o della lesione del direito soggettivo materiale, prima della quale esisteva solo il direito sostanziale, in regime di pacífico gozimento” (Cristina Rapisarda, *Profili della tutela civile inibitoria cit.*, p. 23).

181

A propósito de um breve histórico da tutela preventiva em nosso direito, lembra, com a genialidade que lhe é peculiar, Pontes de Miranda que “à medida que se foram revelando os direitos absolutos, sem ser o de propriedade, manifestou-se, mais viva, a necessidade de tutela jurídica à abstenção. Quanto aos direitos relativos, o problema resolvía-se, na prática, na falta de mais segura investigação científica, pela ação de condenação, ou pela ação de preceito cominatório, isto é, a ação de abstenção com o preceito inserto na citação. A primeira técnica foi a do preceito inserto na citação mesma. Nas Ordenações Afonsinas, Livro III, Título 80, § 6, em que se tinha o processo de preceitação como de ‘autos não começados, mais (mas) cominatórios’, dizia-se que ‘a parte, que se teme ou receia ser agravada, se pode socorrer dos Juizes da terra, implorando seu Offício, per que mandem prover como lhe nom seja feito tal agravo’. A cominação podia ser extrajudicial (§ 7), devendo pedir-se ao juiz a aplicação do preceito: ‘(...) poderá fora do Juizo apelar de tal comminação, a saber poendo-se sob poderio do Juiz, requerendo, e protestando da sua parte a aquelle, de que se teme ser aggravado, que tal agravo lhe nom faça. E se depois do dito requerimento, e protestaçam assy feita, fôr alguma novidade cometida, ou atentada, e o Juiz depois for requerido pera ello, mandará todo tornar, e restituir ao primeiro estado’. A cominação extrajudicial era, no fundo, o exercício da pretensão à abstenção, fora da via de propositura judicial da ação. (...) Nas Ordenações Manuelinas, Livro III, Título 62, §§ 5-7, reproduziram-se as regras jurídicas afonsinas, que também passaram às Ordenações Filipinas, Livro III, Título 78, §§ 5 e 6, mas resumidas, como passamos a ver. Se o interessado preferia a cominação judicial, tinha por ele o § 5, 1.^a e 3.^a partes: ‘E quanto aos autos extrajudiciais, que não são começados, mas cominatórios, dizemos que a parte, que se teme, ou receia ser agravada per a outra parte, pode recorrer aos Juizes da terra, implorando seu Offício, que o provejam, como lhe não seja feito agravo’: ‘E se depois do dito requerimento e protestaçam assim feita, fôr alguma novidade cometida, ou tentada, mandará o Juiz (se for requerido) tornar e restituir tudo

ao primeiro estado. E em tal protestação será inserta e declarada a causa verossímil e razoada, por que protestou: pode-se por exemplo: se algum se temer de outro, que o queira ofender na pessoa, ou lhe queira sem razão ocupar e tomar suas cousas, poderá requerer ao Juiz, que o segure a ele e as suas cousas do outro, que o quiser ofender, a qual sentença lhe o Juiz dará; e se depois dela ele receber ofensa daquele, de que foi seguro, restituí-lo-á o Juiz, e tornará tudo o que foi cometido e atentado depois da segurança dada, e mais procederá contra o que a quebrantou, e menosprezou seu mandado, como achar per Direito” (Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Tratado das ações. Atual. Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 1998. t. I, p. 160-162).

182

Ada Pellegrini Grinover, A tutela preventiva das liberdades: habeas corpus e mandado de segurança. RePro, n. 22, São Paulo: Ed. RT, 1981. p. 27.

183

Ada Pellegrini Grinover, A tutela preventiva das liberdades: habeas corpus e mandado de segurança cit., p. 27.

184

Cristina Rapisarda, Premesse allo studio della tutela civile preventiva. Rivista di Diritto Processuale. Padova, Cedam, jan.-mar. 1980. p. 103.

185

Sobre a questão, v. Sérgio Cruz Arenhart, Perfis da tutela inibitória coletiva, ob. cit., passim; Id. A tutela inibitória da vida privada. ob. cit., passim.

186

Deixe-se claro que, para a propositura da ação inibitória, não é preciso demonstrar um dano futuro, embora ele possa ser invocado, em certos casos, para deixar mais evidente a probabilidade do ato contrário ao direito. Ou seja, nada impede que se invoque dano, ainda que baste arguir a probabilidade de ato contrário ao direito.

187

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1966. t. LIII, p. 85.

188

Aldo Frignani, L'azione inibitoria contro le clausole vessatorie (considerazioni “fuori dal coro” di un civilista). Rivista di Diritto Processuale, Padova, Cedam, out.-dez. 1997. p. 1.000.

Para maiores informações sobre a questão, confira-se a obra de Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela inibitória cit.*, 3. ed.; Sérgio Cruz Arenhart, *Perfis da tutela inibitória coletiva*, ob. cit., passim; Id. *A tutela inibitória da vida privada*. ob. cit., passim.

Segundo Bonasi Benucci, “il motivo per il quale la dominante dottrina intravede nella colpa un elemento costitutivo dell’illecito civile va ricercato, a nostro avviso, nel fatto che l’illecito si è sempre esaminato sotto l’angolo visuale della responsabilità per i danni ad esso conseguenti: e poiché la sussistenza della responsabilità per tali danni è normalmente condizionata alla colpa (art. 2.043 c.c.), si è costruito l’illecito su base soggettiva ossia sulla base della colpa dell’agente” (Eduardo Bonasi Benucci, *Atto illecito e concorrenza sleale*. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Milano, Giuffrè, 1957. p. 579). De acordo com Spolidoro, “parlando di presupposti della inibitoria, dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nel rilevare che essa prescinde dal dolo o dalla colpa dell’agente e dall’essersi verificato un danno nel patrimonio del soggetto passivo” (Marco Saverio Spolidoro, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*. Milano: Giuffrè, 1982. p. 161-163). No mesmo sentido, ao estudar a concorrência desleal, adverte Remo Franceschelli que a tutela que tem por fim inibir a continuação do ilícito, ao contrário da tutela ressarcitória, prescinde da culpa: “Se nonostante che si sia accertato che un atto di concorrenza esiste, colui che lo ha compiuto provi che egli è esente da colpa, ciò avrà per effetto che si escluda il risarcimento del danno. Ma l’attività potrà pur sempre essere fatta cessare e il giudice potrà pur sempre dare i provvedimenti necessari o utili perchè ne vengano eliminati gli effetti” (Remo Franceschelli, *Studi sulla concorrenza sleale*, La fattispecie. Rivista di Diritto Industriale, Milano, Giuffrè, 1963. p. 273). Ver, também, Roberto Goldschmidt, *L’azione preventiva*. Rivista di Diritto Processuale, Padova, Cedam, 1959, p. 408; Andreas Von Tuhr, *Derecho civil, teoría general del derecho civil alemán*. Buenos Aires: Depalma, 1948. v. 3, 2, p. 165-166.

Como diz Rapisarda, a autonomia da inibitória em relação à culpa tem relação com o caráter não sancionatório dessa tutela (Cristina Rapisarda, *Inibitoria*. Digesto delle discipline privatistiche, 1993. v. 9, p. 479-480).

Conforme explica Rapisarda, “da natureza preventiva da inibitória deriva também a ausência da culpa. A ação inibitória, como dito, volta-se para o futuro, e assim fica excluída a possibilidade objetiva de valorar se preventivamente os elementos subjetivos do comportamento ilícito futuro, sobre qual é destinado a incidir o provimento final de tutela” (Cristina Rapisarda, *Inibitoria cit.*, p. 479).

Como escreve José De Oliveira Ascensão ao tratar do tema dos direitos autorais: “É importante observar que estas violações não necessitam em geral de ser ilícitas. Basta o estado de objetiva contrariedade ao direito, portanto a lesão objetiva ao direito do autor, para que a elas se possa recorrer. Distinguimos a violação do direito e a violação ilícita do direito. Nomeadamente, para que haja ilicitude é necessário que se verifique dolo ou negligência do infrator, porque o ilícito é pessoal. Mas aqui é irrelevante que assim

aconteça. A divulgação não autorizada pode ser feita cessar, por maior que seja a boa-fé do utente. O caráter ilícito da violação só relevará para efeito de perdas e danos” (José de Oliveira Ascensão, Direito autoral. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 537). Ainda que o jurista português fale em “violação do direito e violação ilícita do direito” – no nosso sentir de forma equivocada –, deixa claro que “o caráter ilícito da violação só relevará para efeito de perdas e danos”. Para maior aprofundamento, ver Luiz Guilherme Marinoni, Tutela inibitória, 3. ed., cit.

194

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Tratado das ações, t. I, cit., p. 162.

195

A respeito, já disse Welzel – embora em outro campo do direito – que a ilicitude é uma “contradição da realização do tipo de uma norma proibitiva com o ordenamento jurídico como um todo” (Hans Welzel, Das deutsche Strafrecht. 11. ed. Berlim: Walter de Gruyter, 1969. p. 51).

196

Sérgio Cruz Arenhart, Perfis da tutela inibitória coletiva, ob. cit., passim; Id. A tutela inibitória da vida privada. ob. cit., passim.

197

Nesse sentido, Elimar Szaniawski, Direitos da personalidade e sua tutela. São Paulo: RT, 1993. p. 81. Sobre os direitos potestativos, ver a noção de Chiovenda: “En muchos casos la ley concede a alguno el poder de influir con la manifestación de su voluntad en la condición jurídica de outro, sin el concurso de la voluntad de éste (...) Estas facultades son diferentes entre sí, ya sea por las condiciones a que se hallan subordinadas ya porque algunas se ejercen mediante una simples declaración de voluntad y otras con la necesaria intervención del juez (sentencia constitutiva V. § 8). Pero todas tienen de común la tendencia a producir un efecto jurídico en favor de un sujeto y a cargo de outro, el cual no debe hacer nada ni siquiera, para librarse de aquel efecto, permaneciendo sujeto a su actuación. La sujeción es un estado jurídico que no exige el concurso de la voluntad del sujeto ni ninguna acción suya” (Giuseppe Chiovenda, Principios de derecho procesal civil cit., p. 54-55).

198

Sobre o ponto, disse Kayser: “Um direito, escreveu Georges Ripert, não saberia pertencer a todos porque o direito subjetivo é um sinal de desigualdade, e ele não saberia existir em benefício de um, se ele não tem como contrapartida a obrigação do outro. Os direitos da personalidade fazem exceção a esta regra, porque eles pertencem a todas as pessoas físicas. O princípio da igualdade civil não significa somente, em relação a elas, que todas as pessoas físicas são suscetíveis de adquirir os mesmos direitos, mas que elas têm os mesmos direitos. Suas personalidades jurídicas não são uma simples virtualidade: elas lhes conferem estes direitos” (Pierre Kayser, Les droits de la personnalité – Aspects théoriques et pratiques. Revue Trimestrielle de Droit Civil, n. 3, Paris, Sirey, jul.-set. 1971. p. 489).

Frignani faz advertência semelhante ao dizer que “a injunction, que quando corretamente usada representa um eficaz meio de defesa contra o ilícito, ao ser concedida indiscriminadamente pode constituir instrumento de opressão e de injustiça e ter consequências perniciosas, seja para o réu, seja para a comunidade em geral” (Aldo Frignani, *L’injunction nella common law e l’inibitoria nel diritto italiano*, p. 196). Como é óbvio, essa situação deve ser evitada, a fim de não deslegitimar o uso da própria ação inibitória, assim como ocorreu com a ação cautelar.

Tratando do mandado de segurança, escreveu Celso Agrícola Barbi: “Entramos aqui no campo das chamadas ‘ações preventivas’, ou ‘juízos preventivos’, de grande valor prático, mas que devem ser manejados com bastante cautela, para não sobrecarregar o foro com demandas desnecessárias nem entravar o comércio jurídico. Tão importante é o papel das ações preventivas, que no Congresso Internacional de Direito Comparado, realizado em Bruxelas no ano de 1958, foi unanimemente aprovada declaração favorável à criação de um ‘juízo preventivo geral’ em todos os países” (Celso Agrícola Barbi, *Do mandado de segurança*. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 80-81). Advertiu o processualista que, “nesse mesmo Congresso, e sobre o mesmo tema, acentuou o Prof. Jacques Michel Grossen, de Neuchatel, que o problema central dessas ações preventivas é o ‘interesse de agir’, o qual não pode ser resolvido em abstrato, mas sim na base de critérios de ordem prática” (Idem, p. 81). A conclusão do mencionado Congresso tem o seguinte teor: “Il est désirable que dans chaque pays existe la possibilité de s’adresser aux tribunaux non seulement en cas de violation déjà accomplie d’un droit ou d’un intérêt juridique, mais aussi, avec les garanties convenables, lorsqu’il s’agit de prévenir une telle violation en cas de menace objective et actuelle. Cette protection peut être obtenue, selon le cas, soit par un jugement déclaratoire ou préventif. Il est désirable, en outre, que toutes mesures provisoires puissent être ordonnées, au besoin, même en vue d’une contestation future” (Cf. Gian Antonio Micheli, *L’azione preventiva*. Rivista di Diritto Processuale, Padova, Cedam, 1959, p. 222; nota ao final do artigo).

Caio Tácito, Mandado de segurança preventivo. *Revista de Direito Administrativo*, n. 61, Rio de Janeiro, FGV, jul.-set. 1960, p. 222.

Celso Agrícola Barbi, *Do mandado de segurança cit.*, 7. ed., p. 81-82.

“Mesmo no mandado de segurança preventivo, não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo, com base apenas no julgamento subjetivo do impetrante. Impõe-se que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios de parte da autoridade impetrada, ou ao menos indícios de que a ação ou omissão virá a atingir o patrimônio jurídico da parte. Em direito tributário, se o autor inquina determinada exação, prevista em lei, de inconstitucional ou ilegal, mas não demonstra qualquer ameaça a seu direito de não pagá-la, descabe a ação mandamental, que não tem por escopo interpretar a lei em tese” (STJ – REsp. 18414/CE – rel. Min. Demócrito Reinaldo – DJU 15.06.1992, p. 9.223).

204

Alfredo Buzaid. Do mandado de segurança. São Paulo: Saraiva, 1989. v. 1, p. 204. Em acórdão do extinto Tribunal Federal de Recursos, lê-se que “para viabilizar o mandado de segurança preventivo é necessário a ocorrência de situação concreta e objetiva indicativa de iminente lesão a direito líquido e certo” (TFR – AMS 112.033 – rel. Min. Torreão Braz – DJU 19.09.1988, p. 23.557). No mesmo sentido, e mais recentemente, decidiu o Tribunal Regional Federal da 5.^a Região que “o mandado de segurança preventivo exige prova de situação objetiva ensejadora de ameaça de lesão a direito líquido e certo” (TRF 5.a Reg. – AMS 2411 – rel. Juiz Castro Meira – DJU 08.03.1991, Seção 2, p. 4.101). Ainda nessa linha é a lição de Sérgio Ferraz: “O mandado de segurança preventivo não é uma vacina processual, destinada a afastar os receios das naturezas túbias. Seu escopo é a prevenção da prática de ilegalidades ou arbitrariedades, quando a ameaça de sua concretização seja palpável e próxima no tempo. Daí a correta rejeição do remédio quando o ato ou a omissão administrativa não se encontrem em si, ao menos indiciariamente esboçado: ‘simples parecer contrário à pretensão na esfera administrativa não caracteriza ameaça, a justificar requerimento de segurança preventiva’ (TFR – AMS 93.556 – rel. Min. Costa Lima – DJU 23.06.1983, p. 9.344)” (Sérgio Ferraz, Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 1992. p. 95).

205

Pontes de Miranda. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1977. t. XIII, p. 316-317.

206

Adroaldo Furtado Fabrício. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. v. 8, t. III, p. 341-342.

207

TJBA – 4.^a Câmara – Agr. 148/88 – rel. Des. Paulo Furtado – ac. unânime, in Alexandre de Paula, Código de Processo Civil anotado. 5. ed. São Paulo: RT, 1992. v. 4, p. 3.546. Em igual sentido, ver RT 617/198 e 631/152.

208

L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano, p. 205.

209

De Funiak, Handbook of Modern Equity. Boston: Little, Brown & Co, 1956, p. 27, apud Aldo Frignani,. L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano cit., p. 204.

210

Aldo Frignani,. L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano cit., p. 205.

211

Frignani, estudando a jurisprudência da common law, lembra o caso *Salvin v. North Brancepeth Coal Co.*,

no qual foi decidido que, a fim de que uma injunction seja concedida para impedir danos temidos (apprehended), é necessário que o temor seja razoável (reasonable) e, assim, que o perigo não seja remoto ou totalmente improvável (Aldo Frignani, *L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano* cit., p. 153).

212

A lógica do razoável vem seduzindo, cada vez mais, o jurista, que se apercebe que o direito não pode ser governado pela lógica pura. A teoria kelseniana da aplicação do fato à norma vem sendo combatida incessantemente pela doutrina, que denuncia a ingenuidade dessa construção. Como adverte Recaséns Siches, “lo racional puro de la lógica de la inferencia es meramente explicativo, explicativo de conexiones entre ideas, explicativo de nexos entre causas y efectos etc. En cambio, el logos de lo razonable, concierne a los problemas humanos – y por tanto, a los problemas políticos y jurídicos – intenta ‘comprender o entender’ sentidos y nexos entre significaciones, así como también realiza operaciones de valoración, y establece finalidades o propósitos. Es obvio que en nada, en absoluto, la lógica formal no nos suministra ninguna iluminación en la tarea de descubrir los valores pertinentes, ni tampoco en la labor de escoger los fines justificados. La lógica formal es neutral en lo que atañe a los valores éticos, políticos, jurídicos etc. Por el contrario, las normas jurídicas tienen una dimensión intensiva, imperativa, valoradora, normativa, la cual es totalmente desconocida por las leyes de la inferencia” (Luiz Recaséns Siches, *Introducción al estudio del derecho*. México: Porrúa, 1996. p. 252-253).

213

Como já se disse no passado, “é inútil ter um bom procedimento quando se tem uma má organização judiciária ou juízes insuficientes, ao passo que juízes que têm bons conhecimentos podem, a rigor, ajustarem-se a um procedimento medíocre” (René Morel, *Traité élémentaire de procédure civile*. 2. ed. Paris: Recueil Sirey, 1949. p. 3).

214

Aldo Frignani, *L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano*, p. 430.

215

René Morel, *Traité élémentaire de procédure civile*, p. 38-39.

216

Eis o texto original: “Mais la question est de savoir si, par le seul fait qu’une personne voit son droit menacé, elle justifie d’un intérêt suffisamment actuel pour demander aux tribunaux de constater l’existence de son droit. Il faut admettre l’affirmative: une menace suffisamment sérieuse, quoique non encore réalisé, est déjà une atteinte à la sécurité du titulaire du droit. Telle paraît bien être la solution consacrée par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 23 juin 1890 (D. 90.1.289, S. 93.1.519) elle a décidé que ‘celui qui a un droit peut agir contre celui qui le lui conteste, lorsque cette contestation se manifeste par des actes ou des faits qui constituent un trouble matériel ou juridique’ (V. encore Req., 18 avril 1899, S. 1901.1.459; 8 février 1927, S. 1927.1.181; Angers, 3 juillet 1868, D. 68.2.154; Dijon, 3 mai 1898, D. 99.2.114; Poitiers, 21 déc. 1902, sous Cass., S. 1908.1.317 Trib. comm. Épernay, 22 juin 1904, sous Cass., D. 1912.1.245;

Montpellier, 1er. avril 1930, D. H. 1930.372)” (René Morel. Op. cit., p. 39).

217

Novamente, eis as palavras do autor: “Encore faut-il que la menace soit suffisamment sérieuse. Au contraire, des propos peu précis et peu consistants par lesquels une personne contesterait l’existence d’un droit au profit d’une autre ne suffiraient pas à justifier une action préventive, parce que ces propos ne seraient pas de nature à créer un véritable trouble juridique (Limoges, 21 mai 1894, D. 1897.2.377)” (René Morel, Op. cit., p. 39).

218

Aldo Frignani, L’injunction nella common law e l’inibitoria nel diritto italiano , p. 434.

219

Nessa linha, por exemplo, o art. 10, do Código Civil italiano: “Abuso dell’immagine altrui – Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni (2056)”. Esclarece Frignani que, nesses casos, o ilícito tem um papel de importância não indiferente. “De fato, se ele já ocorreu no passado, de sua modalidade, de sua natureza, poder-se-á inferir com notável aproximação a probabilidade da sua continuação ou repetição no futuro” (Aldo Frignani, L’injunction nella common law e l’inibitoria nel diritto italiano , p. 429).

220

Outra questão, como é óbvio, é saber se a divulgação dessa notícia constitui ilícito.

221

Essa situação ensejaria colheita de prova oral em audiência de justificação (nos termos do art. 381, § 5.º, do Código de Processo Civil) o que, em se tratando de lesão à vida privada, à intimidade, à imagem ou à honra, pode inviabilizar a proteção inibitória, na medida em que tal audiência poderá exigir dilação temporal maior que o tempo de que se dispõe para evitar o ilícito. v. Sérgio Cruz Arenhart, Perfis da tutela inibitória coletiva, ob. cit., passim; Id. A tutela inibitória da vida privada. ob. cit., passim.

222

Adverte Ovídio A. Baptista da Silva que “Coniglio, por exemplo, em sua obra clássica sobre provimentos cautelares, já aludia à distinção entre a cognição plena do procedimento ordinário e a modalidade de prova obtida através de simples informatio iudicis, ou informatio saltem summaria, praticada no direito medieval, que não chegam a corresponder à formação de uma prova em sentido próprio, resumindo-se em simples ‘asserzione del creditore’ (no caso do arresto), ‘absque causae cognitione’ (Il sequestro giudiziario e conservativo. 3. ed. 1949. p. 97)” (Curso de Processo Civil, v. 3, p. 134).

223

“(…) Lord Diplok preconizou, como critério orientador do magistrado, para concessão de uma medida liminar, em circunstâncias especiais, um balance of convenience, através do qual o julgador possa avaliar não propriamente a procedência da pretensão de direito material – que a urgência tornara impossível realizar –, e sim as consequências que sua decisão poderá determinar com relação aos litigantes. O magistrado estaria, neste caso, autorizado a conceder a medida provisória uma vez que a demanda não se lhe afigurasse ‘frívola ou vexatória’ sem proceder, neste momento preliminar, nem mesmo à avaliação da plausibilidade do direito invocado pelo autor, dada a invencível premência circunstancial, que impede que este até mesmo produza essa prova sumária” (Curso de Processo Civil, v. 3, p. 135).

224

Idem, p. 136.

225

Carreira Alvim adota alguns desses critérios: “O receio a que se refere a lei traduz uma situação de perigo, pelo que deve ser justificado, quer dizer, vir acompanhado de circunstâncias fáticas objetivas, a demonstrar que a falta da liminar poderá comprometer o provimento final (...). Sendo o receio um sentimento de índole subjetiva, deverá ser analisado, em se tratando de pessoa física, em função de quem o experimenta, considerados a idade, o sexo, a instrução, a condição social etc. É sabido que o velho sente mais temor que o moço, a mulher mais que o homem e a criança mais que a mulher, não podendo tais circunstâncias ser desconsideradas, sob pena de se negar a tutela a quem esteja em condições de merecê-la. Destarte, o que é temor ou receio para o velho não o é para o moço; o que é temor para a mulher não o é para o homem; e o que é temor para a criança não o é para a mulher” (José Eduardo Carreira Alvim, Tutela específica e tutela assecuratória das obrigações de fazer e não fazer na reforma processual. In: Sálvio de Figueiredo Teixeira, (coord.). Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 277-278).

226

Idem, p. 136.

227

Fritz Baur, Tutela jurídica mediante medidas cautelares. Porto Alegre: Fabris, 1985. p. 51-52.

228

Súmula 279, STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Súmula 7, STJ: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

229

“STF – Recurso extraordinário – Acórdão que, pelo exame das provas, concluiu ser inexata a versão dada aos fatos pelo recorrente. Inexistência de questão federal relativa à eficácia, em tese, de determinado meio

de prova, mas tão somente de apreciação da força de convicção delas concretamente, no caso examinado. Reexame inadmissível em recurso extraordinário. Agravo regimental não provido” (STF, AgRg 69.756, 1.^a Turma, rel. Min. Rodrigues Alckmin – RTJ 82/414).

230

“STF – Mandato – Questão de direito. Se o acórdão reconheceu a existência evidente dum mandato, negado pela instância local e atribui-lhe os efeitos de lei, decidiu então sobre a qualificação jurídica do ato, o que é questão de direito, e não de fato. (...) Não menos improcedente é a arguição de discrepância com a Súmula 279. Com efeito, foi preocupação louvável do eminente relator do acórdão embargado afastar de vez e por antecipação, a insinuação de que pudesse tratar-se de reexame de matéria de fato. Nessa linha de raciocínio, enfatizou S. Exa.: ‘Quando se considerasse que o embasamento da demanda se tivesse feito com vista ao vício da simulação, e seu reconhecimento emergisse, por inteiro, da prova, a toda evidência descaberia o apelo para a apuração da sua existência ou não, nos termos da Súmula 279. Todavia, antes de apreciá-la e quiçá para aceitá-la, partiu o acórdão, considerando os instrumentos procuratórios transcritos na escritura, que não constituíam eles mandato e pelas razões antes referidas.’ Vê-se, de trecho tão elucidativo, que não cuidou o venerando aresto impugnado de proceder a reavaliação da prova, senão de dar nova qualificação jurídica ao ato controverso. E, ao fazê-lo, o r. acórdão deparou-se com aquilo que o honrado Ministro Luiz Gallotti denominou de erro conspícuo na qualificação do ato jurídico. Entendeu a douda Turma julgadora, que os instrumentos procuratórios revestiam todos os requisitos legais, habilitando o mandatário à prática dos atos neles consignados. Qualificado o ato jurídico como mandato, deram-se-lhe os efeitos que estavam a reclamar a melhor solução da causa. Isto, obviamente, não importou reexame da matéria de fato, razão por que inexistente a suposta divergência jurisprudencial” (STF – RTJ 74/144). Sublinhe-se que os julgados do STF, referidos neste item, foram proferidos antes da criação do STJ e, portanto, antes da existência do recurso especial.

231

Nessa linha, vale frisar lição do Min. Athos Gusmão Carneiro: “Todavia, a qualificação jurídica de uma manifestação de vontade é quaestio iuris que, em tese, pode ser objeto de recurso extraordinário-especial. Em processo de que somos relator, discute-se se determinada manifestação de vontade, por público instrumento, constitui ‘reversão’ de doação, ou doação condicional, ou doação mortis causa, ou manifestação de última vontade. A qualificação jurídica do ato de vontade determinará qual a lei incidente e, pois sua eficácia” (Athos Gusmão Carneiro. Anotações sobre o recurso especial. Recursos no Superior Tribunal de Justiça. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 117).

232

Nessa linha, a seguinte decisão do STJ: “(...) 1. Conotação processual. O art. 1.º da Lei 1.533, de 1951, cujo teor o mandado de segurança protegerá ‘direito líquido e certo’, não é uma senha que abre as portas do recurso especial; o único efeito dessa regra é o de que o ‘direito’ que dependa de dilação probatória está excluído no âmbito do writ. 2. Recurso especial. Para os efeitos do recurso especial, o art. 1.º da Lei 1.533, de 1951, só é invocável: a) se, havendo prova documental pré-constituída, o juiz ou o tribunal entender incabível o mandado de segurança; b) se, havendo necessidade da dilação probatória, o juiz ou o tribunal decidir o mérito do mandado de segurança, à base de elementos insuficientes. Recurso especial não conhecido” (STJ, REsp 92777/RS, 3.^a Turma, rel. Min. Ari Pargendler – DJU 24.04.2000, p. 50). Mas, o STJ também tem decidido em sentido diverso: “(...) 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento

no sentido de não se conhecer da insurgência especial quando a alegada violação do art. 1.º da Lei 1.533/51 está consubstanciada na demonstração de direito líquido e certo a amparar mandamus, pois, para a verificação de sua existência, é imperativo o reexame de provas demonstrativas do alegado, vedado pelo enunciado 7 da Súmula desta Corte (...)” (STJ, REsp 507922/SC, 6.ª Turma, rel. Min. Hamilton Carvalhido – DJU 28.06.2004, p. 429).

233

“STJ – (...) 2. O art. 1.102 ‘a’, do CPC, dispõe que: (...) 3. A ação monitória tem base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Tal prova consiste em documento que, mesmo não provando diretamente o fato constitutivo do direito, possibilite ao juiz presumir a existência do direito alegado. Em regra, a incidência da aludida norma legal há de se limitar aos casos em que a prova escrita da dívida comprove, de forma indiscutível, a existência da obrigação de entregar ou pagar, que é estabelecida pela vontade do devedor. A obrigação deve ser extraída de documento escrito, esteja expressamente nele a manifestação da vontade, ou deduzida dele por um juízo da experiência. 4. A lei, ao não distinguir e exigir apenas a prova escrita, autoriza a utilização de qualquer documento, passível de impulsionar a ação monitória, cuja validade, no entanto, estaria presa à eficácia do mesmo. (...) 10. Recurso não provido” (STJ, REsp 423131/SP, 1.ª Turma, rel. Min. José Delgado – DJ 02.12.2002).

234

Ver Luiz Guilherme Marinoni Marinoni. Técnica processual e tutela dos direitos cit.

235

Ver Luiz Guilherme Marinoni. Idem.

236

Ver Luiz Guilherme Marinoni. Tutela inibitória cit.

237

Ver comentários ao art. 373.

238

STJ, REsp 474359/RJ, 4.ª Turma, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 04.05.2004.

239

“(…) 1. A inversão do ônus da prova, como já decidiu a Terceira Turma, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao ‘critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6.º, VIII). Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da ‘facilitação da defesa’ dos direitos do consumidor.’ (REsp 122.505-SP, da minha relatoria, DJ 24.08.1998). (...) 3. Recurso especial conhecido e provido, em

parte” (STJ, REsp 332869/RJ, 3.^a Turma, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.09.2002); “STF – Fraude contra credores – Ação pauliana para anular atos de transmissão gratuita de bens (art. 106 do Código Civil). Ônus da prova da insolvência ou solvência do devedor alienante; a este é que cabe provar, para elidir a ação, haver continuado solvente a despeito dos atos translativos impugnados. Recurso extraordinário conhecido e provido. (...) O v. Acórdão recorrido, prolatado em grau de embargos, louvando-se na doutrina do r. julgado da apelação, assentou que a embargante, ora recorrente, não fizera prova da insolvência e da fraude contra a credora. Não se cuida aqui do reexame de provas senão apenas da prevalência da tese de que cabe à autora da ação pauliana fazer a prova da insolvência dos devedores, decorrente do ato de liberalidade feito em favor de uma filha, ou se tal prova compete ao credor impugnante da liberalidade. E embora essa tese seja controvertida na doutrina e na jurisprudência, o Colendo Supremo Tribunal em dois recentes julgamentos, pelo menos como os indicados pela recorrente, propugnou pela que transfere ao réu da pauliana o ônus da prova de que, a despeito da liberalidade ou alienação, continuou solvente e apto para responder por outras dívidas anteriores em favor do credor” (STF – RTJ 75/659).

240

STJ – Recurso especial – Erro sobre critérios de apreciação da prova – Matéria de direito – Cabimento do recurso. O erro sobre critérios de apreciação da prova ou errada aplicação de regras de experiência são matérias de direito, e, portanto, não excluem a possibilidade de recurso especial (STJ, REsp 46.186-3/DF, 5.^a Turma, rel. Min. Edson Vidigal – RT 725/531).

241

STF – Execução para cobrança de cheque não pago pelo Banco sacado em consequência de contra-ordem. Defesa do emitente-executado alegando descumprimento, pelo exeqüente, do negócio subjacente. Falta de começo de prova por escrito do invocado contrato. Impossibilidade de comprová-lo por prova testemunhal. Recurso extraordinário conhecido e provido. (...) Para comprovar esse contrato, cujo valor ultrapassa Cr\$100.000,00, o executado fez inquirir testemunhas e apresentou documentos, que foram considerados pela decisão recorrida como começo de prova por escrito para os efeitos dos arts. 401 e 402, I, do CPC. Entretanto, o acórdão incorreu em erro na qualificação legal dessa prova, visto que nenhum dos documentos foi produzido ou emanou do embargado (...) (STF – RTJ 91/674).

242

Michele Taruffo. La prova dei fatti giuridici cit., p. 294.

243

Taruffo afirma que as decisões incompletas ou “supra-abundantes” são incongruentes. É “supra-abundante” a decisão que se refere a um fato alegado, mas não provado (Michele Taruffo. Idem, p. 295-296).

244

“STF – Anistia fiscal – Imposto de selo. Deixando de dar valor a prova válida (e acolhida por sentença passada em julgado), para ater-se a prova obtida sem instrução administrativa que foi anulada, o acórdão

recorrido violou o disposto no art. 118 do Código de Processo Civil/1939, e divergiu da jurisprudência do STF. Questão que diz respeito à valorização da prova, e não à sua interpretação. Recurso extraordinário conhecido e provido em parte. (...) A inovação das alíneas a e d do preceito constitucional pertinente, recorre extraordinariamente a União Federal, alegando que o julgado, ao dar pela inexistência do crime de sonegação fiscal, ofendeu o critério legal da valorização da prova, com o que negou vigência aos art. 118 e 252 do anterior Código de Processo Civil, e que os indícios da intenção dolosa e do intuito de fraude estão provados nos autos, de forma a caracterizar o crime de apropriação indébita, tendo a decisão atacada, por entender de modo diverso, conflitado com jurisprudência que cuida da matéria relacionada com a prerrogativa do juiz de julgar por livre convencimento e a maneira de se apreciarem as provas dos autos. (...) Consagra a jurisprudência da Suprema Corte, trazida a cotejo, o entendimento de que a prerrogativa de julgar por livre convencimento não outorga ao juiz contrariar a prova produzida. (...) Ora, deixando de dar valor a prova válida – o termo de exame a f. 116 – e prova essa acolhida por sentença passada em julgado (o recurso ex officio versava o despacho de extinção do processo proferido depois de a sentença passar em julgado, porque a anistia se aplicava também aos processos definitivamente julgados pelo Poder Judiciário), o acórdão recorrido violou o disposto no art. 118 do Código de Processo Civil de 1939 e dissentiu do julgado desta Corte (RE 27.990 – RF 163/177). Trata-se, sem dúvida, de caso típico de valorização de prova, e não de sua interpretação” (STF – RTJ 81/280).

245

Cabe ressaltar, aqui, que o STF entende que a violação da norma constitucional, para autorizar o extraordinário, deve ser direta e frontal: “STF – Recurso extraordinário – Violação à norma constitucional – Alegação que demanda o prévio exame de normas ordinárias. Inviabilidade, uma vez que a alegada afronta deve ser direta e frontal Ementa oficial: A violação de norma constitucional capaz de viabilizar o acesso do recurso a esta sede extraordinária há de ser direta e frontal e não aquela que demandaria o prévio exame das normas ordinárias (STF, AgRg em AI 216.262-3-PE, 2.^a Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 17.08.1998, RT 759/161).

STF – Constitucional – Recurso extraordinário: alegação de ofensa à CF, art. 5.º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV. I. Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, incorrendo o contencioso constitucional. II. Decisão contrária ao interesse da parte não configura negativa de prestação jurisdicional (C.F., art. 5.º, XXXV). III. A verificação, no caso concreto, da existência, ou não, do direito adquirido, situa-se no campo infraconstitucional. IV. Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5.º, LIV e LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais, E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal. V. Agravo não provido (STF, RE 154158 AgR/SP, 2.^a Turma, rel. Min. Carlos Velloso, DJU 20.09.2002, p. 00112); STF – (...) Alegação de ofensa ao art. 5.º, incisos XXXV, LIV e LV, bem assim ao art. 93, IX, todos da Constituição da República (...) Hipótese configuradora, quando muito, de ofensa reflexa ao texto constitucional (...). A alegação de ofensa ao texto constitucional, cuja invocação reclame exame prévio e necessário da legislação comum (ordinária e complementar), mesmo que se trate de matéria eleitoral, não viabiliza o trânsito do recurso extraordinário, eis que a verificação de desrespeito à Constituição federal dependerá, sempre, da análise do Código Eleitoral, da Lei de Inelegibilidade e de outros diplomas legislativos equivalentes. Precedentes (STF, AI 469699 AgR/MA, 2.^a Turma, rel. Min. Celso de Mello, DJ 30.09.2003).

246

STF – Confissão extrajudicial feita por escrito tem a mesma eficácia probatória da judicial. Inteligência do art. 353 do CPC. Valor vinculante do juiz, por se tratar de prova legal – Provado o fato, cumpria ao réu provar o fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, art. 333, I e II do CPC – Recurso extraordinário conhecido e provido para julgar procedente a ação nos termos da sentença de primeiro grau. (...) O v. Acórdão recorrido, entretanto, reformando a sentença, julgou improcedente a ação porque, além da confissão do réu, nenhuma outra prova apresentou o autor. Negou, assim, o v. Acórdão recorrido valor à confissão escrita de dívida, cuja autenticidade não era impugnada, ou cuja validade, como manifestação de vontade, não era contestada por qualquer vício legal. (...) Defiro o recurso. A questão, ao que me parece, não tem o veto da Súmula 279, porquanto não se cuida aqui de reexame de prova. O cerne do litígio está no silogismo temático do ônus probatório, como se infere das perspectivas antagônicas em que se colocaram as decisões nas duas instâncias ordinárias. É razoável a posição defendida pelo recorrente com o aval da sentença de primeiro grau; se havia confissão formalizada (art. 353 do CPC) que o réu se propôs enfaticamente neutralizar, a ele passou, integral, o encargo elidente (art. 333, II do CPC). A razão de julgar do acórdão, com inversão de tais regras, leva, em princípio, a considerar ocorrente motivação para a abertura da instância extraordinária de forma a se facultar o norte qualificado do Pretório Excelso. (...) Assim, não podia o v. Acórdão recorrido negar efeito à confissão extrajudicial plena consubstanciada no documento de f. 48, não impugnado. (...) O autor provou, pela confissão válida, o seu crédito, e o réu não conseguiu ilidir a confissão ou demonstrar a sua invalidade. O v. Acórdão recorrido, portanto, negou vigência aos arts. 333 e 353 do CPC (STF, RE 82.001/ SP, 2.ª Turma, rel. Ministro Cordeiro Guerra – RTJ 75/326).

247

Ver Virgilio Andrioli. Prova. Novissimo digesto italiano. vol. 143, p. 274.

248

Eduardo Couture. Fundamentos del derecho procesal civil cit., p. 227.

249

STJ, Resp 324130/DF, 4.ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 12.08.2002.

250

STJ, Resp 183508/RJ, 4.ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 10.06.2002.

251

STJ, Resp 343904/PR, 2.ª Turma, rel. Min. Eliana Calmon, DJ 24.02.2003.

252

STJ, Resp 209687/MS, 4.ª Turma, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 23.08.1999.

253

254

A doutrina jurídica dos países de *civil law* nunca fez questão de ressaltar que, para se garantir a previsibilidade, não importa muito a regra escrita nos códigos ou a norma abstrata, mas fundamentalmente a concretização da norma no caso específico. A previsibilidade depende de qualificações jurídicas unívocas, de modo que a lei não é suficiente para garanti-la, sendo indispensável que o próprio sistema jurídico contenha instrumento capaz de evitar decisões diferentes para casos iguais. Como afirma Massimo Corsale, “se la codificazione fosse essenziale per la certezza come prevedibilità, quest’ultima non potrebbe realizzarsi in ordinamenti basati sul diritto consuetudinario, o giudiziario, o comunque non basati sul diritto legale. Ordinamenti di questo tipo sono sempre esistiti, e non sempre hanno corrisposto a fasi primitive di organizzazione sociale: i due macroscopici esempi del diritto romano e del common law ne fanno fede” (Massimo Corsale, *Certeza del diritto e crisi di legittimità*, Milano: Giuffrè, 1979, p. 36).

255

Arts. 926 e 927, CPC.

256

Neil MacCormick, *The ethics of legalism*, Ratio Juris, 1989, 2, p. 184 e p. 193.

257

“De acordo com a ‘ética do legalismo’, há valores morais e sociais específicos que dependem da manutenção e suporte de uma ordem normativa institucional, para o bem da paz e previsibilidade entre os seres humanos, e como condição (mas não garantia) para manter-se a justiça entre eles” (Neil MacCormick, *Rethoric and the rule of law – A theory of legal reasoning*. New York: Oxford University Press, 2005, p. 6).

258

CPC, art. 926 e ss.

259

CPC, Art. 503. “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no *caput* aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial”.

260

Bentham, nas primeiras décadas do século XIX, disse que há razão para dizer que uma pessoa não deve perder a sua causa em consequência de uma decisão proferida em processo de que não foi parte, mas não há qualquer razão para dizer que alguém não deve perder a sua causa em consequência de uma decisão proferida em processo em que foi parte simplesmente porque o seu adversário não foi (Jeremy Bentham, *Rationale of judicial evidence*, London: Hunt & Clarke, 1827, p. 579). A lição de Bentham foi lembrada quando do julgamento de *Blonder-Tongue v. University of Illinois Foundation* (*Blonder-Tongue v. University of Illinois Foundation*, 402 U.S. 313, 1971), em que a Suprema Corte dos Estados Unidos teve oportunidade de declarar a validade do *nonmutual collateral estoppel*, ou seja, da invocabilidade da coisa julgada sobre questão por terceiro, alheio ao processo em que a coisa julgada (*collateral estoppel*) se formou.

261

Luiz Guilherme Marinoni, Culture and Predictability of the Law, *International Journal of Procedural Law*, v. 6, 2016, p. 185 e ss.

262

O formalismo do direito, em Weber, significa calculabilidade e previsibilidade. Para Max Weber, o capitalismo “precisa de um direito calculável” (*A gênese do capitalismo moderno*, São Paulo: Ática, 2006, p. 95). Ver ainda: Max Weber, *A ética protestante e o “espírito” do capitalismo*, São Paulo: Cia. das Letras, 2004; Max Weber, *Economia e sociedade*, v. 2, Brasília: UnB, 2004; David M. Trubeck, Max Weber on Law and the Rise of Capitalism, *Wisconsin Law Review*, 1972, p. 737-748; Sally Ewing, Formal justice and the spirit of capitalism: Max Weber’s sociology of law, *Law and Society Review*, n. 21, p. 498-499; Hubert Treiber, “Elective affinities” between Weber’s sociology of religion and sociology of law, *Theory and Society*, n. 14, p. 841-842; Richard Swedberg, *Max Weber e a ideia de sociologia econômica*, Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2005, p. 155-170.

263

Quando se alude, por exemplo, a determinação de prova de ofício, afirma-se que o processo em que o juiz atua além do desejo das partes não só é arbitrário, mas é também típico dos regimes ditatoriais. De outra parte, ao se falar em convenção processual, argumenta-se aí estar presente um processo permeado pela liberdade, em que prevalece a autonomia da vontade sobre o “autoritarismo do juiz”.

264

Sobre o tema, ver especialmente a coletânea *Accordi di Parte e Processo*, coordenada por Federico Carpi (*Quaderni della Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, Milano: Giuffrè, 2008), com importantes trabalhos de Federico Carpi, Loïc Cadiet, Vincenzo Ferrari, Giorgio De Nova, Michele Taruffo, Remo Caponi

e Adrian Zuckerman. No Brasil, ver a coletânea *Negócios processuais*, coordenada por Antonio do Passo Cabral e Pedro H. Nogueira, Salvador: JusPodivm, 2017; Julio Guilherme Müller, *Negócios processuais e desjudicialização da produção da prova*, São Paulo: Ed. RT, 2017; Antonio do Passo Cabral, *Convenções processuais*, Salvador: JusPodivm, 2016; Guilherme H. Lage Faria, *Negócios processuais no modelo constitucional de processo*, Salvador: JusPodivm, 2016; Robson Godinho, *Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015. O importante artigo de Loïc Cadiet, *Les Conventions Relatives au Procès en Droit Français: Sur la Contractualisation du Règlement des Litiges*, publicado em “*Accordi di Parte e Processo*”, também foi publicado no Brasil no livro *Perspectivas sobre o Sistema da Justiça Civil Francesa*, São Paulo, Ed. RT, 2017.

265

Elizabeth Thornburg, *Designer Trials*, *Journal of Dispute Resolution*, 2006, n. 1, p. 206 e ss.

266

Elizabeth Thornburg, *Op. loc. cit.*; Jaime Dodge, *The limits of procedural private ordering*, *Virginia Law Review*, v. 97, 2011, p. 724 e ss.

267

Kevin E. Davis e Helen Hershkoff, *Contracting for Procedure*, *William and Mary Law Review*, 2011, p. 533-554.

268

“First, parties should not have the opportunity to create their own procedural rules in a publicly provided litigation system; rather, they should obey the rules placed before them or opt out into arbitration. The two subsidiary concerns of the added cost related to ‘mini-codes of civil procedure’ and the loss of meaningful precedent are oft-cited examples” (Jaime Dodge, *The limits of procedural private ordering*, *Virginia Law Review*, v. 97, 2011, p. 768).

269

“... contract procedure should not be permitted to change the rules of the game on a case-by-case basis without serious public attention to the practice's implications for the continuing vitality of the overall adjudicative structure” (Kevin E. Davis e Helen Hershkoff, *Contracting for Procedure*, *William and Mary Law Review*, 2011, p. 554).

270

Loïc Cadiet, Jacques Normand e Soraya Amrani Mekki, *Théorie générale du procès*, p. 524. Consultese também Loïc Cadiet, *Les conventions relatives au procès en droit français. Sur la contractualisation du règlement des litiges*, *Accordi di parte e processo*, p. 7 e ss.; Michele Taruffo, *Verità Negoziata?*, *Accordi di parte e processo*, p. 69 e ss.; Remo Caponi, *Autonomia privata e processo civile: gli accordi processuali*, *Accordi di parte e processo*, p. 99 e ss.; Adrian Zuckerman, *Adjudication of civil dispute: a mismanaged public service*, *Accordi di parte e processo*, p. 121 e ss. Na doutrina brasileira, Antônio do Passo Cabral,

Nulidades no processo moderno (2. ed.), p. 211; Despolarização do processo e zonas de interesse: sobre a migração entre os polos da demanda, *Revista Forense*, p. 1617, n. 404; *Convenções processuais*. São Paulo. Tese apresentada como requisito para a obtenção do grau de Livre-Docência em Direito, 2015, *passim*.

271

Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Curso de processo civil*, v. II.

272

A natureza dispositiva da confissão é denunciada pelas previsões que vedam sua incidência em relação a direitos indisponíveis (art. 392), que exigem capacidade para a confissão (art. 392, § 1.º) ou que autoriza a anulação da confissão por vício de consentimento (art. 393).

273

Sobre a vulnerabilidade no processo civil, Fernanda Tartuce, *Igualdade e vulnerabilidade no processo civil*. Sobre a configuração dos limites de disposição a partir da ideia de ordem pública, Ricardo Aprigliano, *Ordem pública e processo*. Sobre a flexibilização procedimental em geral, Fernando Gajardoni, *Flexibilização procedimental*.

274

Note-se que essa prerrogativa não se confunde com a previsão do art. 139, VI, que permite ao juiz “dilatator os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito”. Neste último caso, que ocorre de ofício pelo juiz (ainda que deva, antes de decidir, ouvir as partes, na forma do que prevê o art. 9.º), as prerrogativas do juiz são muito mais limitadas: só pode ele dilatar prazos ou alterar a ordem de produção de prova. Já nos termos do art. 190, que ocorre de comum acordo, entre o juiz e as partes, há latitude maior para a alteração dos atos processuais, que pode incidir sobre qualquer evento do processo. Sobre o calendário como meio para a promoção da duração razoável do processo, Antônio do Passo Cabral, “A duração razoável do processo e a gestão do tempo no Projeto de Novo Código de Processo Civil”, *Novas tendências do processo civil*, p. 113-114, vol. II.

275

V., sobre isso, os comentários ao art. 471, adiante.

276

Sobre a convenção a respeito do ônus da prova, v. Robson Godinho. *Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, *passim*.

277

Loïc Cadet, Jacques Normand e Soraya Amrani Mekki, *Théorie générale du procès*, p. 525.

278

Sobre a intrincada problemática da renúncia a direitos fundamentais, Pedro Adamy, Renúncia a direito fundamental.

279

Note-se que é o próprio art. 190, que alude à possibilidade de as partes convencionarem sobre ônus, poderes, faculdades e deveres.

280

Pedro Adamy, Renúncia a direito fundamental, p. 203.

281

Sobre o assunto, José Carlos Barbosa Moreira, “Privatização do processo?”, Temas de direito processual, p. 7 e ss., Sétima Série; “O neoprivatismo no processo civil”, Temas de direito processual, p. 87 e ss., Nona Série.

282

O caso notório, obviamente, é o da Inglaterra: sobre o estado da Justiça Civil inglesa antes das Civil Procedure Rules, Jack Jacob, The fabric of english civil justice; sobre a situação atual, Neil Andrews, Andrews on Civil Procedure, p. 197 e ss., v. I.

283

David H. Taylor e Sara M. Cliffe, Civil Procedure by Contract: A Convoluting Confluence of Private Contract and Public Procedure in Need of Congressional Control, *University of Richmond Law Review*, v. 35, 2002, p. 1085 e ss.

284

Michele Taruffo, Verità negoziata?, in *Accordi di Parte e Processo* (coordenado por Federico Carpi), Milano: Giuffrè, 2008, p. 69 e ss.

285

“... a contract may specify that evidence in the form of hearsay that would otherwise be admissible pursuant to a hearsay exception would be inadmissible unless the declarant were unavailable to testify” (David H. Taylor e Sara M. Cliffe, Civil Procedure by Contract: A Convoluting Confluence of Private Contract and Public Procedure in Need of Congressional Control, *University of Richmond Law Review*, v. 35, 2002, p. 1086).

286

287

Robson Renault Godinho, A possibilidade de negócios jurídicos processuais atípicos em matéria probatória, in *Negócios Processuais* (coordenado por Antonio do Passo Cabral e Pedro H. Nogueira), Salvador: JusPodivm, 2017, p. 577 e ss.

288

Eduardo Cambi, *Prova civil*, São Paulo: Ed. RT, 2006; Paulo Osternack Amaral, *Provas – Atipicidade, liberdade e instrumentalidade*, cit.; Vitor de Paula Ramos, *Ônus da prova no processo civil – do ônus ao dever de provar*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

289

Luiz Guilherme Marinoni, *Il Diritto di Azione come Diritto Fondamentale*, Torino: Giappichelli, 2016, p. 47 e ss; Luiz Guilherme Marinoni, Il diritto di azione come garanzie fondamentale nella Costituzione Brasiliana, *Rivista di Diritto Processuale*, 2008, p. 1176-1191; Luiz Guilherme Marinoni, *El derecho de acción como derecho fundamental*, Bogotá: Temis, 2015, p. 31-64.

290

O grande problema, neste caso, é a demonstração da causalidade, ou seja, é a demonstração de que o acidente causou dano ao feto. A prova dessa causalidade, como é evidente, não pode ser pensada como a prova da causalidade das lesões comuns. Tal prova deve ser compreendida em sintonia com os limites do conhecimento sobre as causas e as consequências das lesões produzidas a um feto. Não há como exigir prova plena da causalidade quando o conhecimento humano não pode explicá-la. Essa exigência implicaria em negar, de uma vez só, o direito à tutela jurisdicional e o próprio direito material. Significa que, quando se considera a convicção judicial, é preciso raciocinar sobre a causalidade na *perspectiva da possibilidade do seu pleno esclarecimento*. Quando essa possibilidade não é plena, não há como exigir uma “convicção de certeza”, bastando a probabilidade. Do contrário não haveria como dar tutela jurisdicional ao direito material, negando-se, no caso, a própria peculiaridade das lesões pré-natais. Cf. Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Arenhart, *Prueba*, Santiago: Thomson Reuters, 2015, p. 212 e ss. Ver ainda Gerhard Walter, *Libre apreciación de la prueba*, Bogotá: Themis, 1985, p. 229-248.

291

Taruffo argumenta que a “justiça da decisão” não pode deixar de estar entre os requisitos exigidos para a configuração do “processo justo”. Afirma que não se pode ter como “justa” toda e qualquer decisão que derive de um “procedimento justo” ou que observou todas as garantias processuais das partes. No seu entendimento, a averiguação da verdade dos fatos é necessária a fim de que o processo justo desempenhe a função que lhe é própria, de modo que o processo é justo quando é sistematicamente orientado a permitir a averiguação da veracidade dos fatos relevantes para a decisão e é injusto exatamente quando obstaculiza ou limita tal averiguação. Cf. Michele Taruffo, Verità negoziata?, in *Accordi di Parte e Processo* (coordenado por Federico Carpi), p. 78-80. Ver Beclaute Oliveira Silva, Verdade como objeto do negócio

juridico processual, in *Negócios Processuais*, Salvador: JusPodium, 2017, p. 553 e ss.

292

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio C. Arenhart e Daniel Mitidiero, *Curso de Processo Civil – Teoria do Processo Civil*, v. 1, 3. ed, São Paulo: Ed. RT, 2017, p. 468-481.

293

Jordi Ferrer Beltrán, *Prueba y verdad en el derecho*, Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 69 e ss.

294

É claro que, ao seu inserir o direito à decisão justa na cláusula do “processo justo”, não há problema em falar em direito ao “processo justo”. O que não se pode admitir é a ideia de legitimidade pelo procedimento em conformidade com os direitos fundamentais *processuais*.

295

O respeito aos direitos fundamentais processuais é requisito para se ter decisão justa. Porém, é requisito insuficiente. A tese que faz supor que a justiça da decisão decorre de um processo justo é redutiva, pois desconsidera o conteúdo da decisão, dando ênfase apenas ao procedimento. Nessa perspectiva, a decisão é o simples resultado do procedimento, um ato jurisdicional despidido de conteúdo substancial. O que importa é somente a qualidade do procedimento. Como diz Taruffo, esta perspectiva “implica la renuncia a valutare se una decisione è o no giusta per il suo contenuto o per gli effetti che produce, e rimanda l'osservatore alla sola considerazione delle modalità con cui si è svolto il processo che la portato a quella decisione” (Michele Taruffo, *Idee per una teoria della decisione giusta*, Sui confini – Scritti sulla giustizia civile, Bologna: Il Mulino, 2002, p. 221).

296

Luigi Ferrajoli, *Principia Iuris – Teoria del Diritto e della Democrazia*, v. 1, Roma: Laterza, 2007, p. 876.

297

No mesmo sentido, Paulo Henrique dos Santos Lucon. “Poderes instrutórios do juiz e negócio jurídico processual”. Comentários ao novo Código de Processo Civil. Coord. Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 575 (comentário 5 ao art. 370 do CPC/2015). Contra, entendendo que é viável acordo que limite as espécies de prova admissíveis em processo, v. Paulo Osternack do Amaral, *Provas – atipicidade, liberdade e instrumentalidade*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 143 e 146.

298

Pedro A. Batista Martins, Panorâmica sobre as provas na arbitragem. Disponível em: “batistamartins.com/wp-content/uploads/kalins-pdf/singles/panoramica-sobre-as-provas-na-arbitragem-2.pdf”. Acesso em 30.05.2018; Francisco Cahali, *Curso de arbitragem*, São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 245.

Aliás, o árbitro, não apenas de acordo com a Lei de Arbitragem brasileira (art. 22, *caput*), mas também consoante vários Regulamentos de Tribunais Internacionais de Arbitragem, tem poder para determinar prova de ofício. Assim, por exemplo, o Regulamento da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional (CCI) afirma, no seu art. 20, 2 e 5, que: “2. Após examinar todas as petições das partes e todos os documentos pertinentes, o Tribunal Arbitral deverá ouvir as partes em audiência contraditória, se alguma delas o requerer. *Na ausência de tal solicitação, poderá o Tribunal Arbitral ordenar, de ofício, a oitiva das partes.* (...) 5. A qualquer momento, no decorrer do processo, o Tribunal Arbitral *poderá determinar às partes que forneçam provas adicionais*”.

A sentença, além de negar o direito fundamental à tutela jurisdicional, terá violado o art. 32, III, combinado com o art. 26, II, da Lei da Arbitragem, uma vez que a justificativa sobre os fatos, na falta da prova *indevidamente excluída*, será incompleta.

Paulo Osternack Amaral, *Provas – Atipicidade, liberdade e instrumentalidade*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 134 e ss.

O “jeito” ou “arranjo” é um modo simpático, muitas vezes até mesmo tocante ou desesperado, de relacionar o impessoal com o pessoal, de forma a permitir a justaposição de um problema pessoal a um problema impessoal, de maneira a solucionar este utilizando aquele como escada ou aríete. Normalmente invoca-se uma relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores externos ao problema formal/legal burocrático a ser enfrentado, mediante o que se obtém a simpatia do representante do Estado e, conseqüentemente, uma solução satisfatória. A distância entre o direito escrito e a sua aplicação prática fez do “jeito” uma instituição para-legal altamente cotada no Brasil, uma parte integrante da cultura, a ponto de, em muitos setores, constituir a regra. O “jeito” é a variante cordial do “sabe com quem está falando”, pois ambos estão fundados na rede de relações pessoais que dão amparo às pretensões do malandro, seja ele cordial (que se utiliza do jeito) ou arrogante (que pode ser a mesma pessoa, após ver frustrada a tentativa do arranjo). Nos dois casos, promove-se a superação da estrutura formal igualitária e impessoal mediante – por exemplo - a invocação de parentes (jeito) ou de autoridades (“sabe com quem está falando”) e a *burla à lei e à administração pública, inclusive da justiça, assume ares de “honrosa exceção”* (Cf. Luiz Guilherme Marinoni e Laércio A. Becker, A influência das relações pessoais sobre a advocacia e o processo civil, *Trabalho apresentado no XX World Congress of Procedural Law*, 2003).

Num sistema em que a estabilidade da resolução da questão é vista como indispensável à tutela da segurança jurídica, articulando-se a partir daí como alicerce para a promoção da liberdade e da igualdade, a solução da questão deixa de dizer respeito apenas às partes e passa a interessar à sociedade e à promoção dos fins do Estado. Se alguém imagina uma situação em que casos ou questões podem ser discutidos várias vezes, “*the possibility of inconsistent judgments is obvious*” e a autoridade do Judiciário

é desprezada, assumindo-se ainda um grave risco de intermitente violação do princípio da igualdade. Ver Allan D. Vestal, *Res Judicata: Preclusion*, New York: Matthew Bender, 1969.

304

David Shapiro, *Preclusion in civil actions*, New York: Foundation Press, 2001, p. 109; Richard Marcus, Martin Redish, Edward Sherman e James Pfander, *Civil Procedure – A modern approach*, St. Paul: West, 2013, p. 1293-1294.

305

De acordo com o § 27 do *Restatement (Second) of Judgments*, quando uma questão de fato ou de direito é efetivamente *discutida e decidida* mediante julgamento válido e final, e a decisão é *essencial* para o julgamento, a decisão é aplicável ou produz efeitos em uma subsequente ação entre as partes, seja a ação baseada na mesma ou em diferente “*claim*”.

306

Erisco Industries, Inc. v. W.C.A.B. (Luvine), Commonwealth Court of Pennsylvania, 2008.

307

Aetna Cas. & Sur. Co. v. Jones, Supreme Court of Connecticut, 220 Conn. 285, 1991.

308

David Shapiro, *Preclusion in civil actions*, p. 58.

309

“If nature of prior hearing carries procedural limitations that would not be present at later hearing, party might not have full and fair opportunity to litigate, and invocation of collateral estoppel would not be appropriate”. (Aetna Cas. & Sur. Co. v. Jones, Supreme Court of Connecticut, 220 Conn. 285, 1991).

310

“The doctrine of collateral estoppel only requires that a party be given a full and fair chance to litigate the issue. *The fact that more conclusive evidence might be presented at a subsequent hearing is neither sufficient nor relevant grounds for disallowing the application of the doctrine in this Commonwealth*” (Dep’t of Transp. v. Martinelli, Commonwealth Court of Pennsylvania, 1989).

311

Maurice Rosenberg, *St. John’s Law Review*, 1969, v. 44, p. 165 e ss; Developments in the Law-Res Judicata, *Harvard Law Review*, 1952, v. 65, p. 818 e ss.; Note, Collateral estoppel by judgment, *Columbia Law Review*, 1952, v. 52, p. 647 e ss.; Collateral estoppel in default judgments: The case for abolition, *Columbia Law Review*, 1970, v. 70, p. 522: “It is the position of this Note that the doctrine of collateral estoppel can only

do harm when applied to default judgments and that its application to those cases should therefore be abolished”.

312

Buck v. Mueller, 221 Ore. 271, 1960; Messerlian v. Goodness, 75 R.I. 203, 1949; Lawhorn v. Wellford, 179 Tenn. 625, 1943.

313

A respeito do direito inglês, Neil Andrews, *English civil procedure*, Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 948-949; Luca Passanante, Processo civile inglese, *Enciclopedia del Diritto*, Annali III, p. 1001-1003.

314

Collateral estoppel in default judgments: The case for abolition, *Columbia Law Review*, 1970, v. 70, p. 522.

315

João de Castro Mendes (*Limites objetivos do caso julgado em processo civil*, Lisboa: Edições Ática, 1968, p. 111), após afirmar que o processo “não pode ser uma surpresa para o autor, surpresa que pode inclusivamente referir-se – e até em termos desfavoráveis – a interesses que o autor entendeu não pôr em jogo ou preferiu deixar fora da apreciação judicial e do risco processual que tal apreciação sempre envolve”, advertiu que, segundo Blomeyer, tal teria sido o argumento decisivo para o legislador da *Zivilprozessordnung* optar pela limitação da coisa julgada ao pedido.

316

Na verdade, o princípio da declaratória incidental surgiu no direito francês, ao redor dois valores da revolução francesa, e depois foi desenvolvido pela doutrina alemã, dando origem ao § 280 da ZPO de 1877. Ver Franz Wieacker, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit*, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1967, p. 277 e ss.

317

Chiovenda assim completa o seu argumento: “secondo le premesse nostre, richiamate anche nel principio di questo paragrafo, la cosa giudicata è la indiscutibilità del provvedimento preso dal giudice sulla domanda accogliendola o respingendola: la risoluzione delle questioni è semplice mezzo a tal fine” (Giuseppe Chiovenda, *Istituzioni di diritto processuale*, v. 1, Napoli: Jovene, 1933, p. 363). Ver Giuseppe Chiovenda, Sulla cosa giudicata, *Saggi di diritto processuale civile*, v. 2, Milano: Giuffrè, 1993; Giuseppe Chiovenda, Cosa giudicata e preclusione, *Saggi di diritto processuale civile*, v. 3, Milano: Giuffrè, 1993.

318

Giuseppe Chiovenda, *Istituzioni di diritto processuale*, v. 1, p. 362-363.

319

Elizabeth Thornburg, ao evidenciar os limites da convenção processual perante as Cortes estatais, alerta para as suas específicas funções, demonstrando que estas não se confundem com a função dos tribunais arbitrais: “... the courts react to litigants who have requested their help by processing the claims and defenses, assisting in settling the controversy, and making available a mechanism to resolve the dispute and enforce the result if agreement is not forthcoming. (...) *The courts second role is to produce public goods and serve public functions. For example, courts create precedents and legal rules. The public processes of courts provide an opportunity for public debate about and the development of social norms*” (Elizabeth Thornburg, Designer Trials, *Journal of Dispute Resolution*, 2006, n. 1, p. 206-207).

320

Giovanni Tarello, *L'interpretazione della legge*, Milano: Giuffrè, 1980, p. 61-64; Riccardo Guastini, *Interpretare e argomentare*, Milano: Giuffrè, 2011, p. 63-66; Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Bologna: Il Mulino, 2007, p. 61; Giuseppe Zaccaria, Complessità della ragione giuridica, *Questioni di interpretazione*, Padova: Cedam, 1996, p. 3-20; Jerzy Wróblewski, Legal syllogism and rationality of judicial decision, *Rechtstheorie*. Berlin: Duncker & Humblot, 1974. v. 5, parte 1, p. 39.

321

Frank Michelman, Constitutional authorship, *Constitutionalism: philosophical foundations*, New York: Cambridge University Press, 1998, p. 88-89; Jerzy Wróblewski, *Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*, Madrid, Civitas, 2001, p. 55 e ss.

322

Luiz Guilherme Marinoni, *O STJ enquanto Corte de Precedentes*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2017, p. 91-107; p. 149-152.

323

Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas*, 3.ed., São Paulo: Ed. RT, 2018.

324

Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes Obrigatórios*, 5. ed., São Paulo: Ed. RT, 2017, p. 96 e ss.; Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes obrigatórios*, Lima: Palestra, 2013, p. 123 e ss.

325

“Num estado moderno, com muitos juízes e muitas Cortes e uma hierarquia estruturada de recursos, as mesmas regras e soluções devem orientar a decisão independente do juiz do caso” (Neil MacCormick, *Rethoric and the rule of law – A theory of legal reasoning*, p. 178). Earl Maltz, em ensaio publicado na *North Carolina Law Review*, afirma que um dos valores mais importante do sistema americano é o de que os princípios que orientam a sociedade devem constituir “regras de Direito” e não *simples opiniões de alguns homens que, temporariamente, ocupam relevantes cargos no Poder* (Earl Maltz, *The nature of precedent*, *North Carolina Law Review*, v. 66, 1988, p. 371).

326

“... a stunted flow of information can distort the creation of precedent and impede efforts by regulators, legislators, and other policymakers to identify social problems and devise public solutions” (Kevin E. Davis e Helen Hershkoff, Contracting for Procedure, *William and Mary Law Review*, 2011, p. 544).

327

Luiz Guilherme Marinoni, *O STJ enquanto Corte de Precedentes*, 3. ed., p. 227-230.

328

A segurança jurídica é subprincípio concretizador do princípio fundamental e estruturante do Estado de Direito. Expressa-se em termos de estabilidade e continuidade da ordem jurídica, bem como de previsibilidade acerca das consequências jurídicas das condutas praticadas no convívio social.

329

Massimo Corsale, *Certezza del diritto e crisi di legittimità*, p. 32-33.

330

É lugar comum, na literatura inglesa e estadunidense, a ideia de que a previsibilidade constitui razão para seguir precedentes. Recorde-se que Hale disse que o *stare decisis* tinha como objetivo satisfazer a exigência de certeza formal. No mesmo sentido, Arthur Goodhart (Precedent in English and Continental Law, *Law Quarterly Review*, v. 50, 1934) sustentou que a certeza jurídica seria a mais importante causa para a instituição do *stare decisis* ou para o estabelecimento de um sistema de precedentes obrigatórios. Ver Theodore M. Benditt, The rule of precedent, *Precedent in Law*, Oxford: Clarendon Press, 1987, p. 89 e ss.

331

Massimo Corsale, *Certezza del diritto e crisi di legittimità*, p. 40.

332

Luiz Guilherme Marinoni, *Coisa Julgada sobre Questão*, São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 196-200.

333

Extraí-se da obra de Weber o entendimento de que o *common law* inglês, ainda que não dotado do mesmo grau de racionalidade do direito europeu continental, era previsível. Weber disse, em *Economia e Sociedade*, que “na área do direito privado *common law* e *equity* são em grande parte ‘formalistas’ na aplicação prática, em virtude da vinculação a precedentes”. (Max Weber, *Economia e Sociedade*, Brasília: UnB, vol. 2, p. 150). Portanto, para Weber o *stare decisis* foi um importante elemento de balanceamento da falta de sistematicidade do *common law*, tendo contribuído notavelmente para a previsibilidade e para o desenvolvimento do capitalismo. Ver Luiz Guilherme Marinoni, *A Ética dos Precedentes*, 2. ed., São Paulo,

334

A previsibilidade permite a definição das expectativas do empresário e, assim, colabora para a otimização dos investimentos e para a racionalização dos gastos com estrutura e matéria-prima, viabilizando, ainda, a adequada remuneração dos trabalhadores. Os investimentos, na falta de previsibilidade, são mais onerosos e menos eficientes, o que desestimula o incremento dos negócios.

335

“The cost savings associated with a system of stare decisis extend beyond those incurred in litigation. Increased certainty not only discourages litigation; it also enables more efficient planning in reliance on precedent. Again, compare the effects of the current system of stare decisis, which establishes some barriers to self-reversal by the Supreme Court, to a more freely discretionary regime. The current system reduces the degree of upheaval in the Court’s body of precedent, thus enabling ‘the political branches and the people’ more efficiently to ‘plan against the background of known rules’. A more discretionary system, by comparison, would make planning and reliance more costly and less efficient” (Thomas R. Lee, Stare decisis in economic perspective: an economic analysis of the Supreme Court’s doctrine of precedent, *North Carolina Law Review*, n. 78, 2000, p. 652). Ver Louis Kaplow, An economic analysis of legal transitions, *Harvard Law Review*, n. 99, 1986, p. 509-617.

336

Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes Obrigatórios*, p. 96-125; Daniel Mitidiero, *Precedentes*, 3. ed, São Paulo: Ed. RT, 2018.

337

Gaetano Silvestri, Le Corti Supreme negli ordinamenti costituzionali contemporanei, *Le Corti Supreme*, Milano: Giuffrè, 2001, p. 45.

338

Luiz Guilherme Marinoni, *Coisa Julgada sobre questão*, esp. p. 163-208.

339

Mais amplamente sobre o tema, perante o direito nacional, v. Ivan Ordini Righi, Eficácia probatória do comportamento das partes. *Revista da Faculdade de Direito da UFPR*. Vol. 20, 1981, *passim*; Isolde Favaretto, *Comportamento processual das partes como meio de prova*. Porto Alegre: Livraria Acadêmica, 1993, *passim*.

340

No sistema italiano, por exemplo, tem-se que a revelia do réu é um comportamento neutro, que não é

tomado em seu prejuízo. Implica consequências processuais, mas não é tomada como uma forma de *facta confessio*, de sorte que não libera o autor de demonstrar os fatos em que baseia seu pedido, ainda que concretamente essa contumácia gere vantagem ao autor, na medida em que o réu não participará da instrução (v., entre outros Remo Caponi, Andrea Proto Pisani. *Lineamenti di diritto processuale civile*. Napoli: Jovene, 2001, p. 159).

341

Sobre o tema, v. mais detidamente o vol. VII, destes *Comentários*.

342

Ivan Ordini Righi. Ob. cit., p. 2.

343

V., Humberto Theodoro Jr., *Comentários ao novo Código Civil*. 2. ed. Coord. Sálvio Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: Forense, 2003, vol. III, tomo II, p. 574-578. Na jurisprudência, esse entendimento era cristalizado pela Súmula 301, do STJ, que estabelece que “em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção *juris tantum* de paternidade”.

344

Idem, ibidem, p. 3/4.

345

O exemplo é de Ivan Righi, no texto antes mencionado.

346

V., sobre o assunto, Sérgio Cruz Arenhart, *Perfis da tutela inibitória coletiva*. São Paulo: Ed. RT, 2003, p. 273 e ss. V., tb., *supra*, item 7.

347

V., sobre isso, *supra*, item 6.

348

Ivan Ordini Righi. Ob. cit., p. 6.

349

Idem, ibidem, p. 6-7.

A teoria de Habermas, contudo, não escapou de severas críticas, por parte de MIGUEL REALE. O filósofo brasileiro afirma que “o pensamento de Habermas plana, tudo somado, numa temática teórico-sociológica que, não obstante visar a superar a tensão entre validade e eficácia do Direito, não consegue resolver in concreto como é que as normas, formuladas segundo a razão comunicativa, adquirem o mínimo de certeza e segurança exigido pela ordem jurídica positiva. É mérito de Habermas focalizar o discurso do Direito à luz da tensão validade-eficácia, mas, a meu ver, ele não consegue resolver a questão nuclear da obrigatoriedade do Direito que não pode resultar de mero fluxo do *ius vivens*” (ob. cit., p. 17). E prossegue o ilustre autor, dizendo que “ainda recentemente Jürgen Habermas, no livro já citado, no qual ele afronta a problemática da justiça – questão esta que, desde Kant e Hegel, não pode deixar de ser analisada por um verdadeiro filósofo –, dá ênfase aos problemas da validade e da eficácia, à luz de seu conhecido conceito de ‘razão comunicativa’, devendo a imprecisão de seus conceitos ser atribuída ao fato de não perceber que no conceito genérico de ‘validade’ albergam-se dois conceitos distintos, essenciais ambos à visão do jurista: o da validade do ponto de vista lógico-formal, que se indica com o termo de vigência; e o de validade segundo um ponto de vista axiológico, isto é, em função da ideia de valor (fundamento)” (ob. cit., p. 79).

Comentários ao CPC - v. VI - Marinoni - Ed. 2018

PARTE II

ARTS. 369 A 380. PARTE II

Capítulo XII

Das Provas

Seção I

Disposições gerais

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

1. O problema das provas típicas e atípicas

O art. 369 fala de meios de prova não especificados no Código de Processo Civil. Com isso deixa claro que os meios de prova não precisam estar nesse Código. Podem estar em qualquer lei – e nesse sentido seriam “meios legais” – ou não expressamente previstos em lei alguma – quando seriam meios não tipificados em lei. É o caso, por exemplo, da extração de argumentos de prova do comportamento das partes,¹ ou da prova estatística.²

Os chamados meios “moralmente legítimos”, assim, seriam os meios não expressamente estabelecidos na lei, mas evidentemente legais, no sentido de conformes à lei.

Como é fácil perceber, a redação truncada desse artigo resulta da falsa assimilação de “meios típicos” por “meios legais” ou de ter dado o significado de “meios típicos” à expressão “meios legais”. Os meios de prova, ao menos em princípio, devem estar de acordo com as normas legais, pouco importando se expressamente previstos na lei. Essa última ideia – de expressa previsão legal – obviamente não tem relação com a prova estar de acordo com o direito ou não, mas sim com a sua tipicidade.

Quando o artigo alude a meios moralmente ilegítimos, não está contrapondo o que é legal com o que é moral, mas sim dizendo que esses meios (moralmente legítimos) são meios que, embora permitidos, não estão expressamente tipificados na lei. Tais meios, dessa forma, são as provas atípicas.

Em outros termos, todos os meios de prova – de lado a possibilidade excepcional da admissão de uma prova ilícita, como será visto a seguir – devem estar de acordo com o direito, e nessa perspectiva são meios de prova legais. Esses meios de prova, porém, podem ser típicos ou atípicos, conforme estejam ou não tipificados na lei.

O fato de um meio de prova não estar expresso na lei nada tem a ver com a sua moralidade, pois o que define a possibilidade da utilização de uma prova é a sua conformação com o direito, e apenas nesse aspecto é que se pode aceitar que um meio moralmente ilegítimo seja considerado um meio de prova não conforme ao direito e, assim, ilegal.

Está claro que a preocupação desse artigo, ao aludir a meio moralmente legítimo, está ligada, a um só tempo, à necessidade e à insegurança da prova atípica. Se não há como negar a possibilidade do emprego de meios de prova não tipificados, existe a possibilidade de que a sua

aplicação seja feita de forma abusiva.

Diante disso, a única solução é pensar no controle da utilização da prova atípica. Assim, por exemplo, se o art. 405, § 1.º, do CPC afirma que o incapaz não pode depor como testemunha, não é possível pedir o seu depoimento sob o rótulo de prova atípica. Ou seja, uma prova que não pode ser utilizada como típica, porque na sua formação violou uma norma (ou porque na sua produção vai violá-la), certamente não pode ser admitida como prova atípica, pena de estar servindo para encobrir a desconsideração de uma regra.

Embora o contraditório não precise ser observado na formação da prova atípica, o emprego dessa prova, além de ter que dar à parte atingida ampla oportunidade de impugnar a sua admissão, de participar da sua produção e de se contrapor à sua valoração, deve conferir-lhe a possibilidade de utilizar uma prova típica em relação ao mesmo fato.

A valoração da credibilidade e da eficácia da prova atípica têm particular importância,³ uma vez que o juiz deve considerar esses elementos para decidir (raciocínio decisório) e para justificar racionalmente a sua decisão (raciocínio justificatório), sendo que a explicitação desses elementos na justificativa é fundamental para que as partes possam controlar a tarefa jurisdicional.

2. A separação entre os planos probatório e fático

Mas não basta retirar do art. 369 a distinção entre prova típica e atípica, concluindo que ambas podem ser utilizadas, pois essas provas – de lado casos excepcionais – devem estar de acordo com o direito, pois apenas assim são hábeis para “provar a verdade dos fatos” – como diz o próprio art. 369.

Porém, antes da análise da questão da prova ilícita, é preciso frisar a separação entre os planos probatório e fático. Essa distinção objetiva sublinhar a distinção entre o fato e a prova. Ainda que ela seja evidente, cabe deixar claro que um fato pode ser objeto de duas (ou várias) provas independentes.

Existindo um fato e duas provas, uma pode ser lícita e a outra ilícita. Ainda que ambas as provas tenham o objetivo de elucidar o mesmo fato, uma é totalmente independente da outra, e assim uma delas obviamente pode ser considerada pelo juiz.⁴ Aliás, essa independência também pode ocorrer quando a prova é posterior à ilícita, mas com ela não tem qualquer vínculo.

O fato também tem a sua autonomia realçada quando a segunda prova, embora decorrente da ilícita, dela se desliga juridicamente, como acontece no caso em que a validade da última prova é admitida com base na teoria de que o fato seria inevitavelmente provado ou descoberto, pouco importando, assim, que tenha sido realizada a partir do resultado obtido por meio da prova ilícita. Trata-se da aplicação da teoria americana da “inevitable discovery exception”, introduzida pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1984, quando do julgamento do caso Nix contra Williams.⁵

Ademais, nada impede que o fato constatado por meio de uma prova ilícita seja reconhecido pelo juiz quando admitido ou confessado em juízo, desde que, como é óbvio, essa confissão seja voluntária.

Lembre-se de que, por último, para definitivamente evidenciar a separação das esferas probatória e fática, se a prova ilícita não tem eficácia no processo, o seu resultado pode ser utilizado no plano extraprocessual para impedir a ocorrência de um fato que provavelmente irá acontecer diante daquilo que foi descoberto.

3. A ilicitude da prova diante da existência ou não de processo, da natureza do direito violado e da qualidade do violador

Há doutrina que distingue a prova obtida antes do processo e depois da sua instauração. Trata-se, porém, de uma distinção sem muita razão de ser, pois é evidente que a ilicitude pode ocorrer

antes do início do processo – como acontece, por exemplo, com a gravação clandestina de uma conversa telefônica – ou depois da sua instauração, em violação de direitos processuais ou materiais.

Note-se, aliás, que não há procedência em ligar a violação do direito material ao momento pré-processual. Ora, se uma testemunha é constrangida a depor em determinado sentido, existe violação a um direito fundamental material dentro do processo.

Outros, percebendo essa questão, preferem distinguir a prova obtida com violação do direito material da prova obtida com violação do direito processual. Assim, a prova testemunhal obtida mediante coação não seria confundida com uma prova obtida com violação ao contraditório.

Contudo, é preciso perceber que uma prova pode violar simples regras do procedimento probatório – cuja necessidade de observância não é imprescindível para a proteção das garantias da parte – e direitos fundamentais processuais. Nessa última hipótese, a prova contém vício tão grave quanto a que viola um direito fundamental material, quando a separação da prova segundo a natureza do direito violado perde sentido.

Por fim, não importa quem violou a norma que gerou a ilicitude, se um funcionário público ou um particular. Embora essa questão importe para o processo penal – em que a prova ilícita é geralmente obtida antes do início do processo, em violação a um direito fundamental material e por um agente público –, é evidente que a prova ilegalmente obtida por um particular merece a mesma reprovação.

4. Ilicitude no plano do direito material: i) na obtenção da prova pré-constituída, ii) na obtenção das informações consubstanciadoras da declaração testemunhal, iii) na formação e na produção da prova e iv) na utilização da prova pré-constituída

No plano do direito material, é possível pensar, em primeiro lugar, na obtenção ilegal da prova pré-constituída ou dos conhecimentos necessários para a declaração testemunhal.

Se uma prova foi lícitamente constituída, mas foi posteriormente obtida de modo ilícito – por exemplo, por meio de invasão de domicílio –, o meio de prova, em si mesmo, é lícito, embora a sua obtenção tenha ocorrido mediante violação do direito material.

Situação parecida acontece quando o depoimento testemunhal é prestado a partir de conhecimentos obtidos de modo ilícito. Assim, por exemplo, se a testemunha obteve as informações mediante a espionagem das atividades da parte. No caso, não se pode dizer que a prova foi obtida de modo ilícito, mas sim que as informações reveladas através da prova foram obtidas de forma ilícita.

Além disso, não há como esquecer de separar as hipóteses em que a ilicitude está na formação da prova daquelas em que a ilicitude está na sua produção. Exemplos do primeiro caso acontecem quando alguém é coagido a fazer uma declaração por escrito, a posar para uma fotografia ou a prestar um depoimento gravado. Mas, quando a testemunha é coagida a depor (no processo), a ilicitude está na produção da prova.

Note-se, porém, que quando é feita a gravação clandestina de uma conversa telefônica o depoente não é forçado a falar, embora a prova seja obtida de forma ilícita, mediante invasão da intimidade.

Além dos casos de formação, produção e obtenção de provas de modo ilícito, há situações em que a ilicitude decorre do uso de um documento como prova, assim como acontece com a utilização de um diário íntimo no processo. Trata-se de situação em que a ilicitude está na exposição do conteúdo do documento.⁶

5. Ilicitude no plano do direito processual: i) na admissão da prova e ii) na produção da prova

Há regras processuais que regulam a fase de admissão da prova. Assim, por exemplo, a admissão da prova deve considerar o momento do seu requerimento. Porém, também não podem ser admitidas as provas documentais obtidas ou formadas com violação do direito material e os documentos que se tornam ilícitos quando utilizados no processo.

No que diz respeito à testemunha coagida e à testemunha que se vale de conhecimentos obtidos de modo ilícito, a violação ocorre no momento da produção da prova. No primeiro caso, a coação é contemporânea à produção da prova; no segundo, embora a violação da intimidade para a obtenção das informações seja anterior, a ilicitude da prova se dá no exato momento em que a testemunha presta o seu depoimento, isto é, em que a prova testemunhal é produzida. Isso evidencia claramente que a ilicitude na produção da prova pode decorrer de violação do direito material.

Porém, a ilicitude da produção (não da formação) da prova deriva, em regra, de violação do direito processual. Assim, por exemplo, quando se violou o contraditório na produção da prova testemunhal ou não se permitiu às partes acompanhar o trabalho do perito, por não terem tido ciência da data e do local em que a prova pericial teve início, conforme exige o art. 474 do CPC. Nesses casos, não há como negar que a produção da prova foi conduzida de modo ilícito, ou que houve ilicitude na produção da prova. Mas essa ilicitude está no plano do direito processual.

Note-se, em resumo, que a admissibilidade e a produção da prova têm relação com os planos dos direitos material e processual. Uma prova pode ser indevidamente – ilicitamente – admitida no processo – em violação ao direito processual –, e uma prova ilícita no plano do direito material pode ser indevidamente – e mais uma vez ilicitamente – admitida no processo. De outra parte, uma prova pode ser produzida mediante violação ao direito material ou em desrespeito ao direito processual.

6. A gravidade da violação

Diante do que acaba de se expor deve ter restado a ideia de que a violação de um direito material (direito à intimidade) é mais grave que a violação de uma regra processual.

Em determinada linha, a prova ilícita pode ser vista como algo que não existiria se não fosse a violação do direito material. Assim a prova obtida mediante invasão de domicílio, de violação de correspondência ou de gravação clandestina de conversa telefônica. Sem esses atos não haveria como falar em ilicitude.

Note-se que há provas que são dependentes do ilícito e provas em cujo procedimento houve uma ilicitude. Em alguns casos a prova existe porque o ilícito foi praticado e, em outros, a existência da prova não é consequência da ilicitude. Ou seja, a prova obtida mediante gravação clandestina ou coação, por exemplo, resulta de um ilícito; mas a prova em cujo procedimento foi violada uma regra processual – ou o contraditório – não constitui o resultado dessa violação. Nesse sentido, seria possível concluir que a prova que resulta da ilicitude é mais grave do que a prova em cujo procedimento o ilícito foi praticado, pois no primeiro caso ela é irremediavelmente ilícita.⁷

Acontece que não é apenas a relação da prova com a ilicitude que importa – se direta ou não. Ainda que a prova não constitua o resultado direto da ilicitude, ela varia conforme a qualidade da norma violada. A violação de uma norma processual pode ser graduada, partindo de uma simples irregularidade para chegar a uma lesão a um direito fundamental processual.

Se determinadas regras processuais infraconstitucionais têm a função de regulamentar um direito fundamental e outras podem simplesmente reproduzir os termos das normas constitucionais, há regras processuais infraconstitucionais que não são imprescindíveis à efetividade de um direito fundamental processual.

Assim, quando a prova é o resultado de um procedimento em que foi cometido um ilícito (e não o resultado direto da ilicitude), é preciso atribuir-lhe significado, uma vez que a prova e o ilícito,

no caso, podem se separar. A repercussão do ilícito sobre a prova poderá ser maior ou menor conforme a indispensabilidade da regra violada para a proteção dos direitos fundamentais processuais.

No caso em que a regra infraconstitucional violada repete os dizeres da norma constitucional, não há dúvida a respeito da violação do direito fundamental processual. Fora daí, para se definir a importância da norma infringida, é preciso indagar sobre a sua essencialidade para a efetividade do direito fundamental processual.

Essa constatação, apesar de simples, revela que uma prova que resulta de um procedimento em que foi cometido um ilícito não é necessariamente ineficaz. A valoração da sua eficácia depende da maior ou da menor essencialidade da norma processual violada, não constituindo uma consequência automática do ilícito.

Não é correto pensar, contudo, que isso resulta da já conhecida ideia de que as provas devem ser diferenciadas conforme tenham origem na violação do direito material ou na violação do direito processual. Uma prova que viola diretamente um direito fundamental processual, ou uma regra que repete os seus dizeres, obviamente não confere ao juiz o poder de valorar a sua eficácia. Como é evidente, a prova obtida ao final do procedimento que violou o princípio da publicidade – obviamente, quando a intimidade ou o interesse social não o exigirem (art. 5.º, LX, CF) – não merece menor rigor do que a prova que é resultado da violação do direito à intimidade.

O fato de a violação do direito material implicar em sanção no plano do direito material, e não unicamente no processo, não tem qualquer relevância no presente caso. Ora, o problema, nesse momento, não é o de determinar o que acontece no plano do direito material – do direito penal etc. –, mas sim o de precisar a repercussão da ilicitude no processo civil, pouco importando se essa ilicitude provém do direito material ou diz respeito à violação de uma norma de natureza processual.

7. A prova obtida com violação de regra processual que não implica lesão a direito fundamental. Consequências

No caso de violação de direito material, de direito fundamental processual ou de uma regra processual imprescindível à sua observância, a prova é ineficaz no processo civil.

A prova não pode ser sanada quando a ilicitude é a sua causa. A prova somente pode ser sanada quando constitui o ponto final de um procedimento em que houve uma ilicitude. Nessa linha, é possível dizer que a prova que resulta da violação de um direito material não pode ser sanada, não acontecendo o mesmo com a prova em cujo procedimento ocorreu um ilícito.

Porém, isso não significa que todas as provas que não constituem resultados de ilícitos sejam sanáveis. A prova produzida com violação do direito processual – ou melhor, que não constitui o resultado do ilícito, mas sim o resultado do procedimento em que ocorreu um ilícito – pode ser sanada somente nas hipóteses em que a regra violada não é essencial à proteção de um direito fundamental processual – assim como os direitos ao contraditório e à defesa.

Nesses casos, tendo em vista que a violação da regra processual pode permitir a salvação do resultado do procedimento probatório – isto é, da prova –, nada impede que ele seja recuperado mediante a observância do requisito legal ignorado.

Ademais, quando se considera a prova obtida com violação de regra não essencial, não há razão para se retirar qualquer eficácia ao seu resultado. Ao contrário, na hipótese de violação de direito fundamental, seja material ou processual, a prova não pode gerar consequência alguma no processo.

Ou seja, a descoberta que se obteve com a prova somente pode ter influência no processo quando o ilícito não é a sua causa (hipótese de violação do direito material) e não violou um direito fundamental processual no procedimento que nela resultou. Se a prova deriva do ilícito ou

a sua obtenção implicou na violação de um direito fundamental processual, a sua descoberta deve ser considerada um “nada”, sem qualquer possibilidade de influir sobre o convencimento do juiz.

No caso em que não foi violada regra processual essencial, a prova, ainda que não sanada, pode ter repercussão no processo, embora não possa ser valorada como uma prova. Nessa específica situação, a descoberta trazida pela prova pode ser considerada livremente pelo juiz, podendo ele conjugá-la com outras provas lícitas para analisar os fatos apresentados ao seu julgamento.

Para tanto, o juiz deverá expor e explicar, na motivação, porque a violação da regra processual não desacreditou a descoberta na sua totalidade. Após, terá que relacionar essa descoberta, relativa à prova maculada, com aquilo que foi evidenciado por meio das provas lícitas, argumentando, de modo racional, a vinculação entre a descoberta obtida por meio da prova ilícita e as provas lícitas.

8. A norma constitucional que proíbe as provas “obtidas por meios ilícitos”

O art. 5.º, LVI, da CF afirma que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”. Esse artigo se refere às provas obtidas mediante a violação do direito material, pois é óbvio que as provas não devem violar os direitos processuais.

Tais provas, em regra, violam direitos fundamentais materiais, como os direitos à inviolabilidade da intimidade, da imagem, do domicílio e da correspondência etc. (art. 5.º, X, XI e XII, CF).

A prova que resulta da violação do direito material não pode ser sanada e produzir qualquer efeito no processo. Nesses casos, como já dito, nada se pode aproveitar da prova, uma vez que o ilícito é a sua causa.⁸

Porém, se foi obtida uma prova mediante a violação da comunicação telefônica (por exemplo),⁹ nada impede que uma nova prova venha a recair sobre o fato que a prova ilícita tentou esclarecer, desde que essa nova prova receba a devida autorização judicial (art. 5.º, XII, CF). Nessa hipótese, como é óbvio, não há como pensar que a prova foi sanada. O que ocorreu foi a realização de uma nova prova de forma lícita.

9. Fundamento e significado do art. 5.º, LVI, da CF

A razão de ser da proibição inserida no art. 5.º, LVI, da CF está na insuficiência de sancionar a prova ilícita apenas no plano do direito material. Para uma maior proteção dos direitos é preciso negar eficácia a tais provas no processo.

Essa constatação, embora simples, é extremamente importante para a compreensão do tema das provas ilícitas. O art. 5.º, LVI, da CF não vedou a violação do direito material para a obtenção de prova – pois isso está proibido por outras normas –, mas proibiu que tais provas tenham eficácia no processo.

Por outro lado, não é correto imaginar que a proibição da prova ilícita surgiu da necessidade de se garantir a descoberta da verdade no processo, pois não se pode ignorar que alguém pode se ver tentado a obter uma prova de forma ilícita justamente para demonstrar a verdade. Na realidade, se tais provas não implicassem na violação de direitos, a busca da verdade deveria impor a sua utilização no processo.

O art. 5.º, LVI, da CF não nega o direito à prova, mas apenas limita a busca da verdade, que deixa de ser possível por meio de provas obtidas de forma ilícita. O interesse do encontro da verdade cede diante das exigências superiores de efetiva tutela dos direitos.

Como é fácil perceber, dita limitação não encontra fundamento no processo, mas sim na

efetividade da proteção do direito material. Ou seja, tal norma constitucional proibiu a prova ilícita para dar maior tutela ao direito material, negando a possibilidade de se alcançar a verdade a qualquer custo.

Diante disso, é inegável que houve uma opção pelo direito material em detrimento do direito à descoberta da verdade. A questão, porém, é saber se essa opção exclui uma posterior ponderação – agora pelo juiz – entre o direito que se pretende fazer por meio da prova ilícita e o direito material violado.

Frise-se que tal norma apenas afirmou que, em princípio e como valor abstrato, a proteção do direito material deve se colocar acima da busca da verdade. Mas não considerou – e nem poderia – o fato de que essa relação ocorre em processos de diversas espécies – penal, civil, trabalhista – e diante de diferentes valores e direitos.

10. A opção do processo penal e a ausência de opção no âmbito do processo civil

A influência do processo penal sobre a ideia de proibição de prova ilícita é muito grande. Como nesse setor a obtenção da prova é deferida à polícia em uma fase anterior ao processo, é visível a necessidade de se colocar freios na atividade policial com o objetivo de impedir a obtenção de provas mediante a violação de direitos fundamentais materiais.¹⁰ Para dissuadir o agente público de obter prova em desrespeito aos direitos, nada mais eficaz do que proibir a sua utilização no processo.

Nessa situação há um processo em que se enfrentam o Estado – titular da pretensão punitiva – e o particular – titular do direito de liberdade. Nesse caso, porém, há nítida preferência pelo direito de liberdade, que se coloca, em uma escala hierárquica, em posição de supremacia em relação à pretensão punitiva estatal.

A diferença entre os processos penal e civil se torna nítida quando se constata, por exemplo, que as partes têm o dever de dizer a verdade no processo civil, enquanto que o réu, no processo penal, deve ser informado do seu direito de permanecer calado.¹¹ Como se vê, a busca da verdade é tratada de modo totalmente diverso em tais processos. De acordo com a Constituição Federal, o preso deverá ser informado “de seus direitos, entre os quais o de ficar calado”. Não se trata apenas de um direito de calar, mas sim de um direito de ser informado da possibilidade de calar. Caso essa informação não ocorra, a prova obtida por meio da declaração é ilícita. Além do mais, não se pode esquecer que o processo penal é marcado pela chamada presunção de inocência ou pela proibição de o juiz condenar o réu quando não está convencido da verdade – o que, como visto quando se tratou da formação da convicção judicial, não ocorre no processo civil.

Essa diferença reflete a distinção entre os bens próprios a cada um desses processos. Enquanto no processo penal o direito de permanecer calado e a presunção de inocência derivam da proeminência do direito de liberdade, no processo civil – não havendo como definir, em abstrato, o bem de maior relevo – ambas as partes têm o dever de dizer a verdade e, em alguns casos, o juiz pode dar tutela ao direito do autor com base em convicção de verossimilhança.

As diferentes realidades situadas em cada um desses processos não podem deixar de ser levadas em consideração quando se pensa na prova obtida de modo ilícito. Ao se tentar uniformizar a maneira de compreender o processo penal e o processo civil, é possível cair no engano de pensar a prova ilícita como algo que não tem qualquer relação com as diversas situações postas nesses diferentes processos.

Contudo, como já demonstrado, o processo penal dá maior relevo ao direito de liberdade, ao passo que o processo civil não faz opção por nenhum dos direitos que podem colidir (pois ela não pode ser feita em abstrato), deixando essa opção para o juiz diante do caso concreto. Isso quer dizer que a norma do art. 5.º, LVI, da CF pode ser conjugada com a opção do processo penal, mas, quando pensada em face do processo civil, apenas pode se ligar a uma falta de opção, ou melhor, à necessidade de que essa opção seja feita diante do caso concreto.

11. A proibição da prova ilícita no processo civil e a regra da proporcionalidade

Alguém poderia dizer que a norma que proíbe a prova ilícita, por instituir um direito fundamental que não possui restrição expressamente autorizada, não poderia sofrer qualquer limitação.¹² Contudo, um direito fundamental não dotado de expressa previsão de restrição não indica uma posição definitiva acerca da sua limitabilidade.¹³

A dificuldade da questão das restrições não expressamente autorizadas aos direitos fundamentais se liga ao problema de resolução das colisões entre os direitos fundamentais e outros bens dignos de proteção. Daí a importância da regra da proporcionalidade ou de um método de ponderação de bens no caso concreto.

Cabe lembrar que quase todos os países que acolheram a proibição da prova ilícita foram obrigados a admitir exceções a fim de preservarem determinados bens e valores dignos de proteção.¹⁴ Como base na regra da proporcionalidade, os tribunais americanos e alemães admitem exceções à proibição das provas ilícitas quando necessário à realização de exigências superiores de natureza pública ou privada, argumentando que a proporcionalidade é essencial para a “justiça no caso concreto”.¹⁵

A regra da proporcionalidade é pacificamente admitida no direito brasileiro,¹⁶ embora muitas vezes tenha a sua aplicação impugnada diante da norma constitucional que proíbe as provas ilícitas. O argumento é o de que a Constituição Federal já fez a ponderação entre a preservação do direito material e o direito à descoberta da verdade. Afirma Luis Roberto Barroso, por exemplo, que a “Constituição brasileira, por disposição expressa, retirou a matéria da discricionariedade do julgador e vedou a possibilidade de ponderação de bens e valores em jogo. Elegeu ela própria o valor mais elevado: a segurança das relações sociais pela proscrição da prova ilícita”.¹⁷

Ora, ninguém pretende negar que o art. 5.º, LVI, da CF realizou uma ponderação entre a efetividade da proteção do direito material e o direito à descoberta da verdade. Porém, tratando-se de processo civil, é incontestável a necessidade de uma segunda ponderação, a ser feita pelo juiz diante do caso concreto. Por meio dessa ponderação, o juiz, mediante a aplicação da regra da proporcionalidade, poderá admitir eficácia à prova ilícita.

Como se vê, é necessária a percepção de que a eleição de um valor, pela norma, não exclui a possibilidade da realização de outra ponderação, a ser feita pelo juiz diante do caso concreto. A resposta a essa nossa argumentação seria no sentido de que a norma constitucional, ao proibir a prova ilícita, não fez restrição a qualquer espécie de processo e, assim, considerou também o processo civil. Essa objeção não impressiona, pois a proibição da prova ilícita não exclui – nem poderia – a radical diferença entre os bens que compõem os diferentes processos. Por isso, a norma que proíbe a prova ilícita, ainda que tenha feito uma ponderação – como fazem, aliás, várias outras normas que consagram direitos fundamentais –, não se libertou da sua reserva imanente de ponderação com outros bens e direitos.

Perceba-se que essa questão se liga à distinção entre princípios e regras, no sentido da doutrina de Alexy. A pergunta que interessa, diante disso, é se a norma constitucional que proíbe a prova ilícita constitui uma regra – que então deve ser aplicada segundo a lógica do “tudo ou nada”¹⁸ – ou um princípio – que abre oportunidade para a ponderação dos direitos no caso concreto.¹⁹

A distinção proposta por Alexy, apesar de importante, traz uma enorme dificuldade em face de casos como o da proibição da prova ilícita. Isso porque uma norma como a relativa à prova ilícita não pode ser qualificada apenas como regra ou como princípio (no sentido excludente), mas sim como uma norma que em certos casos pode se comportar como regra e em outros como princípio.

Assim, no presente caso, pouco importa atinar para as consequências de se ter uma norma como regra ou como princípio, mas sim buscar um critério capaz de identificar uma e outro (a regra e o princípio). É correto afirmar que a norma que se aplica por subsunção é uma regra e a norma que se aplica por ponderação é um princípio. Porém, a subsunção somente é viável quando o legislador ponderou tudo o que havia a ponderar, pois se algo não foi ponderado a aplicação da

norma resta na dependência da ponderação do juiz.

Ou seja, quando uma norma, diante de uma situação, não deixou nada para ser ponderado pelo juiz, há uma regra; caso contrário, quando algo ainda deve ser ponderado, existe um princípio. Note-se, contudo, que a mutação da forma da norma, de regra para princípio, está indissociavelmente ligada ao caso concreto. Se determinado caso concreto não exige ponderação alguma do juiz, outro pode depender da sua ponderação.

Portanto, importa definir se a norma que proibiu a prova ilícita ponderou tudo o que havia a ponderar, fechando as portas para qualquer ponderação por parte do juiz, ou se ainda está aberta para certos casos concretos, quando então deve ser aplicada mediante ponderação. A solução dessa questão não é difícil. A conclusão de que a norma eliminou a necessidade de qualquer outra ponderação somente poderia ser aceita se a sua incidência se desse em casos uniformes, que não guardassem qualquer diferença de fundo, e por isso dispensassem o juiz de qualquer outra ponderação.

Mas a única ponderação feita pela norma constitucional alcançou o direito à descoberta da verdade e a proteção do direito material contra a prova ilícita. Isso quer dizer, simplesmente, que há uma regra, válida para o processo penal e para o processo civil, que proíbe o uso da prova ilícita para viabilizar a descoberta da verdade.

Como a descoberta da verdade, no processo penal, está umbilicalmente ligada à atividade estatal, tal ponderação também atingiu a pretensão punitiva do Estado, proibindo-o de se valer de uma prova ilícita para obter a condenação de um criminoso. Vale dizer: a ponderação da norma diante do processo penal, além de incidir sobre a busca da verdade, atingiu a pretensão punitiva estatal, que é valor que cede em face do direito de liberdade, inclusive conforme normas constitucionais instituidoras de outros direitos fundamentais.

Contudo, no processo civil a realidade é totalmente diversa, pois o autor pode afirmar desde simples créditos pecuniários, passando por direitos não suscetíveis de transformação em dinheiro e direitos não-patrimoniais, até direitos absolutamente fundamentais para a dignidade humana. No processo civil, portanto, não basta a ponderação em torno do direito à descoberta da verdade e o direito material invadido pela prova ilícita, nem há como pensar que os vários direitos que podem ser afirmados pelo autor não merecem prevalência sobre os direitos que podem ser defendidos pelo réu.

Ainda que no processo civil a descoberta da verdade não seja justificativa da prova ilícita – diante da própria norma constitucional –, nele não se exclui a possibilidade de ponderação entre o direito afirmado pelo autor e o direito violado pela prova ilícita. Note-se que a ponderação não é entre a descoberta da verdade e o direito violado pela prova, mas sim entre o direito material que se deseja tutelar na forma jurisdicional e o direito material violado pela prova ilícita.²⁰

Para evidenciar que, em alguns casos, é necessária uma segunda ponderação, basta pensar na situação em que um particular é obrigado a obter uma prova ilícita – diante da inexistência de qualquer outra prova – para proteger um direito fundamental. Ou na hipótese em que uma associação de proteção ao meio ambiente não tem outra alternativa para proteger o direito ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de recurso ordinário em mandado de segurança, através do qual se postulou o desentranhamento de decodificação de fita magnética proveniente de escuta telefônica dos autos de processo criminal em que a impetrante havia sido denunciada por tóxico, assim decidiu: “Mandado de segurança. Escuta telefônica. Gravação feita por marido traído. Desentranhamento da prova requerido pela esposa: viabilidade, uma vez que se trata de prova ilegalmente obtida, com violação da intimidade individual. Recurso ordinário provido. I – A impetrante/recorrente tinha marido, duas filhas menores e um amante médico. Quando o esposo viajava, para facilitar seu relacionamento espúrio, ela ministrava ‘Lexotan’ às meninas. O marido, já suspeito, gravou a conversa telefônica entre sua mulher e o amante. A esposa foi penalmente denunciada (tóxico). Ajuizou, então, ação de mandado de segurança, instando no

desentranhamento da decodificação da fita magnética. II – Embora esta Turma já se tenha manifestado pela relatividade do inciso XII (última parte) do art. 5.º da CF (HC 3.982/RJ, rel. Min. Adhemar Maciel, DJU 26.02.1996), no caso concreto o marido não poderia ter gravado a conversa ao arrepio de seu cônjuge. Ainda que impulsionado por motivo relevante, acabou por violar a intimidade individual de sua esposa, direito garantido constitucionalmente (art. 5.º, X)”²¹.

A relevância desse julgado está em permitir a análise de diversas situações relacionadas com a prova ilícita. No caso, a prova ilícita pode ser i) ligada à pretensão punitiva do Estado posta na ação penal por uso de tóxicos, ii) vinculada ao direito do marido à desconstituição do casamento, e, por fim, iii) analisada em relação à proteção das menores que vinham sendo intoxicadas pela própria mãe através do remédio “Lexotan”.

Se aceitarmos a tese de que a norma que proíbe a prova ilícita já ponderou tudo o que havia a ponderar, estaremos, forçosamente, impedidos de considerar as hipóteses referidas de maneira distinta. Porém, se imaginarmos essa prova diante de uma ação de alteração da guarda dos filhos, seria pouco mais do que perverso negar a sua eficácia para a proteção dos menores. Ora, o Estado, além de ter que se preocupar com os direitos fundamentais que a prova ilícita pode violar, não pode esquecer da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais que dependem, para a sua tutela, da prova ilícita.

Porém, o que mais importa é sublinhar que a norma constitucional apenas ponderou o direito à descoberta da verdade e a efetividade do direito material violado pela prova. Se o direito à descoberta da verdade está intimamente vinculado à pretensão punitiva estatal, deixando claro que a Constituição preferiu evitar que a atividade estatal fosse exercida de modo abusivo, ainda que alguns criminosos pudessem não ser condenados, não há dúvida que também ocorreu, diante do processo penal, uma segunda ponderação, preferindo-se o direito de liberdade em face do poder de punir do Estado.

Mas, no processo civil, por serem diversificados os bens que podem ser reivindicados pelo autor e variadas as situações litigiosas que podem ocorrer, não há como pensar em uma segunda ponderação normativa. Aliás, ainda que se pensasse em dois bens peculiares aos litígios civis, a ponderação que a lei poderia fazer seria, na realidade, uma hierarquização, pois somente podem ser objeto de ponderação normativa os bens que podem ser hierarquizados e, assim, considerados valorativamente em abstrato. Ou seja, os bens que não podem ser colocados em uma escala hierárquica, porque apresentam maior ou menor valor conforme as circunstâncias do caso concreto, sempre estão sujeitos a colidir e, assim, jamais poderão se livrar da regra da proporcionalidade, única alternativa para se solucionar o conflito entre dois bens igualmente dignos de tutela.

Especificamente em relação à prova ilícita no processo civil, como já demonstrado, o conflito pode se dar entre o direito fundamental material que se deseja ver tutelado por meio do processo e o direito fundamental material violado pela prova ilícita. Trata-se de colisão entre dois direitos fundamentais igualmente dignos de tutela, que não foram, nem poderiam ser, objeto de prévia ponderação normativa ou de hierarquização. Dizer que a descoberta da verdade não pode ocorrer por meio de prova ilícita não é o mesmo que afirmar que um direito fundamental material não pode ser através dela demonstrado. O uso da prova ilícita poderá ser admitido, segundo a lógica da regra da proporcionalidade e como acontece quando há colisão entre princípios, conforme as circunstâncias do caso concreto.

Quando se pensa na regra da proporcionalidade nesses casos, há sempre que se considerar o valor do bem jurídico que se busca proteger por meio da prova ilícita. Após, verificar se havia outra prova, além da obtida de forma ilícita, capaz de demonstrar as alegações em juízo. E, por último, analisar de que modo a prova ilícita determinou a violação do direito e, especialmente, se existe a possibilidade de limitação ao direito violado quando observados determinados requisitos legais, uma vez que a violação de um direito que sequer admite restrição legal é mais grave que a violação de um direito que pode ser objeto de restrição. Assim, há distinção entre a obtenção de um testemunho mediante tortura e a escuta ilícita de uma conversa telefônica – que pode ser lícitamente gravada com autorização judicial.

12. A contaminação das provas vinculadas fática e juridicamente à ilícita. A teoria dos frutos da árvore envenenada

Pouca coisa diz a afirmação da conhecida teoria dos frutos da árvore envenenada – criada pela Suprema Corte Americana com o título “the fruit of the poisonous tree”²² – quando entendida no sentido de que as provas derivadas da ilícita também devem ser reputadas ilícitas. Ora, isso é óbvio. O problema é saber quando uma prova está ligada a outra de modo a se contaminar por sua ilicitude.

Deixe-se claro, antes de mais nada, que a ilicitude da prova não contamina o fato a ser esclarecido, podendo se ligar, no máximo, a outras provas. Porém, uma prova ilícita não contamina, como é lógico, todo o material probatório, pois nada impede que um fato seja provado por meio de provas lícitas que nada tenham a ver com a prova ilícita.

A prova obtida de modo ilícito pode propiciar uma outra prova, que então estará contaminada, mas nada impede que o fato que se desejou demonstrar seja objeto de uma prova que com ela não tenha qualquer vinculação. Essa última prova não pode ser dita derivada da ilícita ou pensada como contaminada. Tal prova é absolutamente autônoma e independente.²³

Mas é preciso voltar à questão inicial, ou seja, é necessário estabelecer quando uma prova pode ser considerada contaminada pela prova ilícita. É possível tentar esclarecer dizendo que uma prova somente pode ser dita contaminada quando consequência da ilícita e, assim, transferindo-se o problema para outro local, quando então passaria a importar o significado de “prova que é consequência da ilícita”.

Nesse passo, parece prudente seguir os passos da doutrina e da jurisprudência espanhola, que supõe que a solução da problemática está em saber se a prova questionada como derivada teria sido produzida ainda que a prova ilícita não tivesse sido obtida. Galvéz Muñoz, para demonstrar essa questão, alude ao seguinte julgado do Tribunal Supremo Espanhol: “La ineficacia de una diligencia determinada no impide la validez de otra prueba, salvo que ésta guarde una directa relación con aquélla, de tal modo que sin la primera no hubiera existido la segunda”.²⁴

Mas, como reconhece a própria doutrina espanhola, nem sempre é fácil concluir se a segunda prova teria sido produzida na ausência da prova ilícita ou se existe uma conexão causal contaminante entre as duas provas. Sustenta-se, diante disso, que a contaminação da segunda prova, ou a sua admissão como derivada, além de requerer a presença de uma conexão natural, exige uma conexão jurídica: “No basta, pues, con la existencia de un nexo causal natural con una prueba directamente obtenida de forma inconstitucional para excluir determinada prueba sospechosa, sino que es preciso, además, la existencia de un nexo jurídico entre una y otra. Se podría decir, haciendo uso de una fórmula algo manida, pero muy gráfica, que la conexión natural es un requisito necesario, pero no suficiente, para extender el efecto invalidante de la violación de derechos fundamentales y proceder, en consecuencia, a la exclusión procesal de la prueba refleja”.²⁵

Assim, o problema passa a ser o da identificação da conexão de antijuridicidade entre as provas. Para tanto é preciso verificar não apenas se existe algum elemento fático capaz de romper juridicamente a relação de causalidade, mas, sobretudo, analisar se a admissão da segunda prova como ilícita contribui para a defesa dos direitos que se objetiva proteger por meio da proibição da prova ilícita.²⁶

Ou seja, a teoria da contaminação da prova derivada da ilícita, conhecida como teoria dos frutos da árvore envenenada, somente tem sentido quando a eliminação da segunda prova traz efetividade à tutela dos direitos fundamentais. Como explica Gálvez Muñoz, “es preciso demostrar cada vez que se plantee la aplicación de la doctrina de los frutos del árbol envenenado que la misma cumple la finalidad que se persigue con ella, pues en caso contrario nos arriesgaríamos a que la limitación de la verdad procesal y de todos los valores que ésta protege fuera en ocasiones enteramente inútil y desprovista, por tanto, de toda justificación”.²⁷

A questão, então, adquire formato quando se indaga sobre os critérios determinantes da ausência de conexão de antijuridicidade entre a prova ilícita e a prova derivada. Ou seja, não mais importa se há relação natural entre a segunda prova e a prova ilícita, mas sim se a segunda prova pode, pela ruptura do nexo de antijuridicidade, ser considerada juridicamente independente.

É quando importam, além da admissão ou da confissão voluntária sobre o fato objeto da prova ilícita, as chamadas exceções de descobrimento provavelmente independente (hypothetical independent source rule) e de descobrimento inevitável (inevitable discovery exception).²⁸

13. Exceções à teoria dos frutos da árvore envenenada: o “descobrimento inevitável” (inevitable discovery exception) e o “descobrimento provavelmente independente” (hypothetical independent source rule)

Na exceção do descobrimento inevitável se admite que a segunda prova deriva da ilícita, porém se entende que não há razão para reputá-la nula ou ineficaz. Isso porque a descoberta por ela constatada ocorreria mais cedo ou mais tarde. A lógica do salvamento da segunda prova está em que não há motivo para retirar eficácia de uma prova que trouxe uma descoberta que muito provavelmente seria obtida. Dessa forma seria possível dizer que nem todos os frutos da árvore venenosa são proibidos, pois alguns podem ser aproveitados.

Ou seja, embora a segunda prova seja considerada derivada da ilícita, ela produz efeitos no processo. Com isso estaria quebrado o nexo de antijuridicidade entre a prova ilícita e a prova derivada. A ilicitude persiste no plano do direito material, embora a prova derivada possa ser utilizada no processo. Isso porque, embora não se possa deixar de sancionar no plano do direito material aquele que obteve tais provas, não se deve negar eficácia a uma prova da qual decorre uma evidência que seria trazida por outra. Com isso não se isenta de responsabilidade aquele que atua de forma ilícita, mas se evita que a violação da lei possa negar um fato que seria inevitavelmente descoberto.

O juiz, para atribuir eficácia à prova derivada, obviamente deve justificar a sua decisão, expressando as circunstâncias e as regras de experiência que indicam que aquilo que foi alcançado por meio da prova derivada seria naturalmente obtido por meio de uma prova lícita.

Isso pode ocorrer particularmente no âmbito do processo penal. A Suprema Corte Americana, ao que parece, apontou pela primeira vez para essa questão em 1984, quando do julgamento do caso *Nix contra Willians*.²⁹ Nesse caso, a polícia obteve uma confissão mediante violação dos direitos fundamentais, através da qual foi relatado o local em que estava o cadáver da vítima. Acontece que a polícia já presumia que o cadáver poderia estar nesse local, tanto é que aí trabalhavam vários policiais e voluntários. Como o corpo seria encontrado mais cedo ou mais tarde – fosse por meio da atuação dos próprios policiais, fosse em virtude da colaboração de algum voluntário –, entendeu a Suprema Corte que a prova derivada deveria produzir efeitos processuais, uma vez que o cadáver seria naturalmente descoberto independentemente da ilicitude.³⁰

Situação um pouco diferente é a da chamada exceção de descobrimento provavelmente independente.³¹ Na exceção de descobrimento inevitável a segunda prova é aceita como derivada, mas admite-se que ela possa produzir efeitos em razão de que a sua descoberta seria naturalmente trazida por uma outra prova. Quebra-se o nexo de antijuridicidade com base na ideia de que o descobrimento era inevitável. Na exceção de descobrimento provavelmente independente, a segunda prova não é admitida como derivada, mas como uma prova provavelmente independente, e, assim, despida de nexo causal com a prova ilícita.

Para melhor explicar: no caso anterior é quebrada a relação de antijuridicidade, admitindo-se que a prova derivada produza efeitos, enquanto que, na hipótese de descobrimento provavelmente independente, nega-se a própria relação causal, de modo que, nessa situação, não há propriamente exceção à teoria da árvore venenosa, pois a segunda prova é tida como um fruto que com ela não se liga. Ou seja, nesse último caso a dúvida recai sobre a natureza da segunda

prova, se independente ou não, isto é, se despida ou não de relação causal com a prova ilícita, ao passo que no caso da exceção de descobrimento inevitável não se questiona a respeito da relação causal da segunda prova, mas apenas se o conteúdo da prova, apesar de demonstrado por uma prova ligada com a ilícita, seria posto às claras por uma segunda prova.

14. O problema da obtenção de informações de modo ilícito e da prova testemunhal que pode nelas se basear

Não há dúvida de que a prova testemunhal produzida a partir de informações obtidas mediante violação do direito à intimidade é ilícita. A ilicitude está na obtenção das informações e na formação e na produção da prova.

O real problema, nesse caso, é o de saber se o depoimento testemunhal se baseia, ou não, em informações obtidas mediante, por exemplo, violação do domicílio ou gravação clandestina de conversa telefônica.

É claro que, se a testemunha afirmar que o seu depoimento se funda em informações obtidas de forma ilícita, ainda que por um terceiro, o depoimento testemunhal deve ser automaticamente considerado ilícito. Porém, maior dificuldade passa a existir quando, embora existindo a constatação de violação de domicílio ou de gravação ilícita aptas ao fornecimento de informações importantes para a elucidação do litígio, a testemunha afirma que o seu depoimento é baseado em fatos conhecidos de maneira lícita.

Nesse caso, como é óbvio, não há que se pensar em exceção à teoria dos frutos proibidos da árvore venenosa, pois o depoimento testemunhal, quando aceito, é considerado imaculado, ou, para prosseguir com a imagem, colocado em um cesto em que cabem apenas frutos que não provêm da árvore venenosa.

Mas a verificação da proveniência do fruto nada mais é do que a aferição da credibilidade da prova testemunhal. Isto é, o juiz, em um caso em que a fonte do testemunho é colocada em dúvida, deve constatar a origem das informações objeto do depoimento. Isso deve ser feito por ocasião do próprio depoimento testemunhal e, se necessário, inclusive a partir de outras provas e testemunhas, aplicando-se o art. 457, § 1.º, CPC. Além disso, como é natural, o juiz deve expressar, na sua motivação, as razões que o levaram a admitir ou não a prova testemunhal, permitindo, assim, o seu devido controle pelas partes.

Portanto, a situação em que a polícia obtém uma prova a partir de informações ilicitamente obtidas³² deve ser devidamente separada da hipótese em que, no processo civil, informações foram indevidamente recolhidas, mas não se sabe se a testemunha adquiriu conhecimento de forma independente.

15. A teoria da descontaminação do julgado

Essa teoria nada tem a ver com a contaminação da segunda prova pela primeira, mas sim com a descontaminação do julgado, ou melhor, com a decisão de que uma prova, em que o julgado se baseou, era ilícita, e assim deve ser afastada. Essa decisão tem o efeito de descontaminar o julgado.

O problema é saber como realizar tal descontaminação. É certo que se o tribunal, ao reconhecer a ilicitude da prova, deve afastá-la, outro julgamento deverá ser feito pelo juízo de primeiro grau. Mas, se o julgamento voltar a ser feito pelo mesmo juiz que admitiu a prova ilícita, certamente existirá uma grande probabilidade de que o seu convencimento seja por ela influenciado, ainda que inconscientemente.

Não se quer dizer, note-se bem, que o juiz que se baseou na prova ilícita irá buscar uma sentença de procedência a qualquer custo, ainda que inexistam outras provas válidas, mas apenas que a valoração dessas outras provas dificilmente se livrará do conhecimento obtido por meio da prova ilícita.

Trata-se de situação que é peculiar à natureza humana, e assim algo que deve ser identificado para que a descontaminação do julgado seja plena ou para que a sua descontaminação pelo tribunal elimine – ou previna – qualquer possibilidade de infecção posterior. Portanto, se o tribunal decide que uma das provas em que a sentença se baseou é ilícita, o julgamento de primeiro grau deverá ser feito por outro juiz, que não aquele que proferiu a sentença anterior.

A questão que daí advém é relativa ao juiz natural, ou melhor, à forma de definir o juiz que deverá analisar o caso. É preciso frisar o grande perigo de que essa escolha possa ser arbitrária, e, portanto, apontar para a necessidade de se minimizar, na medida do possível, a margem de discricionariedade para a definição do “novo juiz”. Em princípio, esse “novo juiz” deve ser alguém já competente para substituir o juiz afastado.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

1. Poder probatório do juiz

De acordo com o art. 370, e seu parágrafo único, cabe ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento, a produção das provas necessárias à apreciação do mérito, impedindo a realização de diligências inúteis ou protelatórias.³³

Como se vê, o juiz tem o poder – de acordo com o sistema do Código de Processo Civil brasileiro –, quando os fatos ainda não lhe parecerem esclarecidos, de determinar prova de ofício, independentemente de requerimento da parte ou de quem quer que seja que participe do processo, ou ainda quando estes outros sujeitos já não têm mais a oportunidade processual para formular esse requerimento.³⁴ Em verdade, não se trata propriamente de um poder, mas sim de um dever-poder. Na realidade, para a consecução de seu objetivo público, o processo – representado aí pela figura do juiz – tem o dever de se esclarecer da melhor forma possível a respeito do conflito que deve ser examinado, a fim de atuar, também da melhor forma possível, o Direito ao caso concreto. Não se trata, por isso mesmo, de simples poder ou prerrogativa; antes, constitui efetivo dever, imposto por lei, de alinhado à finalidade pública do processo civil.

O juiz tem o dever de esclarecer-se a respeito das alegações de fatos relevantes da causa, aplicando o art. 370, e só após, se ainda remanescer dúvida a respeito desses fatos, julgar com base na regra do ônus da prova. Com efeito, se o juiz tem o dever de esclarecer a situação fática, julgando o mais próximo possível daquilo que realmente ocorreu, não há como se negar a possibilidade dele determinar prova de ofício, para somente após, em caso de insucesso, julgar com apoio na referida regra do ônus da prova.³⁵ Essa solução, muito comum nos tribunais, funda-se na premissa de que o magistrado que determina produção de provas de ofício (logicamente, quando necessário) somente assume a posição que dele é esperada.

Impor ao juiz a condição de mero espectador da contenda judicial, atribuindo-se às partes o exclusivo ônus de produzir prova no processo, é, quando menos, grave petição de princípios. Ora, se o processo existe para a tutela dos direitos, deve-se conceder ao magistrado amplos poderes probatórios para que bem possa cumprir a sua tarefa.

Ademais, é sempre bom lembrar que o juiz que se omite em decretar a produção de uma prova relevante para o processo estará sendo parcial ou mal cumprindo sua função. Já o juiz que determina a realização da prova de ofício, especialmente porque lhe deve importar apenas a descoberta da verdade, e não aquele que resulta vitorioso (o autor ou o réu), estará voltado apenas para a efetividade do processo.³⁶

2. A motivação quando das fases de admissão e de produção da prova

É corrente a ideia de que a prova deve recair sobre os fatos controvertidos, pertinentes e relevantes.

Segundo afirma o art. 374 do CPC, não dependem de prova os fatos: I – notórios; II – afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III – admitidos no processo como incontroversos; e IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. No caso da não incidência de um desses incisos, o juiz deve fixar o fato alegado como controvertido no momento do saneamento, logicamente se ainda houver necessidade de instrução da causa.

Acontece que o fato controvertido deve ser pertinente e relevante. Pertinente à discussão do litígio, ou seja, fato essencial ou fato que grave ao seu redor – e que, assim, possa contribuir para a demonstração do primeiro. Relevante é o fato que, uma vez demonstrado, pode ser útil para convencer o juiz sobre uma hipótese ou para dar credibilidade a uma prova.

É possível, ainda, que um fato relevante já tenha sido objeto de prova, e que essa prova, além disso, não necessite de outra para a confirmação da sua credibilidade, quando existirá um fato relevante e uma prova irrelevante.

A motivação do juiz é imprescindível quando se defere ou indefere uma prova sob o argumento de o fato ser, ou não, controvertido e pertinente, e de o fato ou a prova ser, ou não, relevante.

Além de relevante, a prova, analisada em abstrato, deve ser potencialmente capaz de demonstrar o fato que se deseja elucidar. Por isso, a parte não apenas deve descrever o fato a ser esclarecido, mas também a capacidade e a utilidade da prova diante daquilo a que se propõe. Demais disso, não é possível esquecer que a inadmissão da produção da prova pode se fundar na violação de regras processuais ou mesmo na sua ilicitude material.

Na fase de produção da prova, toda decisão que possa acarretar gravame ao intento da parte de fornecer ao juiz elemento de convicção deve ser adequadamente motivada.³⁷ Não importa se o indeferimento se deu pela razão de o fato ter sido reputado incontroverso, impertinente ou irrelevante, ou se a prova foi considerada irrelevante ou incapaz de demonstrar o fato que se pretendia ver esclarecido, ou ainda se foi violada regra processual que impede a sua produção ou se a prova foi considerada ilícita.

A Constituição Espanhola de 1978 possui, no seu art. 24.2, uma importante regra a respeito do direito à prova. Essa norma, embora aludindo a um direito à prova pertinente,³⁸ além de obviamente descartar a prova sobre fatos incontroversos, impertinentes e irrelevantes, bem como a prova irrelevante e potencialmente inidônea,³⁹ garante, por consequência lógica, o direito à motivação da denegação da produção da prova.

Nesse sentido há um interessante julgado do Tribunal Constitucional Espanhol que, ao aplicar o art. 24.2, assim concluiu: “2. Este Tribunal ha declarado en reiteradas ocasiones que el derecho fundamental a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE) engloba, como una de sus manifestaciones, el derecho a que la prueba pertinente, propuesta en tiempo y forma, sea admitida por los Juzgados y Tribunales ordinarios (SSTC 40/1986 [RTC 1986\40], 196/1988 [RTC 1988\196] y 87/1992 [RTC 1992\87], entre otras), correspondiendo a éstos, con carácter exclusivo, la formalización del juicio de pertinencia entre los medios de prueba propuestos por las partes y el objeto litigioso de que se trate en cada caso (v. gr. SSTC 55/1984 [RTC 1984\55] y 22/1990 [RTC 1990\22]). El hecho, sin embargo, de que la realización de dicho juicio sobre la pertinencia probatoria pertenezca con carácter exclusivo a los órganos judiciales integrantes del Poder Judicial, no implica en modo alguno que tales órganos puedan proceder al rechazo o a la admisión de las pruebas de manera arbitraria. La efectividad del derecho a la prueba consagrado en el art. 24.2 CE, en efecto, requiere insoslayablemente que el pronunciamiento judicial en cuestión aparezca debidamente motivado, de forma que queden exteriorizadas de manera adecuada las razones por las cuales se considera que un determinado medio probatorio resulta impertinente de cara a la resolución judicial de la controversia (v. gr. SSTC 40/1986, 51/1985 [1985\51] y 233/1992 [RTC 1992\233]). El rechazo irregular de la prueba por el órgano jurisdiccional, sin embargo, no determina necesariamente la vulneración del derecho

fundamental en cuestión. Tal y como también ha declarado este Tribunal, la relación de instrumentalidad existente entre el derecho e la prueba y la prohibición de indefensión (SSTC 158/1989 [RTC 1989\158] 205/1991 [RTC 1991\205], 33/1992 [RTC 1992\33] y 87/1992) hace que la constatación de una irregularidad procesal en materia probatoria no sea por sí sola suficiente para que la pretensión de amparo adquiera relevancia constitucional. Pues, para que así ocurra, el defecto procesal ha de tener una incidencia material concreta; por lo que si ésta no se ha producido, tampoco cabe apreciar la existencia de indefensión desde la perspectiva constitucional”.⁴⁰

A sentença do Tribunal Constitucional Espanhol, ainda que evidencie a necessidade da motivação, afirma que a irregularidade no indeferimento da prova, se não tiver “incidência concreta”, não viola o direito de defesa. O Tribunal Constitucional relaciona o direito à prova com o direito de defesa, concluindo que, se a parte que teve denegada a prova não demonstrar o prejuízo concreto sofrido, ainda quando potencial, ou seja, a possibilidade de evidenciar os fatos em seu favor, não há que falar em violação de direito de defesa. A lógica é correta quando se considera que a parte somente tem interesse em uma prova que possa potencialmente lhe garantir a demonstração da sua versão dos fatos.

Acontece que o direito à motivação vai além, pois deve ser considerado o direito de exigir do juiz uma justificação sobre o indeferimento da prova. E essa justificação deve ser dada pelo juiz de primeiro grau, sem que possa ser considerada supérflua pelo órgão ad quem ou mesmo pelo Tribunal Constitucional, sob pena de admitir – na lógica da sentença espanhola – que o dever de motivação pode ser suprido pelo Tribunal Constitucional. Note-se, com efeito, que nesse caso o Tribunal Constitucional não está simplesmente afirmando que o direito de defesa não foi violado, mas sim suprimindo o dever de motivação do juiz de primeiro grau, como se esse dever não fosse pessoal e, assim, pudesse ser transferido e suprido.

Diferente seria a situação se o juiz houvesse motivado a denegação e a parte não tivesse com ela se conformado. Nessa hipótese, a presença de motivação obrigaria a parte a demonstrar que a sua denegação, embora motivada, desconsiderou que a prova, se produzida, teria a potencialidade de alterar a convicção judicial.

3. Inadmissibilidade da prova e recorribilidade

É papel do juiz velar pelo andamento adequado do processo e pela solução da causa em tempo razoável. Por isso, não deve o juiz permitir que sejam realizadas provas desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias.

Por isso, como visto, sempre que algum dos sujeitos do processo requerer providência dessa ordem, cabe ao juiz indeferir sua realização. Obviamente, esse indeferimento deve ser motivado (art. 489, §§ 1.º e 2.º, CPC) e só é cabível em casos em que a produção da prova seja incapaz de contribuir para a adequada solução do litígio.

A discordância do interessado, em regra, não pode mais ser feita por meio de agravo de instrumento. Ainda que em certos casos se deva dar interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, parece que nem todo indeferimento de prova admitirá impugnação por agravo. Assim, tais irresignações, em regra, serão veiculadas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1.º, do CPC.

Excepcionalmente, porém, em se tratando de prova cuja presença ou ausência no processo implique grave prejuízo, é de se admitir o agravo. Assim, por exemplo, a admissão de prova ilícita, a caracterização (ou não) de certa conduta como confissão ou a discussão sobre o custeio de prova técnica devem, naturalmente, admitir impugnação por agravo, ainda que estas hipóteses não estejam contempladas no art. 1.015 do CPC.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

1. Modelo de convicção racional do juiz

O art. 371 do CPC expõe a ideia de que, como regra geral, o processo civil brasileiro adota, como sistema de valoração da prova, o modelo da persuasão racional, também chamado de convicção motivada.

Por esse regime, o juiz não tem sua convicção presa, a priori, a nenhuma valoração imposta por lei. O juiz é livre para formar sua convicção a partir de qualquer das provas dos autos.

Como contrapartida, porém, impõe-se-lhe o dever de motivar especificamente as razões que formaram sua convicção, expondo de forma precisa as razões pelas quais entendeu por dar valor a certas provas (e qual valor dado) e por negar valor a outras.

Põe-se, por isso, ênfase no dever de fundamentação da decisão judicial, já que ela é a única válvula de controle da convicção judicial. A rigor, como pondera Taruffo,⁴¹ dificilmente, para o Direito, tem-se como saber os verdadeiros motivos (íntimos, psicológicos) que levam um magistrado a chegar a certa conclusão. Porém, é necessário que ele consiga, de forma racional, expor motivação suficiente e adequada que apoie essa conclusão. Nesse sentido é que o dever de motivação é essencial.

2. Excepcionalidade de outros modelos de valoração da prova

Embora o art. 371 deixe clara a opção do modelo da convicção racional como regra, a análise sistemática da legislação processual nacional demonstra que há exceções a esse modelo.

Há, por exemplo, casos em que se adota, no sistema nacional, o modelo da prova legal (ou tarifada), em que a própria lei antecipa o valor que certa prova deve gerar ou, ao contrário, exclui a possibilidade de que se possa valorar de certo modo alguma prova. É o que ocorre, por exemplo, com as presunções legais absolutas – em que a prova do fato se torna irrelevante, porque a convicção judicial é predeterminada por regra legal – ou com as proibições de emprego da prova testemunhal (arts. 442, 443 e 444 do CPC).

Muito mais excepcional é a aceitação no direito brasileiro do modelo da livre convicção (não motivada), por meio da qual é dispensada a fundamentação sobre as razões do convencimento. Ainda assim, pode-se indicar como caso em que esse modelo é aceito o do tribunal do júri, no campo do processo penal. No campo processual civil, poder-se-ia dizer que a decisão de suspeição por motivo de foro íntimo implica, dentre outros, um raciocínio probatório que também envolve convicção que dispensa motivação.

Em todo caso, a importância em se determinar o modelo perante o qual se opera está em avaliar a extensão e o grau de exigência de motivação que se pode impor à autoridade judiciária ou àquele que participa da fixação dos fatos no processo.

3. Facilitação da prova, inversão da prova e formação do convencimento judicial

Note-se que não é porque o juiz não pode penetrar na essência da verdade que pode descurar da necessidade de se convencer, pensando bastar para tanto a chamada “verossimilhança preponderante”, que significa a possibilidade de o juiz julgar em favor da parte que demonstra ter o direito mais verossímil.

Ademais, embora em regra o juiz deva se convencer da verdade (verdade possível), o alcance desse limite pode ser dispensado em casos excepcionais, em que a dificuldade de produção de prova e o direito material em discussão recomendem a facilitação da prova, a inversão do ônus probatório ou mesmo a redução das exigências de prova para a formação do convencimento judicial adequado ao caso concreto.

Também importa perceber o papel das presunções na formação da convicção judicial. As

presunções legais relativas, isto é, aquelas em que o direito material afirma que de um fato A decorre um fato B, admitindo o afastamento da presunção mediante a prova de que o fato presumido não ocorreu, foram pensadas como técnicas de inversão do ônus da prova. Tal solução, entretanto, não é exata, pois essa espécie de presunção tem o nítido objetivo de facilitar a demonstração do fato presumido. Tanto é que não dispensa o autor de provar o fato em que a presunção se funda. A presunção legal relativa não concretiza um verdadeiro caso de dispensa ou de inversão da prova. A hipótese pode ser vista, em princípio, como de distribuição da prova, mas somente encontra verdadeiro qualificativo quando visualizada na perspectiva da sua razão de ser, ou melhor, do motivo de tal distribuição, que é a facilitação da prova.

Mas as presunções judiciais também se orientam em tal sentido, pois visam facilitar a demonstração dos fatos a partir da prova de outros, dos quais são deduzidos por meio do raciocínio judicial (presuntivo). Nesse caso, como a presunção não é estabelecida pela lei, ela depende das circunstâncias do caso concreto. Em outras palavras, a presunção judicial resulta da dificuldade de produção da prova do fato direto e das necessidades do direito material, constituindo mais uma técnica de facilitação da prova. As presunções judiciais permitem a formação do convencimento judicial segundo as necessidades do caso concreto. Nesse sentido, é possível dizer, na linha de Musielak, que a presunção judicial faz com que o juiz se convença da “verossimilhança preponderante”.⁴²

Isso acontece porque, como vimos, o grau de credibilidade da presunção varia conforme a convicção que se tenha na procedência da ilação formulada. Essa ilação assenta-se em sua capacidade de satisfazer os seus aspectos extensivos – de cobrir a totalidade do fato probandum – e intensivo – que do fato indiciário decorra apenas o fato probandum.⁴³ Além disso, como a presunção é o resultado de um raciocínio baseado em regras de experiência, a força da presunção cresce na medida do valor da regra de experiência em que o raciocínio se pautou.

Walter afirma que a prova por presunção judicial tem a intenção de justificar reduções necessárias do módulo de prova, porém não é plenamente apta a esse fim. Segundo ele, os casos em que a jurisprudência alemã reduz o módulo da prova com base nas presunções simples poderiam ser justificados por razões do próprio direito material. Por isso, diz que, ao invés de se pensar em presunção judicial, é melhor exigir “una prueba menor que la necesaria para llegar al convencimiento de la verdad, y por qué razones. Entonces no solo resultaría innecesaria toda la intrincada problemática en torno a las reglas de experiencia”.⁴⁴

O processualista alemão afirma que não é necessário pensar em prova por presunção quando o juiz pode se contentar com a verossimilhança a partir da própria prova plena. Ou seja, bastaria reduzir o módulo da prova à verossimilhança preponderante (ou suficiente), sendo desnecessário recorrer à prova por presunção. Não se daria uma forçada elasticidade à prova por presunção, evitando-se atribuir à presunção simples a capacidade de extrair ilações dificilmente justificáveis a partir das regras de experiência.

De qualquer forma, a proposta de Walter não tem muita importância em termos de resultados práticos, pois não há muita diferença em entender que a prova plena, e não a presunção, pode conduzir à verossimilhança suficiente. Com efeito, compreendendo-se que a presunção é um juízo, que inclusive pode ser somada a outras presunções para a formação do juízo sobre o mérito, não há como concluir que a prova plena, e não a presunção, pode acarretar a verossimilhança.

O que se pode dizer, e com proveito, é que não há razão para pensar em presunção quando não há regra de experiência capaz de lhe conferir credibilidade. Nessa situação, a única saída é tomar em consideração o direito material em litígio, como acontece, por exemplo, em relação às chamadas lesões pré-natais, conforme explica o próprio Walter: “El régimen especial de que gozan los requisitos de prueba en las lesiones prenatales frente a los supuestos de lesión ‘normales’, se justifica por lo limitado de nuestros conocimientos acerca de las causas y consecuencias de la lesión de un feto. Pero si se quiere aplicar en serio la conclusión de que un daño en la salud sufrido por una criatura entre su concepción y su nacimiento por efecto de un delito cometido en su madre, tiene que ser indemnizado con prescindencia de lo que digan todas las construcciones jurídicas, habrá que ayudar a que esa conclusión prospere, teniendo en cuenta las específicas

dificultades de la prueba en la prenatalidad. También aquí el medio indicado es la reducción del módulo de prueba: La prueba por presunción simple fracasa también aquí. Supongamos que en un accidente automovilístico una mujer encinta se fracture una tibia y una costilla y que sufre, además, una severa conmoción cerebral. Más tarde da a luz una criatura que presenta daños en el cerebro. ¿Es esto consecuencia del accidente? Ello no es inverosímil, pero no responde a un hecho típico. Tampoco es aplicable el § 287 de la ZPO. Lo único que podría aplicarse sería invertir la carga de la prueba en perjuicio del damnificado, quien tendría que probar entonces que el accidente no fue la causa del daño. Sin embargo, esa inversión tiene que considerarse una ultima ratio, porque de cualquier manera ella permite que en casos extremos sea suficiente una mera posibilidad para producir una prueba o fundar una pretensión. Si subsistiesen dudas de peso acerca de la causalidad del accidente, pero sin que esa causalidad pueda excluirse con certeza, el demandado quedaría no obstante obligado a resarcir, si se invirtiese la carga de la prueba. A la postre, se le exigiría al damnificado menos que la prueba de una verosimilitud preponderante. Pero las dificultades de prueba son tenidas debidamente en cuenta en cuanto al módulo de prueba es reducido, en los supuestos relativos a criaturas por nacer, a la verosimilitud preponderante”.⁴⁵

Não é apenas a prova por presunção, vista como mecanismo de facilitação da prova, que pode contribuir para a formação do convencimento do juiz, mas também a própria redução das exigências de prova (ou a redução do módulo da prova). É possível dizer, em princípio, que a prova por presunção pode ser utilizada para suprir a dificuldade de produção da prova plena – ou da prova do fato direto –, enquanto que a redução das exigências de prova é dependente das necessidades do direito material em litígio.

De lado a prova por presunção e a redução das exigências de prova, há outra técnica que serve para facilitar o convencimento judicial, retirando do autor o ônus da produção da prova mediante a sua transferência ao réu. Note-se que a inversão do ônus não é uma técnica de facilitação da prova, até mesmo porque, em razão dela, a prova não é produzida pelo autor. Tanto a inversão do ônus quanto a redução das exigências de prova não são técnicas ligadas à facilitação da produção da prova, porém mais precisamente à facilitação do convencimento judicial.

Importa, por isso, atentar para as técnicas que interferem na convicção judicial, especialmente facilitando sua formação (ou a motivação a respeito de sua formação) ou reduzindo o grau de exigência que se espera na convicção (ou na fundamentação a seu respeito) judicial.

4. A redução das exigências da prova como consequência da necessidade de se viabilizar tutela jurisdicional efetiva aos direitos

A regra do ônus da prova, ao impor ao autor o ônus de demonstrar o direito, muitas vezes torna extremamente difícil ou impossível a produção de prova do fato direto. Admite-se, então, a prova por presunção e a inversão desse ônus.

Acontece que algumas situações, em face da sua natureza e da intenção da norma de direito material, tornam a verossimilhança suficiente. Para ocuparmos o exemplo dado acima, das lesões pré-natais, cabe lembrar que a dificuldade de produção de prova direta ou de prova por presunção – em razão da insuficiência de regras de experiência –, eliminaria a possibilidade de se condenar o causador do dano.

Nesse caso, como é óbvio, o direito material impõe o dever de ressarcir, como acontece em todos os casos em que alguém é responsável por um dano. O grande problema, em tal hipótese, é a demonstração da causalidade, vale dizer, a demonstração de que o acidente causou uma lesão ao feto.

A prova dessa causalidade, como é evidente, não pode ser pensada como a prova da causalidade das lesões “comuns”. Tal prova deve ser compreendida em sintonia com os limites dos conhecimentos sobre as causas e as consequências das lesões produzidas a um feto. Melhor explicando: não há como exigir prova plena da causalidade quando o conhecimento humano não pode explicá-la. Tal exigência implicaria em negar, de uma só vez, o direito à tutela jurisdicional e

o próprio direito material.

Ou seja, a convicção judicial deve pensar a causalidade na perspectiva da possibilidade do seu pleno esclarecimento. Quando essa possibilidade não é plena, não há como exigir uma “convicção de certeza”, bastando a “verossimilhança”. Do contrário não haveria como dar tutela jurisdicional ao direito material, negando-se, no caso, a própria peculiaridade das lesões pré-natais.

5. A importância do plano do direito material para a elaboração da justificação sobre a convicção

Como visto, a convicção judicial não pode ter pretensão à uniformidade, como se o juiz pudesse formar a sua convicção sem olhar para o caso concreto. Ao juiz é indispensável considerar as circunstâncias do caso concreto que revelam dificuldades na produção da prova.

Exemplo disso, revelado por Walter, é o caso de seguro contra roubo: “La jurisprudencia no exagera los requisitos para producir la prueba de una contingencia, a fin de proteger al asegurado ‘contra una desvalorización del seguro contra robo’. Dicho en otras palabras, para que el seguro mantenga el sentido por el cual se lo contrató, no se le puede exigir al asegurado que produzca una prueba plena (lo que no es siempre fácil precisamente en casos de robo) y negarle el seguro si no se logra una convicción plena. La jurisprudencia sobre seguros confirma nuestra tesis de que hay que tener en cuenta el derecho material u otros aspectos relativos a la relación jurídica”.⁴⁶

Como está claro, a convicção judicial não pode ser pensada como algo que diz respeito apenas ao direito processual, compreendido na sua tentativa de isolamento em face do direito material. Para que os direitos possam ser adequadamente tutelados, a convicção do juiz não pode deixar de considerar as diferenças entre as várias situações de direito material.

6. A sociedade de risco e a prova da causalidade

Determinadas atividades, importantes para o desenvolvimento social, geram risco de danos. Diante disso, afirma-se que o risco faz parte da sociedade contemporânea.

Acontece que essa constatação não pode prescindir de uma reação, pois não há racionalidade em obrigar a sociedade a suportar os riscos que aproveitam apenas a alguns. Sustenta-se que o dano, quando proveniente de certas situações, prescinde de culpa. Entretanto, isso não é suficiente para um adequado gerenciamento do risco. É necessário pensar na causalidade, ou seja, na relação do dano com algum fato ou alguma atividade, cuja prova passa a ser o calcanhar de Aquiles do sistema.

Se o titular de uma atividade está ciente de que pode provocar danos, é evidente que essa prévia consciência somente pode ser admitida como racional ao aceitar a responsabilidade pelo risco de dano que lhe é inerente. Porém, as mesmas razões que levam a culpa a ser pensada de forma diferenciada diante das situações de risco obrigam que a causalidade seja vista de modo especial, ou melhor, que a prova da causalidade não exija os mesmos requisitos dos casos comuns, em que o risco não está presente.⁴⁷

Nos casos de responsabilidade pelo risco, aceita-se a possibilidade de eventual dano e a responsabilidade pelo seu ressarcimento. Ou seja, mesmo antes da ocorrência de qualquer dano, já se parte da premissa de que um dano pode vir a ocorrer. Se o risco da atividade é aceito em razão de que o seu titular se responsabiliza pelos eventuais danos, não há como supor que a vítima do dano deve sofrer a dificuldade da demonstração da causalidade, como se o risco não tivesse que aí também interferir.⁴⁸

Quem gera um risco especial não assume apenas a responsabilidade pelo dano, porém, mais precisamente, adquire a responsabilidade pelo perigo que pode culminar em dano, e assim também assume o risco de que a causalidade não possa ser devidamente elucidada. Imaginar que essa dificuldade deva ser suportada pela vítima é simplesmente desconsiderar as razões da

responsabilidade pelo risco.

Lembre-se de que o titular de uma atividade que gera poluição não deve arcar apenas com os prejuízos que podem ser a ele diretamente atribuídos. A sua responsabilidade vai além, pois se a sua atividade impõe um prejuízo à sociedade, o benefício ocasionado somente será legítimo caso ocorra uma devida compensação, por meio de impostos, taxas etc. Nessa hipótese, não há responsabilidade por um dano em concreto, mas sim responsabilidade em razão da atividade que, por sua própria natureza, traz prejuízos ambientais.

Contudo, no caso de dano eventual, a lógica não é muito diferente, uma vez que também aí se dispensam a culpa e o rigor da prova da causalidade relativa aos casos normais. É que, se o empresário assumiu a responsabilidade pelo perigo, não é justo que a sociedade tenha que arcar com a dificuldade de provar a causalidade.⁴⁹ É por essa razão que, diante das situações de perigo, basta a verossimilhança suficiente, sendo dispensável a convicção de certeza.

7. A relação entre as violações de deveres profissionais e de normas de proteção e de prevenção de acidentes com a prova da causalidade

Não há dúvida que existe, em abstrato e hipoteticamente, uma relação entre as violações de deveres profissionais e de normas de proteção e de prevenção de acidentes com os danos. Ou melhor, esses deveres objetivam evitar danos. A violação de tais deveres deve ser vista como um anúncio de que o infrator assumiu a possibilidade de provocar dano.

É claro que a relação entre a violação e o dano somente tem importância quando a causalidade é posta em dúvida. Diante dessa dúvida, restaria à vítima, em princípio, o ônus de demonstrar a causalidade. Mas, como o infrator, ao violar o seu dever, aceitou o risco de produzir dano, é natural atribuir-lhe, como *consequência natural, o risco da dificuldade de elucidação da causalidade, ou o risco dessa dúvida*.⁵⁰ Ou melhor, o infrator, ao desconsiderar o seu dever, assume um risco de dano, que – como acontece com o titular da atividade perigosa – deve gerar-lhe um risco em face da prova.

Em razão de certa violação, a causalidade pode ser insuscetível de elucidação ou ter o seu esclarecimento dificultado. É possível concluir que no primeiro caso o infrator paga com a inversão do ônus da prova e no segundo com a redução das exigências de prova, isto é, com a “verossimilhança preponderante” (ou suficiente).

Para melhor explicar, vejamos três exemplos apresentados por Walter. No primeiro, um cliente é encontrado morto no pátio de uma hospedaria. O pátio não estava iluminado e, assim, o dono da hospedaria teria violado o seu dever. Mas o dono da hospedaria afirmou, na sua defesa, que o cliente caiu ao retornar ao pátio, quando não havia a obrigação de mantê-lo iluminado. Diante disso, conclui o processualista alemão: “Es verdad que el hecho puede haber ocurrido de dos maneras: que haya sufrido una caída al abandonar la fonda, pero también que eso le haya sucedido al regresar más tarde a ese lugar. Sin embargo faltando puntos de apoyo concretos para esa segunda posibilidad y estando comprobado que el cliente salió de la fonda por el patio, es preponderantemente verosímil que sufriera la caída en esa ocasión. Esta verosimilitud preponderante tiene que ser suficiente, por que las dudas de que haya ocurrido así por haber aún otra posibilidad, no deben ser soportadas por quién se vio perjudicado por el incumplimiento”.⁵¹

No segundo, um expectador de um cinema é encontrado inconsciente aos pés de uma escadaria que começa atrás da saída de emergência. Essa escada foi construída com violação das normas edilícias. Coloca-se a seguinte dúvida: a vítima desmaiou em consequência do ar viciado, esbarrando na porta, ou caiu na escada ao tentar abandonar a sala por se sentir indisposto. E a conclusão de Walter é a seguinte: “En ese caso estaba comprobada una violación de las normas de seguridad de la policía de la construcción. No se había aclarado, sin embargo, si el espectador se había desmayado antes de caer a consecuencia del aire viciado y si el accidente se produjo por esa causa, o si había perdido el conocimiento solo al caer en la escalera defectuosa (al tener que abandonar la sala por haberle sobrevenido un vahído). En el primer supuesto, la construcción

defectuosa de la escalera carece de consecuencias para el daño. En la segunda hipótesis está comprobada la causalidad posible del incumplimiento del deber (aunque el demandante puede haber caído también a consecuencia de un vahído y no por defectos de la escalera) y, por lo tanto, hay que reducir los requisitos de prueba a favor del demandante. Pero tampoco entonces su acción prosperará: las tres posibilidades son igualmente verosímiles y ninguna de ellas lo es de modo preponderante”.⁵²

No último, em um local destinado à prática da natação, falta a divisão entre o local destinado aos nadadores e o local reservado aos principiantes. Uma pessoa que não sabe nadar morre afogada na região profunda. A morte pode ter sido causada pelo fato de que a vítima não sabia nadar, mas também em virtude de problemas de saúde. Em relação a esse caso, escreve Walter: “Distinto es el caso del que no sabe nadar. La muerte de este se debió, o bien a un ahogamiento por inmersión en una zona de profundidad peligrosa para los que no saben nadar (por la falta de vallado) o bien a un repentino colapso cardíaco o circulatorio. La infracción a un deber empeoró también aquí típicamente y de un modo sensible la posición probatoria. El riesgo de la inesclarecibilidad tiene que ser soportado aquí plenamente por el infractor, o sea que es él quien tiene que soportar la carga de la prueba de que la falta de vallado no fue la causa del accidente fatal. Si el bañero hubiese cumplido con su deber, el bañista no se habría ahogado porque había respetado la valla. O se habría ahogado, por no respetarla, o habría muerto de un colapso circulatorio. Pero en estos dos últimos casos, el bañero no sería responsable. La inesclarecibilidad es aquí una consecuencia típica de la violación del deber, consecuencia que por justicia tiene que soportar el incumplidor. En el caso concreto, el Tribunal Superior Estadual tuvo por ‘poco verosímil’ que el hombre se hubiese ahogado en el sector hondo, porque quienes están en peligro de ahogarse suelen agitarse y gritar, y no hundirse silenciosamente como había ocurrido en ese caso. Pero la Corte Federal de justicia estimó que se había dado la prueba por presunción simple de que el hombre se había ahogado en la zona honda de la pileta, debido precisamente a su profundidad. Esto explica dos casos. En primer lugar, que la sanción de una verosimilitud preponderante es insuficiente en este caso (véase la sentencia de Tribunal Superior Estadual, aunque la Corte Federal de Justicia sostuvo igualmente, al referirse a la presunción simple, que era preponderantemente verosímil que el hecho hubiese ocurrido de determinada manera). En segundo lugar, que también aquí, en un caso atípico, la presunción simple está siendo utilizada para fundamentar el resultado a que se desea llegar. (El hecho de que una persona que no sabe nadar se hunda silenciosamente y se ahogue en un sector profundo, a causa de esa profundidad ¿lleva el ‘sello de lo usual y habitual’? La justificación más reciente que da la Corte para este caso y también para el primero (el del cliente de la taberna) reza también: ‘En estos casos se había comprobado de cualquier manera determinada contribución a la acción o determinado estado de cosas, que podía haber causado directamente el resultado producido...’. Completamos esta proposición añadiendo la expresión ‘violatoria del deber’ (lo que es admisible, por cuanto esos estados de cosas – patio no iluminado, pileta no vallada – eran violatorios de deberes, y tenemos que la Corte confirma nuestra tesis: el incumplimiento del deber justifica por sí solo una reducción del módulo e inclusive una inversión de la carga de la prueba)”.⁵³

Como demonstram esses exemplos, é preciso, em primeiro lugar, que a violação do dever possa ter dado causa ao dano. Assim, no segundo exemplo, se o expectador desmaiou – em razão do ar viciado – antes de chegar à escada, é claro que essa violação não poderia ter colaborado para o dano. Mas, se a violação do dever pode ter contribuído para o dano, é preciso verificar se a violação eliminou – ou não – a possibilidade de a vítima produzir prova.

Se a vítima pode produzir prova, será bastante que essa chegue à verossimilhança, uma vez que a impossibilidade de uma convicção de certeza em relação à causalidade, no caso em que um dever foi violado, não pode ser por ela suportada. Como já foi observado, aquele que viola um dever aceita o risco de produzir um dano e, por consequência, o risco da dúvida acerca da causalidade (ou o risco probatório).

No caso da queda no pátio por ausência de iluminação, provou-se que o cliente da hospedaria saiu diretamente pelo pátio no momento em que a luz estava apagada. Essa prova demonstra a verossimilhança suficiente, uma vez que o dono da hospedaria, ao violar o seu dever, assumiu o

risco de que o acidente ocorresse, e assim não pode exigir uma prova do exato momento da queda.

Porém, no segundo exemplo, em que o cliente de um cinema foi encontrado caído, a possibilidade de a queda ter sido ocasionada pelo defeito da escada não era mais verossímil do que a possibilidade dessa queda ter ocorrido em razão de um mal-estar ou de uma “tontura”.

No caso da hospedaria, admitiu-se que a versão da vítima era verossímil, ao passo que, no da escadaria, entendeu Walter que não se poderia falar em verossimilhança. Note-se que, no caso da hospedaria, a dúvida era relativa ao momento da queda, e existia prova de que a vítima havia cruzado o pátio quando o dono da hospedaria tinha o dever de iluminá-lo. No caso da escadaria a situação era diferente, pois a dúvida era sobre a causa da queda, e não era verossímil que um defeito na construção da escada pudesse ser a sua causa, tanto é que essa circunstância sequer foi alegada pela vítima em sua petição inicial. Nesses dois exemplos, a violação do dever não retirou da vítima a possibilidade de produzir prova. Mas a sua produção somente gerou uma verossimilhança suficiente apenas no caso da hospedaria.

Resta analisar o terceiro caso, ou seja, aquele em que o dono de um clube de natação violou seu dever de informar os seus clientes a respeito da parte profunda da piscina, que não poderia ser utilizada pelos principiantes, vindo alguém a se afogar exatamente em tal local. O réu alegou que a vítima teria se afogado em razão de um colapso. Perguntava-se, então, se a violação do dever poderia ter contribuído para o afogamento ou se esse havia se dado em razão de problemas de saúde. Diante dos termos da contestação, concluiu Walter que nada poderia ser esclarecido pelo autor: “La inesclarecibilidad es aquí una consecuencia típica de la violación del deber, consecuencia que por justicia tiene que soportar el incumplidor”.⁵⁴

Em princípio seria possível simplesmente afirmar que na hipótese do cinema a dúvida recaía na causa da queda e na do clube de natação sobre a causa da morte, e que nesse sentido não existiria grande distinção entre as duas situações. Acontece que a escada, ainda que com defeito, não representa o mesmo perigo do que uma piscina profunda para os que não sabem nadar. Não porque o defeito na escada pode provocar um dano leve e a piscina a morte por afogamento, mas sim porque a probabilidade de alguém cair em uma escada que não está de acordo com as normas de construção é bem menor do que a probabilidade de uma pessoa que não sabe nadar se afogar em uma piscina profunda. Em outros termos: no caso do clube de natação sequer se discutiu sobre o fato de que a piscina, em que houve a morte da vítima, não deveria ser utilizada por pessoas que não sabem nadar, até porque isso é notório. Ao contrário, no caso da queda na escada do cinema, nada indicava que isso poderia acontecer, tanto é que, segundo Walter, esse fato sequer foi alegado na petição inicial, não ocorrendo, mais tarde, qualquer prova que evidenciasse ao menos a verossimilhança de que isso poderia acontecer. Se em um caso o perigo é notório, no outro ele não foi sequer alegado.

Ademais, o interessado na responsabilização não teve a necessidade de demonstrar a violação do dever legal e o fato de que a vítima morreu na piscina, pois isso era incontroverso. A única controvérsia girava sobre a causa da morte. Mas o que levou a vítima a nadar em local impróprio foi a ausência de aviso, ou a violação do dever legal, e por isso não era racional exigir a demonstração de que a vítima morreu afogada.

Diante de tudo isso, o que mais importa é demonstrar – e essa é a nossa intenção – que a violação de um dever, ao abrir oportunidade à produção de danos, deve ser tomada em conta diante da dificuldade da demonstração da causalidade. Em suma, com base na ideia de que o violador assume o risco probatório, o juiz, conforme o caso, pode se contentar com a verossimilhança ou inverter o ônus da prova.

8. O dano provocado pelas chamadas emissões intoleráveis e a prova da causalidade

De acordo com o art. 1.277 do CC, “o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”. Em complemento ao caput do art. 1.227,

preceitua o seu parágrafo único: “proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança”.

Em princípio, trata-se da possibilidade de “fazer cessar” o ilícito e, assim, da necessidade de se usar a ação inibitória,⁵⁵ cuja prova está relacionada a um fato futuro, no caso a continuação do ato ou da atividade. Como esse ato ou atividade, para ser feito cessar, deve ser ilícito, o referido parágrafo único apresenta as linhas para a sua identificação.

Contudo, o que aqui interessa é o ressarcimento do dano. Ou de forma mais precisa: a causalidade entre as emissões e o dano. Com efeito, são frequentes, na prática, ações em que se pede ressarcimento de danos provocados por emissões, como, por exemplo, nos casos em que se alega que a pintura de uma casa foi danificada por fuligens provocadas por determinada fábrica.⁵⁶

Em um caso como esse, caberia perguntar sobre a existência de norma definidora do grau de emissão tolerável. Presente norma apontando as emissões como intoleráveis, e identificada fuligem nas paredes da casa, a dúvida sobre se os danos à pintura foram ou não provocados pelas emissões deve pesar sobre o infrator, que então assume o ônus da prova.

É que, nesse caso, quem viola o dever não assume somente o risco de produzir um eventual dano, pois a emissão que supera determinado valor, segundo a norma, provoca danos. O autor, diante da superação do valor previsto na norma e da existência de fuligem nas paredes, não tem mais nada a provar. O réu é que terá que provar, para se livrar da responsabilidade, que o dano não foi ocasionado pela fuligem. Nesse caso, a inversão do ônus da prova é resultado da constatação de que a emissão de fuligem, em determinado grau, provoca dano.⁵⁷

Mas há casos em que não existe norma determinando o grau de emissão tolerável. Nessa hipótese, cabe ao juiz, considerando a natureza da utilização, a localização do prédio – atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas – e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança, concluir sobre a licitude da emissão.

A conclusão judicial da intolerabilidade da emissão, se pode abrir oportunidade para a procedência de uma ação inibitória que objetive impedir a continuação das emissões, também pode permitir a conclusão a respeito dos prejuízos que acarretam aos vizinhos. A prova de que essas emissões acarretam prejuízos, porque não decorre imediatamente da norma, deve ser feita pela vítima.

O problema é saber se a vítima, nesse caso, pode se limitar a produzir prova capaz de gerar a verossimilhança. A resposta deve ser positiva, pois aquele que produz emissões, ainda que consideradas intoleráveis apenas judicialmente, corre o risco de produzir certos danos aos vizinhos. Ora, se o risco é assumido, o rigor da prova de que o dano foi gerado pela emissão deve ser reduzido, bastando a verossimilhança. De outro modo: a dúvida sobre a capacidade da emissão produzir o dano teria que ser suportada pela vítima.

9. A prova da simulação

O art. 167, § 1.º, do CC afirma que há simulação, nos negócios jurídicos, quando i) aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; ii) contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; e iii) os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

Ciente da dificuldade da prova da simulação, o art. 446, I do CPC, afirma expressamente ser lícito à parte provar com testemunhas “nos contratos simulados, a divergência entre a vontade real e a vontade declarada”.

Porém, não é suficiente proclamar que a simulação pode ser demonstrada por meio de testemunhas. Em regra, somente é possível demonstrar que alguém desejou algo, e declarou coisa diversa, através da prova de fatos que circundam ao redor da alegação da simulação. Admitindo-se

a prova de tais fatos – isto é, a prova indiciária – o magistrado fica investido da possibilidade de formar um juízo sobre a simulação a partir dos indícios.⁵⁸

Ao raciocinar do indício para a presunção, o juiz deve se valer, conforme já explicado, de regras de experiência. Acontece que, por meio de regras de experiência, é quase impossível concluir, com convicção absoluta, que um fato indica que o demandado desejou algo diferente do que declarou.

Isso quer dizer que a prova da simulação deve ser compreendida como uma prova de verossimilhança. Perceba-se, aliás, que o art. 167, § 1.º, I, do CC fala em negócios jurídicos que “aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem”.

Ou seja, o próprio Código Civil fala em aparência. Se o direito material, para dar efetividade à tutela do inocente lesado, contenta-se com a aparência, não há sentido em exigir, exatamente daquele que o direito material visa proteger, uma prova que inviabilize a sua proteção.

10. O relatório dos fatos controvertidos e das provas das partes

O modelo da convicção motivada exige ampla e adequada fundamentação em matéria de prova. Essa fundamentação, por óbvio, exige várias etapas, que vão desde a exposição adequada dos elementos probantes até a sua correta valoração.

O art. 489, I, do CPC brasileiro é expresso em exigir, entre um dos requisitos da sentença, “o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo”.

Em termos de motivação, pouca coisa pode interessar mais ao relatório do que a definição dos fatos controvertidos e das provas admitidas e produzidas. Não há dúvida que a fixação dos pontos controvertidos, que deve ser feita na fase de saneamento (art. 357, II, CPC), é imprescindível para o juiz deixar claro o que deveria ser elucidado com a prova. Diante disso, torna-se também fundamental que a sentença descreva as provas que foram admitidas, produzidas e valoradas.

A relação entre as provas admitidas e as produzidas é importante para destacar a razão pela qual a parte, apesar de ter a prova admitida, não a produziu, e qual o significado que daí se pode extrair.

Por outro lado, a relação entre a prova produzida e a valorada permite às partes o controle sobre o objeto da valoração judicial, para que seja evitada a consideração de prova não produzida.

Essa possibilidade deixa de ser meramente fantasiosa quando se constata o caso lembrado por Salaverría, em que a Corte de Cassação italiana se baseou no depoimento de uma testemunha – fundamental para o deslinde da causa – que havia falecido dezessete anos antes de o processo ser instaurado.⁵⁹

Porém, a definição das provas valoradas tem ainda mais importância para identificar as provas que, apesar de valoradas, são ilícitas, ou foram produzidas com desrespeito às regras processuais ou ao princípio do contraditório.⁶⁰

11. A explicação do conteúdo das provas

Mas não basta apenas elencar as provas produzidas e valoradas. Ao juiz cabe explicar os seus conteúdos, sob pena da necessidade de a indicação dessas provas deixar de ter valor.

Isso para que o juiz não incorra no equívoco de motivar a sentença com base em prova substancialmente diferente da produzida. Não são incomuns, na prática, sentenças fundadas em respostas a quesitos periciais que não retratam o que está nos autos, ou mesmo, sentenças que distorcem um depoimento testemunhal.

Porém, a necessidade de explicar o conteúdo das provas se relaciona mais de perto à necessidade de o juiz expor o seu entendimento sobre elas. Sem isso, não há como saber se existe contradição na fundamentação judicial baseada nas provas, pois não se sabe sequer o sentido em que ele as tomou.

Claro que essa última situação é ligada aos casos em que a prova é dúbia, seja por apontar em um ou mais sentidos, seja por conduzir a um resultado que possa sustentar duas ou mais hipóteses.

Assim, por exemplo, pode haver uma prova pericial que aponte em duas direções. Caso a prova não possa traduzir em graus a probabilidade, é necessário ao juiz referir a indefinição da prova e, por isso, a necessidade de ela ser reforçada com outros argumentos de convicção. Tratando-se de prova que possa espelhar maior probabilidade em determinado sentido, essa situação também deve ser advertida pelo juiz, pois somente assim a sua valoração final (do conjunto probatório) será justificável.

No caso em que, por exemplo, o depoimento testemunhal é certo em determinada direção, mas essa (direção) pode sustentar hipóteses que se debatem, cabe ao juiz relatar a situação, para que então se possa conhecer a lógica da valoração do conjunto das provas. Melhor explicando: é preciso valorar as provas individualmente e relacioná-las entre si. A valoração conjunta, como é óbvio, depende da valoração de cada uma das provas, mas a valoração individualizada de cada uma das provas deve dialogar com a valoração das demais.⁶¹

12. A motivação da prova indiciária e da presunção

Aqui, cabe lembrar, antes de mais nada, a distinção entre indício, prova indiciária e presunção. O indício é um fato que serve para o juiz se orientar a respeito do fato probando, enquanto a prova indiciária é aquela que se destina a prová-lo, de modo que tudo o que foi dito sobre a necessidade de referir as provas e seus conteúdos vale para as provas indiciárias. A diferença é a de que, aqui, há um elemento entre a prova e a convicção final do juiz. Trata-se da presunção, que, embora também constitua um juízo, significa um verdadeiro argumento para a convicção do juiz.

Para a formação da presunção não basta, conforme já explicado, o indício e a prova indiciária, pois a presunção é o resultado do raciocínio judicial que tem o indício (provado) apenas como premissa, para dele extrair, por dedução, o fato probando.

A presunção, assim, é o resultado desse raciocínio judicial, e, portanto, deve ser considerada de forma individualizada e ao lado das demais provas e de outras eventuais presunções. Em outros termos: embora a presunção exija um juízo individual, ela faz parte do conjunto probatório.

Além disso, ainda que, em princípio, a presunção deva ser estabelecida em um momento cronológico anterior ao da apreciação do conjunto probatório, isso não elimina a possibilidade de o próprio raciocínio presuntivo considerar as demais provas. Ou seja, o fato de a presunção exigir um raciocínio atento a fato e prova determinados (indiciários) e, particularmente, a regras de experiência que a ela digam respeito, não impede que o raciocínio presuntivo considere as demais eventuais presunções e outras provas.

13. Motivar não é apenas se basear nas provas que convergem na direção da hipótese vencedora

Na prática forense são usuais as sentenças motivadas somente com base nas provas que demonstram a hipótese vencedora. Alguém dirá que isso é natural, pois o juiz, quando motiva, deve justificar a razão pela qual optou pela versão de uma das partes.

Porém, embora o que ocorra na prática possa parecer lógico, não é difícil corrigir o equívoco através da advertência de que não basta ao juiz aludir às provas que confirmam a hipótese por ele abraçada, já que isso está muito longe de ser uma justificativa das suas razões. Para que ele

realmente possa justificar a sua decisão, não pode deixar de demonstrar que as eventuais provas produzidas pela parte perdedora não lhe convenceram.

Ou mais precisamente, o julgamento somente pode ser feito com base nas provas que favorecem uma das partes quando não há nos autos alguma prova que possa beneficiar a outra. Isso quer dizer que não importa quem requereu a prova, pois ainda que tenha sido postulada pela parte vencedora pode favorecer à perdedora, ainda que em parte.

É o que ocorre, com muita frequência, em relação às provas testemunhais. Diante dessas, parece que o juiz procura recortar os depoimentos das testemunhas para dar ênfase aos trechos que demonstram a hipótese vencedora. Acontece que o juiz não pode considerar uma parte do depoimento e esquecer a outra como se estivesse justificando a versão do vencedor.

Ora, dessa maneira o juiz não justifica as suas razões, mas sim as razões de uma das partes. Por isso, é preciso eliminar o péssimo vício contido na sentença que pensa estar motivada ao justificar as razões do vencedor, supondo que os argumentos relativos para a não aceitação das provas da parte perdedora estejam implícitos.⁶²

Na verdade, a necessidade de o juiz justificar as suas próprias razões, demonstrando o motivo pelo qual prefere uma prova em relação à outra, nada mais é do que um corolário do direito à prova, uma vez que, como é evidente, o direito a provar não se resume à possibilidade de produzir a prova, mas também refere-se ao direito de ter essa prova valorada, pouco importando qual venha a ser o sentido da decisão judicial.⁶³

Aliás, nesse sentido nos parece correta a advertência, já feita em sede doutrinária, de que a motivação é mais importante para o perdedor do que para o vencedor.⁶⁴ A motivação importa mais para o perdedor não apenas porque é ele que pode recorrer, mas especialmente porque é o perdedor que pode não se conformar com a decisão, e assim ter a necessidade de buscar conforto na justificação judicial.

Além disso, não há como esquecer a obviedade de que a motivação também se dirige aos terceiros, isto é, ao público, que tem o direito de conhecer as exatas razões do juiz, além de ser imprescindível para o controle do seu poder. É evidente que o juiz que nada fala sobre as provas que beneficiam a parte vencida nada explica aos terceiros e foge do controle sobre o seu poder, uma vez que pode distorcer os argumentos das partes.

Frise-se, por fim, que a sentença, por ser resultado do diálogo argumentativo, obviamente deve justificar as razões pelas quais os argumentos de uma das partes são rechaçados em prol da outra.

14. A necessidade de motivação de todas as provas produzidas

Nessa altura não deve mais existir dúvida sobre a necessidade de o juiz explicar as razões pelas quais não acolhe as provas do perdedor. A razão desse tópico é outra.

O seu objetivo é enfrentar a propalada possibilidade de o juiz deixar de valorar as chamadas provas supérfluas.

É possível que o juiz, após a definição dos fatos controversos, permita que a prova testemunhal aborde um fato reputado incontroverso. Alguém poderia dizer que isso não traria prejuízo à cognição dos fatos, e que assim não haveria motivo para obstaculizar esse proceder.

Além disso, não seria desarrazoado afirmar que a parte prejudicada pelo depoimento testemunhal que abordou fato incontroverso deveria interpor agravo retido no momento oportuno, pena de o depoimento se cristalizar como indiscutível e, assim, ter que ser considerado nos moldes em que foi produzido pela sentença.

Porém, permitir que a prova testemunhal recaia sobre um fato incontroverso é, evidentemente, retirar da parte a quem beneficia a incontrovérsia a possibilidade de produzir provas em relação a

tal fato. Isso violaria o direito ao contraditório, vale dizer, o direito de participar adequadamente do processo, argumentando para a convicção do juiz.

Não obstante – e isso deve ficar claro –, não é por isso que o juiz pode calar sobre tal parte do depoimento testemunhal, raciocinando como se ele não existisse. Cabe ao juiz, nessa situação, explicar as razões que impedem que essa parte do depoimento possa servir para apoiar a hipótese contrária à decisão – proferida na audiência preliminar – que reputou o fato como incontroverso.

Também não é impossível que o juiz admita a produção de prova em relação a um fato impertinente ou irrelevante, ou mesmo uma prova irrelevante ou incapaz de propiciar a elucidação dos fatos. É certo que, nesses casos, a situação é diferente, pois a prova foi expressamente admitida no processo.

Entretanto, não há como obrigar o juiz a ter um fato como pertinente ou relevante quando verifica, ao final do procedimento, que ele não possui uma dessas qualidades. O mesmo ocorre, como é óbvio, em relação às provas irrelevantes e inidôneas ao objetivo a que se destinam.

Acontece que a existência de provas que – com um nome abrangente – podem ser ditas “supérfluas” – porque incapazes de alterar a convicção judicial – não dá ao juiz o direito de se omitir sobre elas.⁶⁵ Se isso fosse viável, isto é, se bastasse ao juiz calar diante de uma prova que reputa supérflua, seria impossível saber quando o magistrado foi omissor por entender a prova supérflua, quando a esqueceu ou, o que é pior, a encobriu para melhor justificar a hipótese do vencedor.⁶⁶

15. Raciocínio probatório, decisão e justificação

Não há mais dúvida de que a lógica da demonstração matemática, fundada no método lógico-dedutivo, está muito longe de poder explicar o raciocínio probatório.⁶⁷ Não há quem possa duvidar de que a prova não pode ser pensada em termos de demonstração matemática.

Porém, a inviabilidade desse método conduziu a um extremo oposto, especialmente quando Perelman, ao restringir o significado de “demonstração” – relegando-o ao âmbito da matemática e das ciências a ela afins –, concluiu que a prova não tem função demonstrativa.⁶⁸

Taruffo salienta que qualquer referência ao possível papel da retórica na decisão judiciária é ambígua se não se distingue ao menos entre retórica como persuasão e retórica como uso de argumentos racionais. Adverte que no primeiro sentido a retórica não tem nada a ver com a racionalidade, e diz respeito somente ao fato que alguém se persuade ou seja persuadido por qualquer coisa, enquanto, no segundo, que pertence essencialmente a Perelman, a retórica se refere ao uso de argumentos racionais, e pode equivaler – se depurada das implicações mais “persuasivas” – à racionalidade como *ragionevolezza* e não como demonstração *stricto sensu*.⁶⁹

Em outras palavras, se a retórica é compreendida como o uso de argumentos racionais e a decisão não é vista como o resultado de um raciocínio dedutivo, repelem-se as ideias de retórica como mera persuasão e de retórica como alternativa à “demonstração”. Basta que os referidos “argumentos racionais” sejam identificáveis e controláveis, e assim permitam uma adequada justificação da decisão.⁷⁰ Diante disso, como é óbvio, o significado de “demonstração” é mais abrangente, pois passa a abarcar uma demonstração realizada a partir de argumentos racionais justificáveis e controláveis.⁷¹

A impossibilidade de o raciocínio probatório se basear na demonstração própria à matemática não pode redundar na aceitação de que a decisão do juiz possa restar sem controle e, assim, sem uma justificação racional. A ampliação do conceito de demonstração objetiva deixar clara a possibilidade de o juiz demonstrar e justificar as suas razões de modo racional.

O juiz, ao valorar a credibilidade das provas, as provas na forma individual – sejam diretas ou indiretas – ao estabelecer a ligação entre o indício e o fato probando e ao avaliar o conjunto de argumentos das partes – provas e presunções etc. –, certamente submete o seu raciocínio a

sistemas e critérios racionais, embora esses não possam ser explicados em uma perspectiva que possa satisfazer aos apreciadores da “segurança matemática”.

A decisão judiciária deve se fundar em critérios e métodos racionais e, a partir daí, ser motivada. Ou, como diz Taruffo, deve conter argumentos justificativos suficientes a fazer supor que a decisão se funde em “boas razões”.⁷² Da possibilidade de a decisão ser demonstrada através de argumentos racionais decorre a obviedade de que toda decisão não pode deixar de ser motivada, pois o juiz deve justificar as suas razões.

Essa justificação tem relação com a necessidade de controle das decisões. Não se trata de controlar o que o juiz pensou – até porque isso é impossível –, mas sim de controlar a racionalidade das razões que ele apresenta para justificar a sua decisão.⁷³

Não é difícil perceber, diante do que se acaba de expor, que o raciocínio para a justificação obviamente pressupõe os raciocínios probatório e decisório, ou melhor, a raciocínio relativo à prova e o raciocínio que se faz para decidir.

Não há dúvida que esses dois últimos podem se confundir, pois o juiz raciocina sobre a prova para decidir. Mas muitas vezes o juiz faz um raciocínio a respeito dos fatos e das provas sem que, com ele, possa imediatamente decidir. Por isso, há uma distinção entre raciocinar sobre a prova para, posteriormente, decidir e raciocinar, ainda que sobre a prova, decidindo.

A análise da credibilidade da prova, da relação entre as provas e os fatos e das presunções constitui um raciocínio que antecede a decisão, enquanto, através do raciocínio decisório, o juiz analisa o conjunto probatório ou outros critérios que lhe permitam decidir.

Embora os raciocínios probatório e decisório pareçam se identificar – ainda que sejam diferentes – bem mais fácil é separá-los do raciocínio justificativo, pois é evidente que, após o juiz ter raciocinado sobre as provas e proferido a sua decisão, resta-lhe justificar.

É certo que a análise do juiz sobre as provas, bem como a sua decisão, deve ser guiada por critérios racionais. Isso, porém, não elimina a necessidade de o juiz justificá-los. Nesse sentido, há uma brutal diferença entre os critérios de análise probatória e de decisão e os argumentos de justificação.

A diferença entre esses critérios e os argumentos de justificação está presente na radical distinção de natureza entre o raciocínio que trabalha com tais critérios e aquele que se vale dos argumentos justificativos. Quando se pensa, por exemplo, na credibilidade de uma prova, ou mesmo em um critério de decisão, realiza-se um raciocínio que se coloca frente a duas opções e deve escolher uma delas, ao passo que, quando se está diante do raciocínio justificativo, não há mais o que escolher, pois é apenas necessário justificar, através de argumentos, os raciocínios que antes foram feitos.

É óbvio que a distinção entre essas modalidades de raciocínio não quer dizer que a racionalidade da justificativa não possa ter base na racionalidade dos raciocínios que conduziram à decisão. Como dito, a justificativa não exclui a necessidade de racionalidade de critérios probatórios e decisórios. Ou seja, a racionalidade desses critérios não excluiu a racionalidade da justificativa e vice-versa.

Alguém poderia dizer, é certo, que uma justificativa racional pode esconder critérios probatórios e decisórios irracionais e que a racionalidade desses critérios não excluiu uma justificativa fundada em argumentos não racionais. Porém, essa lembrança, ao contrário de invalidar a distinção entre os raciocínios, a confirma ainda mais.⁷⁴

Sob outro ângulo, toda prova impõe ao juiz o dever de relacioná-la com o fato que deseja evidenciar. Isso ocorre, com maior clareza, no caso da prova de um fato direto, mas também está presente quando se pensa na prova de um fato indireto, uma vez que, antes de o juiz poder raciocinar a partir do fato indiciário para o fato essencial, deve concluir a respeito da relação entre

a prova indiciária e o indício.

Isso quer dizer, simplesmente, que antes de o juiz estabelecer a ligação entre a prova e o fato, deve valorar a credibilidade da prova. Não se trata de valorar se a prova identifica o fato, mas sim se o documento é formalmente exato ou se o perito e a testemunha são idôneos ou mesmo se a prova pericial e a prova testemunhal têm saliências que retirem a sua credibilidade.

Convém lembrar, desde logo, que o perito pode ser recusado por impedimento ou suspeição (arts. 467 e 157, § 1.º, CPC) e, ainda, ser substituído quando carecer de conhecimento técnico ou científico (art. 468, I, CPC) ou, evidentemente, de idoneidade moral. No que diz respeito à testemunha, a parte pode contraditá-la, arguindo a sua incapacidade, impedimento ou suspeição (art. 457, § 1.º, CPC). Além disso, o juiz pode, de ofício ou a requerimento, determinar “a acareação de 2 (duas) ou mais testemunhas ou de alguma delas com a parte, quando, sobre fato determinado que possa influir na decisão da causa, divergirem as suas declarações” (art. 461, II, CPC).

Mas isso não basta para o controle da credibilidade da prova. A prova pericial está sujeita a pedidos de esclarecimentos pelas partes e pelo juiz (art. 477, §§ 2.º e 3.º, CPC) e, excepcionalmente, pode abrir ensejo a uma segunda perícia, que, segundo o art. 480, § 1.º, do CPC, “tem por objeto os mesmos fatos sobre que recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu”. Enquanto isso, se um dos motivos que apontem para incapacidade, impedimento ou suspeição for revelado apenas no curso do depoimento, é claro que ele deve ser tomado em consideração. Aliás, o juiz deve atentar para as condições mentais e psicológicas do depoente e para a lógica do seu depoimento com o objetivo de detectar eventuais desvios de memória e contradições conscientes ou inconscientes da testemunha.

Para a valoração da credibilidade da testemunha, o juiz tem que se valer das regras de experiência comum, o que, obviamente, deixa o seu raciocínio muito longe de um simples esquema dedutivo-demonstrativo. Mas isso não quer dizer que o juiz fique impedido de justificar racionalmente a sua valoração, e que, assim, a sua decisão possa ficar ausente de controle. O real problema, como é fácil perceber, consiste na determinação e no correto emprego dos critérios capazes de propiciar uma adequada valoração da testemunha.⁷⁵ Para exemplificar, basta lembrar que Taruffo, ao aludir a tais critérios, afirma que não se pode excluir, em princípio, o recurso a perícias que ajudem o juiz a valorar a credibilidade de uma testemunha, ao menos quando essa valoração seja particularmente difícil e delicada.⁷⁶

Qualquer circunstância que aponte para a desestabilização da prova deve ser revelada na motivação da sentença, ainda que não interfira na valoração individual da prova ou no resultado do julgamento. Ou seja, ainda que uma anormalidade não retire a credibilidade da prova, e assim permita a sua relação com o fato, ou mesmo que a credibilidade da prova ou a própria prova do fato não sejam capazes de propiciar um julgamento favorável à parte que nela possui interesse, o juiz não pode deixar de aludir a essa circunstância na sua motivação.

Em suma: antes de se tentar ligar a prova ao fato é preciso analisar a sua credibilidade, pois a prova somente pode provar depois de ter sido aprovada, ou, como salienta Iacoviello, “toda prova, antes de provar, deve ser provada”.⁷⁷

Diante de tudo isso, pode ter passado encoberta a distinção entre a credibilidade da prova e a sua valoração individualizada.

É que a credibilidade da prova, ao nosso ver, tem relação com a sua idoneidade. Assim, a prova pericial que contém contradições que inviabilizam a sua própria prestabilidade para o esclarecimento do fato, do mesmo modo que o depoimento que contém em seu bojo graves contradições, não passam pelo teste de credibilidade e, assim, sequer podem ser relacionados com o fato que almejam elucidar.

Algo diferente ocorre quando a prova é considerada idônea ou crível. Nesse caso, não é correto imaginar que o juiz passa imediatamente para o julgamento do mérito. Esse último requer a valoração de todas as provas e presunções existentes nos autos, ou simplesmente a valoração do

conjunto probatório.

Acontece que, antes da valoração do conjunto probatório, o juiz deve estabelecer a relação entre a prova e o fato direto e a prova e o fato indireto e, nessa última hipótese, ligar mentalmente o indício e o fato essencial. Essa prévia análise, portanto, obviamente não tem a ver com o raciocínio que o juiz faz ao valorar o conjunto probatório. Somente existe um conjunto probatório a partir da definição das provas e das presunções. Note-se bem: não apenas depois da definição da credibilidade da prova, mas sim após a conclusão de que uma prova pode, ou não, demonstrar um fato ou indicar uma presunção.

Contudo, essa separação entre a valoração individualizada da prova e a valoração do conjunto probatório não elimina a possibilidade de o sentido de uma prova ou de uma presunção ser estabelecido com o auxílio das outras provas e presunções.

16. O percurso do raciocínio do juiz entre a prova e o fato

Não há como ignorar a diferença entre a situação em que o juiz tem contato imediato com o fato e a aquela em que o seu contato é apenas mediato, ou melhor, entre a prova cujo contato do juiz é imediato (inspeção judicial) e a prova intermediada (p. ex. prova testemunhal).

Nesse último caso, afirma-se que, antes de o juiz relacionar a prova intermediada com o fato, deve passar pela análise da credibilidade da prova, segundo a regra de que, antes de provar, a prova deve ser provada.

Contudo, como demonstramos há pouco, a aferição dos requisitos relativos à credibilidade da prova testemunhal deve anteceder a relação entre o seu resultado e o fato. Ou seja, a segurança da ponte mental entre a prova e o fato depende da conclusão sobre a real aptidão que a prova possui para provar.

Não obstante, uma vez estabelecida a idoneidade da prova, o juiz deve relacioná-la com o fato que se propõe a demonstrar. Com efeito, após o juiz ter conferido credibilidade à prova, o seu raciocínio deve estabelecer a ligação entre ela e o fato, seja direto ou indireto. Em relação a esse último, entretanto, o juiz não para aí, pois, após saber que o indício (fato indiciário) está provado pela prova indiciária, o seu raciocínio deve ir adiante para estabelecer a relação inferencial entre o indício e o fato direto (ou essencial).

No que diz respeito ao fato que a prova se propõe a demonstrar, o raciocínio do juiz caminha apenas entre a hipótese fática e a prova, uma vez que a relação entre esses dois elementos é proposta de forma antecedente no plano lógico-semântico. Tal raciocínio, assim, é o que basta para unir os dois elementos, sem necessidade de maior complexidade, ainda que esse raciocínio também deva ser motivado.

Quando dissemos mais acima que, após o juiz ter conferido credibilidade à prova, o seu raciocínio deve estabelecer a ligação entre ela e o fato, seja direto ou indireto, não tivemos outra intenção senão demonstrar que o raciocínio judicial relativo à prova e o fato direto possui a mesma estrutura daquele que se coloca entre a prova indiciária e o fato indireto.

Quem imagina que a diferença entre tais raciocínios tem a ver com a relação entre a prova e o fato – seja ele direto ou indireto – está enganado, pois a distinção decorre da obviedade de que, em relação ao fato indireto, não basta a relação entre ele e a prova indiciária, sendo necessário ao juiz ir adiante para estabelecer, através do raciocínio que chamamos de presuntivo, uma relação inferencial entre o fato indireto e o fato direto.

Nesse percurso entre o indício e o fato essencial, através do qual se olha a presunção, o juiz precisa de bases para o seu caminho. Ou melhor: o juiz, para verificar se o indício aponta, e em que medida, para o fato essencial, deve se orientar por critérios, que são chamados de regras de experiência.⁷⁸

Não é difícil perceber que, se as regras de experiência guiam o raciocínio presuntivo,⁷⁹ é preciso controlá-las. Diante disso, impõe-se imediatamente a conclusão de que as regras de experiência, sejam quais forem, devem ser precisamente relatadas e motivadas na decisão, para que seja possível controlar o poder do juiz, basicamente, a consistência da sua base empírica e sua eventual arbitrariedade.⁸⁰

Não é apropriado, nesse momento, um maior aprofundamento do tema das regras de experiência, uma vez que essa matéria deverá ser abordada quando dos comentários ao art. 375 (infra), que classifica as regras de experiência em “comuns” e “técnicas”. Mas, como aqui interessa a motivação do raciocínio, é preciso frisar que a qualidade do raciocínio presuntivo se funda na “força” que se pode extrair das regras de experiência. A análise, então, passa a exigir resposta à questão de como estabelecer essa “força” ou o valor das várias regras de experiência.

Nessa perspectiva, cabe distinguir, desde logo, as regras de experiência comum e as regras de experiência técnica. As primeiras, segundo o art. 375 do CPC, são “subministradas pela observação do que ordinariamente acontece”. Ora, aquilo que “ordinariamente acontece” tem, em princípio, um valor menos crível do que as regras de experiência técnica. Mas, para que essa separação fique mais compreensível, cabe dar significados às regras de experiência “comum” e às regras de experiência “técnica”.

As regras de experiência técnica, em princípio, podem variar de uma posição firmemente aceita na comunidade científica, passando por definições ainda discutidas pela ciência, e chegando a observações do que ordinariamente acontece no manuseio de algumas técnicas.

Em relação à primeira hipótese, ainda que essa seja a regra de experiência que melhor possa explicar a presunção, o problema é que, diante de muitas questões, não há consenso sobre uma regra científica. Portanto, parece ser inadequada a solução que já foi utilizada no direito americano, no sentido de determinar a credibilidade da regra técnica a partir do seu consenso na esfera científica, por meio do que se denominou de *general acceptance test*.⁸¹ Aliás, esse critério já foi desacreditado nos Estados Unidos por não permitir a consideração de “descobertas” novas e originais, ainda não amplamente aceitas pelos cientistas.⁸²

A exigência de consenso, além de não permitir a consideração de boa parte das situações concretas, encontra o seu maior equívoco na falta de constatação de que a regra de experiência não precisa ter precisão absoluta e, mais do que isso, que é quase impossível dar credibilidade absoluta a uma regra de experiência ou mesmo a uma prova de um fato direto.

Como a presunção faz parte da valoração probatória, ela deve ser relacionada com outras eventuais presunções e provas, e por isso não há qualquer sentido em se impor uma regra de experiência de validade universal. O que importa é estabelecer o grau de aceitabilidade da regra na comunidade científica⁸³ (e, como antecedente, logicamente verificar se a técnica foi difundida em congressos e em revistas científicas especializadas), quem são os cientistas que a aceitam (se têm maior ou menor reconhecimento na comunidade), e, ainda, fixar qual é a exata discussão sobre ela.

Ao utilizar a regra de experiência técnica, o juiz deverá não apenas referir e explicar a regra científica, como também precisar o grau e a qualidade da sua aceitação, além de contextualizá-la em face do litígio e das eventuais outras provas e presunções. Além disso, nada impede que o juiz, nessa situação, determine a ouvida de um perito da sua confiança sobre a circunstância, dando às partes a oportunidade de indicar assistentes técnicos.

Vejamos, agora, a terceira hipótese, isto é, as regras que decorrem da observação do que ordinariamente acontece no manuseio de algumas técnicas. Aqui, ao contrário do que se pode supor, não há regra de experiência técnica, mas sim regra de experiência comum relacionada com o uso de alguma técnica, o que é algo completamente diverso. Portanto, é o momento de passar a enfrentar os critérios que podem gerar credibilidade nas regras de experiência comum.

As regras de experiência comuns têm relação com condutas individuais e sociais que se fundam

em leis supostamente científicas ou em observações da natureza ou outras regras vulgarizadas na sociedade.

É claro que o emprego dessas regras, assim como as regras de experiência técnicas, deve ser motivado pelo juiz, até para que se verifique em que o juiz se fundou e a partir de que razão. O problema é justamente o de saber se essa “razão”, em que o juiz se apegou, merece credibilidade.

Nessa linha, é preciso que o juiz explique o sentido da regra de experiência, ou em que consiste, para evitar que a ela seja atribuído um significado que não possui. Antes de tudo, porém, é necessário frisar que a regra de experiência comum deve ser aceita na sociedade em que a decisão vai ser tomada.

Quando há dúvida sobre a aceitação da regra pelo senso comum, é racional considerá-la como destituída de legitimação *in re ipsa*, e dessa forma como carecedora de própria e específica confirmação ou justificação.⁸⁴ Como diz Taruffo, somente as noções e informações que são clara e evidentemente patrimônio da cultura média do ambiente social em que a decisão é proferida podem ser utilizadas sem justificação específica, ao menos até que não sejam adotadas razões convincentes capazes de excluir o seu emprego.⁸⁵

A partir daí é preciso verificar se a regra de experiência eventualmente colide com uma regra de experiência técnica ou outra regra de experiência comum. Tratando-se de colisão com regra de experiência técnica, há de prevalecer essa última, pois seria completamente irracional aceitar a possibilidade de o juiz se valer de uma regra de experiência comum desacreditada pela ciência.⁸⁶

Mas nada impede que uma regra de experiência comum entre em choque com outra regra da mesma natureza. No caso em que, em princípio, duas regras de experiência comuns estão à disposição do juiz, não se pode admitir que ele possa escolher uma ou outra sem base ou critério racional, pois isso seria legitimar o arbítrio.⁸⁷

A regra de experiência comum, colida com outra de igual natureza ou não, sempre deve ser aferida em termos de probabilidade. Para tanto é preciso analisar a sua base empírica, ou melhor, o número de vezes em que a hipótese nela substanciada se repete.⁸⁸ O juiz deve apontar a probabilidade da regra de experiência para explicar o fato probando, não estando impedido, como já foi dito, de relacioná-las com outras provas ou presunções.

Se, diante da análise da base empírica de certa regra de experiência comum, verifica-se que ela comporta exceções, torna-se ainda mais evidente a necessidade de estabelecer uma ligação entre elas, o contexto do litígio e todos os argumentos (provas etc.) das partes. Nesse caso, como a credibilidade da regra de experiência é sensivelmente abalada, sua probabilidade resta ligada às demais circunstâncias do caso concreto.⁸⁹

Há, sob outro aspecto, uma nítida distinção entre a valoração individual da prova e a valoração do conjunto probatório.

A valoração individual tem o objetivo de verificar a relação entre uma certa prova e o fato. O que importa, nessa fase, é estabelecer se determinada prova demonstra a hipótese fática. Por isso, é acertado dizer que a própria valoração da prova integra-se à fase da valoração individual, uma vez que tem a intenção de evidenciar a aptidão de uma prova específica para demonstrar o fato. A valoração individual, assim, somente viabiliza a constatação de que uma prova demonstra o fato em determinado sentido e grau (obviamente não matemático).

É possível perguntar o local em que a presunção se insere entre a valoração individual e a valoração do conjunto probatório. Como dito, a presunção é um juízo, e não uma prova. Trata-se de juízo que decorre de raciocínio (que chamamos de presuntivo) que parte da prova de um fato indireto, isto é, de prova (indiciária) que se destina a demonstrar o fato indireto. Nesse caso, considerada a prova do fato indireto, o juiz raciocina, através de regras de experiência, para concluir se pode deduzir o fato direto do fato indireto (provado).

Não há qualquer dúvida que a valoração da prova indiciária é uma valoração individualizada. O problema é saber se valoração individualizada abarca a prova indiciária e a presunção (o juízo), ou se a presunção somente é formada quando da valoração do conjunto probatório.

Pois bem. A presunção se encontra, no iter do raciocínio judicial, entre a valoração da prova indiciária e a valoração do conjunto probatório. Dessa forma, é antecedente à valoração do conjunto das provas. Nesse sentido, aliás, é mais exato concluir que a valoração do conjunto probatório é, na realidade, a valoração dos argumentos de convicção, aí incluídas as provas e as presunções.

É certo que um determinado caso conflitivo pode comportar duas ou mais presunções, que assim podem convergir ou ter sentidos contrários. Portanto, a valoração do conjunto incluiu a valoração das presunções.

Não se pretende dizer, com isso, que uma prova ou uma presunção, após terem sido valoradas, não podem ser redimensionadas quando da valoração conjunta. O que se quer demonstrar, através da demarcação dos momentos de valoração, é que, dentro do raciocínio lógico, a valoração da prova, a valoração da presunção e a valoração do conjunto de argumentos têm momentos diferentes. Mas isso não teria maior importância se essa distinção não fosse fundamental para permitir o controle da racionalidade do raciocínio judicial.

Portanto, o que deve ficar claro é que a valoração individual e a valoração final não são excludentes – e esse obviamente não é o desejo de quem alude a elas – ou meramente complementares, mas sim dois momentos de um todo, ou algo que se forma a partir de partes inter-relacionadas.⁹⁰

Alguém poderia dizer que a valoração conjunta deve conduzir a uma boa história ou a uma história convincente. Ainda que isso guarde uma boa dose de procedência, é preciso esclarecer que essa história somente será convincente quando tomar em conta as valorações que lhe antecederam, isto é, as provas e as presunções.

A valoração conjunta se propõe à construção de uma história racional para a qual é fundamental a atenção às provas e às presunções. Seria supérfluo dizer que essa história deve levar em conta as presunções em sentido contrário e as provas da parte contrária.

Porém, não basta nem mesmo que o juiz se baseie nas provas e presunções quando lhe é viável elaborar duas ou mais histórias em princípio aceitáveis. Se as provas e as presunções permitem a elaboração de duas ou mais versões, cabe ao juiz estabelecer a melhor entre elas, ou, como escreve Taruffo, a “melhor” narração possível entre aquelas que parecem sensatas em relação ao caso concreto.⁹¹

Como se vê, agora o problema passa a ser o da fixação da melhor das versões. E, para tanto, mais uma vez surge a necessidade de critérios racionais justificáveis e controláveis.

Nesse sentido, Taruffo propõe a distinção entre duas dimensões do raciocínio que conduz à escolha da melhor das versões, ou seja, as dimensões analítica e sintética.⁹²

A primeira dimensão indica que o juiz deve escolher a versão que esteja baseada nas provas que outorguem convicção de verdade. As provas conferem a cada uma das várias hipóteses possíveis, relativas a cada um dos fatos, graus diversos de confirmação, sendo que a escolha racional deve ser a que prefere as hipóteses que geram, a partir dessas provas, a maior convicção e, por consequência, a versão que esteja mais profundamente ancorada nas provas disponíveis.⁹³

Afastese a ideia errônea de que a dimensão sintética se destina à valoração conjunta das várias valorações que foram feitas em relação a cada uma das provas. Isso nada tem a ver com a dimensão sintética, pois é o resultado do emprego do método analítico, que, ao enfrentar cada uma das provas, pode chegar à versão mais fortemente baseada no conjunto probatório.⁹⁴

Quando, a partir das provas, aparecem duas histórias (ou narrações) igualmente viáveis, surge

a necessidade de estabelecer mais um método de escolha racional. É quando passa a importar a perspectiva sintética e então entram em consideração os critérios da coerência e da congruência.⁹⁵

A dimensão sintética diz respeito à melhor história (narração) centrada sobre as provas dos fatos. Nessa dimensão não há racionalidade em preferir uma história cujos fatos careçam de prova ou se fundem em provas que ofereçam menor grau de convencimento.⁹⁶

Mas, se as provas estabelecidas na dimensão analítica dão origem a várias histórias, todas viáveis a partir das provas e relações de inferência já fixadas, não resta outra alternativa a não ser escolher a história que confira o maior grau de coerência e congruência.

As dimensões analítica e sintética não se excluem. Trata-se de perspectivas e dimensões diferentes, destinadas a possibilitar uma escolha racional das hipóteses em confronto. A perspectiva sintética não constitui uma alternativa à analítica, mas sim uma perspectiva complementar que pode ser utilizada para uma eventual escolha – quando essa escolha for necessária, ou seja, quando dos fatos provados não decorrer apenas uma história.

Ademais, ainda que alguns sustentem, simplesmente, que o juiz deve escolher a história de uma das partes, isto é, aquela que lhe parecer mais coerente independentemente das provas, não é possível ignorar que dessa maneira se admitiria que é possível escolher uma narração coerente, mas não verdadeira. Porém, a coerência narrativa tem relação com as diversas histórias que podem ser propostas em relação a um caso a partir das provas estabelecidas e, portanto, jamais se deve pensar que o critério da coerência é capaz de excluir a dimensão analítica.

Taruffo afirma que o processo não deve ter interesse nas narrações coerentes e falsas, porém nas narrações verdadeiras, ainda que incoerentes.⁹⁷ Essa afirmação, contudo, deve ser melhor ponderada.

É certo que a dimensão analítica prevalece sobre o critério narrativo, pois ninguém pode duvidar que o juiz deve preferir a versão ancorada nas provas. Acontece que uma versão, apesar de fundada nas provas, obviamente não tem que corresponder à “essência” da verdade (até porque essa não pode ser penetrada) e, por essa razão, não há motivo para excluir a tese de que há uma verdade construída no processo.

Essa “verdade” não precisa ser uma das propostas pelas partes, uma vez que o juiz pode construir a sua, sem ter a necessidade de optar por uma das narrativas dos conflitantes, pois nada impede – e até mesmo é comum – que o juiz aceite apenas parte da narrativa do autor e parte da narrativa do réu.⁹⁸

Isso quer dizer que a “verdade do processo” não precisa estar em uma das narrativas, mas evidentemente jamais vai alcançar um *status* que seja diferente da “verdade processual”, que não pode se desligar da participação dialética das partes.⁹⁹

Pois bem. Se o juiz não precisa se render a uma das narrativas das partes, não há como aceitar que ele possa admitir uma narrativa incoerente. Como a coerência é um critério complementar ao analítico, o juiz jamais poderá negar a perspectiva analítica para preferir o incoerente. Do mesmo modo, justamente porque a coerência pressupõe a passagem pela dimensão analítica, não há como aceitar que o juiz possa optar por uma narração coerente, mas falsa.

A menos que se pense em verdade e falsidade em termos absolutos (o que, como amplamente demonstrado, aqui é totalmente descabido). Ora, se o juiz não pode desprezar a dimensão analítica ao raciocinar sobre a coerência, é mais do que óbvio que não pode propor como coerente uma versão destituída de provas.

A ideia de narrativa coerente, porém falsa, só faz sentido quando se aceita a premissa de que o juiz deve optar por uma das narrações, sem poder construir a sua.

Quando se pensa na versão a ser estabelecida, não se pode negar a importância, também, da sua coerência lógica. Como demonstra Taruffo, relevam aí os elementos lógicos da versão,

basicamente os relacionados à não-contradição e à coerência inferencial.¹⁰⁰

Uma versão não-contraditória não pode aceitar um fato como verdadeiro e falso, admitir fatos incompatíveis como verdadeiros, ou empregar, em um mesmo contexto, regras de inferência também incompatíveis. Por outro lado, as inferências com que o juiz elabora as suas concatenações para ligar os fatos indiretos e diretos, objetivando formar juízos a partir das provas igualmente devem ser coerentes.¹⁰¹

Ainda que essas questões devam ser enfrentadas quando da fixação dos pontos controvertidos, da admissão e da valoração das provas e da elaboração das presunções, não há dúvida que a versão (das partes ou a fixada pelo juiz) não terá coerência lógica se contiver alguma dessas ilogicidades.

O discurso, ademais, deve ser congruente. Congruente é a narração que reflete o conjunto dos fatos, ou, em outras palavras, a que estabelece uma ligação com o conjunto dos fatos provados. A melhor versão, além de ausente de contradições, deve ser a que realmente espelha os fatos provados. A congruência, nesse sentido, é um teste de verificação da correspondência entre a narrativa judicial e os fatos provados.

Nessa perspectiva, Taruffo afirma que são incongruentes as histórias incompletas ou “supra-abundantes”.¹⁰²

No caso em que uma prova, parcela de uma prova, ou mesmo um fato provado não são tomados em consideração pela narrativa judicial, há incompletude. Não é incomum, com efeito, sentenças que deixam de referir a determinados depoimentos testemunhais, a parte deles, ou ainda a fatos provados.

Por outro lado, são muito frequentes as decisões que referem apenas às provas que confirmam a versão da parte vencedora ou, o que é pior, decisões que retalham as provas para dar fundamento à versão do vencedor. Como é evidente, aqui não estamos na dimensão do raciocínio decisório, mas sim na do raciocínio justificativo, pois o juiz não está buscando critérios racionais para decidir, mas sim argumentos para justificar como decidiu.

Porém, o fato de o juiz ter que justificar, e não mais decidir, obviamente não lhe dá o direito de apenas lembrar as provas que apontam na direção da versão da parte vencedora, como justificar fosse somente argumentar em favor da parte que venceu, e não argumentar em favor da decisão mesma. Ora, se o juiz preferiu as provas A e B – que favorecem o autor – em detrimento da prova C – que beneficia o réu – não basta fazer referência às provas A e B, sendo necessário explicar a razão pela qual a prova C não lhe convenceu.

Nessa altura, alguém poderia dizer que o juiz não precisa assim proceder, pois a aceitação das provas A e B implica na rejeição implícita da prova C. Essa ideia, contudo, não pode ter guarida, pois não há como pensar em justificação implícita, que, na realidade, é uma maneira de acobertar a inexistência de justificação. Ora, é preciso que o juiz faça referência a todas as provas, explicitando os motivos que o levaram a acolher umas e não outras.

Não é possível identificar – embora lamentavelmente isso não seja incomum – a desnecessidade de o juiz enfrentar todos os fundamentos de direito das partes, com uma imprópria desnecessidade de o juiz analisar as provas que não beneficiam a parte vencedora. Quando um dos fundamentos de direito é suficiente para o acolhimento do pedido, não há razão para o juiz explicar porque o outro fundamento, também trazido pelo autor, não mereceu acolhida. No caso oposto ocorre o mesmo, pois se um dos fundamentos leva à improcedência, não há porque justificar que os outros não levam.

Nessas situações nenhum prejuízo é trazido à parte que articulou mais de um fundamento, diante da lembrança expressa contida no art. 1.013, § 2.º, do CPC: “quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais”. Isso quer dizer que, se o tribunal chegar à conclusão que o

fundamento acolhido pela sentença não tem procedência, ele poderá apreciar os outros ainda que a parte vencedora não tenha interposto recurso.

Caso o entendimento fosse no sentido de que o juiz deve apreciar todos os fundamentos, ou o outro fundamento seria acolhido – e o pedido julgado procedente com base em dois fundamentos – ou rejeitado – quando a parte vencedora continuaria na mesma situação. A conclusão que daí se pode retirar é que não há motivo para a apreciação do outro fundamento, pois a sua não apreciação não pode prejudicar as partes, o que não acontece na hipótese de várias provas, umas favoráveis ao autor e outras ao réu. Ora, é claro que a parte perdedora tem interesse nas provas que lhes são favoráveis e, assim, tem direito de saber a razão pela qual elas não foram acolhidas.

Também é incongruente, e nesse caso por “supra-abundância”, a narrativa que se refere a um fato alegado, mas não provado. Em tal hipótese a decisão estaria, no mínimo, ferindo a regra do ônus da prova.¹⁰³

Como é óbvio, nada impede que uma mesma sentença sofra dos dois males, por não admitir uma prova ou um fato provado e admitir um fato não provado.¹⁰⁴

No artigo “Funzione della prova: la funzione dimostrativa”, Taruffo adverte que a coerência e a congruência podem ser consideradas através de um critério de graus, pois a coerência e a congruência de uma narração, como é óbvio, pode ser maior ou menor.¹⁰⁵

Nessa situação, o que se objetiva é verificar a coerência e a congruência de duas versões viáveis a partir dos fatos, e não, evidentemente, a correção da narrativa judicial.

Se o que interessa é a escolha da melhor história, é claro que a decisão do juiz, para ser considerada racional, deve escolher aquela que seja mais coerente e congruente.¹⁰⁶

Enfim, se ninguém nega a importância da motivação como garantia do cidadão, pouco importa alardear isso de forma demagógica. Se o juiz tem o dever de motivar a sentença, é preciso que ele possa decidir com base em “critérios racionais explicáveis”. Ou melhor, é necessário que a decisão se funde em “critérios racionais” e, além disso, que esses sejam “racionalmente justificados ou explicados”. Como se vê, não basta apenas que a decisão se funde em critérios racionais, pois é preciso, ademais, que o juiz justifique racionalmente a sua decisão.¹⁰⁷

A importância disso tudo, além de obviamente relacionada à legitimidade da função jurisdicional – uma vez que a justificação também é importante para dar conta das razões do juiz perante o público –, está em conferir ao litigante a possibilidade de controlar a decisão.

Quando do controle da racionalidade da justificação, será possível verificar se a versão fática está evidenciada por meio de provas e se os critérios de valoração da prova e de relação entre as várias hipóteses fáticas e as provas, especialmente as regras de experiência, são dotados de racionalidade.

Além disso, a justificativa judicial também poderá ser submetida aos exames da coerência e da congruência, pois não há cabimento em aceitar uma decisão que, em princípio, está ancorada em provas, se essa apresenta contradições (incoerência) ou, ainda, por exemplo, sofre do vício da incompletude (incongruência). De modo que, quando se pensa no controle da decisão, não há razão para priorizar o método analítico em face do sintético.

Contudo, como já foi dito, algo um pouco diverso acontece quando se pensa no desenvolvimento do raciocínio judicial que conduz à decisão. É que aí os métodos analítico e sintético têm a função de viabilizar os raciocínios probatório e decisório e, dessa forma, a própria decisão, ao passo que, no controle da decisão, a consideração de tais métodos têm o objetivo de permitir a verificação da racionalidade da justificativa da decisão. Perceba-se que, na primeira hipótese, o juiz deve racionalizar o seu raciocínio para chegar à decisão e, na outra, o tribunal – ou alguém externo ao juiz – é que vai verificar se a justificativa é racional.

Quando o juiz está desenvolvendo o raciocínio que objetiva culminar na decisão, ele poderá

pensar na coerência e na congruência das versões das partes e, inclusive, propor aquela que, nessa perspectiva, lhe parecer adequada. Mas quando se toma em consideração a justificativa – que, como já foi lembrado, trabalha com argumentos e não testando hipóteses –, não mais importará a coerência e a congruência como métodos destinados a fornecer uma decisão – até porque essa já existe –, mas sim a coerência e a congruência como qualidades imprescindíveis à própria justificativa, cuja ausência pode ser apontada pelo tribunal em razão do recurso.

Quando do raciocínio decisório, como já dito, não há como aceitar que o juiz possa fazer prevalecer – ou mesmo propor – uma determinada história – por lhe parecer coerente –, em detrimento das provas. Somente há necessidade de um método de escolha quando, a partir das provas, surgem duas histórias igualmente viáveis. Nesse momento, então, é que o juiz vai buscar a história que lhe pareça mais coerente e congruente.

Isso quer dizer que os métodos analítico e sintético são sempre complementares, embora tenham funções diferentes diante do raciocínio decisório e do raciocínio justificativo. Salaverría, sem atentar para a dupla função desses métodos, afirma que “la manera de justificar la verdad” de uma proposição “pasa por el test de la narración coherente”. Como é evidente, o jurista espanhol, nessa perspectiva, está pensando no controle da decisão. Diz ele: “la coherencia no constituye la verdad pero la garantiza”.¹⁰⁸ Ao que parece, essa afirmação supõe que a prova concretiza a verdade e a coerência lhe garante.

Acontece que a prova não permite, por si só, nem mesmo o encontro da “verdade processual”, pois podem existir, a partir dela, duas versões viáveis, quando tal verdade seria encontrada através do método sintético. Por consequência, ou precisamente pela razão de que a coerência também é um critério para a fixação da verdade processual, é equivocado dizer que ela serve apenas para “garantir a verdade”. Ela serve, isto sim, para viabilizar a decisão e para permitir o controle da sua justificativa.

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

1. Prova emprestada

Prova emprestada é aquela que, produzida em outro processo, é trazida para ser utilizada em processo em que surge interesse em seu uso. Trata-se de evitar, com isso, a repetição inútil de atos processuais, otimizando-se, ao máximo, as provas já produzidas perante a jurisdição, permitindo-se, por consequência, seu aproveitamento em demanda pendente. Entretanto, não é apenas a ideia de aproveitamento de atos que importa, quando se pensa em prova emprestada. Eventualmente, pode acontecer que a prova não possa mais ser colhida, por alguma circunstância, motivo mais que suficiente para autorizar, ao menos em princípio, a tomada de empréstimo da prova já realizada em outro processo.

A legitimidade da prova emprestada depende da observância do direito ao contraditório. Daí a razão pela qual o art. 372 estabelece que a valoração da prova emprestada sujeita-se ao juízo racional do magistrado, mas depende da observância do contraditório.

A prova pode ser trasladada de um processo a outro, desde que as partes do processo para o qual a prova deve ser trasladada tenham participado adequadamente em contraditório do processo em que a prova foi produzida originariamente. Sabe-se que o exercício do poder estatal através do processo jurisdicional há de ser legítimo, e a legitimidade do exercício desse poder somente pode ser conferida pela abertura à participação dos contendores. Em outras palavras: se o processo jurisdicional deve refletir o Estado Democrático de Direito, sua ideia básica é garantir aos interessados participação efetiva no procedimento que vai levar à edição da decisão.

É certo que a efetividade do acesso à justiça depende da racionalização da prática de atos processuais e está intimamente ligada à possibilidade de se poder alegar e provar, mas tudo isso deve ser temperado diante do direito que os interessados na solução do litígio têm de adequadamente participar da aquisição da prova que vai importar para a formação do juízo. Aliás,

esse direito garantido às partes também possui importância fundamental para que a própria jurisdição possa cumprir sua obrigação de forma perfeita e legítima.

2. Prova emprestada e contraditório posterior

Considerando essas premissas, é possível enxergar três situações distintas. Inicialmente, pode-se cogitar a respeito da aceitação do uso da prova emprestada em relação a meios de prova que sempre admitem o contraditório integral posteriormente à sua produção. É o caso da prova documental. Essa prova – não importa o momento em que tenha sido colhida ou o processo em que tenha sido produzida – sempre admite que as partes possam exercer seu direito de contraditório – seja pela produção de prova contrária, seja pela impugnação do seu teor ou das suas formalidades. Em relação a tal meio de prova não há dificuldade em aceitar o empréstimo, ressalvados os casos em que outras garantias possam interferir em seu traslado.

3. Prova emprestada não documental e mesmas partes

Em segundo lugar, pode-se imaginar a tentativa de empréstimo de uma prova (não documental) de um processo para outro, ambos contendo as mesmas partes. Nessa hipótese também não há dificuldade em aceitar a prova emprestada. Havendo, excepcionalmente, necessidade de se cogitar sobre novos fatos, ou sobre novos enfoques dados aos fatos – v.g., a necessidade de ouvir a testemunha a respeito de outra questão, ou sobre aspecto da questão não examinado no processo anterior –, somente será possível emprestar a prova se for viável reabrir o contraditório a seu respeito ou, ao menos, separar a prova anterior dos novos aspectos, permitindo-se a produção de nova prova sobre as questões não abordadas anteriormente.

4. Prova emprestada e litigantes distintos

Por fim, cabe imaginar a situação em que se busca emprestar prova de um processo, em que litigaram “A” e “B”, para um processo entre “A” e “C”, ou para um processo entre “C” e “D”. Nessas hipóteses, ou apenas uma das partes é identificada com a do processo em que a prova foi produzida, ou nenhuma das partes é idêntica. Em tais situações, como o contraditório das partes não foi garantido na produção da prova, será necessário examinar se é possível cumprir com tal garantia no processo para o qual se pretende exportar a prova. Sempre que for possível garantir o contraditório – com a mesma eficácia que se teria caso o contraditório houvesse sido observado no processo primitivo –, o empréstimo da prova será admissível. Caso contrário, em princípio, a prova emprestada será inviável.

De todo modo, o contraditório não pode ser o único critério considerado. Eventualmente, ainda que não se consiga mais efetivar o contraditório em relação à prova, haverá situação em que a proibição do seu uso redundará na impossibilidade de se sustentar certa pretensão em juízo. Imagine-se, por exemplo, caso em que a única prova que se possui foi produzida em processo em que o contraditório não pode ser reconstituído (ou porque as partes são distintas, ou porque há elementos não recuperáveis etc.). Ter-se-á, aqui, verdadeiro conflito de direitos fundamentais processuais (entre o direito ao contraditório e o direito à tutela jurisdicional), que evidentemente não pode preferir, de forma abstrata, uma ou outra posição. Haverá necessidade de se ponderar os direitos fundamentais em colisão conforme as circunstâncias do caso concreto, aplicando-se a regra da proporcionalidade.¹⁰⁹

5. Prova emprestada e colisão de interesses fundamentais

Identicamente, pode ocorrer que o uso da prova emprestada esbarre em outros direitos fundamentais, a exemplo do sigilo ou da intimidade. Suponha-se a intenção de se utilizar prova de processo havido entre “A” e “B” em processo composto por partes diferentes, e que a prova em questão implique alguma restrição à intimidade de “A” ou de “B”. A violação dessa intimidade em processo em que o interessado é parte pode ser admitida, mas será mais dificilmente aceita

quando o litígio envolver outros sujeitos. Mais uma vez, somente a consideração do caso concreto – à vista dos direitos envolvidos – poderá oferecer solução adequada à situação e resposta sobre a possibilidade do uso da prova emprestada.

De qualquer forma, é claro que a prova emprestada poderá não receber a mesma valoração da obtida no processo em que foi originariamente produzida. As circunstâncias do segundo processo, as particularidades do empréstimo e mesmo a variação na efetivação do contraditório podem impor valoração diferente à prova, caso comparada com a força que lhe foi atribuída no primeiro processo. Tudo isso, logicamente, deverá ser adequadamente examinado e motivado pelo juiz do segundo processo, considerando-se as necessidades de convicção judicial e de motivação das decisões.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1.º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2.º A decisão prevista no § 1.º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3.º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I – recair sobre direito indisponível da parte;

II – tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4.º A convenção de que trata o § 3.º pode ser celebrada antes ou durante o processo.

1. O sentido da distribuição do ônus da prova

A regra do art. 373, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Não há racionalidade em exigir que alguém que afirma um direito deva ser obrigado a se referir a fatos que impedem o seu reconhecimento pelo juiz. Isso deve ser feito por aquele que pretende que o direito não seja reconhecido, isto é, pelo réu.

Na Alemanha, onde não há norma similar a do art. 373 – que expressamente prevê a distribuição da prova entre as partes – a ideia de distribuição do ônus da prova segue a mesma lógica. Argumenta-se que a parte que pretende ser beneficiada pelos efeitos de uma norma deve provar os pressupostos fáticos para a sua aplicação. Se para a aplicação de uma norma são relevantes os fatos constitutivos, impeditivos, modificativos e extintivos, aquele que deseja a produção dos seus efeitos deve provar somente os fatos que são exigidos para a sua aplicação, e não os que impedem a sua aplicação, ou modificam ou extinguem o direito. Na ausência de regra expressa sobre a divisão do ônus da prova, a doutrina alemã, desenvolvendo a ideia de que a discussão em torno da aplicação de uma norma pode girar em torno dos fatos constitutivos, impeditivos, modificativos e extintivos, chegou à conclusão lógica de que o autor somente deveria provar os fatos pressupostos para a aplicação da norma, e o réu os fatos impeditivos, modificativos

ou extintivos. Por isso, a teoria que expressou tal problemática ficou conhecida como Normentheorie.¹¹⁰

Afirma-se que a regra do ônus da prova se destina a iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se convencer sobre como os fatos se passaram. Nesse sentido, a regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos.¹¹¹

Mas, não há como entender que o art. 373, quando dirigido ao juiz, é uma mera regra de decisão. Mesmo quando se pensa tal regra como dirigida apenas ao juiz – e não às partes – não há como deixar de separar a sua aplicação como regra de decisão e como regra determinante da formação do convencimento judicial.

Quando a doutrina considera a regra do ônus da prova em relação ao juiz, supõe que a sua única função é a de viabilizar a decisão no caso de dúvida. Nessa linha, por exemplo, Patti afirma que tal regra confere ao juiz a oportunidade de acolher ou rejeitar a demanda quando, não obstante a atividade probatória das partes – ou mesmo na sua ausência – ele esteja em dúvida em relação à “verdade” dos fatos.¹¹²

É certo que o juiz pode se convencer ainda que o ônus da prova não tenha sido cumprido. Lembre-se de que o juiz pode determinar a produção de prova de ofício ou mesmo se convencer mediante prova produzida pela outra parte. Nessa situação, diante da inexistência de dúvida, realmente não há razão para o juiz invocar a regra do ônus da prova como regra de decisão e, nessa perspectiva, é correta a conclusão de que a regra do ônus da prova somente deve importar em caso de dúvida.

Acontece que esse raciocínio somente é exato quando se toma a regra do ônus da prova como regra de decisão, ou seja, como regra que passa a importar apenas depois de o juiz ter passado pela fase do convencimento e, obviamente, ter restado em estado de dúvida. Ou melhor, a insistência de que a regra do ônus da prova, quando dirigida ao juiz, importa apenas quando há dúvida, decorre da falta de constatação de que o juiz somente pode decidir depois de ter passado pela fase de convicção.

Na fase de convicção, e, portanto, antes de ter chegado a uma eventual dúvida, o juiz deve considerar não só a natureza dos fatos em discussão e a quem incumbe a sua prova, mas também a natureza da situação concreta a ele levada para julgamento. Como já foi dito, a chamada técnica da verossimilhança atua em casos excepcionais, ou seja, diante de específicas situações de direito substancial, que exigem que o convencimento judicial possa se formar a partir da verossimilhança do direito sustentado pelo autor. Assim, por exemplo, os casos das chamadas lesões pré-natais, quando não há racionalidade em exigir do autor, para a procedência da ação ressarcitória, a prova de que a doença do recém-nascido deriva do acidente que a sua mãe sofreu quando em gestação.

Em um caso como esse, como é pouco mais do que óbvio, a ausência de prova não leva o juiz a um estado de dúvida, que teria que ser dissipada através da aplicação da regra do ônus da prova como regra de decisão, julgando-se improcedente o pedido pelo motivo de o autor não ter se desincumbido do ônus da prova. E isso por uma razão bastante simples: o juiz, nesses casos, não finaliza a fase de convencimento em estado de dúvida. Estar convicto que a verossimilhança é o bastante não é o mesmo que estar em dúvida.

Quando se fala que a regra do art. 373 importa para a formação do convencimento, deseja-se dizer que ela pode ser atenuada diante de determinadas situações de direito substancial. Perceba-se que, ao se admitir que a técnica da verossimilhança tem a ver com a formação do convencimento judicial, fica fácil explicar porque o juiz, ao considerar o direito material em litígio, não deve se preocupar com a prova de determinados fatos, considerados de impossível esclarecimento. Se o juiz para decidir deve passar por um contexto de descoberta, é necessário que ele saiba não apenas o objeto que deve descobrir, mas também se esse objeto pode ser totalmente

descoberto. Apenas nesse sentido é que o convencimento, considerado como expressão do juiz, pode ser compreendido. Ou melhor, o convencimento judicial somente pode ser pensado a partir do módulo de convencimento próprio a uma específica situação de direito material, pois o juiz somente pode se dizer convencido quando sabe até onde o objeto do seu conhecimento abre oportunidade para o convencimento.

A exigência de convencimento varia conforme a situação de direito material e, por isso, não se pode exigir um convencimento judicial unitário para todas as situações concretas. Como o convencimento varia de acordo com o direito material, a regra do ônus da prova também não pode ser vista sempre do mesmo modo, sem considerar a dificuldade de convicção própria ao caso concreto.

Quando a regra do ônus da prova passa a considerar a convicção diante do caso concreto, ela passa a ser responsável pela formação da convicção, que pode ser de certeza ou de verossimilhança. Ou melhor, pode ser de verossimilhança sem ser de dúvida. Como o convencimento antecede a decisão, não há como aceitar a ideia de que a regra do ônus da prova somente tem importância para permitir a decisão em caso de dúvida, e não para a formação do convencimento. Ora, o juiz que decide com base em verossimilhança não está em estado de dúvida, ao contrário, ele está convencido de que a verossimilhança basta diante das circunstâncias do caso concreto. É claro que o juiz pode reduzir o rigor da regra do ônus da prova na decisão. Mas aí já terá se convencido da verossimilhança.

Lembre-se, como argumento, de que embora se dê ao réu a oportunidade de produzir prova para tentar demonstrar a inexistência do fato constitutivo – a chamada contraprova – não se pode admitir que o réu produza prova para demonstrar que um determinado fato que interessa ao autor não pode ser esclarecido, quando a dúvida, em relação a ele, não impedir a formação da convicção de verossimilhança. A não admissão dessa prova, como é óbvio, faz parte do raciocínio judicial que se destina a formar o convencimento de modo que a sua racionalidade sequer pode ser aferida quando desligada da convicção inerente à específica situação de direito material em litígio.

Porém, a regra do ônus da prova não se dirige apenas ao juiz, mas também às partes, com o fim de dar-lhes ciência de que a prova dos fatos constitutivos cabe ao autor, e a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao réu.

Como já foi dito, ninguém duvida que o juiz pode julgar favoravelmente à parte que não cumpriu o ônus da prova, uma vez que o julgamento pode se basear em provas produzidas de ofício ou mesmo em provas produzidas pela parte contrária. Mas, isso não retira a importância de que as partes saibam, de forma prévia, a quem incumbe o ônus da prova, pois se esse ônus não precisa ser necessariamente observado para que a parte obtenha um resultado favorável – e nesse sentido seria correto sustentar que o ônus da prova não é um verdadeiro “ônus”, como será melhor explicado no próximo item –, não há como negar que a parte deve ter ciência prévia do que deve fazer para ter um julgamento favorável independentemente de outras provas, produzidas de ofício ou pela parte contrária.

2. Conceito de ônus, ônus da prova e risco na não produção da prova

O conceito de ônus foi objeto de calorosos debates entre alguns dos mais importantes expoentes da Teoria Geral do Direito. Centralizou-se a discussão teórica na busca por uma decantação de outros conceitos tais como o dever, a obrigação, a sujeição e a faculdade.¹¹³

Deve-se a Canelutti, passos importantes para a definição de “ônus”. Em um primeiro momento, tomando por critério o grau de liberdade do sujeito, o autor classificou o ônus como espécie de “dever” em sentido amplo. Os “deveres”, em sentido amplo, teriam como expressão máxima da ausência de liberdade à sujeição, mitigada progressivamente pela obrigação, pelo ônus e pela faculdade.¹¹⁴

A sujeição representa a total ausência de liberdade do sujeito, que nada pode fazer, senão

“sujeitar-se” ao comando normativo. Na obrigação, não obstante a existência de um comando determinando um agir, existe para o indivíduo a liberdade de infringir, sofrendo a sanção correspondente; caso cumprida a obrigação, o cumprimento corresponde a um interesse de outrem, proveniente de um vínculo jurídico. Diante do ônus, o sujeito tem liberdade para agir segundo seus próprios interesses – em conformidade ou em desconformidade. Caso decida desconsiderar o comando normativo, não comete ilícito algum ou sofre qualquer sanção jurídica. Como diz Carnelutti, a pedra de toque para distinguir ônus de obrigação consiste em verificar se a violação do preceito pode ou não ser definida como ato ilícito.¹¹⁵

Razões semelhantes servem para diferenciar o ônus dos deveres em sentido estrito. A relação processual é permeada por diversos “deveres processuais”, como o dever de se comportar no processo de boa-fé. Trata-se de comando, reforçado por sanção, que condiciona o comportamento das partes, especialmente no interesse público de probidade, no desenvolvimento do processo. No caso do descumprimento desse dever, resta caracterizado um ilícito.

Contudo, não basta diferenciar o “ônus” da obrigação e do dever em sentido estrito. Em termos da correlação de poderes entre as partes, mais do que diferenciar o “ônus” da obrigação e do dever, torna-se incontroverso o fato de que, “todo aquele que age, ou deixa de agir, a partir de um ônus, o faz estando em uma posição subjetiva jurídica ativa na relação processual”.¹¹⁶

Nesse sentido, incide em equívoco a doutrina que classifica o ônus como espécie de dever, pois o ônus representa um poder. Porém, o poder proveniente de um ônus é diverso do poder derivado de um direito subjetivo, já que o titular do direito subjetivo, em sua configuração dinâmica, possui uma “pretensão” ao comportamento de outrem, que suporta o correlato dever jurídico específico de comportamento.

Lembre-se, como exemplo, da diferença entre o direito à prova,¹¹⁷ que tem por correlato o dever de o Estado garantir aos jurisdicionados a utilização de todos os meios de prova adequados para a tutela dos direitos, e o ônus da prova, poder da parte produzir prova com a finalidade de convencer o juiz.

Nessa linha, fica claro que o exercício do ônus não possui correlação com o comportamento da outra parte, sendo satisfeito com o agir voluntário daquele que detém essa espécie de poder. Mas, por ser espécie de poder da parte, o ônus assemelha-se à faculdade.

Porém, outras peculiaridades permitem uma maior precisão ao conceito de ônus. Se no ônus e na faculdade a atuação da parte possui fundamento em um interesse pessoal, no ônus, a lei determina o comportamento a ser adotado e o risco em contrariá-lo, enquanto que, na faculdade, tal escolha permanece totalmente no foro íntimo da parte, diminuindo a previsibilidade dos efeitos do comportamento.

É possível sintetizar o conceito de ônus como espécie de poder da parte que possibilita o agir, segundo interesses próprios, não obstante a existência de norma pré-determinada, cuja inobservância pode trazer prejuízos à própria parte onerada.¹¹⁸

Entretanto, há uma questão, já levantada no item anterior, que agora pode ser melhor explicada. A ideia de ônus costuma ser ligada a um comportamento necessário para a obtenção de um efeito favorável, ao passo que, diante do ônus da prova, a parte onerada pode obter um resultado favorável mesmo sem cumprir o seu ônus, isto é, ainda que sem produzir prova. Lembre-se que nada impede que o julgamento favorável ao autor se funde em provas produzidas de ofício ou pela parte adversa.

Isso indica, com clareza, que a produção de prova não é um comportamento necessário para o julgamento favorável – ou para o resultado favorável. Na verdade, o ônus da prova indica que a parte que não produzir prova se sujeitará ao risco de um resultado desfavorável, ou seja, o descumprimento do ônus não implica, necessariamente, um resultado desfavorável, mas no aumento do risco de um julgamento contrário, uma vez que, como precisamente adverte Patti, “una certa percentuale di rischio sussiste anche per la parte che ha fornito la prova”.¹¹⁹

A ideia de ônus da prova não tem o objetivo de ligar a produção da prova a um resultado favorável, mas sim o de relacionar a produção da prova a uma maior chance de convencimento do juiz.

3. Fatos constitutivos, impeditivos, modificativos e extintivos

Mas, se o ônus ou o risco da não produção da prova deve ser distribuído entre o autor e o réu segundo a natureza dos fatos, ou melhor, conforme sejam eles constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos, chega a ser intuitiva a necessidade de análise dos seus conceitos.

Discorrendo sobre os fatos jurídicos, afirma Chiovenda que os fatos constitutivos são aqueles que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém, e exemplifica fazendo referência ao empréstimo, ao testamento, ao ato ilícito e ao matrimônio. Os fatos extintivos são aqueles que “fazem cessar uma vontade concreta de lei e a consequente expectativa de um bem” (v.g., pagamento),¹²⁰ ao passo que os modificativos pressupõem válida a constituição do direito, mas tendem a alterá-lo”. Trata-se de fatos que modificam o direito (v.g., a moratória concedida ao devedor).¹²¹

De acordo com a doutrina chiovendiana, as circunstâncias de fato que têm por escopo específico dar vida a um direito e que normalmente produzem esse efeito podem ser chamados de fatos constitutivos, porém, para que essas circunstâncias possam dar vida a um direito devem se apresentar outras, cuja falta impede que o direito possa ter vida. Quando falta uma das circunstâncias que devem concorrer com os fatos constitutivos há um fato impeditivo.¹²² Vejamos a explicação, à luz do direito italiano, realizada por Chiovenda: “Todo direito nasce de determinadas circunstâncias que têm por função específica dar-lhe vida: contudo para produzirem o efeito que lhes é próprio, normal, devem concorrer outras circunstâncias (...). A posse da coisa móvel pelo vendedor é a condição específica (fato constitutivo) para que o comprador lhe adquira a propriedade, ainda que a coisa não pertencesse ao vendedor: não obstante se o comprador obrou de má-fé, esse efeito não se produz;¹²³ assim se o proprietário perdera a coisa. Em tais hipóteses a incapacidade, a violência, o dolo, o erro, a simulação, a ilicitude, a má-fé, a qualidade de coisa perdida funcionam como fatos impeditivos do direito; e da mesma forma toda a circunstância que obste a um fato produzir o efeito que lhe é normal, que constitua a razão de sua existência”.¹²⁴

Não é difícil perceber que o maior problema, para a compreensão disso tudo, reside na qualificação dos fatos impeditivos, pois o fato impeditivo não pode ser tido como o contrário do fato constitutivo. O fato impeditivo não impede a formação da *fattispecie* da qual o fato constitutivo faz parte e visa constituir. O fato impeditivo não é um elemento que integra a *fattispecie*, mas sim algo que está do seu lado de fora, e assim apenas impede que o fato constitutivo produza os seus efeitos. Vale dizer, o fato constitutivo é sempre suficiente para dar origem a *fattispecie*, mas o fato impeditivo retira a sua eficácia ou impede que ela produza efeitos. É nesse sentido que se diz que o fato impeditivo atua externamente sobre a eficácia do fato constitutivo, ou melhor, impede que a *fattispecie* produza efeitos ainda que os seus elementos constitutivos estejam presentes.¹²⁵

Para auxiliar a compreensão, Patti lança mão da *fattispecie* da aquisição da posse útil para a usucapião em relação ao fato impeditivo tolerância, previsto no art. 1144 do Código Civil italiano, que afirma que os atos praticados com a tolerância alheia não podem servir de fundamento à aquisição da posse. Lembra que a jurisprudência italiana já chegou a afirmar que a tolerância elimina o *animus possidendi*, e assim um dos elementos constitutivos, mas que esse entendimento incide no equívoco de não perceber que aquele que pratica os atos pode não conhecer a tolerância do titular do direito, ou não a levar em consideração, ainda que com conhecimento. Ou seja, a tolerância não elimina o *animus possidendi*, ou esse elemento constitutivo, mas apenas a aquisição da posse.¹²⁶ A tolerância impede que a *fattispecie*, constituída pelo *animus possidendi*, produza os seus efeitos.¹²⁷

Por fim, e agora para relacionar, de forma didática, as várias espécies de fatos antes

consideradas, vale lembrar o seguinte: se o autor pede o pagamento da dívida e o réu alega que ela foi parcelada, somente podendo ser exigida em parte, o fato é modificativo; se o réu alega o pagamento, o fato é extintivo; se o réu afirma a exceção de contrato não cumprido, o fato é impeditivo.¹²⁸

A relevância dessa análise está em que situar um fato corretamente, entre os fatos constitutivos, extintivos, impeditivos ou modificativos, é imprescindível para a correta distribuição do ônus da prova,¹²⁹ como também para a adequada compreensão da tutela antecipatória fundada em abuso de direito de defesa, ou seja, da antecipação da tutela que pode ser concedida quando há controvérsia apenas em relação aos fatos que devem ser provados pelo réu.¹³⁰

É preciso observar, contudo, que a distribuição do ônus da prova a partir da classificação dos fatos pode ser vista como um mecanismo artificial, ou melhor, como algo comprometido com a própria natureza universalista do procedimento ordinário, que distribui os riscos do processo e o ônus da prova sem qualquer atenção para o que ocorre no plano do direito material e na realidade da vida.

A distribuição do ônus da prova não pode deixar de considerar as especificidades das situações de direito material. Para tanto, além das presunções legais relativas, são importantes normas particulares ligadas a determinadas situações de direito substancial que prevejam uma distribuição do ônus da prova diferenciada em relação à regra geral do art. 373 ou a possibilidade da atenuação do rigor dessa regra ou ainda a possibilidade de inversão do ônus da prova. Além disso, nada impede, na ausência dessas normas, que o próprio juiz, considerando a situação de direito material controvertida, trate de forma particularizada a questão do ônus da prova, logicamente, justificando o seu procedimento.

4. Prova dos fatos impeditivo, modificativo e extintivo e contraprova

Cabe esclarecer a distinção entre a prova dos fatos impeditivo, modificativo e extintivo e a contraprova. Tal distinção, na verdade, não recai sobre a prova, mas sim sobre o fato que a prova objetiva demonstrar.¹³¹

Há contraprova quando o réu contesta o fato constitutivo e requer prova em relação a ele. A contraprova não é apenas a que objetiva invalidar formalmente a prova do fato constitutivo, como a que visa demonstrar a falsidade do documento que aponta para o fato constitutivo. A contraprova diz respeito ao próprio fato constitutivo, e não apenas à sua prova. Se o autor produziu prova documental ou testemunhal, a contraprova pode demonstrar o contrário do que essas provas trazem em seu conteúdo. Assim, por exemplo, se o autor produziu prova testemunhal para demonstrar que o réu atravessou o sinal vermelho, o réu produz contraprova quando requer a ouvida de uma testemunha para dizer o contrário.

Quando o réu não contesta o fato constitutivo, mas afirma um fato capaz de impedir que o fato constitutivo produza os seus efeitos, ou fatos que impliquem na modificação ou na extinção do direito, não há como pensar em contraprova pela simples razão de que não houve contestação ao fato constitutivo.

Perceba-se que não é pela razão de que ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo que o réu não poderá produzir prova em relação a ele. O réu tem o ônus de contestar de forma adequada e especificada os fatos alegados na petição inicial, podendo requerer a produção de prova, ou a contraprova, para demonstrar a inexistência do fato alegado pelo autor.

É lógico afirmar que a contraprova somente tem razão de ser quando o autor produziu alguma prova do fato constitutivo, ou existe algum argumento de prova capaz de evidenciar a sua existência. Acontece que na contestação, ou mesmo momentos antes da audiência preliminar, o réu apenas pode saber que uma determinada prova foi requerida, mas nunca ter certeza de que foi admitida. Por isso, o réu pode requerer contraprova, mesmo que a prova requerida pelo autor ainda não tenha sido admitida.

5. Ônus da prova e ônus da alegação

Em princípio – de lado a contraprova – a parte somente pode e precisa provar as suas afirmações de fato. Basicamente os fatos relevantes e os fatos indiciários que a ele estão ligados.

A questão que interessa ao presente item diz respeito a se saber se a parte pode ser dispensada de provar algum fato alegado e, ainda, se pode provar um fato não alegado. O desenvolvimento dessa questão demonstrará a lógica da separação entre ônus da prova e ônus da alegação.

Pois bem, como será visto com mais vagar quando dos comentários ao próximo artigo, o art. 374 afirma expressamente, em quatro incisos, que não dependem de prova os fatos: i) notórios; ii) afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; iii) admitidos, no processo, como incontroversos; e iv) em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Diante disso, a única dúvida que aqui poderia existir diz respeito aos fatos notórios, pois os outros, como é evidente, devem ser afirmados. Alguém poderia imaginar que o fato notório não precisa ser afirmado, uma vez que é de conhecimento público. Porém, quando a parte pretende retirar uma consequência de um fato, seja ele notório ou não, deve evidentemente alegá-lo. A particularidade que incide sobre o notório é apenas a de que ele não precisa ser provado.

A confusão que aí ocorre é fruto da ausência de distinção entre afirmação de fato, como componente da pretensão, e regra de experiência,¹³² que nada mais é do que uma regra de juízo. Quando um fato constitui uma regra de experiência, essa é uma regra da qual o juiz se vale para julgar o litígio e, assim, os fatos que lhe dão conteúdo. Nessa perspectiva, a regra de experiência tem semelhança com uma regra de direito. Ao contrário, o fato notório faz parte da pretensão e, por isso, deve ser deduzido. De modo que, nesse caso, há um fato que precisa ser alegado, mas não necessita ser provado.

Porém, há fatos que podem ser provados, apesar de não alegados. Um fato indiciário, ainda que não alegado, pode ser fixado como controvertido de ofício na audiência preliminar, e até mesmo posteriormente, na fase instrutória, devendo o juiz, em qualquer dos casos, além de dar oportunidade para que as partes falem, justificar a sua decisão. Nessa hipótese, ainda que a fixação de um fato como controvertido também implique na determinação de prova de ofício, as partes também podem requerer prova em relação a ele.

Portanto, a distinção entre ônus da alegação e ônus da prova é evidente, pois há fatos que devem ser alegados, mas não precisam ser provados, e outros que não precisam ser alegados e podem ser provados.

6. Ônus da prova na ação declaratória negativa

Por meio da ação declaratória negativa, o autor pede a declaração da inexistência de um direito afirmado pelo réu. Nessa ação, o problema diz respeito ao ônus da prova dos fatos constitutivos do direito sobre o qual se pede a declaração de inexistência.

Se o ônus da prova for considerado na perspectiva da posição das partes, esse será do autor, que terá que provar a inexistência dos fatos constitutivos do direito. Se o ônus da prova for pensado na dimensão do interesse na demonstração dos pressupostos fáticos para a incidência da norma relativa ao direito discutido, o ônus da prova será do réu, a quem incumbirá a prova da existência dos fatos constitutivos, pois a coisa julgada material, ao qualificar eventual decisão de improcedência, confere ao réu os mesmos efeitos que obteria se a ação declaratória fosse positiva.

Caso o ônus da prova seja deixado ao autor, admitir-se-á que o direito do réu seja declarado sem que ele tenha produzido prova, ou pior, que o direito do réu seja declarado apenas porque o autor não conseguiu provar a inexistência dos fatos constitutivos. Além disso, é impossível ao autor provar a inexistência de todos os possíveis fatos constitutivos do direito do réu, uma vez que os fatos constitutivos de um direito são somente do natural conhecimento daquele que se diz seu

titular. Como é óbvio, uma ação declaratória negativa pode ser proposta a partir dos fatos afirmados pelo réu, mas nunca daqueles que ele ainda pode alegar.

Porém, parece que a solução de obrigar o réu a suportar o ônus da prova dos fatos constitutivos também não é adequada. Por isso, a doutrina, especialmente a italiana, tem tentado encontrar alternativas para o problema. Há quem pense no prejuízo que pode ser provocado pela afirmação da existência de um direito, quando o autor da ação declaratória negativa teria o ônus de provar os fatos constitutivos do prejuízo e o réu o ônus de provar fatos que justifiquem o comportamento afirmação que teria dado causa ao prejuízo. Essa tese, proposta por Verde,¹³³ não foi acatada por Proto Pisani¹³⁴ e Patti,¹³⁵ especialmente pelo motivo de que o prejuízo abre oportunidade a uma ação condenatória e não a uma ação declaratória.

Mas, se o que efetivamente pretende o autor da ação declaratória não é a condenação pelo prejuízo, porém sim a definição da inexistência do direito, resta em aberto a questão do ônus da prova.

Já foi dito que não há sentido em atribuir ao autor o ônus da prova da inexistência de todos os possíveis fatos constitutivos do direito – até porque, de outra maneira, bastaria ao réu contestar alegando todos os possíveis fatos constitutivos do seu direito – e que também não é justo obrigar o réu a provar os fatos constitutivos do direito que o autor quer ver declarado inexistente.

Diante disso, Proto Pisani propõe que se olhe não só para o pedido, mas também para a causa de pedir da ação declaratória negativa.¹³⁶ Nessa ação, o autor é obrigado a indicar um determinado fato – por exemplo extintivo – ou a inexistência de um fato constitutivo (causa de pedir), não lhe bastando pedir apenas a declaração da inexistência de um direito (pedido). Quando o autor deixa de indicar um fato, o juiz não pode julgar o mérito ou declarar a existência ou a inexistência do direito, de modo que a sua decisão não poderá beneficiar nem o autor nem o réu.

Mas, considerando-se os fatos constitutivos, poderia o autor afirmar a inexistência de qualquer um deles? Como diz Proto Pisani, se o autor tivesse a liberdade de escolher o fato constitutivo cuja inexistência quer pôr como fundamento da ação declaratória negativa, poderia escolher o fato cuja inexistência é evidente ou de qualquer forma bastante fácil de provar, o que faria com que a liberdade de escolha do autor acabasse implicando na assunção do ônus da prova pelo réu.¹³⁷

Portanto, o fato constitutivo cuja inexistência se deve alegar somente pode ser aquele posto como fundamento da afirmação extrajudicial do réu. Aliás, é racional que o fato constitutivo que fundamentou a afirmação do réu – e não outro qualquer – seja posto na causa de pedir. Por isso, o autor apenas deve ter o ônus de provar a sua inexistência, além da situação de que esse fato constituiu o fundamento da afirmação extrajudicial, incumbindo ao réu o ônus de provar os outros eventuais fatos constitutivos por ele alegados.¹³⁸

Como é fácil perceber, a tese de Proto Pisani encontra problema na hipótese em que o réu afirma a existência do direito sem deixar qualquer marca capaz de indicar o fato em que se apoiou. Proto Pisani responde a esse problema dizendo que nesse caso a contestação do réu, por ser genérica, ou seja, não se fundar em um fato específico, excluiria o interesse de agir na declaração negativa.¹³⁹

Da resposta de Pisani discorda Patti, afirmando que o interesse de agir também advém da mera afirmação genérica de titularidade do direito – especialmente quando consideradas as suas consequências sobre as relações com terceiros.¹⁴⁰

Contudo, ainda que possa existir interesse de agir na declaração negativa diante da mera afirmação da existência de um direito – como sustenta Patti – não é possível entender que o autor, em um caso como esse, deva ter o ônus de provar a inexistência de todos os fatos constitutivos. Como a genérica e inespecífica afirmação do réu não retira o interesse do autor na ação declaratória negativa, impulsionando-o a pedir a declaração da inexistência do direito em juízo, não é justo que o autor deva ser penalizado por estar exercendo o seu direito de ação, e assim que deva assumir o ônus da prova da inexistência dos fatos constitutivos que sequer foram

individualizados pelo réu.

7. Saneamento do processo, a fixação dos pontos controvertidos e o deferimento das provas

Na fase de saneamento – que pode ocorrer por simples decisão escrita ou em audiência (art. 357, caput e § 3.º, CPC) – decididas as questões que poderiam obstaculizar o desenvolvimento do processo, devem ser fixados os pontos controvertidos e, a partir daí, deferidas as provas reputadas necessárias para elucidá-los.

Antes da fixação dos pontos controvertidos e do deferimento das provas, o juiz deve abrir às partes ampla oportunidade de discussão, seja por escrito, seja na própria audiência. Essa discussão dá origem a um importante diálogo, fundamental para que se possa chegar à definição do que é controvertido e nas provas necessárias e capazes de contribuir para a solução do litígio. Esse debate, aliás, pode dar origem à proposta de saneamento, feita pelas partes (art. 357, § 2.º, CPC) e submetida à homologação judicial, demonstrando a importância da participação das partes nesse momento.

A fixação dos fatos controvertidos tem os objetivos de i) racionalizar o desenvolvimento do processo, de maneira que não se perca energia com fatos não controvertidos; ii) facilitar a compreensão das provas necessárias e adequadas; e iii) abrir oportunidade ao julgamento antecipado relativo à parcela do pedido ou a um dos pedidos cumulados incontroversos.

Como é óbvio, não é possível ampliar ou alterar a causa de pedir na fase do saneamento do processo. Assim, não é cabível fixar como controvertido um fato relevante que não compõe a causa de pedir ou a defesa de mérito indireta. Mas, o juiz pode fixar como controvertido qualquer fato indiciário, relativo aos fatos relevantes afirmados, ainda que não tenha sido alegado na petição inicial ou na contestação, além de evidentemente poder determinar a produção de prova de ofício.

Não há razão para se fixar como controvertido um fato indiciário que não possa contribuir para o julgamento do mérito. Por isso, somente um fato ligado ao fato relevante e capaz de influir sobre a solução do litígio pode ser fixado como controvertido. Contudo, se na fase instrutória o juiz perceber que um fato indiciário, inicialmente não fixado como controvertido, deve ser esclarecido, nada impedirá a determinação de prova de ofício em relação a ele. Entretanto, convém lembrar que, antes da produção da prova, será preciso dar às partes oportunidade de falar sobre a importância da elucidação do fato e da adequação da prova.

8. Direito de produzir prova e ônus da prova

Conforme demonstrado, a parte que tem o ônus de provar não tem, só por isso, a necessidade de produzir prova para obter um resultado favorável. A ideia de ônus da prova significa apenas que a não produção da prova pode, ainda que com probabilidade, apenas eventualmente resultar em um julgamento desfavorável.¹⁴¹

A regra do ônus da prova, assim, configura mais precisamente um indicativo à parte de que a produção da prova lhe confere maiores chances de obter um julgamento favorável. Ainda que o ônus da prova seja associado ao risco na sua não produção, não se pode negar que a parte que possui esse ônus tem o direito de produzir todas as provas adequadas à demonstração do seu direito. O ônus e o direito, no caso, não se chocam, pois o ônus tem a ver com as consequências processuais do comportamento da parte, enquanto que o direito se dirige contra o Estado, que não pode negar, inclusive a quem tem o ônus probatório, o direito de produzir prova.

Mas, se não há dúvida que aquele que tem o ônus probatório também possui direito à prova, não tão clara assim é a situação da parte sobre a qual não recai o ônus da prova. A parte que não tem o ônus da prova somente deve requerer a produção da contraprova quando temer que a parte onerada possa influir sobre o convencimento do juiz. Porém, o problema surge exatamente quando o juiz não admite a contraprova com base no argumento de que a parte onerada já o

convenceu.

Acontece que o direito à prova, como é óbvio, é tanto da parte onerada quanto da parte destituída do ônus probatório. Se a parte que não possui o ônus da prova também tem o direito de influir sobre o convencimento do juiz, não se pode negar-lhe o direito à prova apenas porque a prova fornecida pelo onerado é convincente. O fato de uma prova ser convincente não elimina a possibilidade de o juiz formar o seu convencimento em sentido oposto. Ou melhor, o convincente é apenas uma qualidade da prova, e por isso não retira a possibilidade de que outra prova possa levar a um julgamento diverso.

Não se quer dizer, com isso, que o juiz não possa negar a produção de uma prova inútil ou que recaia sobre um fato irrelevante ou com objetivo protelatório. Essa possibilidade é óbvia, e tem a ver com a tarefa que deve ser cumprida quando da audiência preliminar. A questão que se propõe aqui possui outros contornos. Deseja-se demonstrar que o direito à prova impede o juiz de negar a produção de uma prova que possa influir sobre o seu convencimento, ainda que seja requerida pela parte que não tem o ônus da prova, pois o contrário seria admitir que o convencimento judicial depende apenas da atuação da parte onerada, pouco importando a prova que pode ser produzida pela parte contrária.

É certo que, se o juiz não se convencer de que a parte onerada tem razão, a não admissão da prova não prejudicará a parte não onerada. Porém, o juiz não pode se convencer apenas a partir das provas da parte gravada pelo ônus quando a parte adversa puder produzir provas capazes de influir sobre o seu convencimento.¹⁴²

9. O estado de dúvida, o dever de decidir e a regra do ônus da prova

Como já foi dito, a regra do ônus da prova se dirige às partes e ao juiz. Quando o juiz é o seu destinatário, importa para a formação do seu convencimento – uma vez que o juiz pode reduzir as exigências de prova, visando formar a sua convicção, conforme a situação concreta e a regra do ônus da prova – e para a sua decisão.

Frise-se que a separação da relevância da regra do ônus da prova diante dessas duas últimas situações decorre do fato de que o juiz resta convencido – ainda que da verossimilhança – ao reduzir as exigências de prova segundo as necessidades do caso concreto, enquanto que a regra do ônus da prova funciona como regra de decisão quando o juiz não forma o seu convencimento ou, em outras palavras, fica em estado de dúvida.

Referindo-se a regra do ônus da prova como de regra de decisão, Comoglio, Ferri e Taruffo apresentam uma lição bastante didática sobre a importância de tal regra para viabilizar a decisão do juiz. Segundo os professores da Universidade de Pavia, como o juiz não pode deixar de decidir ou aplicar um non liquet, são definidos critérios que permitem a solução do litígio quando os fatos principais não restam esclarecidos, os quais são constituídos pelas regras que disciplinam o ônus da prova. Tais regras importam quando um fato principal resulta destituído de prova, pois a sua função é estabelecer a parte que deveria provar o fato e determinar as consequências que sobre essa recaem diante da ausência de tal prova.¹⁴³

Nesse sentido, a regra do ônus da prova se apresenta como regra destinada a viabilizar a decisão do juiz em caso de dúvida ou, em outros termos a dar ao juiz não convencido a possibilidade de decidir.

10. As tentativas de expulsar a dúvida: o princípio da verossimilhança preponderante e a ideia de que a falta de convicção judicial faz surgir uma sentença que não produz coisa julgada material. Crítica

As doutrinas sueca e alemã abandonaram a regra do ônus da prova como critério dirigente da decisão judicial em caso de dúvida. Isso porque, para essa doutrina, o julgamento pode fugir da regra do ônus da prova quando existir um grau de 51% ou um mínimo de preponderância da

prova.

Tal doutrina alude a verossimilhança preponderante – a Överviktsprincip, na Suécia e a Überwiegensprinzip, na Alemanha – para indicar que a convicção pode ser de verossimilhança preponderante.¹⁴⁴ A lógica dessa tese se funda na ideia de que a verossimilhança, ainda que mínima, permite um julgamento mais racional e melhor motivado do que aquele que se baseia na regra do ônus da prova.

A admissão de que o juiz está convencido quando a verossimilhança pende para um dos lados praticamente elimina a impossibilidade de convicção e, dessa maneira, o estado de dúvida, que exigiria os critérios próprios da regra do ônus da prova como método para julgar. Ou seja, se não existe dúvida, não há necessidade de aplicar a regra do ônus da prova.

A lógica da verossimilhança preponderante se funda na premissa de que as partes sempre convencem o juiz, ainda que minimamente, o que é totalmente equivocado. O juiz não se convence quando é obrigado a se contentar com o que prepondera. Lembre-se de que a teoria da verossimilhança preponderante não se confunde com a possibilidade de o juiz reduzir as exigências de prova ou as exigências de convicção para atender a uma particular situação de direito material. Nesse último caso, não se trata de julgar com base na verossimilhança que preponderar, mas sim de julgar com base na verossimilhança exigível à luz das circunstâncias do caso concreto, quando então o juiz se convence, ainda que da verossimilhança, por ser essa a convicção de verdade possível diante do caso concreto.

Uma outra teoria, ao lidar com a dúvida, em princípio não a esconde, mas a afirma. Essa teoria aceita a possibilidade de o juiz chegar ao final do procedimento sem se convencer, dizendo que o juiz, nesse caso, deve proferir uma sentença contrária à parte que tem o ônus da prova. Essa teoria tenta se desfazer da dúvida ao firmar a ideia de que a sentença proferida pelo juiz que não se convenceu, e assim foi obrigado a julgar com base na regra do ônus da prova, não produz coisa julgada material.

Essa última teoria, em outras palavras, propõe a tese da coisa julgada secundum eventum probationis.¹⁴⁵ Porém, essa modalidade de coisa julgada material é peculiar aos procedimentos em que não se admite prova diferente da documental – como o mandado de segurança – e às ações que tratam de direitos difusos e coletivos, nas quais a legitimidade para a causa é outorgada a alguém que obviamente não é o titular, ou o titular exclusivo, do direito material em litígio.

No primeiro caso, porque o próprio procedimento especial não possibilita prova diferente da documental, ou melhor, porque o procedimento especial só permite que o juiz se convença com prova documental. Quando é necessária prova diferente da documental, embora o procedimento especial não a admita, abre-se a oportunidade para que o litígio seja resolvido por meio do procedimento comum, onde todas as provas são admissíveis.

No outro caso, em que o autor não é o titular, ou o titular exclusivo, do direito material, a ausência de coisa julgada material no caso de insuficiência de provas é consequência da falta de correspondência entre a titularidade da ação processual e a titularidade do direito material. A premissa é a de que, sendo o direito em litígio de titularidade de pessoas que podem não estar no processo, a ausência de provas não deve prejudicá-los.

Como está claro, a racionalidade dessas hipóteses de coisa julgada secundum eventum probationis não têm relação alguma com “dúvida”, mas com outras situações. Ao contrário, a teoria que afirma que toda e qualquer sentença fundada em prova não suficiente não produz coisa julgada material tenta eliminar a autoridade e a estabilidade da sentença fundada em dúvida.

Na realidade não há muita diferença em proibir o non liquet e admitir que a sentença, na hipótese de insuficiência de provas, não produz coisa julgada material. Ora, se o juiz é obrigado a julgar, o seu julgamento deve ter autoridade e se tornar estável, impedindo a sua negação ou rediscussão.

Em resumo: não é correto tentar eliminar a dúvida afirmando que o juiz se convence, ainda que minimamente, ou que a sentença, quando fundada em prova insuficiente, não produz coisa julgada material. É que as partes devem convencer o juiz, e esse, para julgar, em regra deve estar convicto da verdade, com exceção de particulares situações de direito substancial em que se admite que a sua convicção possa se formar com base em verossimilhança. Além disso, não há qualquer racionalidade em admitir que a sentença, apenas porque baseada em provas insuficientes, não produz coisa julgada material, pois isso seria o mesmo que supor que os conflitos devem se eternizar até que as partes tenham meios para provar ou até que o juiz possa se convencer, o que apenas serve para contestar a falibilidade dos meios de conhecimento, da prova, do processo, das partes e do juiz.

11. Ônus da prova, princípio da aquisição da prova e prova de ofício

O cumprimento do ônus da prova não é necessário para que o onerado obtenha um resultado favorável. Isso porque o juiz pode se convencer com base em outras provas, sejam elas produzidas pela outra parte ou por determinação de ofício do próprio juiz.

Diante disso, alguém poderia pensar que a regra do ônus da prova perde a importância, ou, pelo menos, que essa regra passa a ter relevância apenas como regra de juízo, isto é, para a hipótese em que as provas não foram suficientes para o juiz se convencer.

Na verdade, quando se percebe que as provas podem não ser suficientes, ainda que o juiz possa determiná-las de ofício e não deva considerar a sua proveniência, torna-se mais evidente a importância da regra do ônus da prova como regra de juízo. É que as provas, ainda que produzidas de ofício, podem não ser suficientes para o juiz se convencer.

Porém, o fato de que o juiz pode considerar todas as provas trazidas aos autos e, inclusive, determiná-las de ofício, não elimina a necessidade de que as partes saibam, de antemão, o que devem provar.

Isso porque, como é evidente, a circunstância de que o juiz possa se convencer a partir de prova produzida pela outra parte é residual, e assim está muito longe de retirar o interesse da parte onerada na produção da prova.

E o mesmo ocorre em relação à prova de ofício, até porque essa somente deve ser determinada quando o juiz, verificando a inércia das partes, conclui sobre a importância da sua produção para esclarecer os fatos. É importante lembrar, aliás, que as partes é que estão em condições de conhecer os fatos – que realmente importam para a demonstração do fato principal – e as provas, especialmente as testemunhais, que podem colaborar para a elucidação do litígio. De lado as chamadas “provas referidas”, a atuação do juiz de ofício fica circunscrita à prova pericial, e isso após as partes não terem se calado sobre ela, o que demonstra que o ativismo do juiz em relação à produção da prova jamais poderá eliminar a importância da regra do ônus da prova em sentido objetivo (como regra de juízo) e em sentido subjetivo (como regra dirigida às partes).

É fundamental perceber que o ônus da prova, ainda que não deva ser necessariamente cumprido pela parte vencedora, constitui um alerta para o risco de que essa pode ser vencida se não provar, o que é obviamente suficiente para se concluir que o princípio da aquisição da prova e todo o ativismo judicial pertinente à instrução probatória jamais serão capazes de obscurecer a importância de se alertar a parte de que a não observância de tal ônus a expõe a risco.¹⁴⁶

12. Posse do documento e ônus da prova documental

Quando um documento está em poder de terceiro, o juiz, mediante requerimento da própria parte interessada, pode ordenar a sua exibição, conforme o art. 401 e seguintes do CPC.

Se o descumprimento da ordem pelo terceiro configura crime de desobediência, e assim abre margem para a sanção correspondente, o art. 77 do CPC afirma que “todos aqueles que de

qualquer forma participem do processo”, caso não observem as ordens do juiz, devem ser multados. Além disso, caso seja possível localizar o documento, poderá ser determinada busca e apreensão (cf. art. 403, parágrafo único, CPC).

Na hipótese em que o documento está com um terceiro, ou seja, no caso em que o meio de prova está na posse de um terceiro, obviamente não há como se pensar em presunção ou em inversão do ônus da prova. A “possibilidade” de admitir como verdadeiro o fato que, por meio do documento, pretendia-se provar, ou mesmo de inverter o ônus da prova, somente se apresenta quando o documento está na posse da parte adversa – não gravada pelo ônus probatório.

Colocou-se “possibilidade” entre aspas para salientar que o fato de o documento estar na posse da parte adversa, não deve implicar, necessariamente, presunção ou inversão do ônus da prova. Qualquer decisão contrária à parte adversa da onerada pressupõe uma ordem judicial de entrega de documento não cumprida, o que significa que a simples posse do documento não é suficiente para a formação de presunção, para a inversão do ônus da prova ou ainda para se retirar argumentos de prova desse comportamento. Nesse último caso, aliás, por uma razão absolutamente evidente, pois a posse de um meio de prova certamente está longe de configurar um comportamento processual negativo.

Porém, deve-se extrair do comportamento processual da parte que não atendeu à ordem judicial consequências jurídico-processuais que possam equivaler ao documento não entregue, conforme estabelece o art. 400 do CPC. O descumprimento da ordem forma uma presunção relativa de verdade, o que equivale à inversão do ônus da prova na sentença – já que a inversão pressupõe que o ônus da prova passa da parte inicialmente onerada àquela que está na posse do meio de prova. Por ser relativa, essa presunção deve ser considerada em face das demais provas existentes nos autos.

13. Posse do documento e ônus da prova pericial

Vejamos, agora, o problema da prova pericial que deve recair no documento que está na posse da parte contrária a que possui interesse em produzi-la.

A diferença, aqui, é a de que a prova pericial, ao contrário da documental, não se utiliza apenas do documento, mas incide sobre ele para chegar a um outro resultado ou a uma outra evidência.

Quando é possível pré-determinar os resultados a que a prova pode chegar, um favorável e outro desfavorável à parte onerada, a situação não é difícil. Quando a parte que está na posse do documento descumpra a ordem judicial, basta inverter o ônus da prova e considerar o resultado que a parte onerada queria obter produzindo a prova pericial. Note-se que, tanto no caso de prova documental (vista no item anterior) quanto no de prova pericial, o descumprimento do dever de entrega gera a inversão do ônus, mas a valoração do conjunto probatório admite prova em contrário.

A diferença é que a não apresentação do documento implica, nos termos do art. 400 do CPC, a presunção de veracidade do fato que, por meio do documento, a parte pretendia provar, enquanto que, na prova pericial, o fato não depende do documento, mas sim da perícia que, a partir do documento, pretendia-se produzir. A presunção, portanto, será da veracidade do fato que a perícia pretendia demonstrar. Mas, como se trata de presunção relativa, não há como negar a possibilidade de o juiz considerar prova em contrário ao fato presumido.

Frise-se que não importa se o resultado da perícia é imprevisível, e assim pode beneficiar uma parte ou outra. O que realmente interessa é o significado do comportamento da parte que se nega a apresentar os documentos em juízo. Ora, desse comportamento deve ser extraída uma consequência jurídico-processual, precisamente a de que a parte que necessita do documento não mais precisa provar o fato que a perícia pretendia evidenciar. Com isso estabelece-se uma presunção relativa ou o ônus da prova é invertido.

Além disso, há hipóteses em que o documento é necessário para que a parte possa demonstrar

um determinado valor, como ocorre nos casos de prestação de contas ou de apuração de haveres. Nesses casos, a parte precisa ter acesso ao documento para poder chegar ao valor a que tem direito. Por exemplo: precisa conhecer os documentos que integram a contabilidade para que a prova pericial tenha condições de apurar o valor devido.

Nessas hipóteses, a racionalidade indica que a parte deve ter a possibilidade de afirmar o valor devido, ainda que com base nos elementos que tenha a sua disposição, dando-se à parte contrária, além da possibilidade de fornecer os documentos necessários para a produção da prova pericial, apenas a oportunidade de discutir o raciocínio que se baseou em tais elementos – e não os elementos que substituem aqueles que deveriam ser apresentados pelos documentos, ou seja, como a inversão do ônus da prova aqui não basta, deve-se admitir que o autor produza a prova a partir dos elementos que possui, pois não é possível que a parte que está na posse dos documentos seja beneficiada pelo seu mau comportamento.

14. O procedimento da exibição (arts. 396 a 404 do CPC) e o direito da parte se recusar a apresentar o documento ou contestar a sua posse

Até agora pouco se falou do procedimento de exibição de documento – previsto entre os arts. 396 e 404 do CPC –¹⁴⁷ que discrimina a forma que deve ser utilizada para a obtenção de documento ou coisa contra a parte ou contra um terceiro-particular. A exibição, dirigida à parte, não tem natureza de ação, mas de mero incidente, embora o juiz também possa determinar a exibição de ofício.

Esse incidente pode ser instaurado a pedido de algum sujeito parcial do processo, devendo conter a individualização da coisa ou do documento a ser exibido, a finalidade da prova buscada e as razões pelas quais se entende que a coisa ou o documento está em poder da parte contrária (art. 397, CPC). Realizado o pedido, será o requerido intimado a responder em cinco dias, quando poderá exibir o documento ou a coisa ou se negar a apresentá-lo, fundando-se em uma das escusas do art. 404 do CPC ou no fato de não ter o documento ou a coisa – caso em que será permitido ao requerente provar o contrário.

Não cabe recusa da exibição em várias hipóteses, algumas das quais arroladas no art. 399 do CPC: i) se o requerido tiver obrigação legal de exibir; ii) se o requerido aludiu ao documentou ou a coisa, no processo, com o intuito de constituir prova; iii) se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.

O art. 404 do CPC, em elenco meramente exemplificativo, enumera algumas hipóteses em que a parte (ou o terceiro) pode se recusar a exibir. Diz ele que “a parte e o terceiro se escusam de exibir, em juízo, o documento ou a coisa se: i) concernente a negócios da própria vida da família; ii) a sua apresentação puder violar dever de honra; iii) sua publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal; iv) sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo; v) subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição; vi) houver disposição legal que justifique a recusa de exibição”.

Como é óbvio, tais motivos de recusa, aliados a outros que podem aparecer como fundados em face dos diversos casos concretos, aplicam-se à recusa na apresentação de documento afirmado imprescindível para a produção das provas documental e pericial.

A presunção – ou a inversão do ônus da prova – apenas se forma quando a parte não contesta ou tem a sua justificativa negada. Não é possível estabelecer a presunção de veracidade – ou inverter o ônus da prova – antes de a parte ter tido a devida oportunidade de alegação e prova.

15. A presunção de veracidade do art. 400 do CPC, a inversão do ônus da prova e a prova pericial que não pode ser produzida em razão da não entrega do documento em juízo

Não havendo necessidade de prova, ou colhida prova em audiência específica, o juiz poderá negar ou ordenar a exibição. Diz o art. 400 que “ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar”. Essa presunção é certamente relativa – e não absoluta – pois a sua racionalidade – ou a sua razão de ser – está em dispensar o onerado de produzir prova e não em formar uma ficção de verdade, impedindo-se prova em sentido contrário ou que o juiz chegue em uma solução oposta ao valorar o conjunto probatório.

A parte que possui o documento e não o entrega é penalizada com a formação de uma presunção iuris tantum, ou, em outros termos, sofre a inversão do ônus da prova. De modo que a parte que descumpriu a ordem somente pode esperar por algo que seja capaz de desacreditar a presunção. Se nenhuma prova for capaz de permitir ao juiz formar convicção diversa, a presunção deve ser acolhida, ainda que isso não signifique a procedência do pedido, pois do fato, como é sabido, pode não decorrer o direito. Cabe advertir, com efeito, que tal presunção pertine a um fato e não a um direito.

Por outro lado, a circunstância de a não entrega do documento, segundo o art. 400 do CPC, dizer respeito ao fato que poderia ser elucidado pelo documento e não àquele que poderia ser demonstrado por meio da perícia, não altera o raciocínio de que a não entrega de documento não pode prejudicar a parte que dele necessita, pois de outra forma estaria premiando aquela que desrespeita o juiz.

Deixe-se claro, ademais, que apesar de a presunção decorrente da não entrega do documento ser relativa ou iuris tantum, e assim permitir prova em sentido contrário, evidentemente não é necessário que o juiz comunique às partes que o ônus da prova está invertido para poder considerar tal presunção no momento da sentença. Se a parte descumpriu a ordem judicial, dando abertura à formação da presunção, é completamente irracional imaginar que não deva pagar por seu comportamento apenas porque o juiz não lhe disse que deveria provar em sentido contrário.

Como é óbvio, a inversão do ônus da prova é decorrência automática do não cumprimento da ordem de entregar e, como esse não cumprimento é posterior ao momento do deferimento das provas, pouco adiantaria comunicar a inversão do ônus probatório. Na verdade, como é fácil perceber, a inversão do ônus da prova, nesse caso, assume importância como regra de juízo.

16. A simples posse do meio de prova não é critério justificativo da inversão do ônus da prova

Como está claro, o fato de a parte desonerada estar na posse do documento, não pode implicar na inversão do ônus da prova. Ou seja, a suposição de que a posse do documento, por facilitar a produção da prova, deve permitir a conclusão de que a prova deve ser produzida pela parte que possui o meio de prova, não leva em consideração a diferença entre ônus da prova e posse do meio de prova.

A posse do meio de prova é meramente circunstancial, nada tendo a ver com o ônus da prova, que é ditado por razões de bom senso, ou melhor, no interesse de quem alega um fato. É certo que o ônus da prova pode ser invertido diante de certas situações de direito substancial, que impõem uma distribuição diferenciada da prova. Porém, a posse do meio de prova, em princípio, não é motivo ou razão suficiente para a inversão do ônus. Essa inversão, operante como regra de juízo, somente é possível quando a parte que possui o documento não cumpre a ordem judicial que determina a sua entrega.

17. A recusa à perícia médica e a inversão do ônus da prova

O comportamento das partes, revelado por meio de ato processual comissivo ou omissivo,¹⁴⁸ constitui fato jurídico processual que pode ter relevância na formação do convencimento judicial.¹⁴⁹ A relevância desse comportamento dependerá do significado que dele se possa extrair diante do litígio – e justificar racionalmente.

Há casos em que o autor, para demonstrar o seu direito, necessita que o réu submeta-se à perícia médica. Esse último, porém, temendo o resultado do exame, pode impedir a sua realização, não se apresentando ao perito.

Ora, é bastante fácil relacionar a recusa injustificada do réu com a tentativa de impedir a prova pericial e um resultado que lhe seja contrário. Não foi por outra razão que o Código Civil estabeleceu, no art. 231, que “aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa”.

Por meio dessa norma foi positivada a consequência que o juiz deve extrair do comportamento da parte, ou melhor, o art. 231 nada mais fez do que definir a consequência que o juiz deve retirar da negativa injustificada da parte em “submeter-se a exame médico necessário”, dizendo que ela, nesse caso, não “poderá aproveitar-se de sua recusa”.

Quando se afirma que a parte não “poderá aproveitar-se de sua recusa”, deseja-se esclarecer que a não realização do exame médico e a consequente falta de prova do fato que essa perícia pretendia evidenciar não podem prejudicar a parte que tinha interesse na prova e beneficiar aquela que a obstaculizou.

Se a parte que tem o ônus da prova não pode ser prejudicada pelo comportamento negativo da outra, a constatação de recusa injustificada implica na admissão de que o fato que a perícia visava demonstrar não mais precisa ser provado pelo titular do ônus. A recusa injustificada deve ser considerada por ocasião da sentença, quando o juiz inverte o ônus da prova, retirando-o da parte que requereu a prova.

Mas, o Código Civil vai além, dizendo, no art. 232, que “a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame”. Contudo, essa norma não tem efeito muito diferente da do art. 231, pois a recusa injustificada somente não beneficiará ao faltante quando outra prova puder evidenciar o fato. Fora daí, a recusa terá que significar o que “se pretendia obter com o exame”.

Assim, se o réu se negar a submeter-se a exame de DNA, é evidente que “não poderá aproveitar-se da sua recusa” (art. 231, CC), razão pela qual essa poderá significar “a prova que se pretendia obter com o exame” (art. 232). Quando o art. 232 afirma que a recusa “poderá” suprir a prova, ele quer dizer que o fato que se pretendia evidenciar com a prova pode ser demonstrado em sentido contrário. Nesse caso, a recusa evidentemente não implicará no fato que se desejava provar.

Frise-se, por outro lado, que a extração de uma consequência processual da recusa da parte em submeter-se ao exame médico não viola, nem de longe, qualquer direito da personalidade, razão pela qual não há que se pensar em harmonização de direitos em choque, como se o direito à prova tivesse que ser harmonizado diante do direito da personalidade.

18. A recusa do terceiro ao exame médico

Como é óbvio, a recusa de um terceiro nada tem a ver com a inversão do ônus da prova, mas, em alguma medida, com a impossibilidade da sua produção. Apenas por esse motivo, e diante da sua estreita relação como o problema tratado no item anterior, é que abordaremos tal questão.

Em uma ação de investigação de paternidade, em que o afirmado pai do autor já faleceu, pode ser necessário submeter ao exame de DNA pessoa que não integra a relação processual. Nessa hipótese, o juiz pode determinar que o terceiro se submeta ao exame médico, apesar de o art. 380 do CPC, que trata dos deveres do terceiro, não conter inciso semelhante ao do art. 379, II, que afirma ser da parte “colaborar com o juízo na realização da inspeção judicial que for considerada necessária”.

Se o exame médico é imprescindível para a adequada solução do processo e para a efetividade do direito material, a não observância, por parte do terceiro, da determinação judicial de submeter-se ao exame de DNA, não só viola o seu dever de colaborar com a justiça como também

agride o direito de a parte descobrir o verdadeiro pai. De modo que a inexistência de sanção contra o terceiro somente teria fundamento se o juiz não pudesse obrigá-lo a realizar o exame, e esse fundamento apenas teria lógica se tal exame não fosse absolutamente necessário para o respeito ao direito material e para a seriedade da função jurisdicional.

Como é óbvio, não há como extrair consequências processuais em relação a um estranho à relação processual, mas há como obrigá-lo a observar as determinações do juiz pela simples razão de que ninguém pode se eximir “de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade” (art. 378, CPC). Tanto é verdade que está escrito, no art. 380 do CPC que “incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa: I – informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento; e II – exhibir coisa ou documento que esteja em seu poder”.

O fato de o art. 380 somente se referir a coisa e a documento – que podem ser apreendidos mediante busca e apreensão – obviamente não significa que a multa, prevista no art. 77, § 2.º, do CPC, não possa ser utilizada para compelir o terceiro a cumprir as determinações judiciais, inclusive a de submeter-se a exame médico.

Na realidade, as mesmas razões – que devem ser compreendidas em uma perspectiva histórica e de valores – que atualmente fundamentam o uso da multa ou de outros meios de indução para compelir o réu a cumprir as decisões do juiz (arts. 536 e 537, CPC), autorizam o seu uso para obrigar o terceiro a atender as determinações judiciais. Lembre-se que a negação do uso de meios de indução não tinha relação com a natureza do atingido – parte ou terceiro –, mas sim com a ideia de que ninguém poderia ser constrangido a fazer algo contra a sua própria vontade.

Acontece que a autonomia da vontade não pode mais ser vista como antigamente, e assim não há como supor que o terceiro não possa ser compelido sob pena de multa ou de qualquer outro meio de indução a atender às determinações do juiz. Mas, alguém poderia argumentar que a hipótese em exame não configura uma simples ordem judicial, porém o constrangimento da liberdade para o cumprimento de uma ordem do juiz que obriga a realização de um exame médico. Ou seja, que há diferença entre obrigar ao cumprimento da ordem judicial e obrigar ao cumprimento de uma ordem judicial que imponha um exame médico.

Não há dúvida de que as ordens judiciais são distintas conforme os seus objetivos, e que algumas delas – pensadas em abstrato – não são viáveis. Entretanto, obrigar alguém a realizar um exame médico, que não gera qualquer risco à saúde e é necessário à resolução de um litígio e à proteção do direito material, não representa, nem de longe, uma ordem judicial inadmissível. Seria bem mais que hipocrisia sustentar que essa ordem atenta contra a dignidade humana e a intangibilidade do corpo humano. Na verdade, como não é difícil concluir, o que viola a dignidade humana, por desprezar o direito material que depende da realização do exame e o próprio direito de acesso à justiça – que é negado quando o direito à prova é obstaculizado –, é a recusa injustificada do terceiro.

A ordem para a realização de exame médico não viola qualquer direito da personalidade. Recorde-se que se está pressupondo a recusa injustificada, e não a alegação – que deve ser evidenciada – de que o pretendido exame médico, em virtude de um motivo específico, pode trazer determinado risco à saúde.

Frise-se, aliás, que o juiz pode retirar da recusa injustificada do terceiro um argumento de prova. Pense-se novamente em um caso concreto: na hipótese em que a ação de investigação de paternidade é proposta quando o afirmado pai já faleceu, e esse último, solteiro e sem descendentes, deixou apenas a sua mãe como herdeira. Suponha-se que o exame de DNA, para comprovar a relação de filiação, deva também recair sobre o único irmão do falecido, o qual, por não ser herdeiro, não é réu na ação de investigação. Como já foi demonstrado, nada impede que se obrigue um terceiro a submeter-se a um exame médico. Mas, seria possível extrair da sua recusa injustificada um argumento de prova? Partindo-se da premissa de que uma pessoa estranha ao processo não tem qualquer interesse no seu desfecho, tal pergunta não poderia ter resposta positiva. Contudo, o terceiro, nesse caso, além de irmão do falecido, é o filho vivo da única herdeira, ré no processo. Portanto, não há como fingir não ver o seu interesse no processo e na

frustração de qualquer prova capaz de evidenciar a relação de filiação. Diante disso, se a sua recusa for injustificada e não for possível obrigá-lo a realizar o exame, o juiz poderá retirar argumento de prova desse comportamento. Nesse caso, considerada a peculiaridade da situação, importará, mais do que nunca, a racionalidade da justificação do juiz, devendo o juiz, além de caracterizar a recusa como injustificada, explicar as razões que evidenciam o interesse do terceiro no processo e na frustração da prova.

19. As diversas necessidades do direito material e a possibilidade de tratamento diferenciado do ônus da prova na ausência de lei

É evidente que a distribuição do ônus da prova não pode ser sequer pensada sem tomar em conta o direito material.

Em verdade, bem ponderadas as coisas, não existe motivo para supor que a alteração do ônus da prova somente é viável quando prevista em lei. A própria norma contida no art. 373 não precisaria estar expressamente prevista, pois decorre do bom senso ou do interesse na aplicação da norma de direito material, que requer a presença de certos pressupostos de fato, alguns de interesse daquele que postula a sua atuação e outros daquele que não deseja vê-la efetivada. Recorde-se que o ordenamento alemão não contém norma similar à do art. 373, e, por isso, a doutrina alemã construiu a Normentheorie.¹⁵⁰

Da mesma forma que a regra do ônus da prova decorre do direito material, algumas situações específicas exigirão o seu tratamento diferenciado. Isso pela simples razão de que as situações de direito material não são obviamente uniformes. A suposição de que a modificação do ônus da prova deveria estar expressa na lei está presa à ideia de que essa, ao limitar o poder do juiz, garantiria a liberdade das partes.

Atualmente, contudo, não se deve pretender limitar o poder do juiz, mas sim controlá-lo, e isso não pode ser feito mediante uma previsão legal da conduta judicial, como se a lei pudesse dizer o que o juiz deve fazer para prestar a adequada tutela jurisdicional diante de todas as situações concretas. Como as situações de direito material são várias, deve-se procurar a justiça do caso concreto, o que repele as teses de que a lei poderia controlar o poder do juiz. Esse controle, atualmente, somente pode ser obtido mediante a imposição de uma rígida justificativa racional das decisões, que podem ser auxiliadas por regras como as da proporcionalidade e suas sub-regras.

Se não é possível ao legislador afirmar, como se estivesse tratando de situações uniformes, que o juiz deve sempre aplicar essa ou aquela regra do ônus da prova, também não lhe é possível dizer que apenas uma ou outra situação de direito material pode permitir a sua modificação.

É claro que tal alteração pode ser prevista para determinadas situações – como acontece com as relações de consumo – mas não é certo concluir que essa expressa previsão legal possa excluir a atuação judicial em outras, ainda que nada esteja disposto na lei.

20. A modificação judicial do ônus da prova no CPC (art. 373, § 1.º)

Afirma o art. 373, § 1.º, do código que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

A regra contém nítido equívoco, já que não trata, propriamente, de distribuição ou de modificação do ônus probatório. Trata, ao contrário, da distribuição do dever de prova, e se reflete como expressão dos arts. 378, 379 e 380, do CPC.

Se uma das partes não pode produzir certa prova, que pode ser produzida pela parte contrária,

não se trata de aplicar a regra do ônus probatório, porque não há estado de dúvida judicial a ser resolvido pela lei. Há, sim, problema de aporte de prova.

Por isso, quando o juiz impõe “a quem não teria o ônus original da prova” o dever de trazer esse elemento – ou então extrai argumento de prova dessa omissão – logicamente a discussão está longe de discutir o ônus da prova. Está impondo a alguém o dever de aportar elementos de prova aos autos, sob pena de se extrair da conduta omissiva presunções contrárias a essa parte.

Daí também a razão pela qual a regra afirma, em sua parte final, que essa imputação do dever de prova deve ocorrer no saneamento do processo (art. 357, III, do CPC). Afinal, se essa decisão determina a alguém que produza certa prova – cujo ônus não lhe é inicialmente atribuído – e se esse sujeito tem condições de trazer essa prova, evidentemente é necessário se dar a ele tempo e condições para cumprir com esse dever.

21. Situações em que o direito material requer o tratamento diferenciado do ônus da prova

Como o juiz deve se convencer de algo que está no plano do direito material, não há como imaginar ser possível exigir uma convicção uniforme para todas as situações de direito substancial.

Por essa razão, lembrou-se que em alguns casos, como os de lesões pré-natais, de seguro, relativos a atividades perigosas e em que se violou um dever legal de segurança ou de proteção, a redução das exigências de prova ou de convicção de certeza é justificada pela própria estrutura e natureza dessas situações. Nessas hipóteses, o juiz pode reduzir as exigências de convicção ou de prova e julgar o pedido procedente com base em convicção de verossimilhança.

Mas, como também foi dito anteriormente, o julgamento com base em verossimilhança é apenas uma das maneiras de atender o direito material diante da fria regra do ônus da prova. Assim, é chegado o momento de melhor elaborar os critérios justificadores da modificação do ônus da prova, que nada mais é do que uma outra forma de adequar a convicção do juiz e o processo às particularidades do direito material.

Se não basta como regra e para todos os casos conflitivos concretos a verossimilhança preponderante, uma vez que o juiz, para definir os litígios, deve procurar se convencer da verdade, é certo que essa última ideia é relativa, pois, como dito, nem sempre a situação de direito material objeto do processo pode exigir do juiz, para a procedência do pedido, que o autor observe o ônus de provar o fato constitutivo.

Por isso, em determinadas situações, ao juiz é admitida a convicção de verossimilhança. Tais situações têm particularidades próprias, suficientes para demonstrar que a exigência de prova plena seria contrária ao próprio desejo do direito material. Ou, em outras palavras, que nessas situações o próprio direito material não exige prova plena ou não se concilia com a aplicação da regra do ônus da prova. Lembre-se, por exemplo, dos casos das lesões pré-natais e das hipóteses de atividades perigosas.

Como é óbvio, quando o direito material nada tem de particular, a dúvida implica o julgamento com base na regra do ônus da prova, e, assim, a verossimilhança aí não basta. Acontece que existem particulares situações de direito material que não apenas justificam a convicção de verossimilhança, porém vão além, justificando a inversão do ônus da prova.

Em princípio, a alteração do ônus da prova somente é admissível como regra dirigida às partes, pois deve dar à parte que originariamente não possui o ônus da prova a possibilidade de produzi-la. Quando se inverte o ônus é preciso supor que aquele que vai assumi-lo terá a possibilidade de cumpri-lo, pena de a alteração do ônus da prova significar a imposição de uma perda, e não apenas a transferência de um ônus. Nessa perspectiva a inversão do ônus da prova somente deve ocorrer quando a parte contrária tem a possibilidade de demonstrar a não existência do fato cujo ônus seria originalmente atribuído ao seu adversário (art. 373, § 2.º, do CPC).

E evidente que o fato de o réu ter condições de provar a não existência do fato constitutivo não permite, por si só, a inversão do ônus da prova. Isso apenas pode acontecer quando as especificidades da situação de direito material, objeto do processo, demonstrarem que não é racional exigir a prova do fato constitutivo, mas sim exigir a prova de que o fato constitutivo não existe, ou seja, a inversão do ônus da prova é imperativo de bom senso quando ao autor é impossível ou muito difícil provar o fato constitutivo, mas ao réu é viável, ou muito mais fácil, provar a sua inexistência (art. 373, § 1.º, do CPC).

Em outros casos, porém, a inversão do ônus da prova não decorre do fato de que ao réu a prova é mais fácil. Nesses casos, em que a produção da prova é árdua às duas partes, uma particularidade da situação de direito material deve demonstrar que a situação de dúvida não deve ser suportada pelo autor, como ocorre nos “casos comuns”.

Recorde-se, ainda para exemplificar, o caso da vítima que morreu na piscina do clube que não indicou a sua inadequação para as pessoas que não sabem nadar. Como a discussão girava em saber se o autor havia morrido afogado ou de colapso (como dizia o réu), chegou-se a uma situação que dificilmente poderia ser objeto de elucidação.

Não obstante, deve-se partir do pressuposto de que aquele que viola uma norma de prevenção ou de proteção aceita o risco de produzir dano. Mas, a aceitação desse risco implica, por consequência *lógica, em assumir o risco relativo à dificuldade na elucidação da causalidade entre a violação e o dano, ou melhor, em assumir o ônus da prova capaz de esclarecê-la.*

Nos casos em que o direito material impõe a alteração do ônus da prova, essa mudança deve ocorrer no saneamento do processo (art. 357, III, do CPC) quando a prova, a ser requerida pela parte, é ao menos possível. Mas, quando o fato se torna insuscetível de elucidação por qualquer das partes, o juiz pode, a despeito da vedação legal (art. 373, § 1.º, in fine, do CPC) modificar a regra do ônus da prova na sentença, ao considerar os fatos que dão composição ao conflito, inclusive os incontroversos, e as regras de experiência.

Resumindo: em regra, o juiz deve procurar uma convicção de verdade e, por isso, só deve julgar com base na regra do art. 373 em caso de dúvida, vale dizer, quando o autor não lhe convencer da existência do fato constitutivo ou quando o réu não lhe convence da existência do fato modificativo, impeditivo ou extintivo. Porém, particulares situações de direito material exigem que o juiz reduza as exigências de prova, contentando-se com uma convicção de verossimilhança. Nesses casos, ainda que o autor possa produzir prova, o próprio direito material demonstra que o processo para tratá-lo de maneira adequada e efetiva não pode exigir mais do que uma convicção de verossimilhança.

Ao lado disso, há situações em que a uma das partes é impossível, ou muito difícil, a produção da prova do fato cujo ônus lhe foi inicialmente atribuído, mas ao seu adversário é viável, ou mais fácil, a demonstração da sua inexistência, o que justifica a alteração do ônus da prova. Ademais, há casos em que a prova é impossível, ou muito difícil, para ambas as partes, mas a impossibilidade de esclarecimento de certo fato deve pesar sobre a parte a quem não recai, originalmente, o ônus da prova; nesse caso, a alteração do ônus da prova também se impõe.

A modificação do ônus da prova, em princípio, deve ocorrer no saneamento do processo, para dar à parte a oportunidade de produzir a prova. Mas, no caso em que a inesclarecibilidade do fato constitutivo pode ser imputada ao réu, a inversão do ônus da prova pode ocorrer na sentença.

Também na sentença deve ser invertido o ônus da prova no caso em que o réu está na posse de um documento e se recusa injustificadamente a apresentá-lo em juízo. Essa inversão pode ocorrer em relação à prova documental ou à prova pericial, quando uma outra necessitar do documento não fornecido.

Quando a parte se recusar injustificadamente a colaborar com uma prova, o juiz deve retirar argumento de prova desse comportamento. Se a parte se recusar à perícia médica, ou colaborar com qualquer outra prova pericial, o juiz, mais uma vez, deve inverter o ônus da prova na

sentença.

Excepcionalmente, quando o juiz puder extrair do comportamento do terceiro uma tentativa de frustrar a prova, essa sua recusa deve ser considerada como argumento de prova, podendo até mesmo conduzir à inversão do ônus da prova na sentença.

22. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor

Demonstrado que o ônus da prova não é exclusividade de uma específica situação de direito material, mas sim necessidade para o seu adequado tratamento, cabe, ainda, passar à análise da regra do art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que expressamente indica os pressupostos para a inversão do ônus da prova nas relações de consumo.¹⁵¹

De acordo com essa norma, é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”.

A leitura da regra do art. 6.º, VIII, propõe as seguintes questões: i) a inversão do ônus da prova exige a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor ou apenas um desses elementos?; ii) o que significa verossimilhança da alegação e hipossuficiência do consumidor?; iii) qual é o momento para a inversão do ônus da prova?¹⁵²

O art. 6.º, VIII, afirma claramente que a inversão do ônus da prova é possível, em favor do consumidor, quando “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente”. Ao menos a interpretação gramatical impõe a conclusão de que basta a verossimilhança ou a hipossuficiência.¹⁵³

Mas para que seja possível expressar os significados de verossimilhança e hipossuficiência, é preciso considerar o contexto em que essas expressões são utilizadas. Ou seja, é preciso recordar as razões de distribuição e inversão do ônus da prova e agora relacioná-las com a natureza das relações de consumo e com a posição que o consumidor nelas ocupa.

Deixe-se claro que o fato de o consumidor não precisar provar culpa diante do adimplemento imperfeito ou dos danos nada tem a ver com inversão do ônus da prova. No primeiro caso – quando se fala em vício do produto ou do serviço ou em responsabilidade pelo adimplemento imperfeito (arts. 18, 19 e 20, CDC) – não importa a culpa, de modo que sobre ela sequer é preciso cogitar. Na hipótese de dano provocado pelo adimplemento imperfeito ou de dano derivado do chamado fato do produto ou do serviço, o próprio Código de Defesa do Consumidor é expresso em excluir a necessidade da demonstração da culpa (arts. 12, 14 e 23, CDC).¹⁵⁴

Por outro lado, no caso de responsabilidade pelo fato do produto, o art. 12, § 3.º, do CDC diz que “o fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: I – que não colocou o produto no mercado; II – que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”. Na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço, preceitua o art. 14, §3.º, do mesmo código que “o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”. Como se vê, tais normas afirmam, expressamente, que o consumidor não precisa provar o defeito do produto ou do serviço, incumbindo ao réu o ônus de provar que esses defeitos não existem.

Em ação de ressarcimento baseada em responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, além de a responsabilidade ser objetiva, o consumidor é dispensado de provar o defeito do produto ou do serviço. Até aqui a única questão probatória que aparece diz respeito à prova do defeito, mas o ônus dessa prova é expressamente imputado ao réu, não recaindo sobre o consumidor. Nesse caso, como é óbvio, o juiz não precisa inverter o ônus da prova, pois esse ônus já está invertido (ou definido) pela lei.

No caso em que o réu não consegue demonstrar que o defeito não existe, faltaria, ainda, ligar esse defeito ao dano. Exemplifique-se com a hipótese do remédio que contém defeito na sua fabricação. Como é pouco mais do que óbvio, um remédio com defeito somente pode gerar responsabilidade – ainda que essa prescindir de culpa – quando causa um dano. O problema, então, passa a ser o da prova da causalidade. Como provar que uma doença, ou um problema no feto, foi ocasionado pelo defeito de um remédio?

Frise-se que, em um caso com esse, a relação de consumo é marcada pela violação de uma norma que objetiva dar proteção ao consumidor. O fabricante que viola essa norma assume o risco da dificuldade de prova da causalidade. Se a prova da causalidade é difícil, basta que o juiz chegue a uma convicção de verossimilhança para responsabilizar o réu. Essa convicção de verossimilhança, é claro, não se confunde com a convicção de verossimilhança da tutela antecipatória, pois não é uma convicção fundada em parcela das provas que ainda podem ser feitas no processo, mas sim uma convicção que se funda nas provas que puderam ser realizadas no processo, mas, diante da natureza da relação de direito material, devem ser consideradas suficientes para fazer crer que o direito pertence ao consumidor.

Essa convicção de verossimilhança nada mais é do que a convicção derivada da redução das exigências de prova, e assim, em princípio, seria distinta da inversão do ônus da prova. Mas, o art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor alude, expressamente, à possibilidade de inversão do ônus da prova quando a alegação for verossímil. Na verdade, quando esse código mistura verossimilhança com inversão do ônus da prova, está querendo dizer que basta a verossimilhança preponderante ou que a inversão do ônus da prova pode ser utilizada como regra de juízo, ainda que ao réu não tenha sido dada oportunidade para a produção de prova e que a convicção, que deu origem à decisão que inverteu o ônus da prova, seja apenas de verossimilhança.¹⁵⁵

No caso em que o autor alega que um defeito no sistema de freios do seu veículo lhe acarretou um acidente com danos materiais e pessoais, e o fabricante não demonstra a inexistência desse defeito, a dificuldade no preciso esclarecimento de que o dano foi gerado pelo defeito não pode ser suportada pelo consumidor, bastando-lhe, assim, fazer o juiz acreditar na verossimilhança de que esse defeito tenha provocado o dano. A dificuldade no pleno esclarecimento da relação de causalidade diante do risco probatório assumido pelo fabricante – que produziu o sistema de freios com defeito –, obviamente, deve ser imputada a ele. É por isso que basta a verossimilhança ou que o juiz inverta o ônus da prova, com base na verossimilhança, na própria sentença.¹⁵⁶

A outra hipótese de inversão do ônus da prova na sentença decorre da chamada hipossuficiência do consumidor. Por hipossuficiência, aqui, deve-se entender a impossibilidade de prova – ou de esclarecimento da relação de causalidade – trazida ao consumidor pela violação de uma norma que lhe dá proteção por parte do fabricante ou do fornecedor. A hipossuficiência importa quando há inesclarecibilidade da relação de causalidade e essa impossibilidade de esclarecimento foi causada pela própria violação da norma de proteção.

Melhor explicando: em determinados casos, ainda que não seja possível determinar, por meio de prova, que um defeito ocasionou um dano, seja porque as provas não são conclusivas, seja porque as regras de experiência não são absolutas, pode ser viável ao menos chegar a uma convicção de verossimilhança, a qual é legitimada em razão de que o violador da norma de proteção assumiu o risco da dúvida. Nessas situações, é possível inverter o ônus da prova na sentença com base na verossimilhança da alegação. Porém, quando não se pode chegar nem mesmo à verossimilhança da alegação, basta a hipossuficiência, ou a impossibilidade de o consumidor produzir prova para esclarecer a relação de causalidade, com o acréscimo de que essa impossibilidade para legitimar a inversão do ônus da prova, deve ter sido acarretada pela própria violação do dever de proteção.¹⁵⁷

Nessas duas hipóteses, a inversão do ônus da prova é uma regra de juízo, ou melhor, é uma regra de decisão, capaz de permitir ao juiz se convencer e decidir de acordo com a relação de direito material. Não há sequer motivo para pensá-la como regra dirigida à parte, pois em nenhum dos casos se exige prova do fabricante ou do fornecedor.

Mas, quando a prova é impossível, ou muito difícil, ao consumidor, e possível, ou mais fácil, ao fabricante ou ao fornecedor, a inversão do ônus da prova se destina a dar a este a oportunidade de produzir a prova que, de acordo com a regra do art. 373, caput, incumbiria ao autor, nos exatos termos do art. 373, § 1.º, do CPC. Agora não se trata de inverter o ônus da prova para legitimar – na sentença – a incompletude ou a impossibilidade da prova, mas de transferir do autor ao réu o ônus de produzi-la – o que deve ser feito no saneamento do processo.

Em síntese, a regra do art. 6.º, VIII, do CDC, não exclui a incidência do art. 373, § 1.º, do CPC, já que os dispositivos tratam de problemas diversos e conduzem a institutos também diferentes. Um deles (o do CDC) trabalha com situações em que certa prova é impossível, o que justificaria imputar ao fornecedor o prejuízo da dúvida; o preceito do CPC, ao contrário, pretende distribuir entre as partes o dever de aportar provas ao processo – quando possível – extraído de sua falta presunções decorrentes do comportamento da parte (com a aplicação do ônus correspondente).

Alguém perguntaria se, nesse último caso, a inversão seria fruto da verossimilhança ou da hipossuficiência. Como essa verossimilhança, conforme já dito, não deve ser confundida com a verossimilhança própria aos juízos que se formam no curso do processo, somente a dificuldade de produção de prova caracterizada pela peculiar posição do consumidor – ou a hipossuficiência – pode dar base à inversão do ônus da prova na audiência preliminar.

23. Ônus da prova, convicção e motivação

Como o art. 373 e a alteração do ônus da prova, como regras de decisão, supõem que o juiz não tenha encontrado uma convicção de verdade, cabe tentar deixar mais claro o significado dessa ausência de convicção, assim como o da chamada “inesclarecibilidade” do fato constitutivo e o da convicção de verossimilhança. Essa última, aliás, abre oportunidade a um julgamento de procedência com base na ideia de verossimilhança preponderante ou, como deseja o art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a partir da inversão do ônus da prova fundada em verossimilhança.

Melhor esclarecendo: para o juiz aplicar a regra do art. 373, caput, deve chegar a um estado de dúvida. Para impor a modificação de que trata o art. 373, § 1.º, do CPC, deve estar diante de situação em que a regra geral do ônus da prova implica gravame exagerado para a parte inicialmente onerada, o que não ocorreria caso o ônus fosse atribuído a seu adversário. Para inverter o ônus da prova com base em hipossuficiência – na sentença – deve concluir que o fato constitutivo é insuscetível de elucidação. E, finalmente, para inverter o ônus da prova com base em verossimilhança, ou ainda para se fundar na ideia de verossimilhança preponderante, deve formar ao menos uma convicção de verossimilhança.

Acontece que a convicção – como já demonstrada – não pode ser medida em graus ou em números. A dúvida, a inescclarecibilidade e a convicção de verossimilhança, ainda que constituam pressupostos para o juiz decidir, apenas podem ser demonstradas na motivação da sentença, ocasião em que o juiz justifica a decisão.

Como a convicção é explicada por meio da motivação, é possível dizer que a convicção é racionalizada na motivação, ou melhor, a convicção de verdade, a dúvida, a inescclarecibilidade do fato constitutivo e a convicção de verossimilhança são racionalizadas mediante a própria racionalização dos argumentos utilizados para justificá-las. Ou seja, a legitimidade da inversão do ônus da prova com base em verossimilhança ou com base em hipossuficiência – ou mesmo a simples aplicação do art. 373 ou de seu § 1.º, do CPC – requer a análise da motivação. Se os argumentos utilizados – por exemplo, a existência de uma presunção ou de uma regra de experiência, ou a ausência de prova ou a sua impossibilidade – não forem adequados para justificar uma ou outra, ou ainda se a motivação incidir em falta de coerência lógica em relação aos critérios utilizados para demonstrar a convicção, a dúvida ou inescclarecibilidade, a decisão carecerá de legitimidade.

Isso demonstra a separação entre convicção, decisão e motivação. Em determinada dimensão, a convicção é importante para a decisão, pois o juiz para decidir tem que saber o que é necessário

(ou o que basta) para julgar o pedido procedente e, assim, quando é suficiente uma convicção de verossimilhança, por exemplo. Em outra perspectiva, a convicção somente importa quando é posta às claras, ou seja, quando é racionalizada na motivação. Ou seja, se a convicção é importante para a decisão, o certo é que a convicção e a decisão somente poderão ser compreendidas em face da motivação quando deverão ser justificadas racionalmente.

Portanto, se a inversão do ônus da prova requer, por exemplo, convicção de verossimilhança, a decisão que inverte o ônus da prova somente será legítima quando a sua motivação racionalizar adequadamente tal convicção e os elementos que a determinaram.

24. A inversão voluntária unilateral do ônus da prova

Já foi dito que o juiz, ao analisar o conjunto probatório, pode valorar a prova produzida pela parte que não tem o ônus de produzi-la em seu desfavor. Isso acontece, conforme explicado, em razão do princípio da aquisição da prova, isto é, pelo motivo que toda e qualquer prova, não importa por quem tenha sido produzida, ou se produzida em razão de determinação de ofício, deve ser valorada pelo juiz e, assim, serve para a formação do seu convencimento.

Diante do princípio da aquisição da prova, uma mesma prova, conforme o seu resultado, pode favorecer ao autor ou ao réu, de modo que se a prova, que também interessa ao autor, é requerida pelo réu, o juiz não pode indeferi-la sob o argumento de que o réu não tem o ônus da prova. Aliás, mesmo que a prova tenha sido requerida apenas pelo réu, o juiz somente deve homologar a sua eventual desistência depois de consultada a parte adversa. Pelo mesmo motivo, depois de deferida a prova, o requerimento de desistência da sua produção, por parte do réu, não deve ser levado em conta pelo juiz antes de ouvida a parte contrária.

Mas, o fato de o réu requerer a produção de uma prova que não lhe cabe não significa um desejo de assumir o ônus da prova que grava o autor, mas sim a vontade de influir sobre o convencimento do juiz para demonstrar que o fato constitutivo não existe. De modo que a atitude do réu, em princípio, deve ser vista apenas como contraprova, e não como inversão unilateral do ônus da prova. Portanto, se o juiz, ao final do processo, tiver dúvida sobre a existência do fato constitutivo, o pedido deverá ser julgado improcedente, pois o ônus da prova é do autor, ainda que o réu tenha requerido contraprova.

Assim, não é porque o réu requereu a produção de prova documental ou de prova testemunhal para demonstrar a não existência do fato constitutivo, e o seu resultado pode interessar ao autor, que o ônus da prova do fato constitutivo foi invertido. Não há nada, nesse caso, que indique que o réu teve desejo de assumir o ônus da prova. Ao contrário, o seu desejo foi o de convencer o juiz de que o autor não tem o direito afirmado.

Porém, algo diferente acontece quando é considerada uma determinada prova pericial que especificamente interessa ao autor, mas foi requerida pelo réu. Ou melhor, a inversão do ônus da prova implica na assunção do ônus sobre o fato, ao passo que o requerimento de uma específica e determinada prova pericial (ou mesmo da ouvida de certa testemunha) quer dizer apenas que a prova, que era do interesse do autor, será produzida por ter sido requerida pelo réu, e ao final valorada para formar o convencimento do juiz – que então não deve se importar com a proveniência da prova.

Essa situação, no entanto, não deve ser compreendida como uma verdadeira inversão unilateral do ônus da prova. Por inversão unilateral do ônus da prova, somente é possível conceber a assunção da produção de uma específica prova que é da incumbência da parte contrária que poderá ser realizada, ainda que a parte que não tem o ônus de produzi-la, dela desista.

Comoglio, Ferri e Taruffo afirmam que a inversão unilateral do ônus da prova se verifica quando uma parte se oferece para provar um fato que não tem o ônus de provar, assumindo as consequências negativas do seu eventual insucesso.¹⁵⁸ Entretanto, é improvável que uma parte deseje assumir o ônus da prova sobre um fato que incumbe à outra parte provar. Racional é supor

que a parte ao requerer a prova sobre um fato que não lhe cabe provar esteja tentando fazer uma contraprova. Apenas nos casos de requerimento de uma específica prova que interessa à outra parte é que a parte requerente pode sofrer as consequências negativas do resultado da prova.

Comoglio, Ferri e Taruffo advertem que a jurisprudência italiana é rigorosa em exigir que o réu, ao requerer uma prova que não tem o ônus de produzir, assuma explicitamente as consequências negativas que sofrerá no caso de não conseguir provar o fato que não tem o ônus de demonstrar.¹⁵⁹ Contudo, ao menos quando considerada uma específica prova – e não o ônus da prova do fato – não parece que a parte não onerada tenha que assumir, de forma explícita, o risco do resultado da prova, pois esse risco é logicamente aceito quando a prova é requerida. Ou melhor: a parte assume o risco da prova no mesmo instante em que assume o seu ônus.

Postas essas premissas, observe-se o contido no art. 373, § 3.º, do CPC.¹⁶⁰ Essa, como se tem por evidente, é a que resulta de convenção entre as partes. Sua leitura evidencia que toda a regra do art. 373 é de cunho dispositivo, podendo ser alterada livremente, desde que observados certos limites, pelas partes. Essa conclusão ressaí evidente da interpretação a contrario sensu do § 3.º do art. 373, em questão. Como esclarece este dispositivo, “a distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I – recair sobre direito indisponível da parte; II – tornar excessivamente difícil a uma das partes o exercício do direito”.

Ora, se apenas em tais casos é proibida a convenção que distribua de forma diversa o ônus da prova entre as partes, então em todas as demais situações esta convenção é admitida. Trata-se, portanto, de negócio jurídico processual, admitido desde que satisfeitos os requisitos para a validade de qualquer negócio jurídico (agentes capazes, objeto lícito e forma admitida em lei). Trata-se, ademais, de instituto clássico no direito nacional, que demonstra, embora de modo restrito e pouco usado, há muito a presença de instrumentos de contratualização do processo encampada pelo legislador de 2015 (art. 189).

Assim, desde que as partes sejam capazes – capacidade de ser parte e capacidade de estar em juízo – e desde que intervenham nesse acordo todas as partes que serão atingidas pela distribuição distinta do ônus da prova, é viável realizá-la. Sublinhe-se, todavia, que esse acordo poderá eventualmente ser invocado – para afastar os efeitos da possível sentença desfavorável – por terceiros prejudicados, ainda que intervenientes no processo, quando, por sua incidência, a defesa dos interesses destes terceiros puder vir a ser afetada. Em tais casos, demonstrando a ocorrência do prejuízo em decorrência desta modificação convencional do ônus da prova, o terceiro poderá afastar o efeito de intervenção (art. 123, I), exigindo reapreciação judicial de suas alegações.

Quanto à licitude do objeto para esse negócio processual tem-se que, em princípio, qualquer causa, ressalvadas as hipóteses apresentadas no § 3.º, do art. 373, autoriza a sua elaboração. Também não são suscetíveis de modificação do ônus da prova as causas que versem as relações de consumo, sempre que essa “inversão” venha em prejuízo do consumidor (art. 51, VI, do CDC). Ainda, não admitem modificação do ônus da prova as situações em que normas ditadas no interesse público (e, portanto, de caráter cogente) atribuem o ônus de certa prova a alguém. Como se está aqui diante de regra de conteúdo impositivo (inafastável pela vontade das partes), obviamente não terá cabimento a modificação convencional do ônus da prova nesses casos. Desse modo, sempre que, por exemplo, existir regra que fixe presunção legal relativa em relação a determinado fato, sendo essa regra caracterizada como de ordem pública, não será admissível a alteração de seu conteúdo, através da manipulação convencional do ônus da prova.¹⁶¹

Em relação, finalmente, à forma da modificação convencional, a lei não impõe modo predeterminado. Admite-se, pois, que seja veiculada por qualquer forma. Poderá esta convenção ser realizada dentro do processo ou fora dele. Poderá constar de contrato, como cláusula específica (a fim de prevenir futura demanda, ou facilitar a condição de uma das partes nesta) ou poderá ser objeto de pacto específico. Poderá versar sobre várias afirmações de fato ou apenas sobre algum dos pontos do processo. Não há, enfim, forma legal predefinida para essa convenção.

Poder-se-ia cogitar, eventualmente, de requisito formal específico para a convenção sobre ônus da prova naqueles casos em que a lei material exige certa forma para atos jurídicos (a exemplo dos

arts. 108, 1.369, 1.653, 1.793 e 2.015 do CC). Em tais casos, seria possível pensar que, como a lei exige a escritura pública para a validade do negócio jurídico a respeito de tais matérias, a mesma forma seria exigível para a convenção a respeito do ônus da prova. Não parece, todavia, adequada essa conclusão.

Na realidade, a convenção que aqui se estabelece é sobre a prova de afirmação de fatos. Não há qualquer disposição a respeito dos direitos envolvidos (para cuja disposição se exige a forma específica). Não tem, portanto, cabimento estender o requisito de validade dos negócios jurídicos a respeito de tais direitos para abranger também o negócio jurídico processual, incidente sobre a prova de afirmação em relação àqueles atos. Há, portanto, liberdade de forma sempre no que diz respeito a essa convenção.¹⁶²

A única ressalva que se admite diz respeito a eventuais exigências, feitas pelo direito material, em relação a cláusulas como a aqui examinada. Exemplificativamente, tem-se a regra do art. 424 do Código Civil, que determina que em contratos de adesão, tratando ou não de relação de consumo, são nulas as cláusulas que “estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio”. Pode suceder que a cláusula que modifique o regime do ônus da prova conflite com o comando acima exposto. Nestes casos, obviamente, não será ela admissível.

Pontes de Miranda,¹⁶³ argumentando sobre este preceito, considera que “os próprios contratantes podem estabelecer que somente alienará algum bem móvel ou semovente, se a prova do depósito em pagamento foi em determinado banco, ou que só recebe cheque visado”. Na verdade, porém, parece não ser o tema de que trata esse dispositivo. Todavia, a fixação de certo meio específico de prova – para a demonstração de determinado fato em juízo – como cogitado pelo autor, deve, realmente, ser admitida, ainda que sob fundamento distinto: não tem ela por base o § 3.º do art. 373 em comento, mas sim a apreciação dos requisitos formais do negócio jurídico celebrado entre as partes (a respeito do direito material).

25. Convenção sobre o ônus da prova e direito indisponível

Se determinados direitos são indisponíveis e se algumas pessoas não podem dispor dos seus direitos – ainda que esses, em relação às outras pessoas, sejam disponíveis – o direito processual obviamente deve impedir tal disponibilidade e, ao mesmo tempo, conter normas que sejam capazes de evitar que essa disponibilidade ocorra de forma indireta.

A norma do art. 373, § 3.º,¹⁶⁴ I, enquadra-se nessa última situação, pois afirma que a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova é nula quando recai sobre direito indisponível da parte. O seu objetivo, como não é difícil perceber, é impedir que o titular de um direito indisponível, ou alguém que não tenha capacidade para dispor de um direito, ao assumir um ônus probatório que em princípio não lhe pertence, torne praticamente impossível a sua tutela por meio do processo.

Em outros termos, a finalidade da regra contida no inciso I do § 3.º do art. 373 é impedir que as partes disponham de maneira indireta e sub-reptícia de um direito indisponível.¹⁶⁵

Obviamente, só se veda a convenção sobre ônus da prova em demandas que envolvam direitos indisponíveis se o acordo for prejudicial ao titular do interesse indisponível. Do contrário, quando a modificação do ônus probatório lhe for favorável, nenhum sentido haveria em se recusar aplicação ao negócio processual.¹⁶⁶

26. Convenção que torna excessivamente difícil à parte o exercício do direito

A convenção sobre o ônus da prova, além de somente poder incidir sobre direito disponível, não pode tornar excessivamente difícil à parte o exercício do seu direito, conforme expressamente dispõe o inciso II do § 3.º do art. 373.

Porém, antes de tudo é preciso verificar se essa convenção, quando admissível, impede o juiz de determinar prova de ofício.

Tal convenção, como é evidente, não torna incontroverso um fato, pois não recai sobre fato algum, mas apenas sobre o ônus da prova. A parte que adquire mediante convenção o ônus da prova, assume o risco da dúvida, ou melhor, o risco de não ser capaz de convencer o juiz sobre a existência de um fato que, antes da convenção, deveria ser provado pela outra parte. Entretanto, assumir o risco da dúvida não significa eliminar a possibilidade de o juiz determinar prova de ofício, uma vez que, conforme já vimos, o juiz não tem o seu convencimento limitado à atividade da parte que possui o ônus probatório. A parte que assume o ônus da prova somente sofre o efeito derivado do risco da dúvida quando o juiz não se convence. Ora, o fato de o juiz ter o poder de determinar prova de ofício não quer dizer que sempre lhe será possível determiná-la, ou mesmo que, quando possível, essa prova sempre será capaz de convencê-lo da existência do fato.

Colocado o problema nesses termos, resta analisar quando a convenção, ao recair sobre direito disponível, torna excessivamente difícil o exercício do direito. Excessivamente difícil não é o mesmo que impossível, já que é evidente – e assim não precisaria estar escrito em norma alguma – que a convenção não pode tornar impossível o exercício do direito.

No caso em que a convenção é inserida em um contrato de adesão, em prejuízo do aderente, não é difícil concluir sobre a sua abusividade, pois destinada a dificultar a eventual situação processual deste. Fora daí é necessário verificar se a convenção é racional, uma vez que assim não é aquela que retira o ônus probatório da parte que, diante do direito material, está em condições favoráveis para a demonstração do fato (art. 190, do CPC).

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I – notórios;

II – afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III – admitidos no processo como incontroversos;

IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

1. Introdução

O art. 374 trata de algumas situações em que os fatos não precisam ser provados. Tais fatos não exigem que o autor se preocupe em prová-los.

Em princípio, o juiz está dispensado de formar uma convicção sobre esses fatos enquanto fatos individuais, embora deva considerá-los quando da valoração do conjunto probatório ou no momento da decisão.

2. Fatos notórios

O fato notório é, antes de tudo, um fato que possui a mesma importância dos demais fatos articulados pela parte. Como fato essencial, é imprescindível para a composição da causa de pedir, e, como fato secundário, importa para a demonstração do fato essencial.

A diferença está em que o fato, quando notório, dispensa prova para ser aceito como verdadeiro. Como se vê, a notoriedade é uma qualidade do fato, ou melhor, é uma qualidade do fato que é conhecido no momento e no lugar em que a decisão é proferida.

No que diz respeito ao lugar é simples entender que um fato pode ser notoriamente conhecido em um lugar e não em outro. Quanto ao momento, cabe esclarecer que um fato pode se tornar, ou mesmo ter sido, notório. Por isso, a notoriedade deve ser relacionada com o momento da decisão. Um fato pode ser i) presenciado pelo público ao ocorrer, ii) mais tarde ser transmitido ao

conhecimento do público, ou ainda iii) restar esquecido. Note-se que os meios de comunicação de massa podem transmitir um fato ao vivo ou levar o seu acontecimento à população, motivo pelo qual importam tanto para a imediata notoriedade, quanto para a sua posterior formação.

Um fato pode ser considerado notório (em termos gerais) quando faz parte da cultura do “homem médio” situado no lugar e no momento em que a decisão é proferida, assim como, por exemplo, eventos da vida social, política e econômica. Mas, determinados fatos podem ser notórios a certos agrupamentos, como aos estudantes de uma Universidade ou aos profissionais de uma determinada área. Fala-se, nesse sentido, em notoriedade relativa.¹⁶⁷

Como dito, o fato notório não depende de prova. Mas, para tanto, deve ser aceito com essa qualidade. Se o réu contesta a notoriedade do fato, o autor pode provar o fato afirmado notório ou apenas a sua notoriedade. Não é necessário que o autor prove o próprio fato afirmado como notório, bastando provar a sua notoriedade. Ainda que a notoriedade possa ser considerada um indício da existência do fato,¹⁶⁸ a partir da regra de experiência de que o fato considerado notório em geral existe, não é possível esquecer que essa regra de experiência foi expressamente adotada pelo art. 374, I, que estabeleceu que o fato notório independe de prova. Ora, se o art. 374, I, reza que o fato notório não depende de prova, basta demonstrar a sua notoriedade.

Contudo, o réu pode afirmar a falsidade da convicção daqueles que têm o fato como verdadeiro, sem negar a existência de um conhecimento geral que o admite como verdadeiro. Nesse caso, o juiz pode entender, na audiência preliminar, que o fato, ainda que notório, deve ser provado, quando então deverá ser provado o próprio fato, uma vez que a sua notoriedade (conhecimento geral) é incontroversa.

Mas, para a devida compreensão do tema que aqui interessa, é preciso distinguir fato notório e regra de experiência.¹⁶⁹ Lembre-se que, de acordo com o art. 115 do CPC italiano, o juiz pode utilizar, como fundamento da sua sentença, sem necessidade de prova, “*le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza*”, e que essa norma, segundo a maior parte da doutrina italiana, refere-se aos fatos notórios e às regras de experiência.¹⁷⁰ Contudo, os fatos notórios e as regras de experiência não apenas possuem naturezas distintas, como também têm funções completamente diferentes no processo.

Por regras de experiência é preciso entender as generalizações, noções, critérios, leis empíricas, assim como as noções fundadas em leis naturais, lógicas e científicas, que o juiz – considerado como “homem médio” – encontra na “experiência do mundo”.¹⁷¹ As regras de experiência, portanto, ligam-se às formas por meio das quais o homem pensa sobre o mundo. Tais formas assumem a condição de regras de experiência no processo exatamente para que o juiz possa pensar sobre as provas e os fatos. Assim, por exemplo, o juiz analisa a credibilidade de uma prova, valora as provas e estabelece a relação entre o fato indiciário e o fato essencial através das regras de experiência. Ou seja, uma regra de experiência serve até mesmo para se extrair a verdade de um fato do notório.

O fato notório, como todo fato necessário para o autor demonstrar o seu direito, deve ser afirmado na petição inicial,¹⁷² ao contrário das regras de experiência, que constituem regras de juízo, e assim obviamente não precisam ser alegadas pelas partes. É fácil concluir que da diferença de natureza e de função entre os fatos notórios e as regras de experiência decorrem efeitos, como o de que apenas o fato notório deve ser alegado – e não a regra de experiência.

3. Confissão

Confessa a parte que admite como verdadeiro um fato ou um conjunto de fatos desfavoráveis a sua posição processual, mas favoráveis à pretensão do seu adversário (art. 389, CPC). A confissão é classificada em efetiva e ficta, judicial e extrajudicial e espontânea e provocada.¹⁷³

A confissão efetiva constitui conduta positiva ou atitude da parte realmente ocorrida no mundo fático, e que, por isso, foi presenciada pelo juiz (ou por outra pessoa habilitada a documentá-la),

não podendo ser desprezada. Ao contrário, a confissão ficta consiste em mera ficção jurídica – imposição do legislador – sendo de somenos relevância se reflete ou não o efetivamente ocorrido. Dessas ideias, pode-se desde logo perceber que a confissão efetiva representa argumento (para o juiz) robusto e quase insuperável, já que consiste no reconhecimento, pela parte, de que certo fato contrário ao seu interesse e favorável ao interesse da parte adversa, efetivamente, se passou da forma como narrado. Já a confissão ficta, como ficção de confissão que é, advém de mera imposição legal (de regra abstrata e genérica), sendo desvincilhada dos fatos concretos da causa.

Por outro lado, a lei admite a confissão judicial ou extrajudicial. A confissão extrajudicial é aquela produzida fora do processo. Em princípio, ela tem a mesma eficácia da confissão judicial; porém, se feita de modo oral, somente tem valor quando a lei não exige prova literal (art. 394, CPC).

De outra parte, afirma o art. 390 do CPC que a confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. A confissão provocada ocorre quando a parte, em seu depoimento pessoal, acaba por confessar fatos contrários ao seu interesse e favoráveis ao adversário. Enquanto isso, a confissão espontânea pode se dar em qualquer momento do processo, no caso em que a parte nele comparece pessoalmente, ou através de advogado munido de poderes específicos, admitindo como verdadeiros fatos contrários ao seu interesse e favoráveis ao seu adversário.

A confissão, tanto judicial quanto extrajudicial, pode ser feita por representante dotado de poderes específicos. Como diz o art. 213, parágrafo único, do CC, em preceito repetido pelo art. 392, § 2.º, “a confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado”. A confissão feita por alguém sem poderes para confessar, ou que extrapole os limites dos poderes que lhe foram conferidos, é ineficaz – e não nula – o que significa que a confissão decorrente da falta de poderes não possui a eficácia própria e peculiar à confissão feita por quem está apto a confessar, embora possa ser ratificada na forma adequada e fornecer ao juiz elementos de convicção.

A confissão espontânea difere da não contestação, pois esta não exige que o advogado tenha poderes especiais. Ademais, a confissão é suficiente para dispensar a prova sobre o fato confessado, enquanto que a não contestação, além de requerer um comportamento passivo do réu em relação ao fato, exige também a falta de outras afirmações que possam, ainda que implicitamente, demonstrar a vontade de contestar o fato afirmado.

Embora o art. 391 afirme que a confissão faz prova contra o confitente, o art. 374, II, deixa claro que não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. É sabido que a confissão (Geständnis), no direito alemão, é um instituto que exclui a necessidade da prova, tendo ela sido equiparada, no que diz respeito aos seus efeitos, ao instituto da não contestação (Nichtbestreiten).¹⁷⁴ Não é por outra razão que Rosenberg afirma que “o efeito da confissão consiste em que o fato admitido não necessita de prova e deve ser considerado pelo magistrado como verdadeiro na sentença, ainda que ele não esteja convencido de sua veracidade”.¹⁷⁵

Portanto, diante do art. 374, II, a confissão deve ser vista como uma circunstância determinante da dispensa da prova sobre o fato confessado. A confissão gera duas consequências: a dispensa de prova do fato pela parte contrária (art. 374, II) e a presunção de veracidade (quase que absoluta) sobre o fato confessado. Note-se, porém, que a tese de que a confissão dispensa a prova sobre o fato confessado não se choca com a ideia de que o juiz pode chegar a uma conclusão distinta da que decorre da confissão.

Quando tratamos do fato notório, advertimos que a circunstância de um fato ser de conhecimento público – portanto, notório – não exclui a possibilidade de o juiz formar uma convicção diversa daquela que as pessoas têm sobre o fato. Mesmo que o fato notório não dependa de prova, o juiz pode ter dúvida sobre a sua essência, ou seja, sobre a verdade do fato, ainda que a seu respeito exista uma versão notória.

É certo que, em relação à confissão, a situação é diferente, uma vez que ela é feita pela própria

parte, não decorrendo de terceiros, como o fato notório. Contudo, também em relação ao fato confessado, o juiz pode, ainda que excepcionalmente, formar uma convicção distinta. Ou seja, não há racionalidade em aceitar um fato, ainda que confessado, que colide frontalmente com outros fatos aceitos como verdadeiros, ou que é logicamente inexplicável por intermédio das regras de experiência.

Por outro lado, parece importante frisar a diferença entre a confissão, a não contestação e o reconhecimento jurídico do pedido. Esse último pertine ao direito, enquanto que a confissão e a não contestação dizem respeito somente a fatos.

Na realidade, o instituto do reconhecimento jurídico do pedido – que possui origem no direito alemão – não se confunde com a confissão e com a não contestação, pois se refere a uma admissão mais ampla – do próprio pedido e não de um fato – chamada pela doutrina alemã de reconhecimento judicial (*gerichtliches Anerkenntnis*).¹⁷⁶

O réu, ao reconhecer a procedência do pedido, impede que o juiz solucione o litígio, mas abre mão do seu direito material, sendo o processo encerrado com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, a. Porém, na confissão e na não contestação, o réu apenas aceita determinados fatos como verdadeiros, o que pode conduzir, ou não, ao reconhecimento do direito pelo juiz, até porque dos fatos confessados podem não decorrer os efeitos jurídicos pretendidos.¹⁷⁷

4. Não contestação

4.1. O dever de contestar na forma específica, suas exceções e os efeitos da sua inobservância

Discute-se, no direito italiano, a respeito da existência de um princípio geral de não contestação. Parte da doutrina afirma a existência desse princípio, segundo o qual o fato não contestado não tem necessidade de ser provado e é excluído do *thema probandum*.¹⁷⁸

Sustentando esse princípio, alguns processualistas dizem que os fatos afirmados por uma parte e não contestados pela outra devem ser considerados provados,¹⁷⁹ enquanto outros escrevem que a não contestação não diz respeito ao campo probatório, pois não fornece ao juiz elementos de convencimento, mas apenas impede que ele deva ou possa formar uma convicção autônoma a respeito dos fatos não contestados.¹⁸⁰

Mas há quem entenda que o ordenamento italiano não alberga um princípio geral de não contestação. Segundo os partidários dessa tese, a regra geral, no direito italiano, é a de que, em caso de fato não contestado, não se verificará alguma automática *relevatio ab onere probandi*, embora o juiz possa retirar da não contestação argumentos de prova,¹⁸¹ em conformidade com o art. 116 do CPC italiano.¹⁸²

No direito brasileiro, segundo o art. 341, o réu deve manifestar-se precisamente sobre os as alegações descritas na petição inicial, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato não impugnadas, salvo: (i) se não for admissível, a seu respeito, a confissão; (ii) se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento que a lei considerar da substância do ato; (iii) se estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Em nosso direito, como se vê, há um princípio que estabelece a necessidade de o réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, ficando dispensados de prova os fatos não impugnados ou não contestados. Para sublinhar a importância desse princípio, recorde-se que, segundo Calmon de Passos, há, em face do Código, “um ônus de impugnação atribuído ao réu, no tocante aos fatos alegados pelo autor, em sua inicial, como igual ônus cabe ao autor quanto aos fatos extintivos e impeditivos postos pelo réu em sua contestação, quando sobre eles tiver de se manifestar (art. 326¹⁸³). O princípio é salutar e sua admissibilidade, em termos mais rigorosos que os vigentes no direito anterior, será arma poderosa contra a chicana e o desnecessário e desmoralizante retardamento dos processos”.¹⁸⁴

Porém, afirma Calmon de Passos que, não ocorrendo qualquer das exceções previstas nos incisos do art. 341 (acima lembradas), o fato não impugnado é fato provado, pois não reclama produção de prova.¹⁸⁵ Nesse ponto, contudo, é preciso discordar, uma vez que não se pode confundir fato provado com fato dispensado de prova. Fato não contestado não é fato provado; a regra do art. 341 apenas dispensa o fato não contestado de prova. A norma do art. 341, em outras palavras, não tem por escopo fornecer ao juiz elemento de convicção, mas reduzir a massa dos fatos controversos, visando tornar mais eficiente a prestação jurisdicional.

Não se diga, por outro lado, à semelhança do que faz parte da doutrina italiana, que a não contestação de um fato afirmado pela parte adversária deve ser valorada de modo a fornecer ao juiz apenas argumentos de prova. Ora, para que o fato não seja considerado controverso, é suficiente que ele venha afirmado por uma parte e não contestado pela outra.

Ainda que o autor possa apresentar prova com a petição inicial, o certo é que o objeto da prova somente é definido após a contestação, precisamente na decisão de saneamento, quando o juiz deve fixar os fatos controvertidos – nos termos do art. 357. Se o objeto da prova somente é precisado após a contestação, de nada importará, em termos probatórios e de convicção, a prova fornecida pelo autor ou a eventual prova que o réu,¹⁸⁶ ou mesmo o juiz, de ofício, deseje ver produzida sobre o fato não contestado.

A não contestação de um fato, quando não se choca com o conjunto da defesa, implica a presunção legal da sua veracidade.¹⁸⁷ Nessa linha, adverte Patti que, segundo as teses mais contemporâneas, a exigência da prova se põe apenas depois da contestação e sua amplitude é por ela limitada, o que significa concluir que o objeto da prova é circunscrito pela contestação¹⁸⁸ – embora se possa dizer, apenas para ser mais preciso, que o objeto de prova é delimitado somente na decisão de saneamento, até porque o réu pode alegar, na contestação, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, quando o autor será intimado para sobre eles falar – nos termos do art. 350 do CPC brasileiro.

Contudo, como já salientado, a regra que dispensa o fato não contestado de prova não se aplica quando, a seu respeito, não for admissível a confissão. O art. 392 diz que não vale como confissão a admissão, em juízo, de fatos relativos a direitos indisponíveis. O art. 213 do CC – sem aludir a validade, mas sim a eficácia – afirma que “não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados”. Portanto, em relação a tais fatos, pouco importa a não contestação. Lembre-se, aliás, que o art. 345, II, afirma que a revelia não leva a que se repute verdadeiros os fatos alegados pelo autor se o litígio versar sobre direitos indisponíveis.¹⁸⁹

Além disso, segundo o disposto na norma do art. 341, II, não é presumido verdadeiro, ainda que não contestado, o fato que, para produzir os seus efeitos típicos, dependa de instrumento especial, considerado pela lei como da substância do ato. Como diz o art. 406, quando a lei exigir, como da substância do ato, o instrumento público, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Por outro lado, estabelece o art. 345, III, que a revelia não induz à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Trata-se do chamado documento substancial, que não se presta a provar o direito, mas sim a constituí-lo. Portanto, se o documento exigido for instrumento público, a não contestação não terá o condão de fazer presumir verdadeiro o fato.

O último dos incisos do art. 341 é o que requer mais atenção. Diz que os fatos não contestados não serão presumidos verdadeiros se estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Para que um fato possa ser considerado não contestado, não basta simplesmente a não contestação – ou um mero comportamento passivo em relação ao fato – sendo necessário verificar se outras alegações, contidas na contestação ou mesmo na reconvenção, não significam, mesmo que implicitamente, a sua negação. Se o réu deixa de contestar um fato de forma específica, o efeito da não contestação – ou seja, a admissão do fato como verdadeiro – somente se produzirá se

as demais alegações da defesa não forem tomadas como negação do fato não contestado de maneira individualizada.¹⁹⁰

Para que um fato não contestado possa ser presumido verdadeiro, é necessário analisar a defesa globalmente, verificando, a partir do conjunto das alegações do réu, se é certo concluir que o fato não especificamente impugnado foi aceito como verdadeiro. É apenas a partir da análise da defesa na sua totalidade que se pode dizer que um fato não contestado deve ser considerado incontroverso.

Ressalte-se, além disso, que a contestação através de respostas evasivas, que pode configurar deslealdade processual (arts. 77 e 79), não se presta para tornar controversos os fatos articulados pelo autor. É interessante lembrar, aliás, que o art. 549, 2.^a parte, da “Ley de Enjuiciamiento Civil” (espanhola) afirma que as “respostas evasivas” podem ser consideradas como uma espécie de “confissão” dos fatos a que se referem.¹⁹¹

No direito brasileiro, afirma o CPC que a parte tem o dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade (arts. 77, I, e 79, II) e que o réu deve se manifestar precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial (art. 341). Isso conduz à evidente conclusão de que as respostas meramente evasivas não tornam os fatos controversos.

O réu deve contestar especificamente todos os fatos articulados pelo autor.¹⁹² Vejamos o seguinte exemplo: “A” pede que “B” seja condenado a pagar indenização por ter ocasionado, por culpa, danos ao seu automóvel. “A” pode afirmar que “B” (i) cruzou a via preferencial; (ii) estava em velocidade não permitida; e (iii) estava embriagado. O réu deve contestar as três afirmações se não deseja favorecer o autor.

Na análise da não contestação é importante distinguir as seguintes hipóteses: i) pedido com pluralidade de fatos constitutivos; ii) não contestação dos fatos constitutivos de um dos pedidos, quando outros pedidos, amparados em outros fatos constitutivos, também foram deduzidos em juízo.¹⁹³

5. Presunção legal de existência ou de veracidade

O art. 374, IV, trata da presunção absoluta, também conhecida por presunção *iuris et de iure*, afirmando que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Nesse caso, o fato secundário (ou fato indiciário) do fato principal é o próprio fato principal, ao qual o legislador atribui um determinado efeito jurídico, relegando o fato que seria o principal ao nível de motivo ou de ratio.¹⁹⁴

O raciocínio presuntivo, em tal hipótese, fica apenas como suposto, pois é totalmente irrelevante para a aplicação da presunção. Fixada a hipótese normativa, a presunção desvincula-se do raciocínio que a autorizou, incidindo no caso concreto independentemente de qualquer outra valoração lógica. Vale dizer: a presunção abstrai-se totalmente da razão da sua existência e a lógica que subsidiou a sua previsão não tem qualquer relevância em juízo.¹⁹⁵

É por isso que o art. 374, IV, diz que os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade não dependem de prova. Na realidade, a avaliação fática, nesse caso, não importa para o juiz, pois as conclusões hipotéticas lançadas na lei o vinculam. Com efeito, a prova é inútil diante da presunção absoluta, não importa se destinada a reforçar a conclusão ou a tentar demonstrar que a presunção parte de um silogismo falso.¹⁹⁶ Toda espécie de contraprova ou de prova concorrente é irrelevante, na medida em que o suporte fático do silogismo, embora tenha sido importante para a sua fixação como hipótese normativa, não possui qualquer significado no caso concreto.

Lembre-se que, ao contrário do que ocorre em relação às presunções absolutas, as presunções relativas (ou *iuris tantum*) admitem prova em contrário, ou, mais precisamente, a prova que contraria a conclusão da presunção é relevante e pode afastar a incidência daquela. Por isso, as

presunções relativas relacionam-se a mecanismos de prova do fato, não estando abrangidas pelo art. 374, IV, em exame.

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

1. Regras de experiência comum e regras de experiência técnica

O juiz, para formar o seu raciocínio sobre o litígio, vale-se de regras de experiência, ditas comuns e técnicas. Essas regras têm o objetivo de permitir, entre outras coisas, a análise da relação entre o indício e o fato essencial.

As regras de experiência comum decorrem de generalizações formadas no seio da sociedade, as quais podem ter base em crenças religiosas, regras de moral ou mesmo em leis naturais, lógicas ou científicas.¹⁹⁷ Enquanto isso, as regras de experiência técnica derivam do pensamento técnico-científico sobre uma determinada situação.

Como as regras de experiência comum podem se fundar em leis científicas e as regras de experiência técnica delas derivam, alguma confusão pode ocorrer. Mas, essa confusão é facilmente eliminada quando se constata que a regra de experiência técnica é ancorada diretamente no pensamento científico (ou em uma lei científica), enquanto que a regra de experiência comum é uma versão popular acerca de uma lei ou do pensamento da comunidade científica.

2. Regras de experiência comum e regras gerais retiradas da experiência através da via indutiva

Como dito, as regras de experiência comum estão nos conceitos e versões que fazem parte da cultura da sociedade em determinado momento e local. Mas, essa ideia de regra de experiência foi negada pela doutrina que forjou os primeiros – e até hoje célebres – conceitos de regra de experiência ou de “máxima de experiência”.

Tais conceitos tiveram o nítido intuito de racionalizar a noção de regra de experiência, ligando-a a um modelo silogístico dedutivo do juízo de fato.¹⁹⁸ A regra de experiência deveria ser vista como uma regra geral, da qual derivaria, por dedução, a existência de um fato.

Friedrich Stein, em seu conhecido livro sobre o “conhecimento privado do juiz”, disse que as máximas de experiência são definições ou juízo hipotéticos de conteúdo geral desligados dos fatos concretos analisados no processo, procedentes da experiência, porém independentes dos casos particulares de cuja observação foram induzidos, e que, além desses casos, pretendem ter validade para outros.¹⁹⁹ Na concepção de Carnelutti –²⁰⁰ expressamente fundada em Stein – a regra de experiência²⁰¹ constituiria a premissa maior do silogismo e assim permitiria ao juiz deduzir, a partir do fato percebido, a existência ou não do fato essencial.

Assim, as regras de experiência seriam obtidas por meio de indução, e serviriam para legitimar, por meio de dedução, o fato probando.²⁰² Acontece que, como demonstrou Taruffo, não há sentido em imaginar que o senso comum formule regras de experiência capazes de estabelecer deduções dotadas de validade lógica.²⁰³ A sociedade e o senso comum elaboram regras e generalizações – muitas vezes fundamentais para o juiz raciocinar – não raramente destituídas de confirmação e que, por isso, estão além das regras gerais. Na realidade, caso as regras de experiência fossem reduzidas às regras gerais – como queria Stein – restariam eliminadas aquelas que o juiz precisa utilizar para compreender o conteúdo de fatos que somente podem ser explicados a partir de regras que fazem parte da cultura da sociedade, embora não possam ter o qualificativo de incontestáveis e plenamente válidas.²⁰⁴

Isso tudo quer dizer que as regras de experiência comum não são apenas aquelas que, induzidas a partir da experiência, permitem um raciocínio dedutivo capaz de afirmar a verdade de um fato, mas também aquelas que, surgidas do senso comum e também ancoradas na

experiência, são fundamentais para o juiz compreender um fato e, especialmente, a relação entre o indício e o fato essencial, ainda que não sejam capazes de garantir a incontestabilidade do raciocínio inferencial que ligou um ao outro.

Aliás, as próprias regras de experiência técnica podem não ser dotadas de sustentabilidade absoluta, podendo também receber esse qualificativo as que ainda não se consolidaram na comunidade científica – como será demonstrado no item 6, *infra*.

Como é possível perceber, a identificação das regras de experiência em regras gerais, devidamente consolidadas e capazes de garantir um raciocínio lógico-dedutivo suficiente para se concluir a respeito de um fato, se por um lado é capaz de racionalizar o problema e garantir maior segurança jurídica, por outro lado elimina do conceito de regras de experiência uma série enorme de situações em que o juiz tem que se voltar às regras de cultura para formar o seu raciocínio, o que significa dizer que apenas retira do conceito de regras de experiência algo que, necessariamente, deve ser utilizado pelo juiz e controlado pelas partes.

Ora, se isso fosse aceitável, toda essa matéria – que, por ser imprescindível ao juiz, não pode ser desprezada – teria que ser transportada para outro local, quando então seria necessário formar um novo conceito jurídico para abrangê-la, o que seria ilógico em termos de ciência do direito.

3. Controle da aplicação das regras de experiência. A importância da motivação

A circunstância de as regras de experiência terem um conteúdo mais abrangente do que aquele que era admitido por Stein e Carnelutti, estando umbilicalmente ligadas ao senso comum – e assim às generalizações e regras fincadas na cultura social – e à evolução contínua da tecnologia e da ciência – o que nega a possibilidade de se pensar somente em regras técnicas consolidadas no patrimônio científico – não significa que o juiz possa utilizá-las de maneira irracional e que as partes não possam controlar o seu uso.

O problema é saber como realizar esse controle. Diante da óbvia impossibilidade desse controle poder ser feito pela lei ou por um raciocínio lógico-formal, não resta outra alternativa a não ser pensar em critérios capazes de apontar para o uso e para a conceituação racional dessas regras.²⁰⁵

Embora tais critérios não devam ser analisados nesse momento, é importante frisar que as regras de experiência devem ser relatadas e demonstradas na motivação da decisão. Ou seja, o juiz, através de argumentação racional, deve demonstrar a idoneidade da regra de experiência, assim como a oportunidade do seu uso para a decisão. Essa é a única maneira de se garantir a racionalidade na utilização das regras de experiência e, ao mesmo tempo, a possibilidade de seu controle pelas partes, evitando que o juiz pense que pode utilizá-las sem qualquer critério, estabelecendo argumentos destituídos de qualquer valor.

Embora isso pareça evidente, o fato é que as decisões, na prática, sequer aludem às regras de experiência, e muitas vezes o juiz e as partes nem mesmo percebem a sua utilização. Portanto, a exigência de argumentação racional da validade das regras de experiência, embora imprescindível para a racionalidade da decisão e para o adequado uso do recurso, lamentavelmente não existe no cotidiano forense – o que é extremamente grave, especialmente quando considerada a dimensão da garantia da motivação das decisões.

4. Critérios para o controle das regras de experiência comum

A motivação deve aludir às regras de experiência, demonstrando os seus conteúdos e fundamentos. Ou deve explicar os significados e as bases de sustentação das regras de experiência, para que então fiquem claras as razões que conduziram à decisão. Mas, existem alguns critérios básicos para garantir a sua idoneidade, os quais constituem, por assim dizer, os primeiros filtros da racionalidade do seu uso. Vamos a eles.

Não é difícil perceber que uma regra de experiência pode ser negada ou ter a sua credibilidade

abalada com o passar do tempo. Por essa razão, a motivação deve demonstrar que a regra de experiência é correspondente ao momento em que a decisão é tomada. Além disso, deve ser referida ao que acontece na sociedade, não bastando a sua relação com algumas pessoas. Ou melhor, a regra de experiência deve ser extraída a partir do senso comum da coletividade ou da comunidade em que o fato a ser demonstrado está inserido. Em resumo, a motivação deve demonstrar, através de argumentação racional, a proveniência e a atualidade da regra de experiência comum.²⁰⁶

Quando há dúvida se a regra pertence ao senso comum da sociedade em determinado momento, a motivação deve confirmá-la com algum outro argumento. Isso quer dizer que a regra de experiência somente é bastante quando pode ser claramente demonstrada como pertencente ao senso comum em determinado momento e local.²⁰⁷

Acontece que a regra de experiência comum, em tese, pode ser contrariada por outra regra de experiência comum ou por uma regra de experiência técnica.²⁰⁸ Não há razão para estranhar a possibilidade de uma regra de experiência comum ser confrontada por outra da mesma natureza. Isso é absolutamente possível em razão da natureza dessas regras, plantadas no seio da conflituosidade das relações sociais. Ocorrendo eventual contradição entre regras de experiência comum, nenhuma delas merece presunção de credibilidade. Diante de uma circunstância desse tipo, seria arbitrário o uso de uma regra de experiência ao invés de outra, a menos que existentes outros argumentos a darem guarida a uma delas.

No caso em que a regra de experiência comum se choca com regra de experiência técnica deve prevalecer a última, pois o contrário seria afirmar a racionalidade de o juiz utilizar uma regra de experiência comum negada pela ciência.²⁰⁹ Por isso é importante ao juiz verificar a possibilidade de norma de experiência comum ser contrariada por norma de experiência técnica. Quando o juiz detectar tal possibilidade, não é necessário o recurso a um auxiliar técnico, embora isso não seja impossível em face das circunstâncias do caso concreto. A (des)necessidade de um profissional técnico, no caso em que se evidenciar uma questão técnica de razoável complexidade, deve ser explicada na motivação.

Até aqui tratamos de critérios básicos garantidores da idoneidade das regras de experiência. Porém, maior problema surge quando se pergunta sobre a base empírica de uma determinada regra de experiência comum. Para a análise dessa questão, é preciso deixar claro que uma regra de experiência, assim como qualquer outro fato, não pode pretender lograr uma incontestabilidade absoluta. Fixe-se, assim, a premissa de que toda e qualquer regra de experiência circula no patamar da probabilidade.²¹⁰ Dessa constatação decorre a consequência lógica de que a sua idoneidade funda-se em seu grau de probabilidade, ou melhor, na probabilidade que a motivação afirma existir a partir de certos dados.

Como se vê, é necessário estabelecer o significado desses “dados”, isto é, dos fundamentos que permitem ao juiz afirmar a probabilidade da regra de experiência. Quando se analisa a base empírica de uma regra de experiência, a primeira indagação recai sobre a sua amplitude, vale dizer, sobre o número de casos tomados em consideração. A partir daí, é preciso verificar a regularidade com que a regra de experiência se manifestou, ou melhor, se houve exceções e em que grau.²¹¹ A segurança da regra de experiência cresce na razão proporcional do número de casos e da regularidade da sua manifestação. Ou para ser mais preciso: a regra de experiência é tanto mais confiável quanto maior for o número de casos considerados, porém também depende da porcentagem em que é confirmada dentro do número de hipóteses analisadas.

A regra de experiência tem a sua credibilidade reduzida quando possui exceções. É lógico que essa credibilidade será tanto menor, quanto maior for o número de exceções, sendo que em algumas situações pode ser praticamente impossível determinar se a regra de experiência a elas se sobrepõe. Deixe-se claro, porém, que o fato de uma regra de experiência ter exceções não elimina a possibilidade de sua utilização. Porém, por reduzir a sua credibilidade, exige que o juiz a confirme a partir de outros argumentos ou provas ou das circunstâncias do caso concreto.

Note-se que uma regra de experiência tem, como seu inverso, a sua exceção, e não outra regra

de experiência contrária ao seu sentido. Daí, aliás, a importância da distinção, revelada pela lógica jurídica, entre contraditório e contrário, pelo que o contraditório de “branco” é “não branco” e o contrário de “branco” pode ser cinza etc. O contraditório da regra de experiência é a sua exceção, enquanto que nada impede a consideração, diante de um determinado caso conflitivo, de duas normas de experiência contrárias. Nessa particular hipótese uma delas deverá prevalecer, quando importarão os demais elementos do caso concreto.

Entretanto, não basta apenas pensar no conteúdo e na força da regra de experiência, sendo também preciso verificar o modo como ela é empregada. Isso porque, como não é difícil perceber, uma regra de experiência pode ter validade em si, quando considerada autonomamente, mas o seu emprego não ter cabimento diante de uma determinada situação concreta. É preciso que exista relação entre a situação fática e a regra de experiência, de modo que essa última seja realmente capaz de permitir a sua elucidação.

Lembre-se, ademais, que as regras de experiência que servem para um grande número de situações não têm a mesma eficácia das regras de experiência que se amoldam, de forma mais particularizada, a determinados fatos.²¹² Algumas regras de experiência, diante da sua generalidade e elasticidade, têm uma influência muito tímida sobre o convencimento do juiz, enquanto que outras têm grande importância para a elaboração do raciocínio inferencial.

5. Regras de experiência comum a respeito de questões técnicas, regras de experiência técnica e necessidade de auxílio de profissional técnico

Já foi dito que o senso comum pode produzir versões sobre questões técnicas, e que nesse caso há regras de experiência comum. Para ser mais exato, trata-se de regras que decorrem da observação do que ordinariamente acontece no manuseio de algumas técnicas. As regras de experiência técnica, ao contrário, são provenientes da comunidade científica, ainda que conhecidas pela coletividade e pelo juiz.

Como é óbvio, no caso em que há dúvida sobre uma regra de experiência comum da espécie referida, é imprescindível verificar se a comunidade científica tem posição a respeito. Nesse caso, se a regra de experiência técnica confirmar a regra de experiência comum, essa última será automaticamente substituída pela primeira, e se a regra de experiência comum se chocar com a regra de experiência técnica, prevalecerá a última.

Embora exista diferença entre regras de experiência técnica conhecidas pela coletividade e regras de experiência comum que constituem versões de questões técnicas, a circunstância de que as regras de experiência técnica são do conhecimento da coletividade não significa que o juiz não possa recorrer ao auxílio de um perito para esclarecê-las. Ora, se as regras de experiência técnica jamais pudessem requerer o auxílio de um perito, elas seriam apenas aquelas que estão consolidadas na comunidade científica.

6. Critérios para o controle das regras de experiência técnica

Lembre-se que frequentemente não há consenso a respeito de determinadas questões na comunidade científica. Em relação a esse ponto, aliás, cabe voltar a frisar a solução do general acceptance test, que foi utilizada nos Estados Unidos para determinar a credibilidade de uma regra técnica a partir do seu consenso na área científica.²¹³

Se a busca de consenso a respeito de uma regra técnica fosse imprescindível ou até mesmo desejável, tal método não teria sido rapidamente abandonado nos Estados Unidos sob a acusação de não considerar que a ciência sempre está em constante evolução – e que, assim, as técnicas sempre estão em mutação – e de não perceber que é muito habitual e quase natural a inexistência de consenso na esfera científica sobre certas questões – e que essa ausência de percepção impediria o juiz de adotar regras técnicas que, ainda que não absolutas, podem ser imprescindíveis para a compreensão dos litígios, especialmente quando conjugadas a outros elementos e circunstâncias dos diferentes casos concretos.

Nada deve impedir, diante de certos casos conflitivos, o uso de regras técnicas ainda discutidas na ciência, quando então o juiz poderá recorrer a um perito. O objetivo da participação do perito é definir os limites da discussão sobre a regra técnica, assim como o seu grau de credibilidade na comunidade científica, até porque, como já dito, mesmo as regras de experiência comum transitam no plano da probabilidade.

O auxílio do perito não deriva da necessidade de se estabelecer uma “certeza” sobre a questão científica, pois isso seria absurdo. É evidente que uma questão ainda controvertida pelos cientistas não pode ser solucionada por um perito judicial. Nesse caso, a função do perito é explicar a posição da comunidade científica sobre o conteúdo da questão.

O perito deverá considerar a base empírica da questão técnica, isto é, o número de casos em que foi submetida a teste, aprovada e reprovada. Além disso, deve bem esclarecer as suas consequências e implicações, ainda que naturalmente em termos de probabilidade, diante da própria controvérsia científica frente à questão. Para tanto, é fundamental ter em conta a idoneidade das fontes de relato das pesquisas, ou seja, o prestígio dos institutos que realizaram os estudos e das revistas ou jornais científicos em que foram publicados, e ainda se foram divulgados em congressos especializados e por cientistas reconhecidos.²¹⁴

Como está claro, o auxílio do perito obviamente não se presta para superar a dúvida sobre a questão técnica – pois isso nem os cientistas conseguiram fazer – mas sim para apontar o estado atual da questão diante da comunidade científica. A circunstância, absolutamente natural, de não existir definição científica acerca da questão técnica, não impede a sua consideração pelo juiz. O juiz não busca alcançar uma verdade da mesma qualidade daquela que importa aos cientistas. Ou seja, as exigências que são impostas aos cientistas são completamente diferentes daquelas que se colocam ao juiz.

Mas, alguém poderia dizer que é muito perigoso deixar ao juiz decidir se é necessário, ou não, o auxílio de um perito. Acontece que o juiz, ao aplicar uma regra de experiência técnica, deve demonstrá-la na motivação. Se houver dúvida quanto à regra e o juiz não determinar a intervenção pericial, a motivação certamente será falha, quando a regra adotada poderá ser objeto de controle através de recurso.

Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar.

1. Ônus de demonstrar o direito alegado

Afirma o art. 376 que o juiz pode determinar a prova da alegação do direito. Isso não quer dizer, é claro, que a parte não tenha o direito de impugnar o teor e a vigência do direito alegado. Nesse caso, o juiz pode determinar que a parte prove o direito que alegou, não existindo razão para se imaginar que a parte que o contesta deva fornecer prova em contrário.

Mas, ainda que o juiz desconheça o direito, e assim possa determinar a sua prova, nada impede – ao contrário aconselha – a sua atuação de ofício. Aliás, o § 293 da ZPO alemã, afirma expressamente que o juiz pode não se contentar com as provas produzidas pelas partes. Adverte que essa espécie de direito somente deve ser provada quando não conhecida pelo juiz e que “para a determinação destas normas de direito, o tribunal não está limitado às provas produzidas pelas partes, podendo valer-se também de outras fontes de conhecimento e ordenar tudo o que conduz à sua utilização”.

Porém, o juiz não pode determinar a prova do direito municipal ou estadual pertinente à sua competência. Em outros termos, se o direito municipal ou estadual é do Município ou do Estado em que o juiz exerce a sua atividade, não há como admitir que possa exigir prova do seu teor e vigência. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “tratando-se de norma legal editada pelo Poder Executivo do Distrito Federal, não pode o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal deixar de decidir questão arguida, sob o fundamento de que não fora juntado aos autos o texto da referida norma”.²¹⁵

Também não tem aplicação o comando em exame em recurso especial, conforme já entendeu o Superior Tribunal de Justiça.²¹⁶ Segundo a compreensão daquela Corte, dado que nas instâncias extraordinárias é vedada a produção de prova, não teria aplicação a regra que permite a “produção de prova” de direito local, estadual, estrangeiro ou consuetudinário.

2. “Alegação do direito”

Muito embora o art. 376 fale em prova da alegação do direito, tentando fazer acreditar que se está diante de algo semelhante a uma alegação de fato, a verdade é que essa alegação não insere na ideia de um fato no litígio, mas sim de uma regra – no processo – destinada a servir de base para a análise dos efeitos jurídicos dos fatos. Nessa perspectiva, é nítida a distinção entre alegação de fato e alegação de direito, sendo completamente descabida a sua pretendida identificação.

Não obstante isso, é patente que o que se prova não é o direito, propriamente dito. O que se prova são fatos. No caso, o que se prova é o *teor* e a *vigência* de certas regras, o que evidentemente não se confunde com a norma jurídica a ser extraída desses textos.

3. Direito municipal, direito estadual e direito estrangeiro

Como já anunciado acima, o juiz só pode determinar a prova do direito municipal ou estadual que não é conhecido no local em que possui competência.

Em relação ao direito estrangeiro, pode determinar a prova do seu teor e da sua vigência no caso em que o seu conhecimento for necessário para a regulação do litígio ou quando for importante para a aplicação da *lex fori*.²¹⁷

A prova do direito estrangeiro pode ser feita por ofício, conferido por autoridade competente do país de origem, por parecer de jurista, por passagem de livro reconhecido, ou ainda através de julgado recente do país estrangeiro, desde que a decisão não seja excepcional, mas realmente espelhe o pensamento que os tribunais possuem a respeito da regra a ser esclarecida.

4. Costume, fato notório e regra de experiência

O direito consuetudinário, também conhecido por costume, irradia-se da repetição de atitudes humanas que o meio social transforma em regras jurídicas.²¹⁸ Por direito consuetudinário se deve entender o costume que possui relevância jurídica, pois aquele que não possui eficácia jurídica não tem aqui qualquer importância.²¹⁹

Não é possível confundir, por outro lado, costume e fato notório. O costume não é um fato, como o fato essencial ou o fato indiciário, mas sim algo que se retira do comportamento da sociedade. O costume não é um fato que faz parte da fundamentação do pedido, e nesse sentido não precisa ser afirmado na inicial – ao contrário do fato notório. O costume não se insere na engrenagem de fatos que compõe a fundamentação, pois constitui, à semelhança da regra legal, algo que o juiz deve considerar ao verificar se dos fatos decorre o efeito jurídico pretendido. Por isso, o juiz não é obrigado a determinar a prova do costume, embora tenha a faculdade de assim proceder.

Ademais, o costume também se diferencia nitidamente da regra de experiência. Ainda que a regra de experiência constitua uma regra de juízo, o certo é que a regra de experiência importa apenas no processo, ao passo que o costume produz efeitos jurídicos no plano do direito material e, assim, não deve ser considerado apenas no processo.

O costume, como a regra de direito material, é observado no processo apenas quando o juiz indaga se dos fatos decorrem os efeitos jurídicos pretendidos, enquanto que a regra de experiência serve para o juiz valorar uma prova ou para estabelecer a relação inferencial entre o fato indiciário e o fato probando. A regra de experiência se destina a permitir a formação de um

critério lógico capaz de aferir o sentido dos fatos, mas o direito consuetudinário é tomado em consideração quando o juiz, já tendo aferido os fatos, analisa as suas consequências jurídicas. Ou para ser ainda mais claro: as regras de experiência comum são aplicáveis ainda que o costume (e não apenas a lei) possa regular a situação litigiosa.

Embora o direito consuetudinário não seja um fato, mas sim algo que serve para o juiz verificar as suas consequências jurídicas, o art. 376 afirma que o juiz pode determinar a sua prova. Isso, como é óbvio, quando o costume, além de não ser do seu conhecimento, não é próprio ao Município ou ao Estado em que está sediado.

Para que se possa compreender a prova do costume, é preciso previamente indagar sobre o seu conteúdo. Pois bem, é sabido que o costume é integrado por dois elementos: o uso e a chamada *opinio juris necessitatis*. O uso é caracterizado pela prática reiterada de um ato no seio da sociedade. Essa prática deve estar incorporada na vida social, e, por isso, além de pública, obviamente não pode ser episódica e proveniente apenas de algumas pessoas.

A *opinio juris necessitatis* consiste na convicção da necessidade da prática do ato para a obtenção de um efeito jurídico, ou seja, na convicção social da necessidade jurídica da prática do ato.²²⁰

Para a prova dos elementos caracterizadores do costume poderão ser produzidas todas as provas admissíveis, conforme as especificidades da situação concreta.

Art. 377. A carta precatória, a carta rogatória e o auxílio direto suspenderão o julgamento da causa no caso previsto no art. 313, inciso V, alínea “b”, quando, tendo sido requeridos antes da decisão de saneamento, a prova neles solicitada for imprescindível.

Parágrafo único. A carta precatória e a carta rogatória não devolvidas no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo poderão ser juntadas aos autos a qualquer momento.

1. Produção de prova através de carta precatória ou carta rogatória e suspensão do processo

O art. 313, V, b, do CPC, afirma que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito “tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo”. Dispõe o mesmo art. 313, em seu § 4.º, que nessa hipótese o período de suspensão nunca poderá exceder um ano, findo o qual “o juiz determinará o prosseguimento do processo” (art. 313, § 5.º, do CPC).

O art. 377 estabelece que a carta precatória e a carta rogatória somente suspendem o processo, no caso do art. 313, V, b, quando requeridas antes da decisão de saneamento do processo. Ou melhor: a carta precatória e a carta rogatória, quando necessárias para a verificação de um fato ou para a produção de uma prova, apenas suspendem o processo quando requeridas antes da decisão de saneamento. Embora o art. 313, V, b, incida quando for necessário produzir prova em outro juízo, o art. 377 deixa claro que a suspensão do processo somente pode ocorrer quando a carta houver sido requerida antes do saneamento do processo.

É preciso deixar claro que tal suspensão é relacionada à necessidade da prova para a compreensão dos fatos, embora essa necessidade possa não ser suficiente para se aguardar o retorno da carta. Como já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, “carta precatória não cumprida só suspende o processo quando requerida antes do saneador. Não basta a indispensabilidade da prova, mas é preciso, também, que a precatória tenha sido requerida antes do saneador para suspender o processo”.²²¹

Porém, é preciso distinguir a situação em que a prova foi requerida no momento adequado, mas o pressuposto para a expedição da carta surgiu apenas após a decisão que saneou o processo. É o caso, por exemplo, de ter sido requerida prova testemunhal no prazo devido e, posteriormente, descobrir-se que uma das testemunhas deve ser ouvida através de carta precatória. Nessa hipótese, a carta deve ser recebida no efeito suspensivo, ainda que requerida após o saneamento.

De qualquer forma, as circunstâncias de a carta não ter efeito suspensivo quando requerida após o saneamento e de o prazo de suspensão não poder superar um ano não são absolutas, e assim podem ser amenizadas diante de especiais circunstâncias do caso concreto – quando o juiz entender que a prova é fundamental para a solução do litígio – desde que obviamente fundamentadas.

2. Carta devolvida em “qualquer momento” (quando já interposto recurso de apelação)

Quando a carta for requerida após o saneamento, e a prova que através dela se pretender produzir não tiver sido devidamente requerida, a sua expedição – em princípio – não deve ser deferida. Quando a prova for adequadamente requerida, e o pressuposto para a expedição da carta surgir após o saneamento, a sua expedição – como já dito acima – deve ser acompanhada pela suspensão do processo.

Mas, no caso em que a necessidade da expedição da carta era percebida quando do requerimento da prova, e a carta for requerida somente após o saneamento, o processo, em princípio (fora dos casos concretos marcados por especiais circunstâncias), não deve ser suspenso. Além disso, como reza o art. 313, § 4.º, essa suspensão não pode exceder a um ano.

Quando a carta for deferida sem efeito suspensivo ou devolvida depois de expirado o prazo para o seu cumprimento, poderá ser juntada aos autos “a qualquer momento” – diz o parágrafo único do art. 377. Por “qualquer momento” é possível entender o julgamento em primeiro grau de jurisdição ou o julgamento diante do recurso. Quem entende que o tribunal pode determinar a produção de prova de ofício, por lógica deve interpretar “qualquer momento” como o julgamento do segundo grau de jurisdição.

Evidentemente, a juntada dessa carta depois do julgamento de segundo grau é medida irrelevante, já que eventuais instâncias remanescentes (Tribunais Superiores) não têm atribuição de reexaminar fato. Em tais casos, eventualmente, deve incidir a hipótese do art. 966, VII, do CPC, a autorizar o emprego de ação rescisória, ainda que em interpretação ampliativa daquele preceito.

Art. 378. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade.

1. Dever de colaboração com o Poder Judiciário

A regra em exame apresenta determinação geral – aplicável às partes e a terceiros – a respeito da instrução processual. De acordo com ela, qualquer pessoa que possa trazer elementos capazes de influenciar a decisão judicial tem o dever de aportá-los ao processo. Por outro lado, a cláusula também importa em submeter o sujeito – parte ou terceiro, seja interessado ou não – ao poder judicial instrutório, caracterizando o seu dever “passivo” de colaboração.

Note-se que essa imposição de colaboração, ainda que genérica e impessoal, deve ser considerada um dever. Aliás, esse dever se relaciona com aquele estabelecido no art. 77, I, do CPC, que obriga as partes e a qualquer pessoa que participe do processo a “expor os fatos em juízo conforme a verdade”. Frise-se que esse dever, hoje, atinge qualquer pessoa que participe do processo – ainda que indireta e eventualmente – o que torna a simbiose entre o art. 77 e o art. 378 praticamente perfeita. Também por conta disso, é possível concluir que a violação desse dever caracteriza litigância de má-fé (art. 80, II, CPC), de forma a sujeitar o infrator à “multa, que deverá ser superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa” e a indenizar a parte prejudicada dos prejuízos sofridos, além dos honorários advocatícios e das despesas processuais (art. 81, CPC).

Evidencia-se, pois, que o descumprimento do dever estabelecido no art. 378 (e com maior razão daquelas imposições presentes nos arts. 379 e 380) possui punição clara no CPC, apresentando, por conseguinte, clara conotação coercitiva. A regra em questão, portanto, não constitui mera exortação para as partes e para os terceiros, mas verdadeiro comando dirigido a todos que

possam, de alguma forma, colaborar com o Poder Judiciário para a adequada solução da causa.

Com efeito, a ratio essendi dessa previsão é evidente: se o Estado deve solucionar o conflito de interesses com a finalidade de aplicar o direito – sendo esse, também, o objetivo último da sociedade na instituição do Estado-jurisdição – a coletividade deve ministrar meios (de forma mais completa possível) para que a decisão jurisdicional seja a mais adequada possível. Daí resulta que o dever de colaboração é inerente ao monopólio da jurisdição. Demais disso, não é possível esquecer que esse dever decorre do dever geral de sujeição ao poder do Estado. Afinal, se todos estão submetidos ao poder estatal, igualmente estão subjugados pela jurisdição, de forma a estarem constrangidos a colaborar com o Estado para a “descoberta da verdade”.

2. Exclusão do dever de colaboração

Mas, em que pese a aparente amplitude da regra em questão, o dever de colaboração nem sempre se impõe às partes ou aos terceiros. Por razões claras, as partes têm um dever mais abrangente do que alguns terceiros, sendo que algumas restrições aplicáveis a estes podem não ser invocáveis por aqueles. Porém, há situações em que ninguém (seja parte ou terceiro) está sujeito à colaboração com a jurisdição. Normalmente tais casos vinculam-se a situações de proteção de outros interesses – também relevantes para a ordem jurídica – que, no caso concreto, acabam por sobrepor-se à genérica imposição de colaboração. Costuma-se tratar de tais hipóteses sob a rubrica de regras de exclusão, termo tirado do direito norte-americano e que aponta de modo claro a finalidade de tais preceitos: exonerar o sujeito do dever de colaboração em razão de um interesse mais relevante (na situação concreta) para a ordem jurídica.

O CPC é repleto de regras que excluem o dever de colaboração (das partes e de terceiros) diante de determinadas situações. Também legislações extravagantes preveem situações similares, especificamente em relação a determinadas informações ou a respeito de certas categorias de pessoas.

Assim, por exemplo, há: i) aqueles que estão impossibilitados de colaborar com a verdade na condição de testemunha, de acordo com o art. 447 do CPC. Por outro lado, afirma o art. 448 que a testemunha não é obrigada a depor de fatos: i) que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge ou companheiro e aos seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta, ou na colateral até terceiro grau; ii) a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo.

Ainda de acordo com o CPC (art. 388), a parte não é obrigada a depor de fatos: i) criminosos ou torpes, que lhe forem imputados; ii) a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo; iii) a respeito dos quais não possa responder sem desonra própria, de seu cônjuge ou companheiro, ou ainda de parente em grau suscetível; iv) que coloquem em perigo a vida do depoente ou de seu cônjuge, companheiro ou parente em grau suscetível. Essas restrições, porém, conforme reza o parágrafo único do art. 388, não se aplicam às ações de estado ou de família.

Identicamente, afirma o art. 404 do Código de Processo Civil que a parte e o terceiro se escusam de exhibir, em juízo, o documento ou a coisa se : i) concernente a negócios da própria vida da família; ii) sua apresentação puder violar dever de honra; iii) sua publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, ou ainda lhes representar perigo de ação penal; iv) sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar respeito; v) subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição; vi) houver disposição legal que justifique a recusa na exibição. De acordo com o parágrafo único do mencionado art. 404, se os motivos de que tratam os números “i” a “vi” disserem respeito só a uma parte do conteúdo do documento, de outra se extrairá cópia reprográfica, com a lavratura de auto circunstanciado, para ser apresentada em juízo.

O dever de sigilo, considerado em diversas destas regras, repousa na necessidade de resguardo de determinadas profissões e estados. Certas profissões – como a de médico e advogado – e estados – como o de padre – dependem de uma relação de confiança e, por isso, requerem que as intimidades porventura reveladas sejam trancadas sob segredo.

Por outro lado, a prerrogativa da escusa do dever de depor, outorgada àquele que, depondo, praticará o crime de violação de sigilo – tal como definido pelo art. 154 do Código Penal, que estabelece que comete crime quem revelar, sem justa causa, “segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem” – está fundada em razões óbvias. O privilégio contra a autoincriminação é garantia constitucional da liberdade. A exigência de que o acusado confesse seu crime ou de que a pessoa indique fato que pode resultar-lhe sanção penal é ofensiva à tendência universal que aponta para a necessidade de preservação da liberdade.

Nesse caso, se o juiz insistir no depoimento – após ter ocorrido a escusa do dever de depor – inexistente crime. Isso porque, diante da imposição judicial – ainda que ilegal – resta afastado o dolo e, assim, não há como falar de crime de violação de sigilo. A violação do sigilo também estará autorizada – como hipótese de “justa causa” – quando a revelação do segredo tiver amparo no interesse público. O médico, assim, estará autorizado a revelar o segredo se exigir o interesse público, a exemplo da tentativa de impedir proliferação de doença contagiosa. Fala-se em “justa causa” no caso de interesse moral superior,²²² quando incidiria, em outras palavras, o princípio da proporcionalidade.

Na dimensão do tema que nos ocupa, costuma-se falar muito em sigilo bancário, que se constitui na obrigação, de que são portadores os bancos, de não revelar, salvo evidente justa causa, as informações que obtenham em razão de sua atividade profissional. Tal sigilo, como é óbvio, igualmente não é absoluto, cedendo diante do Fisco e das comissões parlamentares de inquérito, e sempre que um interesse superior o exigir.²²³

3. O dever de colaboração e o dever de lealdade processual

Não há relação direta entre o dever de colaboração com o Judiciário (ora estudado) e o dever de lealdade processual. É verdade que, em sentido lato, a ideia de lealdade pode abranger a noção de veracidade e, conseqüentemente, a colaboração ativa com o Poder Judiciário. Todavia, em sentido estrito, não há vinculação direta entre tais deveres.

A ZPO alemã, em seu § 138, ²²⁴ afirma que as partes devem esclarecer as circunstâncias do fato da causa de modo completo e conforme a verdade. Diz, ainda, que cada parte deve se manifestar sobre os fatos afirmados pelo adversário e que aqueles que não venham expressamente contestados devem ser considerados admitidos se a intenção de querer contestar não resultar de outras declarações da parte.²²⁵

No direito brasileiro, além de o art. 77, I e II, do CPC afirmar que o réu tem o dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade e não alegar defesa ciente de que é destituída de fundamento, o 341 do CPC diz que o réu deve impugnar precisamente os fatos narrados na petição inicial sob pena de presunção de veracidade. Portanto, à semelhança do que ocorre no sistema alemão, no nosso ordenamento está presente o dever de o réu colaborar com a verdade e se manifestar sobre os fatos narrados na petição inicial.

Perceba-se que o art. 341, ao dizer que certos fatos não impugnados devem ser presumidos verdadeiros, admite o silêncio para preservar o direito de liberdade do réu. Mas não esquece do seu dever de lealdade ou de dizer a verdade, acrescentando que o seu silêncio faz presumir os fatos não impugnados como verdadeiros. Ou seja, se o sistema não pode obrigar o réu a dizer que não tem razão, apressa-se em estabelecer o seu dever de impugnar os fatos de forma precisa sob pena de presunção de veracidade. Isso é muito importante, já que valoriza ao máximo a busca da verdade material e reduz a massa dos fatos controvertidos, pois todos sabem que os fatos constitutivos podem ser contestados com intuito meramente protelatório.

Enfim, note-se que há grande diferença entre silenciar e apresentar versão falsa no processo, ou, no caso específico, impugnar alegação de fato ciente da veracidade daquela alegação. Estas últimas condutas certamente violam o dever de veracidade e, assim, merecem ser punidas na forma do art. 81, do CPC. O silêncio, ao contrário, pode quando muito importar na presunção de

veracidade e, eventualmente, acarretar a vitória da parte contrária.

4. O dever de lealdade e a fixação dos fatos controvertidos

Deve ser ressaltada a ligação entre o art. 341 do CPC e a fixação dos pontos controvertidos no saneamento do processo. Como é sabido, a defesa de mérito indireta não atinge o fato constitutivo, limitando-se a afirmar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Tal defesa de mérito, por lógica, pode não ter compatibilidade alguma com a contestação do fato constitutivo. Veja-se, por exemplo, que se o autor afirma um crédito em razão de uma venda, e a contestação alega vícios da mercadoria, o réu apresenta defesa de mérito indireta, mas admite a compra e venda e o não pagamento, isto é, os fatos constitutivos. O réu pecaria em lógica e faltaria ao seu dever de lealdade se afirmasse que não recebeu a mercadoria e, ao mesmo tempo, que ela contém vícios.

Não se diga que isso seria possível em razão do princípio da eventualidade, que permite ao réu expor uma defesa para a eventualidade da outra não ser acolhida. Isso não é admissível quando implicar em afirmações fáticas logicamente inconciliáveis.

Scarselli,²²⁶ ao tratar dessa situação perante o direito italiano, diz que o juiz deveria considerar, nesses casos, os arts. 88 e 116, segunda parte, do CPC daquele país. O art. 88 afirma que “as partes e os seus defensores têm o dever de se comportar em juízo com lealdade e probidade”, enquanto que o art. 116, segunda parte, diz que o juiz pode retirar argumentos de prova das respostas que as partes lhe dão por ocasião do chamado interrogatorio non formale, da renúncia injustificada das partes a admitir inspeções e, em geral, do seu próprio comportamento no processo.

Além do estabelecido no art. 77, I e II, diz ainda o CPC brasileiro, no seu art. 80, II, que aquele que “alterar a verdade dos fatos” deve ser considerado litigante de má-fé. Ora, uma contestação que aceita e nega o mesmo fato certamente viola o dever de veracidade. O réu que assim procede, por alterar a verdade dos fatos, deve ser considerado litigante de má-fé. Nesse caso, o juiz, com base no princípio da lealdade processual, deve determinar que o réu esclareça a sua defesa na audiência preliminar. Se o réu não se manifestar ou não esclarecer a sua contestação de forma adequada, o juiz pode deduzir, a partir desse comportamento e da incompatibilidade lógica da defesa, que a contestação do fato constitutivo violou o dever de lealdade e, assim, reputar o fato constitutivo como não-contestado, deixando de fixá-lo como controvertido.

Ademais, se a defesa de mérito indireta exigir prova testemunhal ou pericial e se mostrar infundada, deverá ser concedida tutela da evidência com base no art. 311, I, do CPC, isto é, com base em “abuso de direito de defesa”. Quando os fatos constitutivos não são controvertidos, não há racionalidade em obrigar o autor a esperar o tempo necessário para o réu se desincumbir do ônus da prova de fato que, segundo o art. 373, II do CPC, cabe-lhe provar e se apresenta infundado.

Art. 379. Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte:

I – comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for interrogado;

II – colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária;

III – praticar o ato que lhe for determinado.

1. O sentido do “preservado o direito de não produzir prova contra si própria”

O direito angloestadunidense trata pelo nome de privilégios (evidentiary privileges) certas concessões feitas a determinadas pessoas ou situações, em que se dispensa o dever de colaboração com o Estado, na busca de provas.

Como observa o art. 378, do CPC, em princípio existe um dever geral de colaboração na reconstrução dos fatos da causa. Todavia, porque a Constituição também se compromete com outros valores, sendo necessário, às vezes, limitar esse dever geral, a fim de não ofender outra garantia também tida como fundamental ao Estado brasileiro.

São essas situações, que tanto podem favorecer as partes como os terceiros, tratadas com o nome de privilégios, como visto nos comentários ao artigo antecedente.

O Código Civil brasileiro havia ampliado sobremodo este privilégio, chegando a dispor que ninguém é obrigado a depor sobre fatos que possam expô-lo (ou a seu cônjuge, ou a parente em grau sucessível, ou ainda a amigo íntimo) a “perigo de vida, de demanda, ou de dano patrimonial imediato” (art. 229, III). O dispositivo encontra-se revogado, mas claramente inspirava-se em uma interpretação equivocada da dimensão da garantia contra a autoincriminação.

Esse mesmo equívoco, ao que parece em uma primeira leitura, inspirou o art. 379, do CPC. Ao que parece, o início do art. 379 estabelece uma cláusula geral que cria um “imaginado” direito civil para a parte de não produzir prova contra si. Esse direito, em que pese a aparente previsão legal, na realidade não existe e jamais poderia existir em um sistema como o nacional. Como já se disse, o dever de produzir prova é uma imposição que decorre do próprio texto constitucional, de modo que somente em razão de outro valor também constitucional poderia ser restringido. Por isso, é plenamente justificável que se restrinja o dever de colaboração para a proteção da garantia contra a autoincriminação, já que essa também tem assento constitucional (decorrendo, na ótica da doutrina e da jurisprudência, do contido no art. 5.º, LVII, da CF). Todavia, a amplitude da redação – absolutamente injustificada e absurda, diga-se – da parte inicial do art. 379 praticamente cria um direito “fundamental” à não colaboração e, assim, um direito também “fundamental” a esconder a verdade no processo civil. Em última análise, a interpretação literal desse preceito (em sua parte inicial) institui e legitima a chicana processual e autoriza a litigância abertamente de má-fé, o que não se pode aceitar.

Supor que a parte tenha o direito de esconder a prova que lhe é desfavorável, e que só tenha o “dever” – que aí é nada mais do que o seu próprio interesse – de trazer aos autos a prova que lhe é favorável, realmente, é imaginar que a parte deve sempre tentar litigar, ainda que de forma abusiva, na esperança de que a parte contrária não consiga obter por outra via a prova que foi, com a autorização do código, escondida. Nada há que justifique esse imaginado “direito”, que sequer se harmoniza com a seriedade que se espera de quem litiga judicialmente.

Não bastasse a falta de respaldo constitucional e ético para esse preceito, vê-se ainda que ele sequer encontra eco na própria estrutura do CPC. De fato, o código possui várias regras que impõem um dever de produção de provas para a parte, permitindo, inclusive, no caso de desobediência (que, logicamente, só ocorrerá quando a prova for desfavorável a essa parte), o emprego de medidas coercitivas ou sub-rogatórias para a obtenção da informação (v.g., art. 400, parágrafo único). O exemplo da exibição de documento ou coisa contra a parte é eloquente. Prevê o código que, em havendo recusa na exibição, pode o juiz valer-se de quaisquer “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido” (art. 400, parágrafo único). Ora, como imaginar que podem conviver um direito à não produção de prova contra si e o poder judicial de impor a exibição do documento recusado pela parte? Seria esforço vão tentar defender a existência desse direito amplo à não colaboração!

Ademais, a suposta existência de um direito (civil) de não produzir prova contra si é claramente incompatível com a previsão, no ordenamento jurídico, da técnica da confissão (em especial, a ficta). Afinal, se é “direito” da parte “não produzir prova contra si”, então como se justifica que aquele que exerce esse direito (se recusando a depor), nos termos do art. 386, sofra os efeitos da confissão ficta?

Enfim, é evidente que a parte inicial do art. 379 é apenas um excesso infeliz, que exige interpretação que o reduza aos seus limites constitucionais: o direito de não produzir prova que possa repercutir em sua incriminação ou que possa repercutir em outra garantia constitucional, a exemplo do sigilo. Assim, em que pese a literalidade do dispositivo, o preceito – até para se harmonizar com o resto do Código de Processo Civil e para compatibilizar-se com o texto constitucional – impõe que se compreenda que a garantia oferecida pela parte inicial do art. 379 é, e só pode ser, aquela que sempre foi aceita no plano constitucional brasileiro, ou seja, a garantia contra a autoincriminação ou contra a violação de outros valores fundamentais constitucionais.

Em síntese, deve-se entender a ressalva inicial, posta no art. 379, do CPC, como se ali estivesse escrito que ressalvados os casos – já indicados ao longo do código – em que a parte não é obrigada a contribuir para a descoberta da verdade (preservação contra a autoincriminação, preservação dos sigilos, preservação do dever de honra), há sempre o dever de colaboração.

2. Deveres de colaboração impostos à parte

Após determinar que qualquer pessoa colabore, na medida do que puder, para a descoberta da verdade, o CPC estabelece deveres instrutórios específicos à parte. Recorde-se, de todo modo, que esses poderes não excluem outros, inclusive em matéria probatória, nos termos do que prevê o art. 77, do CPC.

Especificamente em relação aos deveres do art. 379, é importante lembrar que, em relação ao depoimento a que está obrigada a parte, a imposição não se refere apenas ao oferecimento de respostas às perguntas que lhe forem dirigidas. Mais do que isso, a parte está obrigada a comparecer em juízo quando assim lhe for determinado. Note-se que esse dever é exigível ainda quando a parte não tenha o ulterior dever de depor a respeito de certos fatos (art. 388). Isso porque poderá haver a inquirição a respeito de outros fatos, cabendo à parte, ainda, em regra, justificar a razão pela qual não deve depor a respeito de certos fatos.

Outrossim, competirá à parte responder às perguntas formuladas pelo juiz, pessoal e diretamente. Observe-se que o direito de se calar – que a parte pode ter diante de alguma regra de exclusão (v.g., art. 388) – está muito longe de um direito de mentir em juízo. De fato, o CPC protege com o silêncio alguns interesses reputados relevantes pela ordem jurídica (como a intimidade, a proteção contra a autoincriminação), mas essa proteção não dá à parte a possibilidade de alterar ou ocultar a verdade. A dispensa do dever de colaborar obviamente não gera um direito de conturbar a tarefa judicial da investigação dos fatos.

Nesse passo, calha lembrar que é dever das partes “expor os fatos em juízo conforme a verdade” (art. 77, I), e que é ato de litigância de má-fé “alterar a verdade dos fatos” (art. 80, II). Esse dever de veracidade, geral para todo tipo de procedimento, impõe às partes que, quando estiverem sujeitos ao dever de colaboração com o Poder Judiciário, desenvolvam esse dever segundo a verdade e a sinceridade. Não há, portanto, um direito de mentir em juízo, ao menos no Processo Civil Brasileiro.

3. Sanções à violação do dever de colaboração e do dever de veracidade

De outro lado, as sanções impostas à violação de tais deveres podem assumir diferentes formas. Quando se examinar os preceitos específicos, em matéria probatória, a respeito dos compromissos da parte, será possível notar que a sanção geralmente atribuída à violação dos deveres acima enumerados é a presunção da veracidade do fato. Nesse caso, a conduta da parte que se recusa a colaborar com o Poder Judiciário é tomada como indicativo de seu interesse em omitir algo ou em falsear a verdade, de forma que seu silêncio passa a ser interpretado contra ela. Essa interpretação, aliás, como pondera Ivan Righi, independe de previsão legal específica, já que “o comportamento das partes, revelado através dos atos que praticam e das atividades que omitem no curso do processo, é fato jurídico que pode apresentar relevância probatória”.²²⁷ De toda sorte, o direito positivo possui inúmeras hipóteses em que se fixa presunção contrária à parte diante de sua omissão em colaborar, a exemplo do que preveem os arts. 385, § 1.º, 386 e 400 do CPC e os arts. 231 e 232 do CC.

As presunções derivadas de tais situações são iuris tantum, o que significa dizer que o magistrado não fica a elas vinculado. Todavia, a incidência de tais presunções importa, ultima ratio, significativo prejuízo instrutório, na medida em que dificilmente a parte conseguirá desfazer os seus efeitos.

Conquanto a sanção da presunção seja o caminho normal em tais casos, vê-se de pronto que ela não é a única cabível. Como está claro nos arts. 77 e 80 do CPC, o litigante de má-fé pode ser

condenado a pagar multa de um a dez por cento sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos sofridos, dos honorários advocatícios e de todas as despesas efetuadas.

É importante advertir que essa sanção pode ser imposta cumulativa ou alternativamente à presunção antes indicada. Em regra, ao lado da incidência da presunção de veracidade, cumprirá ao juiz aplicar a multa como modo de combater a litigância de má-fé. Todavia, haverá situações em que a presunção não terá cabimento. Imagine-se, por exemplo, a necessidade de exibição de um documento importante para o cálculo do valor de alguma coisa: sem a sua exibição, não haverá forma de atingir-se o valor buscado, de nada servindo a presunção imposta pelo art. 400 do CPC. Nesses casos, a sanção típica – a presunção – não terá utilidade, transformando-se a multa na alternativa cabível. Em tais situações, tal multa assume óbvia natureza coercitiva, compelindo o sujeito a colaborar com o Judiciário, já que a presunção, em si, não atenderá a essa finalidade.

Ao lado dessas sanções, o Código também autoriza o emprego, em alguns desses casos, de medidas de indução ou de sub-rogação (v.g., art. 400, parágrafo único, do CPC).²²⁸ Nessa linha, nada impede a aplicação de medidas como a busca e apreensão de coisas e documentos, especialmente para situações como a do exemplo antes descrito, em que a presunção do art. 400 não tem eficácia. Note-se, aliás, que a fim de viabilizar a colaboração da parte com o processo, será viável a utilização de qualquer técnica de sub-rogação – como a busca e apreensão – ou de coerção – a exemplo da multa pecuniária diária, nos moldes previstos pelo art. 537 – tendentes a obter o resultado desejado (a prova) com a colaboração da parte ou independentemente dela.

A quem pense serem exagerados e infundados esses poderes instrutórios, cabe invocar o exemplo do direito comparado. Merece referência, em especial, o disposto no art. 519 do CPC português. Esse artigo dispõe que “todas as pessoas, sejam ou não partes na causa, têm o dever de prestar a sua colaboração para a descoberta da verdade, respondendo ao que lhes for perguntado, submetendo-se às inspeções necessárias, facultando o que for requisitado e praticando os actos que forem determinados”. E, em seguida – estabelecendo as sanções cabíveis para o descumprimento do preceito – afirma que “aqueles que recusem a colaboração devida serão condenados em multa, sem prejuízo dos meios coercitivos que forem possíveis; se o recusante for parte, o tribunal apreciará livremente o valor da recusa para efeitos probatórios, sem prejuízo da inversão do ônus da prova decorrente do preceituado no n.º 2 do art. 344 do Código Civil”.

Art. 380. Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa:

I – informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento;

II – exhibir coisa ou documento que esteja em seu poder.

Parágrafo único. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias.

1. Os terceiros e o dever de colaboração

Completando o sistema geral de colaboração instrutória, o CPC evidencia que o terceiro está sujeito ao dever de colaboração não apenas segundo a fórmula aberta do art. 378, mais especificamente em relação às condutas descritas no art. 380.

Assim, além do dever de colaborar com o Poder Judiciário nos termos do art. 378, o terceiro deve informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento e exhibir em juízo coisa ou documento que possua.

Deixe-se claro que, quando o CPC estabeleceu tais imposições, não excluiu a colaboração por outras vias. O terceiro está sujeito ao dever de colaboração sempre e por qualquer modo que interesse ao processo – ressalvadas, apenas, as hipóteses de exclusão legal (v.g., os arts. 388, 404 e 448, CPC). As situações descritas na regra ora em exame são apenas exemplos de condutas que estão impostas aos terceiros, já por conta da cláusula genérica do art. 378. Assim, ainda que não exista expressa previsão a respeito, o terceiro também está obrigado a fornecer material para a

realização de prova técnica (v.g., fornecer escrita para a realização de exame grafotécnico), franquear o ingresso de peritos para a realização de prova em bem de sua propriedade, ou mesmo sujeitar-se à prova pericial.

Logicamente, esses deveres do terceiro também serão excluídos em situações especiais – previstas ou não na legislação – em que há a necessidade de preservação de outro interesse maior, de importância axiológica mais evidente – como a intimidade, a honra, o sigilo, a vida, a incolumidade pessoal etc. Haverá circunstâncias, previstas no ordenamento positivo ou extraídas do arcabouço principiológico constitucional, que excluirão o dever de colaboração, a exemplo do que se tem nos arts. 404 e 448 do CPC. Porém, ressalvadas essas situações específicas, o dever de colaboração é geral, impondo-se a qualquer terceiro, tenha ou não interesse jurídico na causa.

2. Exigibilidade do dever de colaboração frente aos terceiros

Em relação aos terceiros, ao contrário do que ocorre com as partes, o CPC, clara e indiscutivelmente estabelece um arsenal geral para a efetivação do dever de colaboração. A par de instrumentos específicos, previstos em momentos particulares da produção probatória, o código prevê, no seu art. 380, parágrafo único, que “poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias”.

Ou seja, prevê-se uma cláusula geral que autoriza ao magistrado o emprego de medidas de indução ou de sub-rogação²²⁹ para o atendimento pelo terceiro da ordem de colaboração.

Ao lado dessa regra geral, o código emprega vários instrumentos – indicados em casos específicos, seja de caráter indutivo, seja de conteúdo sub-rogatório – para a obtenção da colaboração do terceiro.

Tome-se, como exemplos de medida sub-rogatória, a busca e apreensão contemplada pelo art. 403, parágrafo único e a chamada condução – que substitui o comparecimento voluntário do sujeito – prevista para a testemunha, ex vi do disposto no art. 455, § 5.º. Indutiva, por outra parte, é a sanção criminal incidente na hipótese de desobediência ao comando legal (art. 330, CP) e no caso de recusa de depor como testemunha (crime de falso testemunho, conforme prevê o art. 342, CP), ou ainda ao emprego de multa ou outro meio de indução, na forma prevista pelo art. 403, parágrafo único.

Ao lado dessas medidas, poder-se-ia ainda pensar no emprego da sanção prevista no art. 77, IV, c/c o seu § 2.º, do CPC. Segundo esse artigo, cabe a qualquer pessoa que, de qualquer forma, participe do processo, o dever de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”. Nos termos do § 2.º, dessa regra, a violação a esse preceito sujeita o infrator à multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Ainda que essa medida tenha, em princípio, caráter punitivo, a sua existência certamente estimula os terceiros a colaborar com o Poder Judiciário, constituindo mais uma forma de sanção para efetivar a decisão judicial. A medida, ademais, por seu caráter punitivo, pode certamente ser cumulada com outra técnica sub-rogatória ou indutiva, tendente a forçar o terceiro a colaborar com o Judiciário, ou eventualmente a substituir a necessidade de sua participação.

Note-se que, a rigor, é possível dizer que o amplo sistema de medidas de indução e de sub-rogação disponível em relação a terceiros pode também ser empregado em relação à parte, como já visto nos comentários ao artigo anterior. A única diferença relevante está em que, em relação à parte, em princípio, o emprego dessas medidas depende da inutilidade do recurso à presunção de veracidade a ser empregada em relação à parte que não colabora.

Vale dizer: em regra, para a parte, é suficiente o emprego da presunção de veracidade diante da sua não colaboração. Porém, se a incidência dessa presunção for insuficiente ou inútil, então o juiz pode lançar mão dos mesmos instrumentos de sub-rogação ou de indução para obter a colaboração da parte ou para substituir o efeito dessa renitência.

3. Colaboração de terceiro e contraditório

Desse modo, é possível concluir que nenhuma estranheza deve causar o fato de terceiros serem atingidos pelos efeitos de decisões judiciais. O que não se admite é que os terceiros possam ser prejudicados pela decisão judicial sem que se lhes dê oportunidade para tentar evitar o prejuízo. Por outras palavras, a fim de que legitimamente tais efeitos possam se fazer sentir sobre esses terceiros, é necessário que se garanta a eles o contraditório, ainda que posterior à decisão, mas sempre – salvo motivo evidente e relevante, que aconselhe outra solução – anterior à possível incidência da sanção decorrente de sua eventual desatenção.

De fato, o contraditório é essencial para autorizar a recepção por terceiros de efeitos do provimento judicial. Ninguém, afinal, pode admitir que alguém seja obrigado a sujeitar-se a efeitos de ato estatal sem que possa opor-se a tanto. Por outro lado, o prejuízo para esse terceiro não decorre, diretamente, da incidência do efeito da decisão judicial sobre sua esfera jurídica, senão da ulterior aplicação da sanção (consequência) decorrente da não observação desse efeito. Deveras, o fundamental não é que o terceiro seja ouvido antes de expedida a ordem para que entregue determinada coisa, mas sim – para a concreção do contraditório, que objetiva evitar que essa pessoa sofra prejuízo sem ser ouvido – que possa defender-se antes da apreensão do bem ou da aplicação de punição pela não observância da ordem judicial. Excepcionalmente, quando razões de maior interesse o determinar, poderá até mesmo ocorrer a postecipação do contraditório para momento ulterior à efetivação da decisão judicial.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Sobre o comportamento dos sujeitos processuais como meio de prova, v. *supra*, item 10.

2

Sobre a prova estatística, v. o vol. VII, destes *Comentários*, na parte introdutória à “prova pericial”.

3

Luigi Paolo Comoglio; Corrado Ferri; Michele Taruffo. Op. cit., p. 518.

4

Além disso, o juiz não pode se valer da prova ilícita para se convencer do contrário do que se pretendeu por meio dela demonstrar.

5

Luis Gálvez Muñoz. La ineficacia de la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales. Navarra: Aranzadi, 2003. p. 194.

6

Cf. Isabel Alexandre. Provas ilícitas em processo civil. Coimbra: Almedina, 1998. p. 25-27.

7

Luis Gálvez Muñoz. Op. cit., p. 93 e ss.

8

Luis Gálvez Muñoz. Op. cit., p. 148 e ss.

9

Lembre-se, porém, que a gravação da conversa telefônica por um dos interlocutores não constitui ilícito. Nesse sentido, aliás, já julgou o Tribunal de Justiça de São Paulo: “O que a Constituição veda é a interferência de terceiro no interior do diálogo, sem aceitação do comunicador ou do receptor. Aquilo que se domina de interceptação, dando azo a gravação clandestina. Mas a conversa regular entre duas pessoas que se aceitam como comunicador e receptor, em livre expressão do pensamento, admite gravação por uma das partes, assim como seria possível gravar o teor de conversações diretas, sem uso de aparelho telefônico” (RT. 698/160). No mesmo sentido decidiu o Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: “É possível como prova a gravação em fita magnética feita unilateralmente por um dos interlocutores ainda que com o desconhecimento do outro, pois somente ocorre o sigilo das comunicações quando a interceptação é feita por terceiro, sem a autorização de qualquer dos interlocutores, conforme disposto na Lei 9.296/96” (RT 750/654). Ver, ainda, RT 699/71; RT 731/334; Revista de Jurisprudência do TJRS 190/282. Pelo mesmo motivo, não há ilicitude em levar a juízo gravação de recado deixado em secretária eletrônica, desde que, como é óbvio, aquele que requer a produção dessa prova tenha acesso direto ao aparelho.

10

Tanto é verdade que a Constituição da República Portuguesa trata das provas ilícitas no n. 8 do art. 32, que se refere expressamente às garantias do processo criminal.

11

Art. 5.º, LXIII, da CF.

12

Jorge Reis Novais. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela Constituição. Coimbra: Coimbra, 2003. p. 569.

13

“Ter um direito fundamental não significa ter uma posição juridicamente sustentada de natureza absoluta, definitiva ou fechada, ainda que, no decurso da sua efetivação, os direitos fundamentais se concretizem em posições jurídicas que podem reunir essas características. Ter um direito fundamental de liberdade significa, na sua dimensão subjetiva, ter uma posição forte de garantia de liberdade e autonomia pessoal, que vincula diretamente as entidades públicas e de que estas, mesmo quando atuam nas vestes do legislador democraticamente legitimado, não dispõem livremente e onde só podem intervir

desde que preenchidos requisitos constitucionais estritos. Porém, dada a ineliminável necessidade de essas posições – ou, na sua dimensão objetiva, os valores jusfundamentais – serem compatibilizados com outros bens, interesses ou valores igualmente dignos de proteção jurídica, as garantias jurídicas proporcionadas pelos direitos fundamentais são, à partida, concebidas como garantias imanentemente condicionadas por uma reserva geral de compatibilização com outros bens que o Estado deve prosseguir e a cuja realização se encontra igualmente vinculado” (Jorge Reis Novais. Op. cit., p. 570).

14

É exatamente esta a advertência de Luis Gálvez Muñoz: “Lo más importante, con todo, es tener en cuenta que la mayoría de los países que acogen la prohibición de admitir en el proceso las pruebas conseguidas de modo inconstitucional se han visto necesariamente obligados a admitir excepciones. De una u otra forma, y con un alcance mayor o menor, han tenido que admitir la aplicación condicionada de la regla de exclusión, a fin de preservar determinados valores dignos de protección. En unas ocasiones la regla ya nació revestida de matices y excepciones, como un compromiso entre la defensa de los derechos fundamentales y la obtención de la verdad procesal, pero en otras ha sido el paso del tiempo y el contraste con la realidad lo que ha acabado flexibilizándola” (Luis Gálvez Muñoz Op. cit., p. 131).

15

Nicolò Trocker. Processo civile e costituzione. Milano: Giuffrè, 1974. p. 618 e ss.

16

A respeito da regra da proporcionalidade e de suas sub-regras, ver, no direito brasileiro, Paulo Bonavides. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 314 e ss; Luis Roberto Barroso. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996; Raquel Denize Stumm. Princípio da proporcionalidade no direito constitucional brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1995; Suzana de Toledo Barros. O princípio da proporcionalidade e o controle da constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília Jurídica, 1996; Paulo Arminio Tavares Buechele. O princípio da proporcionalidade e a interpretação da Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.

17

Luis Roberto Barroso. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. Rio de Janeiro: Renovar, 1993. p. 346. No mesmo sentido Ada Pellegrini Grinover. Liberdades públicas e processo penal. São Paulo: Saraiva, 1976.

18

Dworkin, na obra *Taking Rights Seriously*, afirma que as regras obedecem à lógica do “tudo ou nada”, enquanto que os princípios a do “peso” ou da “importância” (Ronald Dworkin. *Taking Rights Seriously*. Cambridge: Harvard University Press, 1978. p. 70 e ss.).

19

Alexy, ao desenvolver sua teoria dos direitos fundamentais, adverte que a distinção qualitativa entre

regras e princípios tem importante papel nesse setor. Afirma que os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes, ao passo que regras são normas que podem ser cumpridas ou não, uma vez que, se uma regra é válida, há de ser feito exatamente o que ela exige, nem mais nem menos. Por isso, os princípios, ao contrário das regras, são chamados de mandatos de otimização, que podem ser realizados em diferentes graus, consoante as possibilidades jurídicas e fáticas. As regras contêm determinações em um âmbito fática e juridicamente possível. Enquanto isso, a realização dos princípios depende das possibilidades jurídicas e fáticas, as quais são condicionadas pelos princípios opostos, e assim exigem a consideração dos pesos dos princípios em colisão segundo as circunstâncias do caso concreto. No caso de conflito de regras, o problema é de validade, enquanto que, na hipótese de colisão de princípios, a questão é de peso. Quando há colisão de princípios, um deve ceder diante do outro, conforme as circunstâncias do caso concreto. Isso significa que, aí, não há como se declarar a invalidade do princípio de menor peso, uma vez que ele prossegue íntegro e válido no ordenamento, podendo merecer prevalência, em face do mesmo princípio que o precedeu, diante de outro caso concreto (Robert Alexy. *Teoría de los derechos fundamentales*. Trad. Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002. p. 88-92).

20

Como é sabido, a Constituição Federal afirma que “a lei não prejudicará” a coisa julgada (art. 5.º, XXXVI). Diante disso, alguém poderia indagar se o juiz pode aplicar a regra da proporcionalidade para balancear a coisa julgada material com um direito material que se pretende fazer valer em juízo por meio da ação. Note-se, porém, que a norma constitucional, nesse caso, ponderou entre a segurança jurídica e o risco de eventuais injustiças, nada deixando para ser ponderado pelo juiz.

O art. 966 do CPC estabelece situações em que a coisa julgada pode ser objeto de desconstituição. Na realidade, se a coisa julgada material é garantida constitucionalmente, alguém poderia dizer que o art. 966 do CPC a restringe e, assim, é inconstitucional. Entretanto, não se nega a possibilidade de a lei estabelecer hipóteses em que a coisa julgada material pode ser desconstituída. A lei pode assim proceder, mas jamais poderá afirmar que a coisa julgada – seja ela relativa a qualquer situação concreta – não precisa ser observada. Ou seja, a lei não pode prejudicar a coisa julgada, raciocinando como se ela não houvesse sido preferida e garantida pela Constituição.

Se a lei não pode prejudicar a coisa julgada, o juiz também não pode desconsiderá-la, ainda que sob o pretexto de estar estabelecendo a sua ponderação com um outro direito fundamental. É que, como já dito, a Constituição, ao garantir a coisa julgada material, já realizou a ponderação entre a segurança jurídica – advinda da coisa julgada – e o risco de eventuais injustiças.

Perceba-se que a situação, aqui, é distinta da relativa à prova ilícita. A norma que proíbe a prova ilícita faz apenas a ponderação entre a efetividade do direito material por ela violado e a descoberta da verdade. A admissibilidade do emprego da regra da proporcionalidade, na hipótese de prova ilícita, decorre da premissa de que a norma não ponderou entre a efetividade do direito material violado pela prova e o risco de negação de todas as espécies de direitos materiais.

Lembre-se que a proibição de descobrir a verdade por meio de prova ilícita tem o objetivo especial de colocar freio na ansiedade da atividade punitiva estatal. É possível dizer, portanto, que a norma aceitou o risco de a justiça deixar de condenar um criminoso, mas não negou a possibilidade de tutela de um direito fundamental dependente de prova ilícita. Ou seja, tal norma não ponderou tudo o que havia a ser ponderado, e por isso deixou ao juiz a possibilidade de ponderar entre o direito fundamental

violado pela prova e o direito fundamental que se pretende através dela tutelar.

Ao contrário, a norma constitucional que proíbe a desconsideração da coisa julgada nada deixa a ser ponderado pelo juiz, pois ponderou entre a segurança jurídica, ou entre a estabilidade das relações jurídicas, e o risco de eventuais injustiças, aceitando a possibilidade de o processo civil conviver com uma decisão injusta. Se essa última opção é boa ou má não importa na presente dimensão. Ou melhor, se essa opção pode ser discutida, não há como esquecer que ela foi feita pela Constituição e nessa perspectiva deve ser respeitada.

21

STJ, RMS 5352-GO, 6.^a Turma, rel. Min. Luiz Vicente Cernichiaro, j. 27.05.1996, DJU 25.11.1996 (também na RSTJ, vol. 90, p. 359 e ss).

22

U.S. Supreme Court; 251 U.S. 385 (1920); *Silverthorne Lumber Co., Inc., et al. v. United States*; n. 358.

23

Luis Gálvez Muñoz. Op. cit., p. 155 e ss.

24

Tribunal Supremo Espanhol, Sala Segunda, “Sentencia” de 16 de março de 1995; citado por Luis Gálvez Muñoz. Op. cit., p. 171.

25

Idem, p. 178.

26

Idem, p. 183-184.

27

Idem, p. 185.

28

Idem, *ibidem*.

29

Idem, p. 194.

U.S. Supreme Court; 467 U.S. 431 (1984); NIX, WARDEN OF THE IOWA STATE PENITENTIARY v. WILLIAMS; CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE EIGHTH CIRCUIT; n. 82-1651. Ver, também, U.S. Supreme Court; 470 U.S. 298 (1985); OREGON v. ELSTAD CERTIORARI TO THE COURT OF APPEALS OF OREGON; n. 83-773.

U.S. Supreme Court; 445 U.S. 463 (1980); UNITED STATES v. CREWS. CERTIORARI TO THE DISTRICT OF COLUMBIA COURT OF APPEALS; n. 78-777.

Tratando da prova derivada da ilícita no âmbito do processo penal, assim decidiu o STF: “Prova ilícita. Escuta telefônica mediante autorização judicial: afirmação pela maioria da exigência de lei, até agora não editada, para que, ‘nas hipóteses e na forma’ por ela estabelecidas, possa o juiz, nos termos do art. 5.º, XII, da Constituição, autorizar a interceptação de comunicação telefônica para fins de investigação criminal; não obstante, indeferimento do habeas corpus pela soma dos votos, no total de seis, que, ou recusaram a tese da comunicação das provas decorrentes da escuta telefônica, indevidamente autorizada, ou entenderam ser impossível, na via processual do habeas corpus, verificar a existência de provas livres da contaminação e suficientes a sustentar a condenação questionada; nulidade da primeira decisão, dada a participação decisiva, no julgamento, de Ministro impedido (MS 21.750, 24.11.1993, Velloso); conseqüente renovação do julgamento, no qual se deferiu ordem pela prevalência dos cinco votos vencidos no anterior, no sentido de que a ilicitude da interceptação telefônica – à falta de lei que, nos termos constitucionais, venha a discipliná-la e viabilizá-la, – contaminou, no caso, as demais provas, todas oriundas, direta ou indiretamente, das informações obtidas na escuta (fruits of poisonous tree), nas quais se fundou a condenação do paciente” (STF, HC 69912-0/RS, Pleno, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 16.12.1993, DJU 25.03.1994, p. 6012).

Sobre o assunto, José Roberto dos Santos Bedaque, Poderes instrutórios do juiz, passim; Sérgio Mattos, Da iniciativa probatória do juiz no processo civil, passim; Michele Taruffo, “Poderes probatórios das partes e do juiz na Europa”, Processo civil comparado – Ensaio, p. 57 e ss.; Trícia Navarro Xavier Cabral, Poderes instrutórios do juiz no processo de conhecimento, passim.

STJ: “Processual civil. Benefício acidentário. Perícia médica. Determinação ex officio pelo juiz. Possibilidade. Em se tratando de ação para a concessão de benefício acidentário, é possível ao juiz determinar ex officio a realização de perícia médica, tendo em vista a sua importância para a solução da lide, ainda que o segurado, motivado pelo deferimento do benefício no âmbito administrativo, tenha requerido o julgamento conforme o estado do processo, por entender desnecessária a prova técnica. Recurso não conhecido” (STJ, REsp 285872, 5.ª Turma, rel. Min. Félix Fischer, DJ 09.04.2001).

Ver Maristela da Silva Alves, O ônus da prova como regra de julgamento. Prova cível, p. 88.

Ver José Roberto dos Santos Bedaque, Poderes instrutórios do juiz, p. 78 e ss.

Não é por razão diversa que as partes têm um inegável direito de participar da produção da prova.

Art. 24 da Constituição da Espanha: “1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa e a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. 3. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar hechos presuntamente delictivos”.

“La simple denegación de la práctica de un medio de prueba por el juez o tribunal que conocen del asunto no supone necesariamente indefensión y vulneración del derecho del litigante a la prueba. El juez puede y debe valorar si los medios de prueba son idóneos al fin al que se destinan, y deberá hacerlo en un doble aspecto. Atendiendo al medio de prueba propuesto, en cuanto se revele eficaz para conseguir la prueba de los hechos alegados por la parte; y atendiendo también a los hechos mismos sobre los que se pretende practicar la prueba, y su importancia o trascendencia en el litigio. Si el juez o tribunal llegan a la conclusión de que el medio propuesto no será útil, o que los hechos que se pretende probar no son trascendentes en el litigio, podrán denegar la admisión de los medios de prueba propuestos sin que de ello derive vulneración alguna para los derechos del litigante afectado (Jorge Carreras del Rincón. Comentarios a la doctrina procesal civil del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Madrid: Marcial Pons, 2002. p. 298).

Tribunal Constitucional, sentencia 198/1997, de 24.11.1997; referido por Jorge Carreras del Rincón, idem, p. 310-311.

Michele Taruffo. A prova. Trad. João Gabriel Couto. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 130-131; Id. La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti. Bari: Laterza, 2009, p. 239-240.

42

Apud Gerhard Walter. Op. cit., p. 229 e ss.

43

Fleming James Jr.; Geoffrey C. Hazard Jr.; John Leubsdorf. Civil Procedure cit., p. 346 e ss.

44

Gerhard Walter. Op. cit., p. 239.

45

Gerhard Walter. Op. cit., p. 243.

46

Gerhard Walter. Op. cit., p. 244-245.

47

Gerhard Walter. Op. cit., p. 256 e ss.

48

Gerhard Walter. Op cit., p. 258.

49

Sobre a relação entre a responsabilidade pelo dano ambiental e a sociedade de risco, ver Luciane Tessler. Tutelas jurisdicionais do meio ambiente: inibitória, de remoção do ilícito e do ressarcimento na forma específica. Dissertação de mestrado, Curitiba, UFPR, 2003; José Rubens Morato Leite; Patryck Ayala. Direito ambiental na sociedade de risco. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002; Michel Prieur, Droit de l'environnement. Paris: Dalloz, 1991; Jean Pierre Centi. Le prix de l'environnement, Une approche par l'analyse économique du droit, in M. Falque; M. Massenet (coords.). Droits de propriété et environnement. Paris: Dalloz, 1997; José Eduardo de Figueiredo Dias. Tutela ambiental e contencioso administrativo (da legitimidade processual e das suas consequências), Coimbra: Coimbra, 1997.

50

Gerhard Walter. Op. cit., p. 269-270.

51

Gerhard Walter. Op. cit., p. 276.

52

Gerhard Walter. Op. cit., p. 276-277.

53

Gerhard Walter. Op. cit., p. 277-278.

54

Gerhard Walter. Op. cit., p. 278.

55

Ver Luiz Guilherme Marinoni. Tutela inibitória. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2003.

56

Ver Luiz Guilherme Marinoni. Tutela inibitória, 3. ed., cit., p. 173 e ss., quando se faz referência a julgado do Tribunal de Alçada do Paraná, relatado pela então Juíza do Tribunal de Alçada, Dra. Regina Afonso Portes.

57

Gerhard Walter. Op. cit., p. 283.

58

Luiz Guilherme Marinoni. Simulação e prova. Revista de Direito Processual, v. 22, Curitiba, Genesis, p. 843 e ss.

59

Juan Igartua Salaverría. Op. cit., p. 153.

60

Além disso, lembra Salaverría que “también hay algo que añadir desde la perspectiva extraprocesal. El inventario de las vicisitudes probatorias del juicio se hace imprescindible ‘para ilustrar al lector sobre la confrontación de las posiciones parciales en la materia (...) Es sabido que en la práctica no se hace así, con lo que la justificación de la valoración de la prueba suele aparecer suspendida en un vacío de antecedentes, imposible de cubrir por quien no disponga de información precisa de lo acontecido en el juicio, y aún así’” (Juan Igartua Salaverría. Idem, p. 152).

61

“No hay valoración conjunta racional si previamente no se ha tomado en cuenta el valor de los distintos

elementos que forman aquel conjunto, como tampoco se puede otorgar una fiabilidad definitiva a cada fuente de prueba con independencia de la atribuida a las demás (máxime si son de signo contrario) (...) Diré, por tanto, que la valoración individualizada de las pruebas condiciona la valoración conjunta y que ésta reacciona sobre las pruebas valoradas individualmente” (Juan Igartua Salaverría. *Idem*, p. 154).

62

Como disse Taruffo, em conferência proferida na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná em abril de 2004, “la verità non scaturisce solo dalle prove favorevoli all’esistenza di quel fatto, ma anche – e soprattutto – dal confronto tra prove favorevoli e prove contrarie. Se le prove contrarie non vengono prese in considerazione proprio perché sono contrarie ad una determinata ipotesi, l’accertamento di quel fatto non è adeguatamente giustificato, in quanto non risultano le ragioni per le quali si esclude che tale accertamento potesse essere diverso. Occorre poi considerare che una motivazione ‘implicita’ è in realtà una non-motivazione: il fatto che il giudice giustifichi la propria decisione facendo riferimento alle prove A.B e C non dice nulla, e quindi non la giustifica in alcun modo, intorno alla decisione di non considerare rilevanti le prove contrarie D, E ed F. Se il giudice ha ritenuto queste prove non attendibili, deve spiegare adeguatamente le ragioni di questa sua valutazione; in caso contrario la motivazione del giudizio di fatto è incompleta” (Michele Taruffo. *La motivazione della sentenza*. Revista Genesis de Direito Processual Civil. v. 31, p. 680 e ss.).

63

Salaverría afirma que o contraditório obriga o juiz a indicar as razões que excluem a versão e as provas da parte perdedora (Juan Igartua Salaverría. *Op. cit.*, p. 158).

64

J. Normand, *Le domaine du principe de motivation*. In W.A.A. *La motivation* (Travaux de l’Association H. Capitant), Paris, 2000, p. 18, nota 3, citado por Salaverría, *idem*, p. 159.

65

“Si el rechazo a admitir una prueba pertinente exige motivación, igual régimen habrá de valer para las pruebas que hayan acreditado relevancia prima facie (puntualizo por mi cuenta) y a la postre el juez acaba negándosela. Pero veo venir esta objeción: cuando en la motivación fáctica se obliteran determinadas pruebas, puede inferirse que eso obedece a que el juez no las ha estimado relevantes, y no se hable más. Por lo mismo – respondo yo – cuando un juez no admite una prueba cabe suponer que aquél no le ha reconocido pertinencia, y asunto concluido” (Juan Igartua Salaverría. *Idem*, p. 161).

66

Ver Michele Taruffo. *Studi sulla rilevanza della prova*. Padova: Cedam, 1970. p. 292 e ss.; Juan Igartua Salaverría. *Op. cit.*, p. 162 e ss.

67

“Il punto inerente alla distinzione tra la struttura dimostrativa e il carattere cogente del discorso logico-

matematico, e la natura ‘aperta’ e non cogente del discorso giuridico è in sé piuttosto banale; invero, eccezion fatta per le dichiarazioni programmatiche del razionalismo giurisnaturalistico di derivazione leibniziana, o del positivismo sistematico ottocentesco, l’immagine di una giurisprudenza more geometrico dimostrata ha sempre avuto un successo assai limitato, e non può affatto considerarsi come la concezione oggi prevalente del ragionamento giuridico.” (Michele Taruffo. *La motivazione della sentenza civile*. Padova: Cedam, 1975. p. 194-195).

68

Michele Taruffo. *Funzione della prova: la funzione dimostrativa*. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1997. p. 553-554.

69

Michele Taruffo. *Il controllo di razionalità della decisione fra logica, retorica e dialettica*. Disponível em <http://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/86679>. Também disponível em *RePro*, v. 32, n. 143, jan. 2007.

70

Ver Robert Alexy. *Teoria da argumentação jurídica – A teoria do discurso racional como teoria da justificação jurídica*. São Paulo: Landy, 2001; Luciana Dias. *Decisão, motivação da sentença e discurso*. Tese de doutorado, Curitiba, UFPR, 2004.

71

“Molte teorie dell’interpretazione e della decisione possono definirsi in tutto o in parte ‘retoriche’ in questo senso, in quanto escludono che la decisione sia il frutto di un ragionamento deduttivo o dimostrativo, e mettono in evidenza il ruolo delle ‘argomentazioni ragionevoli’ nel contesto della decisione giudiziaria. Dalla topica giuridica riscoperta da Viehweg all’analisi delle forme di argomentazione giuridica, dall’ermeneutica applicata al diritto all’elaborazione dei modelli di giustificazione delle decisioni, gli approcci che si occupano degli elementi di ragionevolezza argomentativa delle decisioni giudiziarie sono numerosi. Essi si orientano verso modelli non legati agli scherni semplicistici della deduzione sillogistica, né dotati del rigore della dimostrazione, ma pur sempre fondati su forme razionali. La ragionevolezza degli argomenti è infatti sufficiente a garantire la controllabilità delle ragioni che giustificano la decisione. Ciò che rimane al di fuori di queste analisi è, ancora una volta, la retorica intesa come strumento diretto alla persuasione inconsapevole” (Michele Taruffo. *Il controllo di razionalità della decisione fra logica, retorica e dialettica cit.*).

72

“La Richtigkeit della decisione, sottolinea infatti Habermas, significa accettabilità razionale, fondata su buone ragioni” (Michele Taruffo. *Idem*).

73

“Il controllo sulla motivazione non è un controllo sulla validità e fondatezza del decision-making, ma sulla validità e fondatezza delle ragioni di cui il giudice si serve per rendere accettabile ‘all’esterno’ la sua

decisione. Ciò è tutto quello che il giudice può fare per render conto del modo in cui ha esercitato il potere decisorio, ed è tutto quello che può e deve essere richiesto al giudice nel contesto di un ordinamento che non ammette decisioni arbitrarie” (Michele Taruffo. Idem).

74

“Naturalmente dire che il ragionamento decisorio e il ragionamento giustificativo sono qualitativamente diversi non significa escludere in maniera assoluta che tra essi possano esservi punti di contatto. Per un verso, il giudice che sa di dover motivare razionalmente la propria decisione sarà indotto, se non altro per risparmiare tempo ed energie, ma anche per razionalizzare i suoi procedimenti di scoperta, ad utilizzare criteri ed inferenze razionali nel procedimento che lo porta a formulare la decisione finale. In questo senso l’obbligo di motivazione può avere apprezzabili effetti nel senso di indurre il giudice a ‘ragionare’ piuttosto che a decidere sulla base di fattori arbitrari, casuali o capricciosi. Per altro verso, nel redigere la motivazione il giudice potrà utilizzare i criteri e le inferenze razionali che può aver usato nel corso dell’iter di formulazione della decisione, se non altro perché ciò gli consente di risparmiare tempo ed energia. Si potrebbe dire che più è razionale il ragionamento decisorio, più è agevole svolgere il ragionamento giustificativo. Si potrebbe anche auspicare che i giudici non solo motivino razionalmente le proprie decisioni, ma formulino anche tali decisioni in modo razionale, poiché in tal modo si eviterebbero decisioni arbitrarie. Tuttavia, considerazioni di questo genere non possono far venir meno l’irriducibile diversità che separa il procedimento con cui la decisione viene formulata dal ragionamento con cui essa viene giustificata nella motivazione della sentenza” (Michele Taruffo. La motivazione della sentenza, *Revista de Direito Processual Civil*, v. 31, p. 674 e ss.).

75

Michele Taruffo. Funzione della prova: la funzione dimostrativa, *Rivista di Diritto Processuale*, 1997. p. 555.

76

Idem, ibidem.

77

F. M. Iacoviello, La motivazione..., citado por Salaverría, Op. cit., p. 154.

78

Lembre-se que, quando se alude às regras de experiência, também se fala em “senso comum”, “cultura média” e em background knowledges (Cf. Michele Taruffo. Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2001. p. 667 e ss.; Senso comum, experiência e ciência no raciocínio do juiz. Conferência, Curitiba, Faculdade de Direito da UFPR, mar. 2001, p. 17.

79

Deixe-se claro que as regras de experiência também têm grande importância quando o juiz raciocina para

aferir a credibilidade da prova.

80

Juan Igartua Salaverría. Op. cit., p. 167.

81

Idem, p. 165.

82

Idem, p. 166.

83

Idem, ibidem.

84

Michele Taruffo. Funzione della prova: la funzione dimostrativa cit., p. 561.

85

Idem, ibidem.

86

“Per far ciò non occorre un giudice-scienziato, ma occorre almeno un giudice informato e aggiornato, se non altro capace di rendersi conto del problema, e della necessità di sottoporre a verifica l’attendibilità dei propri criteri di valutazione” (Idem, p. 562).

87

Para um maior aprofundamento, ver, a seguir, os comentários ao art. 375.

88

Juan Igartua Salaverría. Op. cit., p. 168.

89

Idem, p. 169.

90

Assim, em termos, Juan Igartua Salaverria. Idem, p. 182.

91

Michele Taruffo. Funzione della prova: la funzione dimostrativa cit., p. 565.

92

Michele Taruffo. La prova dei fatti giuridici, nozioni generali. Milano: Giuffrè, 1992. p. 281 e ss; Funzione della prova: la funzione dimostrativa cit., p. 566 e ss.

93

Idem, p. 567.

94

Michele Taruffo. La prova dei fatti giuridici, nozioni generali cit., p. 282.

95

Michele Taruffo. Funzione della prova: la funzione dimostrativa cit., p. 568.

96

Michele Taruffo. La prova dei fatti giuridici, nozioni generali cit., p. 290.

97

“Il processo non è interessato ad acquisire narrazioni coerenti anche se false, ma narrazione vere (anche se incoerenti)” (Michele Taruffo. Idem, p. 287).

98

Como, aliás, advierte o próprio Taruffo (Idem, p. 289).

99

Sobre as teorias da verdade como coerência e como consenso, ver Anna Pintore, Il diritto senza verità. Torino: Giappichelli, 1996. p. 143 e ss. e p. 188 e ss.

100

Michele Taruffo. La prova dei fatti giuridici, nozioni generali cit., p. 294.

101

Idem, ibidem.

102

Idem, p. 295.

103

Idem, p. 295-296.

104

“Lo stesso discorso vale inoltre, a ragione ancora maggiore, per la narrazione che sia totalmente incongruente perché afferma fatti del tutto privi di dimostrazione probatoria e trascura i fatti accertati secondo le prove. È chiaro d'altronde che questa narrazione è incongruente in quanto non tiene conto dei fatti provati, ma è in sé falsa in quanto afferma, narrandoli come veri, fatti che veri non sono nel contesto degli elementi di conferma acquisiti al processo” (idem, p. 296).

105

Michele Taruffo. *Funzione della prova: la funzione dimostrativa cit.*, p. 568.

106

Idem, ibidem.

107

54 Advirta-se que Taruffo distingue a decisão da motivação, afirmando que “decision-making e motivazione non si identificano”. Segundo o professor da Universidade de Pavia, “la formulazione della decisione avviene attraverso una concatenazione di scelte di varia natura (interpretativi, cognitive) organizzate in una sequenza variabile da caso a caso, ma che ha comunque natura ermeneutica ed euristica. Per ogni scelta il modulo fondamentale è quello della formulazione di ipotesi alternative per poi scegliere quella ‘migliore’ secondo criteri di decisione adeguati e possibilmente razionali. La motivazione è finalizzata a giustificare le scelte, che presuppone già compiute. Il suo modulo fondamentale non è quello della scelta fra alternative, ma quello dell’enunciazione di argomenti razionali a sostegno dell’ipotesi decisoria assunta come migliore” (Michele Taruffo. *Il controllo di razionalità della decisione fra logica, retorica e dialettica cit.*).

108

Juan Igartua Salaverria. *Op. cit.*, p. 185.

109

Ver Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual e tutela dos direitos, cit.*

110

Salvatore Patti. Prove – Disposizioni generali cit., p. 85.

111

Isso não quer dizer, como veremos a seguir, que o juiz não possa se convencer se a parte não cumprir o ônus da prova. Sobre a distribuição do ônus da prova, v., em detalhes, Sérgio Cruz Arenhart, O ônus da prova e sua modificação, *passim*.

112

Salvatore Patti. Prove – Disposizioni generali cit., p. 3.

113

Sobre a evolução do conceito de ônus, sobretudo no Processo Civil, cf. Hernando Devis Echandia. Teoria general de la prueba judicial. Buenos Aires: Fidenter, 1981. p. 393-420.

114

A evolução do pensamento do autor está nas obras Teoria general del derecho. Madrid: Ed. Revista de Derecho Privado, 1955, e Sistema di diritto processuale civile. Padova: Cedam, 1936.

115

Francesco Carnelutti. Teoria general del derecho cit., p. 222.

116

Rodrigo Xavier Leonardo. O conceito de prova e a noção de objeto de prova: considerações a respeito dos juízos de fato no processo civil. Revista Genesis de Direito Processual Civil, vol. 14, Curitiba, Genesis.

117

Nesse sentido, em outra oportunidade escrevemos que “o direito de produzir prova engloba o direito à adequada oportunidade de requerer a sua produção, o direito de participar da sua realização e o direito de falar sobre os seus resultados”. (Luiz Guilherme Marinoni. Novas linhas do processo civil cit., 4. ed., p. 182).

118

Rodrigo Xavier Leonardo. Op. cit.

119

“Tale rischio aumenta in proporzione alla mancanza di ‘forza di convincimento’ della prova fornita dalla parte, e sussiste – in misura maggiore o minore in dipendenza delle circostanze – quando la parte non fornisce alcuna prova” (Salvatore Patti. Prove – Disposizioni generali cit., p. 34-35).

120

Giuseppe Chiovenda. Instituições de direito processual civil. São Paulo : Saraiva, 1965. vol. 1, p. 7.

121

Moniz De Aragão, Egas Dirceu. Exegese do Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Aide. vol. 4, t. I, p. 92.

122

Cf. Giuseppe Chiovenda. Instituições de direito processual civil cit., 1965, p. 8.

123

De acordo com o art. 1268 do Código Civil brasileiro, “feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono. § 1.º Se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que ocorreu a tradição. § 2.º Não transfere a propriedade a tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo”. Diante dessa regra, fica claro que a propriedade do alienante é fato constitutivo, não bastando a posse da coisa móvel, com exceção das hipóteses referidas no caput do art. 1268. A boa-fé do adquirente importa apenas em face dessas exceções e se o alienante adquirir a propriedade mais tarde. Nessas situações, a má-fé do adquirente constitui fato impeditivo.

124

Giuseppe Chiovenda. Instituições de direito processual civil cit., 1965, p. 9.

125

Salvatore Patti. Prove – Disposizioni generali cit., p. 91-92.

126

Idem, p. 93.

127

Segundo Proto Pisani, não há grande dificuldade para distinguir entre fatos constitutivos e fatos modificativos ou extintivos, embora seja problemática e de imensa dificuldade a distinção entre fatos constitutivos e impeditivos. O processualista italiano afirma que na ausência de critérios lógico-formais, a

distinção entre fatos constitutivos e fatos impeditivos deve ser efetuada com base em critérios empíricos. Lembra que o legislador italiano ajuda o intérprete através do emprego de duas técnicas: i) indicando claramente, sobre o plano lexical, o sujeito que deve provar um determinado fato; ii) fazendo recurso à técnica das presunções legais relativas (Proto Pisani, Andrea. *Lezioni di diritto processuale civile* cit., p. 487-489).

128

Segundo Manuel De Andrade são impeditivos os fatos suscetíveis de obstar a que o direito do autor se tenha validamente constituído (v.g., incapacidade, simulação, erro, dolo etc.), e ainda, ao menos parcialmente, os que, operando ab initio, apenas retardem o surgir desse direito ou sua exercibilidade; são modificativos os que podem ter alterado o direito do autor tal como ele validamente se constituiu (v.g., a mudança de local de uma servidão); são extintivos os que tenham produzido a cessação do direito do autor, depois de este já validamente formado (v.g., condição resolutiva, termo peremptório, pagamento, prescrição etc.) (Andrade, Manuel A. Domingues de. *Noções elementares de processo civil*. Coimbra: Almedina, 1979. p. 131, apud, Brito, Wanda Ferraz de; Soares, Fernando Luso; Mesquita, Duarte Romeira. *Código de Processo Civil actualizado e anotado*. Coimbra: Almedina, 1994. p. 329-330).

129

V. Revista dos Tribunais 673/105 e ss.; Revista dos Tribunais 716/ 210 e ss.; Revista dos Tribunais 692/157 e ss.; Revista dos Tribunais 679/142 e ss.; Revista dos Tribunais 671/193 e ss.; Revista dos Tribunais 724/ 423 e ss.; Revista dos Tribunais 732/ 276 e ss.; Revista dos Tribunais 672/119 e ss.; Revista dos Tribunais 689/230 e ss.

130

Luiz Guilherme Marinoni. *Tutela antecipatória e julgamento antecipado*. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2003. p. 62 e ss.

131

Salvatore Patti. *Prove – Disposizioni generali* cit., p. 97 e ss.

132

Cf. Salvatore Patti. *Prove – Disposizioni generali* cit., p. 8-12.

133

Giovanni Verde. *L'onere della prova nel processo civile*. Napoli: Jovene, 1974. p. 55 e ss.

134

Proto Pisani, Andrea. *Appunti sulla giustizia civile*. Bari: Cacucci, 1982. p. 106.

135

Salvatore Patti. Prove – Disposizioni generali cit., p. 57.

136

Proto Pisani, Andrea. Appunti sulla giustizia civile cit., p. 107.

137

Idem, p. 109.

138

Idem, p. 109-110.

139

Proto Pisani, Andrea. Appunti sulla giustizia civile cit., p. 110.

140

Salvatore Patti. Prove – Disposizioni generali cit., p. 58-59.

141

V., Sérgio Cruz Arenhart, O ônus da prova e sua modificação, passim.

142

“Non bisogna dimenticare che mentre la mancata formazione del convincimento non danneggia la parte non onerata che non è stata ammessa a provare, viceversa se il giudice perviene al convincimento in base alle prove fornite dalla parte gravata dall’onere, risulta evidente la lesione del diritto alla prova (e dell’interesse sostanziale) della parte non ammessa a provare in quanto non gravata dall’onere” (Salvatore Patti Prove – Disposizioni generali cit., p. 41-42).

143

Luigi Paolo Comoglio; Corrado Ferri; Michele Taruffo. Lezioni sul processo civile cit., p. 526.

144

Salvatore Patti. Prove – Disposizioni generali cit., p. 164.

145

É o que propunha Marcelo Abelha, ainda na vigência do CPC/1973. Diz ele em significativa passagem: “A

prova deve ser vista, sim, como algo intrínseco, necessário e indisponível à ordem jurídica justa. Há estreita e, diríamos, umbilical ligação entre a prova e a coisa julgada como instrumento de pacificação social. Se a coisa julgada é instrumento político da busca dessa paz e harmonia, é certo também que a prova é o elemento ou instrumento idôneo para que a coisa julgada dê, efetivamente, justiça... Por tudo isso, reconhecendo-se que o julgamento pelo art. 333 do CPC no caso *non liquet* é um grave exemplo de descomprometimento com a ordem jurídica justa, é certo que a melhor solução para o sistema seria desativar a coisa julgada, porque o escopo social (justiça) do processo não teria sido alcançado. Dever-se-ia, portanto, relativizar a coisa julgada, abrindo-se a hipótese de rediscussão do que teria sido julgado com base no art. 333 (*non liquet*), sempre que houvesse acesso a provas que permitissem alcançar um resultado que fosse corretivo da eventual injustiça” (Marcelo Abelha. Op. cit., p. 162). Ainda que essa proposta seja bem intencionada, não há como pensar que a prova, no sentido proposto, de meio ideal de esclarecimento dos fatos, tenha alguma coisa a ver com a função do processo e, portanto, com a natureza da coisa julgada material. O direito à prova ou o direito à participação são direitos que decorrem da necessidade de legitimação do processo e do seu produto, mas não servem, e infelizmente jamais poderão servir, para garantir um resultado verdadeiro, como deseja o autor do interessante ensaio. Lembre-se, como dizia Calamandrei, de que a verdade do juiz somente pode ser encontrada a partir dos meios de prova que lhe são disponíveis (Piero Calamandrei. *Verità e verosimiglianza nel processo civile cit.*, p. 164 e ss). De outra forma, as partes se colocariam na posição de dois historiadores que, por não conseguirem convencer o público acerca de uma tese, poderiam ficar eternamente à espera de um meio de prova para convencer o juiz. É por isso que a aplicação da regra do art. 333 do CPC é – ainda que não ideal – absolutamente necessária, enquanto que a coisa julgada material jamais poderá ser descartada diante da sua finalidade – que também tem repercussão social – de dar fim aos conflitos. Lembre-se que a coisa julgada é inerente ao Estado de Direito e, assim, deve ser vista como um sub-princípio que lhe dá conformação. Com efeito, a coisa julgada material é atributo indispensável ao Estado Democrático de Direito e à efetividade do direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário – obviamente quando se pensa no processo de conhecimento. Nesse exato sentido é a lição de Rosenberg-Schwab-Gottwald, quando sustentam a idéia de que a “*materielle Rechtskraft is notwendige Folge des Rechts auf Rechtsschutz durch die Gerichte. Sie findet ihre verfassungsgemäße Verankerung im Rechtsstaatsprinzip*” “A coisa julgada material é uma consequência necessária do direito à proteção legal pelos tribunais. Sua ancoragem constitucional é encontrada no princípio do Estado de Direito” (Leo Rosenberg; Karl Heinz Schwab; Peter Gottwald. *Zivilproßrecht*. 15. ed. München: Verlag C.H. Beck, 1993. p. 915). Ou seja, de nada adianta falar em direito de acesso à justiça sem dar ao cidadão o direito de ver o seu conflito solucionado definitivamente. Por isso, se a definitividade inerente à coisa julgada pode, em alguns casos, produzir situações indesejáveis ao próprio sistema, não é correto imaginar que, em razão disso, ela simplesmente possa ser desconsiderada. Nesse sentido, não parece que a simples afirmação de que o Poder Judiciário não pode emitir decisões contrárias à justiça, à realidade dos fatos e à lei, possa ser vista como um adequado fundamento para o que se pretende ver como “relativização” da coisa julgada. Por outro lado, apesar de se reconhecer o primado do princípio da dignidade da pessoa humana como vetor do sistema do direito, é certo que o atual desenvolvimento das teorias pelas quais sempre seria obtível uma decisão justa ainda não possibilitam sua execução fática, como pretendeu, por exemplo, a “tese da resposta correta” de Ronald Dworkin (*Taking rights seriously*. Cambridge: Harvard University Press, 1978), uma das mais discutidas na atualidade, a qual pressupõe a existência de um juiz sobrenatural – Hércules –, o que por si só inviabiliza a sua utilização na prática. Em outras palavras, ainda não existem condições de disciplinar um processo que sempre conduza a um resultado justo e, assim, não há como admitir a “desativação da coisa julgada”.

146

Contra, em termos, Luigi Paolo Comoglio; Corrado Ferri; Michele Taruffo. Lezioni sul processo civile cit., p. 527.

147

Ver, adiante, os comentários a tais artigos.

148

Sobre a influência do comportamento das partes sobre a regra do ônus da prova, ver Gian Antonio Micheli. La carga de la prueba. Buenos Aires: Ejea, 1961. p. 148 e ss.

149

Escreveu Ivan Righi: “interessa, isto sim, o comportamento processual que permite ilações racionais, de conteúdo probatório, úteis para decisão da lide. Vale dizer, a conduta que – encarada pelo juiz como fato processual – sirva de indício e propicie, mediante o emprego de critério lógico-dedutivo, uma conclusão acerca de questão importante ao equacionamento do litígio”. (Righi, Ivan. Eficácia probatória do comportamento das partes. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, n. 20, a. 20, Curitiba, 1981/1982, p. 17 e ss.). V., sobre o comportamento dos sujeitos processuais como argumento de prova, *supra*, na parte geral deste volume, item 10.

150

Leo Rosenberg. Die Beweislast auf der Grundlage des Bürgerlichen Gesetzbuchs und der Zivilprozessordnung. 5. ed. München: Beck, 1965. p. 91 e ss.

151

“Prova – Ônus – Contrato – Código de Proteção e Defesa do Consumidor – Lei 8.078/1990 – Art. 6.º – Contrato firmado em data anterior a vigência do Código de Defesa do Consumidor – Circunstância que não impede a aplicação imediata da Lei nova aos contratos que envolvem relações de consumo ainda em andamento, firmadas antes do seu advento – Inversão do ônus da prova determinado” (1.º TACSP – 6.ª C – AI 645.280-7/002 – rel. Juiz Jorge Farah).

152

“Consumidor – Ônus da prova – Inversão – Faculdade concedida ao Juiz, que irá utilizá-la no momento que entender oportuno, se e quando estiver em dúvida, geralmente por ocasião da sentença – Inteligência do art. 6.º, VIII, da Lei 8.078/1990.

“Nesse contexto, há de ficar consignado que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, VIII, do CDC é uma faculdade concedida ao Juiz que irá utilizá-la no momento em que entender oportuno, geralmente por ocasião da sentença. Essa providência deve ocorrer se e quando o julgador estiver em dúvida, ou seja, quando for proferir a sentença, que é o momento processual adequado para o exame e a valoração da prova. É uma regra de julgamento que deve ser aplicada na sentença ao se proferir a decisão

de mérito” (1.º TACivSP – Câm. 3 – AI 912.726-8 – rel. Juiz Roque Mesquita – Revista dos Tribunais 780/278).

Ainda que essa questão não possa ser solucionada de maneira tão simples, conforme se demonstrará na sequência do presente item, é importante frisar que o art. 38 do CDC afirma expressamente que “o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina”. Nesse caso, portanto, não há que se aplicar o art. 6.º, VIII, do CDC – que subordina a inversão do ônus da prova a determinados pressupostos (verossimilhança e hipossuficiência) que devem ser aferidos pelo juiz –, pois o art. 38 afirma expressamente – já resolvendo a questão – que o ônus da prova “da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina”. V., ainda, sobre o tema, Sérgio Cruz Arenhart, O ônus da prova e sua modificação, passim.

153

“Consumidor – Prova – Inversão do ônus – Acionamento que fica a critério do Magistrado sempre que houver verossimilhança na alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente – Inteligência do art. 6.º, VIII, da Lei 8.078/90 – Ementa oficial: A regra contida no art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que cogita a inversão do ônus da prova, tem a motivação de igualar as partes que ocupam posições não-isonômicas, sendo nitidamente posta a favor do consumidor, cujo acionamento fica a critério do Juiz sempre que houver verossimilhança na alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência, por isso mesmo que exige do Magistrado, quando da sua aplicação, uma aguçada sensibilidade quanto à realidade mais ampla onde está contido o objeto da prova cuja inversão vai operar-se...

“Da regra inserta no art. 6.º, VIII, do CDC, extrai-se que a inversão do ônus da prova (a) é posta em favor do consumidor, (b) fica a critério do juiz, (c) sempre que houver verossimilhança na alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, e (d) segundo as regras ordinárias de experiência” (STJ – 4.ª T. – Resp 140.097-SP – rel. Min. Cesar Asfor Rocha – Revista dos Tribunais 785/184).

“Consumidor – Prova – Relação de consumo que compreende serviços hospitalares – Inversão do ônus – Facilitação da defesa do consumidor em razão da hipossuficiência econômica – Inteligência do art. 6.º, VIII, da Lei 8.078/90 – Voto vencido.

“Induvidosamente a relação jurídica é de consumo, por compreender serviços de natureza hospitalar. A finalidade do Código, que disciplina tal tipo de interação, é a de proteger e defender o consumidor. De modo especial, o inc. VIII, do art. 6.º, tem por escopo a facilitação da defesa de seus direitos, como resultante do princípio da vulnerabilidade (art. 4.º, I). Para tanto, admite a inversão do ônus da prova, quando a critério do juiz (de ofício, inclusive, por se tratar o Código de Defesa do Consumidor de norma de ordem pública, art. 1.º), for verossímil a alegação ou hipossuficiente o consumidor. A alternativa pela disjuntiva ou permite a presença, apenas, de um desses requisitos, para autorizar a inversão” (TJSP – 5.ª Câm. 5. de Direito Privado – AI 225.510.4/3 – rel. Des. Marcus Andrade – Revista dos Tribunais 802/206).

“Consumidor – Ônus da prova – Inversão – Admissibilidade, se verossímil a alegação ou verificada sua hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiência – Inteligência do art. 6.º, VIII, da Lei 8.078/90. Ementa oficial: A teor do preceito do art. 6.º, VIII, da Lei 8.078/90, é possível a inversão do ônus da prova em favor dos autores se for verossímil a alegação ou se o consumidor for hipossuficiente segundo as regras ordinárias da experiência” (TJSC – Câm. 1 – Ap. 1999.016289-3 – rel. Des. José Volpato de Souza – Revista dos Tribunais 815/369).

“Mesmo caracterizada relação de consumo, o ônus da prova só é de ser invertido quando a parte requerente tiver dificuldades para a demonstração de seu direito dentro do que estabelecem as regras processuais comuns, ditadas pelo art. 333 e incs. presentes a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência” (TARGS – Julgados do Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul, vol. 102, p. 213-214).

154

“A responsabilidade pelos vícios dos produtos ou dos serviços tem fundamento diverso da responsabilidade pelos acidentes de consumo. A primeira está relacionada à falta de equivalência entre o garantido e o prestado, enquanto que a segunda se funda no dano.

“Em relação à responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, o CDC estabelece de forma expressa a responsabilidade objetiva (arts. 12 e 14, CDC). Entretanto, no que diz respeito à responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço, a doutrina ora pensa em responsabilidade objetiva ora em culpa juris et de jure.

“Porém, falta-lhe a percepção de que a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço tem dois patamares: a do inadimplemento e a do dano por ele provocado. O direito de exigir o cumprimento perfeito independe de culpa; essa somente poderia ter relevância diante do dano provocado pelo adimplemento imperfeito.

“Contudo, afirma o art. 23 do CDC que ‘a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade’. Como é óbvio, se a responsabilidade pelo cumprimento imperfeito não tem relação com a culpa, esse artigo somente pode dizer respeito à responsabilidade pelo dano derivado do cumprimento imperfeito.

“Mas, como diz o referido art. 23, para a responsabilização pelo dano decorrente do inadimplemento, pouco importa a ignorância do fornecedor sobre os vícios do produto ou do serviço, o que significa que, no sistema do CDC, a demonstração de boa-fé não é capaz de elidir a responsabilidade pelo dano causado ao consumidor.

“Assim, considerando que a necessidade de adimplemento perfeito (específico) não tem razão para tomar em consideração a culpa, resta a conclusão de que o sistema do CDC é adequado ao dispensá-la no único local em que poderia ser indagada, ou seja, no que concerne aos danos decorrentes do fato do produto ou do serviço e em relação aos danos derivados do inadimplemento” (Luiz Guilherme Marinoni. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais 2004, p. 234 e ss).

155

Note-se que os Tribunais, muitas vezes, ao tratarem do ônus da prova, indagam apenas se o réu está ou não sujeito às regras do CDC, quando, além dessa circunstância, deve estar presente um dos pressupostos do art. 6.º, VIII, desse código. Veja-se, por exemplo: “Apelação cível – Responsabilidade civil objetiva – Queda de passageiro no interior de coletivo – Dever de indenizar – Decorrente do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, porque concessionária de serviço público – Inversão do ônus da prova – A empresa de transporte coletivo é prestadora de serviços, estando submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova – Dano moral e material – Redução dos valores – Apelo parcialmente provido – Unânime...

“A tese da demandada é de não ter a autora se desincumbido de provar que o fato se deu no

interior de coletivo de sua propriedade, porquanto, na empresa, não há qualquer registro sobre o mesmo...

“Por primeiro, consigno que a demandada é prestadora de serviços, logo, estando submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo plausível a inversão do ônus da prova” (TJRS – art. 12, CC – AP 70006749212 – rel. Des. Agathe Elsa Schmidt da Silva).

156

“Prova – Responsabilidade Civil – Acidente de trânsito – Ônus – Código de Proteção e Defesa do Consumidor – Art. 6.º, VIII. Decisão interlocutória agravada que, depois de inverter o ônus da prova, com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, foi reconsiderada para incumbi-la ao consumidor – Lide que envolve relação de consumo, com nexos entre causa e efeito, por defeito de fabricação do veículo, noticiado pela prova documental nos autos – Hipóteses em que se impõe a inversão do ônus em benefício do consumidor” (1.º TACSP – art.11, CC – AI 00649687-7/007 – rel. Juiz Maia da Cunha).

157

Os Tribunais, ainda que sem compreender o problema na perspectiva do texto, têm percebido que a dificuldade na produção da prova é justificativa para a inversão do ônus da prova: “Prova – Inversão do ônus – Admissibilidade – Consumidor – Alegação de prejuízo decorrente de falha no sistema operacional de cartão de crédito e de caixas eletrônicos – Prova técnica específica, cujos elementos e dados para a sua realização devem ser fornecidos pela instituição financeira, por ser a operadora do sistema e prestadora do serviço – Cliente que é mero usuário, desconhecedor de qualquer dado técnico – Aplicação do art. 6.º, VIII, da Lei 8.078/1990...

“E inversão do ônus da prova, para o caso em testilha, revela-se pertinente face à natureza da prova pericial, constante de exame da apontada falha do sistema operacional de cartão de crédito e de caixas eletrônicos, redundante do alegado prejuízo sofrido pela agravada” (1.ª TACivSP – Câ. 2 – AI 981.449-3 – rel. Juiz Ribeiro de Souza – Revista dos Tribunais 789/275).

“Inversão do ônus da prova – Art. 6.º, VIII, do CDC – Cabimento da inversão apenas se, presentes a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, a parte tivesse dificuldade para a demonstração de seu direito – Hipótese não configurada nos autos – Não caracterização, ademais, de hipossuficiência, no sentido técnico que lhe empresta o art. 6.º, VIII, do CDC – Recurso provido...

“O inc. VIII, do art. 6.º. do Código de Defesa do Consumidor, possibilita a inversão do ônus da prova, mas com o escopo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor, isso no caso de ser ele hipossuficiente ou verossimilhante a defensor. Vale enfatizar: a finalidade é a de facilitar a defesa dos direitos do consumidor. Sob esse prisma, bem ressaltou o E. Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul que, ‘mesmo caracterizada relação de consumo, o ônus da prova só é de ser invertido quando a parte requerente tiver dificuldades para a demonstração de seu direito dentro do que estabelecem as regras processuais comuns...’” (1.º TACivSP – Câ. 2 – AI 943.744-9 – rel. Juiz Cyro Bonilha).

A doutrina também vem frisando a dificuldade na produção da prova como critério para a inversão do ônus da prova: “Isso assentado, impõe-se ao juiz decisão de inversão, em favor do consumidor, sempre que se evidencie mais fácil ao fornecedor a produção da prova. Destarte, não se há de exigir do autor, que se afirma vítima de erro médico, que prove a culpa do cirurgião, senão que a este

cumprirá demonstrar de que se utilizou de todos os meios adequados da técnica e da ciência, no momento de relevo. O cirurgião está em situação inequivocadamente superior, não apenas em razão de seus conhecimentos técnico-científicos, mas também porque, em determinadas circunstâncias (como quando sob anestésico o paciente), apenas ele, dentre os figurantes da relação, tem condições de alguma demonstração” (Antônio Dall’agnol Júnior. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Revista Jurídica, vol. 280, p. 10). No direito português, em direção similar, concluiu recentemente Rui Manuel de Freitas Rangel: “O encargo da prova cabe à parte que se encontra em melhor situação para a produzir, constituindo, sem dúvida, um estímulo para que a prova seja produzida pela parte que mais perfeitamente pode auxiliar a descoberta da verdade” (Rui Manuel de Freitas Rangel. O ônus da prova no processo civil. Coimbra: Almedina, 2002. p. 366).

158

Luigi Paolo Comoglio; Corrado Ferri; Michele Taruffo. Op. cit., p. 529.

159

Idem, ibidem.

160

Sobre a modificação convencional do ônus probatório, v. Sérgio Cruz Arenhart, O ônus da prova e sua modificação, p. 56 e ss.

161

Nelson Nery Jr. aponta exemplos desta situação em relação ao direito do consumidor. Segundo ele, “os arts. 12, § 3.º, e 14, § 3.º, do CDC determinam que, para haver exclusão da responsabilidade de o fornecedor indenizar o dano decorrente do fato do produto ou serviço (acidentes de consumo), é preciso que ele comprove a existência e verificação das causas excludentes adotadas pela lei. Da mesma forma, o art. 38 do Código diz competir o ônus da prova da veracidade da informação ou comunicação publicitária a quem as patrocina. Nesses casos, como o ônus da prova está atribuído ao fornecedor por normas de ordem pública (art. 1.º do CDC), estas não podem ser derogadas por convenção das partes” (Ada Pellegrini Grinover et al., Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, p. 506).

162

No mesmo sentido, Godinho, Robson. Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo Código de Processo Civil, ob. cit., p. 242-243.

163

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, tomo IV, p. 274.

164

A norma contida no § 3.º, I e II do art. 373 – que repete o contido no art. 333, parágrafo único, do CPC/73 –

tem nítida inspiração no art. 2.698 do Código Civil italiano, que assim estabelece: “Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l’onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l’inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l’esercizio del diritto”.

165

Luigi Paolo Comoglio; Corrado Ferri e Michele Taruffo. Op. cit., p. 528.

166

Assim tb., Robson Godinho. Ob. cit., p. 257.

167

Luigi Paolo Comoglio; Corrado Ferri; Michele Taruffo. Op. cit., p. 510.

168

Segundo Patti, a prova da notoriedade pode constituir um forte argumento de prova da verdade do fato e, nesse sentido, deve ser vista como uma prova indiciária (Salvatore Patti. Prove – Disposizioni generali cit., p. 78). Comoglio, Ferri e Taruffo, contudo, escrevem que a verdade de um fato está implícita na sua própria notoriedade, uma vez que o ambiente social e a cultura média nele inserida garantem a sua veracidade (Luigi Paolo Comoglio; Corrado Ferri; Michele Taruffo. Op. cit., p. 510).

169

Sobre as regras de experiência, ver a seguir os comentários ao art. 375.

170

Luigi Paolo Comoglio; Corrado Ferri; Michele Taruffo. Op. cit., p. 510.

171

Idem, p. 511.

172

Comoglio, Ferri e Taruffo, entretanto, pensam de forma contrária, escrevendo que os fatos notórios não precisam ser alegados, porque esses “si impongono alla conoscenza del giudice” (idem, ibidem).

173

Para maior aprofundamento, ver Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart. Prova e convicção, p. 495 e ss.

174

Ver Wolfgang Grunsky, Grundlagen des Verfahrensrechts, p. 163.

175

Leo Rosenberg, Tratado de derecho procesal civil, tomo II, p. 216.

176

Leo Rosenberg e Karl Heinz Schwab, Zivilprozessrecht, p. 700.

177

Como diz Clito Fornaciari Júnior, “com a confissão não fica o juiz adstrito a julgar contra aquele que confessou, pois, como diz respeito a fatos, apesar de estes se tornarem incontrovertidos, por estarem provados contra o confitente, deles poderão não emergir as consequências pretendidas pelo autor” (Reconhecimento jurídico do pedido, p. 11).

178

Filippo Colia, L’ordinanza per il pagamento di somme non contestate nel processo del lavoro. Rivista di Diritto Processuale, p. 538 e ss.

179

Salvatore Patti, Prove –Disposizioni generali, cit., p. 69 e ss.

180

Giuseppe Tarzia, Lineamenti del processo di cognizione, p. 112; Giovanni Verde, Prova. Enciclopedia del Diritto, vol. 37, p. 613 e ss.

181

Virgilio Andrioli, Commento al Codice di Procedura Civile, vol. 1, p. 338 e ss.

182

Art. 116 do CPC italiano: “Valutazione delle prove – [1] Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. [2] Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire la ispezione che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”.

183

O texto se refere ao dispositivo do CPC/1973, hoje revogado. O preceito em questão equivale, atualmente, ao art. 350.

184

José Joaquim Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, cit., vol. 3, p. 274.

185

Idem, p. 275.

186

“O eventual requerimento de prova relativamente a fatos não contestados deve ser considerado irrelevante” (Salvatore Patti, Prove – Disposizioni generali, cit. p. 70).

187

“O fato alegado por uma parte e não contestado pela outra deve ser considerado verdadeiro” (Salvatore Patti, Prove – Disposizioni generali, cit., p. 70).

188

Cf. Salvatore Patti, Prove – Disposizioni generali, cit., p. 70.

189

Diz Calmon de Passos “que o princípio não vige, com o apoio no inc. I: a) quando o réu não poderia prestar depoimento pessoal e, conseqüentemente, por esse meio ensejar a confissão, mediante aceitação expressa da verdade de um fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário; b) ou quando, prestando depoimento pessoal, a confissão é inadmissível. Se a confissão não era obtível pelo depoimento pessoal, o silêncio na contestação não pode valer confissão ficta. Pode-se, portanto, afirmar não incidir o ônus da impugnação quando é parte a Fazenda Pública, ou quando é parte um incapaz, ou ainda uma pessoa jurídica e seu representante carecem de poder, segundo o estatuto, para confessar” (José Joaquim Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, cit., 1983, p. 276-277).

190

A não contestação “nasce da un sistema di argomentazioni del difensore o della parte, comparsa de persona, che sia conciliabile con la verità dei fatti allegati dall'altra parte o dal difensore di questa, ne importa che la conciliabilità sia implicita o esplicita” (Virgilio Andrioli, Prova. Novissimo Digesto Italiano, vol. 143, p. 274).

191

Art. 405, segunda parte: “En la contestación a la demanda habrán de negarse o admitirse los hechos aducidos por el actor. El tribunal podrá considerar el silencio o las respuestas evasivas del demandado

como admisión tácita de los hechos que le sean perjudiciales”.

”.

192

Ver Moniz de Aragão, Exegese do Código de Processo Civil, cit., vol. 4, tomo I, p. 98; José Rogério Cruz eTucci, A causa petendi no processo civil, p. 149-150.

193

Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Tutela antecipatória e julgamento antecipado.

194

Cf. Andrea Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, cit., p. 482.

195

José Carlos Barbosa Moreira, As presunções e a prova. Temas de direito processual – Primeira série, p. 62.

196

Eduardo Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, cit., p. 227.

197

Michelle Taruffo. Il giudizio prognostico del giudice tra scienza privata e prova scientifica. Sui Confini – Scritti sulla giustizia civile. Bologna: Il Mulino, 2002. p. 339.

198

Michelle Taruffo. Funzione della prova: la funzione dimostrativa cit., p. 559.

199

Friedrich Stein. El conocimiento privado del juez cit., p. 22.

200

Francesco Carnelutti. La prova civile cit., 1947, p. 64.

201

Carnelutti salientou que a doutrina alemã, ao tratar do tema, utilizou as fórmulas “regra de experiência” (Erfahrungssatz) e “regra da vida” (Lebensregel), a primeira preferida por Stein e a segunda por Fitting (idem, 1947, p. 65).

202

Sobre o tema, ver Twining, William. Theories of Evidence: Bentham & Wigmore. Stanford: Stanford University Press, 1985. p. 142 e ss.

203

Michelle Taruffo. Funzione della prova: la funzione dimostrativa cit., p. 559.

204

“Ne rimarrebbe esclusa una grande quantità di nozioni di senso comune che non sono riconducibili in alcun modo alla forma di leggi o regole generali ma che sono di uso quotidiano, anche da parte dei giudici” (idem, p. 560).

205

Michelle Taruffo. Il giudizio prognostico del giudice tra scienza privata e prova scientifica cit., p. 340.

206

Michele Taruffo. Funzione della prova: la funzione dimostrativa cit., p. 561.

207

Idem, ibidem.

208

Idem, p. 562.

209

“Per far ciò non occorre un giudice-scienziato, ma occorre almeno un giudice informato e aggiornato, se non altro capace di rendersi conto del problema, e della necessità di sottoporre a verifica l’attendibilità dei propri criteri di valutazione” (idem, ibidem).

210

Como percebeu Salaverría, “no todas las máximas poseen la misma probabilidad” (Juan Igartua Salaverría. La motivación de las sentencias, imperativo constitucional cit., p. 168).

211

Idem, ibidem.

212

Michele Taruffo. Funzione della prova: la funzione dimostrativa cit., p. 564.

213

Juan Igartua Salaverría. La motivación de las sentencias, imperativo constitucional cit., p. 165; Angelo Dondi. Problemi di utilizzazione delle “conoscenze esperte” come “expert witness testimony” nell’ordinamento statunitense. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Milano, Giuffrè, 2001. p. 1.145 e ss.

214

Juan Igartua Salaverría. La motivación de las sentencias, imperativo constitucional cit., p. 166.

215

STJ, 1ª Turma, rel. Min. Garcia Vieira, REsp. 98377-DF, DJU 03.08.1998, p. 84.

216

STJ, 4ª Turma, rel. Min. Marco Buzzi, AgRg no Ag 1.288.387-MG, *DJe* 18.02.2015; STJ, 2ª Turma, rel. Min. Castro Meira, REsp 1.089.205-GO, *DJe* 28.06.2013.

217

Antônio Carlos de Araújo Cintra. Prova do direito estrangeiro. Revista dos Tribunais 485/16, São Paulo: Ed. RT, 1976. p. 16.

218

Cf. F. C. Pontes de Miranda. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1974. t. IV, p. 243.

219

O Tribunal de Justiça de São Paulo já utilizou o costume contra legem, afirmando que “segundo os usos e costumes dominantes no mercado de Barretos, os negócios de gado, por mais avultados que sejam, celebram-se dentro da maior confiança, verbalmente, sem que entre os contratantes haja troca de qualquer documento”. Entendeu-se que a exigência de documento acabaria por introduzir nos meios pecuaristas da região um fator de dissociação (Revista dos Tribunais 132/660).

220

Lembre-se que a opinio juris necessitatis é apontada como elemento capaz de permitir a distinção entre o costume e o uso.

221

Revista dos Tribunais 534/232.

222

Cf. Hermenegildo de Souza Rego. Dever de sigilo e escusa de depor. RePro, n. 33, São Paulo: Ed. RT, 1984. p. 201 e ss.

223

V. Sérgio Carlos Covello. O sigilo bancário como proteção à intimidade. Revista dos Tribunais, vol. 648, São Paulo, Ed. RT, 1989. p. 27 e ss.

224

ZPO alemã, §138: “1. Die Parteien haben ihre Erklärungen über tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit gemäss abzugeben.

2. Jede Partei hat sich über die von dem Gegner behaupteten Tatsachen zu erklären.

3. Tatsachen, die nicht ausdrücklich bestritten werden, sind als zugestanden anzusehen, wenn nicht die Absicht, sie bestreiten zu wollen, aus den übrigen Erklärungen der Partei hervorgeht.

4. Eine Erklärung mit Nichtwissen ist nur über Tatsachen zulässig, die weder eigene Handlungen der Partei noch Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen sind”.

225

Cf. Giuliano Scarselli. La condanna con riserva. Milano: Giuffrè, 1989. p. 419.

226

Cf. Scarselli, Giuliano. La condanna con riserva cit., p. 439.

227

Righi, Ivan. Eficácia probatória do comportamento das partes cit., p. 2.

228

Embora o texto legal se refira a medidas de indução, de coerção, mandamentais ou sub-rogorias, há aí clara superafetação da regra. Medidas de coerção são uma das espécies de medidas de indução, na medida em que estas podem ser ou de coerção ou de pressão positiva. “Mandamentais”, por outro lado, é eficácia de decisão, que é veiculada com o acoplamento de técnica de indução, para a obtenção da colaboração do ordenado. Portanto, não há nenhum sentido em se empregar a expressão pleonástica tal como feito pelo texto legal. Basta saber que é sempre possível o emprego de medidas de indução e de sub-rogação.

Como já dito anteriormente, a expressão empregada pelo código (medidas de indução, coerção, mandamentais ou de sub-rogação) evidentemente constitui uma impropriedade, na medida em que as técnicas de coerção são espécie de técnicas de indução e que a eficácia mandamental é a eficácia da decisão que implica ordem – e à qual se acopla medida de indução ou de sub-rogação para o seu atendimento. Por outras palavras, só existem medidas de indução ou de sub-rogação; o resto é excesso inútil da regra.

Comentários ao CPC - v. VI - Marinoni - Ed. 2018

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABELHA, Marcelo. Breves considerações sobre a prova nas demandas coletivas ambientais. In: LEITE, José Rubens Morato; DANTAS, Marcelo Buzaglo. *Aspectos processuais do direito ambiental*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.

ABRAHÃO, João. O valor probatório das reproduções mecânicas. *RePro*. n. 20. São Paulo: Ed. RT, 1980.

ADAMY, Pedro. *Renúncia a direito fundamental*. São Paulo: Malheiros, 2011.

AGUIAR, João Carlos Pestana de. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 1974. vol. 4.

ALEXANDRE, Isabel. *Provas ilícitas em processo civil*. Coimbra: Almedina, 1998.

ALEXY, Robert. *Teoria da argumentação jurídica – A teoria do discurso racional como teoria da justificação jurídica*. Trad. Zilda Hutchinson Schild da Silva. São Paulo: Landy, 2001.

_____. *Teoría de los derechos fundamentales*. Trad. Ernesto Garzon Valdés. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1993.

_____. _____. 3. reimp. Trad. Ernesto Garzon Valdés. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002.

ALSINA, Hugo. *Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial*. 2. ed. Buenos Aires: Ediar, 1961. t. III.

ALVES, Maristela da Silva. *O ônus da prova como regra de julgamento – Prova Cível*. Rio de Janeiro: Forense, 1999.

AMARAL, Paulo Osternack. *Provas – atipicidade, liberdade e instrumentalidade*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

AMARAL SANTOS, Moacyr. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994. vol. 4.

_____. *Primeiras linhas de direito processual civil*. São Paulo: Saraiva, 1990. vol. 3.

_____. *Prova judiciária no cível e comercial*. 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 1968. vol. 3.

ANDRADE, Manuel A. Domingues de. *Noções elementares de processo civil*. Coimbra: Almedina, 1979.

_____. *Teoria geral da relação jurídica*. 7. reimp. Coimbra: Almedina, 1992. vol. 2.

ANDREWS, Neil. *Andrews on civil procedure – court proceedings*. Cambridge: Intersentia, 2013. vol. I.

_____. *English civil procedure*. Oxford: Oxford University Press, 2003.

ANDRIOLI, Virgilio. *Commento al Codice di Procedura Civile*. 3. ed. Napoli: Jovene, 1957. v. 2.

- _____. _____. Napoli: Jovene, 1964. vols. 1 e 2.
- _____. Prova. *Novissimo digesto italiano*. vol. 143. Torino: Utet.
- ANTOINE, Mireille; ELOY, Marc; BRAKELAND, Jean-François. *Le droit de la preuve face aux nouvelles technologies de l'information*. Namur: E.Story-Scientia, 1992 (Cahiers du Centre de Recherches – Informatique et Droit, n. 7).
- APRIGLIANO, Ricardo. *Ordem pública e processo*. São Paulo: Atlas, 2011.
- ARAÚJO, Francisco Fernandes de. Requisição de informações pelo poder judiciário. *RePro*. n. 38. São Paulo: Ed. RT, 1985.
- ARENHART, Sérgio Cruz. *A tutela inibitória da vida privada*. São Paulo: Ed. RT, 2000.
- _____. A verdade substancial. *Revista de Direito Processual Civil*. Gênese, 1996.
- _____. *Perfis da tutela inibitória coletiva*. São Paulo: Ed. RT, 2003.
- _____; MARINONI, Luiz Guilherme. *Manual do processo de conhecimento*. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2005.
- ARMELIN, Donaldo. Tutelas jurisdicionais diferenciadas. In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). *O processo civil contemporâneo*. Curitiba: Juruá, 1994.
- ARRUDA ALVIM, José Manoel. Ação incidental de falsidade ideológica de laudo pericial – Preclusão – Sentido da palavra “documento”. *RePro*. n. 54. São Paulo: Ed. RT, 1989.
- _____. Anotações sobre a medida liminar em mandado de segurança. *RePro*. n. 39. São Paulo: Ed. RT, 1985.
- _____. A nulidade da sentença por infração ao art. 398 do Código de Processo Civil. *RePro*. n. 3. São Paulo: Ed. RT, 1976.
- _____. *Código de Processo Civil comentado*. São Paulo: Ed. RT, 1975. vols. 1 e 2.
- _____. Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil. *RePro*. n. 1. São Paulo: Ed. RT, 1976.
- _____. *Manual de direito processual civil*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 1986. vol. 2.
- _____. *Tratado de direito processual civil*. São Paulo: Ed. RT, 1990. vols. 1 e 2.
- ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. *Mandado de segurança contra ato judicial*. São Paulo: Ed. RT, 1989.
- ASCARELLI, Tullio. Registrazione nei libri di commercio e confessione. *Rivista di Diritto Processuale*. Tomo I. Padova: Cedam, 1930.
- ASCENÇÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
- ATTARDI, Aldo. Le ordinanze di condanna nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado secondo la legge di riforma. *Giurisprudenza italiana*, 1992.
- AYALA, Patryck; MORATO LEITE, José Rubens. *Direito ambiental na sociedade de risco*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.
- BAILEY, Richard. Overcoming veriphobia – learning to love truth again. *British Journal of Educational Studies*. vol. 49. n. 2. Oxford: Blackwell Publishers, jun. 2001.
- BAPTISTA, Francisco de Paula. *Teoria e prática do processo civil e comercial*. São Paulo: Saraiva, 1988.

- BARASSI, Lodovico. *La teoria generale delle obbligazioni*. Milano: Giuffrè, 1964.
- BARBI, Celso Agrícola. *Ação declaratória principal e incidente*. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996.
- _____. *Do mandado de segurança*. Rio de Janeiro: Forense, 1966.
- _____. _____. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993.
- BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *Abuso dos direitos processuais*. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
- _____. A Constituição e as provas ilicitamente adquiridas. *Ajuris*. vol. 68.
- _____. A Constituição e as provas ilicitamente obtidas. In: _____. *Temas de direito processual*. Sexta série. São Paulo: Saraiva, 1997.
- _____. A função social do processo civil moderno e o papel do juiz e das partes na direção e na instrução do processo. *RePro*. n. 37. São Paulo: Ed. RT, 1985.
- _____. A garantia do contraditório na atividade de instrução. *RePro*. n. 35. São Paulo: Ed. RT, 1984.
- _____. A justiça e nós. In: _____. *Temas de direito processual*. Sexta série. São Paulo: Saraiva, 1997.
- _____. Alguns problemas atuais da prova civil. In: _____. *Temas de direito processual*. Quarta série. São Paulo: Saraiva, 1989.
- _____. Antecipação da tutela: algumas questões controvertidas. In: _____. *Temas de direito processual*. Oitava série. São Paulo: Saraiva, 2004.
- _____. As presunções e a prova. In: _____. *Temas de direito processual*. Primeira série. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988.
- _____. Dimensiones sociales del proceso civil. *RePro*. n. 45. São Paulo: Ed. RT, 1987.
- _____. Notas sobre o problema da “efetividade” do processo. In: _____. *Temas de direito processual*. Terceira série. São Paulo: Saraiva, 1984.
- _____. *O novo processo civil brasileiro*. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995.
- _____. _____. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
- _____. Os poderes do juiz. In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). *O processo civil contemporâneo*. Curitiba: Juruá, 1994.
- _____. Os poderes do juiz na direção e na instrução do processo. In: _____. *Temas de direito processual*. Quarta série. São Paulo: Saraiva, 1989.
- _____. Privatização do processo? In: _____. *Temas de direito processual*. Sétima Série. São Paulo: Saraiva, 2001.
- _____. Problemas de la intermediación en el proceso civil. In: _____. *Temas de direito processual*. Terceira série. São Paulo: Saraiva, 1984.
- _____. O neoprivatismo no processo civil. In: _____. *Temas de direito processual*. Nona Série. São Paulo: Saraiva, 2007.
- _____. Regras de experiência e conceitos juridicamente indeterminados. *Revista Forense*. vol. 261. Rio de Janeiro: Forense, 1978.
- _____. Sobre a multiplicidade de perspectivas no estudo do processo. *Revista Brasileira de Direito*

Processual. vol. 56. Rio de Janeiro: Forense.

_____. Sobre a “participação” do juiz no processo civil. In: GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo. *Participação e processo*. São Paulo: Ed. RT, 1988.

_____. Sobre prazos peremptórios e dilatórios. In: _____. *Temas de direito processual civil*. Segunda série. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988.

_____. Tutela sancionatória e tutela preventiva. In: _____. *Temas de direito processual*. Segunda série. São Paulo: Saraiva, 1980.

BARROS, Suzana de Toledo. *O princípio da proporcionalidade e o controle da constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais*. Brasília: Brasília Jurídica, 1996.

BARROSO, Luis Roberto. *Interpretação e aplicação da Constituição*. São Paulo: Saraiva, 1996.

_____. *O direito constitucional e a efetividade de suas normas*. Rio de Janeiro: Renovar, 1993.

BAUR, Fritz. Les garanties fondamentales des parties dans le procès civil en république fédérale d'Allemagne. In: CAPELLETTI, Mauro; TALLON, Denis. *Fundamental guarantees of the parties in civil litigation*. Milano: Giuffrè, 1973.

_____. *Tutela jurídica mediante medidas cautelares*. Porto Alegre: Fabris, 1985.

BECKER, Laércio Alexandre. *Contratos Bancários*. São Paulo: Malheiros, 2002.

_____. Sobre a incerteza e o conteúdo ético do processo civil. *Qual é o jogo do processo?* Porto Alegre: Fabris, 2012.

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. *Poderes instrutórios do juiz*. São Paulo: Ed. RT, 1991.

_____. *Poderes instrutórios do juiz*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1994.

BEGHINI, Roberto. *La prova per testimoni nel rito civile*. Padova: Cedam, 1997.

BELTRAN, Jordi Ferrer. *Prueba y verdad en el Derecho*. Madrid: Marcial Pons, 2005.

BENDITT, Theodore. M. The rule of precedent. *Precedent in Law*. Oxford: Clarendon Press, 1987.

BENETI, Sidnei Agostinho. A estenotipia no Judiciário. *Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo*. vol. 76.

BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconsellos et alli. *Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991.

BENUCCI, Eduardo Bonasi. Atto illecito e concorrenza sleale. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Milano: Giuffrè, 1957.

BENTHAM, Jeremy. *Rationale of judicial evidence*. London: Hunt & Clarke, 1827.

BERMUDES, Sérgio. *Direito processual civil – Estudos e pareceres*. Segunda série. São Paulo: Saraiva, 1994.

BEVILÁQUA, Clóvis. *Código Civil dos Estados Unidos do Brasil*. 5. tir. Rio de Janeiro: Rio, 1955.

_____. *Theoria geral do direito civil*. 6. ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1953.

BIDART, Adolfo Gelsi. Tutela procesal “diferenciada”. *RePro*. n. 44. São Paulo: Ed. RT, 1986.

BOBBIO, Norberto. *Teoria della scienza giuridica*. Torino: Giappichelli, 1950.

- BONAVIDES, Paulo. *Curso de direito constitucional*. São Paulo: Malheiros, 1993.
- BONNIER, Eduardo. *Tratado de las pruebas en derecho civil*. 5. ed. Trad. José Vicente y Caravantes. Madrid: Reus, 1929. vol. 2.
- BORGES, João Eunápio. *Curso de direito comercial terrestre*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, [s.d.]
- BORGHESI, Domenico. L'anticipazione dell'esecuzione forzata nella riforma del processo civile. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Milano: Giuffrè, 1991.
- BUECHELE, Paulo Arminio Tavares. *O princípio da proporcionalidade e a interpretação da Constituição*. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
- BRAKELAND, Jean-François; ANTOINE, Mireille; ELOY, Marc. *Le droit de la preuve face aux nouvelles technologies de l'information*. Namur: E.Story-Scientia, 1992 (Cahiers du Centre de Recherches – Informatique et Droit, n. 7).
- BRITO, Wanda Ferraz de; SOARES, Fernando Luso; MESQUITA, Duarte Romeira. *Código de Processo Civil atualizado e anotado*. Coimbra: Almedina, 1994.
- BUZAID, Alfredo. *Do mandado de segurança*. São Paulo: Saraiva, 1989. vol. 1.
- _____. Do ônus da prova. *Revista de Direito Processual Civil*. vol. 4. São Paulo: Saraiva.
- CABRAL, Antonio do Passo. *Convenções processuais*. Tese apresentada como requisito para a obtenção do grau de Livre-Docência em Direito, São Paulo, 2015. Posteriormente convertida em livro (*Convenções processuais*. Salvador: JusPodivm, 2016).
- _____. Despolarização do processo e zonas de interesse: sobre a migração entre os polos da demanda. *Revista forense*. n. 404. Rio de Janeiro: Forense, 2009.
- _____. A duração razoável do processo e a gestão do tempo no Projeto de Novo Código de Processo Civil. *Novas tendências do processo civil*. Salvador: JusPodivm, 2014. vol. II.
- _____. NOGUEIRA, Pedro H. (coord.). *Negócios processuais*. Salvador: JusPodivm, 2017.
- CADIET, Loic; NORMAND, Jacques; MEKKI, Soraya Amrani. *Théorie générale du procès*. Paris: PUF, 2010.
- _____. Les conventions relatives au procès en droit française. Sur la contractualisation du règlement des litiges. *Accordi di parte e processo*. Milano: Giuffrè, 2008. Também disponível em versão portuguesa (*Perspectivas sobre o sistema da justiça civil francesa*. São Paulo: Ed. RT, 2017).
- CAHALI, Francisco. *Curso de arbitragem*. São Paulo: Ed. RT, 2018.
- CALAMANDREI, Piero. Conseguenze della mancata esibizione di documenti in giudizio. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1930.
- _____. *Eles, os juízes, vistos por um advogado*. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- _____. Verità e verosimiglianza nel processo civile. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1955.
- CALMON DE PASSOS, José Joaquim. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, [s.d.]. vol. 3.
- _____. _____. Rio de Janeiro: Forense, 1983. vol. 3.
- _____. _____. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. vol. 3.

- _____. Confissão (Direito Processual Civil – 1). *Enciclopédia Saraiva do Direito*. vol. 18.
- _____. *Inovações no Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1995.
- CAMBI, Eduardo. *Direito constitucional à prova*. Dissertação de mestrado, orientação Prof. Luiz Guilherme Marinoni, Curitiba, Universidade Federal do Paraná, 1999.
- _____. *Prova civil*. São Paulo: Ed. RT, 2006.
- CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito constitucional*. Coimbra: Almedina, 1986.
- _____. *Direito constitucional e teoria da constituição*. 6. ed. Lisboa: Almedina, 2002.
- CAPONI, Remo. Autonomia privata e processo civile: gli accordi processuali. *Accordi di parte e processo*. Milano: Giuffrè, 2008.
- _____; PROTO PISANI, Andrea. *Lineamenti di diritto processuale civile*. Napoli: Jovene, 2001.
- CAPPELLETTI, Mauro. Acesso alla giustizia come programma di riforma e come metodo di pensiero. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1982.
- _____. Appunti in tema di contraddittorio. In: PUNZI, Carmine (coord.). *Studi in memoria di Salvatore Satta*. Padova: Cedam, 1982. vol. 1.
- _____. Fundamental guarantees of the parties in civil proceedings – General report. In: CAPPELLETTI, Mauro; TALLON, Denis (coords.). *Fundamental guarantees of the parties in civil litigation*. Milano: Giuffrè, 1973.
- _____. *Juizes legisladores?* Trad. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Porto Alegre: Fabris, 1993.
- _____. Las garantías constitucionales de las partes en el proceso civil italiano. In: CAPPELLETTI, Mauro. *Proceso, ideologías, sociedad*. Trad. Santiago Sentís Melendo e Tomás A. Banzhaf. Buenos Aires: Ejea, 1974.
- _____. La “natura” delle norme sulle prove. *Rivista di Diritto Processuale Civile – 2. Série*. vol. 24. Padova: Cedam, 1969.
- _____. *La oralidad e las pruebas en el proceso civil*. Trad. Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: Ejea, 1972.
- _____. *La testimonianza della parte nel sistema dell’oralità*. Milano: Giuffrè, 1962. vol. 1.
- _____. Problemas de reforma do processo civil nas sociedades contemporâneas. In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). *O processo civil contemporâneo*. Curitiba: Juruá, 1994.
- _____; TALLON, Denis (coord.). *Fundamental guarantees of the parties in civil litigation*. Milano: Giuffrè, 1973.
- CARDOZO, Benjamin Nathan. *The nature of the judicial process*. New Haven: Yale University Press, 1991.
- CARNEIRO, Athos Gusmão. Anotações sobre o recurso especial. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). *Recursos no Superior Tribunal de Justiça*. São Paulo: Saraiva, 1991.
- _____. A nova sistemática da prova pericial. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). *Reforma do Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 1996.
- _____. *Intervenção de terceiros*. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1998.
- CARNELUTTI, Francesco. *Diritto e processo*. Napoli: Morano, 1958.

- _____. Documento e negozio giuridico. *Rivista di Diritto Processuale Civile*. vol. 3. Padova: Cedam, 1926.
- _____. Documento e testimonianza. In: _____. *Studi di diritto processuale*. Padova: Cedam, 1939. vol. 3.
- _____. Documento (teoria moderna). *Novissimo digesto italiano*. Torino: Utet, 1960. t. VI.
- _____. *Instituições do processo civil*. Trad. Adrián Sotero de Witt Batista. Campinas: Servanda, 1999. vol. 1.
- _____. *La prova civile*. 2. ed. Roma: Ateneo, 1947.
- _____. _____. Milano: Giuffrè, 1992.
- _____. Le testimoni, questo sconosciuto. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1957.
- _____. *Lezioni di diritto processuale civile*. Padova: Cedam, 1986. vol. 2.
- _____. _____. Padova: Cedam, 1986. vol. 3.
- _____. Note sull'accertamento negoziale. *Rivista di Diritto Processuale Civile*. v. 17. Padova: Cedam, 1940.
- _____. *Sistema de derecho procesal civil*. Trad. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo e Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: Uteha, 1944. t. II.
- _____. *Sistema di diritto processuale civile*. Padova: Cedam, 1936.
- _____. Studi sulla sottoscrizione. In: _____. *Studi di diritto processuale*. Padova: Cedam, 1939. vol. 3.
- _____. *Teoria del falso*. Padova: Cedam, 1935.
- _____. *Teoria general del derecho*. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1955.
- _____. *Teoria geral do direito*. Trad. Antônio Carlos Ferreira. São Paulo: Lejus, 1999.
- _____. Verità, dubbio, certezza. *Rivista di Diritto Processuale* – 2. série. vol. 20. Padova: Cedam, 1965.
- CARPI, Federico. Flashes sulla tutela giurisdizionale differenziata. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Milano: Giuffrè, 1980.
- ____ (coord.). Accordi di parte e processo. *Quaderni della Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, Milano: Giuffrè, 2008.
- CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Tutela específica e tutela assecuratória das obrigações de fazer e não fazer na reforma processual. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). *Reforma do Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 1996.
- CARRERAS DEL RINCÓN, Jorge. *Comentarios a la doctrina procesal civil del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo*. Madrid: Marcial Pons, 2002.
- CARRIÓ, Genaro R. *Notas sobre derecho y lenguaje*. 4. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1990.
- CASTRO FILHO, José Olympio de. *Abuso do direito no processo civil*. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1955.
- CAVALLARI, Ciaccia. *La contestazione nel processo civile*. Milano: Giuffrè, 1993. vol. 2.

- CAVALLONE, Bruno. *I poteri di iniziativa istruttoria del giudice civile*. Milano: Giuffrè, 1968.
- _____. In difesa della veriphobia (considerazioni amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo. *Rivista di diritto processuale*. n. 1. Padova: Cedam, jan-fev. 2010.
- CECHELLA, Claudio. *Il processo civile dopo le riforme*. Torino: Giappichelli, 1992.
- CENTI, Jean Pierre. Le prix de l'environnement – Une approche par l'analyse économique du droit. In: FALQUE, M.; MASSENET, M. (coord.). *Droits de propriété et environnement*. Paris: Dalloz, 1997.
- CHASE, Oscar. *Law, culture, and ritual – disputing systems in cross-cultural context*. New York: New York University Press, 2005.
- CHAVES, Antônio. Os direitos fundamentais da personalidade moral (à integridade psíquica, à segurança, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade). *Revista de Informação Legislativa*. n. 58. Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, 1978.
- CHIASSONI, Pierluigi. *Tecnica dell'interpretazione giuridica*. Bologna: Il Mulino, 2007.
- CHIAVARO, Mario. *Processo e garanzie della persona*. Milão: Giuffrè, 1982. vol. 2.
- CHIOVENDA, Giuseppe. Dell'azione nascente dal contratto preliminare. *Rivista del Diritto Commerciale*. vol. 9.
- _____. *Instituições de direito processual civil*. São Paulo: Saraiva, 1965. vol. 1.
- _____. _____. Campinas: Bookseller, 1998. vols. 1, 2 e 3.
- _____. La natura processuale delle norme sulla prova e l'efficacia della legge processuale nel tempo. In: _____. *Saggi di diritto processuale civile*. Milano: Giuffrè, 1993. vol. 1.
- _____. *Principios de derecho procesal civil*. Trad. José Casais y Santaló. Madrid: Reus, 1922. t. I.
- _____. _____. Trad. José Casais y Santaló. Madrid: Reus, 1925. t. II.
- _____. *Istituzioni di diritto processuale*. Napoli: Jovene, 1933. v. 1.
- _____. Sulla cosa giudicata. *Saggi di diritto processuale civile*. Milano: Giuffrè, 1993. v. 2.
- _____. Cosa giudicata e preclusione. *Saggi di diritto processuale civile*. Milano: Giuffrè, 1993. v. 3.
- CINTRA, Antônio Carlos Araújo. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. vol. 4.
- _____. Prova do direito estrangeiro. *Revista dos Tribunais*. vol. 485. São Paulo: Ed. RT, 1976.
- _____; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. *Teoria geral do processo*. 9. ed. 2. tir. São Paulo: Malheiros, 1993.
- COELHO, Fábio Ulhoa. *Manual de direito comercial*. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
- COLLIA, Filippo. L'ordinanza per il pagamento di somme non contestate nel processo del lavoro. *Rivista di Diritto Processuale*. 1994.
- COMOGLIO, Luigi Paolo; FERRI, Corrado; TARUFFO, Michele. *Lezioni sul processo civile*. 2. ed. Bologna: Il Mulino, 1998.
- CONSTANTINO, Giorgio. Il nuovo processo commerciale: la tutela cautelare. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 2003.

- CORSALE, Massimo. *Certeza del diritto e crisi di legittimità*. Milano: Giuffrè, 1979.
- COSTA, Newton C. A. da. *Conjectura e quase-verdade*. In: LAFER, Celso; FERRAZ JR., Tercio Sampaio (coord.). *Direito, política, filosofia, poesia: estudos em homenagem ao Professor Miguel Reale, em seu octogésimo aniversário*. São Paulo: Saraiva, 1992.
- COTTA, Sérgio. *Quidquid latet apparebit: le problème de la vérité du jugement*. *Archives de philosophie du droit*. Paris: Dalloz, 1995. t. XXXIX.
- COUTURE, Eduardo J. El concepto de fé pública. In: _____. *Estudios de derecho procesal civil*. Buenos Aires: Ediar, 1949. t. II.
- _____. *Fundamentos del derecho procesal civil*. 3. ed. Buenos Aires: Depalma, 1958.
- COVELLO, Sérgio Carlos. O sigilo bancário como proteção à intimidade. *Revista dos Tribunais*. vol. 648. São Paulo: Ed. RT, 1989.
- CRESCI SOBRINHO, Elício de. O juiz e as máximas de experiência. *Revista Forense*. vol. 296. Rio de Janeiro: Forense.
- CROZE, Hervé; MOREL, Christian. *Procédure civile*. Paris: PUF, 1988.
- Cruz e TUCCI, José Rogério. *A causa petendi no processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 1993.
- _____. *Lineamentos da nova reforma do CPC*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2002.
- CUNHA, Alcides Munhoz da. *A lide cautelar no processo civil*. Curitiba: Juruá, 1992.
- DALLAGNOL, Deltan Martinazzo. *As lógicas das provas no processo*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
- DALL'AGNOL JÚNIOR, Antonio. Distribuição dinâmica do ônus probatório. *Revista Jurídica*. vol. 280.
- _____. Os poderes do juiz. In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). *O processo civil contemporâneo*. Curitiba: Juruá, 1994.
- DAMASKA, Mirjan R. *The faces of justice and state authority*. New Haven: Yale University Press, 1986.
- DAVIS, Kevin E.; HERSHKOFF, Helen. Contracting for procedure. *William and Mary Law Review*, 2011.
- DE PLÁCIDO E SILVA. *Noções práticas de direito comercial*. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1965. vol. 2.
- DENARI, Zelmo et alli. *Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991.
- DENTI, Vittorio. Diritti della persona e tecniche di tutela. In: ALPA, G.; BESSONE, M.; BONESCH, L.; CAIAZZA, G. (orgs.). *L'informazione e i diritti della persona*. Napoli: Jovene, 1983.
- _____. *Il nuovo processo del lavoro*. Milano: Giuffrè, 1974.
- _____. *La giustizia civile*. Bologna: Il Mulino, 1989.
- _____. La natura giuridica delle norme sulle prove civile. *Rivista di Diritto Processuale* – 2. série. vol. 24. Padova: Cedam, 1969.
- _____. Prova documentale (dir. proc. civ.). *Enciclopedia del diritto*. Milano: Giuffrè, 1988. vol. 37.

- _____. Querela di falso. *Novissimo digesto italiano*. Torino: Utet, 1967. t. XIV.
- DESCARTES, René. *Discours de la méthode*. Paris: GF-Flammarion, 1992.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito administrativo*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1993.
- DIAS, José Eduardo de Figueiredo. *Tutela ambiental e contencioso administrativo* (da legitimidade processual e das suas consequências). Coimbra: Coimbra Editora, 1997.
- DIAS, Luciana. *Decisão, motivação da sentença e discurso*. Tese de doutorado, Curitiba, UFPR, 2004.
- DIDIER JR., Fredie Souza. Depoimento pessoal de pessoas jurídicas de direito público. *Revista Jurídica dos Formandos em Direito da UFBA*. vol. 1.
- _____. *Regras processuais no novo Código Civil*. São Paulo: Saraiva, 2004.
- DINAMARCO, Cândido Rangel. *A instrumentalidade do processo*. São Paulo: Ed. RT, 1987.
- _____. _____. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 1996.
- _____. *A reforma do Código de Processo Civil*. São Paulo: Malheiros, 1996.
- _____. *Litisconsórcio*. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1994.
- _____. Relativizar a coisa julgada. *Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo*. n. 55/56. São Paulo: Imprensa Oficial, jan./dez. 2001.
- _____; GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antônio Carlos Araújo. *Teoria geral do processo*. 9. ed. 2. tir. São Paulo: Malheiros, 1993.
- DODGE, Jaime. The limits of procedural private ordering. *Virginia Law Review*, v. 97, 2011.
- DONDI, Angelo. *Effettività dei provvedimenti istruttori del giudice civile*. Padova: Cedam, 1985.
- _____. Problemi di utilizzazione delle “conoscenze esperte” come “expert witness testimony” nell’ordinamento statunitense. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Milano: Giuffrè, 2001.
- DWORKIN, Ronald. *Taking rights seriously*. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
- ECHANDIA, Hernando Devis. *Teoria general de la prueba judicial*. Buenos Aires: Zavalia, 1976.
- _____. *Teoria general de la prueba judicial*. Buenos Aires: Fidenter, 1981.
- EISLER, Rudolf. *Wörterbuch der philosophischen Begriffe*. 4. ed. Berlin, 1930. vol. 3.
- EKELÖF, Per Olof. *Beweiswürdigung*. Beweislast und Beweis des ersten Anscheins. ZZZP. N. 75. 1962.
- ELOY, Marc; ANTOINE, Mireille; BRAKELAND, Jean-François. *Le droit de la preuve face aux nouvelles technologies de l’information*. Namur: E.Story-Scientia, 1992 (Cahiers du Centre de Recherches – Informatique et Droit, n. 7).
- ENGISCH, Karl. *Introdução ao pensamento jurídico*. Trad. João Baptista Machado. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1977.
- ESPÍNOLA, Eduardo. *Sistema do direito civil*. Rio de Janeiro: Rio, 1977.
- EWING, Sally. Formal justice and the spirit of capitalism: Max Weber’s sociology of law. *Law and Society Review*, n. 21.

- FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. vol. 8, t. III.
- FADEL, Sérgio Sahione. *Código de Processo Civil comentado*. Rio de Janeiro: Konfino, 1974. t. II.
- FAGUNDES, Miguel Seabra. *O controle dos atos administrativos pelo poder judiciário*. São Paulo: Saraiva, 1984.
- FARIA, Guilherme H. Lage. *Negócios processuais no modelo constitucional de processo*. Salvador: JusPodivm, 2016.
- FAVARETTO, Isolde. *Comportamento processual das partes como meio de prova*. Porto Alegre: Livraria Acadêmica, 1993.
- FERNANDES NETO, Guilherme. O abuso de direito no Projeto 634-B. *Revista de Informação Legislativa*. n. 106.
- FERRAJOLI, Luigi. *Principia Iuris – Teoria del Diritto e della Democrazia*. Roma: Laterza, 2007. v. 1.
- FERRARA, Francesco. *Trattato di diritto civile italiano*. Roma: Athenaeum, 1921.
- FERRAZ, Sérgio. *Mandado de segurança*. São Paulo: Malheiros, 1992.
- FERREIRA FILHO, Manoel C. *A preclusão no direito processual civil*. Curitiba: Juruá, 1991.
- FERRI, Corrado; TARUFFO, Michele; COMOGLIO, Luigi Paolo. *Lezioni sul processo civile*. 2. ed. Bologna: Il Mulino, 1998.
- FILOMENO, José Geraldo Brito et alli. *Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991.
- FINK, Daniel Roberto et alli. _____. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991.
- FORNACIARI JÚNIOR, Clito. *Reconhecimento jurídico do pedido*. São Paulo: Ed. RT, 1977.
- FOUCAULT, Michel. *A verdade e as formas jurídicas*. Trad. Roberto Cabral de Melo Machado e Eduardo Jardim Morais. Rio de Janeiro: Nau, 1996.
- FRANCESCHELLI, Remo. Studi sulla concorrenza sleale. La fattispecie. *Rivista di Diritto Industriale*. Milano: Giuffrè, 1963.
- FRANCO, Mariulza. É admissível a ação incidental de declaração de falsidade de documento no processo cautelar? *RePro*. n. 50. São Paulo: Ed. RT, 1988.
- FREITAS, Juarez. *Estudos de direito administrativo*. São Paulo: Malheiros, 1995.
- FRIGNANI, Aldo. L'azione inibitoria contro le clausole vessatorie (considerazioni “fuori dal coro” di un civilista). *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1997.
- _____. *L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano*. Milano: Giuffrè, 1974.
- FURNO, Carlo. *Contributo alla teoria della prova legale*. Padova: Cedam, 1940.
- _____. *Teoría de la prueba legal*. Trad. S. González Collado. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1954.
- GADAMER, Hans-Georg. *Verdade e método – Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica*. Trad. Flávio Paulo Meurer. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1998.
- GAJARDONI, Fernando da Fonseca. *Flexibilização procedimental*. São Paulo: Atlas, 2008.

- GÁLVEZ, Juan Monroy. *Introduccion al proceso civil*. Bogotá: Temis-De Belaunde & Monroy, 1996. t. I.
- GARBAGNATI, Edoardo. *Il procedimento d'ingiunzione*. Milano: Giuffrè, 1991.
- GENTILE, Francesco Silvio. *La prova civile*. Roma: Jandi Sapi Editori, 1960.
- GIANESINI, Rita. *Da revelia no processo civil brasileiro*. São Paulo: Ed. RT, 1977.
- GIDI, Antonio. *Coisa julgada e litispendência em ações coletivas*. São Paulo: Saraiva, 1995.
- GIULIANI, Alessandro. *Il concetto di prova* (contributo alla logica giuridica). Milano: Giuffrè, 1971.
- _____. Prova (filosofia del diritto). *Enciclopedia del diritto*. Milano: Giuffrè, 1988. vol. 37.
- GODINHO, Robson. Negócios processuais sobre o ônus da prova no novo Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- _____. A possibilidade de negócios jurídicos processuais atípicos em matéria probatória. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro H. (coord.). *Negócios processuais*. Salvador: JusPodivm, 2017.
- GOLDMAN, Alvin I. *Knowledge in a social world*. Oxford: Clarendon Press, 1999.
- GOLDSCHMIDT, James. *Derecho procesal civil*. Trad. e notas Leonardo Pietro Castro. Barcelona: Labor, 1936.
- GOLDSCHMIDT, Roberto. L'azione preventiva. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1959.
- GOMES, Orlando. Direitos de personalidade. *Revista Forense*. vol. 216. Rio de Janeiro: Forense, 1966.
- _____. *Introdução ao direito civil*. 12. ed. atual. Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 1996.
- GOMES FILHO, Antonio Magalhães. *Presunção de inocência e prisão cautelar*. São Paulo: Saraiva, 1991.
- GONÇALVES, Carlos Roberto. Análise da Lei de Introdução ao Código Civil: sua função no ordenamento jurídico e, em especial, no processo civil. *RePro*. n. 37. São Paulo: Ed. RT, 1985.
- GONÇALVES, Luiz da Cunha. *Princípios de direito civil luso-brasileiro*. São Paulo: Max Limonad, 1951. vol. 1.
- _____. *Tratado de direito civil, em comentário ao Código Civil português*. 2. ed. portuguesa e 1. ed. brasileira. São Paulo: Max Limonad, 1956. vol. 1., t. II.
- GOODHART, Arthur. Precedent in English and Continental Law. *Law Quaterly Review*, v. 50, 1934.
- GOTTWALD, Peter; ROSENBERG, Leo; SCHWAB, Karl Heinz. *Zivilproßrecht*. 15. ed. München: Verlag C.H. Beck, 1993.
- GRECO FILHO, Vicente. *Interceptação telefônica – Considerações sobre a Lei 9.296, de 24 de julho de 1996*. São Paulo: Saraiva, 1996.
- GRINOVER, Ada Pellegrini. *Aspectos constitucionais dos juizados de pequenas causas*. São Paulo: Ed. RT, 1985.

_____. A tutela preventiva das liberdades: *habeas corpus* e mandado de segurança. *RePro*. n. 22. São Paulo: Ed. RT, 1981.

_____. *Liberdades públicas e processo penal*. São Paulo: Saraiva, 1976.

_____; CINTRA, Antônio Carlos Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel. *Teoria geral do processo*. 9. ed. 2. tir. São Paulo: Malheiros, 1993.

____ et alli. *Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991.

GROSSEN, Jacques Michel. L'azione in prevenzione al di fuori dei giudizi immobiliari. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1959.

GUASP, Jaime. *Derecho procesal civil*. Madrid: Civitas, 1998. t. I.

GUASTINI, Riccardo. *Interpretare e argomentare*. Milano: Giuffrè, 2011.

GUSMÃO, Paulo Dourado de. Pressupostos filosóficos da noção do abuso de direito. *Revista Forense*. vol. 120. Rio de Janeiro: Forense, 1948.

HABERMAS, Jürgen. *Direito e democracia, entre facticidade e validade*. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. vol. 1.

_____. *Teoría de la acción comunicativa*. Madrid: Taurus, 1988. t. I.

HABSCHEID, Walther J. *Droit judiciaire privé suisse*. 2. ed. Genève: Librairie de L'Université – Georg & Cie. S.A., 1981.

HART, H. L. A. *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1993.

HAZARD JR., Geoffrey C.; JAMES JR., Fleming; LEUBSDORF, John. *Civil procedure*. 4. ed. Boston: Little, Brown and Company, 1992.

_____; TARUFFO, Michele. *American civil procedure – An introduction*. New Haven: Yale University Press, 1993.

HOYOS, Arturo. La garantía constitucional del debido proceso legal. *RePro*. n. 47. São Paulo: Ed. RT, 1987.

HUNGRIA, Nelson. *Comentários ao Código Penal*. Rio de Janeiro: Forense, 1959. vol. 9.

JACOB, Jack. *The fabric of english civil justice*. London: Stevens, 1987.

JAMES JR., Fleming; LEUBSDORF, John; HAZARD JR., Geoffrey C. *Civil procedure*. 4. ed. Boston: Little, Brown and Company, 1992.

KAPLOW, Louis. An economic analysis of legal transitions. *Harvard Law Review*, n. 99, 1986.

KARAM, Munir. Ônus da prova. *RePro*. n. 17. São Paulo: Ed. RT, 1980.

KAYSER, Pierre. Les droits de la personnalité – Aspects théoriques et pratiques. *Revue Trimestrielle de Droit Civil*. n. 3. Paris : Sirey.

LA CHINA, Sergio. *Diritto processuale civile, le disposizioni generali*. Milano: Giuffrè, 1991.

_____. Esibizione documentale. *Enciclopedia del diritto*. Milano: Giuffrè, 1988. vol. 15.

LARENZ, Karl. *Metodologia da ciência do direito*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989.

LASPRO, Oreste Nestor de Souza. *Duplo grau de jurisdição no direito processual civil*. São Paulo:

Ed. RT, 1995.

LEE, Thomas R. *Stare decisis* in economic perspective: an economic analysis of the Supreme Court's doctrine of precedent. *North Carolina Law Review*, n. 78, 2000.

LENT, Friedrich. *Diritto processuale civile tedesco*. Napoli: Morano, 1962.

LEONARDO, Rodrigo Xavier. O conceito de prova e a noção de objeto de prova: considerações a respeito dos juízos de fato no processo civil. *Revista de Direito Processual Civil*. vol. 14. Gênese.

LESSONA, Carlos. *Teoría general de la prueba en derecho civil*. 3. ed. Madrid: Reus, 1928. vol. 1.

_____. _____. 3. ed. Madrid: Reus, 1929. vol. 2.

_____. _____. 3. ed. Madrid: Reus, 1930. vol. 3.

LÉVY-BRUHL, Henri. *La preuve judiciaire, étude de sociologie juridique*. Paris: Librairie Marcel Rivière et Cie., 1964.

LEUBSDORF, John; HAZARD JR., Geoffrey C.; JAMES JR., Fleming. *Civil procedure*. 4. ed. Boston: Little, Brown and Company, 1992.

LIEBMAN, Enrico Tullio. *Eficácia e autoridade da sentença*. Trad. Alfredo Buzaid e Benvindo Aires. Rio de Janeiro: Forense, 1945.

_____. *Manual de direito processual civil*. Trad. Cândido R. Dinamarco. Rio de Janeiro: Forense, 1984. t. I.

_____. *Manuale di diritto processuale civile – Principi*. 5. ed. Milano: Giuffrè, 1992. t. I.

_____. Questioni vecchie e nuove in tema di qualificazione delle norme sulle prova. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1969. vol. 24.

LIPARI, F. G. Sulla indivisibilità della confessione. *Rivista di Diritto Processuale Civile*. Padova: La Litotipo, 1925. vol. 2.

LOPES, João Batista. *A prova no direito processual civil*. São Paulo: Ed. RT, 2000.

_____. O depoimento pessoal e o interrogatório livre no processo civil brasileiro e estrangeiro. *RePro*. n. 13. São Paulo: Ed. RT, 1979.

LORENZETTI, Ricardo Luis. Nuevas fronteras del abuso de derecho (Situaciones jurídicas lesivas de libertades. Tutela del mercado y amparo). *Revista dos Tribunais*. vol. 723. São Paulo: Ed. RT, 1996.

LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Poderes instrutórios do juiz e negócio jurídico processual. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coords.). *Comentários ao novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

LUDWIG, Celso Luiz. *A alternatividade jurídica na perspectiva da libertação: uma leitura a partir da filosofia de Enrique Dussel*. Dissertação de mestrado, Curitiba, Universidade Federal do Paraná, 1993.

MACCORMICK, Neil. The ethics of legalism. *Ratio Juris*, 1989, 2.

_____. *Rethoric and the rule of law – A theory of legal reasoning*, New York: Oxford University Press, 2005.

MALTZ, Earl. The nature of precedent. *North Carolina Law Review*, v. 66, 1988.

- MANDRIOLI, Crisanto. *Corso di diritto processuale*. Torino: Giappichelli, 1991. vol. 3.
- MARCHEIS, C. B. Probabilità e prova: considerazioni sulla struttura del giudizio di fatto. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. 1991.
- MARCUS, Richard; REDISH, Martin; SHERMAN, Edward; PFANDER, James. *Civil Procedure – A modern approach*. St. Paul: West, 2013.
- MARINONI, Luiz Guilherme. *A antecipação da tutela*. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.
- _____. *Coisa julgada sobre questão*. São Paulo: Ed. RT, 2018.
- _____. Culture and Predictability of the Law. *International Journal of Procedural Law*, v. 6, 2016.
- _____. *Cultura y Previsibilidad del Derecho – la Justificación de um sistema de precedentes en clave histórica moderna*. México: Editorial Porrúa, 2016.
- _____. *Efetividade do processo e tutela de urgência*. Porto Alegre: Fabris, 1994.
- _____. *El derecho de acción como derecho fundamental*. Bogotá: Temis, 2015.
- _____. *Il diritto di azione come diritto fondamentale*. Torino: Giappichelli, 2016.
- _____. Il diritto di azione come garanzie fondamentale nella Costituzione Brasiliana. *Rivista di Diritto Processuale*, 2008.
- _____. La prueba en la acción inhibitoria. *La prueba* (Homenage al maestro Hernando Devis Echandía). Bogotá: Universidad Libre, 2002.
- _____. *Novas linhas do processo civil*. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
- _____. *O STJ enquanto Corte de precedentes*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2017.
- _____. *Precedentes obrigatórios*. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2017.
- _____. *Precedentes obligatorios*. Lima: Palestra, 2013.
- _____. *Questões do novo direito processual civil brasileiro*. Curitiba: Juruá, 1999.
- _____. *Técnica processual e tutela dos direitos*. São Paulo: Ed. RT, 2004.
- _____. *Tutela antecipatória e julgamento antecipado*. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2003.
- _____. *Tutela cautelar e tutela antecipatória*. São Paulo: Ed. RT, 2002.
- _____. *Tutela específica*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2001.
- _____. *Tutela inibitória*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2003.
- _____. Simulação e prova. *Revista de Direito Processual Civil*. vol. 22. Gêneseis.
- _____; ARENHART, Sérgio Cruz. *Manual do processo de conhecimento*. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2005.
- _____; _____. *Prueba*, Santiago: Thomson Reuters, 2015.
- _____; _____. MITIDIERO, Daniel. *Curso de processo civil – Teoria do Processo Civil*. 3. ed, São Paulo: Ed. RT, 2017. v. 1.

- ____; BECKER, Laercio A. A influência das relações pessoais sobre a advocacia e o processo civil. *Trabalho apresentado no XX World Congress of Procedural Law*, 2003.
- MARQUES, José Frederico. *Instituições de direito processual civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1962. vol. 3.
- ____. _____. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1972. vol. 3.
- ____. *Manual de direito processual civil*. São Paulo: Saraiva, 1974. vol. 2.
- ____. _____. São Paulo: Saraiva, 1975. vol. 3.
- ____. _____. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981. vol. 3.
- ____. _____. Atual. Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 1997. vol. 1 e 2.
- MARTINS, Petro A. Batista. Panorâmica sobre as provas na arbitragem. Disponível em: “batistamartins.com/wp-content/uploads/kalins-pdf/singles/panoramica-sobre-as-provas na arbitragem-2.pdf”. Acesso em 30/05/2018.
- MARZOCCHI, Paola. La prova testimoniale. *Rivista di Diritto Processuale*. 1977.
- MATTIROLO, Luigi. *Tratado de derecho judicial civil*. Madrid: Reus, 1933. vol. 2.
- ____. *Tratado de derecho judicial civil*. Madrid: Reus, 1934. vol. 3.
- MELENDO, Santiago Sentís. Naturaleza de la prueba – La prueba es libertad. *Revista dos Tribunais*. vol. 462. São Paulo: Ed. RT, 1974.
- MENDES, João de Castro. *Limites objetivos do caso julgado em processo civil*. Lisboa: Edições Ática, 1968.
- MERRYMAN, John Henry. *La tradición jurídica romano-canónica*. Trad. Eduardo L. Suárez. México: Fondo de Cultura Económica, 1998.
- MESQUITA, Duarte Romeira; BRITO, Wanda Ferraz de; SOARES, Fernando Luso. *Código de Processo Civil actualizado e anotado*. Coimbra: Almedina, 1994.
- MICHELI, Gian Antonio. L'azione preventiva. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1959.
- ____. *La carga de la prueba*. Trad. Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: Ejea, 1961.
- ____. *L'onere della prova*. Padova: Cedam, 1966.
- ____. Teoria geral da prova. *RePro*. n. 3. São Paulo: Ed. RT, 1976.
- ____; TARUFFO, Michele. A prova. *RePro*. n. 16. São Paulo: Ed. RT, 1979.
- MICHELMAN, Frank. Constitutional authorship. *Constitutionalism: philosophical foundations*. New York: Cambridge University Press, 1998.
- MILHOMENS, Jônatas. *A prova no processo*. Rio de Janeiro: Forense, 1982.
- MITIDIERO, Daniel F. *Colaboração no processo civil*. 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2011.
- ____. *Cortes Superiores e Cortes Supremas*. 3.ed. São Paulo: Ed. RT, 2018.
- ____. *Precedentes*. 3. ed. São Paulo: RT, 2018.
- MITTERMAIER, C. J. A. *Tratado da prova em matéria criminal*. 2. ed. Rio de Janeiro: Eduardo &

Henrique Laemmert, 1879.

MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994. vol. 2.

_____. *Exegese do Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Aide, 1984. vol. 4, t. I e II.

MONTELEONE, Girolamo. Spunti per una revisione del concetto di sentenza di condanna come titolo esecutivo. In: MAZZAMUTO, Salvatore (org.). *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*. Napoli: Jovene, 1989.

MONTESANO, Luigi. *Le tutele giurisdizionali dei diritti*. Bari: Cacucci, 1983.

_____. Sull'efficacia probatoria dell'atto pubblico convertito in scrittura privata. *Rivista di Diritto Processuale*. vol. 9. Padova: Cedam, 1954.

MORATO LEITE, José Rubens; AYALA, Patryck. *Direito ambiental na sociedade de risco*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.

MOREL, Christian; CROZE, Hervé. *Procédure civile*. Paris: PUF, 1988.

MOREL, René. *Traité élémentaire de procédure civile*. 2. ed. Paris: Recueil Sirey, 1949.

MORELLO, Augusto Mario. Las nuevas exigencias de tutela. *RePro*. n. 31. São Paulo: Ed. RT, 1983.

MORTARA, Lodovico. *Manuale della procedura civile*. 8. ed. Torino: Utet, 1916. vol. 1.

MOTA PINTO, Carlos Alberto. *Teoria geral do direito civil*. 3. ed. 11. reimp. Coimbra: Coimbra Editora, 1996.

MULLER, Julio Guilherme. *Negócios processuais e desjudicialização da produção da prova*. São Paulo: Ed. RT, 2017.

MUNIZ, Antonio Carlos. Do incidente de falsidade. *Revista dos Tribunais*. vol. 541. São Paulo: Ed. RT, 1980.

MUNÖZ, Luis Gálvez. *La ineficacia de la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales*. Navarra: Aranzadi, 2003.

NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR., Nelson. *Código de Processo Civil comentado*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 1997.

NERY JR., Nelson. *Princípios do processo civil na Constituição Federal*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1995.

_____. *Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 1996.

_____; NERY, Rosa Maria Andrade. *Código de Processo Civil comentado*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 1997.

____ et alli. *Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991.

NEVES E CASTRO, Francisco Augusto das; PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Theoria das provas e sua aplicação aos actos civis*. 2. ed. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos, 1917.

NORONHA, Edgar de Magalhães. *Direito penal*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1965. vol. 4.

NOVAIS, Jorge Reis. *As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela*

Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 2003.

PASSANANTE, Luca. Processo civile inglese. *Enciclopedia del Diritto*, Annali III. Milano: Giuffrè.

PATTI, Salvatore. *Prove – Disposizioni generali*. Bologna/Roma: Zanichelli – Il Foro Italiano, 1987.

PAULA, Alexandre de. *Código de Processo Civil anotado*. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 1992. vol. 2.

_____. _____. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 1992. vol. 4.

_____. *O processo civil à luz da jurisprudência*. Rio de Janeiro: Forense, 1982. vol. 4.

_____. _____. Rio de Janeiro: Forense, 1983. vol. 5.

PEREIRA, Luis Cezar Ramos. A prova do direito estrangeiro e sua aplicabilidade. *RePro*. n. 39. São Paulo: Ed. RT, 1985.

PERELMAN, Chaïm. *Retóricas*. Trad. Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

_____. *Lógica jurídica*. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do direito civil – Introdução ao direito civil constitucional*. 3. ed. Trad. Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

PICARDI, Nicola. I processi speciali. *Rivista di Diritto Processuale*. 1982.

PIMENTEL, Wellington Moreira. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 1975.

PINTORE, Anna. *Il diritto senza verità*. Torino: Giappichelli, 1996.

PISANI, Mario. Intorno alla prova come argomentazione retorica. *Rivista di Diritto Civile*. n. 4. Padova: Cedam, 1959.

PLANIOL, Marcel. *Traité élémentaire de droit civil*. 4. ed. Paris: Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, 1906. vol. 1.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1974. t. IV.

_____. _____. Rio de Janeiro: Forense, 1977. t. XIII.

_____. _____. 4. ed. Atual. Sérgio Bermudes. Rio de Janeiro: Forense, 1995. t. I.

_____. _____. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996. t. IV e V.

_____. *Tratado da ação rescisória*. Campinas: Bookseller, 1998.

_____. *Tratado das ações*. São Paulo: Ed. RT, 1970. vol. 1.

_____. *Tratado das ações*. Atual. Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 1998. t. I e II.

_____. *Tratado de direito privado*. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954. t. IV.

_____. _____. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1963. t. XLIII.

_____. _____. Rio de Janeiro: Borsoi, 1966. t. LIII.

_____. _____. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970. t. IV.

- _____. _____. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970. t. I.
- _____; NEVES E CASTRO, Francisco Augusto das. *Theoria das provas e sua aplicação aos actos civis*. 2. ed. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos, 1917.
- PORTANOVA, Rui. *Motivações ideológicas da sentença*. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1994.
- PRIEUR, Michel. *Droit de l'environnement*. Paris: Dalloz, 1991.
- PROTO PISANI, Andrea. *Appunti sulla giustizia civile*. Bari: Cacucci, 1982.
- _____. Appunti sulla tutela sommaria (note *de iure conditio* e *de iure condendo*). *I processi special*. Studi offerti a Virgilio Andreoli dai suoi allievi. Napoli: Jovene, 1979.
- _____. Breve premessa a un corso sulla giustizia civile. *Appunti sulla giustizia civile*. Bari: Cacucci, 1982.
- _____. I rapporti fra diritto sostanziale e processo. *Appunti sulla giustizia civile*. Bari: Cacucci, 1982.
- _____. *La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela*. Foro italiano, 1990.
- _____. *Le controversie in materia di lavoro*. Bologna-Roma, 1987.
- _____. *Lezioni di diritto processuale civile*. Napoli: Jovene, 1994.
- _____. Sulla tutela giurisdizionale differenziata. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1980.
- PUNZI, Carmine; SATTA, Salvatore. *Diritto processuale civile*. 12. ed. Padova: Cedam, 1996.
- RABONEZE, Ricardo. *Provas obtidas por meios ilícitos*. São Paulo: Síntese, 1999.
- RAMOS, Vitor de Paula. *Ônus da prova no processo civil – do ônus ao dever de provar*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- RAMPAZZI, Gabriella. *Le riforme del processo civile* (a cura di Sergio Chiarloni). Bologna: Zanichelli, 1992.
- RANGEL, Rui Manuel de Freitas. *O ônus da prova no processo civil*. Coimbra: Almedina, 2002.
- RAPISARDA, Cristina. Inibitoria. *Digesto delle discipline privatistiche*. 1993. vol. 9.
- _____. Premesse allo studio della tutela civile preventiva. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1980.
- _____. *Profili della tutela civile inibitoria*. Padova: Cedam, 1987.
- REALE, Miguel. *Fontes e modelos do direito*. São Paulo: Saraiva, 1994.
- _____. *Revogação e anulamento do ato administrativo*. Rio de Janeiro: Forense, 1968.
- _____. *Verdade e conjectura*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983.
- REDENTI, Enrico. *Diritto processuale civile*. 4. ed. Milano: Giuffrè, 1997. vol. 2.
- REGO, Hermenegildo de Souza. Dever de sigilo e escusa de depor. *RePro*. n. 33. São Paulo: Ed. RT, 1984.

- REQUIÃO, Rubens. *Curso de direito comercial*. São Paulo: Saraiva, 1971.
- RICCI, Edoardo F. Il progetto Rognoni di riforma urgente del processo civile. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1987.
- _____. I provvedimenti interinali e cauteri. *La riforma del processo civile*. Milano: Giuffrè, 1991.
- RIGHI, Ivan. Eficácia probatória do comportamento das partes. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná*. n. 20. 1981/1982.
- RINCÓN, Jorge Carreras del. *Comentarios a la doctrina procesal civil del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo*. Madrid: Marcial Pons, 2002.
- RODRIGUES, Silvio. *Dos defeitos dos atos jurídicos*. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, [s.d.]. vol. 1.
- ROSENBERG, Leo. *Die Beweislast auf der Grundlage des Bürgerlichen Gesetzbuchs und der Zivilprozessordnung*. 5. ed. München: Beck, 1965.
- _____. *La carga de la prueba*. Trad. E. Krotoschin. Buenos Aires: Ejea, 1956.
- _____. *Tratado de derecho procesal civil*. Buenos Aires: Ejea, 1995. vol. 2.
- _____; SCHWAB, Karl Heinz. *Zivilprozessrecht*. München: Beck, 1986.
- _____; _____. GOTTWALD, Peter. *Zivilproßrecht*. 15. ed. München: Verlag C.H. Beck, 1993.
- ROSENBERG, Maurice. Collateral estoppel in New York. *St. John's Law Review*, 1969, v. 44.
- _____. Developments in the Law-Res Judicata, *Harvard Law Review*, 1952, v. 65.
- _____. Note, Collateral estoppel by judgment, *Columbia Law Review*, 1952, v. 52.
- _____. Collateral estoppel in default judgments: the case for abolition, *Columbia Law Review*, 1970, v. 70.
- SALAVERRÍA, Juan Igartua. *La motivación de las sentencias, imperativo constitucional*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003.
- SALETTI, Achille. La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 247 cod. proc. civ.: prospettive e problemi. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1975.
- SANSEVERINO, Milton. Recurso cabível no incidente de falsidade documental. *RePro*. n. 24. São Paulo: Ed. RT, 1981.
- SANTO, Víctor de. *La prueba judicial, teoría y práctica*. 2. ed. Buenos Aires: Editorial Universidad, 1994.
- SANTOS, João Manuel de Carvalho. *Código civil brasileiro interpretado*. 10. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1977. vol. 2.
- _____. *Código Civil brasileiro interpretado*. 11. ed. São Paulo: Freitas Bastos, 1980. vol. 3.
- SATTA, Salvatore; PUNZI, Carmine. *Diritto processuale civile*. 12. ed. Padova: Cedam, 1996.
- SCARSELLI, Giuliano. *La condanna con riserva*. Milano: Giuffrè, 1989.
- SCHÖNKE, Adolf. *Derecho procesal civil*. Barcelona: Bosch, 1950.
- SCHWAB, Karl Heinz; ROSENBERG, Leo. *Zivilprozessrecht*. München: Beck, 1986.

- _____.; GOTTWALD, Peter; ROSENBERG, Leo. *Zivilproßrecht*. 15. ed. München: Verlag C.H. Beck, 1993.
- SHAPIRO, David. *Preclusion in civil actions*. New York: Foundation Press, 2001.
- SICHES, Luis Recaséns. *Introducción al estudio del derecho*. México: Porruá, 1996.
- SILVA, Beclaute Oliveira. Verdade como objeto do negócio jurídico processual. In: *Negócios Processuais*, Salvador: JusPodium, 2017.
- SILVA, Francisco de Assis Vasconcellos Pereira da. Indeferimento liminar de incidente de falsidade – Recurso cabível. *RePro*. n. 9. São Paulo: Ed. RT, 1978.
- SILVA, José Casado. Considerações sobre a prova documental. *Revista Forense*. vol. 289. Rio de Janeiro: Forense.
- SILVA, Ovídio A. Baptista da. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2000. vol. 1.
- _____. _____. São Paulo: Ed. RT, 2000. vol. 13.
- _____. *Curso de processo civil*. Porto Alegre: Fabris, 1993. vol. 3.
- _____. _____. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 1998. vol. 1.
- _____. *Do processo cautelar*. Rio de Janeiro: Forense, 1996.
- _____. _____. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.
- _____. *Procedimentos especiais* (Exegese do Código de Processo Civil). Rio de Janeiro: Aide, 1989.
- _____. *Sentença e coisa julgada*. 2. ed. Porto Alegre: Fabris, 1988.
- _____. Tutela antecipatória e juízos de verossimilhança. In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). *O processo civil contemporâneo*. Curitiba: Juruá, 1994.
- SILVESTRI, Gaetano. Le Corti Supreme negli ordinamenti costituzionali contemporanei. *Le Corti Supreme*. Milano: Giuffrè, 2001.
- SIMAS, Hugo. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 2. ed. atual. João Vicente Campos. Rio de Janeiro: Forense, 1962. vol. 8, t. II.
- SMIT, Hans. Constitutional guarantees in civil litigation in the United States of America. In: CAPPELETTI, Mauro; TALLON, Denis (coords.). *Fundamental guarantees of the parties in civil litigation*. Milano: Giuffrè, 1973.
- SOARES, Fernando Luso; BRITO, Wanda Ferraz de; MESQUITA, Duarte Romeira. *Código de Processo Civil atualizado e anotado*. Coimbra: Almedina, 1994.
- SPOLIDORO, Marco Saverio. *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*. Milano: Giuffrè, 1982.
- STEFANO, Franco de. *L'istruzione della causa nel nuovo processo civile*. Padova: Cedam, 1999.
- STEIN, Friedrich. *El conocimiento privado del juez*. Trad. Andrés de la Oliva Santos. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 1990.
- STUMM, Raquel Denize. *Princípio da proporcionalidade no direito constitucional brasileiro*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1995.
- SURGIK, Aloísio. *Lineamentos do processo civil romano*. Curitiba: Livro é Cultura, 1990.

- SWEDBERG, Richard. *Max Weber e a ideia de sociologia econômica*. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2005.
- SZANIAWSKI, Elimar. *Direitos da personalidade e sua tutela*. São Paulo: Ed. RT, 1993.
- TÁCITO, Caio. Mandado de segurança preventivo. *Revista de Direito Administrativo*. n. 61. Rio de Janeiro: FGV, 1960.
- TALAMINI, Eduardo. Pré-constituição da prova. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coords.). *Comentários ao novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- TALLON, Denis; CAPPELETTI, Mauro (coord.). *Fundamental guarantees of the parties in civil litigation*. Milano: Giuffrè, 1973.
- TARELLO, Giovanni. *L'interpretazione della legge*. Milano: Giuffrè, 1980.
- TARTUCE, Fernanda. *Igualdade e vulnerabilidade no processo civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2012.
- TARUFFO, Michele. *Cinco lecciones mexicanas*. México: Escuela Judicial Electoral, 2003.
- _____. Contro la veriphobia. Osservazioni sparse in risposta a Bruno Cavallone. *Rivista di Diritto Processuale*. n. 5. Padova: Cedam, set./out. 2010.
- _____. Funzione della prova: la funzione dimostrativa. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1997.
- _____. Idee per una teoria della decisione giusta. Sui confini – Scritti sulla giustizia civile, Bologna: Il Mulino, 2002.
- _____. *Il controllo di razionalità della decisione fra logica, retorica e dialettica*. Disponível em: [http://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/86679]. Também disponível em *RePro*, v. 32, n. 143, jan. 2007.
- _____. Il giudizio prognostico del giudice tra scienza privata e prova scientifica In: _____. *Sui Confini* – Scritti sulla giustizia civile. Bologna: Il Mulino, 2002.
- _____. La motivazione della sentenza. *Revista de Direito Processual Civil*. vol. 31. Gênese.
- _____. *La motivazione della sentenza civile*. Padova: Cedam, 1975.
- _____. *La semplice verità* – il giudice e la costruzione dei fatti. Bari: Laterza, 2009.
- _____. *La prova dei fatti giuridici, nozioni generali*. Milano: Giuffrè, 1992.
- _____. Presunzioni, inversioni, prova del fatto. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Milano: Giuffrè, 1992.
- _____. *Senso comum, experiência e ciência no raciocínio do juiz*. Conferência, Curitiba, Universidade Federal do Paraná, mar. 2001.
- _____. Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Milano: Giuffrè, 2001.
- _____. *Studi sulla rilevanza della prova*. Padova: Cedam, 1970.
- _____. Verità negoziata? *Accordi di parte e processo*. Milano: Giuffrè, 2008.
- _____; COMOGLIO, Luigi Paolo; FERRI, Corrado. *Lezioni sul processo civile*. 2. ed. Bologna: Il Mulino, 1998.
- _____; HAZARD JR., Geoffrey C. *American civil procedure – An introduction*. New Haven: Yale

University Press, 1993.

____; MICHELI, Gian Antonio. A prova. *RePro*. n. 16. São Paulo: Ed. RT, 1979.

TARZIA, Giuseppe. *Lineamenti del nuovo processo civile*. Milano: Giuffrè, 1991.

____. *Lineamenti del processo di cognizione*. Milano: Giuffrè, 1991.

____. *Manuale del processo del lavoro*. Milano: Giuffrè, 1999.

TAYLOR, David H., CLIFFE, Sara M. Civil procedure by contract: a convoluted confluence of private contract and public procedure in need of congressional control. *University of Richmond Law Review*, v. 35, 2002.

TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. *Código de Processo Civil anotado*. São Paulo: Saraiva, 1989.

____. *Código de Processo Civil anotado*. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1992.

TESSLER, Luciane. *Tutelas jurisdicionais do meio ambiente: inibitória, de remoção do ilícito e do ressarcimento na forma específica*. São Paulo: Ed. RT, 2004.

The Harvard Law Review Association. Contracts to Alter the Rules of Evidence. *Harvard Law Review*, v. 46, 1932.

THEODORO JÚNIOR. Humberto. Ação declaratória e incidente de falsidade: falso ideológico e intervenção de terceiros. *RePro*. n. 51. São Paulo: Ed. RT, 1988.

____. *Comentários ao novo Código Civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. vol. 3, t. II.

____. *Processo de conhecimento*. Rio de Janeiro: Forense, 1948.

THORNBURG, Elizabeth. Designer trials. *Journal of Dispute Resolution*, 2006, n. 1

TISCINI, Roberta. *I nova del procedimento cautelare societário: la cd. strumentalità attenuata e il cd. giudizio abbreviato*. Disponível em: [www.judicium.it/news/ins 22 12 03/cautelare.html].

TOMMASEO, Ferruccio. Intervento. In: TARZIA, Giuseppe (coord.) *Les mesures provisoires en procédure civile*. Milano: Giuffrè, 1985.

TREIBER, Hubert. "Elective affinities" between Weber's sociology of religion and sociology of law. *Theory and Society*, n. 14.

TROCKER, Nicolò. *Processo civile e costituzione*. Milano: Giuffrè, 1974.

TRUBECK, David M. Max Weber on law and the rise of capitalism. *Wisconsin Law Review*, 1972.

TUCCI, Rogério Lauria. Confissão (Direito Processual Civil – 2). *Enciclopédia Saraiva do Direito*. vol. 18.

TWINING, William. *Rethinking evidence – Exploratory essays*. Evanston: Northwestern University Press, 1994.

____. *Theories of evidence: Bentham & Wigmore*. Stanford: Stanford University Press, 1985.

URRACA, José Rodríguez. Las facultades probatorias del juez en el Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica. In: SCHIPANI, Sandro; VACCARELLA, Romano (coord.). *Un "codice tipo" di procedura civile per l'America Latina*. Padova: Cedam, 1990.

VARGAS, Abraham L. *Estudios de derecho processal*. Mendoza: Ediciones Jurídicas Cuyo, 1999. t. I.

- VASCONCELOS, Antônio Vital Ramos de. Requisição de informações à Receita Federal. *Revista de Direito Administrativo*. n. 181-182. Rio de Janeiro: Renovar, 1990.
- VELLOSO, Carlos Mário. Direito líquido e certo, decadência. *Mandado de Segurança*. Porto Alegre: Fabris e IAB, 1986.
- VERDE, Giovanni. Poteri del giudice e poteri delle parti. In: SCHIPANI, Sandro; VACCARELLA, Romano (coords.) *Un "codice tipo" di procedura civile per l'America Latina*. Padova: Cedam, 1990.
- _____. Prova (diritto processuale civile). *Enciclopedia del diritto*. Milano: Giuffrè, 1988. vol. 37.
- _____. *Garanzie costituzionali del processo civile*. Milano: Giuffrè, 1973.
- _____. *L'onere della prova nel processo civile*. Napoli: Jovene, 1974.
- VESTAL, Allan D. *Res Judicata : Preclusion*. New York: Matthew Bender, 1969.
- VIGORITI, Vincenzo. Prove illecite e costituzione. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1968.
- VILLEY, Michel. *La formation de la pensée juridique moderne*. 4. ed. Paris: Dalloz, 1975.
- _____. *Philosophie du droit, II. Les moyens du droit*. 2. ed. Paris: Dalloz, 1984.
- _____. *Réflexions sur la philosophie et le droit, les carnets*. Paris: PUF, 1995.
- VOCINO, Corrado. L'opposizione di terzo contro la sentenza dichiarativa di falso. *Rivista di Diritto Processuale*. vol. 2. Padova: Cedam, 1947.
- VOLTAIRE. Vérités historiques & histoire: certitude de l'histoire. *Dictionnaire philosophique*. Ed. Beuchot, [s.d.].
- VON TUHR, Andreas. *Derecho civil, teoría general del derecho civil alemán*. Buenos Aires: Depalma, 1948. vol. 3.
- WALTER, Gerhard. *Libre apreciación de la prueba*. Bogotá: Themis, 1985.
- WAMBIER, Luiz Rodrigues; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. *Breves comentários à 2ª fase da reforma do Código de Processo Civil*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2002.
- WATANABE, Kazuo. *Da cognição no processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 1987.
- _____. et alli. *Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991.
- WEBER, Max. *A ética protestante e o "espírito" do capitalismo*, São Paulo: Cia. das Letras, 2004.
- _____. *A gênese do capitalismo moderno*. São Paulo: Ática, 2006.
- _____. *Economia e sociedade*. Brasília: UnB. v. 2.
- WELZEL, Hans. *Das deutsche Strafrecht*. 11. ed. Berlim: Walter de Gruyter, 1969.
- WIEACKER, Franz. *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1967.
- WROBLEWSKI, Jerzy. Legal syllogism and rationality of judicial decision. *Rechtstheorie*. Berlin: Duncker & Humblot, 1974. v. 5, parte 1.
- _____. *Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*. Madrid: Civitas, 2001.

YARSHELL, Flávio Luiz. *Tutela jurisdicional específica nas obrigações de declaração de vontade*. São Paulo: Malheiros, 1993.

ZACCARIA, Giuseppe. Complessità della ragione giuridica. *Questioni di interpretazione*. Padova: Cedam, 1996.

ZEISS, Walter. Die Verwertung rechtswidrig erlangter Beweismittel. *ZZP*. N. 89. 1976.

ZUCKERMAN, Adrian. Adjudication of civil dispute: a mimanaged public service. *Accordi di parte e processo*. Milano: Giuffrè, 2008.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. VI - Marinoni - Ed. 2018

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO

(os números em negrito referem-se aos capítulos da Parte I e aos artigos (369 a 380) do CPC, que estão na Parte II. Os números que seguem o número do Capítulo ou do artigo dizem respeito aos itens relativos aos capítulos e artigos)

A

Ações de abstenção, 7, 7.2

Action préventive (direito francês), 7.6.1

Agir comunicativo (teoria do), 2, 2.9

Alegação do direito, 4

Apelação, 370, 3

Aplicação das regras sobre prova no espaço, 3

Aplicação das regras sobre prova no tempo, 3

Audiência, 5

C

Carta precatória, 377

– e carta rogatória concedida sem efeito suspensivo, 377, 1

– e carta rogatória não devolvida dentro do prazo, 377, 2

Carta rogatória, 377

Certeza, 2, 2.4, 2.7.

Código de Defesa do Consumidor e ônus da prova, 8, 8.9, 373, 22, 23.

Coerência lógica, 8, 8.15, 8.16; 371, 16; 373, 23

Coerência narrativa, 8, 8.15; 371, 16

Cognição, 7, 7.6.3, 9, 9.4

Coação, 393, 3 e 6

– coação física, 393, 6

– coação moral, 393, 6

– v. tb. confissão (obtida com vício do consentimento)

Coisa julgada, 2, 2, 8; 373, 6, 10; 393, 8; Seção VII, 9; Subseção II, 2; 430, 1, 2; 432, 4, 6; 433, 1, 2 e 3

– *secundum eventum litis*, 2, 2

Colaboração com a justiça, 2, 2.6

Colaboração com o Poder Judiciário, 2, 2.6

Comportamento da parte e ônus da prova, 7, 7.6.3, **10**

Conduta da parte como prova, **10**

Confissão

– e dispensa de prova, 8, 8.19; 374, 3

– e presunção de veracidade, 8, 8.19

– eficácia da, 8, 8.19

– valor da, 8, 8.19

Congruência de decisão, 8, 8.16

Convenção sobre o ônus da prova, 9, 9.1

– e acordos processuais, 9, 9.1.

– e direito indisponível, 9, 9.1; 373, 25.

– que torna excessivamente difícil o exercício do direito, 9, 9.2; 373, 26

Convencimento judicial (v. Convicção)

– e verdade material, 2, 2.2

– e legitimidade da decisão, 2, 2.6

Convicção, 8, 8.2, 8.4

Costume, 376, 4

Credibilidade da prova, , 6, 6.2; 8, 8.10; 369, 14; 371, 15, 16

Culpa, 7, 7.2; 8, 8.1; 371, 6; 373, 22; 374, 4.1; 398, 3; 428, 3; 466, 1

– e ação inibitória, 7, 7.2.

D

Depoimento pessoal, 6, 6.2, 6.3

– e objeto da prova, 6, 6.2

Depoimento testemunhal, 6, 6.2, 6.3

Descontaminação do julgado, 369, 15

Dever da parte, 9, 9.2, 9.4; 379, 1, 2 e 3

– e negócios processuais, 9, 9.2, 9.4

Dever de colaborar com o Judiciário, 2, 2.6; 378, 1

– exclusão, 378, 2

Dever de colaboração com o juízo e dever de lealdade processual, 2, 2.6, 7, 7.6.3; 378, 3

Dever de prestar em audiência, 6, 6.2, 6.3

– exceções à regra de prestar depoimento em audiência, 5

Dever de contestar na forma específica, 374, 4.1

Dever de sigilo, 378, 2

Dever de veracidade, 2, 2.8; 379, 3

Dever do réu se manifestar sobre os fatos, 8, 8.19; 378, 3

Dever do terceiro, 380, 1

– e contraditório, 380, 3

Direito consuetudinário, 4; 376, 4

Direito estadual, 4; 376, 3

Direito estrangeiro, 4; 376, 3

Direito indisponível, 9, 9.2; 373, 24

Direito municipal, 4; 376, 3.

Direito à prova, 8, 8.10; 373, 8

E

Excessiva dificuldade para demonstração do direito, 7, 7.5; 373, 20

Exceções do dever de prestar depoimento em audiência, 5

Exibição (de documento ou coisa), 5; 378 e 380

F

Fato constitutivo, 6, 6.9; 373, 3

Fato direto, 6, 6.1; 373, 3

Fato extintivo, 6, 6.9; 373, 3

Fato impeditivo, 6, 6.9; 373, 3

Fato indireto, 6, 6.1; 373, 3

Fato modificativo, 6, 6.9; 373, 3

Fato notório, 6, 6.8; 373, 3

Fé pública, 405, 1; 405, 3; 427, 1

H

Hipossuficiência, 8, 8.9; 373, 22

I

Ilicitude da prova, , 8, 8.18

- contaminação das provas vinculadas à ilícita, 369, 12
- descobrimento inevitável, 369, 13
- descobrimento provavelmente independente, 13
- exceções à teoria dos frutos da árvore envenenada, 369, 13
- e Constituição Federal, 369, 8 e 9
- e natureza do direito violado, 369, 3
- e princípio da proporcionalidade, 369, 11
- e qualidade do violador, 369, 3
- e teoria da desconsideração do julgado, 369, 15
- e teoria dos frutos da árvore envenenada, 369, 12
- gravidade da violação, 369, 6 e 7
- no plano do direito material, 369, 4
- no plano do direito processual, 369, 5
- no processo penal e no processo civil (distinção), 369, 10

Impossibilidade de comparecer à audiência, 5

Impossibilidade de depor como testemunha, 8, 8.10; 378, 2

Indício

- conceito, 6, 6.3
- distinção de prova indiciária, raciocínio presuntivo e presunção, 6, 6.3
- e prova da ameaça, 7, 7.6

Injunction, 7, 7.5

Inversão do ônus da prova

- e estado de dúvida ao decidir, 373, 9
- e posse do meio de prova, 373, 16
- e recusa à perícia médica, 373, 17
- inversão voluntária unilateral do ônus da prova, 373, 24
- na audiência preliminar, 373, 22
- no Código de Defesa do Consumidor, 373, 22
- pericial, 373, 15

- possibilidade de tratamento diferenciado pelo juiz na ausência de lei, 373, 19
- situações em que o direito material requer, 373, 21

Interdito proibitório, 7, 7.4

- v. tb. Prova (no interdito proibitório)

Inversão do ônus da prova, 6, 6.9, 8, 8.9

- e estado de dúvida ao decidir, 6, 6.9, 8, 8.9
- e posse do meio de prova, 8, 8.9
- e recusa à perícia médica, 8, 8.9. 8.14.
- no Código de Defesa do Consumidor, 8, 8.9
- pericial, 8, 8.9
- possibilidade de tratamento diferenciado pelo juiz na ausência de lei, 8, 8.9
- situações em que o direito material requer, 8, 8.9

J

Juízo

- e presunção, 6, 6.3 e 6.4
- final, 6, 6.5
- instrumental, 6, 6.6
- provisório, 6, 6.5
- sobre o mérito, 6, 6.5, 6.6 e 6.7

L

Local da produção da prova, 3, 3.2, 5

M

Mandado de segurança, 7, 7.4

Módulo de prova, *ver redução das exigências de prova*

Momento da produção da prova, 3, 3.2, 5

Motivação, 8, 8.2.

- da prova indiciária, 8, 8.11
- e prova, 8, 8.2
- e qualificação jurídica dos fatos, 8, 8.2

N

Não-contestação, 6, 6.9, 8, 8.19

Não-contestação e revelia, 8, 8.19

Normas de juízo, 6, 6.7

O

Ônus da prova, 6, 6.9; 8, 8.1, 8.8, 8.9, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 373, 1

– como regra de julgamento, 2, 2; 373, 2

– como regra dirigida à parte, 373, 1

– dúvida e dever de decidir, 373, 9

– e as diversas situações de direito material, 373, 19 e 20

– e audiência preliminar, 373, 7

– e comportamento da parte, 373, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18

– e convenção sobre o ônus da prova, 373, 25 e 26,

– e convicção, 373, 23

– e direito de produzir a prova, 373, 8

– e determinação da prova de ofício, 373, 11

– e dúvida, 373, 9 e 10

– e fixação dos pontos controvertidos, 373, 7

– e inversão voluntária unilateral, (do ônus da prova), 373, 24

– e motivação, 373, 23

– e posse do documento sobre o qual vai recair a prova documental ou pericial, 373, 12, 13, 14, 15 e 16

– e presunções relativas, 6, 6.9

– e prova de ofício, 373, 11

– e recusa à perícia médica, 373, 17

– e risco na não produção de provas, 373, 2

– inversão, 373, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24

– em ação declaratória negativa, 373, 6

– no Código de Defesa do Consumidor, 373, 22

– como regra de julgamento, 2, 2

– como regra dirigida à parte, 8, 8.9

– dúvida e dever de decidir, 8, 8.9

– e as diversas situações de direito material, 8, 8.9

– e comportamento da parte, 8, 8.9

- e convenção sobre o ônus da prova, 9, 9.1
- e direito de produzir a prova, 8, 8.9; 8.12
- e dúvida, 8, 8.9
- e fixação dos pontos controvertidos, 8, 8.9
- e presunções relativas, 6, 6.9
- e recusa à perícia médica, 8; 8.9; 8.14
- inversão, 6, 6.9, 8, 8.9
- no Código de Defesa do Consumidor, 8, 8.9

P

Paradigma

- do ser, v. ser (paradigma do)
- do sujeito, v. sujeito (paradigma do)
- do agir comunicativo, v. teoria do agir comunicativo

Presunção, 6, 10

- conceito, 6, 6.8
- conflito entre presunções, 6, 6.10
- e fato notório, 6, 6.8
- ficção, 8, 8.7
- e indício, 6, 6.3
- e juízo, 6, 6.4
- prova indiciária, 6, 6.3, **10**
- e conduta dos sujeitos processuais, **10**
- e raciocínio presuntivo, 6, 6.3
- e regra de experiência, 6, 6.8
- presunção legal de existência ou de veracidade, 374, 5
- e ônus da prova, v. ônus da prova
- presunções legais absolutas, 6, 6.9
- presunção judicial, 6, 6.9, **10**
- presunções legais relativas, 6, 6.9
- presunções legais simples, v. presunções legais relativas

Princípio *iura novit curia*, 4

Procedimento monitorio, 8, 8.5

Procedimento probatório

– fases, 5

Proporcionalidade, 369, 11

Prova

– aplicação das regras sobre prova no espaço, 3

– aplicação das regras sobre prova no tempo, 3

– atípica, 10, 369

– começo de prova escrita, 8, 8.12

– credibilidade da, 6, 6.10; 8, 8.10

– da ameaça, 7, 7.4, 7.5 e 7.6

– definição, 2

– direta, 6, 6.2

– do direito líquido e certo, 7, 7.4

– do direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, 4

– escrita, 8, 8.12

– finalidade, 2, 9

– ilícita, (ver ilicitude da prova)

– impossibilidade do seu reexame diante dos recursos especial e extraordinário, 8

– incompatível com determinado procedimento, 8, 8.4

– indiciária, 6, 6.3

– indireta, 6, 6.2

– na ação inibitória, 7

– no interdito proibitório, 7, 7.4

– no mandado de segurança preventivo, 7, 7.4

– no procedimento monitorio, 8, 8.5

– prova impossível, 7, 7.3 e 7.6.3

– redução do módulo da prova (ver redução das exigências de prova)

– requerimento da, 5

– valoração, 5; 7, 7.5

R

Raciocínio decisório, 7, 7.6; 7.11

Raciocínio justificativo, 7, 7.6; 7.11

Raciocínio presuntivo, 6, 6.3

Raciocínio probatório, 6, 6.3; 7, 7.6; 7.11; 370, 15

Redução das exigências de prova, 7, 7.6, 8, 8.8, 8.9

– e efetividade do processo, 8, 8.8

– e direito material, 8, 8.8

Redução do módulo de prova, (v. redução das exigências de prova)

Regra de experiência,

– controle da aplicação das regras de experiência, 8, 8.11; 375, 3

– e costume, 8, 8.11

– e presunção, 6, 6.8

– e fato notório, 6, 6.8

– regra de experiência comum, 375, 1, 2, 4 e 5

– regra de experiência técnica, 375, 1, 5 e 6

Regra de experiência,

– controle da aplicação das regras de experiência, 375, 3; 375, 4

Revelia

– não-contestação e revelia, 5, 8, 8.19; 374, 4

S

Ser (paradigma do), 2, 1 e 5

Sujeito (paradigma do), 2, 4 e 5

Suspensão do processo, 9, 9.1

T

Teoria do agir comunicativo, 2, 9

Tutela inibitória,

– e culpa, 7, 7.2

– e dano, 7, 7.2

– e ameaça, 7, 7.3

– e ilicitude, 7, 7.3

V

Valoração da prova, 6, 6.9, 8, 8.17; 371, 1, 2, 16

– valoração individual, 6, 6.9, 8, 8.17; 371, 11 e 16

– valoração conjunta, 6, 6.9, 8, 8.17

– valoração da prova pericial, , 8.14

– valoração da prova emprestada, 372, 1

– valoração da prova pericial, 373, 13

Verdade,

– busca da verdade e convicção de verdade, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

– construção da verdade processual, 2, 2.1, 2.2; 371, 16

– e procedimento, 2, 2.6

– verdade factível, 2, 2.4, 2.6 e 2.7

– verdade formal, 2, 2.3

– verdade substancial, 2, 2.2 e 2.3

– e procedimento, 371, 16

– e retórica, 2, 2.5, 2.6 e 2.9; 371, 15

– e tópica, 2, 2.5 e 2.6

Verossimilhança, 2, 2.4 e 2.6; 371, 3, 4, 7, 373, 1, 397, 3

– e possibilidade, 2, 2.6

– e probabilidade, 2, 2.6

– preponderante, 6, 6.9; 371, 3, 373, 23

– da alegação (CDC), 8, 8.9

– preponderante, 373, 10; 373, 22; 373, 23

– da alegação (CDC), 373, 22, 23